

CAIO BARTINE

MANUAL *de* PRÁTICA TRIBUTÁRIA

OAB • PROVAS
INDICADO
CONCURSOS



Com **vídeos**
das principais
alterações da
matéria

6^a
edição

revista e
atualizada



MANUAL de PRÁTICA TRIBUTÁRIA



O GEN | Grupo Editorial Nacional – maior plataforma editorial brasileira no segmento científico, técnico e profissional – publica conteúdos nas áreas de concursos, ciências jurídicas, humanas, exatas, da saúde e sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados à educação continuada.

As editoras que integram o GEN, das mais respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade e seriedade.

A missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informação científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao crescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.

CAIO BARTINE

MANUAL de PRÁTICA TRIBUTÁRIA

6^a
edição revista e
atualizada



- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.
- Nas obras em que há material suplementar *on-line*, o acesso a esse material será disponibilizado somente durante a vigência da respectiva edição. Não obstante, a editora poderá franquear o acesso a ele por mais uma edição.
- Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2020 by

EDITORA FORENSE LTDA

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Rua Conselheiro Nébias, 1384 – Campos Elíseos – 01203-904 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-0770 / (21) 3543-0770

faleconosco@grupogen.com.br / www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).
Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).
- Capa: Aurélio Corrêa
Produção digital: Geethik
- Data de fechamento: 29.06.2019
- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

Bartine, Caio

Manual de prática tributária / Caio Bartine. – 6. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODOS, 2020.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-309-8782-4

1. Direito tributário – Brasil. I. Título.

19-59251

CDU: 34:351.713(81)

Vanessa Mafra Xavier Salgado – Bibliotecária – CRB-7/6644

APRESENTAÇÃO

Este *Manual de Prática Tributária* não tem o papel de esgotar as grandes discussões processuais em matéria tributária, mas sim conferir aos estudantes e operadores que militam com o direito processual tributário, seja administrativo ou judicial, as noções basilares para sua atuação.

Para tanto, a obra passa a ser fracionada de modo a abarcar o processo judicial em matéria tributária, desde as medidas judiciais de iniciativa do Estado – *in casu*, por meio da Ação de Execução Fiscal e da Medida Cautelar Fiscal –, bem como as medidas protetivas que o cidadão contribuinte faz jus para evitar os gritantes abusos perpetrados pelo Estado, seja medidas utilizadas antes do lançamento fiscal, após o seu lançamento ou no curso do processo executivo fiscal.

Não se poderia deixar de lado a tratativa dos recursos processuais, insculpidos a partir do art. 994 do Código de Processo Civil, tanto recursos para o segundo grau, como também para as instâncias superiores.

As tratativas do processo administrativo fiscal mereceram sua participação nesta singela obra, sendo instrumento eficaz para importantes discussões no âmbito administrativo, observando o regramento geral do Decreto 70.235/1972, que trata da regra geral do processo administrativo fiscal.

Os estudos dos impostos ordinários em espécie mostram-se fundamentais para defesa dos interesses do contribuinte e têm destaque importante nesta obra, seja na determinação do regramento de incidência tributária, seja na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Por fim, para auxiliar aqueles que estão iniciando os estudos para o ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a inserção dos modelos de petições e recursos são apresentados, bem como as provas anteriores dos exames unificados, administrados pela FGV, garantindo uma boa base para a realização da prova de segunda fase na disciplina de direito tributário.

Espero que este material possa, de forma efetiva, auxiliá-lo(a) no melhor desenvolvimento dos estudos dessa disciplina de suma importância atualmente.

Bons estudos!
Caio Bartine

NOTA À 6ª EDIÇÃO

Esta edição trouxe modificações substanciais nos impostos em espécie, com o advento do novo regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), inserção de novas súmulas do Superior Tribunal de Justiça com importantes reflexos no campo tributário e com a mudança jurisprudencial significativa.

Caio Bartine

SUMÁRIO

PRIMEIRA PARTE PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO

INTRODUÇÃO

1. DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AO PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO

- 1.1 Modelo de apresentação com técnica processual forense
- 1.2 Competência processual
 - 1.2.1 Competência processual de segundo grau
 - 1.2.2 Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
 - 1.2.3 Situações excepcionais de competência processual
- 1.3 Qualificação das partes
 - 1.3.1 Qualificação da pessoa física como sujeito ativo (autor)
 - 1.3.2 Qualificação da pessoa jurídica como sujeito ativo (autora)
 - 1.3.3 Qualificação da pessoa jurídica de direito público interno
- 1.4 Exposição dos fatos
- 1.5 Dos fundamentos de direito
- 1.6 Do pedido
- 1.7 Da produção de provas
- 1.8 Valor da causa
- 1.9 Liminares e antecipação de tutela
 - 1.9.1 Requisitos para a concessão de liminar
 - 1.9.2 Requisitos para a concessão de tutela provisória
 - 1.9.3 Concessão de depósito do montante integral

2. MEDIDAS JUDICIAIS DE INICIATIVA DA FAZENDA PÚBLICA

- 2.1 Medida cautelar fiscal
 - 2.1.1 Modelo de medida cautelar fiscal
- 2.2 Execução fiscal
 - 2.2.1 Homologação de decisões estrangeiras em execução fiscal
 - 2.2.2 Modelo de execução fiscal

3. MEDIDAS JUDICIAIS DE INICIATIVA DO SUJEITO PASSIVO

- 3.1 Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
 - 3.1.1 Principais características
 - 3.1.2 Cabimento
 - 3.1.3 Competência
 - 3.1.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada
 - 3.1.5 Pedido
 - 3.1.6 Das provas e valor da causa
 - 3.1.7 Desfecho
 - 3.1.8 Modelo de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória antecipada de urgência
- 3.2 Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com repetição de indébito fiscal
 - 3.2.1 Principais características
 - 3.2.2 Cabimento
 - 3.2.3 Competência
 - 3.2.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada
 - 3.2.5 Pedido
 - 3.2.6 Das provas e valor da causa
 - 3.2.7 Desfecho
 - 3.2.8 Modelo de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência
- 3.3 Ação anulatória de débito fiscal
 - 3.3.1 Principais características
 - 3.3.2 Cabimento
 - 3.3.3 Competência
 - 3.3.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada
 - 3.3.5 Pedido
 - 3.3.6 Das provas e valor da causa
 - 3.3.7 Desfecho
 - 3.3.8 Modelo de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência
- 3.4 Ação anulatória de decisão administrativa com repetição de indébito fiscal ou compensação de tributos
 - 3.4.1 Principais características
 - 3.4.2 Cabimento

- 3.4.3 Competência
- 3.4.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada
- 3.4.5 Pedido
- 3.4.6 Das provas e valor da causa
- 3.4.7 Desfecho
- 3.4.8 Modelo de ação anulatória de decisão administrativa cumulada com repetição de indébito fiscal
- 3.5 Ação de repetição do indébito fiscal
 - 3.5.1 Principais características
 - 3.5.2 Cabimento
 - 3.5.3 Competência
 - 3.5.4 Restituição de tributos indiretos
 - 3.5.5 Fundamento da ação e nomenclatura adequada
 - 3.5.6 Pedido
 - 3.5.7 Das provas e valor da causa
 - 3.5.8 Desfecho
 - 3.5.9 Modelo de ação de repetição de indébito fiscal
- 3.6 Ação de consignação em pagamento
 - 3.6.1 Principais características
 - 3.6.2 Cabimento
 - 3.6.3 Competência
 - 3.6.4 Fundamento da ação e nomenclatura adequada
 - 3.6.5 Pedido
 - 3.6.6 Das provas e valor da causa
 - 3.6.7 Desfecho
 - 3.6.8 Modelo de ação de consignação em pagamento
- 3.7 Mandado de segurança
 - 3.7.1 Principais características
 - 3.7.2 Fundamento da ação e nomenclatura adotada
 - 3.7.3 Cabimento e legitimidade
 - 3.7.4 Autoridade coatora e sua determinação
 - 3.7.5 Liminar no Mandado de Segurança
 - 3.7.6 Competência
 - 3.7.7 Notificação da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público
 - 3.7.8 Pedido

- 3.7.9 Valor da causa
- 3.7.10 Desfecho
- 3.7.11 Demais considerações relevantes
- 3.7.12 Modelo de Mandado de Segurança com pedido de liminar
- 3.8 Embargos à execução fiscal
 - 3.8.1 Principais características
 - 3.8.2 Cabimento
 - 3.8.3 Competência
 - 3.8.4 Fundamento da ação e nomenclatura adequada
 - 3.8.5 Pedido
 - 3.8.6 Das provas e valor da causa
 - 3.8.7 Desfecho
 - 3.8.8 Modelo de embargos à execução fiscal
- 3.9 Exceção de pré-executividade
 - 3.9.1 Principais características
 - 3.9.2 Cabimento
 - 3.9.3 Competência
 - 3.9.4 Fundamento da ação e nomenclatura adequada
 - 3.9.5 Pedido
 - 3.9.6 Desfecho
 - 3.9.7 Modelo de exceção de pré-executividade

4. PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

- 4.1 Ordem dos processos nos tribunais e incidentes processuais nos tribunais
 - 4.1.1 Incidente de assunção de competência
 - 4.1.2 Incidente de arguição de inconstitucionalidade
 - 4.1.3 Conflito de competência
 - 4.1.4 Homologação de decisão estrangeira e concessão de *exequatur* à carta rogatória
 - 4.1.5 Ação rescisória
 - 4.1.6 Incidente de resolução de demandas repetitivas
 - 4.1.7 Reclamação
- 4.2 Recursos processuais
 - 4.2.1 Juízo de admissibilidade e de mérito recursal
 - 4.2.2 Pressupostos e impedimentos recursais
 - 4.2.3 Efeitos dos recursos
- 4.3 Apelação

- 4.3.1 Principais características
- 4.3.2 Interposição do recurso
- 4.3.3 Juízo de admissibilidade recursal e fundamentação
- 4.3.4 Efeitos no recurso de apelação
- 4.3.5 Modelo de recurso de apelação
- 4.4 Recurso de agravo de instrumento
 - 4.4.1 Principais características
 - 4.4.2 Interposição do recurso e juízo de admissibilidade recursal
 - 4.4.3 Modelo de recurso de agravo de instrumento
- 4.5 Agravo interno
 - 4.5.1 Principais características
 - 4.5.2 Modelo de recurso de agravo interno
- 4.6 Embargos de declaração
 - 4.6.1 Principais características
 - 4.6.2 Processamento e efeitos
 - 4.6.3 Modelo de embargos de declaração
- 4.7 Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça
 - 4.7.1 Recurso ordinário constitucional
 - 4.7.1.1 Cabimento e estrutura do recurso
 - 4.7.1.2 Modelo de recurso ordinário constitucional
 - 4.7.2 Recurso especial e recurso extraordinário
 - 4.7.2.1 Principais características do recurso especial
 - 4.7.2.2 Cabimento e estrutura do recurso especial
 - 4.7.2.3 Modelo de recurso especial
 - 4.7.2.4 Principais características do recurso extraordinário
 - 4.7.2.5 Cabimento e estrutura do recurso
 - 4.7.2.6 Modelo de recurso extraordinário
- 4.8 Embargos de divergência
 - 4.8.1 Principais características
 - 4.8.2 Processamento e efeitos
 - 4.8.3 Modelo de embargos de divergência

SEGUNDA PARTE

INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
 - 1.1 A Consulta Tributária

- 1.1.1 Competência territorial para formulação da consulta fiscal
- 1.1.2 Competência material para formulação da consulta fiscal
- 1.1.3 Objeto da consulta fiscal
- 1.1.4 Efeitos da consulta fiscal
- 1.1.5 Procedimento de consulta fiscal propriamente dito
 - 1.1.5.1 Preparo Preliminar
 - 1.1.5.2 Preparo de Solução
 - 1.1.5.3 Solução da Consulta
- 1.1.6 Recurso quanto à solução da consulta
- 1.1.7 Ineficácia da consulta fiscal
- 1.1.8 Documentos necessários para formulação da Consulta Fiscal em âmbito federal
- 1.1.9 Modelos de Formulários de Consulta Fiscal

2. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROPRIAMENTE DITO

- 2.1 Requisitos formais da notificação de lançamento e do auto de infração
- 2.2 Impugnação administrativa
 - 2.2.1 Requisitos de admissibilidade da impugnação administrativa
 - 2.2.2 Requisito temporal da impugnação administrativa
 - 2.2.3 Requisito processual da impugnação administrativa
 - 2.2.4 Requisito formal da impugnação administrativa
 - 2.2.5 Competência para o julgamento da impugnação administrativa
- 2.3 Recursos administrativos de segunda instância
 - 2.3.1 Formalização do recurso voluntário
 - 2.3.2 Recurso de ofício
 - 2.3.2.1 Cabimento da *reformatio in pejus* da remessa de ofício
 - 2.3.3 Julgamento de segunda instância administrativa
- 2.4 Incidente de uniformização de decisões divergentes das turmas da câmara superior de recursos fiscais
- 2.5 Recurso hierárquico
- 2.6 Nulidades do processo administrativo fiscal
- 2.7 Disposições finais

3. MODELOS DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 3.1 Modelo de impugnação administrativa
- 3.2 Recurso voluntário

TERCEIRA PARTE

REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ORDINÁRIOS

1. IMPOSTOS EM ESPÉCIE

1.1 Regra-matriz de incidência tributária

2. IMPOSTOS FEDERAIS

2.1 Imposto sobre a Importação (II)

2.1.1 Previsão legislativa

2.1.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.1.2.1 Aspecto material

2.1.2.2 Aspecto espacial

2.1.2.3 Aspecto temporal

2.1.2.4 Aspecto pessoal

2.1.2.5 Aspecto quantitativo

2.1.2.6 Demais características

2.2 Imposto sobre a Exportação (IE)

2.2.1 Previsão legislativa

2.2.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.2.2.1 Aspecto material

2.2.2.2 Aspecto espacial

2.2.2.3 Aspecto temporal

2.2.2.4 Aspecto pessoal

2.2.2.5 Aspecto quantitativo

2.2.2.6 Demais características

2.3 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR)

2.3.1 Previsão legislativa

2.3.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.3.2.1 Aspecto material

2.3.2.2 Aspecto espacial

2.3.2.3 Aspecto temporal

2.3.2.4 Aspecto pessoal

2.3.2.5 Aspecto quantitativo

2.4 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

2.4.1 Previsão legislativa

2.4.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.4.2.1 Aspecto material

- 2.4.2.2 Aspecto espacial
 - 2.4.2.3 Aspecto temporal
 - 2.4.2.4 Aspecto pessoal
 - 2.4.2.5 Aspecto quantitativo
 - 2.4.2.6 Demais características
- 2.5 Imposto sobre operações decorrentes de crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários (IOF)
 - 2.5.1 Previsão legislativa
 - 2.5.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 2.5.2.1 Aspecto material
 - 2.5.2.2 Aspecto espacial
 - 2.5.2.3 Aspecto temporal
 - 2.5.2.4 Aspecto pessoal
 - 2.5.2.5 Aspecto quantitativo
 - 2.5.2.6 Demais características
- 2.6 Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR)
 - 2.6.1 Previsão legislativa
 - 2.6.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 2.6.2.1 Aspecto material
 - 2.6.2.2 Aspecto espacial
 - 2.6.2.3 Aspecto temporal
 - 2.6.2.4 Aspecto pessoal
 - 2.6.2.5 Aspecto quantitativo
 - 2.6.2.6 Demais características

3. IMPOSTOS ESTADUAIS

- 3.1 Imposto sobre a Transmissão *Causa Mortis* e Doações de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD)
 - 3.1.1 Previsão legislativa
 - 3.1.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 3.1.2.1 Aspecto material
 - 3.1.2.2 Aspecto espacial
 - 3.1.2.3 Aspecto temporal
 - 3.1.2.4 Aspecto pessoal
 - 3.1.2.5 Aspecto quantitativo
- 3.2 Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestaduais, Intermunicipais e de Comunicação (ICMS)

- 3.2.1 Previsão legislativa
- 3.2.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 3.2.2.1 Aspecto material
 - 3.2.2.2 Aspecto espacial
 - 3.2.2.3 Aspecto temporal
 - 3.2.2.4 Aspecto pessoal
 - 3.2.2.5 Aspecto quantitativo
 - 3.2.2.6 Demais características
- 3.3 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
 - 3.3.1 Previsão legislativa
 - 3.3.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 3.3.2.1 Aspecto material
 - 3.3.2.2 Aspecto espacial
 - 3.3.2.3 Aspecto temporal
 - 3.3.2.4 Aspecto pessoal
 - 3.3.2.5 Aspecto quantitativo

4. IMPOSTOS MUNICIPAIS

- 4.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
 - 4.1.1 Previsão Legislativa
 - 4.1.2 Regra-Matriz de Incidência Tributária
 - 4.1.2.1 Aspecto material
 - 4.1.2.2 Aspecto espacial
 - 4.1.2.3 Aspecto temporal
 - 4.1.2.4 Aspecto pessoal
 - 4.1.2.5 Aspecto quantitativo
- 4.2 Imposto sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos, onerosa e de direitos reais relativos aos imóveis, exceto os de garantia (ITBI)
 - 4.2.1 Previsão legislativa
 - 4.2.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 4.2.2.1 Aspecto material
 - 4.2.2.2 Aspecto espacial
 - 4.2.2.3 Aspecto temporal
 - 4.2.2.4 Aspecto pessoal
 - 4.2.2.5 Aspecto quantitativo
- 4.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

- 4.3.1 Previsão legislativa
- 4.3.2 Regra-matriz de incidência tributária
 - 4.3.2.1 Aspecto material
 - 4.3.2.2 Aspecto espacial
 - 4.3.2.3 Aspecto temporal
 - 4.3.2.4 Aspecto pessoal
 - 4.3.2.5 Aspecto quantitativo

QUARTA PARTE

DIREITO SUMULAR TRIBUTÁRIO

SÚMULAS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA

QUINTA PARTE

EXERCÍCIOS E GABARITOS

1. EXERCÍCIOS
2. QUESTÕES DISCURSIVAS

SEXTA PARTE

DECISÕES JURISPRUDENCIAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA

EMENTÁRIO JURISPRUDENCIAL

BIBLIOGRAFIA

PRIMEIRA PARTE

PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO

INTRODUÇÃO

O **processo judicial tributário** ocorrerá quando os litígios tributários não forem solucionados entre as partes, de maneira extrajudicial. Pode ser iniciado tanto pela **própria Administração Pública**, quando deseja cobrar judicialmente do contribuinte o crédito tributário, ou pelo **próprio contribuinte**, quando deseja exercer o seu direito de defesa ou pleitear a devolução do que foi pago de maneira indevida.

Importante ressaltar que o processo judicial tributário é o mesmo processo civil no qual são solucionadas as lides. Como não temos um “Código de Processo Tributário”, em toda a sua extensão, basicamente, nos utilizamos das normas previstas no processo civil, conforme visto na introdução.

Para que o Poder Público possa iniciar as medidas judiciais cabíveis, deverá inicialmente **notificar o particular**. Assim, o **processo judicial tributário fazendário** será precedido de **procedimentos administrativos** e de **processos administrativos** para que haja legitimidade.

A procura da solução do litígio por intermédio do Poder Judiciário deverá garantir a totalidade do contraditório e da ampla defesa. É a máxima do **devido processo legal**. Nada mais se deseja do que a aplicação das garantias constitucionais para que a solução adotada seja revestida de legalidade e legitimidade.

Devemos nos recordar que o direito processual é construído, conforme bem salienta Alexandre Freitas Câmara, por três institutos fundamentais: **processo, jurisdição e ação**.

O **processo** é o instrumento pelo qual a Democracia é exercida e por meio dele são construídos os atos jurisdicionais. Após o exame do processo, impende examinar a jurisdição, uma das funções estatais. E, dada a inércia – como característica da jurisdição –, temos que examinar a ação, fenômeno que permite provocar sua atuação.

Assim, o **direito processual** visa disciplinar a concretização do direito, principalmente nos casos em que se tenha lesão ou ameaça de lesão a direitos subjetivos. Portanto, acaba por estabelecer a **forma**, as **condições** e os **limites** ao exercício das principais características normativas:

- i) A obrigação de julgar; e
- ii) A obrigação de fundamentar a decisão em normas do próprio sistema jurídico

Podemos considerar como **funções fundamentais do direito processual**:

- i) O controle do arbítrio decisório; e
- ii) A eficácia dos sistemas jurídicos.



Não restam dúvidas de que a primeira grande tensão, que é específica às lides de direito público, é aquela que diz respeito aos **limites do controle judicial dos atos administrativos**, visto que a ingerência judicial nas atividades **administrativa** e **legislativa** – após a universalização da jurisdição judicial – acabam por ter a eficácia condicionada pelo Poder Judiciário.

A ideia de existência de um direito processual tributário se justifica por alguns critérios:

- (i) Pelas peculiaridades do direito tributário, que acabam por torná-lo diferenciado em relação aos demais ramos do direito;
- (ii) Pela especificidade de seu objeto de atuação, o que passa a ser observado co

os limites que são impostos pelo Estado para restringir direitos patrimoniais dos particulares; e

(iii) Pela atuação vinculada do Estado.

Assim, o **sistema processual tributário** passa a ser constituído pelo **conjunto de normas processuais gerais e específicas** que regulam a atividade jurisdicional (o que engloba tanto o processo judicial quanto o processo administrativo), visando a resolver os conflitos que ocorrem nas diversas espécies de relações jurídicas mantidas entre os contribuintes e o Fisco.

Não são raras as vezes em que os conflitos de interesses tributários põem em choque valores constitucionais que estão na mesma hierarquia, uma vez que, da mesma forma que as receitas tributárias figuram como a principal fonte de manutenção das atividades fundamentais do Estado – ao que damos o nome de **federalismo fiscal** –, o tributo se apresenta como o mecanismo mais poderoso de invasão e mitigação da propriedade privada e liberdade individual, exercido quase unilateralmente.

A necessidade da existência de um processo tributário resta clara, ante a disparidade de situações entre Estado e contribuinte. Porém, tal disparidade é autorizada pela Constituição Federal sob a tutela de existência de interesse público, mas com limites impostos pela própria Constituição da República visando a manutenção e a reserva dos direitos fundamentais do contribuinte.

É importante frisar que, quando falamos do processo tributário, isso não se limita às normas que disciplinam a atividade jurisdicional típica – quando desempenhada pelo Poder Judiciário –, mas também àquelas normas que tratam de uma função judicante atípica – quando realizada pela Administração Pública por meio de seus órgãos públicos judicantes.

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AO PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO

O Estado tem o poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, dirimindo o conflito de interesses entre as partes.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “ação é o direito a um procedimento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses, pouco importando qual seja a solução a ser dada pelo juiz”.

O Código de Processo Civil, para a determinação do conceito de ação, adota a denominada **teoria eclética**, tendo como seu precursor **Liebman**. Por tal teoria, o **direito de ação** não está **vinculado a uma sentença favorável**, mas também não é completamente **independente do direito material**. A ação é o direito a uma **sentença de mérito**, seja qual for o seu conteúdo, positivo ou negativo.

Para que tal direito possa ser invocado, devem estar presentes requisitos denominados de **condições da ação**. Caso falte alguma das condições, ocorrerá o que se denomina de **carência da ação**.

Vários dispositivos estabelecidos no Código de Processo Civil de 2015 traduzem a utilização da Teoria Eclética, esposada por *Liebman*. Dentre eles, temos o art. 485, VI, que estabelece a extinção do processo sem a resolução de mérito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A doutrina moderna tem buscado mitigar a aplicação da teoria eclética, determinando que as condições da ação não seriam encaradas como requisitos para a existência da ação, mas sim como **requisitos ao legítimo exercício do direito de ação**.

A ação é identificada por seus **elementos subjetivos e objetivos**. Os elementos **subjetivos** são **as partes**, e os **objetivos** são o **pedido** e a **causa de pedir**.

É de suma importância a identificação de tais elementos, sendo que a lei expressamente consigna que são **pressupostos da petição inicial**, nos termos do art. 319, II, III e IV, do CPC/2015.

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV – o pedido com as suas especificações; (...)

A ausência de algum dos elementos da ação acarretará o **indeferimento da inicial**, por **inépcia**, com a consequente **extinção do feito sem resolução de mérito**, previsto no art. 330, I e § 1.º, do CPC/2015.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1.º Considera-se inepta a petição inicial quando: (...)

Resumidamente, podemos identificar os elementos da ação do seguinte modo:

- i) **Parte**: é aquele que participa da relação jurídico-processual. Aquela que formula ou tem contra si um pedido formulado é denominada de **parte principal**. Temos ainda a **parte auxiliar**, que atua no processo como uma

coadjuvante, como ocorre com o **assistente simples**. Nada obsta, contudo, que na relação processual haja uma **pluralidade de sujeitos**, independentemente do polo, seja ativo ou passivo. São os casos de **litisconsórcio**, que podem ser formados desde o início (litisconsórcio inicial) ou no decorrer do processo (litisconsórcio ulterior). Conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco, a qualidade de parte implica sujeição à autoridade do juiz e titularidade de todas as situações jurídicas que caracterizam a relação jurídico-processual;

- ii) **Causa de pedir**: são os fatos e os fundamentos do pedido, subdividindo-se em **causa remota** e **causa próxima**. A **causa remota** tem relação direta com os fatos; a **causa próxima** tem relação com as consequências jurídicas que decorrem dos fatos narrados. O CPC/2015 dispensa que o autor indique o artigo da lei que atribui o efeito ao fato narrado, exigindo a indicação do fato jurídico, bem como das consequências jurídicas que decorrem desse mesmo fato;
- iii) **Pedido**: é a conclusão da exposição realizada na inicial, ou seja, a pretensão material realizada ao Estado-juiz. Subdivide-se em **pedido imediato** (providência jurisdicional requerida pelo autor) e **pedido mediato** (bem jurídico pretendido). O pedido deve ser certo e determinado, admitindo-se excepcionalmente o pedido genérico, no que diz respeito a quantidade.

Após a análise dos elementos da ação, vamos verificar, de forma sucinta, as **condições da ação**, sendo as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Subdividem-se em **legitimidade**, **interesse de agir** e **possibilidade jurídica do pedido**.

A **legitimidade** decorre da pertinência subjetiva, ou seja, quem são as partes legítimas para a titularidade da relação jurídica, o que se denomina de **legitimação ordinária**. Temos a **legitimação extraordinária** quando a norma autorizar que alguém possa pleitear, em nome próprio, direito pertencente a outrem. Pode ser chamada de **substituição processual**.

O **interesse de agir** é a verificação da adequação do meio utilizado para a obtenção da tutela. Assim, terá interesse de agir quem demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional formulada.

Já a **possibilidade jurídica do pedido** é a afirmação da possibilidade de exame pelo Poder Judiciário da matéria deduzida. Assim, é preciso ter a certeza de que o

Direito abarca a possibilidade de julgar determinada temática.

Por expressa opção do legislador processual, o juízo responsável pela verificação das condições da ação **não pode ser qualificado como juízo de mérito**; tal fato se mostra tão verdadeiro que, quando da **ausência de qualquer condição da ação**, ensejará a **extinção do processo sem resolução de mérito**.

Reza o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Independentemente de a possibilidade de medidas judiciais serem demandadas pela autoria da Fazenda Pública ou do particular, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, temos disposições gerais comuns aplicáveis ao processo judicial tributário.

Tais disposições gerais ocorrem por meio da **fixação de competência jurisdicional para apreciação das ações** (o juízo competente), o **preâmbulo processual** (qualificação das partes), **exposição dos fatos e dos fundamentos e direito**, os **provimentos liminares**, **produção de provas**, **valor da causa**, dentre outros elementos.

A unidade do sistema jurídico processual se funda, assim, sobre três institutos jurídicos básicos:

- Ação;
- Processo; e
- Jurisdição.

O denominado **poder de tributar** perfaz uma exceção constitucionalmente posta ao direito subjetivo absoluto de propriedade do cidadão, devendo ser exercido **nos limites previstos pela Constituição Federal e pela legislação tributária**. Por essa razão, o direito absoluto de propriedade é plenamente oponível a qualquer pretensão tributária do Estado.

Temos, como um bom exemplo, a tributação de fatos e operações que não estejam abrangidos pelas hipóteses tributárias, o que acarreta a **violação de um direito absoluto do contribuinte**, qual seja **de não ser tributado fora dos limites previstos em lei ou na própria Constituição Federal**.

Além das relações já comentadas, temos o denominado **direito potestativo**, em que a qualificação das condutas permite que o sujeito ativo interfira na esfera jurídica do sujeito passivo, de modo a **constituir, modificar ou extinguir** as relações jurídicas. Assim, o titular passivo na relação de direito potestativo não tem dever a prestar, uma vez que fica reduzido à condição de sujeição. Ele acaba por suportar os efeitos jurídicos do exercício dos poderes de seu titular que, por ato unilateral, é capaz de provocar a constituição, modificação ou extinção das relações jurídicas.

Podemos citar como exemplos de direito potestativo:

- Direito de constituição do crédito tributário (constitutivo);
- Direito de escolha nas obrigações alternativas (modificativo);
- Direito de anulação do crédito tributário (extintivo).

Existe uma estreita relação entre a espécie de direito subjetivo (que pode ser **prestacional, potestativo ou absoluto**, denominada de **causa de pedir remota**), a específica forma de violação desse direito (**causa de pedir próxima**) e o tipo de pretensão adequada à recomposição do direito violado (o que se confunde com o **interesse de agir**).

Assim, a possibilidade de cobrança indevida de um tributo, por meio do exercício ilegal do direito de tributar (direito potestativo), dá oportunidade à formulação de pretensão processual obstativa desse direito, impedindo a indevida invasão da esfera jurídica do contribuinte (violação de direito subjetivo absoluto).

De igual modo, a lavratura de auto de infração constitutivo de crédito tributário indevido dará ensejo ao nascimento de um direito subjetivo (potestativo) do contribuinte à anulação do débito e, assim, à formulação da pretensão anulatória do ato de cobrança.

As pretensões processuais que se destinam à composição dos conflitos havidos nas relações jurídico-tributárias são formuladas em estrita observância da espécie de **direito subjetivo material tributário** – seja prestacional, potestativo ou absoluto – e de sua específica forma de violação. Será a violação que determina a **forma de reparação**, condicionando a **tutela jurisdicional pretendida à adequada composição do direito violado**.

Toda a espécie de direito subjetivo tributário ameaçado de violação ou que seja efetivamente violado corresponderá a uma pretensão e a uma tutela jurisdicional adequada à sua preservação ou reparação.

Além das disposições acima, o **estilo de apresentação das peças processuais** demonstra a observância aos melhores padrões forenses, uma vez que serão encartadas nos autos de um processo, sendo manejadas por diversas pessoas.

Um padrão bem aceito na apresentação de uma petição pode ser visto abaixo:

1.1 MODELO DE APRESENTAÇÃO COM TÉCNICA PROCESSUAL FORENSE

1

2

3

NOME DA MEDIDA JUDICIAL EM DESTAQUE ⁴

:

I – DOS FATOS

II – DO DIREITO

“

5”

Da concessão de liminar/tutela antecipada/efeito suspensivo⁶

III – DO PEDIDO

:7

- a) _____
- b) _____
- c) _____

IV – DAS PROVAS

V – VALOR DA CAUSA

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Nome e assinatura do advogado

OAB/ ... n. ...

1. O **endereço** (competência processual) sempre deverá ser realizado em **letras maiúsculas**, devendo ser *evitadas* as abreviaturas.
2. Deve-se indicar um **espaçamento de aproximadamente 10 (dez) centímetros** para que o juízo possa despachar na petição. Hoje, ante o processo eletrônico, a existência do espaçamento existe mais por um critério estético do que por necessidade.
3. No **preâmbulo (qualificação das partes processuais)** deve ser colocada a qualificação da parte e demais informações relevantes, iniciando a primeira linha no meio da folha, sendo as demais com início comum.
4. O **nome da ação** (*nomen juris*) deverá estar em posição de destaque.

5. Utiliza-se o meio da folha (de forma aproximada) para os casos de **transcrição de artigos de lei, ementas jurisprudenciais, súmulas ou citações doutrinárias**.
6. Quando a ação tiver a **existência de requerimento de liminares, tutelas provisórias ou concessão de efeito suspensivo**, o advogado deverá inseri-los em **posição destacada dentro dos fundamentos de direito**, expondo os **motivos da efetiva concessão** pelo juízo competente.
7. Para que ocorra uma melhor observância dos **pedidos e requerimentos** realizados pelo autor da pretensão, mostra-se interessante a **citação dos pedidos através de tópicos**, facilitando, assim, a apreciação da autoridade julgadora competente.

“Art. 53. É competente o foro: (...)

III – do lugar:

- a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
- b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
- c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;
- d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;
- e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;
- f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; (...).”

1.2 COMPETÊNCIA PROCESSUAL

Entende-se por **competência** o **limite da própria jurisdição**. A **competência territorial** diz respeito ao **local para fins da fixação da competência**. É estudada nos termos do art. 53, III e IV, do CPC/2015.

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III – do lugar:

- a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
- b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
- c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;
- d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se

lhe exigir o cumprimento;

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

IV – do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;
(...)

O denominado **foro** indica a **base territorial** sobre a qual cada órgão do Judiciário exerce a sua jurisdição, conforme determina a doutrina. Neste caso, o **foro de um Tribunal Regional Federal** abarca **todas as unidades federadas de sua abrangência**. Já os **Tribunais de Justiça** possuem jurisdição sobre **todos os Municípios que compõe os respectivos Estados da Federação**.

A **competência material** é definida pela Constituição Federal, Constituições dos Estados e pelas leis de organizações judiciárias dos próprios Estados. Esta competência é considerada **absoluta**.

Por fim, temos a denominada **competência funcional**, que se define quando uma causa acompanha outra que já está em curso (ação principal e cautelar, por exemplo). Serve para se dar **maior efetividade a prestação jurisdicional**.

Pela **regra geral**, a competência pode ser definida pela **análise do tributo em questão (critério material)**, desde que haja a exclusão do critério pessoal.

O denominado **critério pessoal** observará a **competência absoluta em razão da pessoa**, de acordo com o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos **juízes federais** compete processar e julgar:

I – as causas em que a **União, entidade autárquica ou empresa pública federal** forem interessadas na condição de **autoras, rés, assistentes ou oponentes**, exceto as de falência, a de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Nesse caso, se a **União**, suas respectivas **autarquias federais**, **fundações públicas federais** (pois, segundo a jurisprudência, as fundações públicas gozam da mesma natureza que as autarquias) e suas **empresas públicas federais** figurarem no polo ativo ou passivo das medidas judiciais, a **competência processual** será deslocada para a **Justiça Federal**, independentemente da **matéria discutida**. Vejamos:

- i) Imaginemos que o caso apresentado se refira a uma pretensão de anulação da incidência de IPVA sobre os veículos que são utilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- ii) O INSS é uma **autarquia federal** discutindo sobre a incidência de **imposto estadual** (IPVA);
- iii) Nesse caso, mesmo que se esteja discutindo um **imposto estadual** (competência material), a competência processual será deslocada para a **Justiça Federal**, por se tratar de um caso de **competência absoluta em razão da pessoa** (competência pessoal).

Resumidamente, conclui-se que a competência processual terá, como regra geral, a **competência material** (pelo tributo), desde que não se observem, nos polos ativo e passivo, a União, autarquias federais, fundações públicas federais e empresas públicas federais, caso contrário, **obrigatoriamente**, a competência processual será deslocada para a **Justiça Federal** (competência pessoal), independentemente da matéria a ser tratada.

Se o tributo for **federal**, a competência será da **Justiça Federal**; sendo **tributos estaduais e municipais**, a competência será da **Justiça Estadual**, destinando-se a medida judicial à **vara especializada**, quando houver, ou, ainda, da **vara cível** competente.

Resumidamente, temos:

TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
	Justiça Estadual (Especializada ou

Justiça Federal	Cível)
-----------------	--------

Tratando-se da **Justiça Federal**, teremos o seguinte endereçamento:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção Judiciária de ...

É sabido que na **primeira instância da Justiça Federal** temos a divisão judiciária em **Seções** e **Subseções**. A principal diferença é que a **seção** indica o **Estado** e a **subseção** indica a **cidade** onde existe a Justiça Federal. Por exemplo, na cidade de **Sorocaba**, no **Estado de São Paulo**, temos o seguinte endereçamento correto:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da **Subseção Judiciária de Sorocaba – Seção Judiciária de São Paulo**

Entretanto, no que diz respeito às **provas elaboradas para o Exame da OAB**, a banca examinadora, em regra, não se preocupa com tal detalhe, **bastando a indicação da Seção Judiciária**.

Sendo assim, para o exame da OAB, faremos o seguinte:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção Judiciária de ...

Em se tratando da **Justiça Estadual**, devemos indicar a **existência de vara especializada** (Vara da Fazenda Pública) ou não (Vara Cível). Para tanto, vamos dividir da seguinte forma:

Quando da indicação, no problema, de um **Estado**, de uma **capital** ou nos casos de **omissão: Fazenda Pública**.

Quando da indicação, no problema, de uma **cidade** ou nos casos

de omissão: Vara Cível.

Exemplo I:

Empresa X, sediada em Campo Grande (Mato Grosso do Sul), destina-se : comercialização de combustíveis e lubrificantes (...)

Neste caso, identificamos a existência da **capital** de um **Estado da Federação**. Assim, o endereçamento seria remetido para o **Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande**, ou, ainda, **Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso do Sul**.

Exemplo II:

Empresa X, sediada em Cabrobó do Norte, destina-se à comercialização de combustíveis e lubrificantes (...)

Neste caso, identificamos a existência de uma **cidade**, sem que seja uma **capital**. Assim, o endereçamento seria remetido para o **Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Cabrobó do Norte**.

Resumidamente, o **endereçamento na Justiça Estadual** ficará do seguinte modo:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado (ou da Comarca) de ... (nos casos da indicação de um Estado, Capital ou omissão)

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara Cível da Comarca de ... (nos casos de indicação de uma cidade ou omissão)



Importante

Quando se tratar de **processo executivo fiscal**, a competência deverá ser do mesmo juízo onde se processa a execução fiscal. Assim, as defesas do executado deverão ser apresentadas para o juiz que analisa a execução fiscal.

Quando do exame da OAB, é possível que o enunciado traga as informações sobre a existência do juízo. No entanto, quando for **omisso o juízo competente**, deverá ser observado o seguinte endereçamento:

Execução Fiscal de tributos federais

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de ...

Execução Fiscal de tributos estaduais e municipais

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Anexo Fiscal da Comarca de ...

1.2.1 Competência processual de segundo grau

Tratando-se dos **tribunais em segunda instância**, a análise é realizada **diretamente pelo Tribunal**, não mais se admitindo a análise pelo juízo *a quo*, sendo o recurso encaminhado para o tribunal competente.

Assim, podemos concluir:

TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
Tribunal Regional Federal Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da ...	Tribunal de Justiça do Estado Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de ...

Região	
--------	--

De acordo com a organização judiciária, os **Tribunais Regionais Federais** encontram-se divididos em **seções judiciárias** e cada uma das seções tem sua subdivisão nas **subseções judiciárias** correspondentes.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	SEÇÃO JUDICIÁRIA
1.ª REGIÃO	Distrito Federal Acre Amapá Amazonas Bahia Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso Pará Piauí Rondônia Roraima Tocantins
2.ª REGIÃO	Rio de Janeiro Espírito Santo
3.ª REGIÃO	São Paulo Mato Grosso do Sul

4.ª REGIÃO	Rio Grande do Sul Paraná
5.ª REGIÃO	Santa Catarina Pernambuco Alagoas Ceará Paraíba Rio Grande do Norte Sergipe

Por fim, quando as causas forem decididas em **única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados** e a decisão **contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência**, ou julgar **válido ato de governo local contestado em face de lei federal** ou ainda der a lei federal uma interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, caberá **Recurso Especial** a ser interposto perante o **Superior Tribunal de Justiça**.

Nos casos de decisão recorrida **contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal** ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal, terá cabimento **Recurso Extraordinário** perante o **Supremo Tribunal Federal**.

RECURSO ESPECIAL	RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Superior Tribunal de Justiça	Supremo Tribunal Federal
Excelentíssimo Senhor Doutor	Excelentíssimo Senhor Doutor
Ministro Presidente do Colendo	Ministro Presidente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça	Supremo Tribunal Federal



Dica

Todo o endereçamento deverá estar disposto por extenso, evitando as abreviaturas comumente utilizadas.

1.2.2 Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

A Lei 10.259/2001 versa sobre a competência da Justiça Federal, restringindo a competência do **juizado especial federal em matéria cível** ao valor correspondente a **60 (sessenta) salários mínimos**, podendo se discutir **qualquer matéria** que seja da competência da Justiça Federal (art. 109 da CF).

Estão **excluídas da competência do juizado especial cível** as seguintes causas:

I – causas entre estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoal domiciliado e residente no País;

II – causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

III – disputa de direitos indígenas;

IV – ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

V – sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

VI – para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal;

VII – que tenham como objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

A Lei 12.153/2009 dispõe sobre os **Juizados Especiais da Fazenda Pública Estaduais, Distritais, Municipais** e dos **Territórios**, tendo por competência o processamento, julgamento e conciliação das causas cíveis até o valor de **60 (sessenta) salários mínimos**.

Também **não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública** as ações:

I – de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre

direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II – sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III – para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal;

IV – que tenham como objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

No foro onde estiver instalado o **Juizado Especial da Fazenda Pública**, a competência será **absoluta**.

Passa a ser plenamente possível o **deferimento do processamento de providências cautelares e antecipatórias** no curso do processo.

Podem figurar no **polo ativo** das causas processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública as **pessoas físicas** e as **microempresas e empresas de pequeno porte**.

No **polo passivo** podem figurar os **Estados, Distrito Federal, Territórios** e os **Municípios**, bem como as **autarquias, fundações e empresas públicas** a eles vinculadas.

Havendo divergência entre as decisões proferidas por Turmas Recursais do mesmo Estado sobre direito material caberá **Incidente de Uniformização**, devendo ser julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do **Desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça**.

Tratando-se de Turmas de **diferentes Estados** que derem à lei federal interpretações divergentes, ou ainda quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgamento do pedido de uniformização será do próprio **Superior Tribunal de Justiça**.

RESUMO GERAL DE COMPETÊNCIA PROCESSUAL

As ações tributárias deverão ser ajuizadas, tendo o seguinte endereçamento:

TRIBUTOS FEDERAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...

Tratando-se de **EXECUÇÃO FISCAL, MEDIDA CAUTELAR FISCAL, EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL** ou **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE** nos **TRIBUTOS FEDERAIS**, que a medida judicial deve ser processada no **mesmo juízo das execuções**, temos:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara das Execuções Fiscais Federais da Seção (o Subseção) Judiciária de ...

TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (Estado Capital e omissão).

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara Cível da Comarca de ... (onde não se encontra vara especializada).

Tratando-se de **EXECUÇÃO FISCAL, MEDIDA CAUTELAR FISCAL, EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE** nos **TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS**, que a medida judicial deve ser processada no mesmo juízo das execuções, temos:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara das Execuções Fiscais da Comarca de ... ou

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Anexo Fiscal da Comarca de ...

2.ª INSTÂNCIA

Na segunda instância, vamos analisar o tributo em questão e endereçar a peça ao Tribunal Regional Federal ou ao Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, temos:

TRIBUTOS FEDERAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da ... Região.

TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de ...

INSTÂNCIA SUPERIOR

Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal

1.2.3 Situações excepcionais de competência processual

Vimos a regra geral na utilização da competência processual nas medidas judiciais em matéria tributária. No entanto, temos situações excepcionais que merecem atenção especial, dentre as quais destacamos:

- a) Exercício da capacidade tributária ativa do Imposto Territorial Rural pelos Municípios

O Imposto Territorial Rural (ITR) é um imposto federal, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal, tendo sua competência tributária outorgada à União. Entretanto, dispõe o art. 153, § 4º, III, da Constituição da República que, caso o:

Municípios realizem a opção, poderão exercer a arrecadação e a fiscalização do ITR (exercício da capacidade tributária ativa).

Visando a manutenção do equilíbrio do federalismo fiscal, a Constituição Federal estabelece, entre os arts. 157 a 162, o mecanismo de repartição de receitas tributárias, permanecendo o Município com 50% (cinquenta por cento) do ITR arrecadado pela União, referente aos imóveis que se encontram em seu território.

Porém, caso o Município opte pelo exercício da capacidade tributária ativa do ITR, a Constituição determina, no art. 158, II, que a totalidade da arrecadação do ITR integre os cofres do próprio Município.

Assim, caso haja medida judicial discutindo tão somente a devolução dos valores pagos indevidamente pelo proprietário do imóvel situado fora da zona urbana do Município, a competência para julgamento da medida será da **Justiça Estadual; isto porque, se houve pagamento indevido, este ocorreu ao Município, que permanecerá com a arrecadação. Não há qualquer legitimidade da União em figurar no polo passivo, pelas seguintes razões:**

- **A medida judicial versa apenas sobre o pagamento indevido de ITR, pagamento este que fora realizado ao Município;**
- **O dinheiro arrecadado integrará os cofres municipais, não detendo a União qualquer legitimidade para figurar no polo passivo, ante a ausência de interesse de agir.**

Entretanto, caso a discussão verse sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de incidência do ITR, a competência processual para o julgamento da medida judicial será da Justiça Federal, vez que apenas a União detém a competência tributária do ITR, sendo esta indelegável e intransferível.

Assim, temos:



- b) Imposto de Renda retido na fonte de servidores públicos estaduais, distritais e municipais

O Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza (IR) tem previsão no art 153, III, da Constituição Federal, podendo incidir sobre rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas.

Conforme determinação legislativa, quando os pagamentos forem realizados por pessoas jurídicas, caberá a elas a responsabilidade de retenção do valor do imposto.

No caso de servidores públicos estaduais, distritais e municipais, as respectivas pessoas jurídicas de direito público interno realizam a retenção. Além disso, o sistema de repartição de receitas tributárias, nos artigos 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, estabelece o seguinte:

Art. 157. Pertencem aos **Estados e ao Distrito Federal**:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituïrem

e mantiverem;

Art. 158. Pertencem aos **Municípios**:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituïrem e mantiverem;

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 447, *in verbis*:

Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

Tal fato acontece porque o valor arrecadado pelos Estados, DF e Municípios ficará em seus próprios cofres, não havendo qualquer legitimidade para que a União figure no polo passivo, por razões simples:

- ✓ A arrecadação foi realizada pelos Estados, DF e Municípios; e
- ✓ O valor arrecadado permanecerá nos cofres públicos desses mesmos entes, não sendo realizada qualquer espécie de transferência para a União.

Assim, se a discussão processual versar, tão somente, sobre **restituição de valores** – por meio de **Ação de Repetição de Indébito Fiscal** – dos servidores estaduais, distritais e municipais, a competência para julgamento dessa medida será da **Justiça Estadual**, mesmo que a discussão trate sobre **Imposto de Renda**, cuja competência tributária pertence à **União**.

CUIDADO

Em se tratando da discussão sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de retenção do IR, mesmo que a ação seja proposta pelos servidores públicos, a competência será da **Justiça Federal**, uma vez que o exercício da competência tributária

pertence tão somente à **União**, não dispondo o Estado de qualquer legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

a) **Sociedade de economia mista**

A sociedade de economia mista sempre deverá observar a **competência material**, ou seja, em razão do tributo, não se aplicando o regramento de competência absoluta em razão da pessoa, vez que o art. 109, I, da Constituição Federal somente se refere às **empresas públicas**, não fazendo qualquer alusão às **sociedades de economia mista**.

Ademais, temos a aplicação da súmula 556 do STF:

É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Assim, caso a PETROBRAS (sociedade de economia mista) tratar sobre questão de Imposto de Renda (imposto federal), a competência para julgamento da medida judicial será da **Justiça Federal**. Caso trate de ICMS (imposto estadual), a competência processual será da **Justiça Estadual**.

1.3 QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A qualificação correta das partes passa a ser imprescindível para a demonstração de uma boa técnica forense e processual.

Assim, a qualificação diferencia entre a **pessoa física** e a **pessoa jurídica**. A classificação da pessoa jurídica pode ser de **direito público** e de **direito privado**.

São **pessoas jurídicas de direito público** a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como suas autarquias e fundações públicas, nos termos do art. 41 do CC.

Já as **pessoas jurídicas de direito privado** subdividem-se em **estatais** (empresas públicas e sociedades de economia mista) e **não estatais** (associações, fundações privadas, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos e o EIRELI).

Art. 319. A petição inicial indicará:

I – o juízo a que é dirigida;

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV – o pedido com as suas especificações;

V – o valor da causa;

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

1.3.1 Qualificação da pessoa física como sujeito ativo (autor)

Para a qualificação da pessoa física, propomos o seguinte:

CONTRIBUINTE, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG n. ..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. ..., endereço eletrônico ..., residente e domiciliado na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ...

Para o exame da OAB, o candidato deverá realizar a identificação por meio da inclusão de (...) ou (xxx) após a inserção dos dados, sob pena de se considerar identificação da peça e levando a anulação da peça práctico-profissional, conforme orientação prevista no edital.

1.3.2 Qualificação da pessoa jurídica como sujeito ativo (autora)

A pessoa jurídica, para que a qualificação seja adequada, dependerá do tipo de

personalidade adotada. Não se pode qualificar um ente público da mesma forma que uma pessoa jurídica de direito privado.

Neste caso, a qualificação mais comum passa a ser de **sociedades**. Sendo assim, como um exemplo, passemos a indicar uma forma de qualificação de sociedade:

SOCIEDADE ..., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..., endereço eletrônico ..., com sede na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ..., neste ato representada por meio de seus sócios (conforme contrato social em anexo) ...

Lembramos ainda que tal qualificação de pessoa jurídica poderá ser alterada dependendo do tipo de pessoa jurídica que ingressa com a pretensão. Assim, na **qualificação de um partido político**, deverá necessariamente ser indicado que está inscrito como **organização político-partidária perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal**, tendo o seu **estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral**, conforme rege a Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos).

PARTIDO POLÍTICO..., pessoa jurídica de direito privado, com estatuto social devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal sob o n. ..., e inscrição perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n. ... com sede na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ...

Na qualificação de **organizações religiosas** ou **demais entidades sem fins lucrativos**, tais informações deverão estar contidas na qualificação, demonstrando ao juízo competente as principais características de cada uma das entidades.

IGREJA/ENTIDADE ASSISTENCIAL ..., pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..., com sede na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ..., neste ato representada por meio de seus dirigentes (estatuto social em

anexo) ...

1.3.3 Qualificação da pessoa jurídica de direito público interno

Tratando-se de medidas judiciais propostas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, a ação sempre será demandada em face de um **ente público federado**, salvo nos casos de **mandado de segurança**, em que a ação mandamental é impetrada **contra o ato ilegal e abusivo de determinada autoridade coatora**.

Cuidando-se de **tributos federais**, as medidas judiciais terão como ré a **União** ou **Fazenda Nacional**; se **tributos estaduais**, o réu será o **Estado** ou a **Fazenda Pública Estadual**, e, no caso de **tributos municipais**, o réu será o **Município**, a **Municipalidade** ou **Fazenda Pública Municipal**. Todas as formas acima descritas estão corretas.

Há discussão sobre o uso da expressão **Fazenda Pública** na indicação do polo passivo da relação jurídico processual, uma vez que alguns indicam tratar-se de um **órgão público**, portanto, desprovido de capacidade processual para figurar como tal. Entretanto, vemos claramente que a **própria Administração Pública** se utiliza da expressão nas **ações demandadas em face do contribuinte**, indicando apenas tratar-se de uma **praxe jurídica e terminológica**, sem que acarrete prejuízos ou atecnia processual.

Essas entidades sempre terão um **representante judicial** ou **procurador**, devendo indicar a sede do funcionamento da repartição pública.

A qualificação passa a ser a seguinte:

União (Fazenda Nacional) Estado (Fazenda Pública Estadual) Município (Fazenda Pública Municipal)	pessoa jurídica de direito público interno, com sede na ..., representada neste ato por seu procurador ...
--	--

1.4 EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Na linguagem processual, os fatos são denominados de **causa de pedir remota**. A

narrativa será sempre a **descrição do problema que foi apresentado** mediante a utilização de uma **terminologia adequada**.

Assim, terminologias como autor, réu, impetrante, impetrado, exequente, executado, dentre outras, devem ser utilizadas para determinação da melhor técnica forense.



Note bem

Para os candidatos do exame da OAB, a exposição dos fatos é a **mera transcrição resumida do enunciado com a terminologia adequada**, sempre realizando o desfecho para que se possa dar continuidade à exposição da peça práctico-profissional.

Um dos exemplos que podem ser adotados como encerramento da narrativa dos fatos é o seguinte:

“Não concordando com a referida exação, ingressa com a presente ação”.

1.5 DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO

A fundamentação jurídica adotada é denominada **causa de pedir próxima**. São as **razões jurídicas** utilizadas pelas partes para a pretensão jurídica.

Ações que sejam de iniciativa do Fisco terão sua fundamentação jurídica sempre direcionada pela **existência do descumprimento de uma obrigação legal por parte do sujeito passivo**. E, nos casos de ações demandadas pelo sujeito passivo, cada qual terá sua fundamentação dentro das características de cada ação, por exemplo, nos casos de declarar a inexistência de uma relação jurídico-tributária por alguma afronta constitucional ou legal, anulação de um débito fiscal etc.

As teses utilizadas como fundamento de direito podem ser divididas da seguinte forma:

- i) **Teses Constitucionais**: podem ser **gerais**, quando se referem a princípios basilares do direito público, tais como segurança jurídica, devido processo legal, razoabilidade, proporcionalidade, como podem ser **específicas**,

quando a defesa dos interesses do contribuinte consiste na afronta às **limitações constitucionais ao poder de tributar**, tais como afronta ao princípio da legalidade, da isonomia, da anterioridade, bem como afronta às imunidades tributárias;

- ii) **Teses Legais:** podem ser divididas na análise das **normas gerais** bem como das **normas específicas**. As **normas gerais** estão dispostas no Código Tributário Nacional (CTN), entre os arts. 96 a 218. Assim, a não observância das normas sobre obrigação, capacidade tributária, responsabilidade tributária são observadas diretamente no CTN. Questões que tratam sobre isenções específicas, regramentos de incidência específicos devem ser obtidos pela análise de normas específicas, como, por exemplo, na Lei Complementar 87/1996, que trata de ICMS, ou da Lei Complementar 116/2003, que trata do ISS;
- iii) **Teses Jurisprudenciais:** pode ocorrer de a defesa principal estar calcada, apenas, nas **decisões jurisprudenciais**, que podem estar **sumuladas** ou **não sumuladas**. Dentre as principais súmulas a serem observadas, temos as súmulas do STF, que se subdividem em **vinculantes** e **não vinculantes**, e as **súmulas do STJ**. Várias temáticas não estão apontadas na jurisprudência sumulada, mas encontram-se em discussão perante os Tribunais Superiores, podendo ser utilizadas como defesa na peça processual. É o caso, por exemplo, da extensão da imunidade recíproca para as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais ao funcionamento do Estado.



Note bem

Para os candidatos do exame da OAB, o fundamento passa a ser a parte mais importante do problema, em que se expõe o verdadeiro conhecimento jurídico atrelado ao raciocínio lógico.

Uma boa forma de iniciar o fundamento do direito é narrando a competência do tributo em questão e onde este se encontra na Constituição Federal ou outra legislação.

1.6 DO PEDIDO

O pedido é extremamente importante, uma vez que **dimensiona a prestação jurisdicional**. Para que o juízo possa proferir sua decisão, faz-se necessário que o demandante diga ao juízo sua pretensão.

De acordo com as determinações do Código de Processo Civil, o pedido não deve ser duvidoso, não pode ser confuso, deve ser lógico, buscando sempre atingir aquilo que foi exposto. Caso contrário, é possível o indeferimento da inicial por não ter coerência o pedido com a causa de pedir.



Dica

O art. 319 do CPC/2015 traz todos os requisitos indispensáveis que deve conter uma petição inicial. Uma vez que inexistente um Código de Processo Tributário, subsidiariamente aplicamos o Código de Processo Civil nas ações tributárias.

1.7 DA PRODUÇÃO DE PROVAS

São admitidas **todas as provas em direito**, desde que estas **não sejam ilícitas**. Em certas demandas (mandado de segurança e exceção de pré-executividade), **não cabe o requerimento de provas**, uma vez que esta deve estar **pré-constituída**.

A prova documental passa a ser um dos meios probantes mais importantes em matéria tributária, apesar de as lides tributárias comportarem outros meios de provas. O momento de se requerer as provas é na petição inicial.



Dica

As provas poderão ser requeridas na peça da seguinte forma:
"Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela prova documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo".

1.8 VALOR DA CAUSA

Toda causa deverá corresponder a um **determinado benefício econômico postulado em juízo**. Passa a ser a **vantagem financeira** ou **patrimonial** que se busca no momento da propositura da ação.

Mesmo naquelas causas que são desprovidas de conteúdo econômico, existe necessidade de se atribuir um valor a elas.

Como sabemos, é **possível a cumulação de pedidos**, nos termos do art. 327, § 1.º, do CPC/2015:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1.º São **requisitos de admissibilidade da cumulação** que:

I – os **pedidos sejam compatíveis** entre si;

II – **seja competente para conhecer deles o mesmo juízo**;

III – **seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento**.

Neste caso, a regra é que o valor deve corresponder à **soma de todos os valores correspondentes aos pedidos**.

Nos **pedidos alternativos** (art. 325 do CPC/2015), o autor deverá atribuir o valor à causa com base no **pedido de maior valor**.

Nos casos de **pedido subsidiário**, em que o autor formula mais de um pedido, tomando geralmente o **primeiro como principal** e o **posterior como secundário**, sucessivamente, tantos quantos forem os pedidos, nos termos do art. 326 do CPC/2015, o valor atribuído à causa será o do **pedido principal**.

Em matéria tributária, pela regra geral, admite-se a cumulação de pedidos na **ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária**, bem como na **ação anulatória de decisão administrativa** (não na ação anulatória de débito fiscal, visto que são distintas), vez que ambas podem admitir cumulação com **repetição de indébito fiscal**.



Dica

Caso o problema não traga o valor da causa, a indicação deverá ser feita da seguinte forma:

“Dá-se à presente causa o valor de R\$... (valor por extenso).”

1.9 LIMINARES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

A expressão **liminar** abrange todas as formas de pronunciamento acautelatório do juiz que é adotado no início do processo. Este pronunciamento do magistrado competente poderá ser **total** ou **parcial**.

No entanto, a expressão **liminar** e a expressão **tutela provisória** são utilizadas em peças processuais distintas, não podendo gerar qualquer espécie de confusão.

A **liminar** passa a ser utilizada em sede de **mandado de segurança** e a **tutela provisória**, seja de **urgência** ou **evidência**, é usada nas ações de procedimento comum, principalmente nas ações **declaratória** e **anulatória**.

1.9.1 Requisitos para a concessão de liminar

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança os fundamentos são: a **existência de fundamento relevante** (*fumus boni juris*) e **perigo da ineficácia da medida** (*periculum in mora*).

O que se pretende, na verdade, é requerer ao juízo competente que a medida liminar seja concedida para **suspender a exigibilidade do crédito tributário**, pois, enquanto a liminar estiver em vigor o Fisco, estará **impossibilitado de prosseguir com a cobrança do crédito**. O fundamento para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de mandado de segurança está no art. 151, IV, do CTN.

Mesmo que a liminar seja requerida **antes do lançamento tributário**, a finalidade acaba sendo a **suspensão da exigibilidade do crédito tributário**. Isso porque, mesmo com a concessão da liminar, o Fisco **não deixará de lançar o tributo**, uma vez que não pode **deixar decair o direito do crédito tributário**. Assim, mesmo que a **tutela provisória** seja concedida, o Fisco **efetuará o lançamento para prevenir a existência da decadência**.

Concedida a liminar, isso não significa que a medida judicial será julgada procedente, podendo ocorrer sua cassação. Se isto ocorrer e o Fisco não efetuar o lançamento, perderá o direito de constituição.

Ademais, reza a súmula 405 do STF:

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

Isso significa que, mesmo que a liminar tenha sido concedida, caso ocorra sua **suspensão** por agravo interposto pelo Fisco ou do julgamento definitivo do mérito (segurança em definitivo), os efeitos da liminar **serão anulados** (efeito *ex tunc*), legitimando o Fisco e **continuar com a cobrança do tributo e lançando as multas e juros devidos pelo período em que se manteve suspensa a exigibilidade do crédito tributário**.

Os **requisitos para a concessão de liminar** estão previstos no art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009:

Art. 7.º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III – que se **suspenda o ato que deu motivo ao pedido** [suspensão da exigibilidade do crédito tributário], quando houver **fundamento relevante** [fumus boni juris] e do ato impugnado puder resultar a **ineficácia da medida** [periculum in mora], caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

1.9.2 Requisitos para a concessão de tutela provisória

De acordo com o CPC/2015, o Livro V traz a denominada **Tutela Provisória**.

As **tutelas provisórias** são tutelas jurisdicionais **não definitivas**, fundadas na **cognição sumária** (exame superficial, baseadas no juízo de probabilidade), podendo fundar-se na **urgência** ou na **evidência**.

Uma vez **deferida a tutela provisória**, ela conserva sua **eficácia durante toda a pendência do processo**:

Art. 296. A tutela provisória **conserva sua eficácia na pendência do processo**, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Exatamente por ser provisória, **poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo**, por meio do surgimento de **novos elementos**, não considerados no momento da decisão que a deferiu, o que se revela possível, dado o fato de que a cognição a ser exercida pelo juiz ao longo do processo tende a aprofundar-se, tornando-se exauriente.

A **decisão que defere a tutela provisória**, a qual será substancialmente fundamentada (nos termos do art. 298 do CPC/2015), será efetivada aplicando-se, no que couber, as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

A **tutela provisória de urgência** pode ser requerida em caráter **antecedente** ou **incidente**.

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em **urgência** ou **evidência**.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, **cautelar** ou **antecipada**, pode ser concedida em **caráter antecedente** ou **incidental**.

A **tutela de evidência** é sempre requerida em **caráter incidental**. Quando a tutela provisória for requerida **incidentalmente** a um processo, será competente para examinar o requerimento o **juízo onde tramita o feito**.

No caso de **tutela de urgência antecedente**, será postulada ao juízo em tese competente para conhecer do **pedido principal**, que já ficará com sua competência fixada para posteriormente conhecer também deste:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Estabelece o art. 300 do CPC/2015 que a **tutela de urgência** será concedida desde que atendidos os pressupostos **formais e materiais**. São considerados **formais** o **requerimento da parte interessada**, a **prova inequívoca dos fatos** e o **abuso do direito de defesa**. Por **materiais** temos a **verossimilhança da alegação**, o **fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação**, o **manifesto propósito protelatório do réu** e a **irreversibilidade do direito aquinhado antecipadamente**.

O que deve ser **comprovado diretamente** passa a ser o **pressuposto material**, sendo que a tutela antecipada poderá ser requerida **antes da constituição definitiva do crédito tributário e posteriormente à sua constituição**.

A **principal finalidade** passa a ser a **suspensão da exigibilidade do crédito tributário**, nos termos do art. 151, V, do CTN, objetivando evitar a cobrança do crédito tributário.

1.9.3 Concessão de depósito do montante integral

Existem situações em que a **liminar ou a tutela provisória não podem ser concedidas** porque lhes faltam os requisitos legais ou ainda por determinação expressa da lei.

O art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016/2009 (norma que regulamenta o mandado de segurança) **veda a concessão de liminar** que tenha por objeto a **compensação de créditos tributários** ou a **entrega de bens e mercadorias provenientes do exterior**, além de outras vedações não afetas à matéria tributária.

A **mesma vedação** para a concessão de liminar **se estende à tutela antecipada**, conforme prevê o art. 7.º, § 5.º, da Lei 12.016/2009.

Um caso muito curioso é a situação da **liberação de mercadorias e bens provenientes do exterior**. Quando a mercadoria ou qualquer bem se encontra no

porto ou no aeroporto e precisa ser liberada, pela análise expressa da lei veda-se a concessão de liminar e de tutela antecipada. Nesse caso, como forma de se liberar a mercadoria ou bem, utiliza-se o **depósito do montante integral**, que terá a **finalidade de liberação imediata da mercadoria** com a consequente **suspensão à exigibilidade do crédito tributário**, nos termos do art. 151, II, do CTN.



Dica

De acordo com a Súmula 112 do STJ, o depósito que suspende a exigibilidade do crédito tributário deve ser integral e em dinheiro.

Nada obsta, entretanto, de o pedido do depósito ser **subsidiário**, mesmo quando se requer a concessão de liminar ou de tutela antecipada, uma vez que, caso o juízo competente entenda não ser possível a concessão de tais medidas, poderá deferir o depósito do montante integral, com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.



Note bem

Atualmente, os casos de liberação de mercadorias advindas do exterior, dependendo do caso em concreto, **acabam ocorrendo mediante a concessão de liminar**, pela **confrontação de princípios constitucionais**, tais como a **dignidade da pessoa humana** (art. 1.º, III, da CF/1988). É o que vemos quando **medicamentos que são necessários à saúde de determinados pacientes** são apreendidos por **motivos de greve dos agentes que pertencem à ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), sendo certo que os juízes concedem liminarmente a liberação desses medicamentos, levando em consideração os princípios constitucionais que estão sendo desobedecidos.

O **depósito do montante integral** somente suspenderá a exigibilidade do crédito tributário quando for **integral e em**

dinheiro, conforme determina a Súmula 112 do STJ.

*Assista ao **vídeo**
sobre o tema.*

<https://youtu.be/9RVw5x-3BAI>



MEDIDAS JUDICIAIS DE INICIATIVA DA FAZENDA PÚBLICA

Para que possamos tratar sobre as ações de iniciativa da Fazenda Pública, faz-se necessário o estudo conciso sobre o **crédito tributário**.

A doutrina define o **crédito tributário** como o **vínculo jurídico que surge com a ocorrência de uma obrigação tributária principal válida**, pelo qual o Estado pode exigir do particular o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária.

Com o surgimento da relação jurídico-tributária, temos a **existência de um débito e um crédito**. Apenas quando este (crédito tributário) for **formalizado a Fazenda Pública** terá o direito de exigir o seu cumprimento.

Assim, o que **dá a exigibilidade ao crédito tributário** é a figura jurídica do **lançamento**, já anteriormente estudado. Uma vez ocorrendo a **representação documental do crédito tributário** para o particular, a **Fazenda Pública** terá **condições de exigi-lo**, nos limites estabelecidos pela própria lei.

A partir do momento em que há a formalização, ele poderá ser exigido, cabendo ao Fisco as medidas competentes para a realização de sua cobrança.

Entre as medidas judiciais existentes a serem demandadas pela Fazenda Pública temos a **medida cautelar fiscal** e a **ação de execução fiscal**.

2.1 MEDIDA CAUTELAR FISCAL



A **medida cautelar fiscal** é um instrumento judicial acautelatório que visa **tornar indisponíveis os bens do sujeito passivo**, a fim de se **garantir o crédito fiscal**, sendo cabível em situações nas quais o Poder Público receia que não vai receber o crédito tributário em razão do seu montante, seja porque o patrimônio do devedor é reduzido, seja porque o comportamento do devedor enseja a fraude.



Note bem

A medida cautelar fiscal não tem cabimento quando pendente de processo administrativo sobre o respectivo tributo.

Sendo uma **medida cautelar**, poderá ser **preparatória** de uma ação principal ou mesmo **incidental**. Se for **preparatória**, seja considerada como ação principal a própria execução fiscal; se **incidental**, será ajuizada no curso do processo executivo.



Importante

A execução fiscal deverá ser ajuizada em **60 (sessenta) dias contados da constituição definitiva do crédito tributário**. Caso a execução não seja ajuizada, levará à cessação da eficácia da liminar.

Incidentalmente, a medida cautelar ajuizada no curso do processo de execução fiscal, quando houver **mais débitos tributários inscritos em dívida ativa que culminarão em outras execuções fiscais**, abrangerá esses créditos tributários.

A medida cautelar fiscal será requerida ao **juízo competente para a execução**

judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

Para que o juízo competente possa conceder a medida cautelar fiscal torna-se essencial:

I – a prova literal da constituição do crédito tributário;

II – a prova documental de alguns casos estabelecidos para a sua concessão.



Note bem

A medida cautelar fiscal poderá ser substituída, a qualquer tempo, por garantia prestada na forma do art. 9.º da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

A **cessação da medida cautelar fiscal** poderá ocorrer nos seguintes casos:

I – quando a execução fiscal não for proposta dentro do prazo de 60 (sessenta) dias;

II – se não for executada em 30 (trinta) dias;

III – se a execução fiscal for extinta;

IV – se o débito fiscal for quitado.

A Fazenda Pública **não poderá requerer novamente a medida cautelar se perder a eficácia por qualquer desses fundamentos** acima citados.

O requerimento da medida cautelar fiscal poderá ser feito **contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário**, quando o devedor:

I – sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;

II – tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;

III – caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;

IV – contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez de seu patrimônio;

V – notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal:

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade;

b) põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros;

VI – possui débitos, inscritos ou não em dívida ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;

VII – aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei;

VIII – tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta pelo órgão fazendário;

IX – pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

Sendo decretada pelo juízo competente, a medida cautelar fiscal **produzirá imediatamente a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação total dos créditos tributários.**

Tratando-se de **pessoa jurídica**, a indisponibilidade **recairá somente sobre os bens do ativo permanente**. Poderá, no entanto, estender-se aos **bens do acionista controlador** e aos bens dos que, em razão do contrato social ou estatuto social, tenham poderes para fazer com que a empresa cumpra com as obrigações fiscais.

Em suma, as **condições objetivas da propositura da medida cautelar fiscal** são:

- ✓ **a existência de crédito tributário ou não tributário** que se encontre constituído de modo regular em procedimento administrativo, isto é, de **crédito tributário ou não tributário** que se tenha tornado definitivo pela não mais existência de qualquer litígio administrativo ou judicial a respeito da sua existência;
- ✓ que o devedor, mesmo não possuindo domicílio certo, tenha se **ausentado ou tentado se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação**. A Fazenda Pública, especialmente se a medida for antes do curso da execução fiscal, há de demonstrar, por via judicial, que o devedor assim está se comportando;
- ✓ que o devedor, por ter caído em insolvência, tenha **alienado ou esteja tentando alienar bens que possui**, ou, se assim não estiver agindo, **tenha assumido ou tentado assumir dívidas extraordinárias**, ou **esteja pondo ou tentando pôr seus bens em nome de terceiro**, ou, por último, **esteja praticando qualquer outro ato tendente a frustrar a execução judicial da Dívida Ativa**;

- ✓ não obstante o devedor **tenha sido notificado pela Fazenda Pública para proceder ao recolhimento do crédito fiscal vencido, tenha deixado de pagá-lo no prazo legal sem oferecer garantia na via administrativa ou judicial.**

Da decisão que conceder liminarmente a medida cautelar fiscal caberá **agravo de instrumento**, observando-se o mesmo prazo e rito estabelecido pelo CPC. Não terá efeito suspensivo, salvo se, através de mandado de segurança, em decorrência de ilegalidade identificada no despacho do juiz, se conseguir o **efeito suspensivo em segundo grau**.

A parte passiva, na medida cautelar fiscal, tem o prazo de **quinze dias**, após ser citada, para **contestar o pedido**, oportunidade em que indicará as provas que irá produzir.

A ausência de contestação resulta na presunção de que são verdadeiros os fatos alegados pela Fazenda Pública. Ocorre que a presunção de veracidade há de ser acolhida se os fatos tiverem sido apontados com base em prova documental.

Caso haja a contestação do devedor, o procedimento deverá obedecer ao **princípio do contraditório**, com observância do **procedimento comum**, respeitando-se o **princípio da ampla defesa** e da **livre investigação das provas**.

Se, no curso de medida cautelar fiscal decretada, o contribuinte prestar **garantia correspondente** ao valor da pretensão da Fazenda Pública, ficarão **extintos os seus efeitos**. Basta o juiz, após ouvir a Fazenda Pública, no **prazo de cinco dias**, declarar expressamente nos autos.

Tal garantia, que tem a força de extinguir os efeitos sentenciais da medida cautelar fiscal, observa o disposto no art. 9º da Lei 6.830/1980:

Art. 9º Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:

I — efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II — oferecer fiança bancária;

III — nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11;
ou

IV — indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2º Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 4º Somente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5º A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições preestabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6º O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

Os autos do procedimento cautelar fiscal devem sempre permanecer apensados aos do processo de execução judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Não é permitido ao juiz mandar desapensá-los e colocá-los em arquivo separado. Eles integram, mesmo que a medida tenha perdido a eficácia, os atos processuais que foram examinados e que resultaram na solução ditada pela sentença final.

Conforme estabelece o art. 15 da Lei 6.830/1980:

Art. 15 O indeferimento da medida cautelar fiscal não obsta a que a Fazenda Pública intente a execução judicial da Dívida Ativa, nem influi no julgamento desta, salvo se o Juiz, no procedimento cautelar fiscal, acolher alegação de pagamento, de compensação, de transação, de remissão, de prescrição ou

decadência, de conversão do depósito em renda, ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida.

2.1.1 Modelo de medida cautelar fiscal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ... VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE ...

(espaço de cinco linhas)

MUNICÍPIO DE ..., pessoa jurídica de direito público interno, com sede na ..., n. ..., neste ato representado por meio de seu procurador infra-assinado, conforme decreto anexo e consoante com o disposto no inc. III do art. 75, do Código de Processo Civil de 2015, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento na Lei 8.397/1992, propor a presente

MEDIDA CAUTELAR FISCAL

em desfavor de ..., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., com sede na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ..., na pessoa de seu representante legal, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

O Requerido é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme respectivas inscrições na Dívida Ativa nº ..., perfazendo um montante total no valor de R\$... decorrente de débitos de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujas Execuções Fiscais encontram-se em curso perante este Douto Juízo competente.

(...)

II – DO DIREITO

(...)

Da concessão de medida liminar

(...)

III – DO PEDIDO

Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência:

a) a distribuição da presente medida por dependência à Execução Fiscal nº ..., em curso perante esse Douto Juízo;

b) seja-lhe concedida a liminar, para a imediata indisponibilidade de (citação dos bens que devem ser indicados para a indisponibilidade), face à urgência e relevância da medida, antes da citação do requerido;

c) a citação do Requerido, para apresentar contestação no prazo legal, indicando as provas

que pretende produzir;

d) a expedição de imediato ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, com o fito de tornar o bem indisponível;

e) seja, ao final, julgado procedente o presente pedido, ratificando a liminar pleiteada, com a consequente desconstituição dos eventuais atos praticados pelo Requerido;

f) a condenação do Requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e decorrentes da sucumbência.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela prova documental que ora está acostada, bem como outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

V – VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Nome e assinatura do Procurador

OAB... n. ...

2.2 EXECUÇÃO FISCAL



Entende-se por **execução fiscal** o processo judicial para cobrança dos créditos tributários e não tributários da Administração Pública. Consiste num **conjunto de atos sucessivos e coordenados** destinados à **realização de um direito**, consubstanciado no **título executivo**. A Lei 6.830/1980 trata acerca da execução fiscal.

Trata-se de uma inspiração nos moldes do processo inquisitorial, em que o **juiz**

passa a ter **protagonismo processual**. Com o CPC de 2015, temos um **modelo cooperativo**. Com isso, adotamos **cinco deveres fundamentais**:

- ✓ dever de inquisitorialidade;
- ✓ dever de prevenção ou advertência;
- ✓ dever de esclarecimento;
- ✓ dever de diálogo; e
- ✓ dever de auxílio das partes.

Pelo **dever de inquisitorialidade**, o juiz deve valer-se de seus poderes inquisitórios na busca da verdade dos fatos. Esse dever há de incidir mais fortemente nos **embargos à execução fiscal**, como também nas **ações anulatórias**, exigindo do juiz um **comportamento ativo na revelação da verdade**, podendo, nos termos do art. 370, “*de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito*”.

O **dever de prevenção ou advertência** determina que o juiz deve prevenir as partes sobre a **falta de pressupostos processuais sanáveis** e sobre **irregularidades ou insuficiências das suas peças ou alegações**. Em razão disso, **incide no processo de execução fiscal** o art. 139, IX, do CPC, segundo o qual incumbe ao juiz “*determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais*”, como também o art. 317, que estabelece o amplo dever do juiz de “*conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício*”, **antes de proferir decisão sem resolução de mérito**.

O **dever de esclarecimento** impõe ao juiz o dever de esclarecer-se junto das partes quanto às **dúvidas que tenha sobre as suas alegações, pedidos ou posições**. Assim, nos termos do art. 139, VIII, do CPC, incumbirá ao juiz “*determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa*”, não havendo qualquer razão para que esse dever não seja aplicado no âmbito da execução fiscal.

No que tange ao **dever de diálogo**, exige-se que o juiz ouça as partes sempre que pretenda conhecer de matéria de fato ou de direito, ainda que cognoscíveis de ofício, sobre a qual aquelas não tenham tido a possibilidade de se pronunciar, abstando-se de proferir as chamadas **decisões-surpresa**. Essa fundamental exigência consta do art. 10 do CPC, sendo também um preceito plenamente aplicável no âmbito da execução fiscal.

E, por fim, o **dever de auxílio das partes** estabelece que o juiz busque auxiliar as partes na remoção das dificuldades ao exercício dos seus direitos ou faculdades ou no cumprimento dos seus ônus e deveres processuais. Esse dever está consagrado no art. 139, inciso VI, consoante o qual incumbe ao juiz *“dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”* e também no inciso IV, por meio do qual cabe ao juiz *“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”*.

A Fazenda Pública somente poderá proceder à execução fiscal caso haja um **débito tributário vencido e não pago**. Como vimos, o crédito tributário se torna **exigível** mediante o **lançamento**. No entanto, se torna **exequível** mediante a **inscrição do crédito tributário em dívida ativa**.

A petição inicial de execução fiscal passa a ter o mesmo procedimento do processo de execução comum. Deve-se atender ao disposto no art. 6.º da Lei 6.830/1980, sabendo-se que a **prova do título executivo a execução fiscal é pré-constituída**. A Fazenda Pública deverá extrair o título executivo extrajudicial, que é a **certidão de dívida ativa (CDA)**, para compor a execução fiscal.

A **inscrição do crédito tributário em dívida ativa** é um procedimento administrativo interno e vinculado, sob pena de, não observado o disposto nos arts. 201 e seguintes do CTN e no art. 2.º da Lei 6.830/1980, sofrer nulidade.

A inscrição em dívida ativa é dotada de **presunção de certeza e liquidez**, podendo ser **elidida por meio de embargos à execução**. Uma vez ajuizada a execução fiscal, o devedor será citado para realizar o pagamento no prazo de **5 (cinco) dias** ou **nomear bens para garantia do juízo**.

Caso o executado não garanta, de **maneira espontânea**, o crédito tributário, o **juízo será garantido de maneira coercitiva**, podendo atingir quaisquer bens, rendas ou direitos do executado, ficando fora somente os bens absolutamente impenhoráveis, conforme denota o art. 184 do CTN.

Não deverão ser requeridas provas na execução fiscal, uma vez que o **título extrajudicial serve justamente para comprovação do direito do crédito**. No que tange ao valor da causa, o **valor da execução fiscal será o valor do débito atualizado**.

A competência para o ajuizamento da execução fiscal será o **foro do domicílio do devedor**. Sendo os **tributos estaduais e municipais**, a competência será da **Justiça Estadual**. Já se o devedor estiver em débitos com **tributos federais**, a competência será da **Justiça Federal**.



Dica

Nos casos de execuções fiscais de débitos de contribuições sociais de segurados obrigatórios, não havendo foro do domicílio do devedor na subseção da Justiça Federal, a ação será movida perante a Justiça Estadual (art. 109, § 3.º, CF/1988).

Podem figurar como **sujeitos ativos** da execução fiscal **todas as pessoas jurídicas de direito público interno** (U – E – DF – M), bem como suas **autarquias**.

Anteriormente, se traduzia a possibilidade de figurar no polo ativo os **entes paraestatais**, expressão essa que se encontra em desuso, uma vez que traduz a possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado, excepcionalmente, exercerem a capacidade tributária ativa, como ocorria no caso dos serviços sociais autônomos. Com o advento da Lei 11.457/2007, as contribuições do sistema “S” são arrecadadas e administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão público federal.

Já no **polo passivo** figuram diretamente o **contribuinte** ou o **responsável**, podendo a execução fiscal ser requerida também em face do fiador, espólio, massa falida e as demais pessoas elencadas no art. 4.º da Lei 6.830/1980.

2.2.1 Homologação de decisões estrangeiras em execução fiscal

O art. 961, § 4º, do CPC/2015 dispõe que *“haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira”*.

Trata-se de matéria que afeta duplamente a ordem pública e a soberania nacional, considerando que:

(i) são pronunciamentos judiciais praticados em execuções fiscais derivadas da cobrança de tributos de outro país contra brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil;

e

(ii) há possibilidade de expropriação de dinheiro, ativos financeiros e bens móveis localizados no território nacional para a satisfação de crédito de Estado estrangeiro.

A prática de determinados atos executivos determinados em processo estrangeiro, ainda quando submetidos ao **procedimento de homologação de sentença**, dependem de **autorização prévia em tratados internacionais** ou que, pelo menos, exista a **promessa de reciprocidade**.

Como o Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais, tanto em matéria tributária quanto cível, principalmente na **recuperação de ativos**, isso enseja a possibilidade de execução fiscal. Após a concessão do *exequatur*, sendo a decisão (seja interlocutória ou sentença) estrangeira homologada, passa a ser **título executivo judicial** e é cumprida na **Justiça Federal de 1ª Instância**.

2.2.2 Modelo de execução fiscal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL DA S
JUDICIÁRIA DE ...

(espaço de cinco linhas)

A FAZENDA NACIONAL, pessoa jurídica de direito público interno, por meio de seu representante infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 784 e art. 515, do Código de Processo Civil de 2015 e Lei 6.830/1980, bem como as demais disposições aplicáveis, propor a EXECUÇÃO FISCAL

A dívida ativa correspondente ao título anexo n. ..., que faz parte integrante desta petição inicial, no valor de R\$... (valor por extenso), contra ...(qualificação completa), com domicílio fiscal na ...(endereço completo).

Requer, ainda, a citação do devedor para pagar o débito, no prazo legal, com juros, custas e demais encargos legais, ou garantir a execução, sob pena de penhora ou arresto, e a intimação do cônjuge, caso a constrição recaia sobre o imóvel.

Dá à causa o valor da dívida acrescida de encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Nome e assinatura do procurador

OAB/ ... n.

MEDIDAS JUDICIAIS DE INICIATIVA DO SUJEITO PASSIVO



O **sujeito passivo da obrigação tributária** tem o direito constitucional e legítimo de apresentar mecanismos de defesa judiciais contra possíveis abusos praticados pelo Estado.

Dentre as peças processuais que podem ser utilizadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, destacamos as seguintes medidas judiciais:

- I – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária;**
- II – Ação Anulatória de Débito Fiscal;**
- III – Ação de Repetição de Indébito Fiscal;**
- IV – Ação de Consignação em Pagamento;**
- V – Mandado de Segurança;**
- VI – Ação Cautelar;**
- VII – Embargos à Execução Fiscal;**
- VIII – Exceção de Pré-Executividade;**
- IX – Recursos.**

Para tanto, analisaremos cada uma das medidas judiciais, indicando os aspectos

principais.

3.1 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA

3.1.1 Principais características

Nessa ação, o interesse direto do autor é limitado à declaração de **existência** ou d e **inexistência** de relação jurídico-tributária, determinada no art. 19, I, do CPC/2015.

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:
I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;
II – da autenticidade ou da falsidade de documento.

Assim, a principal característica da ação é de **dirimir determinada incerteza jurídica que paira sob determinada relação jurídica**.

A declaração que se pretende pode ser tanto **positiva** (quando se deseja determinar o direito a um incentivo fiscal, por exemplo, uma isenção) ou **negativa** (quando se quer que o juízo competente determine que a relação não existe por alguma razão).

Mesmo na possibilidade de se declarar o direito a uma isenção, o contribuinte, por si só, estabelece que a relação jurídico-tributária em razão daquele benefício **deixe de existir**. Sendo assim, mesmo quando se quer o direito a uma isenção, a uma imunidade, é possível a determinação por meio de uma **declaração de inexistência da relação jurídico-tributária**, isto porque a relação tributária deixa de existir tendo em vista o direito a um benefício ou desoneração tributária.

O momento oportuno para a propositura dessa ação se dá **antes da constituição definitiva do crédito tributário**, ou seja, **antes do lançamento**.

Geralmente, o lançamento vem consubstanciado em forma de **notificação de débito**, **aviso de lançamento**, **imposição de um auto de infração** e **imposição de multa (AIIM)** ou ainda **por meio da inscrição em dívida ativa**. Assim, pela regra

geral, o **momento oportuno se dá antes do efetivo lançamento.**

Trata-se de uma peça processual em que se admite a **tutela provisória antecipada**, em regra de **urgência**, sendo que o rito da ação declaratória pode ser **ordinário** ou **sumário**. Só será admitida ação declaratória originária, não tendo cabimento qualquer ação declaratória incidental pelo rito sumário.

3.1.2 Cabimento

Tal ação tem o seu cabimento quando não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, **antes do lançamento tributário.**

3.1.3 Competência

A competência para julgamento da medida judicial será determinada de acordo com o tributo em questão (competência material), salvo os casos de competência absoluta em razão da pessoa (competência processual), em que será deslocada para a **Justiça Federal**, independentemente do tributo em questão. Sendo federal, o encaminhamento da medida se fará perante uma das varas da Justiça Federal; sendo tributos estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual.

Temos, então:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)

3.1.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada

A **ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária** tem como fundamento os arts. 19, I, e 319, ambos do CPC/2015, conforme quadro apontado supra. Uma vez que em tal ação **tem cabimento a tutela provisória antecipada de urgência**, será colocado como fundamento o art. 300 do CPC/2015.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente, poderá ser requerida a autorização do depósito do montante integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Para os candidatos do exame da OAB, não há necessidade do pedido subsidiário somente do pedido de tutela provisória antecipada de urgência, quando houver cabimento.

Assim, teremos como nomenclatura adequada: **Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de tutela provisória antecipada de urgência**.



Importante

Para o exame da OAB, o pedido de tutela antecipada não acarreta ao candidato perda de pontuação, mesmo que não seja diretamente cabível, mas, sendo cabível, sua falta poderá acarretar graves prejuízos.

Nesse sentido, partimos do entendimento que a tutela antecipada **sempre poderá ser requerida na ação declaratória**, salvo nos casos vedados por lei.

3.1.5 Pedido

O pedido da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária passa a ser um pedido simples, podendo conter os seguintes itens:

I – a concessão de tutela provisória antecipada de urgência (quando for requerida), nos termos do art. 300 do CPC/2015, para os fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, V, do CTN;

II – procedência do pedido, para os fins de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Autor(a) e Réu(Ré), nos termos dos artigos (neste caso, o candidato da OAB deverá indicar quais os artigos que foram utilizados na fundamentação do direito);

III – a citação do ente público, na pessoa de seu representante judicial, para apresentar a contestação no prazo legal;

IV – a condenação do ente público competente às custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão do crédito público consistir um bem público indisponível.

Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015.”

3.1.6 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem ser trazidas na petição inicial, com o fim de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

Sendo assim, as provas poderão ser apresentadas da seguinte forma:

Protesta provar todo o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela prova documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da seguinte forma:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

3.1.7 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.
Advogado(a)
OAB/ ... n.º ...

3.1.8 Modelo de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória antecipada de urgência

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL (OU FEDERAL) DA SEÇÃO (OU DA SUBSEÇÃO) JUDICIÁRIA DE ...

(espaço de cinco linhas)

EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional d
Pessoas Jurídicas sob o n. ..., possuindo sede na ..., n. ..., bairro ..., cidade ..., por seu
advogado e bastante procurador que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com

escritório na ..., bairro, ..., cidade ..., onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 19, I, 319 e 300 do Código de Processo Civil de 2015, opor a presente

**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA**

em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ..., na pessoa de seu representante legal (procurador ou representante judicial), pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DOS FATOS

A Autora vem recolhendo regularmente os débitos tributários referentes ao IRPJ de acordo com a legislação vigente.

No entanto, o Decreto regulamentar ... majorou as alíquotas do IRPJ e determinou seu pagamento a partir da data da publicação do mencionado ato normativo. Esta exigência surpreendeu a Autora, não restando alternativa senão a propositura da presente Ação.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento da medida judicial

A medida judicial mostra-se adequada ante a inexistência de lançamento tributário, nos termos do art. 19, I, do CPC, autorizando a utilização da medida visando o afastamento da existência de relação jurídico-tributária entre a Autora e a Ré.

b) Do mérito

O IR é um tributo de competência da União Federal, conforme preleciona a Constituição Federal nos termos do art. 153, III.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal, o qual consagra o princípio da legalidade, nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem lei que o estabeleça.

O art. 150, III, “b”, da Constituição Federal estabelece que nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o aumentou ou instituiu. Esse é o denominado princípio da anterioridade, sendo que, atualmente, por motivos da segurança jurídica, além de respeitar o exercício seguinte, entre determinado exercício e o próximo observar uma lapso temporal de 90 (noventa) dias, apesar de não enquadráveis ao IRPJ, por se constituir exceção expressa no art. 150, § 1.º, da Constituição Federal.

Com efeito, todos os tributos devem atender tais princípios, ressalvadas as exceções previstas no próprio texto da Constituição, sob pena de violarem o princípio da supremacia constitucional.

O IRPJ não está incluído entre as exceções aos princípios da legalidade e anterioridade estatuídas nos arts. 150, § 1.º, e 153, § 1.º, da Constituição Federal.

Assim, fica evidenciado que o Decreto regulamentar, ao majorar a alíquota do IRPJ, exigindo ainda, seu pagamento, a partir dessa publicação, contraria dois princípios fundamentais: o da legalidade, que é genérico para todo o decreto, e o da anterioridade, que é específico do direito tributário, revestindo-se de manifesta inconstitucionalidade.

c) Da concessão de Tutela Provisória Antecipada de Urgência

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 são pressupostos autorizadores da tutela antecipatória: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão da tutela provisória antecipada de urgência justifica-se, pois a violação dos princípios da legalidade e da anterioridade é uma prova cristalina da probabilidade do direito do pedido da Autora.

Por sua vez, como o IRPJ é lançado por homologação, e a data do recolhimento apresenta-se iminente, a Autora está sujeita imediatamente a um crédito tributário maior que o devido. Tal fato demonstra perigo de dano.

Ao final, requer-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

III – DO PEDIDO

Pelo exposto, a Autora requer à Vossa Excelência:

a) a concessão da tutela jurisdicional antecipada de urgência, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, afastando, assim, a exigência quanto à majoração de alíquota do IRPJ, pois a probabilidade do direito e o perigo de dano foram demonstrados, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional;

b) o julgamento procedente do pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária com a União, em relação à majoração da alíquota de IRPJ, em face da violação dos princípios da legalidade e da anterioridade e, por fim, confirmando-se a tutela anteriormente concedida;

c) a citação da União, no endereço já declinado e na pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar contestação e acompanhá-la até o seu final;

d) a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios;

e) a dispensa de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do D. Juízo.

VI – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,

pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.

REVISÃO DA ESTRUTURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA

- Endereçamento
- Qualificação do Autor
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do Réu
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito:
 - após a exposição dos fundamentos de direito, deverá ser aberto um tópico para a explicação da tutela provisória antecipada de urgência
- Do pedido
- Das provas
- Do valor da causa
- Desfecho

3.2 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE

INDÉBITO FISCAL

3.2.1 Principais características

Trata-se de uma **ação declaratória cumulada com uma ação de repetição de indébito**, tendo cabimento quando o sujeito passivo julga estar pagando um tributo de **maneira devida**, mas, por algum **fato superveniente**, o pagamento do tributo poderá se tornar indevido, desde que o juízo competente, inicialmente, declare a inexistência da relação jurídico-tributária para, conseqüentemente, tornar a exigência tributária indevida e condenar a Fazenda à devolução dos valores pagos indevidamente, monetariamente corrigidos.

Quando o sujeito passivo tem direito a uma isenção, uma imunidade, e recolhe o tributo, este recolhimento se torna indevido tão somente se o contribuinte o requerer perante o órgão ou juízo competente. Para fazer valer o seu direito, ele precisa que o juízo declare que a relação jurídica entre o sujeito passivo e o pagamento do tributo se tornou **indevida** tendo em vista a existência de tais benefícios fiscais.

Mesmo que o juízo tenha decidido que determinado tributo não seja devido em sede de controle difuso ou concentrado para outro contribuinte, este poderá se fazer valer dessa decisão para pleitear a declaração de inexistência da relação jurídica cumulada com a devolução dos valores pagos indevidamente, solicitando que a decisão proferida se estenda ao caso concreto, caso não seja uma decisão em **repercussão geral e vinculante**.

Neste caso, quando o sujeito passivo ingressar com pedido cumulativo (declaratória com repetitória), deverá observar o prazo estabelecido para a restituição, qual seja **cinco anos contados do pagamento realizado** (extinção do crédito tributário).

Para que o juízo possa admitir tal ação, faz-se necessária a **juntada do comprovante do pagamento do tributo considerado indevido**, que passa a ser considerado **condição de admissibilidade da referida ação**.

3.2.2 Cabimento

Esta medida judicial tem cabimento **após a ocorrência do pagamento de um tributo supostamente devido que, por um fato superveniente, venha a ser declarado como indevido**. Sendo assim, o lançamento já ocorreu, o tributo já está

sendo pago e o sujeito passivo apenas se apercebe posteriormente que a prestação tributária é indevida.

3.2.3 Competência

A competência para julgamento da medida judicial será determinada de acordo com o tributo em questão. Sendo federal, o encaminhamento da medida se fará perante uma das varas da Justiça Federal; sendo tributos estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual.

Temos, então:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)

Entretanto, temos uma observação extremamente relevante quando a **competência tributária** é atribuída a determinado ente federativo, mas a **capacidade tributária ativa** (arrecadação e fiscalização de tributos) pertence a outra entidade da federação.

É o que ocorre com as **repartições de receitas tributárias e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)**. De acordo com os arts. 157, I, e 158, I, da CF/1988, a receita do imposto decorrente da renda paga pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como das autarquias e fundações públicas vinculadas a estas próprias entidades pagadoras, pertencem a elas.

Assim, caso o imposto de renda seja descontado indevidamente pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a ação deverá ser movida perante a **Justiça Estadual**.

De igual modo, reza a Súmula 447 do STJ:

“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas da ação de restituição de

imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

Podemos concluir que toda vez que ocorrer a retenção na fonte do Imposto de Renda pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, **ações declaratórias de inexistência de relação jurídico-tributária com repetição de indébito**, bem como as **ações de repetição de indébito fiscal propriamente ditas**, deverão ser ajuizadas perante a **Justiça Estadual** da localidade onde ocorreu o pagamento indevido.

A inteligência da súmula acima indicada pode ser utilizada nos casos de **transferência de capacidade tributária ativa** do Imposto Territorial Rural (ITR) da União para os Municípios. Se o que se pretende discutir é a arrecadação ocorrida de forma indevida, a competência para julgamento será da **Justiça Estadual**; isto porque os Municípios permanecem com 100% do produto do ITR arrecadado.

Caso o sujeito passivo possua créditos tributários passíveis de compensação tributária, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/1991 e do art. 74 da Lei 9.430/1996, poderá requerer, em vez da repetição dos valores, a **compensação tributária**, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN.

Importante ressaltar a alteração introduzida pela Lei 13.670/2018, inserindo o art. 26-A na Lei 11.457/2007, devido à introdução do e-Social. Tal norma versa, entre outros temas, sobre a unificação dos órgãos públicos de arrecadação federal, criando a denominada **Super Receita**.

Nesse caso, todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil admitem **compensação**, porém é necessário observar o art. 26-A da referida Lei.



Dica

O candidato somente indicará a compensação no caso de o problema apontar a existência de um **débito** e um **crédito** com a mesma pessoa jurídica de direito público. Em se tratando de tributos federais, a legislação determina que todos os tributos arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil podem ser objeto de compensação.

Porém, em se tratando de tributos estaduais e municipais, há necessidade de autorização legislativa expressa.



Note bem

De acordo com a Súmula 212 do STJ, “a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória”.

3.2.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada

A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com repetição de indébito fiscal tem como fundamento os arts. 19, I e 319, ambos do CPC/2015, e art. 165 do CTN. Uma vez que em tal ação tem cabimento a tutela provisória antecipada de urgência, será colocado como fundamento o art. 300 do CPC/2015. Subsidiariamente, poderá ser requerida a autorização do depósito do montante integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.



Note bem

Nesta ação, torna-se imprescindível o candidato demonstrar que a guia do pagamento do tributo indevido está trazida na petição inicial, sob pena de indeferimento da ação.

Assim, teremos como nomenclatura adequada: **Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito Fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência.**



Importante

Para o exame da OAB, o pedido de tutela provisória antecipada de urgência não acarreta ao candidato perda de pontuação, mesmo que não seja diretamente cabível, mas, sendo cabível, sua falta poderá acarretar graves prejuízos.

Nesse sentido, partimos do entendimento que a tutela provisória

antecipada de urgência **sempre poderá ser requerida na ação declaratória, mesmo cumulada com repetição de indébito fiscal**, salvo nos casos vedados por lei.

3.2.5 Pedido

O pedido da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito fiscal passa a ser um pedido simples, devendo conter os seguintes itens:

I – a concessão de tutela provisória antecipada de urgência (quando for requerida), nos termos do art. 300 do CPC/2015, para os fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, V, do CTN (deverá o candidato requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sempre indicando o seu fundamento, ou seja, para que deseje a suspensão. Neste caso, poderá ser para os fins de evitar o ajuizamento da execução fiscal);

II – procedência do pedido, para os fins de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Autor(a) e Réu (Ré), nos termos dos artigos (neste caso, o candidato da OAB deverá indicar quais os artigos que foram utilizados na fundamentação do direito), e a consequente devolução dos valores pagos indevidamente, com as correções legais, nos termos do art. 165 do CTN (o sujeito passivo poderá requerer, em vez da devolução dos valores, a compensação tributária, desde que observe alguns dos casos previstos no art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996);

III – a citação do ente público, na pessoa de seu representante judicial, para apresentar a contestação no prazo legal;

IV – a condenação do ente público competente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em

razão de o crédito público consistir um bem público indisponível. Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015 ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015”.

3.2.6 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem ser trazidas na petição inicial para os fins de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

Sendo assim, as provas poderão ser indicadas da seguinte forma:

Protesta provar todo o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente pela prova documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da seguinte forma:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

3.2.7 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.
Advogado(a)
OAB/ ... n. ...

3.2.8 Modelo de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL (OU FEDERAL) DA SEÇÃO (OU DA SUBSEÇÃO) JUDICIÁRIA DE ...

(espaço de cinco linhas)

EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n...., possuindo sede na ..., n. ..., bairro ..., cidade ..., por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com escritório na ..., bairro, ..., cidade ..., onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103, do Código de Processo Civil de 2015, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 19, I, combinado com os arts. 300 e 319 do Código de Processo Civil de 2015, e no art. 165 do Código Tributário Nacional, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na, bairro ..., cidade ..., Estado ..., na pessoa de seu representante legal (procurador ou representante judicial), pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DOS FATOS

A Autora vem recolhendo regularmente os débitos tributários referentes ao IRPJ de acordo com a legislação vigente.

No entanto, percebeu a Autora que o recolhimento realizado estava abarcado pela existência de uma isenção, instituída pela Lei n., que previa a isenção de pessoas jurídicas que atendessem os critérios ali estabelecidos.

Com o fito de abster-se de recolher o IRPJ indevidamente e ter a restituição dos valores já recolhidos indevidamente, vem a Autora propor a presente ação.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento da medida judicial

A Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito Fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência mostra-se cabível, visto que há possibilidade de o tributo tornar-se indevido, ante a declaração jurisdicional de inexistência de relação jurídico-tributária, requerendo-se a tutela provisória antecipada de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto o mérito não for definitivamente julgado, evitando-se o ajuizamento de execução fiscal.

b) Do mérito

O IR é um tributo de competência da União Federal, conforme preleciona a Constituição Federal nos termos do art. 153, III.

A Fazenda Nacional, entretanto, vinha procedendo ao recolhimento indevido do referido imposto, uma vez que a Autora faz jus à isenção.

A isenção tributária passa a ser um benefício fiscal concedido mediante lei específica, excluindo o crédito tributário, conforme prevê dispositivo no art. 175 e ss. do Código Tributário Nacional.

A Lei ... prevê a possibilidade de isenção tributária mediante observância dos requisitos ali traduzidos. Conforme se depreende dos documentos em anexo, a Autora tem o direito à concessão da isenção desde o seu início, sendo que o recolhimento do IRPJ efetuado no período deve ser declarado insubsistente.

Inexistindo a relação jurídico-tributária, todo o recolhimento realizado durante o período passa a ser indevido, devendo a Ré abster-se, primeiramente, dos recolhimentos e realizar a devolução dos valores que foram pagos, de maneira indevida.

Prevê o art. 165 do Código Tributário Nacional que o sujeito passivo tem o direito independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento. Tal devolução é consubstanciada nos ditames do inc. I do mesmo artigo, que disciplina a devolução nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.

Ademais, a Autora está pleiteando a devolução de maneira tempestiva, pois ainda não se extinguiu o direito pelo decurso temporal de cinco anos, trazido no art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

c) Da concessão de Tutela Provisória Antecipada de Urgência

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, são pressupostos autorizadores da tutela antecipatória: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão da tutela provisória antecipada de urgência justifica-se, pois a Autora possui o direito ao benefício da isenção, nos termos da Lei ..., não devendo ocorrer o recolhimento do

IRPJ.

Por sua vez, como o IRPJ é lançado por homologação, sendo os recolhimentos já efetuados requer a Autora que os recolhimentos não sejam mais efetuados. No entanto, enquanto o mérito não seja julgado, requer a concessão da tutela provisória antecipada de urgência para se evitar a inscrição do referido tributo em dívida ativa, com a consequente execução fiscal. Tal fato demonstra o receio de perda financeira.

Por fim, requer-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

III – DO PEDIDO

Pelo exposto, a Autora requer à Vossa Excelência:

a concessão da tutela jurisdicional antecipada de urgência, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano foram demonstrados;

o julgamento procedente do pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária com a União, nos termos da Lei ..., com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente, conforme art. 165 do Código Tributário Nacional com todos os encargos legais, confirmando-se a tutela anteriormente concedida;

c) a citação da União, no endereço já declinado e na pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar contestação e acompanhá-la até o seu final;

d) a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios;

e) dispensa da audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do D. Juízo.

V – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n. ...



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o

examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.

REVISÃO DA ESTRUTURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL

- Endereçamento
- Qualificação do Autor
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do Réu
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito:
 - após a exposição dos fundamentos de direito, deverá ser aberto um tópico para a explicação da tutela provisória antecipada de urgência e exposição dos motivos da restituição dos valores pagos indevidamente.
- Do pedido
 - Das provas (indicar, obrigatoriamente, o comprovante de pagamento do tributo indevido mediante a apresentação das guias)
- Do valor da causa
- Desfecho

3.3 AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

3.3.1 Principais características

A ação anulatória de débito fiscal passa a ser, segundo a melhor doutrina, uma espécie de ação declaratória negativa, no qual efetivamente se requer o

reconhecimento da inexistência de uma dívida tributária que está consubstanciada em determinado lançamento tributário.

A estrutura da ação anulatória passa a ser a mesma da ação declaratória. No entanto, a ação anulatória dependerá da juntada de documentos que são indispensáveis ao próprio processo. Dentre os documentos fundamentais, encontra-se o lançamento, que poderá vir por meio de uma **notificação de débito, aviso de lançamento, de um auto de infração e imposição de multa (AIIM) ou ainda de uma inscrição em dívida ativa.**

Assim, a ação anulatória tem a sua base quando o crédito tributário já se encontra regularmente constituído. Para que se constitua o crédito tributário, sendo na modalidade de lançamento de ofício, a Fazenda Pública expede a notificação de lançamento pela via postal ou realiza a entrega pessoal ao sujeito passivo.

Para que o lançamento seja considerado válido, deverá trazer todos os elementos contidos no art. 142 do CTN. Sendo procedimento administrativo vinculado, a falta de qualquer elemento elencado na lei torna o ato viciado, devendo ser anulado.

É cabível também uma espécie de ação anulatória de ato administrativo que indefira o **pedido de restituição de tributo pela via administrativa.** Essa ação anulatória tem fundamento no art. 169 do CTN. Tal ação apresenta uma melhor utilidade processual quando for cumulada com o pedido de restituição do tributo ou com a compensação de tributos.

3.3.2 Cabimento

A ação anulatória tem o seu cabimento **após a constituição definitiva do crédito tributário**, ou seja, **após o lançamento e, pela regra geral, antes do ajuizamento da execução fiscal.**

No entanto, admite-se a ação anulatória mesmo quando **já existe uma execução fiscal**, mas ainda **não ocorreu a citação do executado**, não se formando, ainda, o processo executivo.



Dica

Para que o candidato promova a ação anulatória quando já ajuizada a execução fiscal, o problema deverá indicar de maneira expressa a ausência da citação do devedor, uma vez que não se

pode presumir a ausência de citação para o ajuizamento da referida ação.

É possível o cabimento da ação anulatória **logo que o sujeito passivo seja notificado do débito tributário e deste não concorde**. No entanto, o fato de ingressar com a medida judicial **não impedirá a Fazenda Pública de prosseguir com a inscrição do débito tributário existente em dívida ativa e propor a consequente execução fiscal**. Para que ocorra a **suspensão da exigibilidade do crédito tributário**, faz-se necessário o contribuinte pleitear e obter algumas das situações estabelecidas no art. 151 do CTN.



Note bem

Quando o sujeito passivo ingressa com a ação anulatória **estará abrindo mão do processo administrativo fiscal**, mesmo que já tenha sido iniciado. É o que versa o parágrafo único do art. 38 da Lei 6.830/80.

3.3.3 Competência

A competência para o julgamento da medida judicial será determinada de acordo com o tributo em questão, salvo nos casos de competência absoluta em razão da pessoa, cuja competência será deslocada perante a **Justiça Federal**. Sendo federal, o encaminhamento da medida se fará perante uma das varas da Justiça Federal; sendo tributos estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual.

Temos, então:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando

Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)
--	---

3.3.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada

A ação anulatória de débito fiscal tem como fundamento o art. 38 da Lei 6.830/1980 e 319 do CPC/2015. Uma vez que para tal ação tem cabimento a tutela provisória antecipada de urgência, será colocado como fundamento o art. 300 do CPC/2015.

Assim, teremos como nomenclatura adequada: **Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência.**

Para que o sujeito passivo possa ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se faz necessário o depósito do montante integral, mesmo pela análise do art. 38 da Lei 6.830/80. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou a **Súmula Vinculante 28**, que torna inconstitucional qualquer exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário.

Poderá o sujeito passivo realizar, no bojo da ação, o pedido de concessão de tutela provisória antecipada de urgência, mediante atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC/2015, conforme anteriormente analisado.

No entanto, **caso não haja cabimento de tutela provisória antecipada de urgência** pela falta de atendimento dos requisitos legais ou por vedação expressa da lei, **o sujeito passivo poderá realizar o depósito do montante integral** para fazer jus à **suspensão da exigibilidade do crédito tributário**, nos termos do art. 151, II, do CTN.



Importante

Para o exame da OAB, o pedido de tutela provisória antecipada de urgência não acarreta ao candidato perda de pontuação, mesmo que não seja diretamente cabível, mas, sendo cabível,

sua falta poderá acarretar graves prejuízos.

Nesse sentido, partimos do entendimento que a tutela provisória antecipada de urgência **sempre poderá ser requerida na ação anulatória**, salvo nos casos vedados por lei.

3.3.5 Pedido

O pedido da ação anulatória de débito fiscal passa a ser um pedido simples, devendo conter os seguintes itens:

I – a concessão de tutela provisória antecipada de urgência (quando for requerida), nos termos do art. 300 do CPC/2015, para os fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, V, do CTN, para os fins de evitar o ajuizamento da execução fiscal (tal pedido poderá ser colocado desta forma, desde que não se tenha execução fiscal já ajuizada);

II – procedência do pedido, para os fins de anular o lançamento tributário, nos termos dos artigos (neste caso, o candidato da OAB deverá indicar quais os artigos que foram utilizados na fundamentação do direito);

III – a citação do ente público, na pessoa de seu representante judicial, para apresentar a contestação no prazo legal;

IV – a condenação do ente público competente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão de o crédito público consistir um bem público indisponível.

Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do

CPC/2015”.

3.3.6 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem estar trazidas na petição inicial, para os fins de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

Sendo assim, as provas poderão ser indicadas da seguinte forma:

Protesta provar todo o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela prova documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da forma abaixo:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).



Note bem

O candidato do exame da OAB só indicará o valor da causa caso o problema indicar, não podendo criar valores fictícios, evitando a identificação de sua peça práctico-profissional.

3.3.7 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,

pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n. ...

3.3.8 - Modelo de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL DA S
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

(espaço de cinco linhas)

X Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..., com sede na ... bairro, cidade, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus sócios, por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com escritório na ... bairro, cidade, Estado, onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 38 da Lei 6.830/80, 319 e 300, ambos do Código de Processo Civil de 2015, propor a presente

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

de rito ordinário, em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, por meio de seu procurador, com endereço para citação na ... bairro, cidade, Estado, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

A Autora atua no ramo de indústria de cosméticos, com sede no Estado de São Paulo.

Em novembro de 2011 fora surpreendida com um auto de infração e imposição de multa (AIIM), exigindo o pagamento de IPI sobre a exportação de cosméticos para os EUA, estando na iminência da inscrição em dívida ativa.

Não concordando com a referida exação, não resta à Autora outro meio senão a propositura da presente ação.

II – DO DIREITO

a) Cabimento da medida judicial

A ação anulatória de débito fiscal, nos termos do art. 38 da Lei 6.830/1980, resta cabível ante a existência de lançamento tributário indevido, podendo ser interposta a tutela provisória

antecipada de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

b) Do mérito

O Imposto sobre produtos industrializados (IPI) é um imposto federal, previsto no art. 153, IV da Constituição Federal.

Conforme os fatos narrados, a Autora foi surpreendida com a exigência do referido imposto sobre a exportação realizada para os EUA.

No entanto, mostra-se inconstitucional a referida autuação, vez que a Autora goza de imunidade tributária, nos termos do art. 153, § 3.º, III, da Constituição Federal.

A imunidade é uma vedação constitucional da incidência tributária, podendo ser condicional ou não.

No artigo em comento, a Constituição Federal determina que não incide IPI sobre produtos industrializados destinados ao exterior, sendo uma forma de incentivar a exportação para o desenvolvimento econômico do país, sem que seja exigida daquele que promove a exportação qualquer espécie de condição, bastando que promova a saída do produto do país para os fins de ser internalizado em outro.

Assim, flagrante a inconstitucionalidade da autuação sobre a Autora, devendo o débito ser anulado, por medida de inteira justiça.

c) Da concessão de tutela provisória antecipada de urgência

Conforme determina o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada será concedida, de forma total ou parcial, desde que haja comprovação da existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano resta amplamente demonstrado pela existência de imunidade específica para o IPI quando da exportação de produtos industrializados para o exterior, nos termos do art. 153, § 3.º, III, da Constituição Federal.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo passa a ser demonstrado pela iminência da inscrição do débito em dívida ativa, com o consequente ajuizamento da execução fiscal, podendo acarretar a inviabilidade econômica da Autora.

Destarte, requer a concessão de tutela provisória antecipada de urgência para os fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, requer:

a) a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, mediante observância dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, para os fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional;

b) a procedência do pedido, para anular o lançamento tributário formalizado pelo auto de infração, devido à existência de imunidade tributária, nos termos do art. 153, § 3.º, III, da Constituição Federal;

- c) a citação da Ré, na pessoa de seu procurador, no endereço já indicado, para acompanhar a ação até o seu final;
- d) a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;
- e) a dispensa da audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela prova documental já acostada e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

V – VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/... n. ...



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.



Revisão da estrutura da ação anulatória de débito fiscal

- Endereçamento
- Qualificação do Autor
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do Réu
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito

após a exposição dos fundamentos de direito, deverá ser aberto um tópico para a explicação da tutela provisória antecipada de urgência

- Do pedido
- Das provas
- Do valor da causa
- Desfecho

3.4 AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS

3.4.1 Principais características

A **ação anulatória de decisão administrativa** tem o seu fundamento nos termos do art. 169 do CTN. Trata-se de uma ação pouco utilizada em matéria tributária, mas não de menor importância.

Uma vez que os tributos foram recolhidos indevidamente pelo sujeito passivo, este poderá iniciar um pedido administrativo para buscar a devolução dos valores ou, caso ocorra a possibilidade, pleitear sua compensação.

Entende a consagrada doutrina que a **compensação** é considerada uma modalidade especial de extinção do crédito tributário, prevista nos arts. 156, II, e 170 do CTN. Seria uma forma de substituição do pagamento, uma vez que a Fazenda Pública deixará de receber o crédito tributário ao mesmo tempo em que restitui o crédito do sujeito passivo.

Neste caso, tais pleitos poderão ser requeridos pela via administrativa. Decidindo a Administração Pública que o sujeito passivo não tem direito à restituição dos tributos ou à sua compensação, poderá pleitear a devolução pela via judicial.

Muito se discutiu se o caso de **pedido administrativo de restituição ou de compensação** acarretaria uma **interrupção do prazo prescricional para propositura de ação de repetição de indébito**. Tal discussão levou ao advento da súmula 625 do STJ, *in verbis*:

O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

Assim, mesmo que haja o pedido de restituição pela via administrativa, o prazo para ajuizamento da ação de repetição de indébito fiscal de mantém, não acarretando qualquer espécie de suspensão ou interrupção de prazo.

No entanto, poderá o sujeito passivo ingressar com a ação de repetição do indébito fiscal dentro do prazo legal estabelecido no art. 168, I, do CTN.

O ingresso da ação anulatória da decisão administrativa terá que observar um prazo de **dois anos contados da publicação da decisão administrativa no órgão oficial**.

3.4.2 Cabimento

A ação anulatória de decisão administrativa tem o seu cabimento **após a publicação da decisão administrativa irreformável que denegou a restituição de tributos ou a sua compensação tributária**.

Poderá ser requerida a **antecipação provisória de tutela de urgência**, nos termos do art. 300 do CPC/2015, para evitar o prosseguimento da cobrança tributária enquanto o julgamento de mérito não ocorrer, sendo não usual, pois não se tem, de forma direta, um prejuízo a ser comprovado pelo contribuinte, salvo quando da existência de tributos que tenham que ser recolhidos mensalmente.

3.4.3 Competência

A competência para julgamento da medida judicial será determinada de acordo com o tributo em questão e com a vinculação do órgão administrativo que proferiu a decisão final, salvo nos casos de competência absoluta em razão da pessoa, cuja competência será da **Justiça Federal**, independentemente do tributo em questão. Sendo federal, o encaminhamento da medida se fará perante uma das varas da Justiça Federal; sendo tributos estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual.

Temos, então:

--	--

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)

3.4.4 Fundamento da ação, cabimento de tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada

A **ação anulatória de decisão administrativa** tem como fundamento os arts. 169 do CTN e 319 do CPC/2015. Uma vez que tal ação virá acompanhada ora de **restituição dos tributos**, ora de **compensação tributária**, serão incluídos os respectivos artigos legais que dão suporte aos pedidos: art. 165, III, do CTN (nos casos de repetição do indébito fiscal) ou art. 170 do CTN (nos casos de compensação tributária).

Entretanto, a nomenclatura reputada como adequada é **ação anulatória de decisão administrativa cumulada com repetição de indébito fiscal**.

O pedido de tutela provisória antecipada de urgência **passa a ser inócuo**, uma vez que **não há prejuízo diretamente ligado ao fato da negativa de restituição pela via administrativa**, podendo se fazer valer da via judicial com o fito de requerer a restituição propriamente dita. Outrossim, o pedido de tutela provisória de urgência não possui os requisitos ensejadores para este fim, devendo ser dispensado quando da utilização dessa medida judicial.

3.4.5 Pedido

O pedido da ação anulatória de decisão administrativa passa a ser um pedido simples, devendo conter os seguintes itens:

I – procedência do pedido, para os fins de anular a decisão administrativa, nos

termos dos artigos ... (neste caso, o candidato da OAB deverá indicar quais os artigos que foram utilizados na fundamentação do direito);

II – seja autorizada a repetição dos valores com todos os encargos legais, nos termos do art. 165 do CTN (ou autorização de compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN, extinguindo o crédito tributário, conforme o art. 156, II, do CTN);

III – a citação do ente público, na pessoa de seu representante judicial, para apresentar a contestação no prazo legal;

IV – a condenação do ente público competente na condenação de custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão de o crédito público consistir um bem público indisponível. Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015”.

3.4.6 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem estar trazidas na petição inicial, para os fins de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

Sendo assim, as provas poderão ser indicadas da seguinte forma:

Protesta provar todo o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela prova documental já acostada e

outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No caso da ação anulatória de decisão administrativa com repetição de indébito fiscal, existem documentos que são **obrigatórios na ação, sob pena de indeferimento da medida judicial**:

- a cópia integral da decisão administrativa que denegou a possibilidade de restituição ou compensação de tributos pela via administrativa;
- o comprovante de pagamento dos valores indevidos (nos casos de restituição);
- comprovante dos créditos tributários para com a administração fazendária (nos casos de compensação).

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da seguinte forma:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).



Note bem

O candidato do exame da OAB só indicará o valor da causa caso o problema indicar, não podendo criar valores fictícios, evitando a identificação de sua peça prático-profissional.

3.4.7 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.

Advogado(a)
OAB/ ... n. ...

3.4.8 Modelo de ação anulatória de decisão administrativa cumulada com repetição de indébito fiscal



Note bem

Leva-se em consideração que tal ação fora proposta dentro do prazo de dois anos assinalados pela lei tributária.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL DA S
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

(espaço de cinco linhas)

X Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..., cor sede na ... bairro, cidade, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus sócios, por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com escritório na ... bairro, cidade, Estado, onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 165, III, e 169 do Código Tributário Nacional e 319 do Código de Processo Civil de 2015 propor a presente

AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL

em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, por meio de seu procurador, com endereço para citação na ... bairro, cidade, Estado, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

A Autora atua no ramo de indústria de cosméticos, com sede no Estado de São Paulo.

No mês de agosto de 2009 ingressou com processo administrativo fiscal pleiteando, administrativamente, a restituição dos valores pagos a título de IPI na exportação de cosméticos para os Estados Unidos entre os meses de janeiro a julho de 2009.

No entanto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda da União, entendeu que tais valores seriam devidos, proferindo decisão administrativa irreformável em janeiro de 2010, sendo tal decisão publicada no órgão

oficial a partir de fevereiro de 2010.

Não concordando com a referida exação, não resta a Autora outro meio senão a propositura da presente ação.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento da medida judicial e da tempestividade

A ação anulatória de decisão administrativa mostra-se cabível ante o indeferimento da restituição pela via administrativa há menos de dois anos, sendo solicitada a nulidade da decisão denegatória com a consequente restituição dos valores que foram pagos, monetariamente corrigidos, nos termos do art. 169 do CTN.

b) Do mérito

O Imposto sobre produtos industrializados (IPI) é um imposto federal, previsto no art. 153, IV da Constituição Federal.

Conforme os fatos narrados, a Autora ingressou com o pedido de restituição dos valores pela via administrativa, sendo que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF denegou o pedido, reiterando o posicionamento da Fazenda Pública em perpetrar a exigência, mesmo sendo esta indevida.

Ora, Nobre Julgador, mostra-se flagrante a inconstitucionalidade da referida decisão administrativa, uma vez que a Autora goza de imunidade tributária, nos termos do art. 153, § 3.º, III, da Constituição Federal.

A imunidade é uma vedação constitucional da incidência tributária, podendo ser condicional ou não.

No artigo em comento, a Constituição Federal determina que não incide IPI sobre produtos industrializados destinados ao exterior, sendo uma forma de incentivar a exportação para o desenvolvimento econômico do país, sem que seja exigida daquele que promove a exportação qualquer espécie de condição, bastando que promova a saída do produto do país para os fins de ser internalizado em outro.

De acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, é dever da administração pública anular os seus atos quando eivados de ilegalidade ou revogá-los quando da existência de inconveniência ou inoportunidade perante o interesse público.

Buscou a Autora, mediante a esfera administrativa, a restituição dos valores que foram pagos indevidamente no período assinalado. No entanto, entendeu o colegiado administrativo que os valores recolhidos se mostravam devidos, tendo a Autora que buscar o provimento jurisdicional para a anulação da decisão administrativa com a consequente devolução dos valores pagos, mediante os devidos encargos legais.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, requer:

a) a procedência do pedido, para anular a decisão administrativa, devido a existência de imunidade tributária, nos termos do art. 153, § 3.º, III, da Constituição Federal, com a consequente

restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPI, com os devidos encargos legais;

b) a citação da Ré, na pessoa de seu procurador, no endereço já indicado, para acompanhar a ação até o seu final;

c) a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

d) a dispensa de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela cópia da decisão administrativa irreformável e os comprovantes do pagamento indevido do IPI nos períodos de janeiro de 2009 a julho de 2009, e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

V – VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/... n.



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.



Revisão da estrutura da ação anulatória de decisão administrativa cumulada com repetição de indébito fiscal

- Endereçamento
- Qualificação do Autor
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do Réu

- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito
- Do pedido
- Das provas
- Do valor da causa
- Desfecho

3.5 AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO FISCAL

3.5.1 Principais características

A **ação de repetição de indébito fiscal** tem sua origem no instituto do *solve et repete*. Tal instituto determinava que todo sujeito passivo que pretendesse discutir se determinado tributo era válido ou não deveria, primeiramente, recolher o tributo para pleitear sua devolução.

Verificou-se com o passar do tempo que tal exigência era completamente descabida, pois **privilegiava o Poder Público em detrimento do cidadão contribuinte**, mesmo que este tivesse um direito assegurado legalmente.

Muitas vezes, o **sujeito passivo que pagou indevidamente um tributo também possui um débito tributário com a Fazenda Pública**. Nestes casos, existe a autorização legal para que ocorra a **compensação tributária**, em vez de proceder à mera devolução dos valores pagos indevidamente. Porém, vale frisar que toda compensação tributária dependerá de prévia autorização legislativa, não se admitindo compensação sem que lei autorize.

Importante ressaltar que, para o sujeito passivo poder pleitear a restituição dos tributos pagos indevidamente, a medida judicial deverá vir obrigatoriamente acompanhada do comprovante do pagamento do tributo indevido, objeto da demanda judicial.

Ao obter êxito numa ação de repetição de indébito, a restituição total ou parcial do tributo também concederá ao contribuinte o direito de receber, na mesma proporção, os juros de mora e as penalidades pecuniárias, salvo os referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas por causa da restituição.

A restituição em favor do contribuinte **vence juros não capitalizáveis somente a**

partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

De acordo com a Súmula 188 do STJ:

Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

E, na mesma esteira, a Súmula 162 do STJ:

Na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

O termo inicial de fluência de juros moratórios não é o mesmo da correção monetária para os tributos em geral. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos **a partir do trânsito em julgado da sentença, ao passo que a correção monetária incide desde o pagamento indevido do tributo.**

Nas palavras do STJ, em julgados recentes, houve uma distinção em se tratando de tributos federais. Nas ações de restituição de tributos federais, antes do advento da Lei 9.250/1995, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação, acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN.

Após a edição da Lei 9.250/1995, com especial previsão em seu artigo 39, parágrafo 4.º, passou a incidir a **Taxa Selic** desde o **recolhimento indevido**. Insta ressaltar, contudo, que a Taxa Selic não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque ela inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros (STJ, EDcl no REsp 1.306.105/SP, 2.ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2012).

Quando da determinação e formação dos precatórios, adotamos o disposto na Súmula Vinculante 17:

Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



Dica

Nos tributos federais, o termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto nos juros de mora será da **data do recolhimento indevido do tributo**. Os demais tributos estaduais e municipais, salvo disposição de lei em sentido contrário, se submetem ao regramento previsto no CTN.

3.5.2 Cabimento

Esta medida judicial tem cabimento quando decorrer o **pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária de maneira indevida**. Nos termos do art. 165, *caput*, do CTN, o sujeito passivo **poderá pleitear a restituição independentemente de prévio protesto**, o que já se denota que não se faz necessária qualquer providência administrativa para se requerer a devolução.

Mesmo que o pagamento indevido ocorra espontaneamente pelo sujeito passivo – como nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação – é devida a restituição dos valores pagos enquanto não estiver extinto o direito do sujeito passivo.

O prazo para pleitear a devolução por meio da ação de repetição de indébito fiscal é de **cinco anos**. Nos tributos sujeitos a **lançamento de ofício** ou por **declaração**, o prazo inicia-se quando da ocorrência do pagamento indevido. A discussão pairava nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, uma vez que a doutrina e a jurisprudência sedimentavam entendimento no sentido que o prazo teria início quando **da homologação do lançamento**.

Sendo assim, por tal entendimento, interpretando-se o disposto no art. 168 do CTN, tributos sujeitos a lançamento por homologação teriam o prazo de contagem iniciado **após a homologação**. Neste caso, o sujeito passivo antecipava o pagamento do tributo e o Fisco, tendo o prazo de cinco anos para realização da homologação, sendo que, quando da homologação, teria mais cinco anos para pleitear a devolução.

Com o advento da LC 118/2005, a modificação inserida no art. 168 do CTN acabou por determinar que **tributos sujeitos a lançamento por homologação terão o prazo de contagem para efeitos da ação de repetição do indébito a partir da ocorrência do pagamento**, não tendo a necessidade de manifestação da Fazenda Pública para esse fim.

3.5.3 Competência

A competência para julgamento da medida judicial será determinada de acordo com o tributo em questão, salvo nos casos de competência absoluta em razão da pessoa, cuja competência será da **Justiça Federal**, independentemente do tributo em questão. Sendo Federal, o encaminhamento da medida se fará perante uma das varas da Justiça Federal; sendo tributos estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual.

Temos, então:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)

Entretanto, temos uma observação extremamente relevante quando a **competência tributária** é atribuída a determinado ente federativo, mas a **capacidade tributária ativa** (arrecadação e fiscalização de tributos) pertence a outra entidade da federação.

É o que ocorre com as **repartições de receitas tributárias e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)**. De acordo com os arts. 157, I, e 158, I, da CF/1988, a receita do imposto decorrente da renda paga pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como das autarquias e fundações públicas vinculadas a estas próprias entidades pagadoras, pertencem a elas.

Assim, caso o imposto de renda seja descontado indevidamente pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a ação deverá ser movida perante a **Justiça Estadual**.

De igual modo, reza a **Súmula 447 do STJ**:

“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do Imposto de Renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

Podemos concluir que toda vez que ocorrer a retenção na fonte do Imposto de

Renda pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, **ações declaratórias de inexistência de relação jurídico-tributária com repetição de indébito**, bem como as **ações de repetição de indébito fiscal propriamente ditas**, deverão ser ajuizadas perante a **Justiça Estadual** da localidade onde ocorreu o pagamento indevido.

Caso o sujeito passivo possua créditos tributários que são passíveis de compensação tributária, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/1991 e do art. 74 da Lei 9.430/1996, poderá requerer, em vez da repetição dos valores, a **compensação tributária**, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN.

Em situações excepcionais, o particular poderá figurar como **corrêu** na ação de repetição de indébito fiscal, uma vez que, nas hipóteses de **substituição tributária**, o **substituído** é tratado como **responsável em caráter supletivo**, nos termos do art. 128 do CTN. Assim, o **contribuinte** e o **responsável** terão que formar um **litisconsórcio ativo necessário** para que se promova a ação repetitória **quando o recolhimento do tributo se deu por parte do responsável em face do contribuinte substituído**.

No entanto, se o **contribuinte substituto** se negar a promover a ação em litisconsórcio com o **contribuinte substituído**, o contribuinte substituto deverá ser citado para **integrar a lide** que está sendo movida pelo **substituído**, podendo, inclusive, contestar a ação.

Tratando-se de imposto pago por quem não é proprietário, mas goza da condição de **promitente** comprador, a jurisprudência do STJ (REsp 769.969/RJ, 2.^a T., rel Min. Eliana Calmon, 2007) tem aceitado o adquirente como possuidor e responsável pelo pagamento do tributo, sendo o promitente comprador parte legítima para pleitear a repetição de indébito fiscal.

Ademais, o **contribuinte de fato** não terá direito de restituição, gozando de tal possibilidade apenas a pessoa que figure na condição de **contribuinte de direito**. Segundo tal temática, o STJ publicou, em 9 de maio de 2018, a súmula 614, dotada da seguinte redação:

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídicotributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

3.5.4 Restituição de tributos indiretos

Denominam-se **indiretos** aqueles tributos que, por sua própria natureza,

comportam **repercussão econômica**, ou seja, quando quem efetivamente arca com o ônus tributário passa a ser uma terceira pessoa estranha à ocorrência do fato gerador. Geralmente, **quem acaba assumindo o maior encargo econômico passa a ser o consumidor final**.

O art. 166 do CTN determina que, nesses casos, quem poderá pleitear a restituição passa a ser **aquele que efetivamente provar que assumiu o referido encargo tributário**. No entanto, se ocorreu a transferência do encargo para terceira pessoa, aquele que não assumiu o encargo somente passa a ter legitimidade caso tenha expressa autorização de quem teve o encargo.

A Súmula 546 do STF reza:

Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte *de jure* não recuperou do contribuinte *de facto* o *quantum* respectivo.

3.5.5 Fundamento da ação e nomenclatura adequada

A **ação de repetição de indébito fiscal** tem como fundamento os arts. 165 do CTN e 319 do CPC/2015.



Note bem

Nesta ação, torna-se imprescindível o candidato demonstrar que a guia do pagamento do tributo indevido está trazida na petição inicial, sob pena de indeferimento desta.

Assim, a nomenclatura adequada adotada é: **Ação de Repetição de Indébito Fiscal**.



Importante

Nesta ação pura e simples, **não há o que se falar em antecipação provisória de tutela de urgência**, uma vez que tal ação, de natureza condenatória, apenas está pleiteando a

devolução dos valores que foram pagos indevidamente, **não se podendo frustrar a ordem de pagamento dos precatórios**, que deverá observar o regramento previsto no art. 100 da CF/1988.

Não se confunde com a ação declaratória cumulada com a repetição nem com a ação anulatória de decisão administrativa cumulada com repetição, pois nestas o cabimento de tutela provisória antecipada de urgência possui legitimidade.

3.5.6 Pedido

O pedido da ação de repetição de indébito fiscal passa a ser um pedido simples, devendo conter os seguintes itens:

I – procedência do pedido, para os fins de condenar o ente público competente à devolução dos valores pagos indevidamente, com as correções legais, nos termos do art. 165 do CTN (o sujeito passivo poderá requerer, em vez da devolução dos valores, a compensação tributária, desde que observe alguns dos casos previstos no art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996);

III – a citação do ente público, na pessoa de seu representante judicial, para apresentar a contestação no prazo legal;

IV – a condenação do ente público competente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão de o crédito público consistir em bem público indisponível.

Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade

da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015”.

3.5.7 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem estar trazidas na petição inicial, para os fins de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

Sendo assim, as provas poderão ser indicadas da seguinte forma:

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela guia de pagamento dos tributos pagos indevidamente e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da forma abaixo:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

3.5.8 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.
Advogado(a)
OAB/ ... n. ...

3.5.9 Modelo de ação de repetição de indébito fiscal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL (OU FEDERAL) DA SEÇÃO (OU DA SUBSEÇÃO) JUDICIÁRIA DE ...

(espaço de cinco linhas)

EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º..., possuindo sede na ..., n.º..., bairro ..., cidade ..., por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com escritório na ..., bairro, ..., cidade ..., onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 165 do Código Tributário Nacional e art. 319 do Código de Processo Civil de 2015, propor a presente

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL

em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na ..., bairro ..., cidade ..., Estado ..., na pessoa de seu representante legal (procurador ou representante judicial), pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DOS FATOS

A Autora procedeu ao recolhimento indevido do IRPJ durante os períodos de janeiro de 2009 a julho de 2009, uma vez que já haviam sido recolhidos anteriormente, conforme se comprova nas guias de pagamento em anexo.

Com o fito de obter a restituição dos valores já recolhidos indevidamente, uma vez que já tinham sido pagos, vem propor a presente medida judicial.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento e tempestividade da medida judicial

A ação de repetição de indébito fiscal tem por objetivo o provimento jurisdicional para condenar o ente federal à devolução dos valores pagos, monetariamente corrigidos.

Conforme se verifica, a medida deve ser apresentada dentro do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento indevido, à luz do art. 168, I, do CTN.

b) Do mérito

O IR é um tributo de competência da União Federal, conforme preleciona a Constituição Federal nos termos do art. 153, III.

Trata-se de um tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, uma vez que cabe ao sujeito passivo realizar o pagamento antecipado do referido tributo e, posteriormente, prestar as declarações, tendo a Fazenda Pública um prazo de cinco anos para realizar a homologação, de forma expressa ou tácita, acarretando a extinção

do crédito tributário.

Ocorre que a Autora já havia realizado o recolhimento do tributo em questão, mas, de maneira equivocada e espontânea, realizou novo recolhimento, acarretando o pagamento indevido do próprio tributo em questão.

Neste caso, resta evidente que, com o recolhimento em duplicidade, não pode a Administração Pública Fazendária, em decorrência do princípio da moralidade administrativa enriquecer-se indevidamente, cabendo-lhe o dever de restituir a Autora os valores que foram recolhidos a maior.

Prevê o art. 165 do Código Tributário Nacional que o sujeito passivo tem o direito independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento. Tal devolução é consubstanciada nos ditames do inc. I do mesmo artigo, que disciplina a devolução nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.

Ademais, a Autora está pleiteando a devolução de maneira tempestiva, pois ainda não se extinguiu o direito pelo decurso temporal de cinco anos, trazido no art. 168 do Código Tributário Nacional.

Outrossim, demonstra, por meio das guias de pagamento em anexo, que o referido imposto fora pago em duplicidade.

III – DO PEDIDO

Pelo exposto, a Autora requer à Vossa Excelência:

- a) o julgamento procedente do pedido, condenando a Ré à devolução dos valores pagos indevidamente, conforme art. 165 do Código Tributário Nacional com todos os encargos legais;
- b) a citação da União, no endereço já declinado e na pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar contestação e acompanhá-la até o seu final;
- c) a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios;
- d) a dispensa de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelas guias de pagamento do referido tributo e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do D. Juízo.

V – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.



Revisão da estrutura da ação de repetição de indébito fiscal

- Endereçamento
- Qualificação do Autor
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do Réu
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito
- Do pedido
- Das provas
- Do valor da causa
- Desfecho

3.6 AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

3.6.1 Principais características

Trata-se de uma medida judicial em que o sujeito passivo pretende **adimplir com a obrigação tributária para que não incorra em mora**. Para tanto, o sujeito passivo oferece o crédito tributário em juízo para que a **procedência da medida judicial**

acarrete a consequente **extinção do crédito tributário**.

A ação de consignação em pagamento vem regulada no art. 164 do CTN, que diz:

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I – de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II – de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III – de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1.º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

§ 2.º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

A finalidade principal do sujeito passivo da relação jurídico-tributária não é a de realizar a discussão jurídica sobre o cumprimento da obrigação tributária. Se o sujeito passivo se propõe a realizar a ação de consignação em pagamento, ele tem a certeza jurídica que tem o dever legal de efetuar o cumprimento da obrigação.

No entanto, **o que pode gerar dúvida é a quantia a ser depositada**, quem deve ser a pessoa jurídica de direito público legitimada para receber a quantia, dentre outras. Mas o dever de pagar é incontestável nessa ação. Caso seja necessário, o sujeito passivo terá ao seu alcance outros meios jurídicos para discussão da legalidade.

A ação consignatória pode ser **efetivada por meio de depósitos judiciais realizados em dinheiro** da importância que seja considerada devida pelo consignante.

Deverá ser utilizado também como fundamento da ação, porém, de maneira subsidiária, o disposto nos arts. 539 e ss. do CPC/2015.

Caberá ao sujeito passivo realizar a ação consignatória no **lugar do pagamento, cessando para o devedor os juros e demais encargos**, salvo quando a ação for julgada improcedente.

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1.º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§ 2.º Decorrido o prazo do § 1.º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3.º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4.º Não proposta a ação no prazo do § 3.º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.

3.6.2 Cabimento

As hipóteses de cabimento da ação consignatória estão previstas no art. 164 do CTN. Nos casos **derecusa no recebimento ou subordinação do recebimento à exigência de outras obrigações**, bem como nos casos de **subordinação do pagamento às exigências administrativas sem fundamento legal** (art. 164, I e II, CTN), são evidenciados nos casos de **lançamento de ofício**.

Poderão ocorrer hipóteses em que a pessoa jurídica de direito público condicione o pagamento de um imposto com uma taxa, numa mesma guia de pagamento. Caso uma exigência seja considerada devida e a outra não, pode-se consignar a quantia considerada devida e discutir a outra exação por meio de medida judicial própria (por exemplo, uma ação anulatória de débito fiscal).

O sujeito passivo sempre depositará o valor que entende ser devido. Caso o **pedido** da ação consignatória seja **julgado procedente**, o valor depositado será **convertido em renda a favor do ente público competente**, extinguindo o crédito tributário (art. 156, VIII, do CTN).

Outra hipótese de possibilidade de consignação em pagamento está fundada no art. 164, III, do CTN, no caso de exigência de um tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador por mais de uma pessoa jurídica de direito público. É o caso do ajuizamento de ação consignatória nos casos de **dúvida** ou **bitributação**.

Neste caso, a ação deverá ser **proposta em face de todos os entes públicos**, os quais devem ser **citados para apresentação de suas defesas**.

O cabimento da ação enseja que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária não consegue dimensionar qual ente público passa a ser competente, consignando a importância devida para que os entes públicos possam disputar em juízo o valor consignado.

A dúvida que deve ser capaz de levar ao cabimento da ação consignatória é a denominada **dúvida subjetiva** (aquela em razão de qual é o credor que deverá receber o pagamento). Se a lei já consegue determinar quem é o sujeito ativo da obrigação, a ação consignatória se mostra descabida, cabendo assim outras medidas judiciais (ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ação anulatória de débito fiscal, mandado de segurança).

É cediço que a ação de consignação em pagamento **objetiva liberar o devedor de sua obrigação tributária**, com a **quitação de seu débito**, por meio do **depósito judicial**.

Tal ação é o instrumento processual adequado, inclusive, para o pagamento de tributo em montante inferior ao exigido, quando o Fisco recusa o seu recebimento por valor menor.

Não há qualquer vedação legal a que o contribuinte lance mão da ação consignatória para ver satisfeito o seu direito de pagar corretamente o tributo quando entende que o Fisco está exigindo prestação maior que a devida. É possibilidade

prevista no art. 164 do CTN.

Ao mencionar que a consignação pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar, o § 1.º do art. 164 deixa evidenciada a possibilidade de ação consignatória nos casos em que o contribuinte se propõe a pagar valor inferior ao exigido pelo Fisco. Com efeito, **exigir valor maior equivale a recusar o recebimento do tributo por valor menor** (STJ, REsp 659.779/RS, 1.ª T., rel. Min Teori Albino Zavascki, 2004).

O depósito em consignação é modo de extinção da obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória tem a finalidade de ver atendido o direito – material – do devedor de liberar-se da obrigação e obter a quitação.

Com a atual configuração do rito, a **ação de consignação** pode ter **natureza dúplice**, já que se presta, em certos casos, a outorgar a tutela jurisdicional em favor do Réu, a quem se **assegura não apenas a faculdade de levantar**, em caso de insuficiência do **depósito**, a quantia oferecida, prosseguindo o processo pelas diferenças controvertidas (art. 545, § 1.º, do CPC/2015), como também a de obter, em seu favor, título executivo pelo valor das referidas diferenças que vierem a ser reconhecidas na sentença (art. 545, § 2.º, do CPC/2015).

Como em qualquer outro procedimento, também na ação consignatória o juiz está habilitado a exercer o seu poder-dever jurisdicional de investigar os fatos e aplicar o direito na medida necessária a fazer juízo sobre a existência ou o modo de ser da relação jurídica que lhe é submetida à decisão.

3.6.3 Competência

A competência para julgamento da medida judicial será determinada pela utilização da regra prevista no art. 540 do CPC/2015: **lugar do pagamento**.

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

Tratando-se de ação consignatória fundada no art. 164, I e II, do CTN, a competência obedecerá ao tributo em questão.

Temos, então:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)

Nos casos de ação de consignação em pagamento com base no art. 164, III, do CTN, levará em consideração quais os entes públicos que estão pleiteando o recebimento do crédito tributário. Caso um dos entes públicos seja a **União**, a competência será da **Justiça Federal**, nos termos do art. 109, I, CF/1988, **independentemente de qual for o outro ente público**, seja Estado ou Município.

Caso a demanda seja requerida em face do Estado e do Município, a competência será da **Justiça Estadual** para processamento e julgamento a causa. A distribuição obedecerá às determinações constantes da Lei de Organização Judiciária.

COMPETÊNCIA – ART. 164, III, CTN	
União e Estado União e Município	JUSTIÇA FEDERAL
Estado e Estado Estado e Município Município e Município	JUSTIÇA ESTADUAL

3.6.4 Fundamento da ação e nomenclatura adequada

A ação de consignação em pagamento tem o seu fundamento no art. 164 do CTN

(dependendo do tipo de situação jurídica, indicar o inciso adequado), arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, bem como no art. 319 do mesmo diploma.

Sendo realizado o depósito judicial da quantia, pode ser requerida a **suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto o mérito da ação não for julgado**, nos termos do art. 151, II, do CTN.

A nomenclatura correta da ação é: **Ação de Consignação em Pagamento**.

3.6.5 Pedido

O pedido da ação de consignação em pagamento passa a ser um pedido simples, devendo conter os seguintes itens:

I – autorizar o depósito judicial, na quantia de R\$..., evitando-se a mora e suspendendo-se o crédito tributário, em consonância com o art. 151, II, do CTN;

II – julgar procedente o pedido, reputando-se efetuado o pagamento e convertendo-se a importância consignada em renda para os fins de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, VIII, do CTN;

III – a citação do ente público (ou dos dois entes públicos, nos casos previstos do art. 164, III, do CTN), na pessoa de seu representante judicial (ou de seus representantes judiciais), para que compareça (ou compareçam) a Juízo, assinalando (ou assinalando-lhes) o prazo para o levantamento do depósito ou ofereça as razões de estilo.

IV – a condenação do ente público competente na condenação de custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão de o crédito público consistir em bem público indisponível. Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do

art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015”.

3.6.6 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem estar trazidas na petição inicial, para os fins de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

Sendo assim, as provas poderão ser indicadas da seguinte forma:

Protesta provar todo o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela guia de pagamento dos tributos pagos indevidamente e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da seguinte forma:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

3.6.7 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.

Advogado(a)

3.6.8 Modelo de ação de consignação em pagamento

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ... VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ...

(espaço de cinco linhas)

CONTRIBUINTE, nacionalidade ..., estado civil ..., profissão ..., portador da Cédula de Identidade RG n.º ..., e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º ..., residente e domiciliado na ..., n.º ..., bairro ..., cidade ..., por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com escritório na ..., bairro, ..., cidade..., onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 164, I, do Código Tributário Nacional, art. 319 do Código de Processo Civil de 2015 e arts. 539 e seguintes, também, do Código de Processo Civil de 2015, propor a presente

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

em face da Fazenda Pública Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na, bairro ..., cidade ..., Estado ..., na pessoa de seu representante legal (procurador ou representante judicial), pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DOS FATOS

A Autor recebeu cobrança simultânea, por meio de uma mesma guia de documento fiscal, de dois tributos: IPTU e taxa de conservação das vias e logradouros públicos (TCVLP). No caso da referida taxa, não concordando o Autor com a cobrança, ajuizou ação judicial a fim de declarar sua inconstitucionalidade, havendo pedido liminar, ainda não apreciado, para afastar a obrigatoriedade do recolhimento da referida exação fiscal. Por outro lado, em relação à cobrança de IPTU, pretende o Autor efetuar o pagamento. No entanto, a guia de pagamento é única e contém o valor global dos referidos tributos, tendo o banco rejeitado o pagamento parcial relativo somente ao IPTU.

Com o fito de evitar a mora e pagar e depositar o montante devido do IPTU, propõe o Autor a presente ação.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento da medida judicial

A ação de consignação em pagamento tem o seu cabimento, nos termos do art. 164, II, do CTN, visto que recebeu a cobrança de IPTU com subordinação ao pagamento de outro tributo, perfazendo a referida hipótese.

b) Do mérito

O IPTU é um imposto de competência municipal, previsto no art. 156, I, da Constituição Federal. Tal tributo passa a ser devido quando da propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel em zona urbana do Município.

Conforme os fatos supracitados, a Municipalidade está condicionando, numa mesma guia de pagamento, valores devidos do IPTU e de uma Taxa de Conservação das Vias e Logradouros Públicos, sendo esta última já discutida em sede de ação judicial, por entender o Autor que tal exação é inconstitucional.

A Fazenda Pública Municipal não pode condicionar numa mesma guia de pagamento os tributos em questão, uma vez que os fatos geradores são distintos, sendo as obrigações tributárias autônomas.

Reza o art. 164, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I – de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória (grifo nosso).

Não pode a Ré furtar-se ao recebimento do valor devido de IPTU, uma vez que o Auto entende ser incontroverso o imposto, não podendo ficar em mora por estar condicionado tal valor a uma exação (TCVLP) que está sendo questionada em sede de ação judicial.

III – DO PEDIDO

Pelo exposto, a Autora requer a Vossa Excelência:

a) autorizar o depósito judicial, na quantia de R\$..., evitando-se a mora e suspendendo-se o crédito tributário, em consonância com o art. 151, II, do CTN;

b) julgar procedente o pedido, reputando-se efetuado o pagamento e convertendo-se a importância consignada em renda para os fins de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN;

c) a citação da Municipalidade de ..., na pessoa de seu representante judicial, para que compareça a Juízo, assinalando o prazo para o levantamento do depósito ou ofereça as razões de estilo;

d) a condenação do ente público competente na condenação de custas processuais e honorários advocatícios;

e) a dispensa de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela prova documental já acostada à exordial e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do D. Juízo.

V – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º...

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.



Revisão da estrutura da ação de consignação em pagamento

- Endereçamento
- Qualificação do Autor
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do Réu
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito
- Do pedido
- Das provas
- Do valor da causa
- Desfecho

3.7 MANDADO DE SEGURANÇA

3.7.1 Principais características

Também conhecido como um dos **remédios constitucionais**, o mandado de segurança passa a ser uma das ações mais utilizadas no campo tributário. E isto porque se **destina a impedir ou desconstituir atos ilegais praticados por autoridades administrativas**, tendo o seu fundamento constitucional previsto no art. 5.º, LXIX, da CF/1988.

O que se busca com a ação mandamental é fazer com que um **agente da Administração Pública deixe de praticar um ato ilegal** contra um direito considerado **líquido e certo**, que não seja amparado nem por *habeas corpus* nem por *habeas data*.

É plenamente **possível o objeto do mandado de segurança coincidir com o objeto de uma ação declaratória positiva ou negativa** (ação anulatória de débito fiscal), sendo comum a **admissão de fungibilidade nos casos práticos**, salvo quando a prova nas ações não for pré-constituída.

Muitas vezes, o mandado de segurança é impetrado contra a **ameaça de cobrança de determinado tributo** que tem como pano de fundo uma lei que o instituiu. Veja que o que se quer atacar, de maneira direta, não é a cobrança ilegal do tributo, mas a lei em si. Nesta situação, uma ação judicial de procedimento ordinário seria mais adequada do que a via do mandado de segurança, uma vez que a ação ordinária atacaria no ponto exato a lei em tese e não a cobrança do tributo em si.

Por ser um instrumento que busca atender uma vastidão de informações pertinentes ao sujeito passivo no mundo tributário, os pedidos no mandado de segurança podem ser os mais variados possíveis. É possível, por meio da ação mandamental, ordenar que a autoridade administrativa pratique (prestação positiva) ou deixe de praticar (prestação negativa) determinadas condutas.

Podemos exemplificar **ordenações positivas** quando se destinam a **obrigar ao desembaraço de determinada mercadoria**, quando se **determina a expedição de certidões**, quando se deve inscrever uma sociedade perante o órgão de registro competente, dentre outras.

Já as **ordenações negativas** podem determinar que uma autoridade administrativa **deixe de inscrever o crédito tributário em dívida ativa, deixar de se exigir as**

prestações vincendas de determinado tributo, e assim sucessivamente.

Nada obsta, contudo, de o juízo competente determinar, na sentença mandamental, que a autoridade pratique condutas ou deixe de praticá-las, ou seja, mais de uma ordem na mesma sentença.

Atualmente, o mandado de segurança é regulado pela Lei 12.016/2009, trazendo em seu bojo duas espécies de mandado de segurança: **individual** e o **coletivo**, podendo ocorrer tanto na forma **preventiva** quanto na **repressiva**.

A diferença que resta entre o **mandado de segurança individual** e o **coletivo** não está no número de pessoas, mas por outras razões de caráter técnico. Qualquer pessoa pode impetrar o mandado de segurança individual, bastando que comprove o sofrimento de uma ameaça ou uma efetiva lesão de um direito líquido e certo; no caso de mandado de segurança coletivo, a CF/1988 determina, **taxativamente**, quais são os **legitimados para a impetração**. Ademais, no mandado de segurança coletivo, postula-se **direito alheio em nome próprio**, sendo um caso de **substituição processual** (podendo ser chamada também de legitimação extraordinária).

No que tange à forma preventiva ou repressiva, em matéria tributária podemos identificar pela **existência ou inexistência de lançamento** (art. 142 do CTN). Tratando-se de mandado de segurança **preventivo** (antes do lançamento), o instrumento poderá ser manejado por **aquele que está na iminência de sofrer a lesão sem prazo definido**. Porém, nos casos de mandado de segurança **repressivo**, deverá ser observado o prazo máximo de **120 (cento e vinte) dias contados da lesão cometida** (lançamento propriamente dito).

A doutrina, encampada por Luciano Amaro, Hugo de Brito Machado e José Eduardo Soares de Melo, determina que o prazo mandamental de 120 (cento e vinte) dias é **decadencial**, e não prescricional, uma vez que o sujeito passivo **perde o direito da garantia constitucional assegurada, e não apenas o direito de ação propriamente dito**.

3.7.2 Fundamento da ação e nomenclatura adotada

O mandado de segurança **individual** tem o seu fundamento no art. 5.º, LXIX, da CF/1988 e na Lei 12.016/2009. Há ainda a possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança com fundamento no inc. III do art. 7.º da Lei 12.016/2009.

No mandado de segurança individual, a nomenclatura correta adotada é: **Mandado de Segurança com Pedido de Liminar**.

No caso de **Mandado de Segurança Coletivo**, seu fundamento encontra-se no art. 5.º, LXX, da CF/1988 e no art. 21 da Lei 12.016/2009. Tem cabimento a medida liminar, sendo a nomenclatura correta adotada a seguinte: **Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar**.

3.7.3 Cabimento e legitimidade

Tanto o **mandado de segurança individual** quanto o **coletivo** têm cabimento quando a autoridade administrativa pratica um ato ilegal e abusivo que viola um direito líquido e certo. Na forma preventiva, o sujeito passivo deseja impedir a violação a esse direito; na forma repressiva, pretende-se que a autoridade administrativa se abstenha de continuar a praticar tal violação.

Assim, **sempre que ocorrer a lesão ou a iminência de lesão a um direito líquido e certo tem cabimento o mandado de segurança**.

Como **direito líquido e certo** se pode concluir que é aquele que independe de instrução probatória futura, podendo ser comprovado de plano para o juízo competente quando da impetração da ação mandamental. Assim, a prova no mandado de segurança passa a ser **pré-constituída**.

Também tem cabimento contra **ato disciplinar praticado por autoridade administrativa incompetente** ou que **deixou de observar formalidade considerada essencial**.

De acordo com a Súmula 266 do STF, torna-se **incabível o mandado de segurança contra lei em tese**. Deve-se entender que a finalidade do mandado de segurança **não é o ataque direto à lei**, mas, sim, ao ato praticado pela autoridade administrativa. Mera disposição legal abstrata que não atingiu os direitos do sujeito passivo não é considerada **ofensa a direito líquido e certo**.

De igual modo, **não se admite mandado de segurança contra decisão judicial sujeita a recurso com efeito suspensivo**, de acordo com o art. 5.º, II, da Lei 12.016/2009. Também não tem cabimento se a **decisão judicial transitou em julgado**, de acordo com o inciso seguinte do mesmo dispositivo. Assim, já entendia o STF, quando da edição da Súmula 267:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.

No entanto, a Lei 12.016/2009 possibilitou o manejo do mandado de segurança quando da decisão judicial caiba recurso sem efeito suspensivo.

Tem **legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança** o sujeito passivo que sofreu lesão ou ameaça de lesão a um direito líquido e certo, não importa se pessoa física ou jurídica. Mesmo entes despersonalizados, mas que constituem **universalidades de direitos** (passa a ser o caso da **massa falida**, do **condomínio** ou do **espólio**, pois, mesmo sendo despersonalizados, representam uma universalidade de direitos) têm legitimidade para impetração do *mandamus*.

A **legitimidade passiva** passa a ser a **autoridade administrativa que praticou o ato ilegal e abusivo**. Tal autoridade é denominada de **autoridade coatora**. Essa autoridade pode ser **agente público da Administração Pública Direta ou Indireta**, bem como os representantes de órgãos de partidos políticos e os dirigentes de pessoas jurídicas no exercício das atribuições do Poder Público (agentes públicos delegados).

Nesse caso, o mandado de segurança **não é impetrado em face de uma pessoa jurídica de direito público ou de entidades delegadas**, mas **contra o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora**, sendo esta autoridade aquela que pode sanar a irregularidade.

Uma vez que se trata de uma ação que visa corrigir atos de autoridade administrativa no exercício de suas atribuições, não pode ser impetrado **contra atos negociais ou de gestão comercial** que sejam praticados por administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista ou por concessionárias de serviços públicos (art. 1.º, § 2.º, da Lei 12.016/2009).

3.7.4 Autoridade coatora e sua determinação

Conforme falamos, a **autoridade coatora** é a autoridade administrativa que, no exercício de suas funções públicas, tenha praticado o ato impugnado ou determinou a ordem para a sua prática.

De acordo com a nova sistemática adotada pela Lei 12.016/2009, a autoridade coatora **deve ser indicada juntamente com o órgão ou entidade pública** da qual faça parte.

Existem situações apresentadas em que a **autoridade coatora se mostra evidente**, podendo ser desde um Ministro de Estado, Secretário de Governo até um agente público no exercício de sua regular atribuição.



Importante

No caso do exame da OAB, a autoridade coatora pode ser apresentada no enunciado da peça prático-profissional, devendo o candidato se referir ao agente público mencionado. Porém, o problema poderá ser omissivo, hipótese em que o candidato deverá apresentar uma nomenclatura adequada para a autoridade coatora.

Para se evitarem maiores celeumas, tratando-se de **atos ilegais e abusivos praticados por agentes da Administração Pública que não figuram como agentes políticos de alto escalão** (Presidência da República, governadores, prefeitos etc.), propomos a seguinte identificação:

TRIBUTO	AUTORIDADE COATORA	ÓRGÃO ADMINISTRATIVO
Tributos Federais Aduaneiros (II – IE etc.)	Inspetor Alfandegário da Receita Federal do Brasil	Secretaria da Receita Federal do Brasil
Tributos Federais não aduaneros (IR – ITR – taxas etc.)	Delegado da Receita Federal do Brasil	Secretaria da Receita Federal do Brasil
Tributos Estaduais	Delegado Regional Tributário ou Coordenador do Sistema de	Secretaria da Fazenda do Estado

	Arrecadação e Tributação	
Tributos Municipais Imobiliários (IPTU – ITBI)	Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias	Secretaria de Finanças do Município
Tributos Municipais Mobiliários (ISS – taxas)	Diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias	Secretaria de Finanças do Município

É plenamente possível que, de acordo com a Lei de Organização Judiciária local as **autoridades administrativas sejam outras aqui não indicadas**. Por isso, trata-se de uma mera identificação dentro das atuais legislações.



Dica

Com o intuito de facilitar a realização do preâmbulo, em vez de o candidato indicar o órgão público pelo qual o agente público esteja subordinado, poderá indicar o ente público federado no qual faça parte: sendo autoridade coatora federal, a **União**, autoridade coatora estadual, o **Estado** e a autoridade coatora municipal, o **Município**.

3.7.5 Liminar no Mandado de Segurança

O **mandado de segurança** é considerado uma **medida célere** a ser usada pelo sujeito passivo que sofreu uma **ameaça ou lesão a um direito líquido e certo**. Por ser uma medida considerada de urgência, a **liminar passa a ser inata** do próprio *mandamus*.

Para que o juízo competente possa conceder a liminar, faz-se necessária a análise dos pressupostos ensejadores, previstos no art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009:

- I – ocorrência de **fundamento relevante** para sua concessão (*fumus boni juris*);
- II – do ato impugnado puder resultar a **ineficácia da medida** (*periculum in mora*).

A liminar passa a ser considerada uma necessidade que é imposta ao sujeito passivo diante dos fatos considerados ilegais e abusivos perpetrados por uma autoridade administrativa no exercício de suas funções.

No entanto, caberá ao juízo, **antes do deferimento da liminar, se for o caso, exigir do impetrante caução, fiança ou depósito** com o objetivo de **assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica**. Tal fato é considerado pela majoritária doutrina **incomum e controverso**, uma vez que a exigência de depósito **não se coaduna com a própria finalidade e objeto da medida liminar**.

Poderia ser exigido o depósito como **condição subsidiária nos casos de não concessão da medida liminar**.

É **vedada a concessão de medida liminar** nos seguintes casos:

- I – compensação de créditos tributários;
- II – liberação de mercadorias apreendidas quando advindas do exterior.

Na segunda situação, caso o sujeito passivo queira realizar a liberação da mercadoria, terá que realizar o **depósito do montante integral**. Tal condição legislativa tem suscitado vários requerimentos de inconstitucionalidade por parte dos juristas, uma vez que tal negativa ofende os **princípios de proporcionalidade e razoabilidade, segurança jurídica, imposição de sanções políticas, inafastabilidade da jurisdição**, dentre outros.

3.7.6 Competência

A competência territorial no mandado de segurança é determinada pelo **foro da autoridade coatora**. Neste caso, deverá ser impetrado o mandado de segurança **no local da ocorrência da lesão ou no foro da autoridade que determinou a prática do ato ilegal ou a abusivo**.

Contudo, existem autoridades coadoras que possuem a **prerrogativa de responderem a mandados de segurança diretamente em um Tribunal**, não sendo de competência do juízo de primeiro grau.

Assim, podemos determinar a competência para estas autoridades coadoras da forma a seguir indicada:

--	--

AUTORIDADE COATORA	COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Presidente da República Mesas da Câmara e do Senado Federal Tribunal de Contas da União Procurador-Geral da República Ministros do STF	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ministros de Estado Comandantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Atos do próprio Tribunal Juízes Federais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Governador do Estado Atos do próprio Tribunal Juízes de Direito	TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Lei 12.016/2009 sofreu alteração pela Lei 13.676/2018, em seu art. 16, permitindo a **defesa oral do pedido de liminar** em sessão de julgamento da ação mandamental, conforme assinalado a seguir:

Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar.

Nos demais casos, observamos o tributo em questão e o foro da autoridade coatora ou o local da ocorrência da efetiva lesão.

Temos, então:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara Cível (ou Vara Federal) da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública do Estado de ... (quando existir vara especializada) ou Vara Cível da Comarca de ... (quando não existir vara especializada)

3.7.7 Notificação da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público

A autoridade coatora será **notificada** para prestar informações no **prazo de 10 (dez) dias**, nos termos do art. 7.º, I, da Lei 12.016/2009.

A notificação ocorrerá para que a autoridade **informe as razões da possível ilegalidade que suscitou a impetração da ação mandamental**. Apesar de a nomenclatura utilizada ser **notificação**, esta será equivalente a uma **citação** para todos os efeitos processuais.

Ademais, o processo deverá seguir o seu curso mediante **vistas do Ministério Público**, que atuará como *custos legis* (fiscal da lei) no caso concreto.

A atual legislação atribuiu **prazo de 10 (dez) dias** para que o Ministério Público se manifeste favoravelmente ou não à impetração realizada. Pode ainda pugnar pela **extinção do processo sem resolução de mérito**.

3.7.8 Pedido

O pedido no mandado de segurança deverá conter as seguintes especificações:

I – concessão da liminar, para os fins de ... (determinar a finalidade para a concessão da liminar), mediante observâncias dos requisitos do art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009;

II – procedência do pedido, concedendo a segurança em definitivo, nos termos dos artigos ... (indicar os artigos que fundamentaram o direito), ratificando a liminar pleiteada;

III – determinar a notificação da autoridade coatora no prazo legal, bem como a oitiva do ilustre representante do Ministério Público;

IV – condenação ao pagamento de custas processuais;

V – ciência do feito ao órgão de representação judicial da **União, Estado ou Município** (dependendo do problema), na pessoa de seu procurador, para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo (Súmula 631 do STF);

VI – dispensa da audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.



Importante

Nas ações de mandado de segurança **não se tem condenação em honorários advocatícios**, conforme Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Como se trata de **direito líquido e certo**, não há indicação do tópico de provas, devendo o sujeito passivo trazer na exordial todas as provas que julgar necessárias para a comprovação de seu direito.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão de o crédito público consistir em bem público indisponível. Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não

realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015”.

3.7.9 Valor da causa

O art. 291 do CPC/2015 determina a atribuição de um valor a **qualquer causa de natureza civil**. Ainda que não possua valor econômico, ao mandado de segurança deve-se atribuir um valor (art. 291 do CPC/2015).

Na prática forense adota-se um valor mínimo para o recolhimento da taxa judiciária.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da forma abaixo:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

3.7.10 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.

Advogado(a)
OAB/ ... n.º ...

3.7.11 Demais considerações relevantes

Sendo processado o mandado de segurança, o juízo deverá proferir a sentença em **30 (trinta) dias**. A sentença concessiva da ordem **pode ser executada**

provisoriamente, salvo nos casos em que não for possível a concessão de liminar.

No caso da **sentença denegatória da segurança, mesmo que a liminar tenha sido concedida**, com a prolação da sentença a liminar **será revogada, retroagindo os seus efeitos ao tempo de seu deferimento**, podendo implicar, inclusive, o recolhimento dos valores não pagos no período de vigência da liminar. Nesse sentido, a Súmula 405 do STF prevê:

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

Caso o sujeito passivo queira obter novamente os efeitos da liminar, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, poderá tomar as seguintes providências:

I – interpor **recurso de apelação** com pedido de restabelecimento dos efeitos da liminar revogada;

II – propor **medida cautelar ao Tribunal que julgará a apelação**, postulando liminarmente os efeitos da liminar revogada;

III – impetrar **mandado de segurança para restauração dos efeitos da liminar revogada**.

3.7.12 Modelo de Mandado de Segurança com pedido de liminar

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ... VARA CÍVEL (OU FEDERAL) DA SEÇÃO (OU DA SUBSEÇÃO) JUDICIÁRIA DE ...

(espaço de cinco linhas)

EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º..., possuindo sede na ..., n.º ..., bairro ..., cidade ..., por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com escritório na ..., bairro, ..., cidade ..., onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal, arts. 1º e seguintes da Lei 12.016/2009 e art. 319 do Código de Processo Civil de 2015, impetrar o presente

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

contra ato ilegal e abusivo do Ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil, o qual que lhe faça as vezes no exercício da coação impugnada, agente público vinculado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, entidade da Administração Pública Federal com endereço na ... bairro ..., cidade ..., Estado ..., pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DOS FATOS

A Impetrante vem recolhendo regularmente os créditos tributários decorrentes do IRPJ de acordo com a legislação vigente.

No entanto, o Decreto regulamentar n.º ... expedido por ordem do Ministério da Fazenda majorou as alíquotas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e determinou seu pagamento a partir da data da publicação do mencionado ato normativo. Esta exigência surpreendeu a Impetrante, não restando outra alternativa senão a impetração do presente *mandamus*.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento da medida judicial e tempestividade (no caso de mandado de segurança repressivo)

O mandado de segurança tem o seu cabimento nos casos previstos no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, quando da ameaça ou lesão de um direito líquido e certo perpetrado por uma autoridade administrativa de forma ilegal e abusiva, não sendo amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*.

Conforme se depreende do caso em tela, o cabimento da ação mandamental mostra-se evidente, restando legitimidade do Impetrante.

b) Do mérito

O Imposto sobre a Renda é um tributo de competência da União Federal, conforme preleciona a Constituição Federal nos termos do art. 153, III.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal, o qual consagra o princípio da legalidade, nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem lei que o estabeleça.

O art. 150, III, “b”, da Constituição Federal estabelece que nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o aumentou ou instituiu. Esse é o denominado princípio da anterioridade, sendo que, atualmente, por motivos da segurança jurídica, além de respeitar o exercício seguinte, entre determinado exercício e o próximo observar um lapso temporal de 90 (noventa) dias, apesar de não enquadráveis ao IRPJ, por se constituir exceção expressa no art. 150, § 1.º, da Constituição Federal.

Com efeito, todos os tributos devem atender tais princípios, ressalvadas as exceções previstas no próprio texto da Constituição, sob pena de violarem o princípio da supremacia constitucional.

O IRPJ não está incluído entre as exceções aos princípios da legalidade e anterioridade estatuídas nos arts. 150, § 1.º, e 153, § 1.º, da Constituição Federal.

Assim, fica evidenciado que o Decreto regulamentar, expedido por ordem do Ministério da Fazenda ao majorar a alíquota do IRPJ, exigindo, ainda, seu pagamento, a partir dessa publicação, contraria dois princípios fundamentais: o da legalidade, que é genérico para todo o decreto, e o da anterioridade, que é específico do direito tributário, revestindo-se de manifesta inconstitucionalidade, afrontando direito líquido e certo do Impetrante.

c) Da concessão de medida liminar

Segundo o art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009, são pressupostos autorizadores da liminar: *fumus boni juris* e o *periculum in mora*.

A concessão de liminar justifica-se, pois a violação dos princípios da legalidade e da anterioridade é uma prova da existência do *fumus boni juris* que fora violado.

Por sua vez, como o IRPJ é lançado por homologação, e a data do recolhimento apresenta-se iminente, a Impetrante está sujeita imediatamente a um crédito tributário maior que o devido. Tal fato demonstra o receio de perda financeira, caracterizando o *periculum in mora*.

Mediante a concessão da liminar, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

III – DO PEDIDO

Pelo exposto, a Impetrante requer à Vossa Excelência:

a) concessão da liminar, para os fins de abster do recolhimento indevido do IRPJ, mediante observâncias dos requisitos do art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, IV, do Código Tributário Nacional;

b) procedência do pedido, concedendo a segurança em definitivo, nos termos dos art. 150, III “b” e “c”, da Constituição Federal, e art. 97 do Código Tributário Nacional, ratificando a liminar pleiteada;

c) determinar a notificação da autoridade coatora no prazo legal, bem como a oitiva do ilustre representante do Ministério Público;

d) condenação ao pagamento de custas processuais;

e) ciência do feito do órgão de representação judicial da União, na pessoa do seu representante legal, para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo (Súmula 631 do STF);

f) dispensa da audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para a conciliação e mediação, bem como sobre o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça práctico-profissional. Deve-se atentar, ainda, ao fato de que, em se tratando de mandado de segurança, **não** se deve abrir o tópico **das provas**.



Revisão da estrutura do mandado de segurança com pedido de liminar

- Endereçamento
- Qualificação do Impetrante
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação da Autoridade Coatora
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito

deverá ser aberto um tópico para exposição da concessão de liminar

- Do pedido
- Do valor da causa
- Desfecho

3.8 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

3.8.1 Principais características

Os **embargos à execução fiscal** constituem uma **ação autônoma** incidente a um processo principal, que é o processo de execução fiscal. Como ação, deverá obedecer aos requisitos do art. 319 do CPC/2015.

Mesmo tendo **natureza jurídica de ação**, os embargos são **dependentes de uma execução fiscal**, devendo ser **distribuídos por dependência**, uma vez que o **próprio juiz que determina a execução fiscal** tem a **competência para julgar a ação de embargos**.

Trata-se de uma espécie de ação em que o sujeito passivo (executado) visa defender-se com a possibilidade de obter o efeito suspensivo enquanto não houver o julgamento de mérito.

Para que haja a execução fiscal, faz-se necessário que a Fazenda Pública possua um **título executivo**. Este **título executivo extrajudicial** é a **certidão de dívida ativa (CDA)**. Assim, os embargos são, inicialmente, uma forma de tornar **inválida e insubsistente a certidão de dívida ativa**.

Uma vez inscrita em dívida ativa, as dívidas sem garantia integral ou exigibilidade suspensa são registradas perante o **CADIN** (Cadastro Informativo de créditos não quitados), banco de dados onde são registrados os nomes dos contribuintes responsáveis por débitos perante **órgãos públicos federais**, regido pela Lei 10.522/2002.

A inclusão do devedor no CADIN ocorre 75 (setenta e cinco) dias após a notificação sobre o possível registro, e a suspensão ou exclusão do nome do devedor do cadastro ocorre até 5 (cinco) dias úteis após a comprovação da regularização da situação que deu causa a inclusão.

O procedimento de inscrição foi posteriormente regulamentado pela Portaria PGFN 810/2009, vedando a inclusão de débitos inferiores a R\$ 1.000,00 (mil reais).

Para que os embargos possam ser recebidos e processados com o fito de suspender o curso do processo executivo, deverá ser oferecida uma **garantia de execução**. Essa garantia poderá ser realizada por meio de **depósito, fiança bancária, seguro-garantia ou penhora de bens**.

Levando em consideração a manutenção do dispositivo anterior, de acordo com o CPC/2015, **os embargos à execução não terão efeito suspensivo**, salvo se comprovada a existência de **grave dano de difícil ou incerta reparação**, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC/2015.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1.º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
--

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Conforme prevê o art. 16 da Lei 6.830/1980, o prazo para que o executado possa opor os embargos é de **30 (trinta) dias**, tendo esse prazo natureza peremptória.

O prazo para oposição dos embargos passa a ser contado:

I – da data do depósito realizado nos autos;

II – da juntada da prova de fiança bancária ou do seguro garantia;

III – da intimação da penhora.

Pelo regramento geral, o prazo passa a ser contado **a partir da intimação pessoal feita ao executado**, não levando em consideração a data da publicação.

3.8.2 Cabimento

A ação de embargos à execução fiscal tem cabimento quando da **existência de uma execução fiscal em que o sujeito passivo tenha recebido a citação**.

Enquanto o sujeito passivo não receber a citação da execução fiscal, não haverá a formação do processo executivo, tendo cabimento a **ação anulatória de débito fiscal**.

Assim, concluímos:

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL	
Não ocorreu a citação	Ocorreu a citação
Ação Anulatória de Débito Fiscal	Embargos à Execução Fiscal

Leva-se em consideração que o **cabimento dos embargos à execução fiscal** como medida de defesa **após a citação da execução fiscal** é a **regra geral**. Contudo, poderá existir a possibilidade de arguição de **exceção de pré-executividade**, nas hipóteses de que trataremos adiante.

Na ação de embargos à execução fiscal caberá a **suspensão da ação de execução fiscal**, tendo por fundamento o art. 919, § 1.º, do CPC/2015, devendo o executado

expor a existência de **grave dano de difícil ou incerta reparação**.

Tivemos vários julgamentos desfavoráveis perante o STJ sobre a utilização do antigo art. 739-A, § 1.º, do CPC/1973, alegando alguns Ministros que tal artigo não poderia ser utilizado, uma vez que a lei de Execução Fiscal é específica, não se admitindo o uso do referido artigo para a suspensão do curso do processo executivo.

Entretanto, é cediço o entendimento de que, nas omissões da lei de Execução Fiscal, aplicar-se-á, sempre de maneira subsidiária, o CPC. Assim, mantém-se o uso do art. 919, § 1.º, do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo.

3.8.3 Competência

A ação de embargos à execução fiscal deverá ser **distribuída por dependência a uma execução fiscal existente**. Neste caso, o juízo das execuções competente é aquele em decorrência do tributo em questão, se federal, estadual ou municipal.

Assim, podemos definir a competência para oposição dos embargos à execução fiscal conforme abaixo:

TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara das Execuções Fiscais Federais da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara das Execuções Fiscais da Comarca de ... ou Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Anexo Fiscal da Comarca de ...



Note bem

Nos exames da OAB, o candidato somente deverá se utilizar dos

endereçamentos acima indicados caso o problema **não identifique o juízo das execuções.**

3.8.4 Fundamento da ação e nomenclatura adequada

A ação de embargos à execução fiscal tem o seu fundamento nos arts. 16 da Lei 6.830/1980 e 319 do CPC/2015. Caberá o pedido de efeito suspensivo da execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC/2015, mas este não é utilizado como **fundamento da ação de embargos**, podendo conter apenas no corpo da medida judicial.

É certo que, mesmo que tenhamos algumas discussões relevantes, só se faz possível o recebimento e processamento dos embargos mediante a apresentação de **garantia do juízo**, à luz do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980.

Assim, a nomenclatura correta a ser adotada é: **Embargos à Execução Fiscal** ou **Ação de Embargos à Execução Fiscal**.

3.8.5 Pedido

O pedido na ação de embargos à execução fiscal deverá conter os seguintes itens:

I – que os presentes Embargos sejam recebidos e processados por dependência à Execução Fiscal, concedendo-lhe o efeito suspensivo imediato, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC/2015 até a decisão final;

II – sejam acolhidos e julgados procedentes, para os fins de desconstituição do título executivo e a consequente extinção da Execução Fiscal, nos termos do artigo... (indicar os artigos que fundamentaram o direito);

III – a exclusão do Executado do polo passivo, bem como o levantamento da penhora do imóvel (quando ocorrer a penhora), por medida de justiça;

IV – a intimação da Embargada, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se sobre os presentes Embargos;

V – condenação da Embargada nas custas processuais e honorários advocatícios.



Importante

Para o exame da OAB, há um pedido extra a ser elaborado ou

então sua indicação em forma de tópico apartado, no que diz respeito à audiência de Conciliação e Mediação, em que pese, na prática jurídica, tal fato ser um tanto quanto controverso em razão de o crédito público consistir um bem público indisponível. Nesse sentido, entendemos salutar frisar: “a opção pela não realização da audiência de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, ou indicar sobre a Impossibilidade da Conciliação (autocomposição), conforme art. 334, § 4.º, II, do CPC/2015”.

3.8.6 Das provas e valor da causa

Conforme anteriormente indicado, as provas devem estar trazidas na petição inicial, para os fins de corroborar com a pretensão jurídica.

O valor da causa também deverá ser indicado obrigatoriamente, sob pena de invalidação.

No caso dos embargos à execução fiscal, podem ser alegadas em juízo **todas as matérias de defesa pertinentes**, com a possibilidade de trazer todas as provas em direito admitidas.

Sendo assim, as provas poderão ser indicadas da seguinte forma:

Protesta provar todo o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela guia de pagamento dos tributos pagos indevidamente e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

No que tange ao valor da causa, este poderá ser indicado da seguinte forma:

Dá-se à causa o valor de R\$... (valor por extenso).

3.8.7 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.

Advogado(a)
OAB/ ... n.º ...

3.8.8 Modelo de embargos à execução fiscal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ANEXO FISCAL DA CO
DE SERRA NEGRA

(espaço de cinco linhas)

Distribuição por Dependência

Execução Fiscal n.º ...

João, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG n.º ... devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º ..., residente e domiciliado na ..., bairro, cidade, Estado por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com escritório na ..., bairro, cidade, Estado, onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 16 da Lei 6.830/1980 e art. 319 do Código de Processo Civil de 2015, opor os presentes

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

que lhe move a Municipalidade de Serra Negra, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificada, por meio de seu procurador, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

O Embargante adquiriu, em 1980, um imóvel situado na zona rural do Município de Serra Negra. Em 2009, a Câmara Municipal aprovou lei que alterou o perímetro urbano do Município passando a incluir o imóvel do Embargante. Porém, a área manteve características típicas de

zona rural, sem apresentar qualquer espécie de equipamento urbano, tal como água encanada, iluminação pública, saneamento básico ou calçamento.

Recentemente, o Embargante recebeu notificação de lançamento de IPTU relativo ao exercício de 2010. Como não apresentou pagamento, o débito foi inscrito em dívida ativa e ajuizada a presente execução fiscal, sendo intimado o Autor da penhora de outro imóvel de sua propriedade.

Não concordando com a referida exação, não resta ao Embargante alternativa senão a oposição dos presentes embargos.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento do presente Embargo e sua tempestividade

Nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980, quando da citação válida do devedor haverá o cabimento de Embargos à Execução Fiscal dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, juntada da fiança bancária ou seguro garantia ou da intimação da penhora.

Ante a existência da tempestividade e das demais exigências legais, mostra-se compatível o uso da presente medida judicial, conferindo-se a suspensão do processo executivo até a decisão final de mérito.

b) Do mérito

O imposto sobre a propriedade territorial urbana é um imposto de competência municipal, previsto no art. 156, I, da Constituição Federal e no art. 32 do Código Tributário Nacional.

Conforme os fatos supracitados, o imóvel pertencente ao Embargante estava situado na zona rural da Embargada e, com a modificação legislativa, passou este imóvel a ser incluído no perímetro considerado urbano.

Ocorre, Excelência, que, para definição de zona urbana, o art. 32, § 1.º, do Código Tributário Nacional determina que a lei municipal deve considerar pelo menos a existência, no mínimo, de melhoramentos indicados em dois incisos do referido artigo.

A zona onde se situa o imóvel do Embargante conserva todas as características rurais, não possuindo quaisquer dos melhoramentos indicados na lei tributária, o que acarreta, inicialmente, afronta ao princípio da legalidade.

Como se não bastasse, além da afronta ao princípio da legalidade perpetrado pela Embargada, a competência para instituição do imposto sobre a propriedade é federal, vez que a incidência tributária passa a ser do ITR e não de IPTU, ocorrendo uma invasão de competência tributária.

Não restam dúvidas que a exigência do IPTU pela Embargada passa a ser completamente indevida.

c) Da concessão do efeito suspensivo

Conforme estabelece o art. 919, § 1.º, do CPC/2015, o juízo poderá, a requerimento do Embargante, atribuir o efeito suspensivo aos Embargos quando se comprovar a relevância de seus fundamentos e o prosseguimento da execução acarretar um dano de difícil ou incerta

reparação ao executado, uma vez que a execução já esteja garantida.

Os relevantes fundamentos mostram-se evidentes pela afronta direta ao princípio da legalidade, pela inobservância do art. 32, § 1.º, do Código Tributário Nacional, bem como pela invasão de competência da Embargada, de acordo com os preceitos constitucionais.

Ademais, o imóvel do Embargante já está na iminência de penhora, o que pode acarretar-lhe indevidamente a perda da propriedade, sendo tal situação tão grave a ponto de não ter como aguardar o julgamento final da presente ação.

Destarte, pelos motivos apresentados, requer a concessão do efeito suspensivo até a decisão final, uma vez que os presentes Embargos encontram-se garantidos, nos termos do art. 9.º da Lei 6830/1980.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, requer:

a) que os presentes Embargos sejam recebidos e processados por dependência à Execução Fiscal, concedendo-lhe o efeito suspensivo imediato, nos termos do art. 919, § 1.º, do Código de Processo Civil até a decisão final;

b) sejam acolhidos e julgados procedentes, para os fins de desconstituição do título executivo e a consequente extinção da Execução Fiscal, nos termos do art. 32, § 1º, do CTN;

c) a exclusão do Executado do polo passivo, bem como o levantamento da penhora do imóvel, por medida de justiça;

d) a intimação da Embargada, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se sobre os presentes Embargos;

e) condenação da Embargada nas custas processuais e honorários advocatícios;

f) dispensa da audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

IV – DAS PROVAS

Protesta provas o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela prova documental e pericial, e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do Douto Juízo.

V – VALOR DA CAUSA

Dá a presente causa o valor de R\$... (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...



Importante

Com o intuito de auxiliar os candidatos ao certame da OAB, o examinando poderá abrir um tópico específico para as provas, conciliação e mediação e também para o valor da causa, evitando, assim, possíveis esquecimentos quando da redação da peça prático-profissional.



Revisão da estrutura dos embargos à execução fiscal

- Endereçamento
- Distribuição por Dependência à Execução Fiscal
- Qualificação do Embargante
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação da Embargada
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito
 - deverá ser aberto um tópico para exposição do efeito suspensivo;
- Do pedido
- Das provas
- Do valor da causa
- Desfecho

3.9 EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

3.9.1 Principais características

A exceção ou **objeção de pré-executividade** é o exercício do direito de petição constitucionalmente previsto, sendo admitida **após o ajuizamento da execução fiscal** para evitar as restrições patrimoniais do sujeito passivo decorrente da penhora.

Uma vez que se trata de exercício decorrente do direito de petição admitido em matéria tributária para o sujeito passivo justamente com o fito de **evitar a garantia do**

juízo das execuções, não há cabimento de exceção nos casos de penhora.

Não cabe a exceção de pré-executividade em toda e qualquer circunstância, devendo o executado examinar a existência simultânea de **dois requisitos**:

I – **requisito material**: é indispensável que a matéria invocada seja **suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz** (ordem pública) ou que acarrete alguma **nulidade absoluta no processo executivo**;

II – **requisito formal**: é indispensável que a decisão a ser tomada pelo juízo competente das execuções **não necessite de dilação probatória**.

A exceção de pré-executividade caberá apenas nessas duas circunstâncias cumulativas. A falta de qualquer circunstância levará a discussão em sede de **embargos à execução fiscal**.

Os casos mais comuns de utilização de exceção de pré-executividade são:

I – ilegitimidade de parte;

II – obrigação tributária ilíquida;

III – erros formais no título;

IV – decadência e prescrição.

Em se tratando de **ilegitimidade de parte** deverá ser analisada qual situação em específico, uma vez que, se os responsáveis constavam na CDA, não cabe a discussão da ilegitimidade por meio de exceção, mas, sim, por meio de embargos à execução fiscal. No entanto, nos casos de redirecionamento da execução fiscal contra a pessoa dos responsáveis que não constavam na CDA, a defesa poderá ser realizada mediante exceção de pré-executividade.

De acordo com a Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade só será admitida na execução fiscal relativamente às **matérias conhecíveis de ofício** e que **não demandem exame de provas**.

3.9.2 Cabimento

Conforme já salientado, o cabimento de exceção de pré-executividade conjuga a existência de dois requisitos: um de **caráter material** (matéria de ordem pública ou nulidade absoluta do processo executivo) e outro de **caráter formal** (prova pré-constituída, não tendo cabimento a dilação probatória).

É admissível, na exceção de pré-executividade, a **suspensão da execução fiscal**

com base no **poder geral de cautela do juízo**, estabelecido no art. 297 do CPC/2015.

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.



Note bem

Na peça de Exceção de Pré-Executividade, o candidato deverá abrir um tópico do **cabimento da exceção**, tendo por base o disposto na Súmula 393 do STJ.

3.9.3 Competência

A **competência para o julgamento** da exceção de pré-executividade é o **mesmo para os embargos à execução fiscal**. Neste caso, o juízo das execuções competente é aquele em decorrência do tributo em questão, se federal, estadual ou municipal.

Assim, podemos definir a competência para arguição de exceção de pré-executividade, conforme a seguir:

TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ... Vara das Execuções Fiscais Federais da Seção (ou Subseção) Judiciária de ...	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara das Execuções Fiscais da Comarca de ... ou Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Anexo Fiscal da Comarca de ...



Note bem

Nos exames da OAB, o candidato somente deverá se utilizar dos endereçamentos acima indicados caso o problema **não identifique o juízo das execuções**.

3.9.4 Fundamento da ação e nomenclatura adequada

A exceção de pré-executividade tem o seu fundamento no art. 5.º, XXXIV, *a*, e XXXV da CF/1988 e, notadamente, na Súmula 393 do STJ. Caberá **pedido de efeito suspensivo da execução fiscal**, nos termos do art. 297 CPC/2015, por meio de denominado **poder geral de cautela do juízo**.

Assim, a nomenclatura correta a ser adotada será: **Exceção de Pré-Executividade**.

3.9.5 Pedido

O pedido na exceção de pré-executividade deverá conter os seguintes itens:

I – que a presente exceção de pré-executividade seja recebida, concedendo o efeito suspensivo imediato à execução fiscal n.º ..., nos termos do art. 297 do CPC/2015 até a decisão final;

II – seja o pedido julgado procedente para os fins de anular o processo executivo, nos termos do artigo ... (indicar os artigos que fundamentaram o direito);

III – a exclusão do Excipiente do polo passivo da execução fiscal;

IV – a intimação da Excepta para que apresente as razões de estilo, nos termos da lei;

V – condenação da Excepta nas custas processuais e honorários advocatícios.

Uma observação extremamente importante é a **inexistência de um tópico específico para a produção de provas**, uma vez que esta é pré-constituída, devendo estar traduzida na própria petição.

Não se admite na petição de exceção de pré-executividade **valor da causa**, uma vez que não se trata de ação, mas simples **direito de petição**.



Importante – 1

Como não se trata de ação, mas de exercício do direito de petição, não há cabimento de qualquer tópico de dispensa de audiência de conciliação e mediação.



Importante – 2

Ainda que ocorra a extinção parcial do processo executório, é **devida a condenação em honorários** na exceção de pré-executividade. A jurisprudência do STJ era firme em declarar o cabimento de honorários tanto na execução quando nos embargos, porque eram considerados ação de conhecimento autônoma, extinta por sentença. Entretanto, conforme entendimento no REsp 664.078, entendeu-se que é **plenamente cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade**.

3.9.6 Desfecho

O desfecho é a conclusão da medida judicial dentro dos padrões de técnica forense.

O desfecho mais indicado passa a ser o seguinte:

Termos em que,
pede deferimento.
Local, data.
Advogado(a)
OAB/ ... n.º ...

3.9.7 Modelo de exceção de pré-executividade

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ANEXO FISCAL DA CO
DE SERRA NEGRA

(espaço de cinco linhas)

Execução Fiscal n.º ...

João, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG n.º ... devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º ..., residente e domiciliado na ..., bairro, cidade, Estado por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com escritório na ..., bairro, cidade, Estado, onde receberá as devidas intimações, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil de 2015, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 5.º, XXXIV, “a”, e XXXV da Constituição Federal e Súmula 393 do STJ arguir

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

em face da Municipalidade de Serra Negra, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificada, por meio de seu procurador, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

O Excipiente adquiriu, em 1980, um imóvel situado na zona rural do Município de Serra Negra. Em 2009, a Câmara Municipal aprovou lei que alterou o perímetro urbano do Município passando a incluir o imóvel do Excipiente. Porém, a área manteve características típicas de zona rural, sem apresentar qualquer espécie de equipamento urbano, tal como água encanada, iluminação pública, saneamento básico ou calçamento.

Recentemente, o Excipiente recebeu notificação de lançamento de IPTU relativo ao exercício de 2010, ocasião em que realizou o pagamento, mesmo não concordando com a exigência. Independentemente disso, a Excepta inscreveu suposto débito em dívida ativa e ajuizou a presente execução fiscal, sendo citado o Excipiente para depositar (recolher o valor do tributo supostamente devido) a quantia devida sob pena de penhora.

Inconformado com a referida exigência, uma vez que o débito encontra-se pago, vem ao Douto Juízo arguir a presente exceção.

II – DO DIREITO

a) Do cabimento da Exceção de Pré Executividade

Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Vê-se, claramente, que a situação fática enseja o cabimento dessa petição, motivo este que o Excipiente requer que esta seja recebida e processada.

b) Do Mérito

Conforme os fatos supracitados, o imóvel pertencente ao Excepto está situado em zona rural e, com a modificação legislativa, passou o aludido imóvel a ser incluído no perímetro considerado urbano.

Mesmo não concordando com a exigência, o Excipiente realizou tempestivamente o pagamento do referido imposto, inexistindo qualquer débito pelo inadimplemento, conforme as guias de pagamento do referido imposto em anexo.

Ora, é cediço que o pagamento realizado de maneira integral acarreta a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, sendo a exigência do tributo completamente descabida e indevida.

Ademais, seria uma afronta constitucional o Excipiente ter que garantir o juízo das execuções apenas para ter o seu direito de defesa assegurado.

Conforme reza a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exceção de pré-executividade nas matérias conhecíveis de ofício e que não demandem exame de provas.

Resta evidente que os pressupostos ensejadores do referido direito de petição estão mais do que comprovados, uma vez que o pagamento torna nula qualquer exigência fiscal (nulidade absoluta do processo executivo) e, mediante apresentação das guias de pagamento em anexo, inexistente qualquer dilação probatória.

c) Da concessão do efeito suspensivo

Conforme estabelece o art. 297 do Código de Processo Civil de 2015, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito de outra lesão grave e de difícil reparação.

É cediço que o prosseguimento da execução fiscal baseada em nulidade absoluta acarretará enormes prejuízos ao Excipiente, podendo inclusive pelo não pagamento ter os seus bens contristados judicialmente.

Destarte, pelos motivos apresentados, requer a concessão do efeito suspensivo até a decisão final, por medida de inteira justiça.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, requer:

a) que a presente exceção de pré-executividade seja recebida, concedendo o efeito suspensivo imediato à execução fiscal n.º ..., nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil até a decisão final;

b) seja o pedido julgado procedente para os fins de anular o processo executivo, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional;

c) a exclusão do Excipiente do polo passivo da execução fiscal;

d) a intimação da Excepta para que apresente as razões de estilo, nos termos da lei;

e) condenação da Excepta nas custas processuais e honorários advocatícios.

Termos em que,

pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

Na exceção de pré-executividade, não tem cabimento o tópico específico das provas nem o tópico do valor da causa, por se tratar apenas de um direito de petição e não de uma ação propriamente dita.



Revisão da estrutura da exceção de pré-executividade

- Endereçamento
- Determinação do n.º da execução fiscal
- Qualificação do Excipiente
- Fundamento da ação e nome da ação em destaque
- Qualificação do(a) Excepto(a)
- Exposição dos Fatos
- Fundamentos do Direito
 - deverá ser aberto um tópico para exposição do efeito suspensivo;
- Do pedido
- Desfecho

PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS



O Novo Código de Processo Civil brasileiro dedica o Livro III da Parte Especial para tratativa dos Processos nos Tribunais, sendo regulados todos os meios de impugnação das decisões judiciais, seja por meio dos **recursos** ou de **demandas autônomas de impugnação de decisões**.

Nas palavras de Alexandre Freitas Câmara, o direito processual civil brasileiro desenvolveu, em longo processo evolutivo, um **sistema de precedentes judiciais** que culminou, do ponto de vista normativo, com a edição do Código de Processo Civil de 2015.

Entende-se por **precedente** como um **pronunciamento judicial**, proferido em um **processo anterior**, que é empregado como base na formação de outra decisão judicial, prolatada em processo posterior. Conforme bem ilustra Nelson Nery, o precedente na *common law* vai muito além da simplificação do julgamento que é normalmente enxergado pela doutrina nacional, de modo geral. Neste caso, invoca-se o precedente porque se pretende que há nele uma analogia que permite que o princípio que justifica o caso anterior cubra também o novo caso.

Em vista do exposto, o que ocorreu, por meio das alterações no Código de Processo Civil de 1973, foi a criação de um precedente próprio, consubstanciado na

súmula, nas decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral.

O Código de Processo Civil deixou para cada regimento interno de cada Tribunal a função de regular a uniformização de jurisprudência por meio da súmula de jurisprudência dominante.

Evidentemente, há ligação entre o conceito de **precedente** e o de **jurisprudência**. A **jurisprudência** é um conjunto de decisões judiciais, proferidas pelos Tribunais, sobre uma determinada matéria, em um mesmo sentido. A identificação de uma linha de jurisprudência constante se faz a partir do exame de um conjunto de decisões judiciais, e cada uma destas decisões poderá ser considerada um **precedente**.

A jurisprudência dos Tribunais deve ser **estável, íntegra e coerente**, nos termos do art. 926 do CPC/2015:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1.º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2.º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Essa exigência de **estabilidade** indica que as decisões constantes e uniformes a respeito de determinadas matérias não podem ser simplesmente modificadas arbitrariamente ou de forma discricionária.

Na súmula da jurisprudência dominante do Tribunal não se deve apenas indicar o enunciado, mas também as decisões em que tal matéria foi enfrentada e decidida. Isso serve para que se permita o conhecimento das circunstâncias que levaram à formação daquele entendimento.



Importante

Enunciado de súmula não é um precedente, sendo um extrato de diversos pronunciamentos sobre a mesma matéria.

A elaboração das súmulas dos tribunais se dará na forma prevista no respectivo **Regimento Interno**, conforme ilustra o art. 926, § 1.º, do CPC/2015.

4.1 ORDEM DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E INCIDENTES PROCESSUAIS NOS TRIBUNAIS

Conforme bem ilustra o eminente jurista Alexandre Freitas Câmara, **todos os processos de competência originária, recursos e outros incidentes processuais** que se instaurarem perante um Tribunal deverão ser registrados no protocolo no dia de sua entrada, devendo ser imediatamente distribuídos.

Art. 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição.

Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau.

A distribuição será feita nos termos do **Regimento Interno do Tribunal**, observando-se a alternatividade dos integrantes do mesmo. Tal distribuição deve ser pública e realizada por sorteio eletrônico:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará preventivo o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Feita a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que terá o prazo de **30 (trinta) dias** para restituí-los à Secretaria:

Art. 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar o voto, restitui-los-á, com relatório, à secretaria.

Verificando o relator a ocorrência de **fato superveniente à decisão recorrida** ou de **existência de questão apreciável de ofício** ainda não examinada, e que deva ser considerada no julgamento do recurso, deverá intimar as partes para que se manifestem no prazo de **5 (cinco) dias**, a fim de assegurar a plena observância à garantia do contraditório prévio e efetivo, vejamos:

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1.º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§ 2.º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

Caso o relator verifique a ocorrência de algum **vício sanável** – mesmo sendo aqueles que podem ser conhecidos de ofício – deverá determinar a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou ainda na primeira instância, intimando-se as partes. Sendo cumprida a diligência, sempre que possível, o feito prosseguirá em direção ao julgamento.

Toda a orientação de ordem e organização dos processos nos respectivos tribunais estão inseridos entre os arts. 929 a 946 do CPC/2015.

4.1.1 Incidente de assunção de competência

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1.º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2.º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3.º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4.º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Trata-se de um **incidente processual** a ser instaurado quando o julgamento de recurso, de **remessa necessária** ou de **processo de competência originária de tribunal de segunda instância** envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem a repetição de múltiplos processos.

Segundo preleciona Nelson Nery Junior, a proposta do relator deverá ser aprovada pelo Colegiado (Câmara ou Turma), a quem caberá remeter a causa ao exame do órgão colegiado maior. Afetada a causa ao colegiado maior, é dele a competência para decidir se deve ou não assumir essa mesma competência. Assumindo-a, deverá julgar a causa.

As **razões de interesse público** que podem fundar na **existência da assunção de competência** compreendem:

- I – **prevenção de divergência** entre as turmas e câmaras dos Tribunais;
- II – **dirimir divergências** entre as próprias turmas e câmaras dos Tribunais;
- III – **revisão de questão de constitucionalidade** já decidida pelo Pleno;
- IV – **revisão de súmula do Tribunal**.

A decisão proferida com vistas a prevenir ou compor divergência entre os órgãos fracionários de um mesmo Tribunal **vincula apenas esses órgãos**, que deverão seguir o entendimento firmado pelo órgão competente para tanto.

Caso o relator identifique divergência existente ou que venha a existir, em relação a relevante questão de direito, poderá também propor a instauração do incidente.

4.1.2 Incidente de arguição de inconstitucionalidade

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

- I – rejeitada, prosseguirá o julgamento;
- II – acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1.º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os

prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.
§ 2.º A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.

§ 3.º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

O reconhecimento da inconstitucionalidade de leis ou atos normativos nos tribunais exige observância à **cláusula de reserva de plenário**, estabelecida no art. 97 da CF/1988, pela qual **só se pode afirmar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo com o voto da maioria absoluta dos integrantes do Tribunal ou de seu órgão especial**.

Nos casos em que os Tribunais Estaduais exercem controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 125, § 2.º, da CF/1988, este já é de **competência do Plenário** ou do **Órgão Especial**, o que assegura a observância constitucional de reserva de plenário.

No caso de ser suscitada, para fins de controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, será o caso de se verificar se é preciso instaurar o incidente.

A declaração de inconstitucionalidade não é sucedâneo de recurso, sendo levantada no curso de um processo e constituindo-se como prejudicial do julgamento da causa no Tribunal. Assim, esta fica sobrestada até que se resolva o referido incidente.

A **arguição pode ser manifestada pelas partes ou pelo Ministério Público**, sendo que o relator submeterá a arguição à Câmara, Turma ou outro órgão fracionário para o julgamento da causa, que é, no mais das vezes, um recurso.

Caso seja **rejeitada a alegação, prossegue-se normalmente no julgamento do recurso**; se a Câmara entender que há procedência, remeter-se-á a questão ao Plenário do Tribunal, que, de acordo com o art. 97 da CF/1988, passa a ser o órgão

competente para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

4.1.3 Conflito de competência

Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.

Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar.

Art. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa.

Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência.

Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal:

I – pelo juiz, por ofício;

II – pela parte e pelo Ministério Público, por petição.

Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.

Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.

Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.

Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:

I – súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

II – tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

Art. 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento.

Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

Art. 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal.

Art. 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa.

Temos o **conflito de competência** quando dois ou mais juízos se declaram competentes para o mesmo processo (**conflito de competência positivo**) ou quando dois ou mais juízos se declaram incompetentes para o mesmo processo (**conflito de competência negativo**). Temos ainda situação quando, entre dois ou mais juízos, surge controvérsia acerca da reunião ou da separação de processos.

A solução do conflito dependerá da **instauração de um incidente processual** a ser decidido por Tribunal, tendo o seu procedimento regulado pelos arts. 951 a 959 do CPC/2015.

O julgamento do conflito de competência cabe, pela regra geral, ao **Tribunal a que esteja, vinculados os juízos em conflito**, podendo ocorrer, entretanto, a instauração de conflito de competência entre os órgãos jurisdicionais que não se submetem ao mesmo Tribunal.

4.1.4 Homologação de decisão estrangeira e concessão d exequatur à carta rogatória

Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado.

§ 1.º A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória.

§ 2.º A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 3.º A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo.

Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado.

§ 1.º É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional.

§ 2.º A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente.

§ 3.º A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira.

§ 4.º Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira.

§ 5.º A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo

Superior Tribunal de Justiça.

§ 6.º Na hipótese do § 5.º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência.

Art. 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência.

§ 1.º A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória.

§ 2.º A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior.

§ 3.º O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira.

§ 4.º Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:

I – ser proferida por autoridade competente;

II – ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;

III – ser eficaz no país em que foi proferida;

IV – não ofender a coisa julgada brasileira;

V – estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado;

VI – não conter manifesta ofensa à ordem pública.

Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas

rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2.º.

Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira.

Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória.

Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional.

Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso.

Trata-se de um tema de suma importância em razão da **internacionalização das relações jurídicas, econômicas e sociais** e que se vincula, diretamente, à existência de um sistema global de **cooperação jurisdicional internacional**.

As sentenças estrangeiras somente produzem efeitos no Brasil após sua **homologação pelo Superior Tribunal de Justiça**, cuja competência está fixada no art. 105, I, *i*, da CF/1988, **excetuando-se**, apenas, a **sentença de divórcio consensual**, a qual produz efeito no Brasil independentemente de homologação.

Não apenas sentenças poderão ser homologadas no Brasil, mas **atos estrangeiros** que não tenham natureza jurisdicional, mas que correspondam a pronunciamentos que no Brasil teriam tal natureza.

As **decisões interlocutórias estrangeiras** podem produzir seus efeitos no Brasil, não se tratando nesse caso de homologação, sendo tão somente o caso de o **Superior Tribunal de Justiça** conceder ***exequatur*** à carta rogatória, incluindo-se decisões interlocutórias estrangeiras concessivas de tutela de urgência.

O **processo da homologação da sentença estrangeira** é regido pelos Tratados Internacionais em vigor no Brasil, além das normas regimentais internas do STJ consolidadas nos arts. 216 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Quando do processo de homologação de sentença estrangeira, não se reexamina o conteúdo da decisão homologanda (juízo de delibação), limitando-se a verificação da presença de requisitos formais.

Entre os **requisitos para a homologação da sentença estrangeira**, podemos identificar:

I – autoridade competente;

II – citação regular;

III – sentença homologanda eficaz no Estado de origem;

IV – não homologação de sentença estrangeira que ofenda coisa julgada já formada no Brasil e que não ofenda a ordem pública brasileira.

Além dos requisitos legais, os arts. 216 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça preveem que a sentença deve ser autenticada pelo cônsul brasileiro do Estado de origem.

4.1.5 Ação rescisória

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,

prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1.º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2.º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I – nova propositura da demanda; ou

II – admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3.º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4.º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5.º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6.º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5.º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:

I – quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;

II – o terceiro juridicamente interessado;

III – o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

IV – aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.

§ 1.º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2.º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3.º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

I – cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

§ 1.º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.

§ 2.º O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários mínimos.

§ 3.º Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.

§ 4.º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332.

§ 5.º Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda:

I – não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2.º do art. 966;

II – tiver sido substituída por decisão posterior.

§ 6.º Na hipótese do § 5.º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento

comum.

Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento.

Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.

Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.

Art. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente.

Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindir a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.

Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2.º do art. 82.

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1.º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2.º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3.º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.

Denomina-se **ação rescisória** a demanda pela qual se busca **desconstituir decisão coberta pela coisa julgada**, com **eventual rejugamento de causa original**. Uma vez formada a coisa julgada (formal ou material), o meio adequado para desconstituir-se da decisão que já tenha sido alcançada por tal autoridade é a propositura de ação rescisória.

São **rescindíveis**:

I – decisões de mérito alcançadas pela coisa julgada material;

II – decisões terminativas alcançadas pela coisa formal;

III – decisões de inadmissibilidade de recurso que se tenham tornado irrecuráveis.

Não apenas as sentenças podem ser objeto de ação rescisória, mas também as **decisões interlocutórias**, desde que haja o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015.

A ação rescisória pode ser proposta por quem foi **parte no processo original** ou por seus **sucessores**, por **terceiros juridicamente interessados**, pelo **Ministério Público** ou por **aquele que não foi ouvido no processo de que deveria ter obrigatoriamente participado** (ex.: litisconsorte necessário não citado).

A **legitimidade passiva** alcança a todos aqueles que, tendo sido partes no processo original, não figurem como autores na ação rescisória.

É **competente** para conhecer da ação rescisória o **Tribunal prolator da decisão rescindenda**, sendo **cada Tribunal competente para conhecer de ação rescisória contra seus próprios julgados**.

4.1.6 Incidente de resolução de demandas repetitivas

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1.º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2.º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3.º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4.º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5.º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I – pelo juiz ou relator, por ofício;

II – pelas partes, por petição;

III – pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os

documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça.

§ 1.º Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro.

§ 2.º Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados.

§ 3.º Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário.

Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade,

considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

II – poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III – intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§ 2.º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

§ 3.º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

§ 4.º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3.º deste artigo.

§ 5.º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito

controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.

§ 1.º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.

§ 2.º Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente.

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

I – o relator fará a exposição do objeto do incidente;

II – poderão sustentar suas razões, sucessivamente:

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos;

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência.

§ 1.º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado.

§ 2.º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários.

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

§ 1.º Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

§ 2.º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1.º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2.º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Trata-se de um mecanismo utilizado para **assegurar solução uniforme a demandas repetitivas**, sendo consideradas as **demandas idênticas** que, em grande quantidade, são propostas perante o Poder Judiciário. Diz-se que elas são **idênticas** por terem **objeto e causa de pedir idênticas**, ainda que de partes diferentes.

Não se confunde tal situação com a **conexão**. Nesta, **duas ou mais demandas têm a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto** e nas **demandas repetitivas** temos **inúmeras demandas seriais** tratando do **mesma causa de pedir e objeto**.

A ideia central é assegurar que os **casos iguais recebam resultados iguais**, sendo que tal incidente poderá ser **instaurado perante os Tribunais de Segunda Instância**. Por meio desse incidente, produz-se uma decisão que, **dotada de eficácia vinculante**, assegure a **isonomia e segurança jurídica**.

Alguns **requisitos cumulativos** são exigidos para o atendimento do incidente processual:

I – existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II – existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;

III – existência de, pelo menos, um processo pendente perante o Tribunal, seja recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do próprio Tribunal;

IV – inadmissibilidade do incidente no caso de algum Tribunal Superior ou o STF já possuir, no âmbito de sua competência, afetado recurso para a definição de tese sobre a mesma questão repetitiva.

O incidente de resolução de demandas repetitivas **não está sujeito ao pagamento de custas**, sendo **legitimados** para provocar a instauração **qualquer juiz ou relator que tenha, sob sua direção, processos instaurados por ajuizamento de demanda repetitiva, qualquer das partes daqueles processos, o Ministério Público e a Defensoria Pública.**

4.1.7 Reclamação

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1.º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2.º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e

dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3.º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4.º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5.º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6.º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.

Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.

Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a

decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

Trata-se de um **processo de competência originária dos Tribunais**, tendo por **finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões**.

De acordo com o art. 988 do CPC/2015, temos os seguintes **casos para cabimento da reclamação**:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Vale ressaltar que, da **decisão judicial ou ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante**, caberá **reclamação ao STF**, nos termos do art. 7.º da Lei 11.417/2006. Tem cabimento a reclamação **não só contra atos jurisdicionais**, mas também contra **atos administrativos**. Neste caso, contudo, a reclamação só será admitida mediante o **prévio esgotamento das vias administrativas** (art. 7.º, § 1.º, da Lei 11.417/2006).

A reclamação **pode ser ajuizada por qualquer parte interessada** ou pelo **Ministério Público**, sendo dirigida ao **Tribunal cuja competência se pretende preservar** ou cuja autoridade se pretenda garantir.

Não se admite reclamação para impugnar decisão judicial já transitada em julgado, devendo ser proposta no prazo de interposição de recurso contra a decisão impugnada, ou quando ainda pendente de julgamento tal recurso.

4.2 RECURSOS PROCESSUAIS

Os recursos processuais fazem parte do direito à ampla defesa e contraditório do sujeito passivo e do próprio Estado. São mecanismos de utilização voluntária,

manifestando-se como uma **insatisfação com a decisão prolatada**.

O recurso destina-se a **impugnar decisões judiciais**, sendo que atos não provenientes dessas decisões não poderão ser atacados por recurso.

Por meio do recurso, quatro resultados podem ser alcançados: **reforma, invalidação, esclarecimento e integração da decisão judicial impugnada**.

Uma vez que inexistente em matéria tributária um Código de Processo Tributário que discipline as medidas judiciais e administrativas adotadas pelo Fisco ou pelo sujeito passivo, devemos utilizar das disposições contidas no Código de Processo Civil de 2015, atinentes às questões recursais, a partir dos arts. 994 e seguintes, *in verbis*:

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I – apelação;

II – agravo de instrumento;

III – agravo interno;

IV – embargos de declaração;

V – recurso ordinário;

VI – recurso especial;

VII – recurso extraordinário;

VIII – agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX – embargos de divergência.

Existe uma série de **princípios aplicáveis aos recursos**, entre os quais podemos citar alguns deles:

a) **Princípio da Unicidade**: de uma mesma decisão judicial, pelo regramento geral, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso, excepcionalmente, admitindo-se de uma mesma decisão o **recurso especial** e o **recurso extraordinário**;

b) **Princípio da Fungibilidade Recursal**: mesmo que um recurso inapropriado seja utilizado, existe a **possibilidade de o tribunal admiti-lo como correto**, principalmente quando se pairam dúvidas acerca de qual recurso é cabível;

c) **Princípio do Duplo Grau de Jurisdição**: o direito de obtenção de **reexame de uma decisão judicial de primeiro grau** é um direito subjetivo assegurado pelo devido

processo legal, no entanto, de maneira relativa, uma vez que existem situações legalmente previstas que inadmitem o duplo grau de jurisdição;

d) **Princípio da Correspondência:** deve ocorrer **identidade entre o pronunciamento judicial e o recurso cabível**. Assim, despachos são irrecorríveis, as decisões interlocutórias são agraváveis e as sentenças apeláveis.

4.2.1 Juízo de admissibilidade e de mérito recursal

O denominado **juízo de admissibilidade** verificará se os pressupostos recursais foram completamente atendidos. Dentre os itens que são analisados no juízo de admissibilidade, podemos citar a **tempestividade recursal, cabimento, legitimidade** etc.

Após a **análise da admissibilidade**, o recurso passará para a **análise** ou **juízo de mérito**, em que o tribunal competente dará o seu provimento ou não, levando em consideração a pretensão jurisdicional requerida e os argumentos suscitados pelas partes.

A **legitimidade para recorrer** é a aptidão que deve ter aquele que interpõe o recurso para, naquele caso concreto, impugnar a decisão judicial. Assim, tem legitimidade para recorrer: as **partes**, o **terceiro prejudicado** e o **Ministério Público**.

Além da legitimidade, exige-se ainda que o recorrente tenha **interesse em recorrer**. Passa a ser a utilidade do recurso interposto. Tal interesse se desdobra em dois elementos: **interesse-necessidade** e **interesse-adequação**.

O recurso é **necessário** quando é o único meio capaz de proporcionar, no mesmo processo, o resultado pretendido.

No sistema processual brasileiro existe previsão de várias espécies recursais distintas, conforme disposto no artigo já demonstrado. Assim, o recurso deve ser **adequado** para que **possa vir a ser admitido** e, por conseguinte, **julgado no mérito**. A **interposição de recurso inadequado** implica na sua **inadmissibilidade por ausência de interesse recursal**.

Não se trata, porém, de um quesito absoluto. Por força do **princípio da primazia da resolução de mérito**, deve-se buscar **sanar os vícios processuais** que podem ser sanados. Tal situação se aplica, da mesma forma, para a admissibilidade de recursos.

A **regra da convertibilidade** se aplica em dois casos: a **interposição de recurso especial em caso em que seria admissível o recurso extraordinário** acarreta a

conversão daquele neste, na forma do art. 1.032 do CPC/2015. Do mesmo modo, a **interposição de recurso extraordinário em caso em que seria adequada a interposição de recurso especial** também acarreta a conversão, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015.

Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.

Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.

Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

Já a **regra da fungibilidade** se aplica aos demais casos. Sempre que um recurso inadequado for interposto no lugar do recurso adequado, será possível admitir o **recurso errado** no lugar do **recurso certo** (sem que haja necessidade de conversão) se não houver erro grosseiro na sua interposição nem má-fé do recorrente.



Importante

Tal possibilidade não pode ser aplicada às provas aplicadas no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que, conforme consta explicitamente no edital, o erro do nomen juris da peça processual acarreta a **nulidade da peça prático-profissional**, sendo atribuída a nota **zero**.

4.2.2 Pressupostos e impedimentos recursais

Dentre os pressupostos recursais existentes, temos a **análise de competência recursal**. Qual é o órgão jurisdicional a que se dirige o recurso, chamado de *juízo ad quem*, investido de jurisdição. A investidura de jurisdição do órgão julgador é a **atribuição, por ele recebida da Constituição Federal de 1988 de atuar em determinado tipo de causa**.

Entretanto, poderá acontecer de um recurso ser dirigido a tribunal não investido de jurisdição. Nesse caso, por força do princípio da **primazia da resolução de mérito**, deverá o tribunal não investido de jurisdição determinar a **remessa dos autos ao tribunal investido da função de julgar aquele recurso**, sanando-se, desse modo, o vício processual.

Outro pressuposto recursal é a **capacidade processual**. É que para o recurso ter o seu mérito apreciado é essencial que o recorrente tenha capacidade processual plena. Exige-se dele não só que tenha **capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo**, mas que tenha **capacidade postulatória**.

O último pressuposto processual a ser observado é a **regularidade formal** da interposição do recurso, uma vez que apenas recursos regularmente interpostos podem ter seu mérito apreciado.

A regularidade formal exige: **tempestividade, preparo, forma e motivação**.

Inicialmente, é preciso que o recurso seja interposto no prazo legal assinalado. Como regra geral, tal prazo é de **15 (quinze) dias**, ressalvados os casos de **embargos de declaração**, que é de **5 (cinco) dias**.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5.º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Recurso intempestivo é inadmissível, sendo este um dos vícios processuais **absolutamente insanáveis**. Ademais, exige-se como regra geral o **preparo do**

recurso. Passa a ser o adiantamento das custas relativas a um determinado ato processual. A maioria dos recursos exige, como condição de admissibilidade, o **recolhimento de custas.**

Incumbe ao recorrente, no **ato de interposição do recurso**, exigir o preparo que seja exigível:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

A **regularidade da interposição do recurso** exige que seja interposto pela **forma correta.** A legislação processual exige que seja apresentado por petição, sendo esta **motivada.** A **admissibilidade do recurso** exige que, na petição de interposição, sejam apresentados os fundamentos pelos quais se recorre.

Uma vez que foram observadas as condições do recurso e os pressupostos recursais, verifica-se que o recurso não será apreciado se não estiver presente qualquer **impedimento recursal.**

Entre os impedimentos recursais, temos:

I – **Desistência:** é o ato pelo qual o recorrente **abre mão de ver julgado o recurso interposto.** Este ato **não depende de anuência do recorrido** nem dos litisconsortes. Uma vez que foi manifestada a desistência do recurso, **caberá ao relator homologá-la,** por decisão unipessoal.

II – **Renúncia:** é o ato pelo qual se **abre mão do direito de interpor recurso** contra uma determinada decisão. Existe diferença entre **renúncia** e **desistência,** levando em consideração o momento em que a vontade é manifesta, uma vez que a desistência diz respeito ao **recurso já interposto** e a renúncia é manifesta **sem que tenha ocorrido a interposição do recurso.**

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

III – **Aceitação**: quando se **aceita o que fora decidido**, de forma expressa ou tácita, não se pode, posteriormente, interpor recurso contra a decisão que já aceitou.

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

4.2.3 Efeitos dos recursos

Os efeitos dos recursos podem ser divididos em dois grupos: os **efeitos da interposição** e os **efeitos do julgamento**.

Quando da interposição dos recursos, admitem-se três efeitos: **impeditivo**, **devolutivo** e **suspensivo**.

O **efeito impeditivo** é aquele pelo qual a **interposição de recurso admissível** produz, como consequência, um **impedimento à preclusão da decisão recorrida** ou ao seu trânsito em julgado. Trata-se de um **efeito estabilizador da decisão**. Passa a ser o único efeito da interposição que todas as espécies recursais são, em tese, capazes de produzir.

O **efeito devolutivo**, segundo entendimento doutrinário, decorre do **próprio reexame da decisão judicial proferida**, seja pelo **próprio juízo** que proferiu a decisão ou por um **órgão hierarquicamente superior**. No entanto, tal efeito poderá sofrer restrições. Uma das limitações mais importantes na devolutividade recursal passa a ser a seguinte:

I – o recurso somente poderá levar a reexame a matéria que foi impugnada; **matéria que não tenha sido impugnada sofrerá preclusão**.

O **efeito suspensivo** é aquele que a causa acarreta **impedimento dos efeitos do ato decisório**. Assim, caso um recurso seja recebido no efeito devolutivo, não poderá ser imediatamente executado, salvo quando houver expressa previsão legal.

Além dos efeitos de interposição, podemos adotar os **efeitos do julgamento**, sendo as consequências que se podem produzir pelo fato de ter havido o **julgamento do mérito do recurso**. Os efeitos do julgamento do mérito do recurso podem ser dois:

a anulação e a substituição da decisão.

4.3 APELAÇÃO

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1.º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2.º Se as questões referidas no § 1.º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3.º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterà:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

§ 1.º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2.º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3.º Após as formalidades previstas nos §§ 1.º e 2.º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

II – se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1.º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I – homologa divisão ou demarcação de terras;

II – condena a pagar alimentos;

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI – decreta a interdição.

§ 2.º Nos casos do § 1.º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3.º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II – relator, se já distribuída a apelação.

§ 4.º Nas hipóteses do § 1.º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da

matéria impugnada.

§ 1.º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2.º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3.º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4.º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5.º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

4.3.1 Principais características

O **recurso de apelação** vem estabelecido, atualmente, nos arts. 1.009 e seguintes do CPC/2015, sendo um recurso destinado à **impugnação de sentenças e decisões interlocutórias não agraváveis**.

Não tem cabimento o recurso de apelação nos **Juizados Especiais Cíveis** (Lei 9.099/1995), uma vez que as decisões ali proferidas são **impugnáveis** por meio de **recurso inominado**.

Tratando-se dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstos na Lei 12.153/2009, será admitido **recurso** contra a sentença, nos termos do art. 4.º, não havendo qualquer prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, pelas pessoas jurídicas de direito público, mesmo quando da interposição de recursos.

De acordo com o art. 34 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), só terá cabimento o recurso de apelação das **sentenças proferidas em execuções de valor superior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN)**. Tal interpretação se dá *a contrario sensu*, já que o artigo em comento determina que, se os valores em sentença forem iguais ou inferiores a 50 ORTN, **só se admitirão embargos infringentes ou embargos de declaração**.

4.3.2 Interposição do recurso

O recurso de apelação será interposto no prazo de **15 (quinze) dias da publicação da decisão de primeiro grau**. Deve conter os seguintes requisitos:

I – nome e qualificação das partes;

II – fundamentos de fato e de direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

A petição de interposição, bem como as razões serão remetidas ao **Tribunal competente** (no caso, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, respectivamente).

Em matéria tributária, sempre analisaremos a decisão de acordo com o **tributo em questão**.

A petição de interposição e razões serão encaminhadas para os seguintes tribunais:

TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS
Excelentíssimo Senhor Doutor	Excelentíssimo Senhor Doutor

Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da ... Região.	Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
--	---

4.3.3 Juízo de admissibilidade recursal e fundamentação

Reza o art. 1.010, § 3.º, do CPC que, após as formalidades previstas nos §§ 1.º e 2.º, os autos serão remetidos ao **Tribunal pelo juiz recorrido, independentemente do juízo de admissibilidade.**

Dessa forma, **não ocorre juízo de admissibilidade de apelação pelo *juízo a quo*** (juízo de primeiro grau), **não cabendo a análise dos requisitos, mesmo que de forma provisória.**

Em caso de **usurpação da competência** pelo magistrado, haja vista que a análise de admissibilidade da apelação compete apenas ao *juízo ad quem*, caberá **reclamação perante o Tribunal competente**, por força do art. 988, I, do CPC.

No que tange à **fundamentação**, o apelante deverá indicar o **vício da sentença recorrida**, não sendo admissível uma **apelação genérica**.

O **vício da sentença recorrida** é fundamental para que o tribunal decida pela **reforma** ou pela **anulação** da sentença. Se o **vício** for no **julgamento** (*error in judicando*), sendo provido o recurso, a sentença será **reformada**. Se o **vício** for no **procedimento** (*error in procedendo*), provido o recurso, a sentença será **anulada**.

4.3.4 Efeitos no recurso de apelação

Pela regra geral, a apelação é recebida no duplo efeito: **devolutivo e suspensivo**.

O **efeito devolutivo** passa a ser inerente a todo e qualquer recurso, uma vez que a matéria impugnada pelo apelante será **devolvida para o tribunal**. A matéria que não for impugnada, conforme já salientamos, será preclusa, **salvo em se tratando de matérias de ordem pública** (matérias relacionadas aos pressupostos processuais e às condições da ação).

Caso o tribunal entenda que a sentença proferida, se cumprida, poderá resultar em **lesão grave ou de difícil reparação**, poderá conceder o **efeito suspensivo**.

Na **omissão do juízo**, entende-se que o recurso de apelação foi recebido nos **dois efeitos**, salvo nos casos em que **o recurso de apelação não terá efeito suspensivo**

(art. 1.012 do CPC/2015):

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1.º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I – homologa divisão ou demarcação de terras;

II – condena a pagar alimentos;

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI – decreta a interdição.

4.3.5 Modelo de recurso de apelação

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EC
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ... REGIÃO (ou TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAI
...)

(espaço de cinco linhas)

Processo n.º ...

NOME DO APELANTE (qualificação completa), inconformado com a sentença que .
prolatada nos autos da AÇÃO ..., que move em face de (ou que lhe move) NOME DO APELAD
(qualificação completa), vem por seu advogado, tempestivamente, interpor

RECURSO DE APELAÇÃO,

com fundamento no artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015, cujas razões e guia
comprobatória do preparo seguem acostadas.

Requer o recebimento do presente recurso de Apelação em seus regulares efeitos devolutivo
e suspensivo, bem como a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Termos em que,

pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)
OAB/ ... n.º ...

RAZÕES DE APELAÇÃO

APELANTE: NOME

APELADA: NOME

Origem: (dados do processo)

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLENTA TURMA,

ÍNCLITOS JULGADORES,

I – BREVE RELATO DO OCORRIDO

Trata-se de (narrar o antecedente a sentença)

Contudo o juízo *a quo* entendeu que (narrar o que foi decidido pelo Juiz)

A decisão merece ser reformada, tendo em vista que o juiz não observou preceitos legais basilares do ordenamento jurídico brasileiro.

II – DO CABIMENTO

Inicialmente é importante destacar que o presente recurso tem cabimento nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o ato impugnado tem natureza de sentença.

Além disso, o Apelante é parte no processo, possuindo legitimidade para interposição do presente, como admite o artigo 996 do Código de Processo Civil de 2015.

Também está sendo interposto tempestivamente e acompanhado da guia de preparo, como determinam os artigos 1.003, § 5.º, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

(...)

III – DAS RAZÕES PARA REFORMA/ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA RECORRIDA

Utilização da tese de direito material aplicada ao caso concreto.

IV – DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal seja o recurso *recebido e conhecido* e, em relação ao mérito, lhe seja dado integral *provimento* para reformar (ou anular) a sentença recorrida no sentido de

Requer também a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local, data.

Advogado

OAB/ ... n.º ...

4.4 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1.º;

XII – (Vetado.);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes

requisitos:

I – os nomes das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II – com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1.º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2.º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I – protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II – protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III – postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV – transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V – outra forma prevista em lei.

§ 3.º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum

outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

§ 4.º Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5.º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1.º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2.º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3.º O descumprimento da exigência de que trata o § 2.º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II – ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de

recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III – determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

4.4.1 Principais características

Trata-se de recurso adequado para **impugnar determinadas decisões interlocutórias**, expressamente indicadas em lei como sendo recorríveis em separado.

O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um **rol taxativo** de cabimento desse recurso. O fato da existência de um rol taxativo não implica em afirmar que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita.

A s decisões interlocutórias que não se enquadram no rol taxativo são irrecorríveis em separado, só podendo ser objeto de impugnação em apelação ou contrarrazões de apelação.

4.4.2 Interposição do recurso e juízo de admissibilidade recursal

O **agravo de instrumento** é recurso que se interpõe **diretamente** perante o **Tribunal ad quem**. A **petição de interposição** deverá indicar os **nomes das partes** (agravante e agravado), a **exposição do fato e do direito**, as **razões do pedido de reforma** ou **invalidação da decisão agravada**, o **pedido de reforma** ou **invalidação**, além do **nome completo e endereço completo do advogado das partes**.

A petição ainda deverá conter a **exposição do fato e do direito**, incumbindo-se ao agravante o ônus de apresentar um relato dos aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na causa e que sejam relevantes para o reexame da decisão interlocutória agravada.

Deverá também conter o **pedido de nova decisão**, sendo instruído dos documentos obrigatórios para sua interposição. Sendo os autos físicos – uma vez que o processo

eletrônico dispensa a impressão dos mesmos – tem o agravante a incumbência e instruir o recurso com **peças obrigatórias** e **peças facultativas**.

Dentre as **peças obrigatórias**, temos:

I – cópia da petição inicial ou da contestação;

II – cópia da petição que ensejou a decisão agravada;

III – cópia da própria decisão agravada;

IV – cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade recursal;

V – cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

Já as **peças facultativas** são aquelas em que o agravante reputar úteis para o livre convencimento do juízo competente.

A petição de interposição será acompanhada do **comprovante de pagamento do preparo**, incluindo-se o **porte de retorno**.

O prazo do recurso é de **15 (quinze) dias**, sendo o recurso interposto por protocolo diretamente realizado no tribunal *ad quem*, ou por protocolo na própria comarca, por meio de transmissão de dados ou outra forma admitida por lei, nos termos do art. 1.017, § 2.º, do CPC/2015.

O agravo é recebido, de regra, pelo **efeito devolutivo**, nos termos do art. 995 do CPC/2015.

O relator poderá julgar **monocraticamente** o recurso, inclusive para dar provimento em se tratando dos seguintes casos:

I – decisão recorrida contrária a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal de segundo grau;

II – decisão recorrida contrária a acórdão proferido pelo STF e STJ em julgamento de recursos repetitivos;

III – decisão recorrida contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Não sendo o caso de **decisão unipessoal**, deverá o relator levar o agravo de instrumento a **julgamento colegiado**, pedindo o relator dia para julgamento do recurso. Tal despacho deverá ser proferido no prazo de **um mês contado da intimação do agravado** para oferecer suas contrarrazões.

Admite-se sustentação oral quando a **decisão recorrida versar sobre tutela**

provisória; nos demais casos, não se admite, podendo, inclusive o julgamento colegiado ser realizado em sessão eletrônica.

4.4.3 Modelo de recurso de agravo de instrumento

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ... REGIÃO (ou TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE ...)

(espaço de cinco linhas)

NOME DO AGRAVANTE (qualificação completa) inconformado com a decisão que ..., nos Autos da Ação ..., que move em face de NOME DO AGRAVADO (qualificação completa), vem por seu advogado, tempestivamente, com fundamento no artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, interpor

AGRAVO DE INSTRUMENTO

pelo que expõe e requer a esse Egrégio Tribunal o seguinte.

I – BREVE RELATO DO OCORRIDO

Trata-se de (narrar o antecedente a decisão interlocutória)

Contudo o juízo *a quo* entendeu que ... (narrar a decisão do juiz)

A decisão merece ser reformada tendo em vista que o juiz não observou preceitos basilares do ordenamento jurídico brasileiro.

II – DO CABIMENTO

A decisão proferida é interlocutória, que causará à parte lesão grave de difícil reparação, sendo desafiado via agravo de instrumento.

Preconiza o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que (Neste ponto é necessário justificar com base em um dos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015.

§ 1.º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconconsideração da personalidade jurídica;

- V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
- VI – exibição ou posse de documento ou coisa;
- VII – exclusão de litisconsorte;
- VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
- IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
- X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução.

III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO

Mérito: tese do recurso

IV – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU EFEITO SUSPENSIVO)

O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015 autoriza o relator a conceder tutela provisória no agravo de instrumento, na hipótese de existência de lesão grave de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.

No presente caso, o fundamento é relevante, pois ... (explicar a lesão).

Além disso, caso não seja concedida a medida, o Agravante sofrerá dano grave, já que ... (fatos que justificam a urgência).

IV – DOS REQUERIMENTOS

Desde logo, requer a concessão da tutela antecipada recursal (ou efeito suspensivo) para

Requer que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada, no sentido de

Por oportuno, requer a condenação da parte Agravada ao reembolso das custas do presente recurso, em conformidade com o § 1.º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do artigo 1.016, IV, do Código de Processo Civil de 2015, estão constituídos nos autos os seguintes advogados (nomes, endereços e inscrição na OAB).

Informa, em cumprimento ao disposto no artigo 1.017 do Código de Processo Civil de 2015, que o recurso é instruído com as seguintes cópias:

- a) obrigatórias (decisão agravada, certidão de intimação da certidão agravada e procurações);
- b) facultativas (outras cópias para o julgamento do mérito recursal).

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

PEÇAS OBRIGATÓRIAS QUE INSTRUEM O AGRAVO

- a) Procuração;
- b) Decisão interlocutória Agravada;
- c) Certidão de intimação da Decisão Agravada.

4.5 AGRAVO INTERNO

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1.º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2.º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3.º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4.º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5.º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

4.5.1 Principais características

O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida no

Tribunal pelo relator ou pelo Presidente, sendo cabível no prazo de 15 (quinze) dias.

Todas as decisões monocráticas proferidas nos Tribunais são impugnáveis por agravo interno, mesmo que atribuam efeito suspensivo a recursos ou as que decidam sobre tutela provisória nos processos de competência originária dos Tribunais.

Só será impugnável por agravo interno uma decisão monocrática quando a **lei expressamente declare irrecorrível**, como no exemplo do art. 1.031, § 2.º, do CPC/2015:

Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

§ 2.º Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal.

O recurso **será sempre julgado pelo órgão colegiado** a que o relator (ou o Presidente) se vincula.

A petição de interposição do agravo interno incumbe ao agravante impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível se o recorrente se limitar a produzir os fundamentos do recurso anteriormente interposto.

O **agravo interno** é interposto por **petição dirigida ao relator**, incumbindo-se determinar a **intimação do agravado** para manifestar-se em **contrarrazões** no prazo de **15 (quinze) dias**. Decorrido o prazo, sendo oferecidas as contrarrazões ou não, o **relator poderá retratar-se, reconsiderando a decisão monocrática. Não havendo retratação**, o agravo interno será incluído na pauta de julgamento para a apreciação do órgão colegiado em sessão.

No caso de **negativa de provimento ao agravo interno**, não se admite a **mera reprodução da decisão recorrida**, exigindo-se os **exames dos argumentos** que foram especificamente invocados pelo agravante na impugnação da decisão monocrática.

4.5.2 Modelo de recurso de agravo interno

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator da ... Câmara (Turma) do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de ... (ou Tribunal Regional Federal da ... Região)

Processo n.º ...

Contribuinte, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado que esta subscreve, com fundamento nos arts. 1.021 e seguintes do CPC/2015, interpor

AGRAVO INTERNO

contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação, pela sua manifesta improcedência, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I – BREVE RELATO DO OCORRIDO

Trata-se de (narrar o ocorrido antes da decisão monocrática)

Contudo, o Douto Desembargador entendeu que ... (narrar a decisão monocrática que está sendo atacada).

Assim, requer que a presente decisão seja retratada ou, diante de sua negativa, que o presente recurso seja julgado pelo Colegiado do Egrégio Tribunal, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida.

II – DO CABIMENTO

Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno deste tribunal.

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

(impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada)

IV – DOS REQUERIMENTOS

Requer que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada, no sentido de

Por oportuno, requer a condenação da parte Agravada ao reembolso das custas do presente recurso, em conformidade com o § 1.º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

4.6 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
--

decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1.º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.

§ 2.º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1.º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2.º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidirá monocraticamente.

§ 3.º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível,

desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1.º.

§ 4.º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5.º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1.º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2.º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não

excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3.º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4.º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

4.6.1 Principais características

Os **embargos de declaração** são uma **espécie de recurso** (art. 994 do CPC/2015) que tem por finalidade **esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material**.

Sua função principal é de **sanar os vícios da decisão**. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas **aclará-la e sanar suas contradições ou omissões**.



Dica

Os embargos de declaração cabem contra todo o tipo de decisão, seja interlocutória, sentença ou acórdãos, proferidos em qualquer grau de jurisdição.



Importante

Entende-se por obscuridade a falta de clareza do ato. Por contradição, a falta de coerência da decisão e por omissão, quando o juiz deixar de se pronunciar sobre um ponto que exigia sua manifestação.

4.6.2 Processamento e efeitos

Os embargos de declaração serão opostos no prazo de **5 (cinco) dias**, por quaisquer hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, **a contar da data em que as partes são intimadas da decisão. Não há recolhimento do preparo.**

A sua apresentação **interrompe o prazo para apresentação de outros recursos**, tanto para quem o interpôs como para os demais litigantes, ainda que o recurso não seja admitido.

O recurso de embargos de declaração tem **efeito interruptivo**, uma vez que a oposição dos embargos de declaração **interrompe o prazo de interposição de qualquer outro recurso**, só se produzindo esse efeito se forem tempestivos.

Devemos nos recordar de que se trata de recurso em que **não há exigência de preparo**, razão pela qual **não se cogita o recolhimento de custas**.

4.6.3 Modelo de embargos de declaração

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO EG
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ... (OU TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
REGIÃO)

Processo n.º ...

NOME DO EMBARGANTE (qualificação completa), nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, opor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face do (acórdão, sentença ou decisão a depender do caso) de fls. ..., pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Narrar todo o processo.

II – DO DIREITO

Esclarecer qual foi o resultado do julgamento, se procedente ou improcedente.

Demonstrar, conforme o caso:

- 1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
- 2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
- 3) corrigir erro material;

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer sejam os presentes embargos CONHECIDOS, bem como lhe se dado PROVIMENTO, com o objetivo de ser sanada a obscuridade/contradição/omissão apontada com a consequente ... (especificar o pedido).

Termos em que,

Pede deferimento.

Local, data.

Advogado

OAB/ ... n.º ...

4.7 RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4.7.1 Recurso ordinário constitucional

Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:

I – pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;

II – pelo Superior Tribunal de Justiça:

a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

b) os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

§ 1.º Nos processos referidos no inciso II, alínea “b”, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do art. 1.015.

§ 2.º Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1.013, §

3.º, e 1.029, § 5.º.

Art. 1.028. Ao recurso mencionado no art. 1.027, inciso II, alínea “b”, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1.º Na hipótese do art. 1.027, § 1.º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 2.º O recurso previsto no art. 1.027, incisos I e II, alínea “a”, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

§ 3.º Findo o prazo referido no § 2.º, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

O **Recurso Ordinário Constitucional (ROC)** consiste em recurso vinculado às ações de **competência originária dos tribunais**, exercendo função de apelação, estabelecido no art. 994, V, do CPC/2015, tendo hipóteses de cabimento previstas nos arts. 102, II, e 105, II, da CF/1988, e 1.027 do CPC/2015.

Como **inexiste a possibilidade de se apelar de um acórdão**, houve por bem a necessidade de se prever um **recurso para a hipótese em que ações** são ajuizadas originalmente nos **tribunais decididas por meio de acórdão**.

Excepcionalmente, **há o cabimento de recurso ordinário constitucional de sentença**: quando forem partes **Estado estrangeiro** ou **organismo internacional**, de um lado, e **Município** ou **pessoa residente e domiciliada no país**, de outro.

Como tais causas são julgadas pela **Justiça Federal**, a decisão se dará por meio de **sentença**. Da sentença proferida pela Justiça Federal caberá **recurso ordinário constitucional** para o **Superior Tribunal de Justiça**.

4.7.1.1 Cabimento e estrutura do recurso

Para que se tenha cabimento o recurso ordinário constitucional, faz-se necessário

que o tribunal tenha proferido uma **decisão denegatória** em **instância única** das ações de **mandado de segurança**, *habeas data* e **mandado injunção**.

A **peça de interposição** deverá ser dirigida ao **Presidente do Tribunal** que prolatou o acórdão **denegando o mandado de segurança** (geralmente será esta ação que ensejará, em matéria tributária, o acórdão), e as razões serão encaminhadas ao **Tribunal Superior competente** (Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça).

4.7.1.2 Modelo de recurso ordinário constitucional

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ...

(espaço de cinco linhas)

Processo n.º ...

CONTRIBUINTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, não se conformando, “data maxima venia” com o r. acórdão de fls. ..., por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.027 do Código de Processo Civil de 2015, interpor o presente

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

em face da Fazenda Pública Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, pelas razões de fato e de direito aduzidas.

Destarte, requer sejam as anexas razões de recurso recebidas e remetidas ao Egrégio ... (indicar o Tribunal Superior).

Requer, por fim, a juntada do comprovante do preparo, nos termos da lei.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

RAZÕES DO RECURSO

PROCESSO N.º ...

RECORRENTE: ...

RECORRIDA:

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLEDA TURMA,
ÍNCLITOS JULGADORES,

I – DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS

(...)

II – DAS RAZÕES PARA REFORMA/ANULAÇÃO DA R. ACÓRDÃO RECORRIDO

(...)

III – DO PEDIDO

“Ex positis”, requer-se seja dado integral provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de, reformando-se o r. acórdão recorrido, seja ... (expor os motivos da reforma e os fundamentos).

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

4.7.2 Recurso especial e recurso extraordinário

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I – a exposição do fato e do direito;

II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1.º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

§ 2.º (Revogado).

§ 3.º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

§ 4.º Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.

§ 5.º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

II – ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal

recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6.º do art. 1.036;

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da

controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1.º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

§ 2.º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

§ 1.º Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado.

§ 2.º Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial.

Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.

Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.

Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso

extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.

Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado.

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1.º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2.º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3.º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II – (Revogado);

III – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

§ 4.º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5.º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

§ 6.º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7.º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6.º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno.

§ 8.º Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.

§ 9.º O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

§ 10. (Revogado).

§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.

4.7.2.1 Principais características do recurso especial

O **Recurso Especial** é o recurso de competência do **Superior Tribunal de Justiça**, tendo seu cabimento estabelecido no art. 105, III, da CF/1988, e art. 1.029 do CPC.

Deverá ser interposto perante o **Presidente** ou o **Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça**, contendo uma **peça de interposição** e as **razões do recurso**.

Há necessidade da existência de **prequestionamento** como **condição de admissibilidade**, sendo prevista, de maneira expressa, na Súmula 282 do STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

No mesmo sentido, temos a Súmula 336 do STF:

O ponto omissso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

4.7.2.2 Cabimento e estrutura do recurso especial

São **três situações** que ensejam o cabimento do recurso especial quando decididas em **única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados, Distrito Federal e Territórios**, estabelecidas no art. 105, III, da CF/1988:

I – quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

II – quando a decisão recorrida julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

III – quando a decisão recorrida der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Ocorrendo alguma destas circunstâncias elencadas e, mediante observância das formalidades legais, o **recurso especial será interposto** perante o **Presidente ou Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça**.

O recurso especial será interposto em **duas partes**:

I – **peça de interposição** dirigida ao **Tribunal a quo** que proferiu a decisão;

II – **razões remetidas à Presidência ou Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça**.

4.7.2.3 Modelo de recurso especial

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO ECT
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ...

(espaço de cinco linhas)

Processo n.º ...

CONTRIBUINTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, não se conformando, “data maxima venia” com o r. acórdão de fls. ..., por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal e artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face da Fazenda Pública Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, pelas razões de fato e de direito aduzidas.

Destarte, requer sejam as anexas razões de recurso recebidas e remetidas ao Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, por fim, a juntada do comprovante do preparo, nos termos da lei.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Nome e assinatura do advogado

OAB/ ... n.º

RAZÕES DO RECURSO

PROCESSO n.º ...

RECORRENTE: ...

RECORRIDA:

COLENDO TRIBUNAL,

ÍNCLITA TURMA,

DOUTOS JULGADORES,

I – BREVE RELATO DO OCORRIDO

Trata-se de

Contudo entendeu o juízo de primeira instância que

Por sua vez, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado ... proferiu o acórdão negando a pretensão do Recorrente, em síntese, por entender (resumo do assunto do recurso).

No entanto, como será demonstrado a seguir, o acórdão recorrido merece ser reformado.

II – DO CABIMENTO DO RECURSO

a) DO PREQUESTIONAMENTO

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso tem cabimento uma vez que o acórdão, proferido pelo Tribunal *a quo*, violou expressamente o disposto na lei federal acerca ... (explicar a violação), sendo hipótese de aplicação do artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal.

Além disso, a matéria também foi prequestionada com o cumprimento da súmula 211 desse Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, resta comprovado que os requisitos para a admissibilidade e conhecimento do Recurso Especial.

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

Tese: só discutir matéria unicamente de Direito

Depreende-se, portanto, que o acórdão merece ser reformado.

IV – DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, requer seja o recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar acórdão no sentido de ... (caso concreto).

Requer, também, a inversão do ônus de sucumbência com a condenação do Recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 84 do Código de Processo Civil de 2015.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

4.7.2.4 Principais características do recurso extraordinário

O **Recurso Extraordinário** é o recurso de **competência do Supremo Tribunal Federal**, tendo seu cabimento estabelecido no art. 102, III, da CF/1988, e art. 1.029 do CPC/2015. Trata-se do **exercício do controle difuso de constitucionalidade** exercido pelas partes, uma vez que o **Supremo Tribunal Federal** é o **guardião dos direitos constitucionais**.

Deverá ser interposto perante o **Presidente** ou o **Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal**, contendo uma **peça de interposição** e as **razões do recurso**.

Há necessidade da existência de **prequestionamento** como condição de admissibilidade, sendo prevista, de maneira expressa, na Súmula 282 do STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na

decisão recorrida, a questão federal suscitada”

No mesmo sentido, temos a súmula 336 do STF:

O ponto omissso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

4.7.2.5 Cabimento e estrutura do recurso

São **quatro situações** que ensejam o **cabimento do recurso extraordinário** quando decididas em **única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais** ou pelos **Tribunais de Justiça dos Estados, DF e Territórios**, estabelecidas no art. 102, III, da CF/1988:

I – quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional;

II – quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

III – quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal;

IV – quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Ocorrendo alguma destas circunstâncias elencadas, e mediante observância das formalidades legais, o recurso extraordinário será interposto perante o **Presidente ou Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal**.

O **recurso extraordinário** será interposto em **duas partes**:

I – **peça de interposição** dirigida ao Tribunal *a quo* que proferiu a decisão;

II – **razões** remetidas à Presidência ou Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal.

4.7.2.6 Modelo de recurso extraordinário

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ...

(espaço de cinco linhas)

Processo n.º ...

CONTRIBUINTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, não se conformando, “data maxima venia” com o r. acórdão de fls. ..., por meio de seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal e artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, interpor o presente]

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

em face da Fazenda Pública Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, pelas razões de fato e de direito aduzidas.

Destarte, requer sejam as anexas razões de recurso recebidas e remetidas ao Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Requer, por fim, a juntada do comprovante do preparo, nos termos da lei.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

RAZÕES DO RECURSO

PROCESSO n.º ...

RECORRENTE: ...

RECORRIDA:

COLENDO TRIBUNAL,

ÍNCLITA TURMA,

DOUTOS JULGADORES,

I – BREVE RELATO DO OCORRIDO

Trata-se de ...

Contudo entendeu o juízo de primeira instância que

Por sua vez, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado ... proferiu o acórdão negando a pretensão do Recorrente, em síntese, por entender (resumo do assunto do recurso).

No entanto, como será demonstrado a seguir, o acórdão recorrido merece ser reformado.

II – DO CABIMENTO DO RECURSO

a) DO PREQUESTIONAMENTO

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso tem cabimento uma vez que o acórdão, proferido pelo Tribunal *a quo*, violou expressamente o disposto na lei federal acerca ... (explicar a violação), sendo hipótese de aplicação do artigo 102, III, *a*, da Constituição Federal.

Além disso, a matéria também foi prequestionada com o cumprimento da súmula 282 desse Supremo Tribunal Federal.

Portanto, resta comprovado que os requisitos para a admissibilidade e conhecimento do Recurso Extraordinário.

B) DA REPERCUSSÃO GERAL

Inicialmente, importante destacar que o recurso preenche o requisito da REPERCUSSÃO GERAL previsto no artigo 102, § 3.º, da CF e artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, pois a questão nele versada é relevante do ponto de vista econômico, jurídico, político e social, ultrapassando os limites subjetivos da causa, como prevê o § 1.º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015.

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

Tese: só discutir matéria unicamente de Direito.

Depreende-se, portanto, que o acórdão merece ser reformado.

IV – DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, requer seja o recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar acórdão no sentido de ... (caso concreto).

Requer, também, a inversão do ônus de sucumbência com a condenação do Recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 84 do Código de Processo Civil de 2015.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

4.8 EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;

II – (Revogado pela Lei 13.256/2016);

III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal,

sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

IV – (Revogado pela Lei 13.256/2016);

§ 1.º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.

§ 2.º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.

§ 3.º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.

§ 4.º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.

§ 5.º (Revogado pela Lei 13.256/2016).

Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.

§ 1.º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.

§ 2.º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.

4.8.1 Principais características

Tal **recurso** fora introduzido pela Lei 8.950/1994, sendo que suas **hipóteses de cabimento** vêm previstas no art. 1.043 do CPC/2015:

- I – em **recurso extraordinário** ou em **recurso especial**, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
- II – (Revogado pela Lei 13.256/2016);
- III – em **recurso extraordinário** ou em **recurso especial**, **divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal**, sendo um **acórdão de mérito** e outro que **não tenha conhecido do recurso**, embora tenha apreciado a controvérsia;
- IV – (Revogado pela Lei 13.256/2016).

Sua finalidade é **evitar as divergências no âmbito do STF e STJ uniformizando a jurisprudência**.



Importante

É preciso que a divergência seja atual, não cabendo mais os embargos se a jurisprudência do Tribunal já se uniformizou em um determinado sentido. É o que resultou da edição da súmula 168 do STJ.

4.8.2 Processamento e efeitos

Os **embargos de divergência** são regulados pelos **Regimentos Internos do STF e STJ**, sendo o prazo para sua interposição de **15 dias** contados da decisão embargada.

A **petição de interposição** deve vir acompanhada com a prova da divergência, sendo necessário que ela indique, de forma analítica, em que ela consiste.

Caberá ao relator fazer um prévio **juízo de admissibilidade**, sendo que, se for negativo, haverá possibilidade de o recorrente valer-se de **agravo inominado**, para o mesmo órgão a que competiria o julgamento dos embargos. Se positivo, a parte contrária será intimada para as contrarrazões no prazo de 15 dias.

O **julgamento no STF será feito em plenário**, sendo que, no STJ, se a **divergência se der entre as turmas da mesma seção**, o julgamento será feito pela **Seção**; se entre as **turmas de seções diferentes**, ou entre uma Turma ou uma Seção com a Corte Especial, o julgamento será feito pela **Corte Especial**.

4.8.3 Modelo de embargos de divergência

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR ... DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ou SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

Processo n.º ...

NOME DO EMBARGANTE (qualificação completa), nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1043, inciso (I ou III, dependendo do caso) do Código de Processo Civil de 2015, opor

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

em virtude do venerando acórdão de fls. ..., pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Breve resumo dos fatos, especificando o trecho do venerando acórdão e, que se demonstrará a divergência.

II – DO DIREITO

Demonstrar o cabimento dos embargos: artigo 1043, I ou III, do Código de Processo Civil de 2015 e sua tempestividade – artigo 1003, § 5.º, do Código de Processo Civil de 2015. Deve-se indicar que há entendimento em outra turma do Tribunal que diverge do apresentado no venerando acórdão embargado, sendo necessário transcrever essa parte para ser o confronto.

Não obstante, sobre a matéria discutida no presente recurso, o entendimento da ... Turma desse Colendo Tribunal diverge daquele apresentado no venerando acórdão embargado.

IV – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer sejam os presentes embargos **CONHECIDOS**, bem como lhe seja dado **PROVIMENTO**, com o objetivo de alterar a decisão recorrida, adotando-se o entendimento da ... Turma desse Egrégio Tribunal, para ... (especificar o pedido e a finalidade da alteração do

acórdão).

Termos em que,
Pede Deferimento.

Local, data.

Advogado

OAB/... nº ...

SEGUNDA PARTE

INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

1

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO



Entende-se por **procedimento administrativo fiscal** o conjunto de atos administrativos encadeados entre si para formação de um ato válido praticado pela Administração Pública ou pelo particular. **Não existe garantia de ampla defesa ou contraditório**, destinando-se apenas à coleta de dados e informações necessários à apuração do cumprimento das obrigações tributárias.

Por **processo administrativo tributário** ou **processo administrativo fiscal** entende-se ser aquele pelo qual tanto a Administração Pública quanto o particular discutem uma pretensão fora do âmbito judicial, mediante sequência ordenada de atos administrativos autorizados por lei. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em **processo judicial** ou **administrativo**, e aos acusados em geral são assegurados o

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5.º, LV, da CF/1988). Trata-se do **princípio do devido processo legal**.

Apesar de ser uma pretensão tanto da Fazenda Pública quanto do particular, a majoritária doutrina resume que o processo administrativo fiscal demonstra a situação de **inconformismo** do contribuinte ou responsável em relação ao lançamento tributário.

É fato que o contribuinte **não tem a necessidade de discutir sua pretensão na esfera administrativa**, mas o faz por sua **liberdade**. Não se adota, no país, uma obrigatoriedade por parte do particular em, inicialmente, esgotar as vias administrativas para, posteriormente, ingressar na esfera judicial, salvo exceções constitucionalmente previstas. É o que ocorre nos casos da **Justiça Desportiva**, em que o Poder Judiciário somente admitirá ações após o esgotamento das vias administrativas perante a justiça desportiva. Nos casos de *habeas data* existe uma situação semelhante, vez que a Lei 9.507/1997 determina o esgotamento das vias administrativas. Por fim, em se tratando de descumprimento de súmulas vinculantes, o uso da reclamação só é admitido após o esgotamento das vias administrativas.



Note bem

Existe diferença entre **procedimento administrativo** e **processo administrativo fiscal**. O primeiro versa sobre um conjunto de atos administrativos encadeados e o outro é a discussão de uma pretensão jurídica fora da esfera judicial.

Para a definição da **coisa julgada** em face do particular, nosso país adota o chamado **sistema inglês** ou de **jurisdição única**. Neste sistema, caberá ao **Poder Judiciário** a **decisão definitiva sobre a pretensão do particular**, e não a um tribunal administrativo.

A Administração Pública, no exercício de suas atividades, pratica atos que se enquadram como **atos jurídicos** ou **atos jurídicos**. Os denominados **atos administrativos** são espécies de **atos jurídicos**, configurando-se aqueles que visam à produção de efeitos jurídicos determinados, desde que em conformidade com o interesse público.

Dentre as classificações empregadas, os atos administrativos podem ser

vinculados ou **discricionários**. Os primeiros possuem todo o comportamento da Administração Pública tipificado em lei, sem gerar qualquer margem de atuação. Os segundos admitem certa margem de escolha dentro dos limites legais para que a Administração Pública, pela análise do juízo de conveniência e oportunidade, possa agir para atendimento do interesse coletivo.

Tanto os **atos vinculados** quanto os **discricionários** devem observar os limites estabelecidos em lei. Quando ocorrer um **vício de legalidade** ou **legitimidade** dos atos administrativos, haverá o **controle de legalidade**, exercido pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, quando provocado.

Reza a Súmula 473 do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

No caso dos **atos discricionários**, o Poder Judiciário manifestar-se-á, de igual modo, nos casos de ilegalidade e ilegitimidade. Caberá à Administração Pública a análise do **mérito administrativo**, pela análise da **conveniência e oportunidade** (mérito administrativo).

Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário não poderá rever os atos administrativos (por exemplo, quando temos os atos discricionários), **quando da existência dos critérios de conveniência e oportunidade**. Assim, o Poder Judiciário não poderá discutir o **mérito do ato administrativo**, uma vez que poderá, se o fizer, caracterizar a **violação ao princípio da separação dos Poderes**.

O **processo administrativo fiscal** é regulado pelo **Decreto 70.235/1972**, estabelecendo os atos pelos quais a pretensão administrativa será materializada.

Tal decreto tem força de lei e somente poderá ser alterado mediante **lei ordinária**, trazendo em seu bojo todos os elementos suficientes para a discussão da pretensão do particular ou da própria Fazenda Pública na esfera administrativa.

No entanto, o **informalismo** manifesta-se em vários aspectos do processo, mas também é certo que o elemento que, acima de qualquer outro, mais define o nível de formalidade/informalidade são as **feições do rito procedimental**. Assim, se no

contencioso específico que se tem em mira o procedimento regado é rígido, estabelecendo prazos preclusivos para a prática dos atos que o compõem *in concreto* e definindo minudentemente os ônus processuais entre as partes, não se pode dizer que tal procedimento seja informado pelo **princípio da informalidade**; pode até ser que o informalismo se manifeste em algumas questões secundárias, acessórias, mas princípio informador não será.

No caso do **processo administrativo fiscal**, tem-se um **rito procedimental pontilhado**, entre outros aspectos, por:

(i) **prazos preclusivos** para a apresentação dos recursos e para a produção de provas;

(ii) **atribuições rígidas de competência** entre os vários órgãos especificamente criados para a apreciação do litígio;

(iii) **vedações expressas à apreciação do litígio** em face de circunstâncias minudentemente definidas (entre as quais a existência de ação judicial com o mesmo objeto).

Ou seja, o **contencioso administrativo fiscal** está permeado por circunstâncias que enrijecem muito seu procedimento. Nesses termos, não se pode mais afirmar o **informalismo** como **princípio informador do Processo Administrativo Fiscal**; numa nova formulação principiológica, deve-se partir, no mínimo, do **formalismo moderado**.

A circunstância de o processo administrativo fiscal não manifestar apego exacerbado às formas (como se depreende, por exemplo, do não estabelecimento de requisitos formais específicos para a apresentação de recursos – em termos de conteúdo ou legitimidade *ad processum*), não desnatura o fato de que seu procedimento é, sim, rígido, o que leva à conclusão de que, muito embora não expurgado do contencioso administrativo, não mais serve o informalismo irrestrito como princípio informador deste campo jurídico.

1.1 A CONSULTA TRIBUTÁRIA

A **consulta tributária** é um procedimento administrativo que busca uma declaração formal da Administração Pública acerca da interpretação da legislação tributária. O que efetivamente o particular deseja é a obtenção da segurança jurídica para determinar como se deverá agir em circunstâncias de dúvida na aplicação da legislação tributária.

Podemos concluir que se trata de um direito amparado pela Constituição Federal (direito de petição e direito de informação, art. 5.º, XXXIII e XXXIV, CF/1988). No entanto, apesar de o consulente ter o direito à solução da interpretação da legislação tributária ao fato concreto, a resposta do órgão administrativo competente poderá ser positiva ou negativa, no sentido de determinar que a legislação se aplica ao fato concreto (positiva) ou não (negativa).

A consulta deve limitar-se a **fato determinado**, descrevendo suficientemente o seu objeto e indicando as informações necessárias à elucidação da matéria. Para se efetivar consulta sobre **situação determinada ainda não ocorrida**, o consulente deverá demonstrar **vinculação com o fato**, bem como a **efetiva possibilidade de sua ocorrência**.

Enquanto estiver pendente a decisão do órgão administrativo competente sobre a consulta formulada, **não poderá ocorrer a incidência de juros moratórios e penalidades**. Se isso ocorre, **o direito à consulta perderá o objeto**.

Para os **tributos federais**, o procedimento de consulta está previsto nos **arts. 46 e seguintes do Decreto 70.235/1972**. A Lei 9.430/1996 complementa as regras previstas no decreto em questão, nos termos dos arts. 48 a 50 da referida legislação. Tratando-se dos Estados e Municípios, cada qual poderá estabelecer por meio de legislação o procedimento de consulta específico.



Dica

A **consulta tributária** serve para que a Administração Pública se pronuncie sobre a interpretação de alguma norma tributária.

1.1.1 Competência territorial para formulação da consulta fiscal

A **consulta** deverá ser sempre proposta por **escrito**, sendo competente o **órgão público local da entidade incumbida da administração do tributo**. O procedimento deverá ser proposto no **domicílio tributário do consulente** (art. 127 do CTN).

Uma informação importante está prevista no parágrafo único do art. 46 do Decreto 70.235/1972: **os órgãos da Administração Pública e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais podem formular o procedimento**.

Assim, poderá um Ministério consultar a Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre determinado item da legislação tributária.

Entretanto, não se trata de um procedimento comum a ser adotado, uma vez que os órgãos da Administração Pública acabam resolvendo tais interpretações legislativas no âmbito interno.

1.1.2 Competência material para formulação da consulta fiscal

Conforme salientado, o **preparo do processo** e o **julgamento** competirão ao **órgão local da entidade encarregada da administração do tributo**.

A determinação do art. 54 do Decreto 70.235/1972, mediante análise das alterações posteriores, traz a competência para o julgamento do procedimento de consulta perante o Delegado da Receita Federal do Brasil, em se tratando de tributos federais.

1.1.3 Objeto da consulta fiscal

Segundo determina o art. 46 de Decreto 70.235/1972, a **consulta deverá recair sobre fato determinado**. Não se admite uma formulação de consulta para situações abrangentes, inadmitindo-se **formulação de consulta em tese**.

Uma vez que a **consulta** poderá produzir **efeitos que permitem a dilação no prazo para cumprimento das obrigações tributárias**, exige-se um mínimo ético do consulente, evitando utilizar do procedimento como mera postergação de obrigação fiscal devida.

1.1.4 Efeitos da consulta fiscal

Segundo entendimento doutrinário acerca desse tema, temos duas espécies de momentos distintos para classificação dos efeitos: os chamados **efeitos preliminares** e os denominados **efeitos finais**.

Os **efeitos preliminares** ocorrem logo quando a consulta é realizada, ou seja, quando o consulente formula a consulta perante o órgão administrativo competente (atualmente, perante o Delegado da Receita Federal do Brasil).

Enquanto aquela matéria está sob apreciação do órgão administrativo, **não poderá o Fisco realizar autuações**, informando, para tanto, que o consulente está

descumprindo a obrigação tributária.

Já os **efeitos finais** consolidam a decisão tomada pelo órgão administrativo competente. Uma vez que foi decidido sobre a consulta formulada, a situação que fora questionada adquire **segurança jurídica**.

Determina o art. 49 do Decreto 70.235/1972 que a **consulta não suspende o prazo para o recolhimento do tributo**, seja este **retido na fonte** ou **autolancado** antes ou depois de sua apresentação, **nem o prazo para a apresentação de declaração de rendimentos**.

Assim, **desde que a consulta ocorra antes da data de vencimento do crédito tributário**, qualquer que seja a modalidade de lançamento – uma vez que, neste caso, a doutrina informa não se tratar apenas nos casos de lançamento por homologação – **não haverá cobrança do crédito tributário, acréscimo ou aplicação de penalidades**.

Tal decisão está de acordo com o que determina o art. 161, § 2.º, do CTN, que diz:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

(...)

§ 2.º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento.

1.1.5 Procedimento de consulta fiscal propriamente dito

A **consulta** deverá ser realizada por escrito, sendo a petição dirigida ao órgão público competente e atender aos requisitos formais determinados.

Existem demais exigências documentais dependendo do tipo de consulta formulada, como nos casos de consultas sobre **classificação de mercadorias, de produtos das indústrias químicas e conexas, na classificação de bebidas**, dentre outros.

Podemos dividir o procedimento de consulta propriamente dito em três fases distintas:

- I – **preparo preliminar;**
- II – **preparo de solução;**
- III – **solução.**

1.1.5.1 Preparo Preliminar

Nesta **primeira fase**, teremos a análise dos **requisitos formais** para o cabimento da consulta. Assim, caberá ao órgão administrativo competente analisar a petição e os requisitos formais.

1.1.5.2 Preparo de Solução

Trata-se de uma **análise de mérito** da consulta formulada. Neste caso, a petição de consulta será apresentada perante a autoridade tributária competente do domicílio do consulente (atualmente, como vimos, o Delegado da Receita Federal do Brasil).

O **preparo** propriamente dito consistirá nas seguintes etapas:

- I – **verificação dos requisitos preliminares da formulação da consulta;**
- II – **orientação do interessado quanto à maneira correta de formular a consulta, no caso de serem observada a falta de determinados requisitos que são exigidos pela norma tributária;**
- III – **organização do processo e encaminhamento à Superintendência Regional da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRRF) a que estiver subordinado o Delegado da Receita Federal, desde que tenham sido atendidas as formalidades previstas na legislação.**

1.1.5.3 Solução da Consulta

A **competência** para a determinação da **solução da consulta** é da **Coordenação-Geral da Tributação (COSIT)**, **Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA)** e da **Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF)**.

Cada órgão administrativo competente, dentro da divisão interna, decidirá sobre cada matéria especificada na consulta formulada.



Note bem

O **procedimento administrativo de consulta fiscal** se divide em três fases distintas: **preparo preliminar, preparo de solução e solução.**

1.1.6 Recurso quanto à solução da consulta

A doutrina diverge sobre a **possibilidade de interposição de recurso sobre a decisão final da consulta**. Isso se dá pelo simples motivo que a consulta é um **procedimento administrativo** e não um **processo administrativo**, portanto, não sendo exigível a ampla defesa e o contraditório.

A Lei 9.430/1996, em seu art. 48, declarou que a consulta se resolveria em **instância única**. Ainda, no § 3.º do referido artigo, a legislação determina que **não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta ou do despacho que declarar sua ineficácia**.

No entanto, o mesmo artigo prevê a possibilidade de **recurso especial de divergência**. Neste caso, a legitimação de ingressar com o recurso em comento será do **consulente que tiver conhecimento de solução diferente para a mesma matéria consultada** ou ainda **qualquer agente da Administração**.

A **solução da divergência administrativa** é um simples instrumento de se alcançar a **segurança jurídica da interpretação da legislação tributária**. Trata-se de uma espécie de procedimento que se instaura com a mesma forma e conteúdo de uma **reconsideração**.

Uma vez que existem diferenças entre soluções de consultas sobre a mesma matéria, tendo por fundamento uma idêntica norma jurídica, caberá tal procedimento.

A **competência para o julgamento** da divergência caberá à **Coordenação-Geral de Tributação (COSIT)** ou à **Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA)**, dependendo da matéria, objeto de divergência.

1.1.7 Ineficácia da consulta fiscal

A **consulta fiscal** é o instrumento que possibilita o **esclarecimento de dúvidas** acerca de determinado dispositivo da legislação tributária relacionado a atividade desenvolvida pelo consulente.

A solução adotada pelo órgão fazendário competente pode ser de **eficácia** ou **ineficácia**. Quando **eficaz**, impedirá a **aplicação da multa de mora e juros de mora**, relativamente à **matéria consultada**.

O art. 52 do Decreto 70.235/1972 traz as hipóteses em que a consulta fiscal se tornará **ineficaz**.

Assim, podemos determinar as seguintes situações de **ineficácia**:

I – não produzirá efeito se estiver em **desacordo com os requisitos dos arts. 46 e 47 do Decreto 70.235/1972**.

II – quando a consulta for **formulada por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao objeto**;

III – quando formulada **por quem estiver sob o procedimento fiscal iniciado** para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada;

IV – quando o fato **já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada**, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;

V – quando o fato estiver **disciplinado em ato normativo**, publicado antes da sua apresentação;

VI – quando o fato estiver **definido ou declarado em dispositivo literal de lei**;

VII – quando o fato for **definido como crime ou contravenção penal**;

VIII – quando **não descrever**, completa ou exatamente, a **hipótese a que se referir**, ou **não contiver os elementos necessários** à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora.

1.1.8 Documentos necessários para formulação da Consulta Fiscal em âmbito federal

No caso de Consulta Fiscal realizada por **pessoa jurídica**, temos as seguintes documentações:

- ✓ qualificação completa e endereço eletrônico (*e-mail*);
- ✓ cópia do ato constitutivo e sua última alteração, autenticada ou acompanhada original;
- ✓ número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Específico do INSS (CEI);

- ✓ ramo de atividade.

Em se tratando de Consulta Fiscal realizada por **pessoa física**, temos:

- ✓ qualificação completa e endereço eletrônico (*e-mail*);
- ✓ atividade profissional;
- ✓ número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Se a consulta fiscal for formulada por meio de procurador ou representante legal, deverá ser identificado o representante por **procuração administrativa** (não se trata de procuração *ad judicium* para o processo judicial).

Pode ocorrer de a consulta fiscal ser formulada por algum órgão da Administração Pública, mesmo que não seja procedimento comumente adotado. Assim, além da documentação do representante legal, se faz necessária a apresentação da **cópia do ato de nomeação ou delegação de competência**, caso não conste como responsável pelo órgão público perante o CNPJ.

Além da petição com tais exigências, deve-se apresentar declaração de que:

- ✓ não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou já instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria objeto da consulta;
- ✓ não está intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; e
- ✓ o fato nela exposto não foi objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que foi parte o consulente.

Se a consulta for realizada por pessoa jurídica de direito privado que possua filiais, as declarações deverão ser prestadas pelo **estabelecimento matriz**, abrangendo todas as filiais.

Temos a possibilidade de consulta sobre a **classificação de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio**. Nesse caso, o consulente deverá informar:

- ✓ a classificação adotada e pretendida, com os correspondentes critérios utilizados;
- ✓ o enquadramento do serviço, do intangível ou de outras operações na legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) ou do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), quando for o caso; e

- ✓ descrição do serviço, do intangível ou da operação objeto da consulta.

1.1.9 Modelos de Formulários de Consulta Fiscal

a) Pessoa Física



ANEXO I

**CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
PESSOA FÍSICA**

Ao Coordenador-Geral da Cosit.

(nome completo e atividade profissional) domiciliado(a) na (Rua/Avenida/Praça/Travessa) _____, n.º _____, bairro _____, cidade/UF _____, CEP _____, telefone (____) _____, e-mail _____, Caixa Postal Eletrônica _____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º _____ (obrigatório), por meio de seu(sua) representante legal ou procurador(a), o Sr.(a) _____, portador(a) do documento de identidade n.º _____, expedido por _____, vem, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.396, de 16 de setembro de 2013, formular consulta sobre a interpretação da legislação tributária e aduaneira relativa a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

O(a) consultante informa que:

1) Submete-se ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB n.º 2.356, de 14 de dezembro de 2010.

☐ sim ☐ não

2) Tem prioridade de atendimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 10.048, de 8 de novembro de 2000, c/c art. 3.º da Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003.

☐ sim ☐ não

I - DESCRIÇÃO DETALHADA DA QUESTÃO

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (Dispositivos da legislação que ensejaram a consulta)

III - QUESTIONAMENTOS (Enumerar de forma objetiva):

1)

2)

IV - NÚMERO TOTAL DE QUESTIONAMENTOS:

OBS.: O teor da consulta deve:

- 1) limitar-se a fato determinado, contendo descrição detalhada de seu objeto e indicação das informações necessárias ao esclarecimento da dúvida;*
- 2) indicar o dispositivo da legislação tributária e aduaneira (Lei, Decreto, Regulamento, Instrução Normativa, Ato Declaratório etc., com especificação de artigo, inciso, parágrafo e alínea, se for o caso) causador da dúvida de interpretação;*
- 3) descrever detalhadamente o fato relacionado à atividade do(a) interessado(a) a que será aplicada a interpretação solicitada; e*
- 4) apresentar de forma objetiva qual a dúvida específica do(a) interessado(a) na interpretação do dispositivo da legislação tributária.*

Por fim, o(a) consulente(a) declara que:

- a) não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria objeto da consulta;
- b) não foi intimado(a) a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; e
- c) o fato exposto na consulta não foi objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que foi parte.

_____, ____ de _____ de _____
(local e data)

(nome e assinatura do contribuinte ou de seu representante legal ou procurador)

b) Pessoa Jurídica



ANEXO II

**CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA
PESSOA JURÍDICA**

Ao Coordenador-Geral da Cosit.

A pessoa jurídica

estabelecido(a) na cidade de _____, na (Rua, Avenida, Praça, Travessa) _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, telefone (____) _____, e-mail _____, Caixa Postal _____, Eletrônica _____ inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº _____ (obrigatório), inscrito(a) no Cadastro Específico do INSS (CEI) sob o nº _____ (opcional) e com ramo de atividade _____, por meio de seu(sua) representante legal ou procurador(a), o Sr.(a) _____, portador(a) do documento de identidade nº _____, expedido por _____, vem, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013, formular consulta sobre a interpretação da legislação tributária e aduaneira relativa a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

O(a) consultante informa que:

* Submete -se ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.563, de 19 de dezembro de 2012.

☐ sim ☐ não

I - DESCRIÇÃO DETALHADA DA QUESTÃO

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (Dispositivos da legislação que ensejaram a consulta)

I - DESCRIÇÃO DETALHADA DA QUESTÃO

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (Dispositivos da legislação que ensejaram a consulta)

III - QUESTIONAMENTOS (Enumerar de forma objetiva):

1)

2)

IV - NÚMERO TOTAL DE QUESTIONAMENTOS:

OBS.: O teor da consulta deve:

- 1) limitar-se a fato determinado, contendo descrição detalhada de seu objeto e indicação das informações necessárias ao esclarecimento da dúvida;*
- 2) indicar o dispositivo da legislação tributária e aduaneira (Lei, Decreto, Regulamento, Instrução Normativa, Ato Declaratório etc., com especificação de artigo, inciso, parágrafo e alínea, se for o caso) causador da dúvida de interpretação;*
- 3) descrever detalhadamente o fato relacionado à atividade do(a) interessado(a) a que será aplicada a interpretação solicitada; e*
- 4) apresentar de forma objetiva qual a dúvida específica do(a) interessado(a) na interpretação do dispositivo da legislação indicado.*

Por fim, o(a) consulente(a) declara que:

- a) não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria objeto da consulta;
- b) não foi intimado(a) a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; e
- c) o fato exposto na consulta não foi objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que foi parte.

_____, ____ de _____ de _____
(local e data)

(nome e assinatura do contribuinte ou de seu representante legal ou procurador)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROPRIAMENTE DITO

O **processo administrativo fiscal** terá início com determinados atos de ofício, de apreensão de mercadorias, documentos ou livros e do começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada (art. 7.º do Decreto 70.235/1972).

O **primeiro ato** praticado pelo agente público competente será por **escrito, iniciando a ação fiscal**. Não se trata de qualquer ato por escrito, mas do denominado **mandado de procedimento fiscal**. Este passa a ser o instrumento pelo qual o agente público fiscal está autorizado a iniciar o procedimento de fiscalização.

Caso o agente fiscal entenda que o particular praticou alguma ilegalidade, deverá ser lavrado o **auto de infração**.

Dois são os instrumentos que podem ser utilizados pela Administração Pública para formalização de sua pretensão junto ao particular: a **notificação de lançamento** e o **auto de infração**.

Tais instrumentos deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos que possam comprovar o alegado pela autoridade administrativa competente.

2.1 REQUISITOS FORMAIS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E DO AUTO DE INFRAÇÃO

A **notificação de lançamento** será expedida pelo órgão que administra o tributo. Tal notificação deverá conter os seguintes **requisitos formais** do art. 11 do Decreto 70.235/1972:

- I – a qualificação do notificado;
- II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;

III – a disposição legal infringida, se for o caso;

IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

O **auto de infração** será lavrado por servidor competente, no **local da verificação da falta**, devendo conter os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972:

I – a qualificação do autuado;

II – o local, a data e a hora da lavratura;

III – a descrição do fato;

IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;

VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Na **esfera federal**, a lavratura do auto de infração será realizada pelos **Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil** Mesmo que o agente público autuador não faça parte da circunscrição competente, ou seja, esteja lotado em repartição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo, a autuação será válida.

Uma vez que tanto a notificação de lançamento quanto o auto de infração são **atos administrativos vinculados**, qualquer **vício** levará à **anulação dos respectivos atos**, pela própria Administração Pública, em decorrência do princípio da autotutela, quanto pelo Poder Judiciário, mediante provocação.

O **objeto da notificação de lançamento** será a **pretensão fiscal relativa à exigência do débito tributário** decorrente do descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória.

No que tange ao **auto de infração**, o objeto será a **ocorrência de alguma violação a um preceito legal** que exija do órgão competente a imposição de uma multa de ofício. No caso do **auto de infração**, este terá por objeto tanto o descumprimento de uma obrigação tributária principal (art. 113, § 1.º, do CTN) quanto de uma obrigação tributária acessória (art. 113, § 2.º, do CTN).

2.2 IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

O **início efetivo do processo administrativo fiscal** se dá com a apresentação da

impugnação administrativa pelo particular.

Nada mais é a impugnação administrativa como uma forma de **defesa administrativa** apresentada perante a **primeira instância administrativa**, pela não concordância com a notificação de lançamento ou pela imposição do auto de infração.

A apresentação da impugnação administrativa, de forma tempestiva pelo sujeito passivo da obrigação tributária, acarreta a **suspensão da exigibilidade do crédito tributário**, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Para ocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, **basta a mera apresentação das impugnações e recursos administrativos**, não sendo necessária qualquer espécie de depósito ou arrolamento de bens, conforme bem salientou o STF, na edição da Súmula Vinculante n.º 21:

Súmula Vinculante n.º 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.



Importante

Caso não haja dispositivo legal contrário, o prazo para que o sujeito passivo realize a **impugnação administrativa** é de **30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação**.

2.2.1 Requisitos de admissibilidade da impugnação administrativa

Para que a impugnação administrativa seja admitida perante o órgão administrativo competente, deverão ser observados **requisitos temporais, processuais e formais**.

Uma vez que tais requisitos foram completamente preenchidos, a impugnação administrativa **será recebida pela autoridade competente**, dando-se **início ao processo administrativo fiscal**.

2.2.2 Requisito temporal da impugnação administrativa

O prazo para a apresentação da impugnação administrativa, salvo disposição

legal em contrário, será de **30 (trinta) dias contados da notificação de lançamento ou da imposição do auto de infração** (intimação), nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972. Tal prazo **não poderá ser prorrogado pela autoridade administrativa competente** (prazo peremptório).

A **intimação** para que o sujeito passivo apresente sua **defesa administrativa** (impugnação) pode ser:

I – pessoal;

II – via postal;

III – meio eletrônico (*e-mail*).

A **intimação pessoal** é realizada pelo **agente público competente**, podendo se dar na repartição fiscal ou em outro local. Não apenas o próprio sujeito passivo pode ser intimado, mas os mandatários ou prepostos do sujeito passivo também podem recebê-la.

Na hipótese de o sujeito passivo **recusar-se a assinar a intimação**, a **declaração do agente público** informando o ocorrido **suprirá a ausência da assinatura**, conforme assinalou o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 833.625/MG.

A **intimação via postal** será postada no endereço do sujeito passivo mediante **aviso de recebimento (AR)**, devidamente instruída com os documentos necessários para o exercício do direito de defesa.

Obviamente, para os fins de evitar prejuízos processuais em se remeter documentos em endereço desatualizado, caberá ao sujeito passivo **manter periodicamente atualizado seu domicílio fiscal**. Porém, a falta de domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo **não será impeditivo para o prosseguimento das intimações administrativas**, aplicando-se o disposto no art. 127 do CTN.

A **intimação por meio eletrônico** dependerá de **autorização do sujeito passivo**. Para que se tenha validade a intimação realizada, deverão os atos conter a **assinatura mediante a utilização de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)** e será enviada à Receita Federal do Brasil (tratando-se de impugnação administrativa federal) por meio do **Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte (e-CAC)**, disponível na internet, de acordo com a Lei 11.196/2005 e Portaria SRF 259/2006 e 574/2009.

2.2.3 Requisito processual da impugnação administrativa

Quem tem **legitimidade** para apresentação da impugnação administrativa é o **sujeito passivo da obrigação tributária (contribuinte ou responsável)**. Este poderá **ser representado por procurador**, devendo-se comprovar sua condição de representação.

Tratando-se de impugnação a ser apresentada por **pessoa física** (pessoa natural), pouca controvérsia reside na matéria. No entanto, cuidando-se de **pessoa jurídica**, não se pode confundir a **responsabilidade desta com a de seus dirigentes ou sócios**. Os **sócios** ou **dirigentes** são **meros representantes da pessoa jurídica**, esta sim sujeito passivo da referida obrigação tributária.

Sendo assim, não devem os sócios ou dirigentes possuir ônus de defesa, uma vez que não são partes no procedimento fiscal.

2.2.4 Requisito formal da impugnação administrativa

A impugnação administrativa deverá ser apresentada de **forma escrita**, devendo ser **protocolizada na repartição pública competente da localidade em que ocorreu a lavratura do ato**.

Excepcionalmente, contudo, tem-se admitido apresentação da impugnação administrativa pela **via postal**, mediante **aviso de recebimento (AR)**, pois será este que servirá como protocolo da apresentação tempestiva da impugnação.

Na impugnação administrativa **não é necessária a representação processual por meio de advogado**. No entanto, fazendo a opção por tal profissional, é **indispensável a apresentação de procuração com poderes especiais para este tipo de representação**.

Tratando-se de **pessoa jurídica**, deverá ser juntada **cópia autenticada do contrato social da empresa ou dos estatutos**, demonstrando os poderes de representação daquele que está realizando a impugnação administrativa.

Outras formalidades exigidas para a apresentação da impugnação administrativa encontram-se estabelecidas no art. 16 do Decreto 70.235/1972, determinando que a impugnação deverá conter:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;

IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito;

V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.

2.2.5 Competência para o julgamento da impugnação administrativa

A impugnação administrativa inicia o processo administrativo fiscal em primeira instância administrativa.

Como regra geral, a impugnação administrativa **poderá ser encaminhada para a autoridade administrativa competente**, de acordo com o tributo a ser questionado.

Assim, podemos identificar as seguintes **autoridades administrativas de primeira instância** que exercem competência para julgamento das impugnações:

TRIBUTO FEDERAL	TRIBUTO ESTADUAL	TRIBUTO MUNICIPAL
Delegado da Receita Federal ou Inspetor Alfandegário da Receita Federal	Delegado Regional Tributário	Diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias ou Imobiliárias

No caso apresentado supra, nos **tributos federais** relativos a **aduana** (importação e exportação), a **autoridade competente**, em tese, será o **Inspetor Alfandegário da Receita Federal do Brasil**. No caso de **demaís tributos federais**, a competência será do **Delegado da Receita Federal do Brasil**.

Para os **tributos estaduais**, a competência da impugnação administrativa, em regra, será do **Delegado Regional Tributário**.

Para os **tributos municipais imobiliários** (IPTU, ITBI e demais tributos incidente sobre o imóvel), a competência passa a ser do **Diretor do Departamento de Rendas**

Imobiliárias. Os demais tributos municipais seriam de competência do **Diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias.**

Frisa-se, entretanto, que tais competências **poderão variar para cada Estado ou Município**, dependendo das respectivas legislações locais aplicáveis.

Os arts. 27 a 36 do Decreto 70.235/1972 disciplinam o **julgamento do processo administrativo em primeira instância**. Os processos administrativos que envolvam **crimes contra a ordem tributária** (Lei 8.137/1990) têm **prioridade no julgamento**, assim como os **processos administrativos de alto valor**.

2.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA



Após a decisão prolatada pela autoridade competente da primeira instância administrativa, caberá **recurso voluntário** a ser interposto pelo **sujeito passivo** para a autoridade julgadora da primeira instância que, observados os **requisitos formais e materiais**, remeterá a medida para o **Tribunal Administrativo** competente.

O **recurso voluntário** passa a ser aquele interposto pelo sujeito passivo quando a **decisão for desfavorável em primeira instância**. Caso a decisão, entretanto, seja **desfavorável ao Fisco**, este poderá interpor **recurso de ofício**.

A **interposição tempestiva do recurso voluntário** prorroga a **suspensão da exigibilidade do crédito tributário**, sem a necessidade de existência de qualquer depósito recursal para a continuidade da suspensão da exigibilidade.

Conforme já decidido pelo STF na edição da Súmula Vinculante 21:

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso

administrativo.

A previsão para interposição do recurso voluntário encontra-se no art. 33 do Decreto 70.235/1972. **O prazo para interposição do recurso voluntário** perante a autoridade competente será de **30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância**.

O recurso voluntário suspende os efeitos da decisão de primeira instância na parte controvertida, conforme o caso.

O recurso deverá ser interposto perante a autoridade competente, que remeterá ao **Tribunal Administrativo correspondente** para que o colegiado decida sobre a matéria.

Na **esfera federal**, o **recurso voluntário** deverá ser encaminhado ao **Delegado da Receita Federal de Julgamento** da localidade em que o processo se desenvolveu. Este analisará os requisitos de admissibilidade do recurso para posterior encaminhamento ao **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)** que sucedeu o **Conselho de Contribuintes**, com o advento da Lei 11.941/2009.

Na **fase recursal**, não será permitido juntar **novos documentos** ou ainda requerer **novas diligências** ou **novas provas**, sendo excepcionalmente admitida a **prova documental** nos seguintes casos:

I – se restar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivos de força maior;

II – quando se referir a fato ou a direito superveniente;

III – quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

2.3.1 Formalização do recurso voluntário

Após análise dos requisitos formais necessários, outras formalidades acabam sofrendo dispensa no caso de apresentação do recurso voluntário. É o que ocorre com relação à **qualificação do recorrente**.

Não se faz necessária a qualificação completa do recorrente, uma vez que tais dados já se encontram presentes na impugnação administrativa.

Poderá ser adotada, contudo, **técnica de interposição de recursos**, composto por uma **petição de interposição** a ser dirigida pela **autoridade administrativa**

competente que julgou a impugnação administrativa e das razões anexas, para que estas sejam encaminhadas ao **Tribunal Administrativo** (órgão colegiado) competente.

2.3.2 Recurso de ofício

Trata-se de medida utilizada pela própria Administração Pública quando o Fisco tem **improcedência da pretensão em primeira instância administrativa**.

A **remessa do recurso é, em regra, necessária**, ou seja, mediante a decisão desfavorável da pretensão fiscal, o recurso de ofício se traduz como uma **remessa necessária** para apreciação perante o Tribunal Administrativo competente.

O recurso de ofício deverá ser interposto **obrigatoriamente** (remessa necessária) nos seguintes casos (art. 34 do Decreto 70.235/1972):

I – quando a decisão “exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda”;

II – quando “deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração denunciada na formalização da exigência”.

No que tange ao primeiro inciso, o valor definido pelo Ministério da Fazenda é de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais), incluindo o principal, juros, correções e multas. Ressalta-se que o valor anteriormente citado está determinado de acordo com a Portaria do Ministério da Fazenda 3, de 3 de janeiro de 2008.

Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processos relativos à **restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil** bem como nos casos de **ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados** (art. 27 da Lei 10.522/2002).

2.3.2.1 Cabimento da reformatio in pejus da remessa de ofício

O **recurso de ofício**, conforme assinalado, deverá ser interposto pela autoridade administrativa competente. Em muitos casos, tal recurso se dá de **maneira obrigatória (remessa de ofício)**. A discussão que paira a respeito da **remessa necessária** é se a autoridade administrativa de segunda instância **poderá ou não agravar o sujeito passivo com o julgamento do recurso**.

Com a apresentação do recurso de ofício, **toda a matéria que está sendo**

debatida é devolvida ao **Tribunal Administrativo de segunda instância**, podendo este **agravar com a decisão**. No entanto, deverá ser aberta a oportunidade para apresentação de um **recurso voluntário contra a decisão do Tribunal Administrativo**.

Assim, mesmo que haja a possibilidade de apresentação de **recurso voluntário pelo sujeito passivo**, é possível a existência da *reformatio in pejus* na **decisão administrativa de recurso de ofício**.

2.3.3 Julgamento de segunda instância administrativa

O **juízo dos recursos interpostos perante a segunda instância administrativa** deverá observar a determinação contida no art. 37 do Decreto 70.235/1972 e nos regimentos internos dos Tribunais Administrativos.

Em se tratando da **segunda instância administrativa federal**, o julgamento dos recursos administrativos será de **competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)** cujo regimento interno foi aprovado pela Portaria 256 do Ministério da Fazenda.

O **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)** é um órgão colegiado, paritário e integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, cabendo-lhe julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Possui uma **estrutura administrativa e judicante**, sendo composto por **três seções**, com **quatro câmaras cada seção**. As câmaras são integradas por turmas **ordinárias e especiais**. A **Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)** é formada por **três turmas**. Como **órgão máximo**, temos o **Pleno da CSRF**.

Em **segunda instância administrativa**, a lei prevê duas espécies de recursos (art. 64 da Portaria 256 do Ministério da Fazenda):

I – **embargos de declaração**; e

II – **recurso especial**.

Os **embargos de declaração** terão cabimento quando o acórdão proferido pelo CARF “**contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos**”, ou ainda se for **omitido pela turma**, ponto no qual se deveria pronunciar, conforme reza o art. 65 da Portaria 343/2015.

De acordo com o art. 65, § 1.º, da Portaria 343/2015, a **legitimidade para oposição dos embargos de declaração** será:

I – por conselheiro do colegiado;

II – pelo contribuinte, responsável ou preposto;

III – pelo Procurador da Fazenda Nacional;

IV – pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões;

V – pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão.

O **prazo para oposição dos embargos** será de **5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão**.

O **s embargos de declaração** poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de **5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão**.

Na hipótese de **não acolhimento** dos embargos, o despacho do Presidente da Câmara será **definitivo**. Caso sejam **acolhidos**, os embargos serão submetidos à deliberação da turma.

Sendo opostos tempestivamente, os embargos **interrompem o prazo para a interposição do recurso especial**.

O **recurso especial** será interposto contra a decisão que der à lei tributária uma **interpretação divergente** da que foi dada por outra câmara, turma ou pelo próprio CSRF. **Não tem cabimento o recurso especial** da decisão de qualquer das turmas que aplique súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou ainda que, na **apreciação de matéria preliminar**, decida pela **anulação da decisão de primeira instância**.

É considerado pressuposto de admissibilidade de recurso especial o **prequestionamento das matérias nas demais peças processuais**.

O **recurso especial** será instruído com **cópia do inteiro teor dos acórdãos divergentes** ou com a **cópia da publicação em que foram publicados**.

A **legitimidade para interposição do recurso especial** passa a ser:

I – procurador da Fazenda Nacional;

II – contribuinte.

O recurso deverá ser dirigido ao **Presidente da Câmara recorrida**, que fará o **despacho fundamentadamente** ou **negará seguimento ao recurso**, caso não haja observância dos pressupostos de admissibilidade.

O **prazo** para interposição do recurso será de **15 (quinze) dias** contados da data da ciência da decisão.

2.4 INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE DECISÕES DIVERGENTES DAS TURMAS DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prevê o **procedimento específico** para **uniformização de decisões divergentes entre suas turmas**, no art. 10 do Anexo II do Regimento Interno.

A **competência** para suscitar o incidente de uniformização passa a ser do:

I – presidente ou vice-presidente do CARF;

II – Procurador-geral da Fazenda Nacional;

III – Secretário da Receita Federal do Brasil;

IV – Presidente da confederação representativa das categorias econômicas de nível nacional e de central sindical.

2.5 RECURSO HIERÁRQUICO

A doutrina diverge sobre a possibilidade de interposição de **recurso hierárquico** contra a **decisão definitiva do órgão colegiado**, fundada em **supervisão ministerial**.

Serviria o recurso hierárquico para que o Ministro da Fazenda ou o Secretário de Governo pudessem **rever as decisões dos Tribunais Administrativos**.

O STJ legitimou o cabimento de recurso hierárquico no processo administrativo tributário federal fundando sua decisão na possibilidade de o Poder Executivo rever os atos praticados em decorrência do princípio da autotutela (Súmula 473 do STF), desde que haja a **garantia da ampla defesa**, legitimando-se o devido processo legal (STJ, MS 6.737/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j

10.04.2002).

2.6 NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

De acordo com o art. 59 do Decreto 70.235/1972, são considerados **nulos**:

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

A nulidade será declarada pela **autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade** (art. 61 do Decreto 70.235/1972).

As nulidades poderão ser **relativas** ou **absolutas**. Quando o vício recair sobre a norma que tutela o **interesse disponível da parte**, diz-se **nulidade relativa**. No entanto, quando os vícios **não puderem ser convalidados no curso do processo**, podendo ser **conhecidos de ofício pelo juiz** ou **alegados a qualquer momento pela parte interessada**, temos a **nulidade absoluta**.

2.7 DISPOSIÇÕES FINAIS

A decisão administrativa **não poderá ser reformada quando for contrária aos interesses da Administração Pública**, desde que tenha sido decidida em **última instância**.

Isto significa que o **Tribunal Administrativo faz coisa julgada material contra a Administração Pública**. Mesmo que ocorra a hipótese de **nulidade da decisão administrativa de última instância**, **não poderá ser objeto de qualquer medida judicial por parte da Administração Pública**.

Com o advento da Lei 11.457/2007, fora determinado no art. 24 que o **prazo máximo** para que seja proferida a decisão administrativa irreformável será de **360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte**.

Tal inserção se deu em observância ao art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988, que reza:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

MODELOS DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

3.1 MODELO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

A **impugnação administrativa** deverá observar os **requisitos formais** estabelecidos no art. 16 do Decreto 70.235/1972, que deverá conter:

a) **A autoridade julgadora a quem é dirigida**, ou seja, a autoridade competente para o julgamento da impugnação: no caso da impugnação administrativa federal, a defesa deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil.

b) **Qualificação do impugnante**: aconselha-se adotar a regra disposta no Código de Processo Civil, disposta no art. 319. Tratando-se de pessoa jurídica, a qualificação da empresa, sociedade ou entidade será indispensável, sendo facultativa a qualificação dos sócios, dirigentes ou responsáveis;

c) **Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir**: deverá ocorrer a narração dos fatos, implicando na simples descrição dos acontecimentos. Os fundamentos jurídicos consistem na argumentação jurídica, na consistência jurídica apresentada pelo impugnante. Dever-se-á evitar o excesso de transcrições, sendo claro, objetivo e conciso;

d) **As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito**: o impugnante deverá indicar as provas que pretende produzir, referindo-se às diligências ou perícias. As provas documentais deverão estar anexadas na petição de impugnação, não podendo ser utilizado outro momento, acarretando-se a preclusão. Caso o impugnante pretenda produzir prova pericial e queira indicar assistente técnico, deverá formular os requisitos que queira

que sejam respondidos;

e) **Pedido de improcedência:** é a forma de determinar que o impugnante não concorda com a pretensão da Administração Pública, sendo a consequência lógica da fundamentação da impugnação. Não vigora o princípio da sucumbência, uma vez que se trata de medida administrativa, inexistindo ônus sucumbenciais.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM...

(espaço de cinco linhas)

Auto de Infração n.º ...

IMPUGNANTE, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n., residente e domiciliado na ..., bairro..., cidade de ..., por seu advogado regularmente constituído (instrumento de mandato incluso), vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em face do Auto de Infração (lançamento de ofício) acima referido, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/1972, apresentar tempestivamente

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

conforme razões de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

(...)

II – DO DIREITO

(...)

III – DA PRODUÇÃO DE PROVAS

(...)

III – DO PEDIDO

Por todo o exposto e demonstrada a nulidade do Auto de Infração ora impugnado, requer:

a) sejam os pedidos formulados na presente Impugnação Administrativa julgados totalmente procedentes para o fim de anular o lançamento impugnando, nos termos dos artigos (...)

b) seja declarada a consequente extinção do crédito tributário, conforme artigo 156, IX, do Código Tributário Nacional.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º ...

3.2 RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso voluntário deverá observar os **requisitos formais**, devendo conter:

a) **Peça de interposição e razões do recurso:** na peça de interposição deverá ser apresentada ao **Delegado da Receita Federal do Brasil** em se tratando de tributos federais, ou outra autoridade competente, quando do processo administrativo em âmbito estadual e municipal. No caso de recurso voluntário de tributos federais, deverá ser requerido que as razões do recurso sejam remetidas ao **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF**.

b) **Estrutura das razões do recurso voluntário:** o recurso voluntário será estruturado em três partes: da exposição dos fatos, dos fundamentos para a reforma da decisão e do pedido de reforma.

c) **Exposição dos fatos:** deverá o recorrente narrar os acontecimentos de todo o processo até o momento da interposição do recurso.

d) **Fundamentos para a reforma da decisão:** o recorrente deverá apresentar os argumentos jurídicos para que seja modificada a decisão de primeira instância administrativa. O órgão recursal tem a função de rever a decisão anterior.

e) **Pedido de reforma:** a pretensão processual do recurso é a reforma da decisão, modificando sua conclusão total ou parcial. Deverá o órgão julgador ficar adstrito ao que foi requerido nas razões recursais.

MODELO DE RECURSO VOLUNTÁRIO EM ÂMBITO FEDERAL

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM...

(espaço de cinco linhas)

Processo Administrativo n.º ...

Impugnação Administrativa

RECORRENTE, já devidamente qualificado, por seu advogado regularmente constituído no autos do presente processo administrativo (instrumento de mandato às fls.), vem, respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, tendo em vista a decisão administrativa proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação Administrativa da ora Recorrente, com fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972 apresentar tempestivamente **RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO**.

Após a realização da admissibilidade e demais pressupostos, requer que as anexas razões de Recurso Administrativo Voluntário sejam remetidas ao E. **Conselho Administrativo de**

Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/... n.º...

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – CARF

Processo Administrativo n.º ...

Recorrente: ...

Recorrido: ...

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO,
DOUTOS CONSELHEIROS JULGADORES,

I – DOS FATOS

(...)

II – RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA RECORRIDA

(...)

III – DO PEDIDO

Diante das razões expostas requer-se a total procedência dos pedidos formulados no presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão administrativa recorrida para o fim de anular-se o lançamento impugnando e declarar-se extinto do crédito tributário, nos termos do artigo 156, IX, do Código Tributário Nacional.

Local, data.

Advogado(a)

OAB/ ... n.º...

TERCEIRA PARTE

REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ORDINÁRIOS

1

IMPOSTOS EM ESPÉCIE

Conforme já analisado, os **impostos** têm a sua definição estabelecida no CTN, nos termos do art. 16. **Não há necessidade de lei complementar para a instituição dos impostos**, salvo nos casos do **Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF)**, conforme reza o art. 153, VII, da CF/1988, e dos **Impostos Residuais**, estabelecidos no art. 154, I, da CF/1988.

No entanto, o art. 146, III, *a*, da CF/1988 determina que a **estrutura jurídica dos impostos**, qual seja os seus **atos geradores, bases de cálculo e contribuintes**, devem estar dispostos numa **lei complementar em âmbito nacional**.

Boa parte dos impostos estabelecidos na CF/1988 possui sua estrutura jurídica disposta no CTN (Lei 5.172/1966), a partir do art. 19. Porém, no que diz respeito ao **Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS)** ao **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)** a disposição da estrutura jurídica encontra-se em **lei complementar nacional** à parte do CTN. Trata-se da **LC 87/1996** para o ICMS e da **LC 116/2003** para o ISS.

Já o **Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)** não possui nenhuma determinação das normas gerais mediante edição de uma **lei complementar nacional**. Por esta razão, o STF, aplicando o disposto no art. 24, § 3.º, da CF/1988, determinou a competência legislativa plena dos Estados para legislar

sobre o IPVA, enquanto não sobrevier lei complementar nacional. Dentre outros julgados, destacamos o AgRg no RE 414.259, rel. Min. Eros Grau, em 24.06.2008, em que afirma a “competência dos Estados para edição de normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no art. 24, § 3.º, da CF/1988”.

O mesmo ocorre com o Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). O CTN não traz sua estrutura jurídica – alguns utilizam a estrutura jurídica prevista entre os arts. 35 a 42 do CTN, mas não se trata da estrutura própria desse imposto –, permitindo que os Estados, ante o disposto no art. 24, § 3º, da CF possam editar lei ordinária estadual estabelecendo seu regramento de incidência.

Caso a lei complementar em âmbito nacional seja editada e as normas estaduais relativamente ao IPVA e ao ITCMD forem a ela contrárias, haverá suspensão da eficácia dos dispositivos, nos termos do art. 24, § 4º, da CF.

1.1 REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA

Em cada um dos impostos pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios analisaremos a regra-matriz de incidência tributária. Para que a exigência tributária seja perfeitamente válida, deve ter todas as **condutas previamente descritas em lei**, sob pena de existência de uma **tributação por analogia**, fato este vedado explicitamente ante a existência do **Princípio da Tipicidade Cerrada ou Fechada**, vinculado ao **Princípio da Legalidade**. Tais condutas podem ser denominadas de aspectos ou critérios do fato gerador ou da regra-matriz de incidência tributária. Podemos dividi-los em cinco aspectos:

a) Aspecto material

É a **descrição do fato**, sendo por si só suficiente para fazer nascer a obrigação do particular em ter que pagar tributo. Por exemplo, somente a expressão “circular mercadorias” já nos remonta a que tributo está se falando (neste caso, o ICMS). Assim, entendemos que o aspecto material pode ser definido como **verbo em conjunto com o complemento**.

b) Aspecto espacial

É o **local da ocorrência do fato gerador** de uma obrigação tributária. Esse aspecto está atrelado a saber identificar a **competência tributária** e a **capacidade tributária passiva**, bem como, em determinados casos, o **domicílio tributário**, nos

termos do art. 127, § 1º, do CTN.

c) Aspecto temporal

É o **momento da ocorrência do fato gerador**. É importante a sua descrição para se entender qual a **norma aplicável ao evento concreto**, aos **princípios da anterioridade e irretroatividade** e ao instituto da **decadência tributária nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação** (art. 150, § 4º, do CTN).

d) Aspecto pessoal

São os **sujeitos da obrigação tributária**, divididos no **sujeito ativo** (quem pode exigir o cumprimento da obrigação tributária) e **sujeito passivo** (quem deve cumprir com a obrigação tributária).

O **sujeito ativo**, nos termos do art. 119 do CTN, é aquele que exerce a competência tributária. Nesse caso, temos como dotados dessa competência os entes federados dotados de competência legislativa plena: União, Estados, DF e Municípios.

Entretanto, o STF posicionou-se no sentido de identificar como sujeito ativo da obrigação tributária a **entidade dotada de capacidade tributária ativa**, incluindo-se, portanto, ao rol estabelecido no CTN, as **autarquias e fundações públicas**. Assim, **todas as pessoas jurídicas de direito público interno** figuram como **sujeitos ativos de obrigação tributária**.

Já o **sujeito passivo** é aquele que possui o **dever legal de cumprir com a obrigação tributária**. Pode ser identificado como o **contribuinte** ou o **responsável**. **Contribuinte** é toda pessoa física ou jurídica que realiza a conduta descrita na norma jurídica tributária (fato gerador em abstrato), fazendo nascer a obrigação tributária (fato gerador em concreto). **Responsável** é a terceira pessoa, física ou jurídica, indicada na lei tributária para assumir um determinado encargo, não realizando a conduta típica (seja em abstrato ou concreto), mas gozando de um **nexo de causalidade** com a ocorrência dessa conduta.

e) Aspecto quantitativo

São os **critérios valorativos do fato gerador**, divididos em **base de cálculo e alíquota**. Entendemos por **base de cálculo** o valor estimado pela lei para atribuição de um critério de tributação e por **alíquota** o percentual devido que, multiplicado pela base de cálculo, demonstrará o *quantum* a ser pago pelo particular ao Estado.

As alíquotas podem ser **específicas** (quando levam em consideração uma

determinada unidade de medida) ou *ad valorem* (quando incidentes em percentual). Dependendo de cada tributo em questão, poderemos ter tanto alíquotas incidindo sobre unidades de medida como em percentuais.

Sumariamente, vamos abordar estes cinco aspectos da regra-matriz de incidência tributária, descrevendo-os em cada um dos impostos federais, estaduais e municipais.

IMPOSTOS FEDERAIS

São considerados federais os impostos cuja competência para a sua instituição pertence à União. Tais impostos estão descritos no art. 153 da CF/1988.

2.1 IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)

2.1.1 Previsão legislativa

O imposto de importação (II) é um imposto federal previsto no art. 153, I, da CF/1988.

As normas gerais atinentes à sua estrutura jurídica vêm trazidas entre os arts. 19 a 22 do CTN.

A legislação aplicada que efetivamente institui o imposto é o Decreto-lei 37/1966, e a regulamentação da administração de todas as atividades aduaneiras, fiscalização, controle, tributação das atividades no comércio exterior vem tratada no Decreto 6.759/2009.

Esses são os principais diplomas normativos utilizados para o imposto sobre a importação (II), sem prejuízo de outras normas jurídicas, tais como instruções normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e Tratados e Convenções Internacionais que concedem incentivos fiscais.



Note bem

As principais legislações aplicáveis são: a CF/1988, CTN (arts. 19 a 22) e Decreto-lei 37/1966, com as alterações posteriores.

2.1.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.1.2.1 Aspecto material

Conforme se depreende da análise constitucional (art. 153, I, da CF/1988) e legal (art. 19 do CTN), o imposto é devido na **entrada de produtos estrangeiros no território nacional**.

Entende-se por **território nacional** a área que compreende o espaço terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, em que o Brasil exerce sua soberania.

O denominado **território aduaneiro** compreende o **território nacional**, inclusive o **mar territorial** e o **espaço aéreo correspondente**. Segundo a legislação aduaneira aplicada, podemos dividir o território aduaneiro em **zona primária** e **zona secundária**. É o que determinam os arts. 2.º e 3.º do Decreto 6.759/2009, que dizem:

Art. 2.º O território aduaneiro compreende todo o território nacional.

Art. 3.º A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange:

I – a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira local:

a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados;

b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e

c) a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados; e

II – a zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo.

§ 1.º Para efeito de controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação, referidas no art. 534, constituem zona primária.

§ 2.º Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o

órgão ou empresa a que esteja afeta a administração do local a ser alfandegado.

§ 3.º A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais.

§ 4.º A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados, restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos não utilizados em serviço.

§ 5.º A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às Áreas de Controle Integrado criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil.

Pela simples análise normativa, poderíamos determinar que o **mero ingresso de um navio ou de uma aeronave**, seja no espaço marítimo ou aéreo **seria suficiente para a incidência do referido imposto**, o que seria uma exigência legal absurda.

Lembramos que o território nacional é o **território geográfico**, sendo excluídas as representações diplomáticas no exterior, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras.

Assim, o **aspecto material** resta demonstrado quando do **ingresso definitivo do produto em território nacional**. Não basta o mero ingresso temporário, mas o ingresso do produto com o fito de ser **incorporado à economia nacional**.

Ilustra, com propriedade, a Prof. Mizabel Derzi que somente deve se considerar o ingresso de um produto no território nacional o produto importado do estrangeiro que ingressa à economia nacional para o **uso comercial, industrial ou consumo**, não se considerando o simples **trânsito do produto**.

Portanto, o ingresso do produto deve ser **definitivo**, não se admitindo a incidência do referido imposto quando a entrada for **meramente temporária**. O ingresso de um quadro para exposição, o atracamento de um navio com produtos num determinado porto do país ou o simples ingresso de uma aeronave no espaço aéreo brasileiro, mesmo que contenha produtos, não será suficiente para a incidência do referido imposto.

Percebemos que a incidência do referido imposto se dá sobre **produtos**. Assim, o **campo de incidência** abrange tanto as **mercadorias** quando **bens destinados para o consumo próprio**. Assim, **produto é toda coisa móvel corpórea**, atingindo, inclusive, **produtos para incorporação no ativo fixo das empresas e para o consumo próprio**.

A incidência poderá ocorrer tanto sobre **bens tangíveis** ou **intangíveis**. Assim, poderá incidir tanto sobre um maquinário (bem material, tangível) quanto sobre energia elétrica (bem imaterial, intangível).

De igual modo, a legislação admite a incidência sobre a **entrada presumida de mercadoria estrangeira**. Conforme dispõe o art. 1.º, § 2.º, do Decreto-lei 37/1966, a simples falta ou ausência do produto importado não é significativa para que não haja a incidência do referido imposto. A legislação coloca situações em que o referido imposto pode estabelecer **tolerância quando da perda de peso** ou de **quantidades** quando da **descarga do produto** ou em **condições normais de manuseio**, como pode ocorrer com a importação de grãos.

Mesmo que a mercadoria importada esteja **avariada** ou venha a ser **roubada** ou **furtada não escapará da incidência do referido imposto**, sendo irrelevante se o fato ocorreu após o desembaraço aduaneiro.

a) Não incidência

Estabelece o art. 71 do Decreto 6.759/2009, com as alterações do Decreto 8.010/2013:

Art. 71. O imposto não incide sobre:

I – mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegar ao País por erro inequívoco ou comprovado de expedição, e que for redestinada ou devolvida para o exterior;

II – mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda;

III – mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida;

IV – mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda;

V – embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro, como propriedade da mesma empresa nacional de origem;

VI – mercadoria estrangeira destruída, sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de desembarcada; e

VII – mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída.

§ 1.º Na hipótese do inciso I do caput:

I – será dispensada a verificação da correta descrição, quando se tratar de remessa postal internacional destinada indevidamente por erro do correio de procedência; e

II – considera-se erro inequívoco de expedição, aquele que, por sua evidência, demonstre destinação incorreta da mercadoria.

§ 2.º A mercadoria a que se refere o inciso I do caput poderá ser redestinada ou devolvida ao exterior, inclusive após o respectivo desembarço aduaneiro, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda.

§ 2.º-A. A autoridade aduaneira poderá indeferir a solicitação da destruição a que se refere o inciso VI do caput, com base em legislação específica.

§ 3.º Será cancelado o eventual lançamento de crédito tributário relativo a remessa postal internacional:

I – destruída por decisão da autoridade aduaneira;

II – liberada para devolução ao correio de procedência; ou

III – liberada para redestinação para o exterior.

Além dos dispositivos legais contidos, a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de **não incidência em diversos casos**. Dentre os mais importantes, destacamos a **não incidência de imposto de importação quando o produto está sujeito a pena de perdimento**. Ademais, a **entrada de nova mercadoria em substituição à mercadoria devolvida em razão de defeito** também não terá a incidência, desde que tenha ocorrido a incidência sobre o produto defeituoso quando de seu ingresso.

2.1.2.2 Aspecto espacial

O imposto de importação (II) **incide na entrada de produto estrangeiro no território nacional**. Sendo assim, em **qualquer local do território geográfico brasileiro** onde determinado produto ingressar de maneira definitiva, sendo incorporado à economia nacional, haverá a incidência.

Caberá a ocorrência da fiscalização e controle em todo o território aduaneiro pela **Secretaria da Receita Federal do Brasil**, sendo a fiscalização supervisionada e executada pelo **Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil**.

O **exercício da fiscalização** em todo o território nacional poderá ser **ininterrupto** ou em **horários determinados** nos portos e aeroportos do país.

2.1.2.3 Aspecto temporal

Estabelece o art. 73 do Decreto 6.759/2009:

Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador:

I – na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para consumo;

II – no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:

a) bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de importação comum;

- b) bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada;
- c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira; ou
- d) mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na hipótese em que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja localizada.

III – na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria, na hipótese a que se refere o inciso XXI do art. 689.

IV – na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica.

Parágrafo único. O disposto no inciso I aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo de mercadoria sob regime suspensivo de tributação, e de mercadoria contida em remessa postal internacional ou conduzida por viajante, sujeita ao regime de importação comum.

Para todos os efeitos, considera-se como o aspecto temporal **a data do registro da declaração de importação**, sendo este o entendimento adotado pela atual jurisprudência.

De acordo com as disposições contidas na Secretaria da Receita Federal do Brasil, **a declaração de importação será formulada pelo importador no Siscomex** (Sistema Integrado do Comércio Exterior).

Toda mercadoria procedente do exterior, seja importada a título definitivo ou não, deverá ser submetida a **despacho de importação**, sendo realizado com base em declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria.

Antes de iniciar a operação de importação, caberá ao interessado verificar se está habilitado para usar o Siscomex, sendo o despacho aduaneiro dividido em **despacho para consumo e despacho para admissão em regime aduaneiro especial**.

O denominado **despacho para consumo** ocorre quando as mercadorias ingressadas no país forem **destinadas ao uso**, pelo **aparelho produtivo nacional**, tais como insumos, matéria-prima, bens de produção ou produtos intermediários, ou até mesmo para consumo próprio ou revenda. O principal objetivo é a **nacionalização da mercadoria importada**, aplicando-se o regime comum de importação.

O denominado **despacho para admissão em regimes aduaneiros especiais ou aplicados em áreas especiais** tem por objetivo o ingresso no país de mercadorias, produtos ou bens provenientes do exterior, que deverão permanecer no regime por **prazo certo e conforme a finalidade destinada**, sem a incidência imediata dos tributos, os quais permanecem **suspensos até a extinção do regime**. Trata-se dos casos de regimes especiais de tributação, tais como **admissão temporária**, *drawback*, **regimes de entrepostos industriais**, bem como nas áreas onde se aplicam **regimes aduaneiros**, tais como **Zona Franca de Manaus**, **Áreas de Livre Comércio** e **Zonas de Processamento de Exportação**.

Em síntese, a declaração de importação (DI) passa a ser o documento suficiente para a determinação do momento da incidência do imposto de importação, devendo conter, dentre outras informações:

- a identificação do importador, adquirente ou encomendante;
- a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem do produto importado.

Dentre os principais **regimes aduaneiros especiais**, podemos indicar os seguintes:

- **Admissão Temporária**: previsto nos arts. 353 a 379 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), passa a ser um regime especial que permite o ingresso de mercadorias e produtos do exterior para **permanência temporária no país**, com a **suspensão do pagamento de tributos**, seja de forma total ou parcial;
- **Admissão Temporária para aperfeiçoamento ativo**: previsto nos arts. 380 a 382 do Regulamento Aduaneiro, é o que permite o ingresso, para **permanência temporária no país**, com a suspensão do pagamento dos tributos, de **mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas**, destinadas a **operações de aperfeiçoamento ativo** e posterior reexportação;

- **Drawback**: estabelecido entre os arts. 383 a 403 do Regulamento Aduaneiro, trata-se de um regime especial que visa a **incentivar a exportação**, podendo ser aplicado em três modalidades (suspensão, isenção ou restituição);
- **Free Shop**: previsto nos arts. 476 a 479 do Regulamento Aduaneiro, trata-se de regime especial que permite um **determinado estabelecimento situado em zona primária de portos ou aeroportos alfandegados** alienar mercadorias nacionais ou importadas a passageiros que estejam em deslocamento internacional, mediante pagamento em moeda nacional ou estrangeira.

2.1.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** do imposto de importação é a **União**, sendo o ente federativo competente para a sua instituição e fiscalização.

O **sujeito passivo** será o **importador ou quem a lei a ele equiparar**, bem como o **arrematante de produtos apreendidos ou abandonados**, nos termos do art. 22 do CTN.

O Decreto 6.759/2009 determina, a partir dos arts. 104, 105 e 106, quem poderá figurar na condição de **contribuinte** ou **responsável**:

Art. 104. É contribuinte do imposto:

I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro;

II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente; e

III – o adquirente de mercadoria entrepostada.

Art. 105. É responsável pelo imposto:

I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;

II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro; ou

III – qualquer outra pessoa que a lei assim designar.

Art. 106. É responsável solidário:

I – o adquirente ou o cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto;

II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;

III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;

IV – o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora;

V – o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal;

VI – o beneficiário de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas à execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado; e

VII – qualquer outra pessoa que a lei assim designar.

Na sujeição passiva do imposto de importação, muito se discutiu na jurisprudência pátria sobre a **responsabilidade incidente no transportador**.

O STJ firmou posicionamento no sentido de que **o transportador possui responsabilidade objetiva pelos tributos devidos**, mesmo que a mercadoria tenha sido extraviada quando do transporte. Isto ocorre como um mecanismo para se **coibir a fraude na importação**.

No entanto, caso a mercadoria que estiver sendo transportada seja isenta do referido imposto, não pode ser o transportador responsável pelo pagamento dos tributos. Se na hipótese de isenção o transportador não responde, também não responderá pelo que exceder ao valor que seria devido caso se concretizasse a importação.

Situação diversa passa a ser do **agente marítimo** que figura como **representante de transportadora**. Mesmo que haja a assinatura de um termo de responsabilidade, o

agente marítimo não pode figurar como responsável pelo pagamento do imposto de importação, vez que inexistente previsão legal a esse respeito e a responsabilidade tributária, conforme vimos, não se presume, devendo decorrer de lei.

A Súmula 192 do extinto TFR traduz:

O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para os efeitos do Decreto-lei 37, de 1966.

2.1.2.5 Aspecto quantitativo

Formam o aspecto quantitativo da regra-matriz de incidência a base de cálculo e a alíquota.

Determina o art. 20 do CTN:

Art. 20. A base de cálculo do imposto é:

I – quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;

II – quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;

III – quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação.

A base de cálculo do imposto de importação dependerá do tipo de alíquota a ser aplicada sobre determinado produto. Assim, caso a alíquota seja específica, leva-se em consideração para a base de cálculo determinada unidade de medida. Assim, a base de cálculo não será aferida por fixação em moeda corrente, mas por unidade de medida (por exemplo: tantos reais por tonelada, tantos reais por metro etc.).

No caso de alíquotas *ad valorem*, mais comum, temos a incidência de um percentual sobre o valor definido em lei.

As alíquotas do imposto sobre a importação sempre foram estabelecidas de maneira seletiva, visando os interesses econômicos do país, conforme bem assevera Leandro Paulsen. Desde 1995, passamos a adotar a denominada **Tarifa Externa Comum** (TEC), para determinação de um valor aduaneiro para fins de incidência do imposto de importação.

Nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte, sabemos que a CF/1988 estabelece um tratamento diferenciado em matéria tributária, administrativa, creditícia e previdenciária, visando determinar a existência de livre concorrência dentro dos padrões da ordem econômica, nos termos dos arts. 170, IX, e 179, todos da CF/1988.

Para tanto, fora criado pela LC 123/2006 o denominado **Simples Nacional**, sendo um sistema simplificado de arrecadação e fiscalização de tributos incidentes sobre a atividade empresarial conceituada como microempresa ou empresa de pequeno porte, de modo a simplificar o cumprimento das obrigações administrativas e diminuir a carga tributária. Tal regime passa a ser adotado de modo **opcional** por tais entidades.

Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte sejam optantes do Simples, o pagamento do imposto de importação, nos casos de importação de mercadorias procedentes do Paraguai pela via terrestre, ocorrerá por meio de um **Regime de Tributação Unificada** (RTU).

Neste caso, o pagamento será realizado na data do registro da Declaração de Importação, aplicando-se uma alíquota única de 42,25% sobre o preço da aquisição das mercadorias importadas, correspondendo a 18% de imposto sobre a importação (II), 15% de imposto sobre produtos industrializados (IPI), 7,6% de Cofins Importação e 1,65% de PIS-Importação, conforme determina a Lei 11.898/2009.

2.1.2.6 Demais características

O imposto de importação passa a ser utilizado, pelo Governo Federal, como um mecanismo de regulação econômica. Portanto, passa a ser considerado um **tributo extrafiscal**.

Tendo a característica marcante de tributo extrafiscal, o **princípio da legalidade resta mitigado**, uma vez que suas **alíquotas podem ser alteradas por meio de atos do Poder Executivo**. Assim, o Poder Executivo, normalmente por meio de Decreto, poderá **aumentar** ou **reduzir** as alíquotas do imposto de importação, desde que haja estrita observância da lei. Não poderá o Poder Executivo aumentar acima do limite

máximo ou reduzir abaixo do limite mínimo estabelecido em lei, configurando-se exorbitância do Poder Regulamentar conferido pela CF/1988.

Caso o Poder Executivo exorbite os limites estabelecidos em decorrência do Poder Regulamentar, caberá ao Congresso Nacional a sustação dos atos normativos, nos termos do art. 49, V, da CF/1988.

De igual modo, teremos uma **mitigação do princípio da anterioridade tributária**, uma vez que o referido imposto poderá ser exigido imediatamente, após a publicação da lei, quando esta aumentar ou reduzir as suas alíquotas, conforme estabelece o art. 150, § 1.º, da CF/1988.

A legislação aduaneira estabelece **isenções** a serem aplicadas ao imposto de importação, conforme traduz os arts. 114 a 137 do Decreto 6.759/2009.

Por fim, vale a pena registrar que a doutrina e a jurisprudência caminham no sentido de determinar que o imposto de importação é sujeito a **lançamento por homologação**, uma vez que permanece a competência do importador para estabelecer o cálculo do montante devido, realizando o seu recolhimento antecipado, cabendo ao próprio Siscomex a retirada do numerário da conta do importador, quando da elaboração do registro da declaração de importação perante o sistema. Cabe a um Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a conferência dos valores pagos e da declaração realizada e anuir com o procedimento adotado (homologação).

JURISPRUDÊNCIA

- “O momento da ocorrência do fato gerador observará a regra do art. 23 do DI 37/66 – data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira” (STJ, REsp 174.444/SP, j. 02.08.2001, rel. Min. Milton Luis Pereira, *DJ* 11.03.2002).
- “Roubo ou avaria do produto por ocasião do transporte interno: exigência devida do II” (STJ, REsp 1.172.027/RJ, j. 26.08.2010, rel. Min. Elian Calmon, *DJ* 30.09.2010).
- “Pagamento do II, ICMS e IPI: condição para o desembaraço aduaneiro do produto – afastamento da Súmula 323 STF” (STJ, REsp 180.131, j. 22.09.1998, rel. Min. José Delgado, *DJ* 23.11.1998).
- “A mercadoria importada qualificada como bagagem acompanhada que fora

apreendida em zona secundária e desacompanhada de Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA) será restituída ao viajante até o limite da cota de isenção determinada pela Receita Federal (art. 33 da IN 1.059/2010 da RFB) aplicável a pena de perdimento em relação à mercadoria que exceda esse limite. Isso porque, conforme dispõe o art. 33 da IN 1.059/2010 da RFB, o viajante procedente do exterior poderá trazer, com a isenção a que se refere o *caput* do art. 32, em sua bagagem acompanhada (art. 2.º, III), livros, folhetos, periódicos, bens de uso ou consumo pessoal e outros bens cujos limites de valor global não ultrapassem os limites da cota de isenção determinada por esse dispositivo normativo. De fato, de acordo com o art. 3.º, os ‘viajantes que ingressarem no território brasileiro deverão efetuar a declaração do conteúdo de sua bagagem, mediante o preenchimento, a assinatura e a entrega à autoridade aduaneira da Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA)’ Todavia, o art. 3.º-A, *caput*, dessa mesma Instrução Normativa determina que estão dispensados de apresentar a DBA de que trata o art. 3.º ‘os viajantes que não estiverem obrigados a dirigir-se ao canal ‘bens a declarar’’. Ocorre que, entre os viajantes que estão obrigados a dirigir-se ao canal ‘bens a declarar’ – e que, portanto, devem apresentar a DBA – enquadra-se o viajante que trazer ‘bens cujo valor global ultrapasse o limite de isenção para a via de transporte, de acordo com o disposto no art. 33’ (art. 6.º, VIII, da IN 1.059/2010 da RFB). Deste modo, se o que está dentro da cota de isenção dispensa declaração de bens, conclui-se que a pena de perdimento só é pertinente aos produtos que, por estarem acima dos limites da cota, venham a configurar dano ao erário, nos termos do art. 689 do Decreto 6.759/2009, já que, quanto a eles, há sim a obrigação de apresentação de declaração e demais formalidades de internação” (rel. Min. Humberto Martins, j. 12.08.2014).

- “A concessão do benefício de **ex-tarifário** alcança a importação realizada entre o pedido do referido benefício fiscal e a sua efetiva concessão, se a administração fazendária demorar injustificadamente a analisar e conceder o benefício. A concessão do benefício fiscal denominado **ex-tarifário** consiste na isenção ou redução de alíquota do imposto de importação, a critério da administração fazendária, para o produto desprovido de similar nacional, sob a condição de comprovação dos requisitos pertinentes. Sobre o referido benefício, cabe uma interpretação sistemática e a incidência do princípio da razoabilidade. É certo que a autorização de desembaraço aduaneiro com

suspensão de tributos constitui ato discricionário do Ministro de Estado da Fazenda (art. 12 do Decreto-lei 2.472/1988), sujeito, portanto, a juízo de oportunidade e conveniência. Porém, a injustificada demora da Administração na análise do pedido de concessão de regime **ex-tarifário**, por se tratar de importação de mercadoria sem similar nacional, somente concluída após a internação do bem, não pode prejudicar o contribuinte que atuou com prudente antecedência, sob pena de flagrante e direta ofensa ao princípio da razoabilidade. Assim, deve-se assegurar ao requerente a redução de alíquota do imposto de importação, nos termos da legislação de regência. Não haveria lógica em entender de modo diferente, pois acarretaria a situação de o requerente, apesar de iniciar o procedimento para concessão do benefício fiscal, apresentar os documentos exigidos e preencher todos os requisitos necessários, não se beneficiar do **ex-tarifário**, mas somente abrir portas para que seus concorrentes paguem o imposto de importação com a alíquota reduzida” (rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.02.2014).

- “Recurso extraordinário em que se argumentou a não incidência do II e do IP sobre operação de importação de sistema de tomografia computadorizada, amparada por contrato de arrendamento mercantil. Alegada insubmissão do arrendamento mercantil, quer seria um serviço, ao fato gerador do imposto de importação (art. 153, I, da Constituição). Inconsistência. Por se tratar de tributos diferentes, com hipóteses de incidência específicas (prestação de serviços e importação, entendida como a entrada de bem em território nacional – art. 19 do CTN), a incidência concomitante do II e do ISS não implica bitributação ou violação de pretensa exclusividade e preferência de cobrança do ISS” (RE 429.306, rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJE* 16.03.2011, j. 1º.02.2011, 2ª T.).
- “Importação de automóveis usados. Proibição ditada pela Portaria 8, de 13-5-1991, do Ministério da Fazenda. Alegada afronta ao princípio constitucional da legalidade. Entendimento do STF no sentido da legalidade da Portaria que editou lista dos bens de consumo passíveis de importação e, ao mesmo tempo, proibiu a importação de bens de consumo usados (RE 203.954-3)” (RE 187.321, rel. min. Ilmar Galvão, *DJ* 30.05.1997, j. 25-2-1997, 1ª T.).

2.2 IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO (IE)

2.2.1 Previsão legislativa

O imposto sobre a exportação (IE) é um imposto federal previsto no art. 153, II da CF/1988.

As normas gerais atinentes à sua estrutura jurídica estão previstas entre os arts. 23 a 28 do CTN.

A legislação aplicada que efetivamente institui o imposto é o Decreto-lei 1.578/1977, com as modificações constantes nas legislações posteriores, e a regulamentação da administração de todas as atividades aduaneiras, fiscalização, controle, tributação das atividades no comércio exterior vem tratada no Decreto 6.759/2009.

Esses são os principais diplomas normativos utilizados para o imposto sobre a exportação (IE), sem prejuízo de outras normas jurídicas, tais como instruções normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e Tratados e Convenções Internacionais que concedem incentivos fiscais.

2.2.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.2.2.1 Aspecto material

O imposto de exportação incide na **saída do produto nacional ou nacionalizado** do território nacional.

Entende-se por **território nacional** a área que compreende o espaço terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, em que o Brasil exerce sua soberania.

O denominado **território aduaneiro** compreende o território nacional, inclusive o mar territorial e o espaço aéreo correspondente. Segundo a legislação aduaneira aplicada, podemos dividir o território aduaneiro em **zona primária e zona secundária**. É o que determinam os arts. 2.º e 3.º do Decreto 6.759/2009, que é utilizado como mesmo critério material para o imposto de importação:

Art. 2.º O território aduaneiro compreende todo o território nacional.

Art. 3.º A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange:

I – a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira local:

a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados;

b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e

c) a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados; e

II – a zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo.

§ 1.º Para efeito de controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação, referidas no art. 534, constituem zona primária.

§ 2.º Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou empresa a que esteja afeta a administração do local a ser alfandegado.

§ 3.º A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais.

§ 4.º A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados, restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos não utilizados em serviço.

§ 5.º A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às Áreas de Controle Integrado criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil.

Entende-se por **nacionais** todos os produtos que são produzidos em território nacional. Os denominados **nacionalizados** são os produtos que foram incorporados à economia nacional.

Reza o art. 212, § 1.º, do Decreto 6.759/2009:

Art. 212. O imposto de exportação incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior.

§ 1.º Considera-se nacionalizada a mercadoria estrangeira importada a título definitivo.

Incide o referido imposto na exportação considerada **definitiva**, ou seja, na saída do produto do território nacional para ingresso (incorporação) definitivo no território de outra nação.

A simples saída **temporária** não se sujeita à incidência do imposto sobre a exportação.

Lembramos que o território nacional é o **território geográfico**, sendo excluídas as representações diplomáticas no exterior, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras.

2.2.2.2 Aspecto espacial

O imposto de exportação (IE) incide na **saída do produto nacional ou nacionalizado do território nacional**. Sendo assim, em **qualquer local do território geográfico brasileiro** de onde determinado produto sair de maneira definitiva, sendo incorporado à economia de outro país, haverá a incidência.

Caberá a ocorrência da fiscalização e controle em todo o território aduaneiro pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo a fiscalização supervisionada e executada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

O exercício da fiscalização em todo o território nacional poderá ser ininterrupto ou em horários determinados nos portos e aeroportos do país.

2.2.2.3 Aspecto temporal

Estabelece o art. 1.º, § 1.º, do Decreto-lei 1.578/1977:

Art. 1.º O Imposto sobre a Exportação, para o estrangeiro, de produto nacional ou nacionalizado tem como fato gerador a saída deste do território nacional.

§ 1.º Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da Guia de Exportação ou documento equivalente.

De acordo com a nova sistemática de integração do Comércio Exterior, adotado pelo Siscomex, a denominada **guia de exportação** passa a ter como equivalente o **registro de exportação**.

Entretanto, **existe mais de um registro realizado perante o Siscomex**. Temos o **Registro de Venda (RV)**, **Registro de Crédito**, sendo estes irrelevantes para fins de incidência do referido imposto.

A jurisprudência dominante já se pronunciou a respeito, determinando que a incidência do referido imposto ocorre com o **registro de exportação**.

2.2.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** do imposto de exportação é a **União**, sendo o ente federativo competente para a sua instituição e fiscalização.

O **sujeito passivo** (contribuinte ou responsável) é determinado no art. 5.º do Decreto-lei 1.578/1977 e no art. 27 do CTN: “Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar”.

Não há um critério legal que determine como **contribuinte apenas a pessoa jurídica, podendo figurar**, de igual modo, uma **pessoa física**. Da mesma forma, não importa para os fins de incidência e determinação do contribuinte se a exportação é realizada de maneira esporádica ou habitual, uma vez que basta promover a saída do produto nacional ou nacionalizado do território nacional, para fins de incidência.

Não há qualquer determinação, salvo as disposições contidas no Código Tributário Nacional, sobre o responsável tributário, admitindo-se, neste caso, as normatizações contidas no CTN sobre o tema.

2.2.2.5 Aspecto quantitativo

O **aspecto quantitativo** passa a ser estabelecido pela **base de cálculo e alíquota** no Código Tributário Nacional nos arts. 24 e 25.

Art. 24. A base de cálculo do imposto é:

I – quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;

II – quando a alíquota seja *ad valorem*, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento.

Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos.

A **base de cálculo do imposto de exportação**, assim como ocorre com o imposto de importação, **dependerá do tipo de alíquota a ser aplicada sobre determinado produto**. Assim, caso a **alíquota** seja **específica**, leva-se em consideração para a **base de cálculo determinada unidade de medida**. Logo, a base de cálculo não será aferida por fixação em moeda corrente, mas por unidade de medida (por exemplo, tantos reais por tonelada, tantos reais por metro etc.).

No caso de **alíquotas *ad valorem***, mais comuns, temos a incidência de um **percentual sobre o valor definido em lei**.

A utilização comum na questão referente ao imposto de exportação diz respeito ao uso dos **Incoterms**.

Os denominados **Incoterms** são termos que designam as **formas mais usuais no comércio internacional**. A criação advém da **Câmara de Comércio Internacional (CCI)**, visando administrar conflitos oriundos da interpretação dos contratos internacionais firmados entre exportadores e importadores concernentes à transferência de mercadorias, despesas que são decorrentes das transações internacionais e, notadamente, tratar da responsabilização nos casos de perdas e danos.

Inicialmente, tais termos foram aplicados em transportes marítimos e terrestres, a partir de 1936. A partir da década de 70, foram também aplicados aos transportes aéreos. Com o aparecimento do sistema intermodal de transporte, utilizando processos de inutilização de carga, mais dois termos foram criados na década de 80.

Atualmente, aplica-se o denominado **Incoterm 2000**, adaptando-se às recentes modificações nas zonas de livre comércio, comunicações eletrônicas e todas as modificações que enfrentamos nos transportes de mercadoria.

Temos usualmente **13 (treze) termos representados por meio de siglas**, sendo os mais comuns os seguintes:

1) **FOB (free on board)**: o vendedor, sob sua própria conta e risco, **deve colocar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador**, no porto de embarque designado. Competirá ao vendedor atender a todas as formalidades da exportação;

2) **CIF (Cost, Insurance and Freight)** por tal cláusula, **todas as despesas, incluindo seguro marítimo e frete até a chegada no porto de destino designado**, correm por conta do **vendedor**. Desde o momento em que há a **transposição da amurada do navio**, no porto de embarque, todos os **riscos são por conta do comprador**, que receberá a mercadoria no porto de destino e arcará com todas as despesas, tais como desembarque, tributação aduaneira, dentre outros. É utilizada somente nos casos de **transporte marítimo**.

Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a base de cálculo é o **preço FOB da mercadoria**. Já a alíquota é fixada conforme determinação do art. 3.º do Decreto-lei 1.578/1977:

Art. 3.º A alíquota do imposto é de trinta por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a cinco vezes o percentual fixado neste artigo.

2.2.2.6 Demais características

O imposto de exportação passa a ser utilizado, pelo Governo Federal, como um

mecanismo de regulação econômica. Portanto, é considerado um **tributo extrafiscal**.

Em vista dessa característica marcante, o **princípio da legalidade resta mitigado**, uma vez que suas **alíquotas podem ser alteradas por atos do Poder Executivo**. Assim, o Poder Executivo, normalmente por meio de Decreto, poderá **aumentar ou reduzir as alíquotas do imposto de exportação**, desde que haja estrita observância da lei. Não poderá o Poder Executivo aumentar acima do limite máximo ou reduzir abaixo do limite mínimo estabelecido em lei, configurando-se exorbitância do Poder Regulamentar conferido pela CF/1988.

Caso o Poder Executivo exorbite os limites estabelecidos em decorrência do Poder Regulamentar, caberá ao Congresso Nacional a sustação dos atos normativos, nos termos do art. 49, V, da CF/1988.

De igual modo, teremos uma **mitigação do princípio da anterioridade tributária**, uma vez que o referido imposto **poderá ser exigido imediatamente**, após a publicação da lei, quando esta aumentar ou reduzir as suas alíquotas, conforme estabelece o art. 150, § 1.º, da CF/1988.

JURISPRUDÊNCIA

- “Não é qualquer registro no SISCOMEX que corresponde à expedição do documento equivalente à guia de exportação prevista no § 1º, *in fine*, do art. 1º do DL 1.578/1977, como determinante da ocorrência do fato gerador do tributo. Somente o Registro de Exportação corresponde e se equipara à Guia de Exportação. Editada a Resolução 2.112/1994 do Banco Central do Brasil depois dos registros de venda, mas antes dos registros de exportação, submetem-se as operações respectivas às alíquotas nelas fixadas, visto que tal fixação se dera antes da ocorrência do fato gerador” (AI 578.372 AgR, rel. min. Ellen Gracie, *DJE* 12.03.2010, j. 09.02.2010, 2ª T.).

2.3 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (IR)



2.3.1 Previsão legislativa

O imposto sobre a renda (IR) tem previsão constitucional estabelecida no art. 153, III, § 2.º, da CF/1988.

O Código Tributário Nacional traz entre os arts. 43 a 45 as disposições gerais atinentes ao referido imposto.

No que diz respeito ao imposto de renda sobre pessoa física (IRPF), a legislação aplicável passa a ser determinada na Lei 7.713/1988 e Lei 9.250/1995. Já o imposto de renda incidente sobre pessoa jurídica (IRPJ) vem estabelecido na Lei 8.981/1995 e Lei 9.430/1996, além de outros diplomas normativos existentes.

A regulamentação do referido imposto, bem como os critérios para a sua arrecadação, fiscalização e administração tributária, está determinado no Decreto 9.580/2018, denominado de Regulamento do Imposto de Renda (RIR), tanto aplicável a pessoa física quanto a pessoa jurídica.

2.3.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.3.2.1 Aspecto material

O imposto sobre a renda incidirá sobre a obtenção de **renda e proventos de qualquer natureza**.

Pela determinação estabelecida no CTN, a partir do art. 43, temos:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1.º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.

§ 2.º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.

Antes de adentrarmos nas informações estabelecidas no Código Tributário Nacional, cumpre ressaltar o que se considera **renda e a sua diferença com relação aos proventos**.

Entende-se por **renda** todo o **acréscimo patrimonial decorrente do produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos**. Já os **proventos** são os **acréscimos patrimoniais que decorrem de ganhos obtidos de atividades que já se cessaram com o tempo**.

Para o Prof. Roque Carrazza, a **renda** passa a ser entendida como **disponibilidade de uma riqueza nova**, sendo os **proventos** uma **forma de obtenção de valores que não são o resultado imediato de um trabalho que está sendo desenvolvido**, mas de um trabalho ou atividade que já cessou. Assim, o **recebimento de valores a título de aposentadoria entraria no conceito de proventos** e o **salário recebido em decorrência do exercício de uma atividade ingressaria no conceito jurídico de renda**.

Uma vez que o imposto de renda tem como fator de incidência o **acréscimo patrimonial**, não há incidência de imposto de renda nos valores que são obtidos a título de **indenização**.

Tais entendimentos já estão bastante sedimentados na jurisprudência dominante. Mesmo assim, entende a jurisprudência que deverá ser levado em consideração que o fato de se ter apenas o nome **“indenização”** não é suficiente para **determinação da não incidência**, devendo se atentar para a verba recebida.

Veja o entendimento aplicado de acordo com a súmula 463 do STJ:

Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de **indenização por horas extraordinárias trabalhadas**, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Por mais que a expressão **indenização** seja utilizada nesse caso, tais verbas integram o respectivo salário, gerando acréscimo patrimonial e sujeitando-se à incidência do IR.

Para elucidar as determinações aferidas pela jurisprudência, citamos algumas súmulas que versam sobre a temática:

Súmula 125 do STJ: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

Súmula 136 do STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.

Súmula 215 do STJ: A indenização recebida pela adesão a programa e incentivo à demissão voluntária não está sujeita a incidência do imposto de renda.

Súmula 386 do STJ: São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.

Súmula 498 do STJ: Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.

Mesmo de maneira não sumulada, a jurisprudência já firmou entendimento que não incide o imposto de renda sobre valores recebidos a título de **auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche**.

Nos casos de **ajuda de custo pela utilização de veículo próprio** para exercício da atividade laboral, também temos manifestação sobre a **não incidência de imposto de renda**.

Sem embargo, dispõe ainda o art. 153, § 2.º, I, da CF/1988:

Art. 153. (...)

§ 2.º O imposto previsto no inciso III:

I – será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei.

Entendemos por **generalidade** como a determinação constitucional de que o imposto de renda **deverá incidir sobre toda e qualquer pessoa**, seja esta **física ou jurídica**, indistintamente. Não importa quem recebeu o acréscimo patrimonial, devendo a União determinar o pagamento dentro dos limites estabelecidos em lei. Tal critério constitucional realiza uma homenagem direta ao princípio da isonomia, estabelecido nos termos do art. 150, II, da CF/1988:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

A **universalidade** compreende a incidência do imposto de renda **sobre todos e quaisquer rendimentos auferidos pelo contribuinte**, não importando a **licitude ou ilicitude da obtenção**. Vigê, no direito brasileiro, a aplicação do princípio ou cláusula *non olet*, em que o tributo **deverá incidir sejam sobre atividades lícitas ou ilícitas**, uma vez que o que verdadeiramente importa é a ocorrência do fato típico tributário. Apenas não se admite que a ilicitude recaia sobre o elemento essencial da norma de tributação, ou seja, sobre o fato gerador em si.

Por fim, o instituto da **progressividade** é um instrumento de **implementação da capacidade contributiva do contribuinte**, visando a tributar mais quem possui uma maior condição econômica. Trata-se de uma regra constitucional em que, aumentando-

se a base de cálculo, aumenta-se a alíquota, estabelecendo-se uma gradação.

2.3.2.2 Aspecto espacial

Um dos aspectos mais importantes a serem traduzidos na regra-matriz de incidência tributária pertinente ao IR é o **aspecto espacial**, ou seja, a determinação do local da ocorrência efetiva do fato gerador.

Isto porque, para o IR, aplica-se a **extraterritorialidade**, determinando o alcance do fato gerador não apenas no âmbito do território nacional, mas fora dele.

Uma parte da doutrina utiliza-se da expressão **tributação em bases universais**, significando a possibilidade de se determinar a tributação do IR independentemente de onde os valores foram auferidos, se dentro ou fora do país.

Estabelece o § 4.º do art. 3.º da Lei 7.713/1988:

Art. 3.º (...)

(...)

§ 4.º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

O artigo em comento faz a análise da **possibilidade da extraterritorialidade aplicável às pessoas físicas**. Já o art. 25 da Lei 9.249/1995 estabelece a **extraterritorialidade para a pessoa jurídica**:

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.

§ 1.º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior

serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:

I – os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;

II – caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais;

§ 2.º Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:

I – as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;

II – os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;

III – se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;

IV – as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 3.º Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:

I – os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção da participação da pessoa jurídica no

capital da coligada;

II – os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa jurídica;

III – se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de encerramento da pessoa jurídica;

IV – a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações financeiras da coligada.

(...).

Vislumbra-se, assim, tratar-se de aplicação **normativa extraterritorial**, alcançando rendimentos obtidos em outros países, dentro dos estritos limites previstos em lei e desde que haja estrita observância aos **tratados internacionais**, que podem ensejar a inoccorrência de **bitributação sobre renda entre países signatários**.

2.3.2.3 Aspecto temporal

O efetivo **momento da ocorrência do fato gerador** deve levar em consideração o que se denomina **fato gerador complexivo**, uma vez que passa a ser constituído de um encadeamento de fatos continuados dentro de um lapso temporal, de modo que esse será o período definidor do regime de tributação. Assim, a partir do momento em que ocorre a obtenção de renda – considerada pelo CTN como sendo disponibilidade econômica ou jurídica – existem as retenções devidas.

No caso do imposto de renda incidente sobre a pessoa física (IRPF), considera-se ocorrido o fato gerador **em 31 de dezembro do ano-calendário**, tendo o contribuinte o prazo até 30 de abril do ano subsequente para verificação da existência de saldo a pagar e se há restituição ou não, devendo ocorrer os ajustes. Pode ocorrer de o contribuinte ter um saldo a pagar ou um saldo a restituir, dependendo dos ajustes que foram apresentados.

O **saldo a pagar do referido imposto** deverá ser pago até o **último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos**.

Tratando-se do **imposto de renda incidente sobre pessoa jurídica (IRPJ)**, a apuração poderá ser **trimestral** e, nos casos da pessoa jurídica que realize a opção de pagamento com base no **lucro real**, poderá ser **apurado anualmente**.

De acordo com as determinações constantes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o contribuinte, tratando-se de **pessoa física**, poderá apresentar sua declaração tanto via internet, de acordo com um programa próprio que poderá ser baixado pelo contribuinte. Inclusive, temos a possibilidade de aplicativo em smartphones (APPS) para que se possa enviar a declaração e acompanhar o seu processamento.

Caso haja apresentação em atraso, haverá a aplicação de multa pelo atraso da entrega da declaração, tendo um valor mínimo estabelecido – podendo ser alterado a cada exercício – **alcançando o montante máximo de 20% (vinte por cento) do imposto de renda devido**.

2.3.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** do imposto sobre a renda é a **União**, sendo o ente federado competente para a sua instituição. Entretanto, teremos situações excepcionais de **retenção na fonte (IRRF)**, em que a sujeição ativa poderá ser dos **Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**.

Isso ocorre quando do **pagamento dos vencimentos dos servidores públicos**, uma vez que esses entes federativos, na condição de pessoas jurídicas de direito público interno, terão o dever legal de retenção, no entanto, permanecendo com a totalidade do produto arrecadado, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da CF.

O **sujeito passivo** passa a ser determinado no Código Tributário Nacional e nas demais legislações extravagantes. Dispõe o art. 45 do CTN:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto

cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

a) Contribuinte do IRPF

O contribuinte do IRPF são **as pessoas físicas que percebem rendimentos tributáveis**, de acordo com a determinação legal.

Estabelece o Decreto 9.580/2018, nos arts. 1º e 2º:

Art. 1º As pessoas físicas que perceberem renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto sobre a renda, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1º; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43 e art. 45; Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2º; Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4º; e Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 3º, parágrafo único).

§ 1º São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a legislação em vigor (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43 e art. 45).

§ 2º As pessoas físicas residentes no exterior terão suas rendas e seus proventos de qualquer natureza, inclusive os ganhos de capital, percebidos no País tributados de acordo com as disposições contidas nos Capítulos V e VI do Título I do Livro III.

Art. 2º O imposto sobre a renda será devido à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos, observado o disposto no art. 78 (Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 2º).

Caso a **pessoa física receba rendimentos de uma pessoa jurídica**, caberá à

pessoa jurídica a realização da retenção dos valores devidos na fonte, conforme estabelece a legislação aplicável (art. 7.º, II, da Lei 7.713/1988). Caso o **recebimento seja realizado entre pessoas físicas**, competirá **àquele que percebeu os rendimentos** o pagamento dos valores devidos a título de IR pelo denominado **carnê-leão**.

b) Contribuinte do IRPJ

São considerados contribuintes do IRPJ todas as **peçoas jurídicas e empresas individuais**, conforme determinado pela legislação aplicável.

Vale analisar o disposto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018) sobre a determinação do contribuinte do IRPJ:

Art. 158. São contribuintes do imposto sobre a renda e terão seus lucros apurados de acordo com este Regulamento (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27):

I - as pessoas jurídicas, a que se refere o Capítulo I deste Título; e

II - as empresas individuais, a que se refere o Capítulo II deste Título.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se independentemente de a pessoa jurídica estar regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27, § 2º; e Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 126, caput, inciso III).

§ 2º As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência ficam sujeitas às normas de incidência do imposto aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo (Lei nº 9.430, de 1996, art. 60).

§ 3º As empresas públicas e as sociedades de economia mista, e as suas subsidiárias, são contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas (Constituição, art. 173, § 2º; e Lei nº

6.264, de 18 de novembro de 1975, art. 1º e art. 2º).

§ 4º As sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores ficam sujeitas às mesmas normas de incidência do imposto sobre a renda aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei nº 9.532, de 1997, art. 69).

§ 5º Fica sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento imobiliário nas condições previstas no art. 831 (Lei nº 9.779, de 1999, art. 2º).

§ 6º Exceto se houver disposição em contrário, a expressão pessoa jurídica, quando empregada neste Regulamento, compreende todos os contribuintes a que se refere este artigo.

A legislação atribui a incidência do IRPJ mesmo quando **equiparadas** para este fim, como ocorre nos casos dos **comitentes domiciliados no exterior** e das **sociedades em conta de participação**.

2.3.2.5 Aspecto quantitativo

O imposto sobre a renda será **calculado de acordo com a tributação incidente**, se **decorrente de pessoa física** ou de **pessoa jurídica**.

A base de cálculo do IRPF é o **rendimento bruto**, sendo considerado todo produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões que são percebidas em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (art. 3.º da Lei 7.713/1988).

Mesmo havendo a determinação da incidência sobre os rendimentos brutos auferidos, a **lei autoriza as deduções sobre a base de cálculo**, tais como a saúde e a educação, sendo que as despesas com saúde não apresentam limites para fins de dedução.

Todos os limites e os gastos que podem sofrer dedução da base de cálculo do IRPF estão determinados na legislação atualizada.

Nos termos do art. 35 do Decreto 9.580/2018, temos os **rendimentos isentos e**

não tributáveis, assim como o disposto no art. 66 do referido decreto determinará quais as possíveis **deduções a serem aplicadas sobre a base de cálculo do imposto**.

Uma vez que o imposto sobre a renda é um **imposto pessoal** e se rege, dentre outros critérios, pela **progressividade**, temos a determinação de uma **tabela progressiva** que deve ser observada para fins do cálculo, possuindo as seguintes faixas de alíquotas: 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

Nos termos do art. 122, VI, do Decreto 9.580/2018, para os meses de abril a dezembro do ano-calendário de 2015, a base de cálculo seguirá a seguinte tabela:

Base de cálculo em reais	Alíquota	Parcela a deduzir
Até 1.903,98	–	–
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5%	142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15%	354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5%	636,13
Acima de 4.664,68	27,5%	869,36

Todas as possibilidades de **deduções da base de cálculo** serão determinadas diretamente por lei.

De uma forma bem didática, podemos destacar algumas das principais deduções possíveis:

- 1) deduções com contribuições previdenciárias (art. 67 do RIR);
- 2) despesas escrituradas no livro-caixa (art. 68 do RIR);

3) despesas com informatização pelos titulares de serventias notariais e registrais (art. 70 do RIR);

4) deduções com dependentes e pensão alimentícia (art. 71 e 72 do RIR);

5) despesas médicas (art. 73 do RIR), dentre outras.

Dentre as deduções existentes, as únicas que não possuem limites são as **despesas com a saúde**, englobando-se os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

O denominado **ganho de capital**, quando auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, não será tributado, quando o preço unitário de alienação, no mês em que for realizada, for **igual ou inferior a R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), na hipótese de alienação de ações negociadas no mercado de balcão, e de **R\$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais) nas demais hipóteses, assim como na alienação de um único imóvel que o titular possua cujo valor de alienação seja de até **R\$ 440.000,00** (quatrocentos e quarenta mil reais), desde que não tenha sido realizada outra alienação nos **últimos 5** (cinco) **anos**, nos termos e nas condições estabelecidas em lei.

A **base de cálculo do IRPJ** é o **montante real, presumido ou arbitrado** do lucro. A regra geral é a apuração pelo **lucro real**, sendo que o contribuinte poderá optar pela apuração pelo **lucro presumido**.

A apuração pelo chamado **lucro arbitrado** corre em **caráter excepcional**, quando a pessoa jurídica **deixa de cumprir**, de maneira correta, **as obrigações acessórias** ou realiza alguma **conduta fraudulenta** com o intuito de burlar a Fazenda Pública.

Existem, entretanto, situações que **obrigam a pessoa jurídica a ser tributada pelo lucro real**. Vemos isso na determinação legal esposada no art. 14 da Lei 9.718/1998:

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:

I – cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;

- II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;
- III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
- IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;
- V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2.º da Lei 9.430, de 1996;
- VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
- VII – que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio.

Tal apuração depende que a pessoa jurídica se utilize de **maiores rigores e formalidades**, mediante observância da **totalidade da receita auferida**, possibilitando as **deduções e realizando**, ao **final**, o **cálculo devido**.

Para pessoas jurídicas que tenham **grandes gastos operacionais**, trata-se da **melhor forma de apuração**, salvo, é claro, nos casos em que essa apuração é determinada pela lei.

A **alíquota** é de **15%**, podendo possuir um **adicional de 10%** sobre o **montante do lucro real que supere, no mês, R\$ 20.000,00, totalizando um percentual de**

25%.

Já nos casos de **lucro presumido**, determina a lei no art. 13 e parágrafos:

Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou a R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.

§ 1.º A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário.

§2.º Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou de caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido.

Denomina-se **base de cálculo presumida** porque a obtenção do lucro da pessoa jurídica **poderá ser maior ou menor que o percentual da receita** apontado pela lei.

O art. 15 da Lei 9.249/1995 estabelece como deve ser realizado o **cálculo para pagamento do IRPJ incidente sobre o lucro presumido**:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995:

§ 1.º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

I – um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;

II – dezesseis por cento:

a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 29 da referida Lei;

III – trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

b) intermediação de negócios;

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramentos de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público.

§ 2.º No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.

§ 3.º As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.

§ 4.º O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.

Já o **lucro arbitrado** ocorrerá, conforme dito, em **situações onde decorre o descumprimento**, por parte da pessoa jurídica, **das determinações legais constantes**, fazendo com que a **pessoa jurídica pague determinado valor arbitrado diretamente pela autoridade fazendária**, nas hipóteses autorizadas por lei. É o que determina o art. 51 da Lei 8.981/1995:

Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo:

I – 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último período em que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais, atualizado monetariamente;

II – 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado

monetariamente;

III – 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive a sua correção monetária contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade, atualizado monetariamente;

IV – 0,05 (cinco centésimos) do valor do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;

V – 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;

VI – 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;

VII – 0,8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados;

VIII – 0,9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido.

§ 1.º As alternativas previstas nos incisos V, VI e VII, a critério da autoridade lançadora, poderão ter sua aplicação limitada, respectivamente, às atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços e, no caso de empresas com atividade mista, ser adotados isoladamente em cada atividade.

§ 2.º Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I, quando o lucro real for decorrente de período-base anual, o valor que servirá de base ao arbitramento será proporcional ao número de meses do período-base considerado.

§ 3.º Para cálculo da atualização monetária a que se referem os incisos deste artigo, serão adotados os índices utilizados para fins de correção monetária das demonstrações financeiras, tomando-se como termo inicial a data do encerramento do período-base utilizado, e, como termo final, o mês a que se referir o

arbitramento.

§ 4.º Nas alternativas previstas nos incisos V e VI do caput, as compras são consideradas pelos valores totais das operações, devendo ser incluídos os valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do art. 184 da Lei 6.404, de 1976.

Destaca-se, ainda, o fato de o IR **não se sujeitar completamente ao princípio da anterioridade**, uma vez que, caso haja o **aumento da sua alíquota**, determina o legislador que deverá ocorrer apenas a **observância da anterioridade comum ou de exercício** (art. 150, III, *b*, CF/1988), não se aplicando a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, *c*, CF/1988). Assim, caso o imposto tenha sua alíquota aumentada em dezembro de determinado exercício, poderá ser exigido o valor majorado a partir de janeiro do próximo exercício.

JURISPRUDÊNCIA

- “Incide IRPJ – Apurado pelo regime de lucro real ou presumido – e CSLL sobre os valores referentes à restituição ou à compensação de indébito tributário se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL. De fato, o art. 53 da Lei 9.430/1996 dispõe que ‘Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado’. Tendo em vista o referido dispositivo, o art. 1.º do Ato Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal 25/2003 assim disciplinou: ‘Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL’. A interpretação literal do art. 1.º do ADI SRF 25/2003 poderia levar à

conclusão de que os valores recuperados, correspondentes a despesas deduzidas anteriormente da receita do contribuinte, somente poderiam ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, mas não ao lucro real. Todavia, como a regra de adições e exclusões, para a definição da base de cálculo do IRPJ, é típica do regime de apuração pelo lucro real, infere-se que o espírito do legislador foi tão somente positivar a possibilidade de adicionar, mesmo na sistemática do lucro presumido ou do lucro arbitrado, os valores ressarcidos ao contribuinte. Acrescente-se que a quantia eventualmente recuperada de despesas, tributárias ou não, que em dado exercício foram excluídas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, configura acréscimo patrimonial, de modo que o valor restituído deve ser adicionado à referida base no período de apuração em que ele se tornar disponível. Logo, independentemente da previsão contida no art. 53 da Lei 9.430/1996, que apenas explicita que o raciocínio é válido para os casos de tributação pelo lucro presumido ou arbitrado, é da própria hipótese de incidência do imposto de renda (arts. 43, II, e 44 do CTN) que decorre a exigência do tributo. O mesmo raciocínio se aplica ao fato de o art. 53 da Lei 9.430/1996 não constar do rol do art. 28 da mesma lei como passível de aplicação à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL, haja vista a existência de outras ‘normas da legislação vigente’ que possibilitam a incidência da exação. Agregue-se dentro da ótica de que para fins de incidência tributária a regra é que o acessório segue a sorte do principal, que a Primeira Seção do STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC [art. 1.036 do CPC/2015], no sentido de que os ‘juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17 do Decreto-lei 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373 do Decreto 3.000/99 – RIR/99, assim como o art. 9.º, § 2.º, do Decreto-lei 1.381/74, e art. 161, IV, do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais’ (REsp 1.138.695/SC, 1.ª Seção, DJe 31.05.2013). Nesse contexto, firmada a orientação de que os juros incidentes na repetição do indébito tributário se incluem na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, deduz-se que a verba principal não foge à tributação” (rel. Min. Humberto Martins, j. 12.05.2015, DJe 19.05.2015).

→ **“É possível reter na fonte, na forma dos arts. 64 da Lei 9.430/1996 e 34 da Lei 10.833/2003, o IRPJ, a CSLL, a contribuição para o PIS/PASEP e Cofins, quando do pagamento de contrato de fretamento de aeronave pela administração pública federal.** Da análise do art. 133 da Lei 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), verifica-se que o contrato de fretamento ocorre quando uma das partes, chamada fretador, obriga-se para com a outra, chamada afretador, mediante o pagamento do frete por este, a realizar uma ou mais viagens preestabelecidas ou durante certo período de tempo, reservando-se ao fretador o controle sobre a tripulação e a condução técnica da aeronave. O referido dispositivo legal ressalta a existência de reserva de controle técnico sobre o bem móvel objeto do contrato em questão, fato que remete o contrato a uma natureza mais próxima do conceito de prestação de serviços do que do conceito de mera locação de bem móvel. Sendo assim, não se deve aplicar os precedentes do STF no sentido de que os contratos de locação de bem móvel não se submetem à tributação a título de ISS por não serem prestação de serviços ou locação de serviços (Súmula Vinculante 31 do STF) É que o contrato em questão (fretamento de aeronave) possui em seu bojo indubitável prestação de serviços. Outrossim, também está embutida no contrato de fretamento a locação do bem móvel (aeronave), que constitui em si o fornecimento do bem, além da prestação de serviços efetivada pela tripulação, pelo que não há como a atividade escapar à hipótese de incidência descrita no art. 64 da Lei 9.430/1996 e no art. 34 da Lei 10.833/2003, que estabelecem a técnica de arrecadação de retenção na fonte quando da realização dos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações, bem como empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades de que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto. Com efeito, devido à essa natureza híbrida do contrato de fretamento de aeronave, se as situações individualmente consideradas, relativamente ao fornecimento de bem, locação de bem móvel ou prestação de serviço já ensejariam a retenção dos tributos na fonte, tanto mais deve ensejar a retenção na fonte a hipótese em questão, que possui mais de uma situação ensejadora de sua incidência. Por fim, de registrar que, ainda que não houvesse a arrecadação pela técnica de antecipação mediante retenção na fonte, a empresa continuaria a se submeter à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, posto q praticante dos respectivos fatos geradores, atrelados à aferição de lucro real, lucro líquido ajustado, e receita ou faturamento, respectivamente” (rel. Min.

Mauro Campbell Marques, j. 28.04.2015, *DJe* 07.05.2015).

- **“São isentos do imposto de renda os proventos percebidos de fundo de previdência privada a título de complementação da aposentadoria por pessoa física acometida de uma das doenças arroladas no art. 6.º, XIV, da Lei 7.713/1988.** Isso porque a isenção do imposto de renda prevista no art. 6.º, XIV, da Lei 7.713/1988 – da qual faz jus pessoa física portadora de doença grave arrolada nesse inciso que receba proventos de aposentadoria ou reforma – engloba benefício complementar pago por entidade de previdência privada. É preciso ressaltar que o regime da previdência privada é facultativo e baseia-se na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da CF e da exegese do art. 1.º da LC 109/2001. Assim o capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria – ainda que intitulada de complementar –, possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da CF (REsp 1.121.719-SP, Segunda Seção, *DJe* 04.04.2014), o que legitima a isenção sobre a parcela complementar. Além disso, o caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999), que estabelece a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria no § 6.º do seu art. 39: ‘As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação da aposentadoria, reforma ou pensão’. Ademais, conforme a doutrina, ‘os planos previdenciários privados têm por ponto principal permitir uma continuidade no padrão de vida da pessoa, numa fase madura da vida’. Nesse sentido, a isenção concedida aos portadores de doença grave consubstancia benefício fiscal que visa abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um ‘padrão de vida’ o mais digno possível diante do estado de enfermidade. Precedente citado: REsp 1.204.516/PR, 2.ª T., *DJe* 23.11.2010” (rel. Min. Humberto Martins, j. 10.02.2015, *DJe* 20.02.2015).
- **“Até a data da retenção na fonte, a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado para tanto é o Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas**

(FACDT). Essa sistemática não implica violação do art. 13 da Lei 9.065/1995, do art. 61, § 3.º, da Lei 9.430/1996, dos arts. 8.º, I, e 39, § 4.º, da Lei 9.250/1995, uma vez que se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apuradas pelo regime de competência e pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte, seja do Fisco. Ressalte-se que a taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida” (rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.12.2014, *DJe* 18.12.2014).

- **“Mesmo que a fonte pagadora (substituta tributária) equivocadamente tenha deixado de efetuar a retenção de determinada quantia, a título de imposto de renda, sobre importância paga a empregado, tendo, ainda, expedido comprovante de rendimentos informando que a respectiva renda classifica-se como rendimento isento e não tributável, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária (substituído tributário) deverá arcar com o imposto de renda devido e não recolhido.** Isso porque o STJ tem entendimento pacífico de que o contribuinte substituído, que realiza o fato gerador, é quem efetivamente tem o dever de arcar com o ônus da tributação, que não é afastado pela responsabilidade pessoal do substituto tributário. Precedentes citados: REsp 962.610-RS, 2.ª T., *DJ* 07.02.2008; e AgRg no REsp 716.970/CE, 1.ª T., *DJ* 29.08.2005” (rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.09.2014).
- **“Incide imposto de renda sobre a quantia recebida pelo empregado em razão de acordo coletivo de trabalho firmado com o empregador, no qual fora ajustado a constituição de fundo de aposentadoria e pensão e, alternativamente, o pagamento de determinado valor em dinheiro correspondente ao que seria vertido para o aludido fundo.** Isso porque os valores recebidos pelo empregado, em razão da não perfectibilização do fundo de aposentadoria e pensão, possuem natureza jurídica de acréscimo patrimonial, a ensejar incidência do imposto de renda. Precedentes citados: REsp 996.341/RS, 1.ª T., *DJe* 26.06.2008; e REsp 1.058.771/RS, 2.ª T., *DJe* 31.08.2009” (rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.09.2014).
- **“Na hipótese em que a fonte pagadora deixa de efetuar a retenção do imposto de renda, expedindo comprovante de rendimentos o qual os classifica como isentos e não tributáveis, de modo a induzir o**

empregado/contribuinte a preencher equivocadamente sua declaração de imposto de renda, não é este – mas sim o empregador – o responsável pelo pagamento da multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996. De fato, eximir o contribuinte da multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996 (art. 957, I, do Decreto 3.000/1999 – multa de 75% sobre o valor não recolhido) sempre que não houver a intenção de omitir os valores devidos é excessivamente permissivo e faz tábula rasa ao disposto no art. 136 do CTN, uma vez que, segundo a dicção legal, a omissão dos valores na declaração de imposto de renda enseja a responsabilização objetiva do contribuinte. No entanto, na hipótese em foco, há situação específica em que não houve a omissão dos valores tributáveis na declaração; mas, sim, o registro desses valores como rendimentos isentos e não tributáveis, em razão da informação equivocada fornecida pela fonte pagadora/empregador. Nesse passo, o art. 722 do Decreto 3.000/1999 fixa a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora pelo recolhimento da multa aplicada de ofício e dos juros de mora, quando não há recolhimento do tributo devido, mas o rendimento se encontrar incluído na declaração de imposto de renda do contribuinte. Desse modo, a fonte pagadora/empregador deve ser responsabilizada diretamente pela multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996, liberando-se o contribuinte, por ter sido induzido a erro, da referida responsabilidade. Precedentes citados: REsp 374.603/SC, Primeira Turma, *DJ* 25.05.2006; e REsp 383.309/SC, Segunda Turma, *DJ* 07.04.2006” (rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.09.2014).

- “Imposto de renda. Contribuinte pessoa física. Impossibilidade de o Judiciário atuando como legislador positivo, estabelecer, de modo inovador, mediante utilização de critério próprio, índice de correção monetária da tabela progressiva de incidência do tributo” (ARE 986.252 AgR, rel. Min. Celso de Mello, *DJE* 21.02.2017, j. 9-12-2016, 2ª T.).
- “Imposto de renda. Balanço patrimonial. Atualização. OTN. Artigos 30 da Lei 7.730/89 e 30 da Lei 7.799/89. Mostra-se inconstitucional a atualização prevista no artigo 30 da Lei 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resulta na incidência do Imposto de Renda sobre lucro fictício” (RE 215.811, rel. Min. Marco Aurélio, P., *DJE* 30.10.2014, j. 20.11.2013, com repercussão geral).
- “O valor pago a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL

não perde a característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária. É constitucional o art. 1º e parágrafo único da Lei 9.316/1996, que proíbe a dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas” (RE 582.525, rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJE* 07.02.2014, j. 09.05.2013, P., com repercussão geral).

- “Conforme jurisprudência reiterada deste STF, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do Imposto de Renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo” (AI 643.905 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.05.2013, 1ª T *DJE* 06.06.2013).
- “Imposto de renda. (...) O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido. A Lei 8.981/1995 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum” (AI 479.672 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.05.2010, 2ª T., *DJE* 21.05.2010).

2.4 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

2.4.1 Previsão legislativa

O imposto sobre produtos industrializados tem sua previsão no art. 153, IV, § 3.º, da CF/1988.

Os arts. 46 a 51 do CTN versam sobre as normas gerais aplicáveis, sendo regulado, inicialmente, pela Lei 4.502/1964, com suas alterações posteriores.

O Decreto 7.212/2010 versa sobre o Regulamento do IPI (RIPI), passando determinar a forma de cobrança, arrecadação e administração do referido imposto.

A Tabela de incidência do IPI (TIPI), determinando o montante de alíquotas:

aplicáveis a qualquer espécie de produto, vem sedimentada pelas alterações do Decreto 8.950/2016.

2.4.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.4.2.1 Aspecto material

A incidência do IPI recai sobre a **industrialização do produto**. Neste caso, não basta que se esteja cuidando, pura e simples, do produto *in natura*, sendo necessário que o produto tenha sido industrializado por alguma das partes na operação.

Por essa razão, a jurisprudência, notadamente do STJ e STF, tem se posicionado no sentido da **não incidência do IPI na venda do produto pelo comerciante ao consumidor**, uma vez que nenhum deles realiza o processo de industrialização.

A determinação das **operações de industrialização** vem disciplinada no art. 3.º, parágrafo único, da Lei 4.502/1964:

Art. 3.º (...)

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo:

I – o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros;

II – o acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto;

III – O preparo de medicamentos officinais ou magistrais, manipulados em farmácias, para venda no varejo, diretamente e ao consumidor, assim como a montagem de óculos, mediante receita médica.

IV – a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática

ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas interdependentes, controladora, controlada ou coligadas. (sic)

De uma forma mais especificada, determina o **Regulamento do IPI** (Decreto 7.212/2010), a partir do seu art. 3.º:

Art. 3.º Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.

Art. 4.º Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

I – a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova (transformação);

II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);

III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);

IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou

V – a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação

como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

O próprio Regulamento do IPI determina situações em que **não haverá incidência do IPI**, conforme reza o art. 5.º do Decreto 7.212/2010:

Art. 5.º Não se considera industrialização:

I – o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de apresentação:

a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se destinem a venda direta a consumidor; ou

b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a pessoas jurídicas e a outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes;

II – o preparo de refrigerantes, à base de extrato concentrado, por meio de máquinas, automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos similares, para venda direta a consumidor;

III – a confecção ou preparo de produto de artesanato, definido no art. 7.º;

IV – a confecção de vestuário, por encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou na residência do confeccionador;

V – o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional;

VI – a manipulação em farmácia, para venda direta a

consumidor, de medicamentos officinais e magistrais, mediante receita médica;

VII – a moagem de café torrado, realizada por estabelecimento comercial varejista como atividade acessória;

VIII – a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte:

a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas coberturas);

b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e centrais telefônicas ou outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações, usinas e redes de distribuição de energia elétrica e semelhantes; ou

c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo;

IX – a montagem de óculos, mediante receita médica;

X – o acondicionamento de produtos classificados nos Capítulos 16 a 22 da TIPI, adquiridos de terceiros, em embalagens confeccionadas sob a forma de cestas de natal e semelhantes;

XI – o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos casos em que se destinem ao uso da própria empresa executora ou quando essas operações sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de tais produtos, bem como o preparo, pelo consertador, restaurador ou recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente naquelas operações;

XII – o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;

XIII – a restauração de sacos usados, executada por processo rudimentar, ainda que com emprego de máquinas de costura;

XIV – a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento comercial varejista, efetuada por máquina automática ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas interdependentes, controladora, controlada ou coligadas; e

XV – a operação de que resultem os produtos relacionados na Subposição 2401.20 da TIPI, quando exercida por produtor rural pessoa física.

Parágrafo único. O disposto no inciso VIII não exclui a incidência do imposto sobre os produtos, partes ou peças utilizados nas operações nele referidas.

A CF/1988 determina que o IPI é um **imposto seletivo**, ou seja, admite-se uma **tributação diferenciada** conforme a qualidade do objeto a ser tributado. Trata-se de uma imposição constitucional, estabelecida no art. 153, § 3.º, I, do texto maior.

A **seletividade** é vinculada diretamente à **essencialidade do produto ao consumo**. Assim, **quanto mais essencial o produto for considerado para o consumo, menor sua alíquota**; do contrário, uma vez que o **produto é considerado supérfluo**, poderá ter suas **alíquotas maiores**, sem que isso se configure confisco.

Quem determinará qual produto é considerado mais essencial que o outro é o próprio legislador, uma vez que a determinação da essencialidade por cada contribuinte possui um caráter estritamente subjetivo. Assim, o que pode ser considerado essencial para uns, pode ser considerado supérfluo para outros.

Em determinados casos, a **essencialidade não é revelada pela natureza do produto**, mas, sim, pela sua **finalidade**. Pode ainda ocorrer situações em que **não se revela a análise da essencialidade do produto diretamente**, mas seu **caráter de extrafiscalidade**, visando **inibir a produção de determinados bens de consumo**. É o que ocorre com o cigarro, em que a alíquota é superior a 300% incidente sobre o produto.

Da mesma forma que o IPI rege-se pela seletividade, deverá ser **não cumulativo**, conforme estabelece o art. 153, § 3.º, II, da CF/1988:

Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

A principal finalidade da não cumulatividade é de se evitar o efeito em cascata do tributo, onerando demasiadamente o consumidor final e, conseqüentemente, afetando o produtor com a diminuição do consumo do produto.

Apesar de se considerar uma garantia constitucional, **não se considera uma cláusula pétrea pela própria determinação do STF**, conforme esposado na ADI 939.

A não cumulatividade admite a possibilidade de **gerar ao industrial o creditamento**, por exemplo, **quando da aquisição de matéria-prima ou de qualquer produto intermediário**. Assim, uma vez que tais bens serão incorporados ao produto final acabado, o industrial **poderá se creditar na saída do produto do estabelecimento, abatendo o crédito escritural devido**.

Estabelece o art. 225, § 1.º, do Decreto 7.212/2010:

Art. 225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei 5.172, de 1966, art. 49).

§ 1.º O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados.
(...).

A forma como se dará o **creditamento** decorrente da não cumulatividade também observa os dispositivos constantes no Regulamento do IPI, a partir do art. 226:

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se:

I – do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

II – do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;

III – do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;

IV – do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê direito ao crédito;

V – do imposto pago no desembaraço aduaneiro;

VI – do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador;

VII – do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a industrial;

VIII – do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não compreendidos nos incisos V a VII;

IX – do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão quando descumprida a condição, em

operação que dê direito ao crédito; e

X – do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.

Mesmo pela observância do disposto no Regulamento do IPI, **nem toda entrada que diz respeito ao funcionamento da atividade industrial gera a possibilidade de creditamento**. Exemplifica Leandro Paulsen, citando precedentes do STF, que a aquisição de bens que **integram o ativo fixo permanente da empresa** que não se incorpora ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização **não gera direito ao creditamento do IPI**.

Nos casos em que **não há incidência do referido imposto, não se pode cogitar da possibilidade de qualquer espécie de creditamento**, uma vez que inexistente transferência do ônus fiscal pois a primeira operação não foi tributada.



Importante

No mês de abril de 2019, o STF negou provimento aos Recursos Extraordinários 592.891 (com repercussão geral reconhecida) e 596.614, para admitir a utilização de créditos de IPI na entrada de matérias-primas e insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.

A tese firmada adotou o seguinte posicionamento: há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do artigo 43, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal, combinada com o comando do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Segundo a corrente vencedora, o direito ao creditamento no âmbito da Zona Franca de Manaus está previsto na Constituição

Federal e na legislação tributária infraconstitucional e representa exceção à regra geral com a finalidade de neutralizar as desigualdades em prol do desenvolvimento do país, do fortalecimento da federação e da soberania nacional. Segundo os ministros, o artigo 40 do ADCT, ao constitucionalizar a Zona Franca de Manaus, promoveu o princípio da igualdade por meio da redução das desigualdades regionais.

No que diz respeito à incidência de IPI na importação, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial de que a **não cumulatividade impediria a própria incidência do IPI na importação, quando o importador não ostentasse a condição de contribuinte do imposto, não podendo dele creditar-se, nem tampouco repassá-lo em operação futura.** É o que acontece quando da importação de produtos industrializados pelo particular.

Tal manifestação é adotada pelo STF, gerando certas discussões no STJ, que entende a possibilidade de incidência de IPI mesmo que o importador não seja industrial, neste caso, o próprio particular.

A Primeira Seção do STJ, em 25.02.2015, sob o regime dos recursos repetitivos consolidou jurisprudência no sentido de que não incide IPI sobre veículo importado para uso próprio, tendo em vista que o fato gerador do referido tributo é a operação de natureza mercantil ou assemelhada e, ainda, por aplicação do princípio da não cumulatividade.

No âmbito do STF, o Plenário não havia apreciado a questão a fundo, existiam apenas julgamentos da Primeira e da Segunda Turma, referentes a agravos regimentais, que consolidaram o entendimento no sentido de não incidência do IPI na importação de veículo automotor por pessoa física, que seja importador não habitual, para consumo próprio, ante a limitação constitucional ao poder de tributar imposta pelo princípio da não-cumulatividade.

Todavia, em 12.04.2013, o Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão versada no Recurso Extraordinário 723.651/PR interposto por um cidadão com o objetivo de reformar julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e, assim, ver reconhecido o direito de que pessoa natural que não atua na compra e venda de automóveis, importando veículo para o uso próprio, não está sujeito à incidência do IPI.

O STF, em 04.02.2016, por maioria, apreciando o tema da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio (RE 723651, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04.02.2016).

Assim, quando se trata de importação de veículo automotor por pessoa natural para consumo próprio, analisando o disposto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional sobre o IPI, estão presentes todas as características da relação jurídico-tributária, a saber: o importador (sujeito passivo/contribuinte do imposto), o desembaraço aduaneiro (fato gerador) e o veículo automotor (produto industrializado).

Na importação de produto industrializado (veículo automotor) no exterior, para consumo próprio, há uma única exação do IPI. Destarte, não havendo operações posteriores passíveis de tributação, não há que falar em princípio da não cumulatividade.

A incidência do IPI em virtude de importação de veículo automotor para uso próprio está em consonância com a finalidade extrafiscal do tributo, com o princípio da isonomia e com a livre concorrência, pois coloca a produção nacional em igualdade com a estrangeira.

Importante ressaltar uma situação específica com relação ao microempresário (ME) e o empresário de pequeno porte (EPP), quando optantes pelo **Simples Nacional**. Não há possibilidade de utilização dos créditos para fins de compensação por disposição constante no art. 23 da LC 123/2006:

As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

Na mesma esteira, determinam os arts. 177 e 178 do Regulamento do IPI (Decreto 7.212/2010):

Art. 177. A microempresa e empresa de pequeno porte contribuinte do imposto, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional e que atenda ao disposto na Lei Complementar 123, de 2006, deverá recolher o imposto mensalmente em conjunto com os demais impostos e contribuições, nos termos especificados na referida Lei Complementar.

Parágrafo único. O recolhimento do imposto na forma do caput não exclui a incidência do imposto devido no desembaraço aduaneiro dos produtos de procedência estrangeira.

Art. 178. Às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, é vedada:

I – a apropriação e a transferência de créditos relativos ao imposto; e

II – a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal.

Por determinação expressa na CF/1988, o IPI possui uma **imunidade específica**, conforme reza o art. 153, § 3.º, III: “Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior”.

Uma vez que o produto industrializado foi destinado ao exterior, não há incidência de IPI como forma de incentivo às exportações e pelo fato de não se poder transferir ao exterior encargos tributários que existem apenas internamente.

2.4.2.2 Aspecto espacial

Inexiste dispositivo legal que determine efetivamente onde se determinará o aspecto espacial do IPI. Para tanto, e se tratando de um imposto federal, adota-se, de praxe, o critério da **territorialidade**, sendo considerado **devido o recolhimento em qualquer local do território nacional em que ocorrer a efetiva operação de industrialização**, seja na **saída do estabelecimento industrial**, seja no **desembaraço aduaneiro** ou na **importação de produtos industrializados**.

2.4.2.3 Aspecto temporal

Para determinação do **momento em que ocorre o fato gerador**, levamos em consideração o disposto no Regulamento do IPI (Decreto 7.212/2010), a partir do art 36:

Art. 36. Considera-se ocorrido o fato gerador:

I – na entrega ao comprador, quanto aos produtos vendidos por intermédio de ambulantes;

II – na saída de armazém-geral ou outro depositário do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial depositante, quanto aos produtos entregues diretamente a outro estabelecimento;

III – na saída da repartição que promoveu o desembaraço aduaneiro, quanto aos produtos que, por ordem do importador, forem remetidos diretamente a terceiros;

IV – na saída do estabelecimento industrial diretamente para estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, por ordem do encomendante, quanto aos produtos mandados industrializar por encomenda;

V – na saída de bens de produção dos associados para as suas cooperativas, equiparadas, por opção, a estabelecimento industrial;

VI – no quarto dia da data da emissão da respectiva nota fiscal, quanto aos produtos que até o dia anterior não tiverem deixado o estabelecimento do contribuinte;

VII – no momento em que ficar concluída a operação industrial, quando a industrialização se der no próprio local de consumo ou de utilização do produto, fora do estabelecimento industrial;

VIII – no início do consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, em finalidade diferente da que lhe é prevista na imunidade de que trata o inciso I do art.

18, ou na saída do fabricante, do importador ou de seus estabelecimentos distribuidores, para pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras;

IX – na aquisição ou, se a venda tiver sido feita antes de concluída a operação industrial, na conclusão desta, quanto aos produtos que, antes de sair do estabelecimento que os tenha industrializado por encomenda, sejam por este adquiridos;

X – na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial, quando da ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no inciso VII do art. 25;

XI – no momento da sua venda, quanto aos produtos objeto de operação de venda que forem consumidos ou utilizados dentro do estabelecimento industrial;

XII – na saída simbólica de álcool das usinas produtoras para as suas cooperativas, equiparadas, por opção, a estabelecimento industrial; e

XIII – na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria no recinto alfandegado, antes de aplicada a pena de perdimento, quando as mercadorias importadas forem consideradas abandonadas pelo decurso do referido prazo.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso VII, considera-se concluída a operação industrial e ocorrido o fato gerador na data da entrega do produto ao adquirente ou na data em que se iniciar o seu consumo ou a sua utilização, se anterior à formalização da entrega.

Na mesma esteira, temos no mesmo Regulamento a determinação da **inocorrência do fato gerador**. Assim, dispõe do art. 38 do Decreto 7.212/2010:

Art. 38. Não constituem fato gerador:

I – o desembaraço aduaneiro de produto nacional que retorne ao

Brasil, nos seguintes casos:

- a) quando enviado em consignação para o exterior e não vendido nos prazos autorizados;
- b) por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo ou substituição;
- c) em virtude de modificações na sistemática de importação do país importador;
- d) por motivo de guerra ou calamidade pública; e
- e) por quaisquer outros fatores alheios à vontade do exportador;

II – as saídas de produtos subsequentes à primeira:

- a) nos casos de locação ou arrendamento, salvo se o produto tiver sido submetido a nova industrialização; ou
- b) quando se tratar de bens do ativo permanente, industrializados ou importados pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, destinados à execução de serviços pela própria firma remetente;

III – a saída de produtos incorporados ao ativo permanente, após cinco anos de sua incorporação, pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que os tenha industrializado ou importado; ou

IV – a saída de produtos por motivo de mudança de endereço do estabelecimento.

2.4.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** do imposto sobre produtos industrializados é a **União**, vez que o imposto é de competência federal. A fiscalização do imposto competirá à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Para determinação do **sujeito passivo**, temos as indicações legais de quem pode figurar como **contribuinte** e quem pode figurar como **responsável**.

Reza o art. 51 do CTN:

Art. 51. Contribuinte do imposto é:

I – o importador ou quem a lei a ele equiparar;

II – o industrial ou quem a lei a ele equiparar;

III – o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;

IV – o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.

O Regulamento do IPI (Decreto 7.212/2010) também determina, em seu bojo quem figura na **condição de contribuinte**, a partir do art. 24:

Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:

I – o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira;

II – o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar;

III – o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar; e

IV – os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso I do art. 18.

Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de ato que praticar.

O **responsável tributário** sempre será uma terceira pessoa indicada pela lei para assunção de um encargo tributário, bastando que haja nexo de causalidade com a ocorrência do fato gerador.

Tal responsabilidade poderá ser subsidiária ou solidária, por substituição ou transferência. Ainda, temos as determinações legais atribuindo responsabilidade no caso do cometimento de infrações.

A partir do art. 25 do Decreto 7.212/2010 temos a indicação de **diversas formas de responsabilidade**, abarcando desde a **responsabilidade subsidiária** até a **responsabilidade por infrações**, senão vejamos:

Art. 25. São obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis:

I – o transportador, em relação aos produtos tributados que transportar, desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência;

II – o possuidor ou detentor, em relação aos produtos tributados que possuir ou mantiver para fins de venda ou industrialização, nas mesmas condições do inciso I;

III – o estabelecimento adquirente de produtos usados cuja origem não possa ser comprovada pela falta de marcação, se exigível, de documento fiscal próprio ou do documento a que se refere o art. 372;

IV – o proprietário, o possuidor, o transportador ou qualquer outro detentor de produtos nacionais, do Capítulo 22 e do Código 2402.20.00 da TIPI, saídos do estabelecimento industrial com imunidade ou suspensão do imposto, para exportação, encontrados no País em situação diversa, salvo se em trânsito, quando:

a) destinados a uso ou consumo de bordo, em embarcações ou aeronaves de tráfego internacional, com pagamento em moeda conversível;

b) destinados a lojas francas, em operação de venda direta, nos termos e condições estabelecidos pelo art. 15 do Decreto-lei 1.455, de 7 de abril de 1976;

c) adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, e remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da adquirente; ou

d) remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação;

V – os estabelecimentos que possuírem produtos tributados ou isentos, sujeitos a serem rotulados ou marcados, ou, ainda, ao selo de controle, quando não estiverem rotulados, marcados ou selados;

VI – os que desatenderem as normas e requisitos a que estiver condicionada a imunidade, a isenção ou a suspensão do imposto;

VII – a empresa comercial exportadora, em relação ao imposto que deixou de ser pago, na saída do estabelecimento industrial, referente aos produtos por ela adquiridos com o fim específico de exportação, nas hipóteses em que:

a) tenha transcorrido cento e oitenta dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação;

b) os produtos forem revendidos no mercado interno; ou

c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos;

VIII – a pessoa física ou jurídica que não seja empresa jornalística ou editora, em cuja posse for encontrado o papel, destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere o inciso I do art. 18;

IX – o estabelecimento comercial atacadista de produtos sujeitos ao regime de que trata a Lei 7.798, de 1989, que possuir ou mantiver produtos desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência, ou que deles der saída;

X – o estabelecimento industrial, relativamente à parcela do imposto devida pelos estabelecimentos equiparados de que tratam os incisos XI e XII do art. 9.º, quanto aos produtos a estes fornecidos, na hipótese de aplicação do regime de que trata o art. 222;

XI – o estabelecimento comercial referido no inciso XIII do art. 9.º, pelo imposto devido pelos estabelecimentos equiparados na forma dos incisos XI e XII daquele artigo, quanto aos produtos a estes fornecidos, na hipótese de aplicação do regime de que trata o art. 222; e

XII – o estabelecimento importador, relativamente à parcela do imposto devida pelos estabelecimentos equiparados de que tratam os incisos XIV e XV do art. 9.º, quanto aos produtos a estes fornecidos, na hipótese de aplicação do regime de que trata o art. 222.

§ 1.º Nos casos dos incisos I e II não se exclui a responsabilidade por infração do contribuinte quando este for identificado.

§ 2.º Na hipótese dos incisos X, XI e XII, o imposto será devido pelo estabelecimento industrial ou encomendante ou importador no momento em que derem saída aos produtos sujeitos ao imposto conforme o regime de que trata o art. 222.

Art. 26. É ainda responsável, por substituição, o industrial ou equiparado a industrial, mediante requerimento, em relação às operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 27. São solidariamente responsáveis:

- I – o contribuinte substituído, na hipótese do art. 26, pelo pagamento do imposto em relação ao qual estiver sendo substituído, no caso de inadimplência do contribuinte substituto;
- II – o adquirente ou cessionário de mercadoria importada beneficiada com isenção ou redução do imposto pelo seu pagamento e dos acréscimos legais;
- III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, pelo pagamento do imposto e acréscimos legais;
- IV – o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora, na operação a que se refere o § 3.º do art. 9.º, pelo pagamento do imposto e acréscimos legais;
- V – o estabelecimento industrial de produtos classificados no Código 2402.20.00 da TIPI, com a empresa comercial exportadora, na hipótese de operação de venda com o fim específico de exportação, pelo pagamento do imposto e dos respectivos acréscimos legais, devidos em decorrência da não efetivação da exportação;
- VI – o encomendante de produtos sujeitos ao regime de que trata a Lei 7.798, de 1989, com o estabelecimento industrial executor da encomenda, pelo cumprimento da obrigação principal e acréscimos legais;
- VII – o beneficiário de regime aduaneiro suspensivo do imposto, destinado à industrialização para exportação, pelas obrigações tributárias decorrentes da admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas na execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado; e
- VIII – o encomendante dos produtos sujeitos ao imposto

conforme os regimes de tributação de que tratam os arts. 222 e 223 com o estabelecimento industrial executor da encomenda, pelo imposto devido nas formas estabelecidas nos mesmos artigos.

§ 1.º Aplica-se à operação de que trata o inciso III o disposto no § 2.º do art. 9.º.

§ 2.º O disposto no inciso V aplica-se também aos produtos destinados a uso ou consumo de bordo, em embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, inclusive por meio de ship's chandler.

Art. 28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal (Decreto-lei 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8.º).

Art. 29. São solidariamente responsáveis os curadores quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão da isenção de que trata o inciso IV do art. 55.

Art. 30. Na hipótese dos incisos III e IV do art. 27, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira responde conjunta ou isoladamente pela infração.

A lei, doutrina e jurisprudência claramente distinguem a figura do **contribuinte de fato** do **contribuinte de direito**.

O denominado **contribuinte de direito** é o **sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com fato gerador**, nos termos do art. 121, parágrafo único, I, do CTN. Na cadeia tributária, é quem recolhe o tributo ao Fisco.

O **contribuinte de fato**, por sua vez, é quem suporta o ônus econômico do tributo, ou seja, a quem a carga do tributo indireto é repassada, normalmente o **consumidor final**. **Tributos indiretos** são aqueles que **comportam transferência do encargo**

financeiro.

A caracterização do chamado **contribuinte de fato** tem função didática e apenas explica a **sistemática da tributação indireta**, não se prestando a **conceder legitimidade para que o contribuinte de fato ingresse em juízo com vistas a discutir determinada relação jurídica da qual não faça parte.**

Tratando-se de tributos indiretos – aqueles que comportam transferência do encargo financeiro – a norma impõe que a **restituição somente se faça ao contribuinte que houver arcado com o referido encargo** ou que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido.

Assim, o **contribuinte de fato não detém legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores pagos a título de tributo indireto** recolhido pelo contribuinte de direito, por não integrar a relação jurídica tributária pertinente.

2.4.2.5 Aspecto quantitativo

Para determinação da **base de cálculo**, levamos em consideração o disposto no art. 47 do CTN:

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

I – no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20, acrescido do montante:

- a) do imposto sobre a importação;
- b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;
- c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;

II – no caso do inciso II do artigo anterior:

- a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
- b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III – no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação.

Tratando-se de **importação de produtos industrializados**, a **base de cálculo** a ser considerada é o **preço CIF da mercadoria**, ou seja, o **preço do produto em condições de livre concorrência para a entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país**, com a **inclusão dos custos de frete e seguro**, inclusive com o montante do imposto de importação e determinados encargos cambiais.

Nas **operações internas**, o **preço da operação** será a **base de cálculo**. Não é possível excluir da base de cálculo o valor pago a título de **ICMS**, uma vez que este é **calculado por dentro do preço do produto**. Assim, não há como excluir da base de cálculo do IPI o valor do ICMS.

Nos casos de **juros e correção monetária decorrentes da venda financiada dos produtos**, não podem ser incluídos na **base de cálculo do IPI**, uma vez que **não fazem parte do processo de industrialização e produção**.

A **s alíquotas**, conforme já estudadas, são **seletivas**, tendo por base a **essencialidade do produto para o consumo**.

2.4.2.6 Demais características

O imposto sobre produtos industrializados passa a ser utilizado, pelo Governo Federal, tanto como meio **arrecadatário de receitas** (tributação fiscal) quanto como um **mecanismo de regulação econômica** (tributação extrafiscal).

Tendo a característica marcante de tributo extrafiscal nas situações autorizadas por lei, o **princípio da legalidade resta mitigado**, uma vez que suas **alíquotas podem ser alteradas por meio de atos do Poder Executivo**. Assim, o Poder Executivo, normalmente por meio de Decreto, poderá **aumentar ou reduzir as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados**, desde que haja estrita observância da lei. Não poderá o Poder Executivo aumentar acima do limite máximo ou reduzir abaixo do limite mínimo estabelecido em lei, configurando-se exorbitância do Poder Regulamentar conferido pela CF/1988.

Caso o Poder Executivo exorbite os limites estabelecidos em decorrência do Poder Regulamentar, caberá ao Congresso Nacional a sustação dos atos normativos, nos termos do art. 49, V, da CF/1988.

De igual modo, teremos uma **mitigação do princípio da anterioridade tributária**, uma vez que o referido imposto poderá ser exigido observando-se o **prazo mínimo de 90 dias** após a publicação da lei, quando esta aumentar ou reduzir as suas alíquotas, conforme estabelece o art. 150, § 1.º, da CF/1988.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 494 do STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Súmula 495 do STJ: A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a creditamento de IPI.

- “(...) não há violação do dever fundamental de prestação de serviços de saúde. O princípio da seletividade impõe que o Poder Público gradue a carga tributária conforme a essencialidade da operação ou do produto. Isto não significa haver imunidade, ainda que as operações ou os bens sejam essenciais ao ser humano. Em especial há que ser considerado o princípio da capacidade contributiva, da concorrência e da livre iniciativa, considerado o postulado da solidariedade no custeio das atividades estatais” (RE 429.306, voto do rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 01.02.2011, 2ª T., *DJE* 16.03.2011).
- **“A isenção de IPI para aquisição de automóvel por pessoa com necessidades especiais (art. 1.º, IV, da Lei 8.989/1995) poderá ser novamente concedida antes do término do prazo de 2 anos contado da aquisição (art. 2.º) se o veículo vier a ser roubado durante esse período.** De acordo com o art. 2.º da Lei 8.989/1995, ‘a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI de que trata o art. 1.º desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos’. Esse dispositivo, entretanto, deve ser interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, primando pela inclusão das pessoas com necessidades especiais e não restringindo seu acesso. Com efeito, a orientação do STJ é que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais (REsp 567.873-MG, 1.ª T., DJ 25.02.2004). Assim cabe, na situação em análise, afastar a limitação temporal do art. 2.º. da Lei 8.989/1995, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em razão de motivo de força maior” (STJ, REsp 1.390.345/RS, j. 24.03.2015, rel. Mir Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 07.04.2015).

- “Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio” (RE 723651, rel. Min. Marco Aurélio Tribunal Pleno, j. 04.02.2016, processo eletrônico *DJe*-164, divulg. 04.08.2016, public. 05.08.2016).
- **“Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final” (RE 723.651, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04.02.2016, *DJE* 05.08.2016, com repercussão geral).**
- “Juros na venda financiada: não podem ser incluídos na base de cálculo do IPI (AgRg no Ag 703431).
- “Aquisição de bens que integram o ativo fixo da empresa: inexistência do direito de crédito” (RE 352.856, 2011).
- “Aquisição de energia elétrica combustíveis e lubrificantes: inexistência de creditamento” (RE 603.502, 2011).
- “Aquisição de produtos com alíquota zero: inexistência de creditamento” (RE 566.819, 2011).
- “*Leasing* internacional: incidência de IPI” (REsp 11367713, 2011).
- “Pagamento Indevido: não reconhecimento da legitimidade do contribuinte de fato (adquirente de produto com incidência de IPI)” (REsp 960984, 2011).
- “A elevada alíquota do IPI caracteriza-o, no setor da indústria do tabaco, como tributo dessa categoria, com a nítida função de desestímulo por indução na economia. E isso não pode deixar de interferir na decisão estratégica de cada empresa de produzir ou não produzir cigarros. É que, determinada a produzi-lo, deve a indústria submeter-se, é óbvio, às exigências normativas oponíveis a todos os participantes do setor, entre as quais a regularidade fiscal constitui requisito necessário, menos à concessão do que à preservação do registro especial, sem o qual a produção de cigarros é vedada e ilícita” (AC 1.657 MC, rel. p/ o ac. Min. Cezar Peluso, j. 27.06.2007, P, *DJ* 31.08.2007).
- “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da

correção monetária” (RE 299.605 AgR-ED-EDv, rel. Min. Edson Fachir Tribunal Pleno, j. 06.04.2016, *DJE* 20.06.2016, com repercussão geral).

- “O regime de apuração e de escrituração de tributos ‘Simples’ diminui a carga tributária bruta e a complexidade das obrigações acessórias. Em compensação, nega o direito ao aproveitamento de créditos relativos ao IPI” (RE 523.416 AgR, voto do rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18.10.2011, 2ª T. *DJE* 04.11.2011).
- “(...) o Plenário, ao julgar os RE 353.657-5/PR e RE 370.682-9/SC relativamente à aquisição de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, sufragou o entendimento de que o direito ao crédito pressupõe recolhimento anterior do tributo, cobrança implementada pelo Fisco. (...) o raciocínio desenvolvido é próprio tanto no caso de insumo sujeito à alíquota zero ou não tributado, quanto no de insumo isento, tema não apreciado nos mencionados precedentes. Inexiste dado específico a conduzir ao tratamento diferenciado, permitindo-se o creditamento relativamente à isenção, em que também não se recolhe o tributo, e não se admitindo no tocante à alíquota zero e à não-tributação” (RE 566.819, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2010, *DJE* 10.02.2011).
- “O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa. Com o advento do art. 11 da Lei 9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero” (RE 475.551, rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia Tribunal Pleno, j. 06.05.2009, *DJE* 13.11.2009).
- “A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte, o direito de creditar-se do valor do IPI, quando pago em razão de operações de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabelecimento” (RE 593.772 ED, rel. Min. Celso de

Mello, j. 24.03.2009, 2ª T., *DJE* 30.04.2009).

→ “IPI. Açúcar de Cana. Lei 8.393/1991 (art. 2º). Isenção fiscal. Critério espacial. Aplicabilidade. Exclusão de benefício. Alegada ofensa ao princípio da isonomia. Inocorrência. Norma legal destituída de conteúdo arbitrário. Atuação do judiciário como legislador positivo. Inadmissibilidade. Recurso improvido. Concessão de isenção tributária e utilização extrafiscal do IPI. (...) O postulado constitucional da isonomia. A questão da igualdade na lei e da igualdade perante a lei (RTJ 136/444-445, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello) (...) Isenção tributária: reserva constitucional de lei em sentido formal e postulado da separação de poderes” (AI 360.461 AgR, rel. Min. Celso de Mello, j. 06.12.2005, 2ª T., *DJE* 28.03.2008).

2.5 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DECORRENTES DE CRÉDITO, CÂMBIO, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)

2.5.1 Previsão legislativa

O Imposto sobre Operações decorrentes de crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários (IOF) tem previsão expressa a partir do art. 153, V, da CF/1988.

No § 5.º do mesmo artigo, temos a determinação de uma **incidência única e do estabelecimento de alíquota mínima relativamente ao ouro**, quando este for considerado **ativo financeiro** ou **instrumento de política cambial**.

As normas gerais relativas ao imposto estão previstas entre os arts. 63 a 67 do CTN.

O diploma instituidor do referido imposto é a Lei 5.143/1966, com as alterações posteriores, sendo o Decreto 6.306/2007 o instrumento normativo que regulamenta o IOF.

2.5.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.5.2.1 Aspecto material

O IOF é um imposto federal que possui quatro fatos que desencadeiam sua

incidência: **operações de crédito, câmbio, seguros, títulos ou valores mobiliários.**

Devemos ter em mente que a incidência recai sobre as **operações** decorrentes dessas atividades. Entende-se por **operação** todo ato ou negócio jurídico em que ocorre a transmissão de direitos.

Segundo ensina Hugo de Brito Machado, diz-se **operação de crédito** quando o operador se obriga a prestação futura, concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a solvabilidade do devedor inspira.

Não se pode determinar que o mero saque ocorrido em conta poupança seja considerado operação de crédito. Assim, cumpriu ao STF sumular a matéria, conforme vemos na Súmula 664:

É inconstitucional o inc. V do art. 1.º da Lei 8.033/1990, que instituiu a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguros – IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança.

O **saque em conta poupança** não possui qualquer espécie de **promessa de prestação futura** para que possa se caracterizar como operação de crédito, uma vez que não se reveste de propriedade circulatória.

De igual modo, a concessão de **fiança onerosa** não gera a incidência do IOF, uma vez que **fiança não se caracteriza como qualquer operação de crédito, câmbio ou seguros**, mas se trata de uma obrigação acessória, uma vez que o fiador não disponibiliza o crédito para quaisquer das operações.

Um dos itens importantes a serem discutidos é o fato de se **incidir ou não o IOF sobre operações de factoring**, regido pela Lei 9.532/1997.

Entende-se por **factoring** a **prestação contínua e cumulativa de assessoria mercadológica e creditícia, seleção de riscos, gestão de crédito**, acompanhamento de contas a receber, assessoria para compra de matéria-prima, organização da contabilidade, controle do fluxo de caixa, orçamento de custos entre outros **serviços conjugados com a aquisição de créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços das empresas clientes, realizadas a prazo**. Na prática destaca-se a atividade de negociação de direitos creditórios com deságio.

Reza o art. 58 da Lei 9.532/1997:

Art. 58. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa que

exercer as atividades relacionadas na alínea 'd' do inciso III do § 1.º do artigo 15 da Lei n. 9.249, de 1995 (factoring), direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, sujeita-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF às mesmas alíquotas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições financeiras.

§ 1.º O responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a empresa de factoring adquirente do direito creditório.

§ 2.º O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

O Min. Sepúlveda Pertence, apesar da incidência declarada do IOF sobre as operações de *factoring*, trouxe importante excerto sobre o tema:

“Com efeito, na operação de *factoring* o negócio mercantil consiste na **compra do faturamento**. Os títulos são adquiridos sem que remanesçam, em favor do adquirente, direito de regresso contra o sacador ou garantias inerentes ao endosso ou aval. Já na **operação financeira**, quer os títulos **permaneçam em caução em mãos da instituição bancária para garantia do empréstimo concedido**, quer sejam objeto de desconto, permanece a instituição com direito de regresso ou com as garantias decorrentes do aval e do endosso contra o sacador do título, que continua responsável pela liquidação do empréstimo tomado.

Equiparar as instituições de *factoring* a instituições financeiras é o mesmo que equiparar a estas o comerciante que vende a prazo seus produtos, de vez que é na condição deste que a operadora de *factoring* se investe, ao adquirir o faturamento assumindo os riscos daí inerentes.

Sendo, portanto, **nítido que a atividade de *factoring* não ostenta a mesma natureza das atividades financeiras que compõem a materialidade do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)** nos termos definidos no art. 153, V, da CF, a instituição desse imposto sobre as operações praticadas no exercício dessa atividade agride direta e ostensivamente o referido preceito constitucional.

No que se diz respeito ao IOF incidente sobre **câmbio**, temos a determinação estabelecida no art. 63, II, do CTN:

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:

(...)

II – quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este.

Câmbio é a operação de **troca de moeda de um país pela moeda de outro país**. Por exemplo, quando um turista brasileiro vai viajar para o exterior e precisa de moeda estrangeira, o agente autorizado pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio recebe do turista brasileiro a moeda nacional e lhe entrega (vende) a moeda estrangeira. Já quando um turista estrangeiro quer converter moeda estrangeira em reais, o agente autorizado a operar no mercado de câmbio compra a moeda estrangeira do turista estrangeiro, entregando-lhe os reais correspondentes.

O aspecto material do IOF nas operações de **deseuro** vem estabelecido no art. 63, III, do CTN:

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos

e valores mobiliários tem como fato gerador:

(...)

III – quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável.

Entende-se por **seguro** como todo o contrato por meio do qual **uma das partes** (denominado segurador) **se obriga a indenizar a outra** (denominado segurado) em **caso de ocorrência de um determinado evento** (sinistro), em troca de um **recebimento de um prêmio de seguro**.

Conforme estabelece o Decreto 6.306/2007, as **operações de seguro** compreendem os **seguros de vida e congêneres, seguros de acidentes pessoais e do trabalho, seguros de bens, valores, coisas**, bem como de outros itens não especificados na norma.

E, por fim, o **aspecto material do IOF** incidente sobre **títulos e valores mobiliários** vem determinado no art. 63, IV, do CTN:

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:

(...)

IV – quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.

Temos por **valores mobiliários** documentos emitidos por **empresas ou outras entidades**, sejam **públicas ou privadas**, representativos de um conjunto de direitos e deveres aos seus titulares e que podem ser comprados e vendidos nos mercados de valores mobiliários.

Para as entidades que os emitem, os **valores mobiliários** representam uma **forma de alternativa de investimento**, enquanto para os **investidores são uma forma de aplicação de poupanças** que se caracterizam por uma grande variedade de níveis de

risco e de potencialidade de rentabilidade.

Os referidos documentos que representam os **valores mobiliários** podem ser **títulos em papel** (valores mobiliários titulados) ou **registros informáticos** (valores mobiliários escriturais). Atualmente a grande maioria dos **valores mobiliários** está representada por valores mobiliários escriturais devido à sua maior facilidade de circulação e transação e devido à maior segurança que proporcionam.

2.5.2.2 Aspecto espacial

Vamos analisar o aspecto espacial do IOF incidente sobre o crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários:

a) **Crédito**: nas **operações de crédito**, tributam-se todas as operações ocorridas no território nacional, **excluindo-se a incidência de IOF nas operações de crédito externo**;

b) **Câmbio**: nas **operações decorrentes de câmbio**, a incidência pode se dar tanto em território nacional como nos casos de **liquidação de contrato de câmbio que fora contratado no exterior**, conforme já pacificado pela jurisprudência;

c) **Seguros**: obrigam-se apenas a incidência de IOF sobre os **contratos de seguro firmados em território nacional**;

d) **Títulos e Valores Mobiliários**: uma vez que **inexiste qualquer cláusula que admita a extraterritorialidade**, a incidência compreenderá as operações ocorridas dentro do território nacional.

2.5.2.3 Aspecto temporal

Uma vez que o IOF possui várias **bases econômicas distintas**, vamos analisar o aspecto temporal de cada uma delas:

a) **Crédito**: reza o art. 3.º, § 1.º, do Decreto 6.306/2007:

Art. 3.º (...)

§ 1.º Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:

I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do

interessado;

II – no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;

III – na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a descoberto em conta de depósito;

IV – na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no exterior;

V – na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob a forma de abertura de crédito;

VI – na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7.º e 10 do art. 7.º;

VII – na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se enquadrem como operações de crédito.

§ 2.º O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7.º, não configura entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.

§ 3.º A expressão 'operações de crédito' compreende as operações de:

I – empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos;

II – alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo;

III – mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.

Admite-se pela jurisprudência, entretanto, a **incidência de IOF no momento da celebração do contrato de financiamento**, uma vez que este vincula a vontade das partes (precedentes do STJ).

b) **Câmbio**: estabelece o art. 11 do Decreto 6.306/2007:

Art. 11. O fato gerador do IOF é a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este.

Parágrafo único. Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato da liquidação da operação de câmbio.

c) **Seguros**: estabelece o art. 18 do Decreto 6.306/2007:

Art. 18. O fato gerador do IOF é o recebimento do prêmio.

§ 1.º A expressão 'operações de seguro' compreende seguros de vida e congêneres, seguro de acidentes pessoais e do trabalho, seguros de bens, valores, coisas e outros não especificados.

§ 2.º Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato do recebimento total ou parcial do prêmio.

d) **Títulos e valores mobiliários**: conforme reza o art. 25 do Decreto 6.306/2007, temos várias operações no mercado de capitais que identificam a ocorrência do fato gerador:

Art. 25. O fato gerador do IOF é a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários.

§ 1.º Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato da realização das operações de que trata este artigo.

§ 2.º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer operação, independentemente da qualidade ou da forma jurídica de constituição do beneficiário da operação ou do seu titular, estando abrangidos, entre outros, fundos de investimentos e carteiras de títulos e valores mobiliários, fundos ou programas, ainda que sem personalidade jurídica, e entidades de previdência privada.

Discute-se sobre a incidência de IOF sobre **criptomoedas**. As **criptomoedas** são uma forma de moeda virtual descentralizada que se utiliza da criptografia para manter sua segurança. A primeira das criptomoedas foi a Bitcoin, idealizada em 2008 por Satoshi Nakamoto, e é tida como a grande responsável pela criação do sistema bancário livre.

Em linhas gerais, a **bitcoin** se utiliza de um sistema “**peer-to-peer**”, no qual as **informações são distribuídas diretamente entre os membros da rede**, sem depender de um terceiro. O bitcoin foi revolucionário ao criar um sistema conhecido como “**blockchain**” (cadeia de blocos, em inglês).

O sistema da cadeia de blocos é um **banco de dados aberto**, o que permite o **acesso por qualquer pessoa**, e funciona como um **livro-razão da contabilidade**.

Para superar a necessidade de um terceiro validando as operações, o bitcoin criou a figura dos chamados **mineradores**, responsáveis pela **validação das transações**.

Os chamados **mineradores** nada mais são que **computadores que disputam entre si a resolução de problemas matemáticos complexos** para transformar os nodes em blocos e adicioná-los na cadeia de blocos, e, como recompensa, recebem uma quantidade de bitcoins.

A quantidade de bitcoins recebidos como recompensa pela mineração é reduzida pela **metade em marcos temporais pré-estabelecidos**, com a finalidade de controlar a entrada de bitcoins no mercado e a consequente inflação da moeda. Atualmente são recebidos como recompensa **12.5 bitcoins por cada bloco validado**, no entanto, em **2020, esse valor será reduzido para 6.5 e depois disso haverá a redução de 4 em 4 anos até 2140**, momento no qual deverá existir **21 milhões de bitcoins em circulação**.

Foi a existência de uma moeda segura e anônima que possibilitou o surgimento

dos famosos **mercados negros da internet**. São locais da “**deepweb**” onde são comercializadas uma **variedade de produtos ilegais**.

Em uma análise de **direito comparado**, é evidente a existência de uma **bifurcação**: por um lado, países como os **Estados Unidos e Canadá** adotam uma **postura mais conservadora** e classificam as **criptomoedas como uma propriedade**, por outro lado, **Alemanha e Japão optaram por classificar o bitcoin como dinheiro privado**.

Caso as criptomoedas sejam classificadas como **patrimônio**, estarão sujeitas à **incidência do IOF-Título**, desde que sejam enquadradas juridicamente como um **ativo mobiliário**, ou, ao menos, equiparem-se a este. Por sua vez, caso as criptomoedas sejam classificadas como forma de pagamento, elas poderão estar sujeitas ao IOF-Câmbio.

Veja que **não há similaridade** entre o **conceito jurídico de câmbio**, definido pelo direito bancário brasileiro, e o **conceito de forma de pagamento**, especialmente como proposto no direito comparado internacional. **Câmbio** é sempre entendido como a **troca entre moedas estrangeiras**, ao passo que a conceituação como **forma de pagamento** implica em **reconhecer a característica *sui generis* das criptomoedas** e sujeitá-las ao direito bancário sem, entretanto, reconhecê-las como uma **moeda de fato**.

Nesse caso, o fato gerador do tributo perfar-se-ia no **ato da liquidação da operação de entrega de moeda nacional ou estrangeira**, ou de **documento que a represente**, ou sua **colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue** ou posta à disposição por este, em conformidade com os arts. 63 do CTN e 11 do Decreto 6.306/2007.

2.5.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** do IOF incidente nas operações de crédito, câmbio, seguros, títulos ou valores mobiliários será a **União**. A administração, arrecadação e fiscalização permanecem a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Já a **sujeição passiva** estabelece **contribuintes e responsáveis** em cada uma das operações descritas na hipótese de incidência. Assim, analisaremos o disposto para cada uma das operações:

a) **Crédito**: nas operações decorrentes de crédito, estabelecem os arts. 4.º e 5.º do Decreto 6.306/2007 a figura dos **contribuintes e responsáveis**:

Art. 4.º Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito.

Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física ou jurídica.

Art. 5.º São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I – as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito;

II – as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da alínea 'b' do inciso I do art. 2.º;

III – a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.

b) **Câmbio**: nas operações decorrentes de câmbio, estabelecem os arts. 12 e 13 a figura dos respectivos **contribuintes** e **responsáveis** do IOF.

Art. 12. São contribuintes do IOF os compradores ou vendedores de moeda estrangeira nas operações referentes às transferências financeiras para o ou do exterior, respectivamente.

Parágrafo único. As transferências financeiras compreendem os pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, independentemente da forma de entrega e da natureza das operações.

Art. 13. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio.

c) **Seguros**: os arts. 19 e 20 do Decreto 6.306/2007 identificam a figura do **contribuinte** e **responsável** nas operações decorrentes de seguros.

Art. 19. Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas seguradas.

Art. 20. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as seguradoras ou as instituições financeiras a quem estas encarregarem da cobrança do prêmio.

Parágrafo único. A seguradora é responsável pelos dados constantes da documentação remetida para cobrança.

d) **Títulos e Valores Mobiliários:** os arts. 26 e 27 do Decreto 6.306/2007 estabelecem as figuras do **contribuinte** e **responsáveis** nas operações decorrentes do mercado de títulos e valores mobiliários.

Art. 26. Contribuintes do IOF são:

I – os adquirentes, no caso de aquisição de títulos ou valores mobiliários, e os titulares de aplicações financeiras, nos casos de resgate, cessão ou repactuação;

II – as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na hipótese prevista no inciso IV do art. 28.

Art. 27. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I – as instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários;

II – as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, em relação às aplicações financeiras realizadas em seu nome, por conta de terceiros e tendo por objeto recursos destes;

III – a instituição que liquidar a operação perante o beneficiário final, no caso de operação realizada por meio do SELIC ou da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos –

CETIP;

IV – o administrador do fundo de investimento;

V – a instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição, na forma prevista em normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional;

VI – a instituição que receber as importâncias referentes à subscrição das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário e do Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes.

§ 1.º Na hipótese do inciso II do caput, ficam as entidades ali relacionadas obrigadas a apresentar à instituição financeira declaração de que estão operando por conta de terceiros e com recursos destes.

§ 2.º Para efeito do disposto no inciso VI do caput, a instituição intermediadora dos recursos deverá:

I – manter sistema de registro e controle, em meio magnético, que permita a identificação, a qualquer tempo, de cada cliente e dos elementos necessários à apuração do imposto por ele devido;

II – fornecer à instituição administradora do fundo de investimento, individualizados por código de cliente, os valores das aplicações, resgates e imposto cobrado;

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações decorrentes da responsabilidade pela cobrança do imposto.

§ 3.º No caso das operações a que se refere o § 1.º do art. 32-A, a responsabilidade tributária será do custo diante das ações cedidas.

§ 4.º No caso de ofertas públicas a que se refere o § 2.º do art. 32-A, a responsabilidade tributária será do coordenador líder da oferta.

A observância do aspecto pessoal à luz do Regulamento do IOF é a utilizada pela regra geral, sendo encampada pelo STF em todas as suas acepções.

2.5.2.5 Aspecto quantitativo

O aspecto quantitativo passa a ser identificado pela **base de cálculo e alíquotas**.

No que diz respeito ao IOF, temos a identificação de **bases econômicas distintas para cada situação jurídica definida em lei**. Assim, definiremos, pelos aspectos legais, as respectivas **bases de cálculo e alíquotas** nas operações decorrentes de crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários.

a) **Crédito**: os arts. 6.º e 7.º definem as alíquotas e base de cálculo aplicáveis ao IOF incidente sobre crédito:

Art. 6.º O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia sobre o valor das operações de crédito.

Art. 7.º A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:

I – na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:

a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;

2. mutuário pessoa física: 0,0082%;

b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;

II – na operação de desconto, inclusive na de alienação a empresas de factoring de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, a base de cálculo é o valor líquido obtido:

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

b) mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;

III – no adiantamento a depositante, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês:

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;

b) mutuário pessoa física: 0,0082%;

IV – nos empréstimos, inclusive sob a forma de financiamento, sujeitos à liberação de recursos em parcelas, ainda que o pagamento seja parcelado, a base de cálculo é o valor do principal de cada liberação:

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

b) mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;

V – nos excessos de limite, ainda que o contrato esteja vencido:

a) quando não ficar expressamente definido o valor do principal a ser utilizado, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o valor dos excessos computados no somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;

2. mutuário pessoa física: 0,0082%;

b) quando ficar expressamente definido o valor do principal a ser utilizado, a base de cálculo é o valor de cada excesso, apurado diariamente, resultante de novos valores entregues ao interessado, não se considerando como tais os débitos de encargos:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;

VI – nas operações referidas nos incisos I a V, quando se tratar de mutuário pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, em que o valor seja igual ou inferior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), observado o disposto no art. 45, inciso II: 0,00137% ou 0,00137% ao dia, conforme o caso;

VII – nas operações de financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja pessoa física: 0,0082% ao dia.

§ 1.º O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado.

§ 2.º No caso de operação de crédito não liquidada no vencimento, cuja tributação não tenha atingido a limitação prevista no § 1.º, a exigência do IOF fica suspensa entre a data do vencimento original da obrigação e a da sua liquidação ou a data em que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no § 7.º.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º, será cobrado o IOF complementar, relativamente ao período em que ficou suspensa a exigência, mediante a aplicação da mesma alíquota sobre o valor não liquidado da obrigação vencida, até atingir a limitação prevista no § 1.º.

§ 4.º O valor líquido a que se refere o inciso II deste artigo corresponde ao valor nominal do título ou do direito creditório, deduzidos os juros cobrados antecipadamente.

§ 5.º No caso de adiantamento concedido sobre cheque em

depósito, a tributação será feita na forma estabelecida para desconto de títulos, observado o disposto no inciso XXII do art. 8.º.

§ 6.º No caso de cheque admitido em depósito e devolvido por insuficiência de fundos, a base de cálculo do IOF será igual ao valor a descoberto, verificado na respectiva conta, pelo seu débito, na forma estabelecida para o adiantamento a depositante.

§ 7.º Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente tributada, sendo essa tributação considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da operação inicial.

§ 8.º No caso do § 7.º, se a base de cálculo original for o somatório mensal dos saldos devedores diários, a base de cálculo será o valor renegociado na operação, com exclusão da parte amortizada na data do negócio.

§ 9.º Sem exclusão da cobrança do IOF prevista no § 7.º, havendo entrega ou colocação de novos valores à disposição do interessado, esses constituirão nova base de cálculo.

§ 10. No caso de novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados de operação de crédito em que haja substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor renegociado na operação.

§ 11. Nos casos dos §§ 8.º, 9.º e 10, a alíquota aplicável é a que estiver em vigor na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida ou negócio assemelhado.

§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório dos saldos devedores diários.

§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.

§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco.

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica.

§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea 'a' do inciso I, o inciso III, e a alínea 'a' do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15.

§ 17. Nas negociações de que trata o § 7.º não se aplica a alíquota adicional de que trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à disposição do interessado.

§ 18. No caso de operação de crédito cuja base de cálculo seja apurada por somatório dos saldos devedores diários, constatada a inadimplência do tomador, a cobrança do IOF apurado a partir do último dia do mês subsequente ao da constatação de inadimplência dar-se-á na data da liquidação total ou parcial da operação ou da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no § 7.º.

§ 19. Na hipótese do § 18, por ocasião da liquidação total ou parcial da operação ou da ocorrência de qualquer das hipóteses

previstas no § 7.º, o IOF será cobrado mediante a aplicação das alíquotas previstas nos itens 1 ou 2 da alínea 'a' do inciso I do caput, vigentes na data de ocorrência de cada saldo devedor diário, até atingir a limitação de trezentos e sessenta e cinco dias.

O diploma regulamentador do IOF (Decreto 6.306/2007) traz ainda importantes informações sobre a **aplicabilidade da alíquota zero**, demonstrando, assim, a sua **diferença ante as isenções**. Assim, **não se pode confundir alíquota zero e isenção**, por serem institutos diversos, **apesar do idêntico efeito prático**.

b) **Câmbio**: os arts. 14 e 15 do Decreto 6.306/2007, com alterações de decretos normativos de 2010 e 2011, trazem as informações sobre a **base de cálculo e alíquotas nas operações de câmbio**:

Art. 14. A base de cálculo do IOF é o montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição, correspondente ao valor, em moeda estrangeira, da operação de câmbio.

Art. 15. A alíquota máxima do IOF é de vinte e cinco por cento.

Art. 15-A. (revogado).

Art. 15-B. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento, observadas as seguintes exceções:

I – nas operações de câmbio relativas ao ingresso no País de receitas de exportação de bens e serviços: zero;

II – nas operações de câmbio de natureza interbancária entre instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional autorizadas a operar no mercado de câmbio e entre estas e instituições financeiras no exterior: zero;

III – nas operações de câmbio, de transferências do e para o exterior, relativas a aplicações de fundos de investimento no mercado internacional, nos limites e condições fixados pela

Comissão de Valores Mobiliários: zero;

IV – nas operações de câmbio realizadas por empresas de transporte aéreo internacional domiciliadas no exterior, para remessa de recursos originados de suas receitas locais: zero;

V – nas operações de câmbio relativas a ingresso de moeda estrangeira para cobertura de gastos efetuados no País com utilização de cartão de crédito emitido no exterior: zero;

VI – nas operações de câmbio realizadas para ingresso no País de doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras, de que trata a Lei 11.828, de 20 de novembro de 2008: zero;

VII – nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de crédito ou de débito ou de bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários, observado o disposto no inc. VIII: seis inteiros e trinta e oito centésimos por cento;

VIII – nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de crédito ou de débito ou de bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior quando forem usuários do cartão a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, suas fundações e autarquias: zero;

IX – nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de uso internacional ou de bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito ou de débito decorrentes de saques no exterior efetuado por seus usuários: seis inteiros e trinta e oito

centésimos por cento;

X – nas liquidações de operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: seis inteiros e trinta e oito centésimos por cento;

XI – nas liquidações de operações de câmbio de ingresso e saída de recursos no e do País, referentes a recursos captados a título de empréstimos e financiamentos externos, excetuadas as operações de que trata o inciso XII: zero;

XII – nas liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de até cento e oitenta dias: seis por cento;

XIII – nas liquidações de operações de câmbio para remessa de juros sobre o capital próprio e dividendos recebidos por investidor estrangeiro: zero;

XIV – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para constituição de margem de garantia, inicial ou adicional, exigida por bolsas de valores, de mercadorias e futuros: zero;

XV – nas liquidações de operações simultâneas de câmbio para ingresso no País de recursos através de cancelamento de Depositary Receipts – DR, para investimento em ações negociáveis em bolsa de valores: zero;

XVI – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para aplicação nos mercados

financeiro e de capitais: zero;

XVII – nas liquidações de operações de câmbio para fins de retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais: zero;

XVIII – na operação de compra de moeda estrangeira por instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, contratada simultaneamente com operação de venda, exclusivamente quando requerida em disposição regulamentar: zero.

§ 1.º No caso de operações de empréstimo em moeda via lançamento de títulos, com cláusula de antecipação de vencimento, parcial ou total, pelo credor ou pelo devedor (put/call), a primeira data prevista de exercício definirá a incidência do imposto prevista no inciso XII do caput.

§ 2.º Quando a operação de empréstimo for contratada pelo prazo médio mínimo superior ao exigido no inc. XII do caput e for liquidada antecipadamente, total ou parcialmente, descumprindo-se esse prazo mínimo, o contribuinte ficará sujeito ao pagamento do imposto calculado à alíquota estabelecida no inciso citado, acrescido de juros moratórios e multa, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e no art. 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995.

c) **Seguros:** os arts. 21 e 22 do Decreto 6.306/2007, com alterações recentes em 2012, trazem a **base de cálculo e as alíquotas nas operações decorrentes de seguros:**

Art. 21. A base de cálculo do IOF é o valor dos prêmios pagos.

Art. 22. A alíquota do IOF é de vinte e cinco por cento.

§ 1.º A alíquota do IOF fica reduzida:

I – a zero, nas seguintes operações:

- a) de resseguro;
- b) de seguro obrigatório, vinculado a financiamento de imóvel habitacional, realizado por agente do Sistema Financeiro de Habitação;
- c) de seguro de crédito à exportação e de transporte internacional de mercadorias;
- d) de seguro contratado no Brasil, referente à cobertura de riscos relativos ao lançamento e à operação dos satélites Brasilsat I e II;
- e) em que o valor dos prêmios seja destinado ao custeio dos planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência;
- f) de seguro aeronáutico e de seguro de responsabilidade civil pagos por transportador aéreo;
- g) de seguro garantia.

II – nas operações de seguro de vida e congêneres, de acidentes pessoais e do trabalho, incluídos os seguros obrigatórios de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não e excluídas aquelas de que trata a alínea 'f' do inciso I: trinta e oito centésimos por cento;

III – nas operações de seguros privados de assistência à saúde: dois inteiros e trinta e oito centésimos por cento;

IV – nas demais operações de seguro: sete inteiros e trinta e oito centésimos por cento.

§ 2.º O disposto na alínea 'f' do inciso I do § 1.º aplica-se somente a seguro contratado por companhia aérea que tenha por objeto principal o transporte remunerado de passageiros ou de cargas.

d) **Títulos e Valores Mobiliários:** entre os arts. 28 a 33 do Decreto 6.306/2007, temos as definições das **bases de cálculo e alíquotas** nas operações decorrentes junto

ao mercado de títulos e valores mobiliários, com recentes alterações em 2012:

Art. 28. A base de cálculo do IOF é o valor:

I – de aquisição, resgate, cessão ou repactuação de títulos e valores mobiliários;

II – da operação de financiamento realizada em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

III – de aquisição ou resgate de cotas de fundos de investimento e de clubes de investimento;

IV – do pagamento para a liquidação das operações referidas no inciso I, quando inferior a noventa e cinco por cento do valor inicial da operação.

§ 1.º Na hipótese do inciso IV, o valor do IOF está limitado à diferença positiva entre noventa e cinco por cento do valor inicial da operação e o correspondente valor de resgate ou cessão.

§ 2.º Serão acrescidos ao valor da cessão ou resgate de títulos e valores mobiliários os rendimentos periódicos recebidos, a qualquer título, pelo cedente ou aplicador, durante o período da operação.

§ 3.º O disposto nos incisos I e III abrange quaisquer operações consideradas como de renda fixa.

Art. 29. O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia sobre o valor das operações com títulos ou valores mobiliários.

Art. 30. Aplica-se a alíquota de que trata o art. 29 nas operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e de renda variável, efetuadas com recursos provenientes de aplicações feitas por investidores estrangeiros em cotas de Fundo de Investimento Imobiliário e de Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes, observados os seguintes limites:

I – quando referido fundo não for constituído ou não entrar em

funcionamento regular: dez por cento;

II – no caso de fundo já constituído e em funcionamento regular, até um ano da data do registro das cotas na Comissão de Valores Mobiliários: cinco por cento.

Art. 31. O IOF será cobrado à alíquota de zero vírgula cinco por cento ao dia sobre o valor de resgate de quotas de fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma, na hipótese de o investidor resgatar cotas antes de completado o prazo de carência para crédito dos rendimentos.

Parágrafo único. O IOF de que trata este artigo fica limitado à diferença entre o valor da cota, no dia do resgate, multiplicado pelo número de cotas resgatadas, deduzido o valor do imposto de renda, se houver, e o valor pago ou creditado ao cotista.

Art. 32. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela constante do Anexo.

§ 1.º O disposto neste artigo aplica-se:

I – às operações realizadas no mercado de renda fixa;

II – ao resgate de cotas de fundos de investimento e de clubes de investimento, ressalvado o disposto no inciso IV do § 2.º.

§ 2.º Ficam sujeitas à alíquota zero as operações:

I – de titularidade das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, excluída a administradora de consórcio de que trata a Lei 11.795, de 8 de outubro de 2008;

II – das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de investimento;

III – do mercado de renda variável, inclusive as realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e entidades assemelhadas;

IV – de resgate de cotas dos fundos e clubes de investimento em ações, assim considerados pela legislação do imposto de renda.

V – com Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, com Letra de Crédito do Agronegócio – LCA, e com Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA, criados pelo art. 23 da Lei 11.076, de 30 de dezembro de 2004; e

VI – com debêntures de que trata o art. 52 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com Certificados de Recebíveis Imobiliários de que trata o art. 6.º da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, e com Letras Financeiras de que trata o art. 37 da Lei 12.249, de 11 de junho de 2010.

VII – de negociação de cotas de Fundos de Índice de Renda Fixa em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

§ 3.º O disposto no inciso III do § 2.º não se aplica às operações conjugadas de que trata o art. 65, § 4.º, alínea 'a', da Lei 8.981, de 1995.

§ 4.º O disposto neste artigo não modifica a incidência do IOF:

I – nas operações de que trata o art. 30;

II – no resgate de quotas de fundos de investimento, na forma prevista no art. 31;

§ 5.º A incidência de que trata o inciso II do § 4.º exclui a cobrança do IOF prevista neste artigo.

Art. 32-A. A partir de 24.12.2013, fica reduzida a zero a alíquota incidente na cessão de ações que sejam admitidas à negociação em bolsa de valores localizada no Brasil, com o fim específico de lastrear a emissão de depositary receipts – DR negociados no exterior.

§ 1.º Para os efeitos do disposto no caput, exceto no caso de ofertas públicas, o valor da operação a ser considerado para fins de apuração da base de cálculo deverá ser obtido multiplicando-se o número de ações cedidas pela sua cotação de fechamento

na data anterior à operação ou, no caso de não ter havido negociação nessa data, pela última cotação de fechamento disponível.

§ 2.º No caso de ofertas públicas, a cotação a ser considerada para fins de apuração da base de cálculo do IOF de que trata este artigo será o preço fixado com base no resultado do processo de coleta de intenções de investimento ('Procedimento de Bookbuilding') ou, se for o caso, o preço determinado pelo ofertante e definido nos documentos da oferta pública.

Art. 32-B. (revogado).

Art. 32-C. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento, sobre o valor nocional ajustado, na aquisição, venda ou vencimento de contrato de derivativo financeiro celebrado no País que, individualmente, resulte em aumento da exposição cambial vendida ou redução da exposição cambial comprada.

§ 1.º Poderão ser deduzidos da base de cálculo apurada diariamente:

I – o somatório do valor nocional ajustado na aquisição, venda ou vencimento de contratos de derivativos financeiros celebrados no País, no dia, e que, individualmente, resultem em aumento da exposição cambial comprada ou redução da exposição cambial vendida;

II – a exposição cambial líquida comprada ajustada apurada no dia útil anterior;

III – a redução da exposição cambial líquida vendida e o aumento da exposição cambial líquida comprada em relação ao dia útil anterior, não resultantes de aquisições, vendas ou vencimentos de contratos de derivativos financeiros.

§ 2.º A base de cálculo será apurada em dólares dos Estados Unidos da América e convertida em moeda nacional para fins de incidência do imposto, conforme taxa de câmbio de fechamento

do dia de apuração da base de cálculo divulgada pelo Banco Central do Brasil – PTAX.

§ 3.º No caso de contratos de derivativos financeiros que tenham por objeto a taxa de câmbio de outra moeda estrangeira que não o dólar dos Estados Unidos da América em relação à moeda nacional ou taxa de juros associada a outra moeda estrangeira que não o dólar dos Estados Unidos da América em relação à moeda nacional, o valor nocional ajustado e as exposições cambiais serão apurados na própria moeda estrangeira e convertidos em dólares dos Estados Unidos da América para apuração da base de cálculo.

§ 4.º Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I – valor nocional ajustado – o valor de referência do contrato – valor nocional – multiplicado pela variação do preço do derivativo em relação à variação do preço da moeda estrangeira, sendo que, no caso de aquisição, venda ou vencimento parcial, o valor nocional ajustado será apurado proporcionalmente;

II – exposição cambial vendida – o somatório do valor nocional ajustado dos contratos de derivativos financeiros do titular que resultem em ganhos quando houver apreciação da moeda nacional relativamente à moeda estrangeira, ou perdas quando houver depreciação da moeda nacional relativamente à moeda estrangeira;

III – exposição cambial comprada – o somatório do valor nocional ajustado dos contratos de derivativos financeiros do titular que resultem em perdas quando houver apreciação da moeda nacional relativamente à moeda estrangeira, ou ganhos quando houver depreciação da moeda nacional relativamente à moeda estrangeira;

IV – exposição cambial líquida vendida – o valor máximo entre zero e o resultado da diferença entre a exposição cambial

vendida e a exposição cambial comprada;

V – exposição cambial líquida comprada – o valor máximo entre zero e o resultado da diferença entre a exposição cambial comprada e a exposição cambial vendida;

VI – exposição cambial líquida comprada ajustada – o valor máximo entre zero e o resultado da diferença entre a exposição cambial comprada, acrescida de US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), e a exposição cambial vendida;

VII – contrato de derivativo financeiro – contrato que tem como objeto taxa de câmbio de moeda estrangeira em relação à moeda nacional ou taxa de juros associada a moeda estrangeira em relação à moeda nacional; e

VIII – data de aquisição, venda ou vencimento – data em que a exposição cambial do contrato de derivativo financeiro é iniciada ou encerrada, total ou parcialmente, pela determinação de parâmetros utilizados no cálculo do valor de liquidação do respectivo contrato.

§ 5.º A alíquota fica reduzida a zero:

I – nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País; e

II – nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos no caput.

§ 6.º O contribuinte do tributo é o titular do contrato de derivativos financeiros.

§ 7.º São responsáveis pela apuração e recolhimento do tributo as entidades ou instituições autorizadas a registrar os contratos de derivativos financeiros.

§ 8.º Na impossibilidade de apuração do IOF pelos responsáveis

tributários, tais entidades ou instituições deverão, até o décimo dia útil do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador, por meio dos intermediários e participantes habilitados, as informações necessárias para a apuração da base de cálculo das operações com contratos de derivativos financeiros registrados em seus sistemas, e para o recolhimento do tributo:

I – ao contribuinte residente ou domiciliado no País;

II – ao representante legal do contribuinte residente ou domiciliado no exterior; e

III – ao administrador de fundos e clubes de investimentos, para o qual as informações de que trata o § 8.º poderão ser disponibilizadas diariamente.

§ 9.º Caracteriza-se impossibilidade de apuração ou de cobrança, respectivamente, quando as entidades ou instituições de que trata o § 7.º não possuírem todas as informações necessárias para apuração da base de cálculo, inclusive informações de outras entidades autorizadas a registrar contratos de derivativos financeiros, ou não possuírem acesso aos recursos financeiros do contribuinte necessários ao recolhimento do imposto.

§ 10. As informações a que se refere o § 8.º poderão ser disponibilizadas em formato eletrônico.

§ 11. Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do § 5.º, o valor total da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das operações com exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica titular dos contratos de derivativos.

§ 12. Observado o limite de que trata o § 11, o disposto no inciso I do § 5.º estará sujeito à comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de até doze meses

subsequentes à data de ocorrência do fato gerador do IOF.

§ 13. Quando houver falta de comprovação ou descumprimento de condição de que tratam os §§ 11 e 12, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato gerador e calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no caput, acrescido de juros e multa de mora.

§ 14. Quando, em razão de determinação prévia do Banco Central do Brasil, a taxa de câmbio válida para um determinado dia for definida como a mesma taxa de câmbio do dia útil imediatamente anterior, será considerada como data de aquisição, venda ou vencimento, definida no inciso VIII do § 4.º, para as exposições com aquisição, venda ou vencimento nessa data, o dia útil imediatamente anterior, ficando o próprio contribuinte responsável pela consolidação das exposições destes dias.

§ 15. A partir de 13 de junho de 2013, a alíquota prevista no caput fica reduzida a zero.

Art. 33. A alíquota fica reduzida a zero nas demais operações com títulos ou valores mobiliários, inclusive no resgate de cotas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, instituído pela Lei 9.477, de 24 de julho de 1997.

Observa-se que a legislação de regência é extremamente cuidadosa em estabelecer todos os detalhes para fins de incidência do IOF em todas as operações apresentadas, determinando as respectivas bases de cálculo e contribuintes para fins de incidência.

2.5.2.6 Demais características

O Imposto sobre as Operações decorrentes de Crédito, Câmbio, Seguros, Título e Valores Mobiliários (IOF) passa a ser utilizado, pelo Governo Federal, como um mecanismo de regulação econômica. Portanto, passa a ser considerado um **tributo extrafiscal**.

Tendo a característica marcante de tributo extrafiscal, o **princípio da legalidade resta mitigado**, uma vez que suas alíquotas podem ser alteradas através de atos do Poder Executivo. Assim, o Poder Executivo, normalmente por meio de Decreto poderá **aumentar ou reduzir as alíquotas do imposto sobre operações financeiras**, desde que haja estrita observância da lei. Não poderá o Poder Executivo aumentar acima do limite máximo ou reduzir abaixo do limite mínimo estabelecido em lei, configurando-se exorbitância do Poder Regulamentar conferido pela CF/1988.

Caso o Poder Executivo exorbite os limites estabelecidos em decorrência do Poder Regulamentar, caberá ao Congresso Nacional a sustação dos atos normativos, nos termos do art. 49, V, da CF/1988.

De igual modo, teremos uma **mitigação do princípio da anterioridade tributária**, uma vez que o referido imposto **podará ser exigido imediatamente**, após a publicação da lei, quando esta aumentar ou reduzir as suas alíquotas, conforme estabelece o art. 150, § 1.º, da CF/1988.

O art. 153, § 5.º, da CF/1988 estabelece a **possibilidade da incidência de IOF sobre o ouro**, desde que seja aplicado como **ativo financeiro ou instrumento de política cambial**:

Art. 153 (...)

§ 5.º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;

II – setenta por cento para o Município de origem.

Neste caso, a **incidência do IOF** será sobre a **primeira aquisição do ouro destinado ao mercado financeiro** ou como **instrumento de política cambial** instituídos e cobrados das **instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen)**, cuja alíquota será de **1% sobre o preço da aquisição do ouro**.

O Decreto 6.306/2007 regulamenta a incidência de IOF sobre o ouro, conforme vemos abaixo:

Art. 36. O ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial sujeita-se, exclusivamente, à incidência do IOF.

§ 1.º Entende-se por ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, desde sua extração, inclusive, o ouro que, em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, for destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em operação realizada com a interveniência de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 2.º Enquadra-se na definição do § 1.º deste artigo o ouro:

I – envolvido em operações de tratamento, refino, transporte, depósito ou custódia, desde que formalizado compromisso de destiná-lo ao Banco Central do Brasil ou à instituição por ele autorizada;

II – adquirido na região de garimpo, onde o ouro é extraído, desde que, na saída do Município, tenha o mesmo destino a que se refere o inciso I;

III – importado, com interveniência das instituições mencionadas no inciso I.

§ 3.º O fato gerador do IOF é a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, efetuada por instituição autorizada integrante do Sistema Financeiro Nacional.

§ 4.º Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF:

I – na data da aquisição;

II – no desembarço aduaneiro, quando se tratar de ouro físico oriundo do exterior.

Art. 37. Contribuintes do IOF são as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil que efetuarem a primeira aquisição do

ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial.

Art. 38. A base de cálculo do IOF é o preço de aquisição do ouro, desde que dentro dos limites de variação da cotação vigente no mercado doméstico, no dia da operação.

Parágrafo único. Tratando-se de ouro físico, oriundo do exterior, o preço de aquisição, em moeda nacional, será determinado com base no valor de mercado doméstico na data do desembaraço aduaneiro.

Art. 39. A alíquota do IOF é de um por cento sobre o preço de aquisição.

Art. 40. O IOF será cobrado na data da primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, efetuada por instituição financeira, integrante do Sistema Financeiro Nacional.

§ 1.º O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.

§ 2.º O recolhimento do IOF deve ser efetuado no Município produtor ou no Município em que estiver localizado o estabelecimento-matriz do contribuinte, devendo ser indicado, no documento de arrecadação, o Estado ou o Distrito Federal e o Município, conforme a origem do ouro.

§ 3.º Tratando-se de ouro oriundo do exterior, considera-se Município e Estado de origem o de ingresso do ouro no País.

§ 4.º A pessoa jurídica adquirente fará constar da nota de aquisição o Estado ou o Distrito Federal e o Município de origem do ouro.

Os contribuintes IOF-Ouro recolhem regularmente esse imposto na rede bancária de acordo com a legislação pertinente. O montante dessa arrecadação é transferido por cada instituição financeira, conforme previsão contratual entre o banco e a Receita Federal do Brasil – RFB –, para a Conta Única do Tesouro Nacional – CTU. Os bancos repassam as informações relativas ao recolhimento efetuado para a RFB.

Decididamente, por meio de processamento eletrônico, a RFB classifica o montante da arrecadação bruta de tributos relativa ao período e das deduções correspondentes (restituições, retificações e compensações), se houver, apurando, dessa forma, a arrecadação líquida do período. Tais informações são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN – consulta no SIAFI as informações do período anterior e transfere ao Banco do Brasil o valor global a ser repassado, que, no caso do IOF-Ouro, corresponde a 100% da arrecadação líquida. O Banco do Brasil, por sua vez, credita nas contas correntes dos Entes Federativos os respectivos valores que lhes cabem, segundo informações da RFB fornecidas com base nos documentos de arrecadação do imposto.

Considerando a esfera cabível (estadual, distrital ou municipal), os órgãos responsáveis por fiscalizar e aplicar medidas corretivas e punitivas apropriadas nos casos de desvios na utilização dos recursos são:

- ✓ Controle Interno Estadual ou Municipal (quando houver);
- ✓ Tribunal de Contas Estadual (ou Municipal, quando houver);
- ✓ Ministério Público Estadual;
- ✓ Legislativo Estadual ou Municipal.

Nos casos em que o dinheiro é de origem da União, agregam-se controles adicionais para as transferências vinculadas, entrando em cena órgãos federais de controle:

- ✓ Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU;
- ✓ Tribunal de Contas da União – TCU;
- ✓ Ministério Público da União;
- ✓ Congresso Nacional.

JURISPRUDÊNCIA

- “O ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem: CF, art. 153, § 5º.

Inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei 8.033/1990” (RE 190.363 rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 13.05.1998, *DJ* 12.06.1998).

- “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (AgRg no Recurso Especial nº 1.532.484/PR 2015/0113950-5).
- “IOF. Saques efetuados em cadernetas de poupança. Lei 8.033/90, art. 1º, V. Transmissão de ações de companhias abertas e das consequentes bonificações emitidas: Lei 8.033/90, art. 1º, IV. **I. Inconstitucionalidade do inc. V do art. 1º da Lei 8.033/90, que instituiu a incidência do IOF nos saques efetuados em cadernetas de poupança: RE 232.467-SP, Galvão, Plenário, 29.9.99. DJ de 12.5.2000.** II. Incidência do IOF sobre a transmissão de ações de companhias abertas e das consequentes bonificações emitidas: Lei nº 8.033/90, art. 1º, IV. No ponto, omitiu-se o acórdão embargado, dado que o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou a respeito. Embargos de declaração acolhidos, nesta parte, a fim de ser o RE levado à apreciação do Plenário. III. Embargos de declaração acolhidos, em parte” (STF, Rel. Min. Carlos Velloso, RE-ED 266207).

2.6 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)



2.6.1 Previsão legislativa

O imposto territorial rural (ITR) é um imposto federal estabelecido no art. 153 VI, da CF/1988, bem como no § 4.º do mesmo artigo.

No CTN, os arts. 29 a 31 estabelecem as normas gerais, definindo a regra-matriz de incidência tributária.

O diploma utilizado para instituição do ITR é a Lei 9.393/1996, com a regulamentação pelo Decreto 4.382/2002.

Uma vez que a CF/1988 estabelece a possibilidade de os Municípios exercerem a capacidade tributária ativa, a Lei 11.250/2005 estabelece as condições para que os Municípios possam arrecadar o ITR, estabelecendo convênio com a União.

2.6.2 Regra-matriz de incidência tributária

2.6.2.1 Aspecto material

A **materialidade do fato gerador** no ITR resta demonstrada pelo **exercício da propriedade de imóvel situada em zona rural**, entendida como sendo aquela fora da zona urbana ou de expansão urbana do Município.

O art. 1.228 do CC estabelece sobre o direito de propriedade:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1.º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2.º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3.º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público

iminente.

§ 4.º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.”

“§ 5.º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Somente aquele considerado como **proprietário de imóvel** situado em zona rural cumpre o aspecto de incidência do referido imposto.

O CTN, entretanto, estabelece também como forma de incidência, além do direito de propriedade, a **posse** e o **domínio útil**. O mesmo se dá com a Lei 9.393/1996, que regulamenta o ITR, estabelecendo a incidência sobre o domínio útil e a posse de bem imóvel.

Algumas considerações importantes sobre o domínio útil e posse merecem atenção. O **domínio** significa a própria **relação de propriedade que se exerce sobre o bem imóvel**, garantindo o exercício desse direito de propriedade de modo efetivo, **podendo ser oposto contra qualquer reivindicação de terceiros ou dúvida quanto à legitimidade do ato de aquisição**.

Apenas **aquele que é dono detém**, na sua amplitude, o **domínio sobre o imóvel**, ou seja, somente o **proprietário é o senhor**, que exerce de modo incontestado o *dominus* sobre a coisa. O domínio, contudo, pode ser desdobrado em **domínio direto** e **domínio indireto**. Esse desdobramento do domínio acontece nos casos em que o proprietário do imóvel separa o uso e fruição do bem, do poder de ser titular do domínio integral, tal como acontece com os institutos da enfiteuse ou aforamento e na concessão do direito de superfície.

O **domínio indireto** é **absoluto** e **perene**, e resulta da própria condição de proprietário e senhor. O titular do domínio indireto **detém o poder de disposição sobre o imóvel**, isto é, somente **ele pode alienar o bem** e assim **transferir o próprio**

domínio, a propriedade.

O **domínio direto**, também denominado de **domínio útil**, é o **exercício dos direitos de uso, gozo e fruição sobre o bem imóvel**, mas **sem o poder de disposição**, que é exclusivo do titular do domínio indireto.

No caso da **enfiteuse dos terrenos de marinha**, o **titular do domínio indireto**, o enfiteuta ou senhorio, é o **Poder Público**, proprietário dos terrenos declarados, pela Constituição, como pertencentes à União (Constituição Federal, art. 20, VII).

Com relação à **posse**, esta consiste numa **relação de pessoa e coisa**, fundada na **vontade do possuidor**, criando **mera relação de fato**; é a exteriorização do direito de propriedade. A **propriedade** é a **relação entre a pessoa e a coisa**, que assenta na vontade objetiva da lei, implicando um poder jurídico e criando uma relação de direito.

Entre os modernos há duas teorias importantes:

- **Teoria de Savigny (subjetiva)**: a posse é o **poder de dispor fisicamente da coisa**, com ânimo de considerá-la sua e defendê-la contra a intervenção de outrem. Encontram-se, assim, na posse dois elementos: um **elemento material**, o *corpus*, que é representado pelo **poder físico sobre a coisa**; e um **elemento intelectual**, o *animus*, ou seja, o **propósito de ter a coisa como sua**, isto é, o *animus rem sibi habendi*.

Os dois elementos são **indispensáveis para que se caracterize a posse**, pois, se faltar o *corpus*, **inexiste relação de fato entre a pessoa e a coisa**; e se faltar o *animus*, não existe posse, mas mera detenção.

- **Teoria de Ihering (objetiva)**: considera que a **posse é a condição do exercício da propriedade**. Critica veementemente Savigny; para ele, a distinção entre *corpus* e *animus* é irrelevante, pois a noção de *animus* já se encontra na de *corpus*, sendo a maneira como o proprietário age em face da coisa de que é possuidor.

A lei protege todo aquele que age sobre a coisa como se fosse o proprietário, explorando-a, dando-lhe o destino para que economicamente foi feita. Em geral, **quem assim atua é o proprietário**, de modo que, **protegendo o possuidor**, quase sempre o legislador está **protegendo o proprietário**.

Existem situações extremas em que, mesmo sendo proprietário ou gozando das prerrogativas de proprietário, dotado de *animus dominus*, o **titular não consegue exercer o direito de propriedade**.

Nessas situações, a jurisprudência caminha no sentido de determinar a **não incidência do imposto enquanto a situação de normalidade não se estabelecer**. É o caso de **imóveis rurais invadidos por movimento sem terra**, quando o proprietário, mesmo com o direito concedido pelo Poder Judiciário, **não consegue exercer a reintegração**.

Com a invasão de movimentos sociais, o direito de propriedade fica tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; conseqüentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para o proprietário. Passa a ser inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da função social e da proporcionalidade, segundo o entendimento do STJ, no julgamento do REsp 1.144.982/PR.

Tais situações já foram decididas pela jurisprudência do STJ, e, noutros casos, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), enfrentando o tema, determinou pela não incidência do ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas, de acordo com a súmula 45:

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Para fins de definição do que se considera zona rural, o critério definidor é a **exclusão da área em que não for considerada urbana**. Tal exclusão acaba ocorrendo mutuamente, uma vez que jamais incidirá ITR e IPTU no mesmo imóvel.

O art. 32, § 1.º, do CTN traz importante informação para definição da zona urbana:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por

natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1.º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II – abastecimento de água;

III – sistema de esgotos sanitários;

IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Assim, se o Município determinar, por meio de lei municipal, a existência de melhoramentos constantes no artigo anterior, a **zona será considerada urbana**.

Entretanto, estabelece o art. 15 do Decreto-lei 57/1966:

Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindústria, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

A jurisprudência tem admitido a incidência de ITR nos imóveis que, mesmo situados em zona urbana, sejam utilizados com a atividade preponderantemente extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Trata-se do **critério material** aplicado ao ITR, não se observando a incidência de IPTU.

2.6.2.2 Aspecto espacial

O **aspecto espacial** é o **território nacional**. Assim, todo imóvel situado em zona rural em **qualquer localidade do território nacional** terá a incidência do ITR, salvo nos casos em que a Constituição e a lei determinarem a exclusão de sua incidência.

A CF/1988 autoriza que o **Município** possa exercer a **capacidade tributária ativa sobre o ITR**, fiscalizando e cobrando o referido tributo, permanecendo com o total arrecadado sem ter que devolver ou restituir a União (arts. 153, § 4.º, III, e 158, II ambos da CF).

A dúvida ocorre, no entanto, quando um **imóvel alcança mais de um Município** e estes optam pela arrecadação e fiscalização do ITR.

Determina o art. 1.º, § 3.º, da Lei 9.393/1996:

Art. 1.º (...)

§ 3.º O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte do imóvel.

2.6.2.3 Aspecto temporal

O ITR possui o denominado **fato gerador continuado**, perdurando no tempo e incidindo enquanto ocorrer o exercício do direito de propriedade.

O art. 1.º da Lei 9.393/1996 estabelece:

Art. 1.º O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1.º de janeiro de cada ano.

Assim, a incidência do ITR ocorre a cada dia **1.º de janeiro de cada exercício financeiro**, sendo um imposto sujeito a **lançamento por homologação**.

2.6.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** poderá ser a **União**, uma vez que o imposto é de competência federal, bem como aos **Municípios**, quando estes exercerem a capacidade tributária ativa.

A administração e arrecadação competem à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A lei que regulamenta a arrecadação e fiscalização do ITR pelos Municípios é a Lei 11.250/2005:

Art. 1.º A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no inciso III do § 4.º do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal.

§ 1.º Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

§ 2.º A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

O **sujeito passivo** (contribuinte ou responsável) resta definido nos arts. 4.º e 5.º da Lei 9.393/1996:

Art. 4.º Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer

outro.

Art. 5.º É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional).

No mesmo sentido, o art. 34 do CTN:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2.6.2.5 Aspecto quantitativo

A **base de cálculo** do imposto é considerada como o **valor fundiário**, conforme resta demonstrado no art. 30 do CTN.

Entende-se por **valor fundiário** o chamado **valor da terra nua tributável**, ou seja, o valor da terra sem edificação.

Dispõe o art. 11 da Lei 9.393/1996:

Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua Tributável – VTNT a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização – GU.

§ 1.º Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões previstas no art. 10, § 1.º, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes aos imóveis com grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.

§ 2.º Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R\$ 10,00 (dez reais).

As **alíquotas** podem ser **progressivas**, visando **desestimular a manutenção de**

terras improdutivas. Assim, temos um **caráter extrafiscal na progressividade** admitida para o ITR.

Temos a seguinte tabela de alíquotas admitida:

TABELA DE ALÍQUOTAS

Área total do imóvel (em hectares)	GRAU DE UTILIZAÇÃO – GU (EM %)				
	Maior que 80	Maior que 65 até 80	Maior que 50 até 65	Maior que 30 até 50	Até 30
Até 50	0,03	0,20	0,40	0,70	1,00
Maior que 50 até 200	0,07	0,40	0,80	1,40	2,00
Maior que 200 até 500	0,10	0,60	1,30	2,30	3,30
Maior que 500 até 1.000	0,15	0,85	1,90	3,30	4,70
Maior que 1.000 até 5.000	0,30	1,60	3,40	6,00	8,60
Acima de 5.000	0,45	3,00	6,40	12,00	20,00

Admitindo-se uma **progressividade extrafiscal**, não significa que será admitido

aumento desmedido e por prazo indeterminado de duração; primeiro, porque temos a aplicação do **princípio da vedação ao confisco** (art. 150, IV, da CF); segundo, porque o tempo máximo que se pode estabelecer o aumento é de até **5 anos**.

Assim, as alíquotas do ITR podem ser aumentadas **progressivamente** por **até 5 anos**, sendo que, no **último ano de aumento**, a alíquota não pode ultrapassar **20%** sobre a base de cálculo.

Caso o aumento progressivo do ITR nesse período não consiga alcançar seu objetivo indutor – qual seja evitar a manutenção da propriedade improdutiva –, legitimará a União para expedir decreto visando a **desapropriação rural para fins de reforma agrária** (art. 184 da CF).

2.6.2.6 Demais características

O **sujeito passivo do ITR** possui uma série de **obrigações de caráter acessório**, estabelecidas e reguladas a partir do art. 6.º da Lei 9.393/1996:

Art. 6.º O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.

§ 1.º É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a comunicação das seguintes alterações:

I – desmembramento;

II – anexação;

III – transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, a qualquer título;

IV – sucessão causa mortis;

V – cessão de direitos;

VI – constituição de reservas ou usufruto.

§ 2.º As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis

Rurais – CAFIR, administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer tempo, solicitar informações visando à sua atualização.

§ 3.º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4.º, o contribuinte poderá indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.

As obrigações devem ser cumpridas no prazo assinalado em lei, uma vez que a **falta de apresentação no prazo determinado gera multa de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, não podendo ser inferior a R\$ 50,00** (cinquenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora.

A lei estabelece a **possibilidade de isenção** em determinados casos:

Art. 3.º São isentos do imposto:

I – o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:

- a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção;
- b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior;
- c) o assentado não possua outro imóvel.

II – o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observe os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior, desde que, cumulativamente, o proprietário:

- a) o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros;
- b) não possua imóvel urbano.

Ademais, temos a possibilidade de **imunidade tributária específica**, prevista no

art. 153, § 4.º, II, da CF/1988, que reza:

Art. 153 (...)

§ 4.º (...)

II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel.

Para configuração das **pequenas glebas rurais**, a legislação adota o que podemos denominar de **critério métrico-topográfico**, indicando como pequena gleba rural a **metragem** e a **localização do imóvel em zona rural**.

Reza o art. 2.º da Lei 9.393/1996:

Art. 2.º Nos termos do art. 153, § 4.º, in fine, da Constituição, o imposto não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis com área igual ou inferior a:

I – 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;

II – 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;

III – 30 ha, se localizado em qualquer outro município.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 595 do STF: É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural.

Súmula 23 do CARF: a autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre, de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação das fontes pesquisadas. (**Vinculante**, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 41 do CARF: a não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (**Vinculante**, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 70 do CARF: é imune ao ITR o imóvel pertencente às entidades indicadas no artigo 150, VI, c, da Constituição, que se encontra arrendado, desde que a receita assim obtida seja aplicada nas atividades essenciais da entidade.

Súmula 122 do CARF: a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

→ “Tributário. Imóvel na área urbana. Destinação rural. IPTU. Não incidência Art. 15 do DL 57/1966. Recurso repetitivo. Art. 543-C do CPC [art. 1.036 do CPC/2015]. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ” (STJ, REsp 1.112.646/SP, 1ª Seção, j. 26.08.2009, rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 28.08.2009).

- “É imprescindível a averbação da área de reserva legal no registro do imóvel para gozo do benefício fiscal do ITR” (STJ, EDcl no AgRg no AREs 386.653/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1.^a T., j. 06.05.2014, *DJe* 19.05.2014).
- “É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual é inexigível, para as áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental com vistas à isenção do ITR. Por outro lado, quando se trata de área de reserva legal, é imprescindível a sua averbação no respectivo registro imobiliário” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1315220/MG, 1.^a T., j. 24.04.2014, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJe* 08.05.2014).
- “Tratando-se de matéria sujeita a estrita previsão constitucional – (...) (contribuição social devida pelo empregador) – inexistente espaço de liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema de progressividade tributária, instituir alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo texto da Constituição (...)” (ADI 2.010 MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30.09.1999, *DJ* 12.04.2002).

IMPOSTOS ESTADUAIS

3.1 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCMD)

3.1.1 Previsão legislativa

O imposto sobre a transmissão *causa mortis* e doações de qualquer natureza (ITCMD) é um imposto estadual previsto no art. 155, I, § 1.º, I a IV, da CF/1988.

A determinação das **alíquotas máximas** a serem aplicadas aos Estados está prevista na **Resolução do Senado Federal 9/1992**.

Inexiste uma previsão expressa no Código Tributário Nacional que identifique as normas gerais atinentes ao referido imposto, cabendo a cada um dos Estados exercer sua competência legislativa plena, conforme estabelece o art. 24, § 3.º, da CF/1988.

O art. 1.º da Resolução Senado Federal 9/1992 estabelece a alíquota máxima do ITCMD em **8%**, sendo aplicada a partir de 1.º de janeiro de 1992.

Compete à lei complementar regular o ITCMD se *ode cujus* possuía bens, era residente ou domiciliado ou ainda teve o seu inventário processado no exterior, bem como se o doador tiver domicílio ou residência no exterior (art. 155, § 1.º, *a* e *b*, da CF/1988).

3.1.2 Regra-matriz de incidência tributária

3.1.2.1 Aspecto material

Para fins de estudo, dividiremos o aspecto material em duas formas de incidência:

a) na **transmissão *causa mortis***

A incidência recai sobre a **transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão**, seja esta **legítima** ou **testamentária**, podendo incidir inclusive na **sucessão provisória**.

Sabemos que a sucessão se **abre com a morte** e, para tanto, leva-se em consideração para determinação da sua incidência o **momento do óbito**.

Vige em direito tributário, como regra geral, o **princípio da irretroatividade tributária**, nos termos do art. 150, III, *a*, da CF/1988, e tal regra passa a ser aplicada, também, nos casos de incidência do ITCMD.

Assim, se o **óbito ocorreu em 2002**, cuja lei vigente estabelecia uma **alíquota de 5%**, mas os familiares resolveram **abrir o inventário em 2013**, cuja **alíquota é de 2%**, a alíquota a ser aplicada será de **5%**, não se aplicando o disposto no art. 106 do CTN, que versa sobre a retroatividade benéfica, uma vez que tal retroatividade não ocorrerá em qualquer caso estabelecido em lei.

A **incidência** ocorrerá na **transmissão de qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou mesmo do capital de sociedade**, seja anônima ou não, tais como ações, cotas, participações etc. Outros direitos societários, tais como debêntures, dividendos e outros também possuem incidência da transmissão, desde que seja *causa mortis*.

Valores que estejam depositados em conta, cadernetas de poupança e fundos também sofrem a incidência na transmissão, bem como bens considerados **incorpóreos**.

Entretanto, caso haja **renúncia pura e simples de herança ou legado**, não gera a incidência do ITCMD. Também **não incide** sobre a **importância deixada ao testamenteiro a título de prêmio ou remuneração**, até o limite legal.

Frutos e demais rendimentos de bens do espólio havidos após o falecimento do autor da herança não geram, de igual modo, a incidência do referido imposto.

b) na doação de quaisquer bens e direitos

A lei civil estabelece que **doação** é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra (art. 538 do CC/2002).

A incidência ocorrerá quando da **transferência da titularidade**, ou seja, quando **sair do domínio do doador para o donatário**.

Apesar de, na **doação de bens imóveis**, a efetiva transmissão ocorrer mediante a

efetiva transcrição do título mediante o Registro de Imóveis competente (Lei 6.015/1973), nada obsta de determinada legislação estadual **exigir o recolhimento do ITCMD quando da lavratura da escritura de doação**. Isto porque, em determinados casos, existe a doação, lavra-se a escritura, mas não se leva a registro, acarretando perda de arrecadação do Estado competente.

A **transmissão de bens móveis ou direitos** passa a ser mais simples, uma vez que a transmissão da titularidade ocorre com a **efetiva tradição**. Dependendo do **tipo de bem móvel**, admite-se ainda o **registro**, como ocorre nos casos de **veículos, embarcações, títulos representativos do direito de ações** etc.

Nos casos de **separação judicial**, a legalização dos bens da **meação não está**, em regra, **sujeita a tributação**. No entanto, havendo entrega a um dos cônjuges, de **bens que sejam superiores à meação**, sem que haja indícios de qualquer compensação pecuniária (denominado de **excesso de meação**), **temos a incidência de ITCMD**, por se considerar a **ocorrência de doação**.

3.1.2.2 Aspecto espacial

A CF/1988 estabelece em seu art. 155, § 1.º:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

§ 1.º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela EC 3, de 1993)

I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal; (...).

Assim, a CF/1988 delimita o **aspecto espacial** do referido imposto, seja nos casos de **transmissão** ou **doações**.

3.1.2.3 Aspecto temporal

Competirá a **cada Estado da federação** estabelecer a **regra-matriz de incidência tributária**, determinando os aspectos que a compõem. Mesmo assim, existem critérios que não sofrem mutação em razão da legislação, adotando-se um mínimo comum.

Nos casos de transmissão *causa mortis*, o aspecto temporal ocorre com o **evento morte**, mesmo que seja a **morte presumida**.

Já na **doação**, o **momento da ocorrência do fato gerador** ocorre com **registro do título aquisitivo perante o cartório de Registro de Imóveis** (adotado como regra geral), podendo incidir nos casos da **lavratura da escritura pública de doação**, em casos especificados em lei, quando se tratar de bens imóveis. Já nos casos de **bens móveis**, a materialização da **transmissão para fins de incidência ocorre com a tradição**.

3.1.2.4 Aspecto pessoal

Para a definição do **sujeito ativo**, a CF/1988 estabeleceu uma regra, determinada no art. 155, § 1.º, já salientada anteriormente:

Art. 155 (...)

§ 1.º O imposto previsto no inciso I:

I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regulada por lei

complementar:

- a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
- b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior (...).

O **sujeito passivo** será determinado pela **lei estadual**, podendo ser identificado nos seguintes casos:

I) Na **transmissão *causa mortis***: o **herdeiro** ou **legatário**;

II) No **fideicomisso**: o **fiduciário**;

III) Na **doação**: o **donatário**; e

IV) **Necessão de herança**, de bem ou de direito a título não oneroso: o **cessionário**.

3.1.2.5 Aspecto quantitativo

Temos, no **aspecto quantitativo**, a análise da **base de cálculo** e da respectiva **alíquota**.

A **base de cálculo** é o **valor venal do bem ou direito transmitido**, expresso em moeda nacional.

Deve ser considerado o **valor de mercado do bem** ou direito na **data da abertura da sucessão**, ou seja, na **data do óbito**. O mesmo se dá com relação à **doação**, que levará em consideração do valor estabelecido no **ato ou no contrato de doação**.

Na **transmissão *causa mortis***, o valor do bem ou direito é o atribuído na **avaliação judicial e homologado pelo juiz**, e o **cálculo do imposto** não admitirá a dedução de quaisquer dívidas que onerem os bens transmitidos.

A **incidência do imposto** será sobre a transmissão do **patrimônio que pertencia ao de cujus** (patrimônio hereditário), bem como sobre os **bens decorrentes do curso do processo de inventário**.

A **alíquota máxima** estabelecida por Resolução do Senado Federal é de **8%**, sendo que caberá a cada Estado defini-la mediante a legislação estadual.

Em se tratando de se determinar **alíquotas progressivas** em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber, não temos amparo constitucional.

A **progressividade do ITCMD** foi objeto de questionamento quando do julgamento do RE 562.045/RS, no qual, segundo entendimento da maioria dos Ministros da Suprema Corte, **a progressividade é medida da capacidade contributiva**, sendo que todos os impostos, independentemente de sua classificação como de caráter real ou pessoal, devem guardar relação com a capacidade econômica do sujeito passivo.

Anteriormente, o Supremo reputava que não seria permitido à legislação que regula os impostos classificados como reais, dentre eles o próprio ITCMD, aplicar alíquotas progressivas em função da capacidade contributiva do sujeito passivo, tendo em vista que supostamente o § 1.º do art. 145 da CF/1988 a admitiria exclusivamente para os impostos de caráter pessoal. O próprio IPTU sofreu durante longa data severas restrições por parte da Corte quanto à sua progressividade que não se destinasse a atender à função social da propriedade (RE 194.036-1, *DJ* 20.06.1997; RE 202.261, *DJ* 20.06.1997; RE 198.506-2, *DJ* 20.06.1997; dentre outros). Chegou-se até a editar Súmula sobre o tema (Enunciado 668 – Súmula do STF).

Contudo, segundo entendimento da maioria, no julgamento do RE 562.045/RS **não há incompatibilidade entre a progressividade do ITCMD e o enunciado 668 da Súmula do STF**. A **progressividade pode e deve ser graduada a todos os impostos**, de que natureza for, **inclusive ao ITCMD**, como forma de cumprir o desiderato Constitucional positivado no Princípio da Capacidade Contributiva. Ademais, por se tratar de **imposto direto**, a **incidência do ITCMD** poderia expressar **progressividade** ou **regressividade direta**. E, por fim, **não há risco de confisco**, tendo em vista que é **facultado ao Senado Federal estabelecer mediante resolução o teto das alíquotas do tributo** (art. 155, § 1.º, IV, da CF/1988).

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 112 do STF: O imposto de transmissão “causa mortis” é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão.

Súmula 113 do STF: O imposto de transmissão “causa mortis” é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.

Súmula 114 do STF: O imposto de transmissão “causa mortis” não é

exigível antes da homologação do cálculo.

Súmula 331 do STF: É legítima a incidência do imposto de transmissão “causa mortis” no inventário por morte presumida.

Súmula 435 do STF: O imposto de transmissão “causa mortis” pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia.

Súmula 590 do STF: Calcula-se o imposto de transmissão “causa mortis” sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor.

- “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.150.356/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 25.8.10, processado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, manifestou-se no sentido de ser incompetente o juízo do inventário processado sob a modalidade de arrolamento sumário para reconhecer a isenção do ITCMD. Nos termos do art. 179 do CTN, é atribuição da autoridade administrativa aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral” (AgRg no AgRg no REsp 1205265/SP).
- “Como salientado na decisão agravada, inexistem as alegadas ofensas aos arts. 155 e 1º da Carta Magna Federal, porquanto o acórdão recorrido não negou que o Estado-membro tenha competência para instituir impostos estaduais, nem que o Senado seja competente para fixar a alíquota máxima para os impostos de transmissão *mortis causa* e de doação, mas, sim, sustentou corretamente que ele, por força do art. 150, I, da Carta Magna, só pode aumentar tributo por lei estadual específica e não por meio de lei que se atrele genericamente a essa alíquota máxima fixada pelo Senado e varie posteriormente com ela, até porque o princípio da anterioridade, a que está sujeita essa lei estadual de aumento, diz respeito ao exercício financeiro em que ela haja sido publicada e não, *per relationem*, à resolução do Senado que aumentou o limite máximo da alíquota” (RE 218.086 AgR, rel. Min. Sydney Sanches, j. 8-2-2000, 1ª T., DJ 17.03.2000).

→ “Ao Senado Federal compete a fixação da alíquota máxima para a cobrança do Imposto de Transmissão *Causa Mortis*, cabendo aos Estados a definição da alíquota interna exigível, mediante lei específica, observada a resolução expedida por essa Casa Legislativa” (RE 224.786 AgR, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 24-8-1999, 2ª T., DJ 04.02.2000).

3.2 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS, INTERMUNICIPAIS E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)



3.2.1 Previsão legislativa

O imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte interestaduais, intermunicipais e serviços de comunicação (ICMS) é um imposto estadual previsto no art. 155, II, §§ 2.º a 5.º, da CF/1988.

Tem sua normatização geral estabelecida na LC 87/1996 e os incentivos fiscais regulados pela LC 24/75.

A s **concessões de incentivos fiscais** e isenções são conferidas mediante **convênios**, com o fito de evitar ou minimizar a guerra fiscal.

Trata-se de um imposto criado em 1965, com a denominação de **Imposto sobre Circulação de Mercadorias** (ICM), e foi um dos primeiros impostos que teve sua incidência sobre o valor adicionado – os denominados IVA. Sucedeu o antigo imposto estadual sobre faturamento bruto – **Imposto sobre Vendas e Consignações** –, tendo sua extinção pela CF/1988, assim como os demais impostos federais específicos, tais como petróleo e combustíveis, energia elétrica e mineração.

Houve uma ampliação da base de cálculo para alcançar **todas as mercadorias**, assim como parte dos **serviços** (transporte e comunicação), originando o **Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicações (ICMS)**.

3.2.2 Regra-matriz de incidência tributária

3.2.2.1 Aspecto material

O ICMS é um imposto dotado de **alta complexidade** e com **mais de uma base econômica**. Para tanto, analisaremos as materialidades de cada uma das bases econômicas distintamente.

a) Operações de circulação de mercadorias

Inicialmente, devemos destacar qual o conceito que deve ser adotado para mercadoria. **Mercadoria** é um **produto com destinação comercial**, mercantil. Toda mercadoria é considerada um produto, mas nem todo produto é considerado mercadoria.

A incidência recai sobre a **circulação**. Devemos compreender por circulação a **mudança da titularidade**, e não uma mera ficção jurídica. Deve ocorrer a **efetiva transmissão de direitos**, não bastando a mera circulação física.

Nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, a incidência recai **desde a produção até o consumo final** das mercadorias. Por isso, temos que o ICMS é um **imposto plurifásico**.

Quando identificamos um imposto plurifásico, analisamos sua incidência em **todas as cadeias de produção até a chegada ao consumidor final**. Ademais, por esta razão, faz-se presente a **não cumulatividade**, permitindo que seja deduzido o montante pago nas operações anteriores com as operações subsequentes, acarretando, desta forma, um estímulo maior ao consumo e, conseqüentemente, à produção.

Mesmo nos casos de fornecimentos de alimentação em bares, restaurantes e estabelecimentos similares em que haja simultânea prestação de serviços, há incidência de ICMS.

Reza a Súmula 163 do STJ:

“O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de

serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação”.

Caso interessante trata-se das **vendas de bens que compõem o ativo fixo da empresa não terem incidência de ICMS**. Isto porque a **alienação esporádica não é suficiente para a determinação da incidência** do referido imposto. O mesmo se dá com as **operações para fins de integralização de capital mediante a cessão de bens**. A mera **modificação patrimonial** não se configura como operação mercantil, não sendo suficiente para a incidência de ICMS.

Quando bens do devedor, mesmo quando dotados de fins mercantis, integram a **massa falida**, acabam por **perder a condição de mercadoria**, uma vez que a **venda desse patrimônio não possui a condição necessária para a incidência de ICMS**, qual seja, o intuito **mercantil**.

Outro fator de suma importância decidida por nossa Corte Suprema merece atenção: as **vendas de salvados realizadas pelas seguradoras e a incidência de ICMS**.

Não há como negar que as vendas de salvados realizadas pelas seguradoras **poderiam adquirir o caráter de operações**, adotando-se a definição geral e isolada do termo, mediante o uso de uma interpretação literal.

A doutrina determina que o vocábulo **operações** consiste em atos jurídicos, regulados pelo Direito como produtores de determinada eficácia jurídica. Geraldo Ataliba determina que **não se trata de qualquer operação realizada que se sujeita ao ICMS**. Destas operações apenas poderão ser tributadas as que digam respeito à **circulação atinente a uma especial categoria de bens: as mercadorias**.

Somente terá relevância jurídica aquela **operação mercantil** que acarrete a **circulação de mercadoria**, como meio e forma de transferir-lhe a titularidade. Para que sofram incidência de ICMS, **é imprescindível que a circulação ocorra sobre as mercadorias**.

O **bem salvo de sinistro** já não mais integra a cadeia produtiva, cujo último elo foi a venda do bem ao consumidor final, **encerrando-se definitivamente com o sinistro**. Sua **destinação posterior não é capaz de lhe conferir o predicado de mercadoria**, porque não é produzida ou adquirida com o intuito de venda ou revenda, mas apenas em decorrência do dever de sub-rogação assumido pela seguradora.

Por esta razão, o STF editou a Súmula Vinculante 32:

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

A comercialização dos denominados *softwares* de prateleira possui **incidência de ICMS**, afastando tal incidência quando o *software* for desenvolvimento de maneira personalizada para um encomendante.

O **fornecimento de água** poderá ter incidência de ICMS ou não. Nos casos de **água mineral engarrafada**, temos uma **mercadoria**, sujeita a incidência de ICMS. Diferente da situação referente à **água canalizada**, em que se demonstra a **existência de prestação de serviço público**, podendo ser sujeito a **tributação por taxa** ou a **cobrança mediante tarifa**.

Determina a Súmula 573 do STF:

Não constitui fato gerador do Imposto de Circulação de Mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

Após o advento da EC 33/2001, a CF/1988 assegura, no art. 155, § 2.º, IX, *a*, a **incidência de ICMS sobre a importação de produtos**, mesmo que o particular não seja contribuinte habitual do imposto, **afastando a aplicação da Súmula 660 do STF** e aplicando o disposto na **súmula 661 do mesmo Tribunal**:

Súmula 660 do STF. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.

Ante a inaplicabilidade da súmula, aplica-se o disposto na Súmula 661 do STF, *in verbis*:

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembarço aduaneiro.

b) Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

A incidência do ICMS sobre os **serviços de transporte** engloba a **prestação desses serviços** quando prestados por **pessoas jurídicas de direito privado**, desde que o **serviço seja oneroso**.

Somente ocorrerá a incidência se a relação de transporte tiver, pelo menos, duas pessoas, **não se cogitando a possibilidade de incidência** nos casos de **autotransporte** (transporte de bens da mesma propriedade do titular).

No que diz respeito ao **transporte aéreo de passageiros e cargas**, passa a ser inconstitucional a exigência de ICMS, mesmo ocorrendo efetivamente o transporte interestadual e intermunicipal. Isto porque a formatação da LC 87/1996 que trata sobre as normas gerais inviabiliza a repartição do referido imposto entre os Estados.

Ainda sobre o **transporte aéreo**, primeiro o Senado fixou em **4%** a alíquota incidente sobre a **prestação de serviço de transporte aéreo interestadual**. Depois, o STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.600-8, de dezembro de 2001, **afastou a incidência de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional e sobre o transporte aéreo internacional de cargas**. Por fim, a **prestação de serviços de transporte aéreo de passageiros não está sujeita à incidência do ICMS**.

Não incide ICMS sobre serviços de transporte destinados ao exterior, pela ocorrência de **imunidade tributária específica**, estabelecida no art. 155, § 2.º, X, *a*, CF/1988.

c) Serviços de comunicação

A incidência de ICMS ocorre sobre os serviços de comunicação prestados de **maneira onerosa**, incidindo sobre a **geração, emissão, recepção, transmissão e outros meios de comunicação**.

Entende-se por **comunicação** o processo pelo qual uma informação gerada em um ponto no espaço e no tempo (fonte) é transferida a outro ponto no espaço e no tempo (destino).

A **telecomunicação** passa a ser o nome conferido para a transmissão, emissão ou recepção, seja por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.

A Lei 9.472/2007 dispõe sobre a **organização dos serviços de telecomunicações**, indicando todas as espécies de regulação do serviço, seja em regime jurídico de direito público ou privado.

Para que haja incidência de ICMS, o serviço de telecomunicação deve ser prestado de forma **onerosa**, uma vez que a prestação de serviço gratuita, mesmo quando iniciada no exterior, é considerada **imune para os efeitos de incidência de**

ICMS (art. 155, § 2.º, X, *d*, da CF/1988).

Atividades meramente preparatórias de comunicação não geram a incidência de ICMS. É o caso da atividade de **habilitação de serviços de telefonia** ou de **TV a cabo** (no caso de habilitação, tão somente, e não nos casos de transmissão de comunicação propriamente dita, vez que haverá incidência de ICMS), já substanciada na súmula 350 do STJ:

Súmula 350 do STJ. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.

O **provedor de acesso à internet** também não se configura como serviço de comunicação propriamente dito, passando a ser considerado como serviço de valor adicionado, inexistindo o fato típico tributável.

Reza a Súmula 334 do STJ:

O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet.

Tratando-se de telefonia, o **fato gerador do ICMS** é a **disponibilização de linha em favor do usuário que contrata**, onerosamente, os serviços de comunicação de uma determinada operadora. A **inadimplência** e o **furto por clonagem** acabam fazendo parte dos **riscos da atividade econômica**, que **não podem ser transferidos ao Estado**. Assim, além da incidência do ICMS nos serviços de telefonia, inexistem qualquer previsão legal que permita a **compensação tributária de ICMS em serviços de telefonia** que **não são pagos pelo usuário inadimplente** ou cujo **sinalel tenha sido furtado ou clonado**, prática comum nos aparelhos celulares.

Assim, mostra-se imprescindível:

- (i) que exista uma **relação comunicativa** (formada por cinco elementos: emissor receptor, meio de transmissão, código e mensagem transmitida);
- (ii) que a comunicação seja viabilizada por um terceiro, mediante remuneração.

Existem algumas atividades específicas que geram dúvidas acerca de sua caracterização como serviço de comunicação ou como serviço de natureza diversa.

Tomem-se os exemplos da **TV por assinatura** e do **serviço de radiochamada**. Ambos são **tributados pelos Estados**, que neles vislumbram – com acerto – a

prestação de serviços de comunicação, mas também o são pelos Municípios, que entendem – equivocadamente – haver a predominância de atividades que se subsumem a itens da lista de serviços alcançados pelo ISS, nos termos do Anexo à LC 116/2003.

Outrossim, os intitulados **serviços de valor adicionado** (serviços autônomos, que somente se utilizam da rede de telecomunicações para ser prestados, como no caso do “102 – auxílio à lista”) também são alvo de bitributação. Os Estados cobram o ICMS relativamente a essas atividades, ao passo que os Municípios exigem o ISS nas mesmas atividades.

d) Importação de bens e serviços

O ICMS também incide na importação de bens e serviços do exterior, conforme sinaliza o art. 155, § 2.º, IX, *a*, da CF/1988:

Art. 155 (...)

§ 2.º (...)

IX – incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço (...).

Tal posicionamento adotado pelo legislador após o advento da EC 33/2001 afasta o entendimento anterior adotado pelo STF, por meio da Súmula 660:

Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.

Adequando-se ao disposto na modificação constitucional, edita o STF a Súmula 661, não fazendo mais qualquer distinção de que tipo de pessoa está promovendo a importação, seja física ou jurídica, contribuinte habitual ou não do imposto, seja para consumo ou venda:

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Em se tratando de mercadoria importada do exterior, temos o advento da Súmula Vinculante 48, que reza:

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

3.2.2.2 Aspecto espacial

Para definição do aspecto espacial, devemos levar em conta o **Estado onde ocorre a operação** ou a **prestação de serviços**.

Determina o art. 11 da LC 87/1996:

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I – tratando-se de mercadoria ou bem:

- a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador;
- b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;
- c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado;
- d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física;
- e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido;
- f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou

abandonados;

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização;

h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial;

i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos;

II – tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso XIII do art. 12 e para os efeitos do § 3.º do art. 13;

III – tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12;

c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;

d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;

IV – tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o

do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

§ 1.º O disposto na alínea c do inciso I não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que não o do depositário.

§ 2.º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada.

§ 3.º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:

I – na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;

II – é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

III – considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante e na captura de pescado;

IV – respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular.

§ 5.º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

§ 6.º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes

iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador.

De acordo com a EC 87/2015, que realizou a alteração no art. 155, § 2º, VII, da CF, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final que esteja localizado em outro Estado, deve ser adotada a **alíquota interestadual**, cabendo ao Estado de **localização do destinatário** a diferença entre as alíquotas interna e interestadual:

Art. 155 (...)

§ 2º (...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

Assim, têm-se que, em se tratando de operações interestaduais, quaisquer diferenças entre base de cálculo e alíquota do ICMS serão devidas para o **Estado de destino** (consumidor final), não importando se será utilizado para uso próprio, venda ou revenda.

3.2.2.3 Aspecto temporal

O **momento da efetiva ocorrência do fato gerador** leva em consideração o disposto no art. 12 da LC 87/1996:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

- II – do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;
- III – da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;
- IV – da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;
- V – do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;
- VI – do ato final do transporte iniciado no exterior;
- VII – das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
- VIII – do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:
 - a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
 - b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;
- IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior;
- X – do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;
- XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados;
- XII – da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;
- XIII – da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação

se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente.

§ 1.º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.

§ 2.º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.

§ 3.º Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto.

In casu, a Lei Kandir estabelece, no seu bojo, o momento da ocorrência do respectivo fato gerador em todas as matrizes de incidência tributária, não gerando quaisquer dúvidas nas respectivas operações e prestações de serviços.

3.2.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** será o **DF** ou o **Estado** em que ocorrer a efetiva **operação ou a prestação de serviços de transporte e comunicação**, conforme analisado no critério espacial (art. 11 da LC 87/1996), observando-se o disposto na CF, após o advento da EC 87/2015.

Nos casos de **importação de bens ou serviços**, a jurisprudência dominante entende que é devido o ICMS no **Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria**, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de um Estado diverso. Assim, caso a mercadoria entre pelo Porto de Santos, mas o seu destino final seja Minas Gerais, é

devido o imposto para o Estado das Minas Gerais.

É o que determina o art. 155, § 2º, IX, *a*, da CF:

Art. 155 (...)

IX – incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço.

O sujeito passivo do ICMS é o contribuinte ou o responsável, consignados de acordo com o art. 4º da LC 87/1996:

Art. 4.º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

- I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade;
- II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;
- III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;
- IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro

Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização.

Além da fixação do contribuinte, o ICMS admitirá **responsabilidade tributária pelo seu adimplemento**, sempre observando a determinação imposta a cada um dos Estados, por meio de sua legislação estadual.

A LC 87/1996 **não determina quais as pessoas que serão consideradas responsáveis**, apenas indicando que em tais situações pertencem ao âmbito de **competência de cada um dos Estados da federação**:

Art. 5.º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Art. 6.º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

§ 1.º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

§ 2.º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

Art. 7.º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

3.2.2.5 Aspecto quantitativo

A **base de cálculo do ICMS** pode ser determinada pelo **valor da operação mercantil, o preço dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação**, sempre que forem ocorridos de **forma onerosa**, uma vez que a gratuidade gera situação de **imunidade tributária**.

Somente devem **integrar a base de cálculo os valores que são inerentes às mercadorias ou a prestação de serviços**, podendo, inclusive, incidir sobre o valor da tarifa de energia elétrica, conforme se vê na Súmula 391 do STJ:

O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

Os valores relativos aos **descontos** sempre implicam **diminuição do preço das mercadorias**, mas **nem sempre acarretam a redução na base de cálculo**, a menos que sejam os **descontos considerados incondicionais**. Assim, se um empresário do ramo de eletrônicos vende um aparelho mais barato à vista do que no pagamento em cheques, esse desconto será **condicional apenas ao pagamento à vista**, sendo a incidência do valor de ICMS sobre o montante total. Porém, quando se trata de descontos **incondicionados**, a jurisprudência é pacífica pela exclusão do desconto na base de cálculo do ICMS:

Súmula 457 do STJ: Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.

No que diz respeito aos **encargos relativos ao financiamento do preço nas vendas efetuadas a prazo**, tais encargos **não se incluem na base de cálculo do ICMS**, apesar de a jurisprudência diferenciar, para fins de exclusão ou não, as **vendas realizadas com cartão de crédito**.

Isto porque nas vendas que ocorrem com cartões de crédito ocorre apenas uma **operação cujo preço é pago em mais de uma parcela diretamente pelo comprador**, não podendo ser aplicado o mesmo raciocínio para exclusão dos encargos de financiamento.

No que se diz respeito às **alíquotas do ICMS**, temos a análise estabelecida, inicialmente, na CF/1988:

Art. 155 (...)

§ 2.º (...)

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais;

VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (...).

Segundo ensina José Eduardo Soares de Melo, o ICMS deve ser recolhido pel

alíquota interna no Estado onde saiu a mercadoria para o consumidor final, após a emissão de sua fatura, ainda que tenha sido negociada a venda em outro local, por meio da empresa filial.

Aponta ainda que as **construtoras que adquirem material em Estado que institui a alíquota de ICMS mais favorável** não estão compelidas, ao utilizarem essas mercadorias como insumos em suas obras, à **satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário**, uma vez que, em regra, são **contribuintes de ISS**.

Nas **operações internas**, nas **operações de importações** e nos **serviços prestados no exterior**, em regra, os Estados fixam as **alíquotas entre 18% ou 17%**, enquanto nas **prestações de serviços de comunicação e fornecimento de energia elétrica** giram em torno de **25%**.

Segundo determinação constitucional, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a **alíquota interestadual** e caberá ao **Estado de localização do destinatário** o imposto correspondente à **diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual** (comumente denominada DIFAL).

3.2.2.6 Demais características

A CF/1988, em seu art. 155, § 2.º, determina alguns outros aspectos importantes para o ICMS:

I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II – a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das

mercadorias e dos serviços (...).

O primeiro aspecto diz respeito à aplicação do **regramento da não cumulatividade**. Esta consiste na **possibilidade de se compensar valores creditados com valores debitados em determinado espaço de tempo**. Tal situação visa diminuir o impacto nos encargos finais sobre o consumidor final.

Verifique abaixo, na Tabela 1, como funciona a não cumulatividade do ICMS em três operações de venda:

Tabela 1. Não cumulatividade do imposto em três operações de venda.

Venda	Compra	Valor da Mercadoria	Débito	Crédito	ICMS a Recolher
A	B	R\$ 100.000	R\$ 18.000	-	R\$ 18.000
B	C	R\$ 200.000	R\$ 36.000	R\$ 18.000	R\$ 18.000
C	D	R\$ 300.000	R\$ 54.000	R\$ 36.000	R\$ 18.000
Totais		R\$ 600.000	R\$ 108.000	R\$ 54.000	R\$ 54.000

Dependendo do **Estado de origem e destino**, as alíquotas serão diferentes para poder beneficiar as regiões menos desenvolvidas economicamente, como mostra a Tabela 2:

Tabela 2. Alíquota para operações interestaduais de circulação de mercadorias emprego da alíquota interestadual.

Estado de Origem	Operação Interestadual	Estado Destino
Região	Alíquota Interestadual	Região
Regra Geral: Qualquer Região	12,00%	Sudeste e Sul
Regra dos Desiguais: Sudeste e Sul	7,00%	Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ES
Regra dos Iguais: Norte, Nordeste e Centro-Oeste	12,00%	Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ES

A existência da não cumulatividade fez com que os Estados, por meio de autorização constitucional, estabelecessem um regime de **responsabilidade por substituição** (denominada de **substituição tributária**).

O **objetivo principal** de a **substituição tributária** ter sido instituída no ordenamento jurídico foi **buscar facilitar a fiscalização tributária**, com a possibilidade de **antecipar ou postergar o recolhimento do tributo** para esse fim.

A substituição tributária é para o Estado uma forma de **facilitar a operacionalização do imposto e sua arrecadação**. Assim, começou uma discussão

sobre a retenção do ICMS na fonte, onde o fabricante, ao vender para o comerciante já deve reter o imposto, quando o mesmo ainda será vendido no futuro, ou seja, **antes do fato gerador** (denominada de **substituição tributária progressiva**).

A **substituição tributária** é dividida em **três modalidades**:

- ✓ a **regressiva ou para trás**: em que terceira pessoa (substituto) assume os encargos do contribuinte (substituído), **após a ocorrência do fato gerador**. Como exemplo, podemos citar uma cooperativa de laticínios que adquire leite de diversos produtores e, para não ocorrer a sonegação do imposto, fica responsável pelo recolhimento do imposto;
- ✓ a **progressiva ou para frente**: quando o terceiro (substituto) assume os encargos tributários do contribuinte (substituído) **antes da ocorrência do fato gerador** (fato gerador presumido). Como exemplo, vemos uma distribuidora de bebidas que, pelo fato de distribuir para inúmeros varejistas, fica responsável pelo recolhimento do imposto devido, sendo assim, ele é o responsável substituto que a lei determina; e
- ✓ **concomitante**: comum nos serviços de transporte intermunicipal e interestadual, em que o tomador do serviço fica responsável pela retenção do ICMS devido, e a transportadora fica na condição de substituído, a retenção do ICMS se dá no início da prestação do serviço.

Na **substituição tributária** existem **dois sujeitos**: o **substituto** e o **substituído**. O substituto pode ser exemplificado pela indústria que fica responsável pelo cálculo e pelo recolhimento do imposto do substituído. O **substituto** é aquele que a lei define como o responsável por recolher o imposto, mas não necessariamente pagar o tributo. No caso do **substituído**, é o contribuinte que teve seu imposto recolhido na etapa anterior.

Para o **substituto** chegar à base de cálculo das mercadorias fornecidas ao **substituído**, a Lei Complementar 87/1996, em seu art. 8º, determina que a **base de cálculo** seja definida pelo **preço de venda ao substituto**, acrescido de **todas as despesas cobradas ou transferidas ao adquirente, somando-se esse total e multiplicando pela margem de valor agregado**, definida de acordo com a mercadoria.

A restituição e ressarcimento do ICMS – ST é um ponto crucial dentro da substituição tributária, devido aos valores pagos do tributo antecipado e que em

muitas vezes não ocorre o fato gerador, que é a venda da mercadoria.

O objetivo da **substituição tributária progressiva** é a **antecipação do valor do ICMS** sobre a mercadoria que chegará até o consumidor final. Para se poder antecipar o ICMS devido, é necessária uma **presunção da mercadoria**, onde se tem uma **margem de valor agregado presumida**. Muitas vezes, a **margem de valor agregado** no produto é **superior ao que mostra a realidade de mercado**, fazendo com que o **substituído seja onerado com o valor da mercadoria, não conseguindo repassar este valor para o consumidor final**.

Nem sempre é possível repassar o valor pago na substituição tributária progressiva para o consumidor final, devido a inúmeros fatores, além de outras razões, como quando **não há concretização do fator gerador presumido**. Por isso, existe o **direito de restituição ou compensação**, dentro das hipóteses admitidas por lei.

Outro fator de suma importância é a **concessão dos benefícios de isenção para ICMS**, vez que dependem da determinação de cada um dos Estados por meio de sua legislação estadual, sem que ocorra afronta às determinações aprovadas pelo **Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)** cabendo a este promover a **celebração de convênios** para o efeito de **concessão ou revogação de isenções de ICMS**. A existência do Confaz tem por único e exclusivo objetivo **minimizar a guerra fiscal**.

O Conselho (Confaz) é constituído por **representantes de cada Estado e do DF, bem como um representante do Governo Federal**.

O Conselho pode, em **assuntos considerados estritamente técnicos**, delegar, de modo expresso, a competência para a **Comissão Técnica Permanente do ICMS—Cotepe/ICMS** para decidir sobre o assunto.

O fenômeno da guerra fiscal pode ser descrito como um caso de **concorrência fiscal predatória**, no qual os Estados-membros e o Distrito Federal utilizam-se da **concessão de benefícios fiscais**, na legislação de ICMS, para **atrair ou conservar investimentos privados** em seus territórios.

Trata-se de uma competição fiscal entre entes federados, levada a cabo com instrumentos tributários genericamente descritos como **benefícios fiscais**.

O cenário de guerra fiscal não alcança, tão somente, os casos de ICMS, podendo se estender para o IPVA e o ISS. Veja-se, por exemplo, a decisão proferida na **ADPF 190**, em que se contestava a **constitucionalidade de lei do Município de Poá (SP)**,

que **reduziu a base de cálculo do ISS** na localidade, e também o **reconhecimento de repercussão geral no ARE 784.682**, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual se discute o **local de pagamento do IPVA**, se em favor do Estado no qual se encontra sediado ou domiciliado o contribuinte ou onde registrado e licenciado o **veículo automotor** cuja propriedade constitui fato gerador do tributo. No entanto, o caso mais grave de concorrência fiscal – seja pela perda de arrecadação, seja pelos demais efeitos econômicos que enseja – é o que se efetiva no âmbito da legislação de ICMS.

Como está claro, a guerra fiscal em matéria de ICMS é fundamentalmente um **conflito federativo**. Essa característica, aliada à rigidez do nosso sistema tributário e à densidade constitucional das disposições ofendidas, fazem do STF o locus preferencial de embate entre os diferentes entes subnacionais. A **maior parte das controvérsias jurídicas suscitadas no âmbito da guerra fiscal de ICMS** diz respeito a **questões constitucionais, a demandar resposta em única ou última instância do Supremo Tribunal Federal**, em sede de **controle de constitucionalidade, abstrato** (e.g., em ADI, ADO ou ADPF) ou **concreto** (e.g., em recurso extraordinário).

Os Estados prejudicados questionam, geralmente por meio de ação direta de inconstitucionalidade, **benefícios fiscais concedidos por outros Estados ou pelo Distrito Federal de maneira unilateral**, em desacordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, do texto constitucional. É o caso, por exemplo, da **ADI 3794**, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, proposta pelo Governador do Estado do Paraná, e da ADI 2157 de relatoria do Ministro Moreira Alves, proposta pelo Governador do Estado de São Paulo.

A lista de espécies de benefícios fiscais abarcada pelas ações é tão ampla quanto o rol previsto no art. 1º da Lei Complementar 24/1975. Inclui: **isenções, redução da base de cálculo, créditos presumidos, previsões de devolução** (direta ou indireta) de ICMS **e qualquer outro incentivo fiscal ou financeiro-fiscal concedido na legislação desse imposto**.

Na **ADI 1179**, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, por exemplo, o Tribunal discutiu a **constitucionalidade da Lei 2.273/1994 do Estado do Rio de Janeiro**, que estabelecia **prazo especial para pagamento do ICMS de cinco anos**, além reduzir em **40% a correção monetária aplicável no período**.

Entre as ações que ainda aguardam julgamento no STF está a **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 198**, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, em face dos arts. 2º, § 2º, e 4º da Lei Complementar 24/1975, que

preveem **deliberação unânime para concessão de benefícios fiscais em matéria de ICMS e ratificação tácita dos convênios**, se transcorrido *in albis* o prazo legal.

Na inicial, argumenta-se que a **unanimidade para concessão de benefícios fiscais** violaria o **princípio democrático** (arts. 1º e 3º), a **autonomia dos entes federativos** e o **princípio da proporcionalidade**. A deliberação unânime, segundo aduz o requerente, **não respeita a vontade da maioria**, na medida em que **concede a qualquer Estado-membro a capacidade de impor unilateralmente sua vontade**, por meio do **poder de veto** que a exigência de votação uníssona implica.

Quanto à questão de fundo trazida na ADPF, pode-se afirmar, em síntese, que a Corte se vê diante de **três caminhos de interpretação**. O **primeiro** é declarar que a **exigência de unanimidade simplesmente é incompatível com a ordem constitucional em vigor** e, por conseguinte, **não foi recepcionada**. Isso significa afirmar que o quórum de unanimidade estaria **fora da margem de discricionariedade política do legislador**, e, por isso, não pode ser adotado pela legislação editada com base no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição.

O **segundo** é adotar a **orientação radicalmente oposta e entender que a unanimidade não apenas é compatível como a Constituição em vigor**, mas é, na verdade, **obrigatória**, por conta do **perfil nacional do ICMS**. Seria **inválido**, segundo essa leitura, a escolha de **qualquer outro quórum de deliberação**.

A **terceira** via é **intermediária**. Toma a exigência de deliberação unânime como uma das opções legislativas válidas que podem ser adotadas pelo legislador. Não é obrigatória nem proibida.

Outra matéria que também aguarda julgamento no STF é a **avaliabilidade de adoção de medidas unilaterais de retaliação por Estado-membro em face de benefícios fiscais concedidos de forma irregular por outros entes federados**, na forma de **anulação unilateral dos créditos** – “**glosa de créditos**” – decorrentes de **benefícios fiscais concedidos por outras unidades federativas** sem a observância do previsto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. A chamada “**glosa de créditos**”, no jargão fiscal, significa a **invalidação dos créditos relativos às operações anteriores** (entradas), **não mais podendo ser abatidos nas operações subsequentes** (saídas), a despeito do que determina o preceito constitucional da não cumulatividade.

Até recentemente, o STF **não modulava os efeitos das decisões em que declara a inconstitucionalidade de benefícios fiscais estaduais concedidos de forma**

unilateral, em desacordo com o procedimento previsto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. As ações eram julgadas com eficácia *ex tunc*, ao fundamento de que **restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade**, segundo entendia o Supremo, poderia **estimular ainda mais a concorrência fiscal predatória entre os Estados-membros**.

Porém, em agosto de 2017, foi publicada a LC 160, que trouxe regras para a **remissão e a posterior reinstituição dos créditos tributários de ICMS decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais** concedidos em **desacordo com o disposto na Constituição Federal**, determinando que o Confaz, dentro do prazo de **até 180 dias contados da data de sua publicação**, deveria aprovar **convênio remetindo os créditos tributários, reinstituindo os benefícios fiscais** e disciplinando as demais regras contidas na Lei Complementar, realizado por meio do Convênio 190/2017.

A primeira crítica que se pode fazer à LC 160/2017 é a de que ela, ao invés de tentar pôr um fim à guerra fiscal, simplesmente **previu seu alongamento por prazo que pode chegar a até 15 anos**, não exigindo qualquer contrapartida das unidades federadas, e que tem como requisito somente a **necessidade de que haja a disponibilização da informação de quais benefícios foram reinstituídos**.

Nos termos do Convênio, foram **remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS**, constituídos ou não, **decorrentes dos benefícios fiscais instituídos**, por legislação estadual ou distrital **publicada até 8 de agosto de 2017**, em desacordo com a CF (alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155), **inclusive os desconstituídos judicialmente**.

Também serão **remitidos e anistiados** os benefícios, no período de 8 de agosto de 2017 até a data da reinstituição, desde que a reinstituição não ultrapasse 28 de dezembro de 2018, decorrentes de:

a) **concessão pela unidade federada a contribuinte localizado em seu território**, com base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017, observadas suas condições e limites;

b) **prorrogação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo**;

c) **modificação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo**, para reduzir-lhe o alcance ou montante.

O convênio também destaca que a **remissão** e a **anistia** ficam condicionadas à **desistência**:

I – de **ações ou embargos à execução fiscal** relacionados com os respectivos créditos tributários, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a **quitação integral pelo sujeito passivo das custas e demais despesas processuais**;

II – de **impugnações, defesas e recursos** eventualmente apresentados pelo sujeito passivo **no âmbito administrativo**;

III – pelo advogado do sujeito passivo da **cobrança de eventuais honorários de sucumbência da unidade federada**.

A s **alíquotas** ainda poderão ser **seletivas**, visando à **essencialidade da mercadoria para o consumo**, buscando **estimular o consumo de produtos essenciais** e **desestimular o consumo de produtos supérfluos**.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula Vinculante 32: O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

Súmula 662 do STF:É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas de videocassete.

Súmula 661 do STF:Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembarço aduaneiro.

Súmula 659 do STF: É legítima a cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

Súmula 573 do STF:Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

Súmula 571 do STF: O comprador de café ao IBC, ainda que sem

expedição de nota fiscal, habilita-se, quando da comercialização do produto, ao crédito do ICM que incidiu sobre a operação anterior.

Súmula 546: Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo.

- “O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário. (...) o Colegiado concluiu que a tarifa de assinatura básica mensal não é serviço, mas a contraprestação pelo serviço de comunicação propriamente dito, prestado pelas concessionárias de telefonia e consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS. Asseverou que a ausência de franquia de minutos vinculada ao preço cobrado e, assim, de efetiva comunicação entre o usuário e terceiro é irrelevante e não descaracteriza o serviço remunerado pelo valor da assinatura básica mensal como serviço de comunicação. Acrescentou que o que a Constituição Federal autoriza os Estados e o Distrito Federal a tributar não é exatamente o transporte transmunicipal, a comunicação ou quaisquer outros serviços, mas as prestações onerosas desses serviços” (RE 912.888, rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.10.2016).
- “(...) não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica” (RE 540.829, rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11.09.2014, *DJE* 18.11.2014, com repercussão geral).
- “Tributário. ICMS. Habilitação de aparelhos celulares. A lei geral de telecomunicações (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997) não prevê o serviço de habilitação de telefonia móvel como atividade-fim, mas atividade-meio para o serviço de comunicação. A atividade em questão não se inclui na descrição de serviços de telecomunicação constante do art. 2º, III, da LC 87/1996, por corresponder a procedimento tipicamente protocolar, cuja finalidade refere-se

a aspecto preparatório. Os serviços preparatórios, tais como habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e equipamento, entre outros, que configuram atividade-meio ou serviços suplementares, não sofrem a incidência de ICMS, posto serviços disponibilizados de sorte a assegurar ao usuário a possibilidade do uso do serviço de comunicação, configurando aqueles tão somente atividades preparatórias destes, não incidem ICMS. Inocorrência de violação aos arts. 2º; 150, I; e 155, II, da CF/1988” (RE 572.020, rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.02.2014, *DJE* 13.10.2014).

- “Lei Complementar 87/1996. Constitucionalidade. Mostra-se harmônica com a CF a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre” (ADI 2.669, rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.02.2014 *DJE* 06.08.2014).
- “O fornecimento de água potável por empresas concessionárias desse serviço público não é tributável por meio do ICMS. As águas em estado natural são bens públicos e só podem ser exploradas por particulares mediante concessão, permissão ou autorização. O fornecimento de água tratada à população por empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas não caracteriza uma operação de circulação de mercadoria” (RE 607.056, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10.04.2013, *DJE* 16.05.2013, com repercussão geral).
- “(...) o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS” (ADI 4.389 MC, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 13.04.2011, *DJE* 25.05.2011).
- “O perfil constitucional do ICMS exige a ocorrência de operação de circulação de mercadorias (ou serviços) para que ocorra a incidência e, portanto, o tributo não pode ser cobrado sobre operações apenas porque elas têm por objeto ‘bens’, ou nas quais fique descaracterizada atividade mercantil-comercial” (ADI 4.565 MC, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 07.04.2011, *DJE* 27.06.2011).
- “O STF fixou entendimento no sentido da ilegitimidade da cobrança de ICMS

sobre água encanada, uma vez que se trata de serviço público essencial e não mercadoria. Precedentes” (AI 682.565 AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª T., j. 23.06.2009, *DJE* 07.08.2009).

- “Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Base de incidência reduzida. Sistema opcional. Sendo opcional o sistema a envolver base do tributo reduzida, não se tem violência ao princípio da não cumulatividade no que considerado o crédito de forma proporcional” (RE 477.323, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16.10.2014, *DJE* 10.02.2015).
- “A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da Constituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado” (RE 439.796, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.11.2013, *DJE* 17.03.2014, com repercussão geral).
- “A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2º, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais” (RE 606.107, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.05.2013, *DJE* 25.11.2013, com repercussão geral).
- “A jurisprudência desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, nas operações interestaduais, o creditamento do ICMS na operação subsequente deve corresponder ao montante que foi efetivamente recolhido na operação anterior” (RE 491.653 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T. j. 08.05.2012, *DJE* 21.05.2012).

3.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

3.3.1 Previsão legislativa

O **Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)** é um imposto de competência estadual e do DF, conforme reza o art. 155, III, e § 6.º, da CF/1988.

Trata-se de um imposto relativamente novo, vez que foi inserido no ordenamento

constitucional pela EC 27/1985. Sua origem teve início quando do surgimento da taxa remuneratória de serviço, denominada **Taxa Rodoviária Federal**, instituída pela Constituição da República de 1967, cujo regime autorizava a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cobrarem taxas pelo uso de determinados serviços, dentre eles o uso de suas rodovias. Com o **Decreto-lei 999/1969**, o Governo Federal **aboliu a possibilidade de concomitância de taxas rodoviárias federal, estaduais e municipais**, criando assim a **Taxa Rodoviária Única**.

Já em 1969 surgiu **Taxa Rodoviária Única (TRU)**, que gravava a **propriedade de veículos automotores** pelos seus **valores** e de sua **procedência**. Possuía um **efeito extrafiscal**, favorecendo alguns tipos de veículos como os movidos a **álcool carburante**, sendo partilhado seu recolhimento entre os Estados e a União. Sua forma de cobrança era feita **anualmente**, por força da vistoria e licenciamento dos veículos pelo Departamento de Trânsito (Detran).

Inexistem normas gerais previstas no Código Tributário Nacional e em outra lei complementar nacional. Por essa razão, em observância ao disposto no art. 24, § 3.º, da CF/1988, pela ausência da lei federal, os Estados exercerão sua competência legislativa plena.

3.3.2 Regra-matriz de incidência tributária

3.3.2.1 Aspecto material

O IPVA incide sobre a **propriedade de veículos automotores**, não se estendendo para os casos de **posse ou detenção do domínio útil**.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) traz em seu art. 96 a **classificação de veículos**, de onde podemos extrair que **veículos automotores** são aqueles dotados de **motor próprio e capazes de se locomover em virtude do impulso** (propulsão) ali produzido.

A jurisprudência determina que sobre **aeronaves e embarcações não há incidência de IPVA**.

O **conceito de aeronave** está previsto no art. 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986):

Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em

voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.

Já o **conceito de embarcação** resta previsto no art. 11, parágrafo único e suas alíneas, do Tribunal Marítimo (Lei 2.180/1954):

Art. 11. Considera-se embarcação mercante toda construção utilizada como meio de transporte por água, e destinada à indústria da navegação, quaisquer que sejam as suas características e lugar de tráfego.

Parágrafo único. Ficam-lhe equiparados:

- a) os artefatos flutuantes de habitual locomoção em seu emprego;
- b) as embarcações utilizadas na praticagem, no transporte não remunerado e nas atividades religiosas, científicas, beneficentes, recreativas e desportivas;
- c) as empregadas no serviço público, exceto as da Marinha de Guerra;
- d) as da Marinha de Guerra, quando utilizadas total ou parcialmente no transporte remunerado de passageiros ou cargas;
- e) as aeronaves durante a flutuação ou em voo, desde que colidam ou atentem de qualquer maneira contra embarcações mercantes.

A Constituição Federal, ao determinar o **critério material do IPVA**, não foi específica a ponto de incluir as aeronaves e embarcações, não seria suficiente para o afastamento do referido imposto.

As autoridades federais responsáveis pela **execução das normas sobre a navegação aérea e sobre o meio híbrido** seguem o mesmo entendimento da **não incidência do IPVA** nas aeronaves e embarcações, além de que inexistente registro dos

navios e aeronaves nos Estados e Municípios.

Mesmo que o veículo seja furtado ou destruído, tais fatos não são suficientes para o afastamento do IPVA. Nada obsta, entretanto, de a lei estadual conceder remissões nestes casos.

3.3.2.2 Aspecto espacial

O local da ocorrência do fato gerador será o **local onde o veículo esteja licenciado**, conforme vemos no art. 120 da Lei 9.503/1997:

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

Inexiste na Constituição da República ou em lei federal regra explícita a respeito do **critério espacial a ser utilizado pelos Estados e pelo Distrito Federal no IPVA**, mas esta regra pode ser inferida por meio de uma **interpretação sistemática do ordenamento jurídico**.

Há regras jurídicas que trazem expressos os locais em que o fato deve ocorrer, a fim de que irradie os efeitos que lhe são característicos. Outras, porém, nada mencionam, carregando implícitos os indícios que nos permitem saber onde nasceu o laço obrigacional. É uma opção do legislador.

Apesar de não haver previsão expressa do critério espacial do IPVA na Constituição ou em norma nacional, como já destacado, seus moldes **podem ser deduzidos por uma interpretação histórico-sistemática do ordenamento jurídico brasileiro**.

Partindo-se da **interpretação histórica**, sabe-se que a já extinta Taxa Rodoviária Única (TRU), precursora do atual IPVA, **era cobrada previamente ao registro de veículo ou à renovação anual da licença para circular**. O critério espacial escolhido pelo legislador de outrora, destarte, era o **local do registro ou da renovação da licença para circular**.

O **registro e licenciamento** são, por conseguinte, **obrigatórios**, devendo ser efetuados perante o **órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal**

(DETRAN), no **Município de domicílio ou residência de seu proprietário**. Fica então impossibilitado o contribuinte de registrar seu veículo no DETRAN de Estado no qual não possua domicílio ou residência, por expressa imposição legal. Aquele que declara **falso domicílio para registrar ou licenciar seu veículo** incorre ainda em **sanção administrativa**, esboçada no art. 242 do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, conjugando a determinação da Constituição da República de que os Municípios fazem jus à metade da receita do IPVA sobre os veículos licenciados em seus territórios, juntamente às disposições do Código de Trânsito Brasileiro, do Código Tributário Nacional e do Código Civil, chega-se à conclusão de que o critério espacial do IPVA deve ser, necessariamente, o **local do registro e licenciamento do veículo**, sendo que este só poderá ser feito onde o **contribuinte estiver domiciliado**.

3.3.2.3 Aspecto temporal

O IPVA possui o denominado **fato gerador continuado**, perdurando sua incidência durante o tempo, enquanto o contribuinte for o proprietário do veículo. Assim, o **fato gerador ocorre em 1.º de janeiro de cada exercício financeiro**.

3.3.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** será o **DF ou o Estado em que o veículo tenha sido licenciado**, nos termos do art. 120 da Lei 9.503/1997.

O **sujeito passivo** será o **proprietário do veículo**. Na condição de responsáveis, podem figurar o **adquirente**, em relação ao bem adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou dos exercícios anteriores, e o **titular do domínio útil ou possuidor** enquanto estiver na posse do veículo.

Caso o veículo seja **arrematado em hasta pública**, tal negócio jurídico é forma de **aquisição originária de propriedade**, razão pela qual os **débitos anteriores à arrematação se sub-rogam ao preço pago no lance**, não devendo a responsabilidade recair sobre o arrematante (art. 130, parágrafo único, do CTN).

3.3.2.5 Aspecto quantitativo

A **base de cálculo** é o **valor venal do veículo**. Tratando-se de **veículos novos**, a **base de cálculo** será o **preço constante na nota fiscal**, sendo o pagamento do IPVA proporcional ao número de meses restantes ao exercício fiscal, calculando-se a partir

da data da aquisição.

Nos casos de **veículos usados**, a legislação estadual expedirá uma **tabela de valores venais**, levando inúmeros fatores em consideração, tais como marca, modelo, espécie, ano de fabricação, procedência, tipo de combustível etc.

As **alíquotas** poderão ser **diferenciadas em função do tipo** e da **utilização do veículo**, **não podendo haver distinção entre veículos nacionais e importados**, sob pena de afronta ao **princípio da não diferenciação** (art. 152 da CF/1988).

JURISPRUDÊNCIA

- “Processual Civil e Tributário. IPVA. Aeronaves e embarcações. Não incidência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vício formal Ausência de indicação da hipótese autorizadora do recurso. Superação do vício, quando da leitura das razões for possível inferi-la. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 525382 AGR, Rel. Min. Teori Zavascki).
- “Repercussão Geral – IPVA – Local de Recolhimento – Artigos 146, incisos I III, e 155, inciso III, da Carta da República. Possui repercussão geral controvérsia acerca do local a ser pago o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, se em favor do estado no qual se encontra sediado ou domiciliado o contribuinte ou onde registrado e licenciado o veículo automotor cuja propriedade constitui fato gerador do tributo” (ARE 784682 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.03.2014, processo eletrônico *DJe*-078, divulg. 24.04.2014, public. 25.04.2014).
- “Em arrendamento mercantil, a arrendante é responsável solidária para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ela possuidora indireta do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto. Precedentes” (Edcl no Aresp 207.349/SP).
- “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a responsabilidade da arrendante possuidora indireta do veículo, é solidária, razão pela qual é perfeitamente possível figurar no polo passivo da execução fiscal.” Precedentes: REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, 2.^a T., j. 12.8.2008, *DJe* 2.9.2008; REsp 897.205/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2.^a T., j. 15.3.2007, *DJ* 29.3.2007, p. 253; REsp 868.246/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1.^a T., j. 28.11.2006 *DJ* 18.12.2006, p. 342.

→ “Tributário. IPVA. Arrendamento Mercantil. Responsabilidade Solidária Arrendante. 1. O arrendante, por ser possuidor indireto do bem e conservar a propriedade até o final do contrato de arrendamento mercantil, é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA, nos termos do art. 1.º, § 7.º, da Lei Federal 7.431/1985”. Precedentes: REsp 897.205/DF, Rel. Min. Humberto Martins, *DJU* de *DJU* 29.03.2007; REsp 868.246/DF; Rel. Min. Francisco Falcão, *DJU* 18.12.2006. 2. Recurso especial provido (REsp 744.308/DF).

IMPOSTOS MUNICIPAIS

4.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)



4.1.1 Previsão Legislativa

O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) é um imposto de competência municipal e do DF, previsto no art. 156, I e § 1.º, da CF/1988.

A CF/1988 dispõe no art. 182, § 4.º, II, sobre a **progressividade extrafiscal do IPTU**, e o CTN, em seus arts. 32 a 34, dispõe sobre as normas gerais do referido imposto.

Temos dispositivos previstos no **Estatuto da Cidade** (Lei 10.257/2001), versando sobre a política urbanística.

4.1.2 Regra-Matriz de Incidência Tributária

4.1.2.1 Aspecto material

A **incidência tributária** recai sobre a **propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel**, seja por **natureza ou acessão física**, desde que localizado em **zona urbana do Município**.

Para definição da **zona urbana**, a lei municipal estabelecerá critérios demonstrando a existência de melhoramentos urbanos, estabelecidos em, pelo menos, dois incisos do art. 32, § 1.º, do CTN.

Reza o art. 32, § 1.º, do CTN:

Art. 32 (...)

§ 1.º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II – abastecimento de água;

III – sistema de esgotos sanitários;

IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado”.

O **direito de propriedade** vem estabelecido no art. 1.228 do CC/2002:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Temos o conceito de **posse** estabelecido nos arts. 1.196 e 1.197 do CC/2002:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

O denominado **domínio útil** compreende os direitos de utilização e de disposição, assim como a alienação. Apesar de o atual Código Civil (Lei 10.406/2002) ter proibido a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, permanece como direito adquirido as enfiteuses que já se encontram em vigor.

Atualmente, as **enfiteuses** foram substituídas pelo **direito de superfície**, nos termos do art. 1.369 do CC/2002:

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Com relação à determinação do que se considera **bem imóvel para fins de incidência de IPTU**, os arts. 79 a 81 do CC/2002 estabelecem:

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:

I – os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;

II – o direito à sucessão aberta.

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:

I – as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local;

II – os materiais provisoriamente separados de um prédio, para

nele se reempregarem.

A **acessão física** compreende a **formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de álveo**, bem como as **plantações e construções**, conforme determina o art. 1.248 do CC/2002:

Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I – por formação de ilhas;

II – por aluvião;

III – por avulsão;

IV – por abandono de álveo;

V – por plantações ou construções.

Nas áreas consideradas como **expansão urbana**, de acordo com a lei municipal, também **ocorre a incidência de IPTU**, mesmo que **não tenham todos os melhoramentos** estabelecidos no art. 32, § 1.º, do CTN.

Também **incide o IPTU** sobre os denominados **sítios de recreio**, mesmo que **não sejam dotados de melhoramentos** previstos no art. 32, § 1.º, do CTN. Tal interpretação deve ser feita pela observância do art. 32, § 2.º.

Ademais, a jurisprudência pátria reconheceu a **validade do Decreto-lei 57/1966** para determinação da **incidência de ITR**, mas não de IPTU, para os **imóveis situados em zona urbana**, mas que possuam como atividade-fim a **exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial**.

4.1.2.2 Aspecto espacial

Por ser imposto municipal, a incidência do IPTU ocorrerá no **Município do local da situação do bem**.

Assim, faz-se necessário que a propriedade territorial ou predial esteja **circunscrita no território do Município** onde se verifica o fato gerador, levando-se em consideração a **base geográfica**.

Parece-nos claro que o legislador, ao fixar área de sua competência por imposição da lei, estabeleceu também a competência da União, uma vez que,

inicialmente, o Município manifesta sua competência para que depois a União realize suas delimitações, objetivando homenagear a autonomia municipal.

4.1.2.3 Aspecto temporal

O imposto predial e territorial urbano (IPTU) possui **o fato gerador continuado**, perdurando-se no tempo enquanto de propriedade do contribuinte.

Assim, coube ao legislador determinar que o **momento do fato gerador** ocorre em **1.º de janeiro de cada ano**, por ficção jurídica.

4.1.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** do IPTU é o **Município ou DF** onde estiver situado o **bem imóvel**, em área considerada como urbana.

O **sujeito passivo** se subdividirá em **contribuinte** ou **responsável**.

De acordo com a normatização geral estabelecida no CTN:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Tratando-se do **proprietário**, a incidência e a discussão jurídica sobre a incidência parecem-nos pacificadas. No que tange ao **titular do domínio útil**, este ficará obrigado a satisfazer os impostos e os ônus reais que gravam o imóvel. O **superficiário** também poderá figurar como **contribuinte**, uma vez que **responderá por todos os encargos e tributos que recaírem sobre o imóvel**.

A jurisprudência corrobora no sentido de que o **possuidor**, na qualidade de **promitente comprador**, pode ser considerado como **contribuinte do IPTU com o proprietário do imóvel**.

Temos, porém, algumas figuras jurídicas que estão **excluídas do conceito de contribuintes**: o **usuário ou titular do direito de habitação** (uma vez que apenas usa e percebe os frutos quando o exigirem as suas necessidades e as de sua família, não possuindo propriedade nem posse); o **locatário, arrendatário e comodatário** (uma vez que só possuem a posse direta e, mesmo que se obriguem em contrato, não estão

obrigados ao seu cumprimento pela lei); o **detentor** ou quem exerce a posse em nome de outrem etc.

Já fora pacificado no STJ que cabe à **legislação municipal** estabelecer o **sujeito passivo do IPTU**, conforme Súmula 399.

Sem embargo, o **adjudicante**, na qualidade de **adquirente**, torna-se **obrigado ao pagamento dos tributos incidentes sobre o bem adjudicado**, uma vez que a obrigação tributária decorrente do IPTU é *propter rem*.

Temos uma situação peculiar que acomete nos casos de **desapropriação indireta**. Entende-se por **desapropriação indireta** toda intervenção do Estado na propriedade que venha a **impossibilitar o uso e gozo de um bem, retirando-lhe o conteúdo econômico**. Esta desapropriação indireta pode vir mascarada em alguma forma de **limitação, servidão** ou de outra **restrição imposta à propriedade**.

Mesmo que tenhamos o pressuposto principiológico da supremacia do interesse público sobre o particular, não pode o Poder Público determinar que um particular custeie, isoladamente, a instituição de um benefício coletivo, com o detrimento de seu patrimônio – que lhe é garantido pela ordem constitucional.

Por esta razão, **enquanto não decidida a ação de desapropriação indireta em favor do proprietário do imóvel e transcrita perante o Registro de Imóveis** competente a respectiva carta de sentença, deve continuar **obrigado ao pagamento do IPTU**, uma vez que a capacidade econômica é *ex lege*, e não econômica.

Caso o imóvel esteja situado em **zona de preservação ambiental** contida em **unidades de uso sustentável** em propriedades particulares, **ocorrerá uma perda do valor econômico da propriedade**, em regra. Neste caso, discute-se sobre a **necessidade de redução da base de cálculo do IPTU**, harmonizando, desta maneira, o **direito de propriedade e o meio ambiente equilibrado**.

Diferentemente se dá nos casos de **invasão do imóvel por movimentos sociais**. Neste caso, o **proprietário poderá eximir-se do pagamento do imposto**, uma vez que tem o seu **direito de propriedade esvaziado**. Entretanto, se o **Município não teve qualquer culpa pela invasão**, não pode sofrer a consequência de um fato que não deu causa, persistindo o direito de o proprietário arcar com o ônus tributário.

4.1.2.5 Aspecto quantitativo

A composição da **base de cálculo do IPTU** encontra respaldo no art. 33,

parágrafo único, do CTN, prescrevendo que a base de cálculo do IPTU é o **valor venal do imóvel**.

Deve ser entendido como **valor venal** aquele em que o bem alcançaria se fosse posto à venda, sem a inclusão de encargos de financiamento.

Quem realiza a determinação do valor venal do imóvel é o **próprio Poder Público**, sendo que a **base de cálculo poderá ser alterada sem a observância da anterioridade nonagesimal**.

A **apuração do valor venal** é realizada pelo Município pela utilização da **Planta Genérica de Valores**, o qual leva em consideração os reais elementos do mercado imobiliário para sua fixação.

A **alíquotas poderão ser progressivas**, admitindo-se duas espécies de progressividade: **extrafiscal** e **fiscal**.

A **progressividade extrafiscal** está prevista no art. 182, § 4.º, II, da CF/1988. Tal instrumento fora criado com o intuito de responder diretamente às necessidades de promover a defesa do meio ambiente e o resgate da função social da propriedade, figurando como postulados principiológicos de ordem econômica (art. 170 da CF/1988).

A Lei 10.257/2001, denominada de **Estatuto da Cidade**, prevê inúmeros instrumentos que se destinam ao cumprimento da função social: plano diretor, parcelamento e edificação compulsória, a determinação da progressividade do IPTU no tempo, desapropriação urbanística e exercício do direito de preempção.

Já a **progressividade fiscal** passa a ser admitida nos termos do art. 156, § 1.º, I, da CF/1988, patrocinada pela EC 29/2000. Assim, o imóvel poderá ter **alíquotas progressivas em razão do seu valor**.

Admite-se, ainda, a **seletividade**, nos termos do art. 156, § 1º, II, da CF, permitindo **alíquotas diferenciadas** em razão do **uso e da localização do bem**.

Na progressividade, se estabelece uma função quase linear entre uma grandeza e outra, de forma que o crescimento de uma implicará a majoração de outra.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das

entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais para as quais tais entidades foram constituídas.

Súmula 539 do STF: É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.

Súmula 583 do STF: Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.

Súmula 589 do STF: É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte.

Súmula 668 do STF: É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

Súmula 397 do STJ: O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

Súmula 399 do STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

→ “Tributário. IPTU. Sítio de recreio. Expansão urbana. 1. Incide a cobrança do IPTU sobre ‘sítio de recreio’ considerado por lei municipal como situado em área de expansão urbana. 2. Interpretação do art. 32, § 2.º, c/c o art. 14, do Decreto-lei 57/1966, e o art. 29, da Lei 5.172, de 15.10.1966. 3. Há, também, incidência de IPTU sobre ‘sítio de recreio’ situado em zona de expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 31, § 1.º, do CTN. 4. Recurso improvido” (STJ, REs 181.105/SP, 1.ª T., Rel. Min. José Delgado, 2008).

→ “Tributário. Imóvel na área urbana. Destinação rural. IPTU. Não incidência

Art. 15 do Decreto-lei 57/1966. Recurso repetitivo. Art. 543-C do CPC/1973 [art. 1.036 do CPC/2015]. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do Decreto-lei 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/1973 [art. 1.036 do CPC/2015] e da Resolução 8/2008 do STJ” (STJ, REsp 1.112.646/SP, 1.^a S., Rel. Min. Herman Benjamin, 2009).

- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não são vinculados os valores venais de ITBI e IPTU, porquanto a apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento desses tributos são diversas” (STJ, AgRg no AgInt 1.385.877/RS, 1.^a T., Rel. Min. Sérgio Kukina, 2013).
- “Em sessão realizada em 10.06.2009, a Primeira Seção julgou o Recurso Especial 1.110.551/SP, representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 [art. 1.036 do CPC/2015], em que se reafirmou o entendimento de que tanto o promitente comprador quanto o proprietário (promitente vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis) são legitimados para figurar no polo passivo em demandas relativas à cobrança do IPTU. Assim, cabe ao administrador público eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
- A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.110.551/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.06.2009), é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Não é legítimo condicionar a repetição do indébito tributário relativo ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana à comprovação de que o proprietário, e não eventual locatário, teria suportado o fardo da tributação” (STJ, REsp 1.382.090/RJ, 2.^a T., Rel. Min. Eliana Calmon, 2013).

- “O entendimento da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é pela impossibilidade de que pessoa diferente do proprietário do imóvel seja

legitimado ativo para postular repetição de indébito de IPTU, uma vez que seja locatário, seja destinatário do carnê, a obrigação contratual entre este e o proprietário do imóvel (contribuinte) não pode ser oponível à Fazenda (AgRg no REsp 836.089/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, *DJe* 26.04.2011)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 143.631/RJ, 1.^a T., Rel. Min. Benedit Gonçalves, 2012).

- “O concessionário de uso de imóvel de propriedade municipal não é contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana porque exerce a posse mediante relação de natureza pessoal, sem *animus domini*. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AREsp 176.429/RJ 1.^a T., Rel. Min. Ari Pargendler, 2013).
- “A Primeira Seção desta Corte, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973 [art. 1.036 do CPC/2015], conforme assentado no REsp 1.141.300/MG, decidiu que a ‘entrega de carnês de IPTU pelos municípios, sem a intermediação de terceiros, no seu âmbito territorial, não viola o privilégio da União na manutenção do serviço público postal’ (REsp 1.141.300/MG, rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25.08.2010, *DJe* 05.10.2010). Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no AREsp 434.465/MG, 2.^a T., Rel. Min. Humberto Martins, 2014).
- “IPTU. Progressividade antes da EC 29/2000. Impossibilidade, ainda que pela via de alíquotas de isenções graduais. A utilização do instituto da isenção como instrumento de graduação de alíquotas, com aplicação à generalidade dos contribuintes, não corresponde à sua natureza jurídica. Nesse caso, a isenção deixa de atuar como benefício fiscal. De norma de exceção que é, passa a compor o aspecto quantitativo da norma tributária impositiva, modelando toda a tabela de alíquotas e tendo como efeito a vedada progressividade. Aplicação da Súmula 668 do STF” (RE 355.046, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 01.08.2011, *DJE* 31.08.2011).
- “O STF firmou entendimento no sentido de que não há inconstitucionalidade na diversidade de alíquotas do IPTU no caso de imóvel edificado, não edificado residencial ou comercial. Essa orientação é anterior ao advento da EC 29/2000. Precedentes” (AI 582.467 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, 2.^a T., j. 22.06.2010, *DJE* 06.08.2010).

4.2 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS, ONEROSA E DE DIREITOS REAIS RELATIVOS AOS IMÓVEIS, EXCETO OS DE GARANTIA (ITBI)

4.2.1 Previsão legislativa

O imposto sobre a transmissão de bens imóveis *inter vivos*, onerosa e de direitos reais relativos aos imóveis, exceto os de garantia (ITBI), é um imposto de competência dos Municípios e do DF, previsto no art. 156, II e § 2.º, da CF/1988.

Parte da normatização geral é prevista entre os arts. 35 a 42 do CTN, devendo ser interpretado à luz da CF/1988. Surgiu no Brasil em 1809, por meio do Alvará 3, com a denominação do **imposto da sisa**, tendo sua primeira previsão constitucional na Carta de 1891, que estabelecia, em seu art. 9º, III, como sendo de **competência dos Estados**.

A Constituição de 1934 estabeleceu uma divisão, criando dois impostos, **ambos de competência dos Estados**:

- ✓ Imposto de transmissão de propriedade *causa mortis* (art. 8º, I, “b”);
- ✓ Imposto sobre a transmissão da propriedade imobiliária *inter vivos* (art. 8º, I, “c”).

A Emenda Constitucional 18, de 1965, restabelece a união dos impostos sobre transmissão de bens imóveis, *inter vivos* e *causa mortis*, mantendo-os na **competência dos Estados**, alterando algumas hipóteses de incidência.

Portanto, o dispositivo do CTN, vez que estava sob a égide da CF/1946, deve ser interpretado à luz da CF/1988, que estabeleceu nova dicotomia entre os Estados e os Municípios.

Cabe a cada um dos Municípios a instituição do referido imposto, estabelecendo as normas gerais de incidência tributária.

4.2.2 Regra-matriz de incidência tributária

4.2.2.1 Aspecto material

O ITBI **incide sobre a transmissão de bens imóveis quando esta for em caráter oneroso**, não sendo possível a incidência quando apenas uma das partes se sujeita ao cumprimento de uma prestação patrimonial e a outra à satisfação de um encargo.

Compreende-se na hipótese de incidência a compra e venda, dação em pagamento, permuta, arrematação, adjudicação, uso, usufruto e a enfiteuse. Também tem incidência sobre a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto de arrematação ou adjudicação, bem como a cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e venda.

Também abrange a cessão de direitos à sucessão e a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda.

Os denominados **bens imóveis por natureza** são o solo com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo.

Já os **bens imóveis por acessão física** compreendem tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que não se possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano.

Entretanto, sobre os direitos reais de garantia sobre bens imóveis **não haverá incidência de ITBI**. Assim, nos casos de hipoteca e anticrese, não há que se falar em pagamento de ITBI.

A não incidência de ITBI também recai nos seguintes institutos:

- usucapião;
- desapropriação;
- servidões;
- retrovenda etc.

Nos casos de **divisão do patrimônio no divórcio**, sendo o patrimônio adquirido após o matrimônio, no regime de comunhão parcial de bens, não há incidência do imposto, visto que não há transmissão da propriedade, mas tão somente a partilha dos bens que já pertenciam aos cônjuges. Porém, pode ocorrer de, nessa partilha, por conveniência dos envolvidos, um deles ficar com **uma parte do patrimônio imobiliário que corresponda a mais da metade do que lhe caberia se a partilha**

fosse realizada pelas regras impostas pelo regime de bens. Nesse caso, surge a questão de saber se o ITBI incide sobre a respectiva diferença, como se tivesse havido uma transferência da propriedade.

A transmissão *inter vivos* é a **transferência do direito de uma pessoa a outra por força de um negócio jurídico**. Não se confunde com a aquisição originária da propriedade, que não se sujeita à incidência desse imposto porque não implica em transmissão.

A **aquisição será derivada** quando houver **translatividade** (relação jurídica de transferência), isto é, **transmissão da propriedade**, registrada perante o cartório de Registro de Imóveis, de um sujeito para outro. Nesse modo de aquisição, a propriedade é adquirida com **todos os gravames que pesem sobre ela** (com tudo que eventualmente viciá-la). Na aquisição derivada **não haverá extinção**, pois existe **continuidade da relação**.

Como é cedição, um dos **atributos da propriedade** é a **exclusividade**, mas esta **não impede o fracionamento**, podendo o seu titular, por ato oneroso ou gratuito, atribuir a um terceiro certos poderes a ela inerentes. Como dito, é **possível desmembrar os direitos do domínio, entregando a terceiro**, o que não retira, *a priori*, o direito de propriedade do seu titular. Quando um ou alguns dos poderes inerentes ao domínio se destacarem e se incorporarem ao patrimônio de outra pessoa, teremos o **direito real sobre coisa alheia**.

Conforme divisão doutrinária, há **três classes de direitos reais sobre coisas alheia**, quais sejam:

- ✓ **Direitos reais de aquisição;**
- ✓ **Direitos reais de uso e fruição; e**
- ✓ **Direitos reais de garantia.**

O s **direitos reais de aquisição** têm como espécie: o **direito do promitente comprador do imóvel**.

Os **direitos reais de uso e fruição** se dividem em **oito espécies**:

- a superfície;
- as servidões;
- o usufruto;

- o uso;
- a habitação;
- a concessão de uso especial para fins de moradia;
- a concessão de direito real de uso; e
- a enfiteuse.

Já os **direitos reais de garantia** se subdividem em **três espécies**:

- o penhor;
- hipoteca; e
- anticrese.

No **direito real de aquisição do promitente comprador do imóvel** (também chamado compromisso de compra e venda), o titular concede parcela de seus poderes para permitir que terceiro adquira a coisa para si. Esse direito real na coisa alheia é para que o **terceiro possa adquirir a titularidade da propriedade**, ou seja, o proprietário, mediante contrato, **concede a um terceiro parcelas dos poderes do domínio**, para que o terceiro adquira o título futuramente.

Percebe-se que esse compromisso de compra e venda, só vai adquirir o *status* de direito real **caso não comporte cláusula de arrependimento** e tenha **registro do ofício competente**. Sobre esse direito real, no que tange à incidência do ITBI, quando o compromisso de compra e venda é registrado sem dúvidas está configurado o fato gerador do tributo em comento.

A grande questão paira sobre o compromisso de compra e venda sem registro, em que **são transferidos apenas direitos obrigacionais ou pessoais, e não reais**. Dessa forma, **esse compromisso de compra e venda com registro é um direito real** e, sendo direito real, **constitui hipótese de incidência do tributo em comento**.

No direito real de **usufruto** existem **duas figuras**: o **usufrutuário**, que é aquele que tem a posse direta da coisa, pois só com o uso direto o usufrutuário tem o pleno exercício da coisa; e o **nu-proprietário**, com quem permanecem os direitos de dispor da coisa e de perseguir o bem, ou seja, o possuidor indireto da coisa. É possível a **instituição do usufruto de bem imóvel a título oneroso ou gratuito**.

O usufruto é inalienável e intransmissível, tanto *inter vivos* quanto *causa mortis*, tendo em vista o seu caráter *intuitu personae*. Dessa forma, não há incidência do

tributo nos casos que envolvam a transmissão de usufruto.

O ITBI incidirá apenas na **instituição original do usufruto** e na sua extinção, se for oneroso, por se tratar de um **direito real sobre o imóvel**. Todavia, na maioria das vezes, é **gratuito**, incidindo nesses casos o ITCMD.

A **concessão de direito real de uso** sempre dependerá de prévia autorização legislativa do ente político titular de domínio do bem concedido. Mediante a concessão, a Administração Pública pode **ceder o uso de bens de seu domínio para o particular**, de maneira **remunerada** ou **gratuita**, sob a forma de **direito real resolúvel**, para fomentar o desenvolvimento de atividades socioeconômicas que sejam relevantes para o interesse da sociedade.

Caso essa concessão de uso seja **onerosa**, e tenha ocorrido o **ato de formalidade** – registro no Cartório de Registro de Imóveis –, é **totalmente possível a incidência do ITBI**. Exemplo desse tipo de direito real sobre coisa alheia é a **concessão para exploração de rodoviária e de portos**.

Ademais, a CF estabelece uma **imunidade específica ao ITBI**, conforme se observa no art. 156, § 2º, I, *in verbis*:

Art. 156 (...)

§ 2º (...)

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

O Código Tributário Nacional revela o conceito de **atividade preponderante** em seu art. 37, §§ 1º e 2º:

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento)

da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

A regra, embora claríssima, tem sofrido tentativas de burla por parte de Municípios que, por leis próprias ou simples prática administrativa, limitam a imunidade ao **valor do capital subscrito** (isto é, ao valor *de face* das ações ou quotas emitidas), cobrando o ITBI sobre a diferença entre este e o **valor de mercado dos imóveis colacionados**.

A questão está afetada ao STF em repercussão geral:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156 parágrafo 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado – Tema 796.

A problemática advém do art. 23 da Lei 9.249/1995, segundo o qual

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos.

§ 2º se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como

ganho de capital.

Para uma parte dos Municípios, a parcela correspondente ao **ganho de capital que deixou de ser auferido** (e submetido ao IRPF) na hipótese do parágrafo 1º **sofrerá a incidência do ITBI**, em atenção ao suposto princípio de que algum tributo há sempre de ser pago e à necessidade de preservação da finalidade das imunidades tributárias, que não vêm para beneficiar particulares.

4.2.2.2 Aspecto espacial

O local da ocorrência do fato gerador é o do Município da situação dos bens. Assim, o Município em que se situar o imóvel será competente para a exigência do respectivo tributo.

4.2.2.3 Aspecto temporal

O momento da ocorrência do fato gerador no que diz respeito à compra e venda de bem imóvel passa a ser o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis, uma vez que com o efetivo registro temos a transferência do imóvel.

Independentemente do real momento da ocorrência do fato gerador, na prática, o recolhimento tem sido exigido quando da lavratura da escritura pública de alienação imobiliária ou dos direitos relativos ao imóvel.

O fato é que o recolhimento antecipado, ou seja, quando da lavratura da escritura pública, é uma espécie de fato gerador presumido. E isto se dá por um simples motivo: os contratantes apenas realizavam a lavratura da escritura pública, sem efetuar o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, e por várias vezes repetindo o procedimento com o mesmo imóvel, ou seja, várias alienações apenas com uma nova lavratura de escritura pública, fazendo com que os Municípios perdessem em muito a arrecadação.

Entretanto, tal argumento não é suficiente para a exigência do ITBI antecipadamente, a nosso ver.

4.2.2.4 Aspecto pessoal

O sujeito ativo no ITBI é o Município da situação do bem. Assim, se um imóve

está localizado em São Paulo (SP), pertencente a um proprietário que reside em Porto Alegre (RS), e é alienado para uma pessoa domiciliada em Aracaju (SE), o imposto será devido em São Paulo, local da situação do bem.

Assim, não há qualquer relevância o domicílio do proprietário ou transmitente para a instituição e cobrança desse imposto.

O sujeito passivo pode ser quaisquer das partes na operação tributada, cabendo ao legislador municipal definir qual será o competente para figurar como contribuinte.

Aquele que será escolhido pela lei municipal para figurar na condição de contribuinte deve estar envolvido com a operação que será tributada.

Como responsáveis, podem figurar os tabeliães e os registradores do Registro de Imóveis, caso deixem de exigir a prova do recolhimento do tributo por ocasião da lavratura da escritura ou transcrição do título.

4.2.2.5 Aspecto quantitativo

Nos termos do art. 38 do CTN: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

A base de cálculo deve refletir o valor da transação imobiliária, levando em consideração a capacidade contributiva e o princípio da vedação ao confisco.

O valor venal do imóvel deve ser considerado apenas como limite, não sendo necessariamente utilizado como base de cálculo, podendo ser adotado pela lei municipal.

As alíquotas serão definidas pela lei municipal, não se concebendo a progressividade pela falta de previsão constitucional.

No mesmo sentido, entendeu o STF, editando a Súmula 656: “É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão *inter vivos* de bens imóveis – ITBI – com base no valor venal do imóvel”.

JURISPRUDÊNCIA

- “Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do bem imóvel. (...) 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente. Precedentes do STJ. 3

Agravo Regimental não provido” (STJ, AgRg no AREsp 215.273/SP, 2.^a T. Rel. Min. Herman Benjamin, 2012).

- “O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel motivo pelo qual não incide referida exação sobre o registro imobiliário de escritura de resilição de promessa de compra e venda, contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 764.808/MG, 1.^a T., Rel. Min. Luiz Fux, 2007).
- “A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. Somente após o registro, incide a exação. 2. Não incide o ITBI sobre o registro imobiliário de escritura de resilição de promessa de compra e venda, contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AgIn 448.245/DF, 1.^a T., Rel. Min. Luiz Fux, 2002).
- “Tributário. ITBI. Promessa de compra e venda. Fato gerador não caracterizado. Promessa de compra e venda de imóvel, sem registro, não transfere a propriedade e não constitui fato gerador do ITBI (precedentes do STF e do STJ). Recurso improvido” (STJ, REsp 264.064/DF, 1.^a T., Rel. Min. Garcia Vieira, 2000).

4.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)



4.3.1 Previsão legislativa

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é um imposto de

competência dos Municípios e do DF, estabelecido no art. 156, III e § 3.º, da CF/1988.

A **normatização geral** vem estabelecida pela LC 116/2003, sendo a competência de cada Município a instituição do referido imposto.

Ainda, o Decreto-lei 406/1968 possui parte de seus artigos em vigor, podendo ser utilizado nas hipóteses ali estabelecidas.

4.3.2 Regra-matriz de incidência tributária

4.3.2.1 Aspecto material

A **incidência do ISS** recai sobre a **prestação de serviços de qualquer natureza**.

O termo **serviço** denota **trabalhos** ou **atividades economicamente mensuráveis** que determinada pessoa presta a outra. Já a expressão **qualquer natureza** identifica toda e qualquer origem.

O Prof. Sérgio Pinto Martins, de uma forma bem elucidativa, estabelece que **prestação de serviços é a operação pela qual uma pessoa, em troca de pagamento de um preço, realiza em favor de outra a transmissão de um bem imaterial (serviço). Prestar serviço é vender bem imaterial.**

A LC 116/2003 traz em seu bojo uma lista de serviços que deve ensejar a tributação de ISS, sendo tal **lista taxativa**. Esta não pode ser ampliada por analogia, e, se o serviço não estiver previsto na lista criada pela lei complementar, não poderá servir de hipótese de incidência.

Se por um lado a Constituição Federal de 1988 atribui a competência aos Municípios para legislar sobre assuntos locais e sobre o próprio ISS, determinou também para a **lei complementar definir os serviços** para efeitos de incidência do ISS. Por isso, **não há como se ter uma lista exemplificativa**, tendo em vista o princípio da legalidade e tipicidade cerrada.

Percebe-se que **o que se tributa não é o serviço** porque não existe nenhuma atividade humana que demonstra a existência de capacidade e autoriza a incidência de um tributo, exigido como forma de participação nas despesas públicas, mas a **prestação de serviços**.

A **prestação de serviços** sobre a qual pode incidir o ISS é aquela mediante a celebração de um negócio jurídico subjacente, que tenha conotação econômica.

Não incide, portanto, sobre o **serviço que o empregado presta ao empregador**, por ser serviço que se desenvolve sob uma **relação de subordinação**, mediante **contrato de trabalho** submetido ao regime celetista.

O ISS também **não alcança o autosserviço**, isto é, aquela atividade que é prestada **não como atividade-fim**, mas como **atividade-meio**. O prestador dos serviços executa as atividades para ele mesmo, não para terceiros.

No que diz respeito à **exportação e importação de serviços**, ao mesmo tempo que a LC 116/2003 **cria o benefício à exportação do serviço**, estabelece limites a serem observados pelo contribuinte para a fruição. Se os serviços forem desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, a regra imunizatória não se aplica, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

Percebe-se que a **imunidade** se refere às **prestações de serviços exportados**, pouco importando onde o contrato foi celebrado, onde se situa o prestador ou o tomador do serviço. Importa apenas que a prestação dos serviços tenha sido realizada no exterior para que não ocorra a incidência de ISS.

4.3.2.2 Aspecto espacial

A Constituição Federal de 1988 não definiu o local da prestação de serviços. Existiram **três critérios distintos para fins da determinação do local de incidência do fato gerador**.

A LC 116/2003 preferiu **adotar um sistema misto** para os fins de incidência do ISS. O art. 3.º considerou devido o imposto no **local do estabelecimento prestador** ou **na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador**, e, para as hipóteses expressamente previstas, o **imposto será devido no local da prestação do serviço, do estabelecimento do tomador ou do intermediário**.

Reza o art. 3.º da LC 116/2003:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

X – (VETADO)

XI – (VETADO)

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte,

descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

XVI – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário,

ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

XXIV – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

XXV – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º, ambos do art. 8º-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

Para fins de incidência do ISS, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo

permanente ou **temporário**, e que configure **unidade econômica** ou **profissional**, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

4.3.2.3 Aspecto temporal

O **momento da ocorrência do fato gerador** é o mesmo determinado no art. 3.º da LC 116/2003, que vimos há pouco, ou seja, quando da prestação dos serviços ali identificados.

4.3.2.4 Aspecto pessoal

O **sujeito ativo** é o **DF** ou o **Município** onde se realiza a prestação de serviços.

O **sujeito passivo** é o prestador do serviço, podendo ser tanto pessoa física como jurídica, desde que exista habitualidade e autonomia, independentemente de subordinação.

Não são contribuintes aqueles que prestam serviços em **relação de emprego**, bem como as pessoas que realizam **serviços para si** (autosserviço) e os **serviços prestados sem conteúdo econômico**. Por esta razão, **não são contribuintes do ISS os diretores e membros do conselho consultivo e fiscal das sociedades**.

Caberá a cada Município, independentemente do disposto nas normas gerais estabelecidas na LC 116/2003, quem poderá figurar na condição de responsável.

4.3.2.5 Aspecto quantitativo

A **base de cálculo** do ISS é o **preço do serviço**, estabelecido na forma da lei.

Pelo **preço do serviço** podemos entender **a soma de dinheiro que o comprador paga ou se obriga a pagar ao vendedor em troca da coisa adquirida**. Neste caso, o ISS recai sobre a **receita bruta decorrente da prestação de serviços**, sem dedução de nenhuma parcela componente, nem despesas, custos ou material empregado na prestação de serviços.

Não integram a base de cálculo do ISS o valor do financiamento nas operações de crédito, as atividades que são realizadas por despachantes, os hotéis que realizam despesas com terceiros que são reembolsáveis posteriormente por seus

hóspedes, bem como os valores recebidos por empresas de recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra, dentre outros estabelecidos em lei.

Tratando-se de **tributação de sociedades profissionais** e dos **profissionais autônomos** pelo ISS, a **base de cálculo** deve ser **fixa**. Isto, em decorrência da vigência do art. 9.º do Decreto-lei 406/1968:

Art. 9.º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1.º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho (...).

A **base de cálculo** passa a ser adotada nas sociedades profissionais liberais em caráter pessoal. Isto significa que **não é a sociedade que presta diretamente os serviços**, mas **cada profissional individualmente**. A **essência dos serviços tem caráter personalíssimo**, razão pela qual se distinguem de empresas prestadoras de serviço.

No que tange às **alíquotas**, a CF/1988 estabeleceu à lei complementar competência para **fixar as alíquotas máximas para o ISS**, na forma do § 3.º, I, do art. 156, que foi posteriormente alterado pela EC 37/2002.

A **alíquota máxima** fixada na LC 116/2003 ficou em **5%**, e a EC 37/2002 acrescentou o art. 88, I, do ADCT, dispondo que, enquanto a lei complementar não disciplinar o disposto nos incs. I a III do § 3.º do art. 156 da CF/1988, o ISS terá alíquota mínima de 2%.

Com o advento da LC 157/16, houve a **inserção da letra A no art. 8.º da LC 116/03**, determinando expressamente a **alíquota mínima de 2%**, conferindo um prazo de um ano para que as Municipalidades se adequassem a essa diretriz, sob pena de enquadramento como improbidade administrativa, nos termos do art. 10-A da Lei 8.429/92.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 167 STJ: O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões é prestação de serviços, sujeitando-se apenas a incidência de ISS.

Súmula 274 STJ: O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se nele as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares.

- “Serviços-meio para o alcance de serviços-fim de telecomunicações: secretaria, datilografia, habilitação, mudança e religação de aparelhos, despertador, processamento de dados, entre outros” (STJ, REsp 883.254/MG 1.^a T., Rel. Min. José Delgado, 2007).
- “A entrega em domicílio de GLP não configura serviço autônomo de transporte coleta, remessa de bens ou valores, dentro do território do município, mas apenas meio idôneo à realização das operações mercantis com combustíveis líquidos, não se sujeitando à incidência de ISS” (STJ, REsp 612.490/MA, 2.^a T., Rel. Min. Castro Meira, 2008).

Não incide o ISS sobre a atividade-meio utilizada na prestação de serviço como é o caso da atividade de secretaria (anotação de recados e digitação de mensagens) envolvida na prestação dos serviços de “radiochamada” por intermédio de *pagers* (STJ, REsp 848.490/RJ, 2.^a T., Rel. Min. Elian Calmon, 2008).

- Empresa contratada por uma sociedade empresária para prestar serviços relacionados ao corte, recorte e polimento de granito e mármore. A mercadoria pertence à contratante que a entregou exclusivamente para o seu beneficiamento. Tratando-se de serviço sob encomenda, incide ISS (STJ REsp 888.852/ES, 1.^a T., Rel. Min. Luiz Fux, 2008).

Farmácias de Manipulação que preparam e fornecem medicamentos sob encomenda conforme receita apresentada pelo consumidor: incidência de ISS, tratando-se de serviço previsto expressamente na legislação federal (item 4.07

da lista anexa à LC 116/2003) (STJ, REsp 881.035/RS, 1.^a T., Rel. Min. Teor Albino Zavascki, 2008).

- “A base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros é o preço efetivamente pago pelo usuário no ato da compra e venda dos bilhetes, não o vigente no momento posterior em que se dá a efetiva prestação” (STJ, AgRg AREsp 112.288/RS, 1.^a T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, 2012).
- A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que “as empresas de mão de obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão de obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho”. Na primeira hipótese, o ISS incide “apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores”. Na segunda situação, “se a atividade de prestação de serviço de mão de obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão de obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS”, como ocorre em relação aos serviços prestados na forma da Lei 6.019/1974 (STJ, REsp 1.138.205/PR, 1.^a Seção Rel. Min. Luiz Fux, 2010).
- “No que se refere à base de cálculo, mostra-se ilegítima a incidência do ISS sobre o total das mensalidades pagas pelo titular do plano de saúde à empresa gestora, pois, em relação aos serviços prestados pelos profissionais credenciados, há a incidência do tributo, de modo que a nova incidência sobre o valor destinado a remunerar tais serviços caracteriza-se como dupla incidência de um mesmo tributo sobre uma mesma base impositiva. Por tal razão, o valor repassado aos profissionais credenciados deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela empresa gestora” (STJ, REsp 783.022/MG, 1.^a T., Rel. Min. Denise Arruda, 2009).

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973 [art. 1.036 do CPC/2015] e da Res

08/2008 STJ, firmou a orientação de que incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro (STJ, REsp 1.060.210/SC, 1.^a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2012).

- “1. Conforme julgamento do STF realizado em Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE 592.905/SC) incide ISS sobre operações de arrendamento mercantil. 2. O Município em que foi celebrado o contrato de aquisição de bem mediante *leasing* ou em que era domiciliado o tomador do serviço não é o sujeito ativo do ISS, mas sim aquele no qual atua estabelecimento com poder decisório quanto ao principal elemento do negócio jurídico, que é a aprovação e a concessão do financiamento. 3. Orientação adotada no julgamento do REsp 1.060.210/SC, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973 [art. 1.036 do CPC/2015]. 4. Agravo Regimental provido” (STJ, AgRg no Ag 1.321.606/SC, 2.^a T., Rel. Min. Herman Benjamin, 2013).
- “Tributário. Imposto sobre serviços – ISS. Definição da base de cálculo. Dedução dos gastos com materiais empregados na construção civil. Recepção do art. 9.^o, § 2.^o, *b*, do Decreto-lei 406/1968 pela Constituição de 1988. Ratificação da jurisprudência firmada por esta corte. Existência de repercussão geral” (STF, Repercussão geral no RE 603.497/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, 2010).
- “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS. Possibilidade de dedução dos materiais empregados na construção civil. Recepção do art. 9.^o do Decreto-lei 406/1968 pela Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497, submetido ao rito da repercussão geral, assentou o entendimento de que é possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor referente aos materiais empregados na construção civil. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, AgRg no RE com Ag 728.060/RJ, 1.^a T., Rel. Min. Roberto Barroso, 2014).
- “Tributário. ISS. Serviços de registro público. O regime de tributação previsto no art. 9.^o, § 1.^o, do Decreto-lei 406, de 1968, não é aplicável aos responsáveis pelos serviços de registro público. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AREsp 150.919/RS, 1.^a T., Rel. Min. Ari Pargendler, 2013).
- “Agravo regimental no recurso extraordinário. Serviço de composição gráfica

com fornecimento de mercadoria. Conflito de incidências entre o ICMS e o ISSQN. Serviços de composição gráfica e customização de embalagem meramente acessórias à mercadoria. Obrigação de dar manifestamente preponderante sobre a obrigação de fazer, o que leva à conclusão de que o ICMS deve incidir na espécie. 1. Em precedente da Corte consubstanciado na ADI 4.389/DF-MC, restou definida a incidência de ICMS ‘sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria’. 2. A verificação da incidência nas hipóteses de industrialização por encomenda deve obedecer dois critérios básicos: (i) verificar se a venda opera-se a quem promoverá nova circulação do bem e (ii) caso o adquirente seja consumidor final, avaliar a preponderância entre o dar e o fazer mediante a averiguação de elementos de industrialização. 4. À luz dos critérios propostos, só haverá incidência do ISS nas situações em que a resposta ao primeiro item for negativa e se no segundo item o fazer preponderar sobre o dar. 5. A hipótese dos autos não revela a preponderância da obrigação de fazer em detrimento da obrigação de dar. Pelo contrário. A fabricação de embalagens é a atividade econômica específica explorada pela agravante. Prepondera o fornecimento dos bens em face da composição gráfica, que afigura-se meramente acessória. Não há como conceber a prevalência da customização sobre a entrega do próprio bem. 6. Agravo regimental não provido” (STF, AgRg no AgIn 803.296/SP, 1.^a T., Rel. Min Dias Toffoli, 2013).

- “As operadoras de planos privados de assistência à saúde (plano de saúde e seguro-saúde) prestam serviço sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), previsto no art. 156, III, da CF. Esse é o entendimento do Plenário, que, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a incidência da referida exação relativamente às atividades de administração de planos de saúde. (...) Diferentemente dos seguros-saúde, nos planos de saúde, a garantia oferecida é somente a utilidade obtida mediante a contratação do respectivo plano, o que não exclui o fato de as atividades por elas desempenhadas — operadoras de plano de saúde e operadoras de seguro-saúde — serem “serviço”. Nesse sentido, o ISSQN deve incidir sobre a comissão, assim considerada a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o

repassado para os terceiros prestadores dos serviços médicos” (RE 651.703, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016, *Informativo* 841, com repercussão geral).

- “A Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira. Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a presente reclamação constitucional” (Rcl 14.290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.05.2014, *DJE* 20.06.2014).
- “Os serviços de composição gráfica realizados em fichas telefônicas são prestados em caráter privado. A despeito da atividade não estar acobertada pela imunidade, não há como reconhecer a incidência do ISS na hipótese em virtude de os serviços serem meramente residuais em relação à operação de circulação de tais mercadorias. Aplicam-se ao caso as conclusões do STF sobre a composição de serviços gráficos em embalagens (ADI 4.389-MC)’ (RE 592.752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 18.03.2014, *DJE* 14.04.2014).
- “A Súmula Vinculante 31 não exonera a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do ISS. Se houver ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro” (ARE 656.709 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa 2ª T., j. 14.02.2012, *DJE* 08.03.2012).

QUARTA PARTE

DIREITO SUMULAR TRIBUTÁRIO

SÚMULAS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA



As **súmulas** são verbetes que têm por condão registrar uma interpretação pacífica ou majoritária adotada por um tribunal a respeito de uma determinada temática específica. É o resultado do julgamento tomado pelo voto da **maioria absoluta** dos membros que integram um tribunal, que, por meio de um enunciado, constituem precedentes de uniformização da jurisprudência do próprio órgão.

Com o advento da EC 45/2004, surgiram as denominadas **súmulas vinculantes**, de competência do Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto a validade, interpretação e eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos judiciários ou entre estes e a Administração Pública, acarretando grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questões idênticas.

A regulamentação das súmulas vinculantes é determinada pela Lei 11.417/2006.

A iniciativa de proposta da súmula vinculante passa a ser dos mesmos **legitimados para proposição de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade**. Não só estes podem aprovar, como também **revisar e cancelar** súmulas vinculantes.

Os legitimados estão estabelecidos no art. 103 da CF/1988, bem como no art. 3.º

da Lei 11.417/2006.

Ademais, os **Municípios** poderão **propor a edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes incidentalmente ao curso de processo em que seja parte** (art. 3.º, § 1.º, da Lei 11.417/2006).

Em qualquer caso deverá ocorrer a **intervenção do Ministério Público** por meio do **Procurador-Geral da República** (art. 2.º, § 2.º, da Lei 11.417/2006).

Caso haja **descumprimento** das súmulas vinculantes, caberá **reclamação constitucional**, nos termos do art. 103-A, § 3.º, da CF/1988, perante o Supremo Tribunal Federal.

Várias súmulas, inclusive vinculantes, foram editadas diretamente elencando matéria tributária, e outras, de maneira reflexa, acabam atingindo matéria tributária.

Sendo assim, foram separadas, nesta parte, determinadas súmulas na seguinte ordem: súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ e súmulas dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões, com o intuito de conferir suporte aos estudos em direito processual tributário.

SÚMULAS VINCULANTES

Súmula Vinculante 8

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5.º do Decreto-lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

Súmula Vinculante 12

A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

Súmula Vinculante 19

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o art. 145, II, da Constituição Federal.

Súmula Vinculante 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou

bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Súmula Vinculante 24

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, incs. I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

Súmula Vinculante 28

É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário.

Súmula Vinculante 29

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Súmula Vinculante 31

É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis dissociadas da prestação de serviços.

Súmula Vinculante 32

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

Súmula Vinculante 40

A contribuição confederativa de que trata o art. 8.º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Súmula Vinculante 41

O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

Súmula Vinculante 48

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Súmula Vinculante 50

Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

Súmula Vinculante 52

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula 67

É inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro.

Súmula 69

A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais.

Súmula 70

É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 73

A imunidade das autarquias, implicitamente contida no art. 31, V, “a”, da Constituição Federal, abrange tributos estaduais e municipais.

Súmula 75

Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o Imposto de Transmissão “Inter Vivos”, que é encargo do comprador.

Súmula 76

As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do art. 31, V, “a”, Constituição Federal.

Súmula 77

Está isenta de impostos federais a aquisição de bens pela rede ferroviária federal.

Súmula 78

Estão isentas de impostos locais as empresas de energia elétrica, no que respeita as suas atividades específicas.

Súmula 79

O Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais.

Súmula 81

As cooperativas não gozam de isenção de impostos locais, com fundamento na constituição e nas leis federais.

Súmula 82

São inconstitucionais o Imposto de Cessão e a taxa sobre inscrição de promessa de venda de imóvel, substitutivos do Imposto de Transmissão, por incidirem sobre ato que não transfere o domínio.

Súmula 89

Estão isentas do Imposto de Importação frutas importadas da Argentina, do Chile da Espanha e de Portugal, enquanto vigentes os respectivos acordos comerciais.

Súmula 93

Não está isenta do Imposto de Renda a atividade profissional do arquiteto.

Súmula 95

Para cálculo do Imposto de Lucro Extraordinário, incluem-se no capital as reservas do ano-base, apuradas em balanço.

Súmula 108

É legítima a incidência do Imposto de Transmissão “inter vivos” sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local.

Súmula 110

O Imposto de Transmissão “Inter Vivos” não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno.

Súmula 111

É legítima a incidência do Imposto de Transmissão “Inter Vivos” sobre a restituição, ao antigo proprietário, de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua desapropriação.

Súmula 112

O Imposto de Transmissão “Causa Mortis” é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão.

Súmula 113

O Imposto de Transmissão “Causa Mortis” é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.

Súmula 114

O Imposto de Transmissão “Causa Mortis” não é exigível antes da homologação do cálculo.

Súmula 115

Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o Imposto de Transmissão “Causa Mortis”.

Súmula 116

Em desquite ou inventário, é legítima a cobrança do chamado imposto de reposição, quando houver desigualdade nos valores partilhados.

Súmula 126

É inconstitucional a chamada taxa de aguardente, do Instituto do Açúcar e do Alcool.

Súmula 127

É indevida a taxa de armazenagem, posteriormente aos primeiros trinta dias, quando não exigível o Imposto de Consumo, cuja cobrança tenha motivado a retenção da mercadoria.

Súmula 128

É indevida a taxa de assistência médica e hospitalar das instituições de previdência social.

Súmula 129

Na conformidade da legislação local, é legítima a cobrança de taxa de calçamento.

Súmula 130

A taxa de despacho aduaneiro (art. 66 da Lei 3.244, de 14.08.1957) continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 25.08.1960, que aprovou alterações introduzidas no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).

Súmula 131

A taxa de despacho aduaneiro (art. 66 da Lei 3.244, de 14.08.1957) continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 25.08.1960, mesmo para as mercadorias incluídas na vigente Lista III do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).

Súmula 132

Não é devida a taxa de previdência social na importação de amianto bruto ou em fibra.

Súmula 133

Não é devida a taxa de despacho aduaneiro na importação de fertilizantes e inseticidas.

Súmula 134

A isenção fiscal para a importação de frutas da Argentina compreende a taxa de despacho aduaneiro e a taxa de previdência social.

Súmula 135

É inconstitucional a taxa de eletrificação de Pernambuco.

Súmula 136

É constitucional a taxa de estatística da Bahia.

Súmula 137

A taxa de fiscalização da exportação incide sobre a bonificação cambial concedida ao exportador.

Súmula 138

É inconstitucional a taxa contra fogo, do Estado de Minas Gerais, incidente sobre prêmio de seguro contra fogo.

Súmula 140

Na importação de lubrificantes é devida a taxa de previdência social.

Súmula 141

Não incide a taxa de previdência social sobre combustíveis.

Súmula 142

Não é devida a taxa de previdência social sobre mercadorias isentas do Imposto de Importação.

Súmula 148

É legítimo o aumento de tarifas portuárias por ato do Ministro da Viação e Obras Públicas.

Súmula 191

Inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória (vide observação).

Súmula 192

Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa.

Súmula 239

Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.

Súmula 277

São cabíveis embargos, em favor da Fazenda Pública, em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão.

Súmula 278

São cabíveis embargos em ação executiva fiscal contra decisão reformatória da de primeira instância, ainda que unânime.

Súmula 302

Está isenta da taxa de previdência social a importação de petróleo bruto.

Súmula 306

As taxas de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais são legítimas, quando incidem sobre matéria tributável pelo estado.

Súmula 308

A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do Imposto de Importação, não incide sobre borracha importada com isenção daquele imposto.

Súmula 309

A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do Imposto de Importação, não está compreendida na isenção do Imposto de Consumo para automóvel usado trazido do exterior pelo proprietário.

Súmula 323

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 324

A imunidade do art. 31, V, da Constituição Federal não compreende as taxas.

Súmula 326

É legítima a incidência do Imposto de Transmissão “Inter Vivos” sobre a transferência do domínio útil.

Súmula 328

É legítima a incidência do Imposto de Transmissão “Inter Vivos” sobre a doação de imóvel.

Súmula 329

O Imposto de Transmissão “Inter Vivos” não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária.

Súmula 331

É legítima a incidência do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” no inventário por morte presumida.

Súmula 336

A imunidade da autarquia financiadora, quanto ao contrato de financiamento, não se estende à compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento.

Súmula 348

É constitucional a criação de taxa de construção, conservação e melhoramento de estradas.

Súmula 383

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Súmula 404

Não contrariam a constituição os arts. 3.º, 22 e 27 da Lei 3.244, de 14.08.1957, que definem as atribuições do conselho de política aduaneira quanto à tarifa flexível.

Súmula 405

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

Súmula 435

O Imposto de Transmissão “Causa Mortis” pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia.

Súmula 436

É válida a Lei 4.093, de 24.10.1959, do Paraná, que revogou a isenção concedida às cooperativas por lei anterior.

Súmula 437

Está isenta da taxa de despacho aduaneiro a importação de equipamento para a indústria automobilística, segundo plano aprovado, no prazo legal, pelo órgão competente.

Súmula 439

Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.

Súmula 470

O Imposto de Transmissão “Inter Vivos” não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda.

Súmula 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 493

O valor da indenização, se consistente em prestações periódicas e sucessivas, compreenderá, para que se mantenha inalterável na sua fixação, parcelas

compensatórias do Imposto de Renda, incidente sobre os juros do capital gravado ou caucionado, nos termos dos arts. 911 e 912 do Código de Processo Civil.

Súmula 503

A dúvida, suscitada por particular, sobre o direito de tributar, manifestado por dois estados, não configura litígio da competência originária do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 507

A ampliação dos prazos a que se refere o art. 32 do Código de Processo Civil aplica-se aos executivos fiscais.

Súmula 512

Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Súmula 532

É constitucional a Lei 5.043, de 21.06.1966, que concedeu remissão das dívidas fiscais oriundas da falta de oportuno pagamento de selo nos contratos particulares com a caixa econômica e outras entidades autárquicas.

Súmula 534

O Imposto de Importação sobre o extrato alcoólico de malte, como matéria-prima para fabricação de “whisky”, incide à base de 60%, desde que desembarcado antes do Decreto-lei 398, de 30.12.1968.

Súmula 536

São objetivamente imunes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias os “Produtos Industrializados”, em geral, destinados à exportação, além de outros, com a mesma destinação, cuja isenção a lei determinar.

Súmula 539

É constitucional a lei do município que reduz o Imposto Predial Urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.

Súmula 543

A Lei 2.975, de 27.11.1965, revogou, apenas, as isenções de caráter geral, relativas ao Imposto Único sobre Combustíveis, não as especiais, por outras leis concedidas.

Súmula 544

Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Súmula 545

Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.

Súmula 546

Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte “de jure” não recuperou do contribuinte “de facto” o “quantum” respectivo.

Súmula 547

Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Súmula 548

É inconstitucional o Decreto-lei 643, de 19.06.1947, art. 4.º, do Paraná, na parte que exige selo proporcional sobre atos e instrumentos regulados por lei federal.

Súmula 549

A taxa de bombeiros do estado de Pernambuco é constitucional, revogada a Súmula 274.

Súmula 550

A isenção concedida pelo art. 2.º da Lei 1.815/1953, às empresas de navegação aérea não compreende a taxa de melhoramento de portos, instituída pela Lei

3.421/1958.

Súmula 551

É inconstitucional a taxa de urbanização da Lei 2.320, de 20.12.1961, instituída pelo município de Porto Alegre, porque seu fato gerador é o mesmo da transmissão imobiliária.

Súmula 553

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) contribuição para o Fisco, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra “d”, III, do art. 19 da Constituição Federal.

Súmula 563

O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no art. 9.º, I, da Constituição Federal.

Súmula 565

A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.

Súmula 569

É inconstitucional a discriminação de alíquotas do Imposto de Circulação de Mercadorias nas operações interestaduais, em razão de o destinatário ser, ou não, contribuinte.

Súmula 570

O Imposto de Circulação de Mercadorias não incide sobre a importação de bens de capital.

Súmula 571

O comprador de café ao IBC, ainda que sem expedição de nota fiscal, habilita-se quando da comercialização do produto, ao crédito do ICM que incidiu sobre a operação anterior.

Súmula 572

No cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias devido na saída de mercadorias para o exterior, não se incluem fretes pagos a terceiros, seguros e despesas de embarque.

Súmula 573

Não constitui fato gerador do Imposto de Circulação de Mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

Súmula 574

Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar.

Súmula 575

À mercadoria importada de país signatário do (GATT), ou membro da (Alalc) estende-se a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias concedida a similar nacional.

Súmula 576

É lícita a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias sobre produtos importados sob o regime da alíquota “zero”.

Súmula 577

Na importação de mercadorias do exterior, o fato gerador do Imposto de Circulação de Mercadorias ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador.

Súmula 578

Não podem os estados, a título de ressarcimento de despesas, reduzir a parcela de 20% do produto da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias, atribuída aos municípios pelo art. 23, § 8.º, da Constituição Federal.

Súmula 579

A cal virgem e a hidratada estão sujeitas ao Imposto de Circulação de

Mercadorias.

Súmula 581

A exigência de transporte em navio de bandeira brasileira, para efeito de isenção tributária, legitimou-se com o advento do Decreto-lei 666, de 02.07.1969.

Súmula 582

É constitucional a Resolução 640/1969, do Conselho de Política Aduaneira, que reduziu a alíquota do Imposto de Importação para a soda cáustica, destinada a zonas de difícil distribuição e abastecimento.

Súmula 583

Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano.

Súmula 584

O Imposto de Renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração.

Súmula 585

Não incide o Imposto de Renda sobre a remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil.

Obs.: No julgamento do RE 101.066 (*DJ* de 19.10.1965), o tribunal não conheceu do recurso, entendendo inaplicável a Súmula 585 após a vigência do Decreto-lei 1.418/1975.

Súmula 586

Incide Imposto de Renda sobre os juros remetidos para o exterior, com base em contrato de mútuo.

Súmula 587

Incide Imposto de Renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil.

Súmula 588

O Imposto sobre Serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários.

Súmula 589

É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do Imposto Predial e Territorial Urbano em função do número de imóveis do contribuinte.

Súmula 590

Calcula-se o Imposto de Transmissão “Causa Mortis” sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor.

Súmula 591

A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Súmula 595

É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural.

Súmula 597

Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança decidiu, por maioria de votos, a apelação.

Súmula 615

O princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICM.

Súmula 619 – Revogada

A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito.

Súmula 620

A sentença proferida contra autarquias não está sujeita a reexame necessário, salvo quando sucumbente em execução de dívida ativa.

Súmula 626

A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.

Súmula 648

A norma do § 3.º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.

Súmula 651

A Medida Provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.

Súmula 656

É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel.

Súmula 657

A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

Súmula 658

São constitucionais os arts. 7.º da Lei 7.787/1989 e 1.º da Lei 7.894/1989 e da Lei 8.147/1990, que majoraram a alíquota do Finsocial, quando devida a contribuição por empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços.

Súmula 659

É legítima a cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.

Súmula 660

Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.

Obs.: Inaplicável diante do advento da EC 33/2001 – art. 155, § 2.º, IX,*a*, da Constituição Federal.

Súmula 661

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Súmula 662

É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas de videocassete.

Súmula 663

Os §§ 1.º e 3.º do art. 9.º do Decreto-lei 406/1968 foram recebidos pela Constituição.

Súmula 664

É inconstitucional o inc. V do art. 1.º da Lei 8.033/1990, que instituiu a incidência do Imposto nas Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF sobre saque efetuados em caderneta de poupança.

Súmula 665

É constitucional a taxa de fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989.

Súmula 666

A contribuição confederativa de que trata o art. 8.º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Súmula 667

Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.

Súmula 668

É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

Súmula 669

Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

Súmula 670

O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

Súmula 688

É legítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre o 13.º salário.

Súmula 724

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

Súmula 730

A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de Previdência Social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

Súmula 732

É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.

Súmula 733

Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios.

Súmula 734

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 735

Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.

SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula 16

A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária.

Súmula 20

A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.

Súmula 23

O Banco Central do Brasil é parte legítima nas ações fundadas na Resolução 1.154/1986.

Súmula 49

Na exportação de café em grão, não se inclui na base de cálculo do ICM a quota de contribuição, a que se refere o art. 2.º do Decreto-lei 2.295, de 21.11.1986.

Súmula 50

O adicional de tarifa portuária incide apenas nas operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, objeto do comércio de navegação de longo curso.

Súmula 58

Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.

Súmula 65

O cancelamento, previsto no art. 29 do Decreto-lei 2.303, de 21.11.1986, não

alcança os débitos previdenciários.

Súmula 66

Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.

Súmula 68

A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS.

Súmula 71

O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICM.

Súmula 77

A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep.

Súmula 80

A taxa de melhoramento dos portos não se inclui na base de cálculo do ICM.

Súmula 84

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Súmula 87

A isenção do ICMS relativa às rações balanceadas para animais abrange o concentrado e o suplemento.

Súmula 94

A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do Finsocial.

Súmula 95

A redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados ou do Imposto de Importação não implica redução do ICMS.

Súmula 100

É devido o adicional ao frete para renovação da marinha mercante na importação sob o regime de Benefícios Fiscais à Exportação (Befiex).

Súmula 112

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Súmula 121

Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão.

Súmula 124

A taxa de melhoramento dos portos tem base de cálculo diversa do Imposto de Importação, sendo legítima a sua cobrança sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, da ALALC ou ALADI.

Súmula 125

O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

Súmula 128

Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lance superior à avaliação.

Súmula 129

O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima.

Súmula 135

O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videoteipes.

Súmula 136

O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda.

Súmula 138

O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis.

Súmula 139

Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR.

Súmula 152 – Cancelada

Na venda pelo segurador, de bens salvados de sinistros, incide o ICMS.

Obs.: Julgando o REsp 73.552-RJ, na sessão de 13.06.2007, a primeira seção deliberou pelo cancelamento da Súmula 152.

Súmula 153

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Súmula 155

O ICMS incide na importação de aeronave, por pessoa física, para uso próprio.

Súmula 156

A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.

Súmula 157 – Cancelada

É ilegítima a cobrança de taxa, pelo município, na renovação de licença para localização de estabelecimento comercial ou industrial.

Obs.: Julgando o REsp 261.751-SP – na sessão de 24.04.2002, a primeira seção deliberou pelo cancelamento da Súmula 157.

Súmula 160

É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Súmula 162

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Súmula 163

O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação.

Súmula 166

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Súmula 167

O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS.

Súmula 178

O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na justiça estadual.

Súmula 184

A microempresa de representação comercial é isenta do Imposto de Renda.

Súmula 185

Nos depósitos judiciais, não incide o Imposto sobre Operações Financeiras.

Súmula 188

Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Súmula 189

É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais.

Súmula 190

Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça.

Súmula 198

Na importação de veículo por pessoa física, destinado a uso próprio, incide o ICMS.

Súmula 210

A ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos.

Súmula 213

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Súmula 215

A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do Imposto de Renda.

Súmula 237

Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS.

Súmula 250

É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.

Súmula 262

Incide o Imposto de Renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas.

Súmula 271

A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário.

Súmula 274

O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares.

Súmula 276

As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado. (Cancelada)

Súmula 279

É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Súmula 310

O auxílio-creche não integra o Salário de Contribuição.

Súmula 314

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Súmula 334

O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet.

Súmula 339

É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Súmula 349

Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS.

Súmula 350

O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone.

Súmula 351

A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

Súmula 352

A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.

Súmula 353

As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.

Súmula 355

É válida a notificação do ato de exclusão de Programa de Recuperação Fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela internet.

Súmula 360

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

Súmula 386

São isentas de Imposto de Renda as indenizações de férias proporcionais e c respectivo adicional.

Súmula 391

O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

Súmula 392

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Súmula 393

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Súmula 394

É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de Imposto de Renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual.

Súmula 395

O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.

Súmula 397

O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

Súmula 399

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Súmula 400

O encargo de 20% previsto no DL 1.025/1969 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida.

Súmula 411

É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco.

Súmula 412

A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

Súmula 414

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Súmula 423

A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.

Súmula 424

É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987.

Súmula 425

A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.

Súmula 430

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Súmula 431

É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

Súmula 432

As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar o ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

Súmula 433

O produto semielaborado, para fins de incidência de ICMS, é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do art. 1.º da Lei Complementar 65/1991.

Súmula 435

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Súmula 436

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Súmula 437

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a quinhentos mil reais para opção pelos Refis pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a

constituição de garantia por meio do arrolamento de bens.

Súmula 446

Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Súmula 447

Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

Súmula 448

A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24.10.2000, data de vigência da Lei 10.034/2000.

Súmula 452

A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Súmula 457

Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.

Súmula 460

É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Súmula 461

O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

Súmula 468

A base de cálculo do PIS, até a edição da MP 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador.

Súmula 495

A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a creditamento de IPI.

Súmula 497

Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem.

Súmula 498

Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.

Súmula 499

As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.

Súmula 508

A isenção da Cofins concedida pelo art. 6.º, II, da LC 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei 9.430/1996.

Súmula 509

É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

Súmula 515

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.

Súmula 516

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.

Súmula 521

A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

Súmula 523

A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Súmula 524

No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.

Súmula 553

Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção

Súmula 554

Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

Súmula 555

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Súmula 556

É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1.º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6.º, VII, *b*, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.

Súmula 558

Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.

Súmula 559

Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6.º da Lei n. 6.830/1980.

Súmula 560

A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.

Súmula 569

Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback.

Súmula 583

O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais.

Súmula 585

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Súmula 590

Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.

Súmula 598

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Súmula 612

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Súmula 614

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébitos desses tributos.

Súmula 622

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Súmula 625

O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo

prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

Súmula 626

A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.

Súmula 627

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.^a REGIÃO

Súmula 01

A isenção de custas do art. 9.º, I, da Lei 6.032/1974 não desobriga seus beneficiários da reposição prevista no art. 10, § 4.º, da mesma lei.

Súmula 02

A isenção prevista no art. 9.º, I, da Lei 6.032/1974, é aplicável às causas sob jurisdição federal processadas perante a Justiça Estadual.

Súmula 05 – CANCELADA

O Adicional de Tarifa Portuária – ATP, instituído pela Lei 7.700, de 21.12.1988, incide sobre todos os serviços definidos no art. 5.º do Decreto 24.508, de 29.06.1934.

Súmula 22

São inconstitucionais, por impropriedade formal da via legislativa, os decretos-leis 2.445/1988 e 2.449/1988, que alteraram a contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).

Súmula 25

Nas ações que visem à devolução do empréstimo compulsório de combustível, cobrado indevidamente dos contribuintes, é suficiente a prova de propriedade do veículo, sendo desnecessária a comprovação da quantia paga a esse título, uma vez que o valor do resgate é de ser calculado com base nas Instruções Normativas 147/1986, 92/1987, 183/1987 e 201/1988, da SRF, sobre o consumo médio por veículo.

Súmula 29 – Cancelada

O termo inicial do prazo de prescrição do Empréstimo Compulsório sobre combustíveis, previsto no art. 10 do Decreto-lei 2.288/1986, é o primeiro dia do quarto ano subsequente ao triênio destinado à sua devolução.

Súmula 38 – Cancelada

Nas ações que visem à repetição do valor indevidamente pago a título de Empréstimo Compulsório sobre aquisição de veículo, o prazo de prescrição inicia-se no primeiro dia do quarto ano posterior ao seu recolhimento.

Súmula 41

Os índices integrais de correção monetária, incluídos os expurgos inflacionários, a serem aplicados na execução de sentença condenatória de pagamento de benefícios previdenciários, vencimentos, salários, proventos, soldos e pensões, ainda que nela não haja previsão expressa, são de 42,72% em janeiro de 1989, 10,14% em fevereiro de 1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991.

Súmula 42

Nas execuções da dívida da União, o juiz não poderá reduzir o encargo de 20% (vinte por cento), previsto no Decreto-lei 1.025/1969.

Súmula 45

Não é devida a inclusão de juros moratórios em precatório complementar, salvo se não foi observado o prazo previsto no art. 100, § 1.º, da Constituição Federal no pagamento do precatório anterior.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2.^a

REGIÃO

Súmula 1

O art. 29 do Decreto-lei 2.303, de 1986, não se aplica aos créditos previdenciários.

Súmula 2

O art. 29 do Decreto-lei 2.303, de 1986, não se aplica aos créditos do FGTS.

Súmula 3

A isenção do IOF, prevista no art. 6.º do Decreto-lei 2.434/1988, somente se aplica às importações realizadas no amparo de guias emitidas a partir de 1.º de julho de 1988.

Súmula 5 – CANCELADA

Preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN e desde que não distribuam lucros as instituições de previdência privada gozam da imunidade de impostos prevista no art. 150, VI, “c”, da Carta Magna de 1988 (art. 19, III, “c”, da Constituição Federal de 1967), ainda que cobrem pelos benefícios e serviços prestados.

Súmula 6

Execução fiscal suspensa com base no art. 40 da Lei 6.830/1980 não pode ser julgada extinta, mas arquivada sem baixa na distribuição, após o término do prazo de suspensão.

Súmula 7

Inexistindo Lei Complementar específica, o fato gerador do ICMS, antigo ICM, na hipótese prevista no art. 155, § 2.º, item IX, letra “a” da Carta Magna de 1988 continua a ser a entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário.

Súmula 8

Ajuizada a execução fiscal, de valor inferior ao limite estipulado no art. 1.º do Decreto-lei 1793/1980, não cabe ao juiz extinguir o processo sob alegação de falta de interesse processual da exequente.

Súmula 9

A conversão do Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas jurídicas nos termos do prescrito pelo art. 25 da Lei 7.730, de 31.01.1989, não exclui a incidência da atualização monetária prevista no parágrafo único do art. 15 da Lei 7.738, de 09.03.1989.

Súmula 11

É desnecessária a apresentação dos comprovantes de aquisição de combustíveis – gasolina ou álcool carburante – na ação de restituição do Empréstimo Compulsório instituído pelo Decreto-lei 2.288, de 23 de julho de 1986, que estabeleceu, desde logo, a sistemática de cálculo para sua devolução (art. 16).

Súmula 14

A remessa necessária não pode ser provida para agravar a condenação imposta à fazenda pública, haja ou não recurso voluntário das partes.

Súmula 20

O adicional de tarifa portuária (ATP) incide apenas nas operações realizadas com mercadorias importadas e exportadas, objeto do comércio de navegação de longo curso, não incidindo sobre os serviços de utilização e atracação dos portos.

Súmula 23

Não incide Imposto de Renda sobre a indenização recebida pela adesão ao programa de desligamento voluntário.

Súmula 24

A Contribuição do salário-educação é constitucional, posto que foi expressamente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, através do art. 212, § 5.º, não cabendo, portanto, a sua compensação.

Súmula 25

Nas ações que versem sobre a inexigibilidade do salário-educação, devem figurar no polo passivo da relação processual, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Súmula 31

Na execução fiscal, é vedada a nomeação à penhora de títulos da dívida pública sem liquidez imediata, de difícil ou duvidosa liquidação.

Súmula 34

A Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga aos administradores, autônomos e avulsos, tendo sido declarada inconstitucional, pode ser compensada com contribuições da mesma espécie, desnecessária a comprovação de inexistência de repercussão ou repasse, dada à sua natureza de tributo direto.

Súmula 37

A isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) depende da existência de ato internacional de natureza contratual, firmado pelo Brasil concedendo o benefício à mercadoria importada, não podendo ser concedida por acordo ou tratado de caráter geral, cujo objeto é a regulamentação do comércio internacional.

Súmula 38

As importações de mercadorias realizadas após 1.º de março de 1989, data em que entrou em vigor o sistema tributário nacional instituído pela constituição federal vigente, são regidas pelas leis dos estados e do distrito federal, editadas com fundamento nos convênios, nos termos do § 8.º do art. 34 do ADCT, tendo como fato gerador do ICMS o recebimento da mercadoria pelo importador, que ocorre com o despacho aduaneiro, e aquelas importadas antes da referida data, continuam sujeitas à Súmula 7 deste tribunal, considerando-se como fato gerador a entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário.

Súmula 50

As anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil não têm natureza tributária e estão afeitas às turmas especializadas em direito administrativo.

Súmula 52

É inconstitucional a expressão “**observado, quanto ao art. 3.º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional**”, constante do art. 4.º, segunda parte, da Lei Complementar 118, de 09 de

fevereiro de 2005, por violação ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.^a REGIÃO

Súmula 1

Em matéria fiscal é cabível medida cautelar de depósito, inclusive quando a ação principal for declaratória de inexistência de obrigação tributária.

Súmula 2

É direito do contribuinte, em ação cautelar, fazer o depósito integral de quantia em dinheiro para suspender a exigibilidade de crédito tributário.

Súmula 3

É ilegal a exigência da comprovação do prévio recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços como condição para a liberação de mercadorias importadas.

Súmula 4 – REVISADA PELA SÚMULA 11

A Fazenda Pública – nesta expressão incluídas as autarquias – nas execuções fiscais, não está sujeita ao prévio pagamento de despesas para custear diligência de Oficial de Justiça.

Súmula 11

Na execução fiscal, a fazenda pública está obrigada a adiantar as despesas de transporte do Oficial de Justiça.

Súmula 12

Não incide o Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida a título da denominada demissão incentivada ou voluntária.

Súmula 16

Basta a comprovação da propriedade do veículo para assegurar a devolução, pela média de consumo, do empréstimo compulsório sobre a compra de gasolina e álcool

previsto no Decreto-lei 2.288/1986.

Súmula 17

Não incide Imposto de Renda sobre verba indenizatória paga a título de férias vencidas e não gozadas em caso de rescisão contratual.

Súmula 21

A União federal possui legitimidade passiva nas ações decorrentes do Empréstimo Compulsório previsto no Decreto-lei 2.288/1986.

Súmula 28

O PIS é devido no regime da Lei Complementar 7/1970 e legislação subsequente até o termo inicial de vigência da MP 1.212/1995, diante da suspensão dos Decretos-leis 2.445/1988 e 2.449/1988 pela Resolução 49/1995, do Senado Federal.

Súmula 30

É constitucional o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica previsto na Lei 4.156/1962, sendo legítima a sua cobrança até o exercício de 1993.

Súmula 31

Na hipótese de suspensão da execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/1980, decorrido o prazo legal, serão os autos arquivados sem extinção do processo ou baixa na distribuição.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.^a REGIÃO

Súmula 1

É inconstitucional a exigência do empréstimo compulsório instituído pelo art. 10 do Decreto-lei 2.288, de 1986, na aquisição de veículos de passeio e utilitários.

Súmula 4

É constitucional a isenção prevista no art. 6.º do Decreto-lei 2.434, de 19.05.1988.

Súmula 5

A correção monetária incidente até a data do ajuizamento deve integrar o valor da causa na ação de repetição de indébito.

Súmula 6

A autoridade administrativa não pode, com base na Instrução Normativa 54/1981 – SRF, exigir a comprovação do recolhimento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Súmula 7

É inconstitucional o art. 8.º da Lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988.

Súmula 12

Na execução fiscal, quando a ciência da penhora for pessoal, o prazo para a oposição dos embargos de devedor inicia no dia seguinte ao da intimação deste.

Súmula 13

É inconstitucional o empréstimo compulsório incidente sobre a compra de gasolina e álcool, instituído pelo art. 10 do Decreto-lei 2.288, de 1986.

Súmula 14 – CANCELADA

É constitucional o inc. I do art. 3.º da Lei 7.787, de 1989.

Súmula 18

O depósito judicial destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário somente poderá ser levantado ou convertido em renda, após o trânsito em julgado da sentença.

Súmula 20

O art. 8.º, § 1.º, da Lei 8.620/1993 não isenta o INSS das custas judiciais, quando demandado na justiça estadual.

Súmula 21

É constitucional a Contribuição Social criada pelo art. 1.º da Lei Complementar 70, de 1991.

Súmula 22

É inconstitucional a cobrança da taxa ou do emolumento para licenciamento de importação, de que trata o art. 10 da Lei 2.145/1953, com a redação da Lei 7.690/1988 e da Lei 8.387/1991.

Súmula 23

É legítima a cobrança do Empréstimo Compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica, instituído pela Lei 4.156/1962, inclusive na vigência da Constituição Federal de 1988.

Súmula 28

São inconstitucionais as alterações introduzidas no Programa de Integração Social (PIS) pelos Decretos-leis 2.445/1988 e 2.449/1988.

Súmula 31

Na ação de repetição do indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trânsito da sentença em julgado.

Súmula 32

No cálculo de liquidação de débito judicial, inclui-se o índice de 42,72% relativo à correção monetária de janeiro de 1989.

Súmula 33

A devolução do Empréstimo Compulsório sobre combustíveis (art. 10 do Decreto-lei 2.288/1986) independe da apresentação das notas fiscais.

Súmula 34

Os municípios são imunes ao pagamento de IOF sobre suas aplicações financeiras.

Súmula 37

Na liquidação de débito resultante de decisão judicial, incluem-se os índices relativos ao IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.

Súmula 43

As contribuições para o FGTS não têm natureza tributária, sujeitando-se ao prazo prescricional de trinta anos.

Súmula 44

É inconstitucional a Contribuição Previdenciária sobre *opro labore* dos administradores, autônomos e avulsos, prevista nas Leis 7.787/1989 e 8.212/1991.

Súmula 45

Descabe a concessão de liminar ou de antecipação de tutela para a compensação de tributos.

Súmula 46

É incabível a extinção do processo de execução fiscal pela falta de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis (art. 40 da Lei 6.830/1980).

Súmula 50

Não há direito adquirido à Contribuição Previdenciária sobre o teto máximo de 20 salários mínimos após a entrada em vigor da Lei 7.787/1989.

Súmula 54

Os valores recebidos a título de incentivo à demissão voluntária não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda.

Súmula 55

É constitucional a exigência de depósito prévio da multa para interposição de recurso administrativo, nas hipóteses previstas pelo art. 93 da Lei 8.212/1991 – com a redação dada pela Lei 8.870/1994 – e pelo art. 636, § 1.º, da CLT.

Súmula 58

A execução fiscal contra a fazenda pública rege-se pelo procedimento previsto no art. 730 do Código de Processo Civil.

Súmula 59

A UFIR, como índice de correção monetária de débitos e créditos tributários, passou a vigor a partir de janeiro de 1992.

Súmula 63

Não é aplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal nas ações rescisórias versando matéria constitucional.

Súmula 78

A constituição definitiva do crédito tributário é pressuposto da persecução penal concernente a crime contra a ordem tributária previsto no art. 1.º da Lei 8.137/1990.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO

Súmula 2

A empresa que teve reconhecido o direito à isenção do Imposto de Renda, de conformidade com o art. 13 da Lei 4.239, de 27.06.1963, com a redação dada pelo art. 1.º do Decreto-lei 1.564, de 29.06.1977, antes do advento da Lei 7.450, de 23.12.1985, tem direito adquirido de ver seu pedido de prorrogação examinado pela Sudene e obter a ampliação do benefício por até mais cinco anos, se comprovado o atendimento das condições estabelecidas no art. 3.º do Decreto-lei 1.564, de 29.06.1977.

Súmula 4

É válida a cobrança da contribuição prevista no Decreto-lei 308/1967, com base no limite máximo estabelecido no Decreto-lei 1.952/1982.

Súmula 6

Subsiste, até vigência e eficácia da Lei Complementar 70/1991, a cobrança do Finsocial, com base no Decreto-lei 1.940/1982, sendo inconstitucionais as alterações introduzidas pela Lei 7.887/1989, ressalvada a situação das empresas prestadoras de serviços.

Súmula 7

São inconstitucionais as alterações na contribuição para o Programa de Integração Social introduzidas pelos Decretos-leis 2.445 e 2.449.

Súmula 10

A contribuição previdenciária incide sobre a parte da folha de pagamentos da empresa aos seus administradores, sócios-gerentes e autônomos.

Súmula 12

É inconstitucional o empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei 2.288/1986. Legitimidade passiva da União para a causa.

Súmula 13

O empréstimo compulsório em favor da Eletrobras foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Súmula 14

É inconstitucional a cobrança da taxa de expediente para emissão de guia de importação (Lei 7.690/1988, art. 10).

Súmula 15

É válida a cobrança da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários (Lei 7.940/1989), com base em tabela, por faixas de contribuintes.

SÚMULAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF

Súmula 1

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula 3

Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 4

A partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 5

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 6

É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 7

A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 8

O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de

08/06/2018).

Súmula 9

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 10

Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018) (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 11

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 12

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 13

Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o declarante detenha a guarda judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 14

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não

autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula 15

A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 16

O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1º de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 17

Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 18

A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 19

Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei nº 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 20

Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 21

É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação da autoridade que a expediu. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 22

É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei nº 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 23

A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre, de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação das fontes pesquisadas. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 24

Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 25

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma

das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 26

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei nº 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 27

É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 28

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 29

Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 30

Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 31

Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do procedimento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 32

A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 33

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 34

Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 35

O art. 11, § 3º, da Lei nº 9.311/96, com a redação dada pela Lei nº 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 36

A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica:

em excluir da exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 37

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 38

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 39

Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF nº 578, de 27/12/2017, DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF nº 3 de 09/01/2018).

Súmula 40

A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 41

A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 42

Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 43

Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.

Súmula 44

Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou titular de pessoa jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de obrigatoriedade de apresentação dessa declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula 45

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Súmula 46

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 47

Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico. (Súmula revogada pela Portaria CARF nº 72 de 17/10/2017).

Súmula 48

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 49

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 50

É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 51

As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de natureza tributária. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 52

Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.

Súmula 53

Não se aplica ao resultado decorrente da exploração de atividade rural o limite de 30% do lucro líquido ajustado, relativamente à compensação da base de cálculo negativa de CSLL, mesmo para os fatos ocorridos antes da vigência do art. 42 da

Medida Provisória nº 1991-15, de 10 de março de 2000.

Súmula 54

A constatação de existência de “passivo não comprovado” autoriza o lançamento com base em presunção legal de omissão de receitas somente a partir do ano-calendário de 1997.

Súmula 55

O saldo devedor da correção monetária complementar, correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 56

No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de julho de 2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV, XVII e XVIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1º de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 57

A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 58

No regime do Lucro Real, as variações monetárias ativas decorrentes de depósitos judiciais com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário devem compor o resultado do exercício, segundo o regime de competência, salvo se demonstrado que as variações monetárias passivas incidentes sobre o tributo objeto dos depósitos não foram computadas na apuração desse resultado. (Súmula

revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 59

A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 60

Os juros aplicados na restituição de valores indevidamente retidos na fonte, quando do recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da adesão a programas de demissão voluntária, devem ser calculados a partir da data do recebimento dos rendimentos, se ocorrido entre 1º de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997, ou a partir do mês subsequente, se posterior. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 61

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 62

A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 63

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,

reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Súmula 64

Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7º, inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.

Súmula 65

Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Súmula 66

Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 67

Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 68

A Lei nº 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 69

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 70

É imune ao ITR o imóvel pertencente às entidades indicadas no artigo 150, VI, c da Constituição, que se encontra arrendado, desde que a receita assim obtida seja aplicada nas atividades essenciais da entidade. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 71

Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 72

Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 73

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Súmula 74

Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei nº 11.488, de 2007, que revogou a multa de ofício isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art. 44, § 1º, II, da Lei nº 9.430/96. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 75

A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 76

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 77

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 78

A fixação do termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese de lançamento sobre lucros disponibilizados no exterior, deve levar em consideração a data em que se considera ocorrida a disponibilização, e não a data do aferimento dos lucros pela empresa sediada no exterior. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 79

A partir da vigência da Lei nº 9.249, de 1995, a dedução de contraprestações de arrendamento mercantil exige a comprovação da necessidade de utilização dos bens arrendados para produção ou comercialização de bens e serviços. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo

das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula 81

É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 82

Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 83

O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei nº 10.865 de 2004.

Súmula 84

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 85

Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses veículos.

Súmula 86

É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 87

O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 88

A “Relação de Corresponsáveis – CORESP”, o “Relatório de Representante Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 89

A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Súmula 90

Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 91

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 92

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nen

instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.

Súmula 93

A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 94

Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir da vigência da MP nº 2.158-35, de 2001. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 95

A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 96

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Súmula 97

O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a receita bruta. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 98

A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário. (Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).

Súmula 99

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4º, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Súmula 100

O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 101

Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 102

É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 103

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Súmula 104

Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173 inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 105

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1º, inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajusto anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Súmula 106

Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 107

A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP nº 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula 108

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 109

O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre

controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 110

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 111

O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto nº 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 112

É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 113

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 114

O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 115

A sistemática de cálculo do “Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)” prevista na Instrução Normativa

SRF nº 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei nº 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei nº 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 116

Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 117

A indedutibilidade de despesas com “royalties” prevista no art. 71, parágrafo único, alínea “d”, da Lei nº 4.506, de 1964, não é aplicável à apuração da CSLL (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 118

Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 119

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória nº 449, de 2008, convertida na Lei nº 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 120

Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 121

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 122

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 123

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 124

A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como “não tributados” não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1º da Lei nº 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 125

No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei nº 10.833, de 2003.

Súmula 126

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei nº 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula 127

A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.

Súmula 128

No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei nº 9.363, de 1996 e a Portaria MF nº 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação – RE, quanto da Receita Operacional Bruta – ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de exportação – numerador e denominador. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

QUINTA PARTE

EXERCÍCIOS E GABARITOS

1

EXERCÍCIOS

Os exercícios listados a seguir tiveram como fonte os exames para ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

A prova prático-profissional para os aprovados na primeira fase é composta de uma redação de peça profissional e quatro questões, sob a forma de situação problema.

Nos editais do exame da OAB para a segunda fase em Direito Tributário compreende-se o **processo administrativo fiscal**, abrangendo a consulta e o contencioso administrativo, e o **processo judicial tributário**, compreendendo tanto as ações de iniciativa do Fisco quanto as ações de iniciativa do contribuinte.

Assim, a finalidade dos exercícios é propiciar aos candidatos e futuros advogados condições suficientes para a aprovação no respectivo exame na segunda fase, dentro dos parâmetros estabelecidos pela banca examinadora.

*Assista ao vídeo
sobre o tema.*

<https://youtu.be/Tjlhq15fpc>



EXERCÍCIOS DE PEÇAS PRÁTICO-PROFISSIONAIS

EXERCÍCIO 01 – EXAME 2010.2

Em 10.05.2005 *Livina Maria Andrade* arrematou judicialmente um imóvel por R\$ 350.000,00 localizado no Município de Rancho Queimado. Recolheu o ITBI, com base no valor arrematado em juízo.

A Sra. *Livina Maria Andrade* é agricultora e utiliza o imóvel para a produção agrícola e pecuária.

O imóvel está dentro da zona urbana definida por lei pelo Município, já que a rua onde se encontra o imóvel é asfaltada e o Município fornece água e sistema de esgoto sanitário.

Em 10.05.2008 recebeu notificação fiscal exigindo diferenças no valor do ITBI pago por ocasião da aquisição judicial do imóvel. O Fisco Municipal entendeu que o tributo deveria ser calculado com base no valor da avaliação judicial realizada no processo de execução no qual ocorreu a arrematação (R\$ 380.000,00). A Sra. *Livina* permaneceu inerte e é inscrita em dívida ativa em 10.08.2008.

Em 10.06.2010 foi citada em execução fiscal proposta pelo Município de Rancho Queimado para a cobrança do ITBI e do IPTU dos anos de 2007, 2008 e 2009, os quais nunca foram pagos.

A Sra. *Livina* tem bens penhorados em 10.07.2010 e lhe procura, em 20.07.2010, para a defesa de seus direitos.

Na qualidade de advogado da Sra. *Livina*, elabore a peça processual que melhor atenda o seu direito, especificando seus fundamentos.

EXERCÍCIO 02 – EXAME 2010.3

A empresa Mercantil Ltda. possui como atividade a incorporação e loteamento de empreendimentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro. Em março de 2001, José dos Santos, após exercer a gerência da empresa Mercantil Ltda. por mais de cinco anos, decide se retirar

da sociedade em decorrência de divergências com os planos de expansão da Mercantil Ltda., desejada pelos demais sócios quotistas. José dos Santos aliena as suas quotas para os demais sócios quotistas, os quais assumem a gerência da sociedade e prosseguem nas atividades comerciais da empresa. A Mercantil Ltda., após dois anos de aquisição de novos terrenos, alcança a terceira posição no *ranking* das maiores empresas imobiliárias na cidade do Rio de Janeiro, cujo critério é o faturamento advindo de lançamentos imobiliários em cada ano. Em julho de 2003, contudo, a Secretaria da Receita Federal, em fiscalização realizada na empresa, acaba por realizar uma autuação sobre a Mercantil Ltda., objetivando a cobrança de IRPJ/CSL devidos e não pagos, referentes aos períodos de apuração de janeiro de 1999 a dezembro de 2000, sob a alegação de que determinadas despesas não poderiam ter sido excluídas da base de cálculo dos referidos tributos por não serem despesas diretamente necessárias às atividades da Mercantil Ltda., entre as quais, as despesas de corretagem incorridas na aquisição dos terrenos. Ao término do processo administrativo, a autuação é mantida, e o crédito tributário exigido é posteriormente inscrito em dívida ativa. É ajuizada, em decorrência, execução fiscal, distribuída para o Juízo da 2.^a Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro, com base em Certidão de Dívida Ativa expedida em face de Mercantil Ltda. e de José dos Santos, este na qualidade de corresponsável. Ambos são citados e ofereceram, há dez dias, bens à penhora.

Na qualidade de advogado de José dos Santos, elabore a medida judicial competente para a defesa dos interesses de José dos Santos.

EXERCÍCIO 03 – IV EXAME UNIFICADO

Equipamentos (partes e peças) que estavam sendo transportados para a empresa Micro Informática Ltda. e que seriam utilizados em sua produção foram apreendidos, sob a alegação da Secretaria de

Arrecadação Estadual de que a nota fiscal que os acompanhava não registrava uma diferença de alíquota devida ao Fisco e não teria havido, portanto, o recolhimento do imposto. Na ocasião, houve o auto de infração e foi realizado o respectivo lançamento. A empresa, que tem uma encomenda para entregar, procura você, na condição de advogado, para a defesa de seus interesses.

Na qualidade de advogado da empresa Micro Informática, apresente a peça processual cabível para a defesa dos interesses da empresa, empregando todos os argumentos e fundamentos jurídicos cabíveis.

EXERCÍCIO 04 – V EXAME UNIFICADO

Xisto da Silva, brasileiro, administrador, solteiro, portador da carteira de identidade n. xxxx e CPF n. xxx, residente e domiciliado na Rua X, n. xxx, bairro Z, Município Y, Estado F, recebeu cobrança simultânea, por meio de uma mesma guia de documento fiscal, de dois tributos: IPTU e Taxa de Conservação das Vias e Logradouros Públicos (TCVLP). No caso da referida taxa, certo é que o contribuinte não concorda com sua cobrança, o que o levou, por meio de seu advogado, a ajuizar ação judicial a fim de declarar sua inconstitucionalidade, havendo pedido liminar, ainda não apreciado, para afastar a obrigatoriedade do recolhimento da referida exação fiscal. Por outro lado, em relação à cobrança do IPTU, pretende o contribuinte efetuar o seu pagamento. No entanto, a guia de pagamento é única e contém o valor global dos referidos tributos, tendo o banco rejeitado o pagamento parcial relativo somente ao IPTU.

Nesse caso, considerando que o IPTU ainda não está vencido, bem como o contribuinte não obteve êxito para solucionar seu problema na esfera administrativa, elabore a peça adequada para efetuar o pagamento do imposto municipal, com base no direito material e processual pertinente. Utilize todos os argumentos e fundamentos

pertinentes à melhor resposta. (Valor: 5,0)

EXERCÍCIO 05 – VI EXAME UNIFICADO

Lei Municipal, publicada em 1.º.06.2010, estabeleceu, entre outras providências relacionadas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a majoração da alíquota para os serviços de hospedagem, turismo, viagens e congêneres de 3% para 5%, com vigência a partir de 1.º.07.2010.

À vista disso, o Hotel Boa Hospedagem Ltda., que, em junho de 2010 recolhia, a título de ISS, o valor de R\$ 30.000,00, com base na contratação dos seus serviços por empresas locais para hospedagem de funcionários, com a majoração da alíquota acima mencionada, incidente sobre a sua atividade econômica, passou a recolher, mensalmente, o valor de R\$ 50.000,00. Todavia, as referidas empresas-cliente exigiram – e obtiveram – desconto do valor do aumento do tributo, alegando que seria indevido.

Assim sendo, o contribuinte do ISS se submeteu ao aumento desse imposto durante o período relativo ao mês de agosto a dezembro/2010. Ocorre que, em janeiro de 2011, mediante notícia publicada em jornal de grande circulação, o representante legal dessa empresa teve conhecimento da propositura de ações deflagradas por empresas hoteleiras e de turismo questionando a legalidade do aludido aumento do ISS.

Dessa forma, na qualidade de advogado(a) do Hotel Boa Hospedagem Ltda., formule a peça adequada para a defesa dos seus interesses, de forma completa e fundamentada, com base no direito material e processual tributário.

EXERCÍCIO 06 – VII EXAME UNIFICADO

A Administração Fazendária de determinado Estado, por entender que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT enquadra-se

como contribuinte do IPVA incidente sobre os novos veículos de sua frota, adquiridos e emplacados em seu território, efetuou lançamento tributário direto relativo ao respectivo imposto de sua competência.

Todavia, a aludida empresa, que se encontra no prazo regular para pagamento do IPVA, não quitou o imposto por discordar de sua cobrança, entendendo não ser seu contribuinte, ante a relevância dos serviços de natureza postal para a população.

Sabendo-se que a referida Empresa pretende viabilizar demanda judicial para a defesa dos seus interesses, uma vez que não houve oferecimento de defesa administrativa em tempo hábil, bem como, contados da data da notificação do lançamento tributário até o presente momento consumaram-se 90 (noventa) dias, nessa situação hipotética, redija, na qualidade de advogado contratado pela ECT, a petição pertinente que traga o rito mais célere, com base no direito material e processual tributário, ciente da desnecessidade de outras provas, que não sejam documentais.

EXERCÍCIO 07 – VIII EXAME UNIFICADO

A Construtora Segura Ltda. está sendo executada pela Fazenda Pública Municipal. Entretanto, a empresa havia proposto uma ação de consignação em pagamento, com relação ao mesmo débito apontado na CDA que dá fundamento à execução fiscal, tendo obtido ganho de causa, sendo certo que a sentença transitou em julgado.

Ocorre que a Fazenda Municipal, ao invés de levantar os valores consignados, permitindo a baixa do feito, propôs a execução, mesmo já tendo ocorrido a baixa da inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, determinada pela sentença na consignatória, que deu por cumprida a obrigação fiscal da empresa.

A Construtora Segura Ltda., *expert* na matéria, ingressou com exceção de pré-executividade, que foi liminarmente rejeitada, entendendo o Juiz que o tema deveria ser tratado em sede de

embargos, após a segurança do Juízo.

Prepare o recurso cabível da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando-o de forma completa, registrando toda a matéria de direito processual e material pertinente.

EXERCÍCIO 08 – IX EXAME UNIFICADO

Uma instituição de ensino superior, sem fins lucrativos, explora, em terreno de sua propriedade, serviço de estacionamento para veículos, cuja renda é revertida integralmente para manter suas finalidades essenciais.

Ocorre que tal instituição foi autuada pela Fiscalização Municipal, sob o fundamento de ausência de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativo aos exercício fiscais de 2008, 2009, 2010 e 2011, visto que a atividade econômica, serviços de estacionamento, consta da lista de serviços anexa à lei municipal tributária aplicável à espécie.

A referida instituição pretende viabilizar demanda judicial para a defesa dos seus interesses, uma vez que não houve oferecimento de defesa administrativa em tempo hábil, bem como, contados da data do recebimento do auto de infração pelo Administrador responsável pela instituição até o presente momento, tem-se o total de 100 (cem) dias.

Nesta situação hipotética, considerando que tudo está comprovado documentalmente e que o pagamento do tributo inviabilizaria os investimentos necessários para manter e ampliar os serviços educacionais que a instituição presta, apresente a fórmula jurídica processual mais rápida e eficaz para solucionar a situação descrita, esgotando os fundamentos de direito processual e material, ciente de que, entre a data da autuação e a sua constituição como patrono da referida instituição, transcorreram menos de dois dias.

EXERCÍCIO 09 – X EXAME UNIFICADO

Em ação de indenização, em que determinada empresa fora condenada a pagar danos materiais e morais a Tício Romano, o Juiz, na fase de cumprimento de sentença, autorizou a liberação parcial do pagamento efetuado pelo executado e determinou a dedução do percentual de 27,5% a título de imposto de renda sobre os valores depositados. Determinou ainda a expedição do mandado de pagamento relativo ao depósito da condenação e a baixa e arquivamento dos autos.

Na qualidade de advogado de Tício, redija a peça processual adequada que deve ser proposta em oposição a tal retenção, já superada qualquer dúvida sobre o teor da decisão. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão do cliente, sendo certo que a publicação da decisão mencionada se deu na data de hoje (dia da realização desta prova).

EXERCÍCIO 10 – XI EXAME UNIFICADO

O estabelecimento da sociedade WYZ Ltda., cujo objeto é a venda de gêneros alimentícios, foi interditado pela autoridade fazendária municipal, Coordenador Municipal de Tributação, com fundamento na Lei Municipal – que por sua vez prevê a interdição por falta de pagamento de taxa de inspeção sanitária já devidamente constituída pelo lançamento.

Diante disso, o administrador da sociedade procura um advogado, imediatamente após o ato de interdição, munido dos documentos necessários para a comprovação do seu direito, solicitando a reversão do ato de interdição do seu estabelecimento o mais breve possível, pois a continuidade de seu negócio está comprometida. Pede o administrador, ainda, que seu advogado ajuíze medida judicial que, na hipótese de eventual insucesso, não acarrete o risco de condenação

da sociedade WYZ Ltda. em verba honorária em favor da parte contrária.

Na qualidade de advogado da sociedade WYZ Ltda., redija a petição inicial mais adequada à necessidade do seu cliente, com o objetivo de reverter judicialmente o ato administrativo de interdição do estabelecimento, ciente de que a prova necessária é puramente documental.

A peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão.

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

EXERCÍCIO 11 – XII EXAME UNIFICADO

Felipe das Neves, 20 anos, portador de grave deficiência mental, vem procurá-lo, juntamente com seu pai e responsável, eis que pretendeu adquirir um carro, para ser dirigido por terceiro, a fim de facilitar sua locomoção, inclusive para tratamentos a que se submete semanalmente. Entretanto, o Delegado da Delegacia Regional Tributária negou-lhe o benefício que buscava usufruir, para não pagar ICMS e IPVA. Este benefício está previsto na Lei WWW/00, qual dispõe: “*os portadores de deficiência poderão adquirir veículo automotivo com isenção integral de ICMS e IPVA, sendo os carros de produção nacional, com adaptação e características especiais indispensáveis ao uso exclusivo do adquirente portador de paraplegia, impossibilitado de usar os modelos comuns.*”

Foi impetrado Mandado de Segurança, com pedido de liminar, para que Felipe obtivesse o benefício pretendido. Entretanto, o Juízo negou a liminar, referindo que não se vislumbra a presença de fumaça do bom direito em que se arrime o pleito liminar referido pelo Impetrante. O fundamento foi o de que a norma isentiva tem caráter excepcional e se aplica apenas aos portadores de deficiência física e não aos portadores de deficiência mental. Além disso,

segundo a decisão, a norma pressupõe que o beneficiário da isenção esteja apto a dirigir, tanto que é concedido para contrabalançar as despesas na adaptação do carro. Trata-se, primeiramente, de opção legislativa que não cabe ao intérprete superar. Igualmente, não demonstrado qualquer perigo na demora da solução do caso – afirmou a decisão.

Na qualidade de advogado de Felipe, e ciente de que já vencido o prazo para a interposição de eventuais Embargos de Declaração, mas não superado 10 (dez) dias da data da publicação da decisão, elabore o recurso cabível da decisão que negou a liminar, apresentando todos os fundamentos necessários à melhor defesa do interesse de Felipe, tanto no que pertine ao direito a ser aplicado, quanto à sua interpretação.

EXERCÍCIO 12 – XIII EXAME UNIFICADO

Determinada pessoa jurídica declarou, em formulário próprio estadual, débito de ICMS. Apesar de ter apresentado a declaração, não efetuou o recolhimento do crédito tributário correspondente, o que motivou sua inscrição em dívida ativa.

Em execução fiscal promovida pelo Estado da Federação na 9.^a Vara de Fazenda da Comarca da Capital, o sócio administrador, Fulano de Tal, foi indicado como fiel depositário de um veículo da pessoa jurídica executada, que foi penhorado. A pessoa jurídica ofereceu embargos à execução, ao final julgados improcedentes. A Fazenda do Estado requer, então, a reavaliação do veículo para futuro leilão, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que o veículo não mais está na posse do sócio e não é mais encontrado. A Fazenda do Estado requer e é deferida a inclusão de Fulano de Tal no polo passivo, em razão do inadimplemento do tributo e ainda com base em lei do Estado que assim dispõe:

Artigo X. São responsáveis, de forma solidária, com base no artigo

124, do CTN, pelo pagamento do imposto:

(...)

X – O sócio administrador de empresa que descumpriu seus deveres legais de fiel depositário em processo de execução fiscal;

(...)

O Sr. Fulano de Tal foi citado e intimado a respeito de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, tendo transcorrido 6 (seis) meses desta sua citação/intimação. Nas tentativas de penhora, não foram encontrados bens.

Na qualidade de advogado de Fulano de Tal, redija a peça processual adequada para a defesa nos próprios autos da execução fiscal, considerando que seu cliente não dispõe de nenhum bem para ofertar ao juízo. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão do cliente.

EXERCÍCIO 13 – XIV EXAME UNIFICADO

Em março de 2014, o Estado A instituiu, por meio de decreto, taxa de serviço de segurança devida pelas pessoas jurídicas com sede naquele Estado, com base de cálculo correspondente a 3% (três por cento) do seu faturamento líquido mensal. A taxa, devida trimestralmente por seus sujeitos passivos, foi criada com o objetivo de remunerar o serviço de segurança pública prestado na região. A taxa passou a ser exigível a partir da data da publicação do decreto que a instituiu.

Dez dias após a publicação do decreto (antes, portanto, da data de recolhimento da taxa), a pessoa jurídica PJ Ltda. decide impugnar o novo tributo, desde que sem o risco de suportar os custos de honorários advocatícios na eventualidade de insucesso na demanda, tendo em vista que pretende participar de processo licitatório em data próxima, para o qual é indispensável a apresentação de certidão de regularidade fiscal, a qual será obstada caso a pessoa jurídica deixe de pagar o tributo sem o amparo de uma medida judicial.

Considerando a situação econômica do contribuinte, elabore a medida judicial adequada para a impugnação do novo tributo e a garantia da certidão de regularidade fiscal necessária à sua participação na licitação, considerando a desnecessidade de dilação probatória e indicando todos os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso.

EXERCÍCIO 14 – XV EXAME UNIFICADO

Em 2003, João ingressou como sócio da sociedade D Ltda. Como já trabalhava em outro local, João preferiu não participar da administração da sociedade. Em janeiro de 2012, o Município X, ao verificar que a D Ltda. deixou de pagar o IPTU lançado no ano de 2004, referente ao imóvel próprio em que tem sede, inscreveu a sociedade em dívida ativa e ajuizou execução fiscal em face desta, visando à cobrança do IPTU e dos acréscimos legais cabíveis. Após a citação da pessoa jurídica, que não apresentou defesa e não garantiu a execução, a Fazenda Municipal solicitou a inclusão de João no polo passivo da execução fiscal, em razão de sua participação societária na executada, o que foi deferido pelo Juiz. João, citado em fevereiro de 2012, procura um advogado e explica que passa por grave situação financeira e que não poderá garantir a execução, além de não possuir qualquer bem passível de penhora. Ao analisar a documentação trazida por João, o advogado verifica que há prova documental inequívoca de seu direito. Assim, como advogado de João, elabore a peça adequada à defesa de seu cliente nos próprios autos da execução fiscal.

EXERCÍCIO 15 – XVI EXAME UNIFICADO

A pessoa jurídica A, fabricante de refrigerantes, recolheu em montante superior ao devido o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações de venda à pessoa jurídica B (distribuidora de bebidas), nos anos de 2013 e 2014. Ao

verificar o equívoco, a pessoa jurídica A ajuizou ação, em dezembro de 2014, visando à compensação do indébito do IPI, correspondente ao valor pago em excesso, com débitos do mesmo tributo, anexando, para tanto, autorização expressa da pessoa jurídica B para que ela (pessoa jurídica A) pleiteasse a repetição. A referida ação foi distribuída à 4.^a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado X e foi devidamente contestada pela União. Ao proferir a sentença, o juiz julgou improcedente o pedido, condenado a Autora nos ônus da sucumbência, por entender que (i) o pedido de compensação deveria ter sido realizado inicialmente por meio da via administrativa; (ii) apenas a pessoa jurídica B, contribuinte de fato do imposto, possui legitimidade para pleitear a repetição de indébito do IPI, uma vez que apenas ela suportou o encargo financeiro do tributo; e (iii) somente é possível a repetição do indébito, sendo incabível o pedido de compensação. Diante do exposto, elabore, como advogado(a) da pessoa jurídica A, a medida judicial cabível contra a decisão publicada ontem, para a defesa dos interesses de sua cliente, abordando as teses e os fundamentos legais que poderiam ser usados em favor do autor, ciente de que inexiste qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão. Obs.: responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

EXERCÍCIO 16 – XVII EXAME UNIFICADO

A sociedade empresária XYZ Ltda., citada em execução fiscal promovida pelo município para a cobrança de crédito tributário de ISSQN, realizou depósito integral e opôs embargos à execução. Após a instrução probatória, sobreveio sentença de improcedência dos embargos, contra a qual foi interposto recurso de apelação recebido em seu regular efeito devolutivo (art. 520, V, do CPC). A Fazenda Municipal, após contra-arrazoar o recurso, requer o desapensamento dos autos dos embargos. O Juízo determina o desapensamento e

remete os autos dos embargos para o Tribunal. Um mês após, é aberta vista na execução fiscal à Fazenda Municipal, que requer a conversão em renda do depósito judicial, nos termos do art. 156, VI, do CTN alegando que a execução fiscal é definitiva e não provisória (art. 587 do CPC e Súmula 317 do STJ). O Juízo defere o pedido da Fazenda proferindo decisão interlocutória na qual determina a conversão em renda do depósito e determina a intimação das partes para requererem o que entenderem de direito. Não há, na decisão proferida, qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Na qualidade de advogado(a) de XYZ Ltda., redija a peça recursal adequada a evitar que haja a imediata conversão do depósito em renda.

EXERCÍCIO 17 – XVIII EXAME UNIFICADO

O Município Beta instituiu por meio de lei complementar, publicada em 28 de dezembro de 2012, Taxa de Iluminação Pública (TIP). A lei complementar previa que os proprietários de imóveis em áreas do Município Beta, que contassem com iluminação pública, seriam os contribuintes do tributo. O novo tributo incidiria uma única vez ao ano, em janeiro, à alíquota de 0,5%, e a base de cálculo seria o valor venal do imóvel, utilizado para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) lançado no exercício anterior. Fulano de Tal, proprietário de imóvel servido por iluminação pública no Município Beta, recebeu em sua residência, no início de janeiro de 2013, o boleto de cobrança da TIP relativo àquele exercício (2013), no valor de 0,5% do valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do IPTU lançado no exercício de 2012 – tudo em conformidade com o previsto na lei complementar municipal instituidora da TIP. O tributo não foi recolhido e Fulano de Tal contratou advogado para ajuizar ação anulatória do débito fiscal. Apesar dos bons fundamentos em favor de Fulano de Tal, sua ação anulatória foi julgada improcedente. A apelação interposta foi admitida na primeira instância e regularmente processada, sendo os

autos encaminhados ao Tribunal de Justiça após a apresentação da resposta ao apelo por parte da Procuradoria Municipal. No Tribunal, os autos foram distribuídos ao Desembargador Relator, que negou seguimento à apelação sob o equivocado fundamento de que o recurso era manifestamente improcedente. Não há, na decisão monocrática do Desembargador Relator, qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição de Embargos de Declaração. Elabore a peça processual adequada ao reexame da matéria no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, indicando o prazo legal para a interposição do recurso e os fundamentos que revelam a(s) inconstitucionalidade(s) da TIP.

EXERCÍCIO 18 – XIX EXAME UNIFICADO

Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra, venda e montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. Para o regular exercício de sua atividade, usualmente necessita transferir tais bens entre seus estabelecimentos, localizados entre diferentes municípios do Estado de São Paulo. Apesar de nessas operações não haver transferência da propriedade dos bens, mas apenas seu deslocamento físico entre diferentes filiais de Zeta, o fisco do Estado de São Paulo entende que há incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS nesse remanejamento. Diante da falta de recolhimento do imposto, o fisco já reteve por mais de uma vez, por seus Auditores Fiscais, algumas mercadorias que estavam sendo deslocadas entre as filiais, buscando, assim, forçar o pagamento do imposto pela sociedade empresária. Considere que, entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de dois meses. Considere, ainda, que todas as provas necessárias já estão disponíveis e que o efetivo pagamento do tributo, ou o depósito integral deste, obstará a continuidade das operações da empresa que, ademais, não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários, no caso de

insucesso na medida judicial a ser proposta. Com receio de sofrer outras cobranças do ICMS e novas retenções, e também pretendendo a rápida liberação das mercadorias já apreendidas, uma vez que elas são essenciais para a continuidade de suas atividades, a sociedade empresária Zeta o procura para, na qualidade de advogado, elaborar a petição cabível, ciente de que, entre a retenção e a constituição do advogado, há período inferior a 120 (cento e vinte) dias, e que, para a demonstração dos fatos, há a necessidade, apenas, de prova documental que lhe foi entregue. (Valor: 5,00 pontos) Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

EXERCÍCIO 19 – XX EXAME UNIFICADO

Em 1.º de janeiro de 2014, a União publicou lei ordinária instituindo Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café. As alíquotas da CIDE em questão são diferenciadas conforme o Estado em que o contribuinte for domiciliado. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área da educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.

A pessoa jurídica ABC, exportadora de café, inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. Por tal razão, em 2015, a União ajuizou execução fiscal para a cobrança do valor inadimplido, atualmente em trâmite na 1.ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado “X”.

Diante destes fatos, apresente a medida judicial adequada para impugnação da cobrança da nova contribuição, expondo, justificadamente, todos os argumentos aplicáveis. Para a escolha da medida judicial adequada, considere que esta não poderá ser admitida antes de garantida a execução e que o executado foi intimado de

penhora realizada há 15 dias.

Obs.: A peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

EXERCÍCIO 20 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO EM POVO VELHO

Em janeiro de 2007, a Fazenda Nacional lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica ABC, visando à cobrança de contribuições previdenciárias dos anos de 2005 e 2006. Não houve impugnação administrativa por parte do contribuinte. Em janeiro de 2014, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica ABC, visando à cobrança do referido tributo.

Antes mesmo da citação da contribuinte, a Fazenda Nacional requereu a inclusão, no polo passivo da execução fiscal, de Carlos, gerente da pessoa jurídica ABC, por entender que o não recolhimento da contribuição é motivo para o redirecionamento da execução, o que foi acolhido pelo Juízo da 2.^a Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Estado X.

Após garantia do Juízo, Carlos opôs embargos de execução alegando a prescrição do crédito tributário, a ausência de responsabilidade tributária e, por fim, a nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que não constava na Certidão de Dívida Ativa (CDA) o número do auto de infração que originou o crédito tributário.

No entanto, ao proferir a sentença nos embargos à execução, o juiz julgou improcedente o pedido, determinando o prosseguimento da execução fiscal, por entender que:

- (i) inexistência de prescrição dos créditos tributários, uma vez que às contribuições previdenciárias se aplicam os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91;
- (ii) o mero inadimplemento gera responsabilidade tributária; e

(iii) a inexistência do número do auto de infração na CDA não gera a referida nulidade.

Diante do exposto, elabore, como advogado(a) de Carlos, a medida judicial cabível contra a decisão publicada na quarta-feira, dia 21/09/2016, dia útil, para a defesa dos interesses de seu cliente, abordando as teses, o prazo recursal, todos os fundamentos legais que poderiam ser usados em favor do autor, ciente de que inexistem qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

EXERCÍCIO 21 – XXI EXAME UNIFICADO

A União, por não ter recursos suficientes para cobrir despesas referentes a investimento público urgente e de relevante interesse nacional, instituiu, por meio da Lei Ordinária 1.234, publicada em 01 de janeiro de 2014, empréstimo compulsório. O fato gerador do citado empréstimo compulsório é a propriedade de imóveis rurais e o tributo somente será devido de maio a dezembro de 2014. Caio, proprietário de imóvel rural situado no Estado X, após receber a notificação do lançamento do crédito tributário referente ao empréstimo compulsório dos meses de maio a dezembro de 2014, realiza o pagamento do tributo cobrado.

Posteriormente, tendo em vista notícias veiculadas a respeito da possibilidade desse pagamento ter sido indevido, Caio decide procurá-lo(a) com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos indevidamente.

Na qualidade de advogado(a) de Caio, redija a medida judicial adequada para reaver em pecúnia (e não por meio de compensação) os pagamentos efetuados.

EXERCÍCIO 22 – XXII EXAME UNIFICADO

Caio era empregado da pessoa jurídica X há mais de 10 anos. No entanto, seu chefe o demitiu de forma vexatória, diante de outros

empregados, sem o devido pagamento das verbas trabalhistas. Inconformado, Caio ajuizou medida judicial visando à cobrança de verbas trabalhistas e, ainda, danos morais.

A decisão transitada em julgado deu provimento aos pedidos de Caio, condenando a pessoa jurídica X ao pagamento de valores a título de (i) férias proporcionais não gozadas e respectivo terço constitucional e, ainda, (ii) danos morais. Os valores foram efetivamente pagos a Caio em 2015.

Em junho de 2016, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal visando à cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF incidente sobre as férias proporcionais não gozadas, c respectivo terço constitucional e os danos morais. No entanto, a Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução fiscal deixou de indicar a quantia a ser executada. A ação executiva foi distribuída à 3.^a Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária de M, do Estado E Caio foi citado na execução e há 10 (dez) dias foi intimado da penhora de seu único imóvel, local onde reside com sua família.

Diante do exposto, redija, como advogado(a) de Caio, a peça prático-profissional pertinente para a defesa dos interesses de seu cliente, indicando o prazo, seus requisitos e os seus fundamentos, nos termos da legislação vigente. Considere que a peça processual a ser elaborada tem a garantia do juízo como requisito indispensável para sua admissibilidade.

EXERCÍCIO 23 – XXIII EXAME UNIFICADO

O partido político XYZ, cuja sede está no Município Alfa (capital do Estado “X”), tem quatro imóveis localizados no mesmo município, dos quais um é utilizado para sua sede, um é utilizado para abrigar uma de suas fundações e os outros dois são alugados a particulares, sendo certo que o valor obtido com os aluguéis é revertido para as atividades do próprio partido político XYZ. O administrador de XYZ

por precaução e temendo incorrer em uma infração fiscal, pagou o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) atinente aos quatro imóveis.

Poucos dias depois, descobriu que havia cometido um grande equívoco e procurou um escritório de advocacia. Nesse contexto, considerando que o administrador contratou você, como advogado(a), para patrocinar a causa do partido político XYZ, redija a medida judicial adequada para reaver em pecúnia (e não por meio de compensação) os pagamentos efetuados indevidamente.

EXERCÍCIO 24 – XXIV EXAME UNIFICADO

A indústria Alfa vende bebidas para o supermercado Beta, que, por sua vez, revende-as a consumidores finais, sendo certo que todas as operações ocorrem dentro dos limites do estado ABC, em cuja capital estão domiciliadas as duas sociedades empresárias. No estado ABC tem vigência a Lei Ordinária 123, que prevê a indústria como substituta tributária do ICMS incidente nas operações subsequentes.

Em abril de 2017, o estado ABC exigiu de Alfa todo o tributo incidente sobre a cadeia produtiva descrita. Assim, Alfa pagou o ICMS incidente na operação própria (a venda que fez ao supermercado Beta) e também na operação subsequente – isto é, o ICMS que incidiria na operação entre o supermercado Beta e os consumidores finais.

Dessa forma, para a verificação do valor a ser pago, o ICMS foi calculado sobre o valor presumido de venda da mercadoria ao consumidor final. Ocorre que, para surpresa da indústria Alfa, o supermercado Beta, que sempre vendeu as bebidas produzidas por Alfa pelo valor de R\$ 16,00 (dezesseis reais), resolveu, diante da crise econômica, comercializar as bebidas por R\$ 14,00 (catorze reais).

Com isso, a indústria Alfa entendeu que a base de cálculo do imposto foi inferior àquela que havia sido presumida, razão pela qual, na

prática, pagou, como contribuinte substituto, um valor de ICMS maior do que aquele que seria realmente devido.

Diante disso, e em razão de a indústria Alfa e o supermercado Beta serem clientes do mesmo escritório X, as duas sociedades empresárias lhe expuseram os fatos narrados acima.

Na qualidade de advogado(a) do escritório X, redija a medida judicial adequada para condenar o Estado ABC a restituir, em espécie, o valor do tributo pago a mais.

EXERCÍCIO 25 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICADA EM POA ALEGRE

Por ocasião da importação de equipamentos eletrônicos realizada pela pessoa jurídica PJ, a União entendeu que o recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) por parte da contribuinte havia sido realizado de forma incorreta. De acordo com a União, no caso de desembaraço aduaneiro, o IPI deveria incidir sobre o valor correspondente a 200% do preço corrente dos equipamentos no mercado atacadista da praça do remetente, acrescido do Imposto de Importação (II), das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador. Assim, considerando equivocado o recolhimento do tributo, a União determinou a apreensão dos equipamentos, bem como a interdição do estabelecimento da pessoa jurídica, até pagamento integral do montante devido. Lavrado auto de infração para a cobrança dos valores supostamente devidos, a pessoa jurídica PJ, inconformada com esta situação, decide apresentar medida judicial para a desconstituição do crédito tributário e, nesse sentido, contestar as medidas adotadas pela Fazenda Nacional.

Diante dos fatos narrados, sabendo que as medidas adotadas pela Fazenda Nacional datam de mais de 120 dias e estão causando prejuízos irreparáveis e que não há processo judicial em trâmite a

respeito desse caso, redija a peça processual adequada para a garantia dos direitos da pessoa jurídica PJ, que pretende ver a União condenada em honorários de sucumbência.

EXERCÍCIO 26 – XXV EXAME UNIFICADO

José da Silva, servidor público da Administração Direta do Estado X teve sua licença-prêmio convertida em pecúnia, uma vez que não foi possível gozá-la, por necessidade do serviço. Ao receber tal valor em seu contracheque, verificou que havia sido descontado na fonte o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF). Inconformado, o servidor propôs ação contra o Estado X perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, juntando todos os documentos comprobatórios do desconto efetuado, a fim de obter a restituição do valor descontado. O magistrado estadual indeferiu de plano a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, por afirmar que o Estado X era parte ilegítima para figurar no polo passivo de processo envolvendo Imposto sobre a Renda, tributo de competência da União. Como advogado(a) do servidor, redija a peça prático-profissional adequada para tutelar o seu interesse no bojo deste mesmo processo, ciente de que decorreram apenas 10 dias desde a publicação da sentença.

EXERCÍCIO 27 – XXVI EXAME UNIFICADO

Em execução fiscal ajuizada em 2017, em curso perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado X, o contribuinte José da Silva foi citado para pagar o débito tributário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou apresentar bens à penhora no prazo legal. Transcorrido o prazo, o executado permaneceu inerte. Diante disso, o procurador da Fazenda Nacional requereu a constrição de ativos financeiros do executado e, caso nada fosse encontrado, a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos do executado, nos termos do art. 185-A do CTN.

O juiz, então, valeu-se do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros (BacenJud), mas não encontrou valores vinculados ao CPF do contribuinte executado. Imediatamente após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros pelo BacenJud, mas sem o esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis, como expedição de ofícios dos registros públicos do domicílio do devedor, o juiz determinou, em caráter de tutela provisória cautelar, a indisponibilidade dos bens e direitos do executado (art. 185-A do CTN), como requerido pela exequente, no valor de até três vezes o montante da dívida, como forma de garantir a efetividade final da execução.

O executado, ciente desta decisão, que se encontrava lançada nos autos, mas ainda não publicada, e diante da iminente constrição patrimonial que viria a sofrer, procura você como advogado para que proponha imediatamente a medida adequada para tutela dos seus interesses, mencionando que essa medida não fosse direcionada ao próprio juiz, pois tem notícias de que o mesmo nunca reconsiderou uma decisão.

Assim, redija a peça recursal adequada para buscar a reforma, com urgência, da decisão de indisponibilidade dos bens e direitos do executado.

EXERCÍCIO 28 – XXVII EXAME UNIFICADO

O Estado X, por ter sofrido perdas de arrecadação com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, no art. 155, § 2º, inciso VII, da CRFB/88, instituiu, por lei ordinária, “taxa de vendas interestaduais” com incidência sobre operações de venda destinadas a outros Estados. A taxa tem, como base de cálculo, o preço de venda das mercadorias destinadas a outros Estados e, como contribuintes, os comerciantes que realizam essas vendas, aos quais incumbe o recolhimento do tributo no momento da saída das mercadorias de seu

estabelecimento. Por reputar inconstitucional a referida taxa, a sociedade empresária XYZ deixou de efetuar seu recolhimento, vindo a sofrer autuação pelo fisco estadual. Não tendo a sociedade empresária XYZ logrado êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa e a execução fiscal foi distribuída à 4ª Vara de Fazenda Pública do Estado X. Devidamente citada e após nomeação de bens pela executada, formalizou-se a penhora em valor suficiente à garantia da execução. Após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade empresária XYZ procura você para, na qualidade de advogado(a), promover sua defesa na referida execução fiscal e obstar a indevida excussão dos bens penhorados.

Na qualidade de advogado(a) da sociedade empresária XYZ, redija a medida judicial mais adequada à necessidade da sua cliente, com o objetivo de afastar a cobrança indevida.

EXERCÍCIO 29 – XXVIII EXAME UNIFICADO

A sociedade empresária Sigma S/A, concessionária de serviço público de telefonia, foi autuada pelo Fisco do Estado X, em 31/07/2017, por não recolher ICMS sobre operações de habilitação de telefone celular ocorridas de janeiro a junho de 2010, sendo-lhe dado prazo de trinta dias para pagamento do débito tributário. Inconformada com a exigência, a sociedade resolve primeiro tentar desconstituir tal autuação na via administrativa, recorrendo ao Conselho de Contribuintes do Estado X. Nesse órgão colegiado administrativo, o recurso da sociedade tem seu provimento negado. Irresignada, a sociedade empresária interpõe recurso hierárquico ao Secretário Estadual de Fazenda, conforme permitia a legislação do Estado X. O Secretário de Fazenda nega provimento ao recurso, mantendo a exigência de cobrança do tributo. Esgotada a via administrativa, a empresa imediatamente ingressa em juízo com mandado de segurança de competência originária do Tribunal de Justiça local contra o ato do Secretário Estadual, nos termos do estabelecido pela Constituição do

Estado X. Julgado o *mandamus* pelo Tribunal de Justiça local, a ordem é denegada e a empresa é condenada em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública estadual.

Diante desse cenário, sete dias úteis após a intimação dessa decisão, como advogado(a) da sociedade empresária Sigma S/A, redija a medida judicial adequada para tutela dos interesses do contribuinte no bojo desse mesmo processo.

GABARITO DAS PEÇAS PRÁTICO-PROFISSIONAIS

EXERCÍCIO 01 – EXAME 2010.2

Peça adequada: Embargos à Execução Fiscal

a) Estrutura inicial da peça:

a.1) Endereçamento: juiz de direito de vara da Justiça do Estado.

a.2) Qualificação do autor com base no art. 319 do CPC/2015 (nome, prenome, estado civil, profissão e endereço).

a.3) Qualificação do réu com base no art. 319 do CPC/2015: Município de Rancho Queimado, pessoa jurídica de direito público interno e endereço.

a.4) Exposição dos fatos.

b) Fundamentação:

b.1) Não incidência do IPTU, por se tratar de imóvel destinado a atividade agrícola e pecuária. Art. 15 do Dec.-lei 57/1966;

b.2) Ilegalidade da exigência do ITBI sobre o valor avaliado judicialmente, conforme art. 38 do CTN. O imposto deve ser calculado sobre o valor do bem transmitido. Obtém a mesma pontuação se o candidato defender que o ITBI sequer é devido, pois a arrematação judicial constitui forma de aquisição originária da propriedade.

c) Pedido e valor da causa:

- c.1) Intimação ou citação da ré para oferecer impugnação;
- c.2) Procedência do pedido para cancelar a dívida ativa e extinguir a execução fiscal;
- c.3) Produção de provas;
- c.4) Condenação no ônus da sucumbência;
- c.5) Atribuição do valor da causa.

EXERCÍCIO 02 – EXAME 2010.3

Peça adequada: Embargos à Execução Fiscal

Mérito: Não é cabível exceção de pré-executividade, pois esta só é admitida quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível *ex officio* pelo Juiz. Na situação descrita na questão da peça, *José dos Santos* fora indicado na *Certidão de Dívida Ativa* como sendo corresponsável pelo débito. A questão traz sugestivos indícios sobre a peça correta, embargos à execução fiscal, ao afirmar que: 1) houve a citação de ambos os executados; 2) os executados já ofereceram bens à penhora; a oferta de bens à penhora supre a falta de referência à intimação da penhora e das demais hipóteses do art. 16 da LEF.

a) Estrutura inicial da peça:

a.1) Endereçamento: Juízo da 2.^a Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Idealmente também deveria ser referida a distribuição por dependência.

a.2) Qualificação do autor e do réu: José dos Santos (nome, estado civil, profissão e endereço) e Fazenda Nacional (pessoa jurídica de direito público).

a.3) Exposição dos fatos.

b) Fundamentação:

b.1) Ilegitimidade para figurar no polo passivo. A responsabilidade prevista no *art. 135, III, do CTN é subsidiária* e somente pode ser

imputada ao sócio gerente que agir com má-fé, excesso de poderes ou infração à lei ou por dissolução irregular da empresa e não por mero inadimplemento de tributos. Ausência desses requisitos, pois (i) a autuação não versa sobre fraude ou má-fé praticada pelo sócio gestor, mas sim discussão jurídica quanto à exclusão de despesa ou não da base de cálculo do IRPJ/CSLL; (ii) não houve dissolução irregular pois a empresa continuou as suas atividades após a saída de *José dos Santos*, tendo até *aumentado o seu faturamento* nos anos subsequentes. Súmula 435 do STJ.

b.2) Despesas necessárias à atividade *são dedutíveis* para fins de apuração da determinação do lucro tributável, base de cálculo do IRPJ e CSLL. Segundo o art. 47 da Lei 4.506/1964 e posteriore alterações, são consideradas necessárias as despesas que visam à manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Como a atividade da empresa é a incorporação e loteamento de empreendimentos imobiliários, os custos para aquisição de terrenos devem ser considerados como dedutíveis da apuração do lucro real. Assim, ainda que *José dos Santos* fosse parte legítima, o crédito tributário deve ser cancelado, pois as despesas de corretagem na aquisição de terrenos devem ser consideradas como dedutíveis da base de cálculo do IRPJ/CSLL.

c) Pedido e valor da causa:

c.1) Intimação ou citação da ré para oferecer impugnação.

c.2) Procedência do pedido para considerar *José dos Santos* como parte ilegítima a figurar no polo passivo da execução fiscal ou como pedido alternativo o cancelamento do crédito tributário.

c.3) Produção de provas.

c.4) Condenação no ônus da sucumbência.

c.5) Atribuição do valor da causa.

EXERCÍCIO 03 – IV EXAME UNIFICADO

Peça adequada: Cabível o Mandado de Segurança com pedido de liminar, ante o abuso de poder da autoridade coatora. Cabível igualmente ação anulatória com pedido de antecipação de tutela.

Mérito: A mercadoria só pode ficar detida até a lavratura do auto de infração. Após, deve ser liberada.

Mesmo que a mercadoria estivesse desacompanhada por nota fiscal, não seria possível apreendê-la.

É ilegal e abusiva a apreensão de mercadoria após a lavratura do auto de infração e correspondente lançamento.

Incidência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Ofensa ao princípio da livre-iniciativa. Ofensa ao direito de propriedade (art. 5.º, XXII, e art. 170 da CF/1988).

É defeso à Administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que tal procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese de autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz.

EXERCÍCIO 04 – V EXAME UNIFICADO

Peça adequada: Trata-se de Ação de Consignação em pagamento, com previsão no art. 164, I, do CTN, tendo em vista que a Fazenda Municipal se recusa a receber a prestação tributária apenas quanto ao valor do imposto devido.

Mérito: O Fisco condicionou o recebimento do pagamento do imposto ao pagamento da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, o que torna a ação de consignação o meio hábil para a liberação da dívida fiscal relativa ao IPTU, pretendendo o contribuinte eximir-se de pagar a taxa, que reputa inconstitucional.

a) Estrutura da Peça:

a.1) Fato: A Fazenda Municipal subordina o pagamento do IPTU ao pagamento da taxa, reputando o contribuinte inconstitucional a segunda exação.

a.2) Direito: O Fisco não pode subordinar o pagamento de um tributo a outro, eis que são obrigações autônomas, oriundas de fatos geradores distintos. Caso assim proceda, deverá o contribuinte consignar em Juízo o valor devido.

a.3) Solução: O contribuinte deverá recolher apenas o valor do IPTU mediante a propositura da ação de consignação em pagamento, de acordo com o art. 164, I, do CTN, liberando-se da obrigação tributária existente.

a.4) Pedido e valor da causa:

a) Citação do réu para levantar o depósito ou oferecer resposta;

b) Seja deferido o depósito do valor do IPTU devido, tornando inexigível o crédito tributário correspondente;

c) Seja julgado procedente o pedido, declarando-se extinta a obrigação tributária.

d) Seja o réu condenado em custas e honorários advocatícios;

e) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.

f) Valor da Causa – R\$... (valor total do IPTU a ser consignado).

EXERCÍCIO 05 – VI EXAME UNIFICADO

Peça adequada: Ação de Repetição de Indébito Fiscal

Mérito: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é imposto de competência municipal, cabendo à lei complementar estabelecer as alíquotas máximas e mínimas para fins de incidência. Nessa linha, a LC 116/2003 somente disciplinou, em seu art. 8.º, a alíquota máxima de 5% para o ISS, estando a alíquota mínima de 2% prevista no art. 88, I, do ADCT.

Houve obediência pela Lei Municipal, ora analisada, quanto aos limites mínimos e máximos da alíquota do imposto. Todavia, restou violado o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, *b* e *c*, da CF/1988, o qual determina a vedação quanto à cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bem como deverá ser observado o prazo da noventena, o qual proíbe a cobrança de tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

Desse modo, tendo sido a lei publicada em 01.06.2010 e vigorado em 01.07.2010, é flagrante a violação ao princípio da anterioridade tributária, o que resulta na possibilidade de o contribuinte requerer a repetição dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte decorrente do aumento indevido de tal cobrança.

a) Estrutura da Peça:

a.1) Fato: Lei Municipal, publicada em 01.06.2010, ao estabelecer a majoração da alíquota para os serviços de hospedagem, turismo, viagens e congêneres de 3% para 5%, para vigorar a partir de 01.07.2010, alcançou a atividade econômica do Hotel Boa Hospedagem Ltda., que se submeteu ao aumento deste imposto durante o período relativo ao mês de agosto a dezembro/2010, passando a recolher indevidamente por mês o valor a maior de R\$ 20.000,00.

a.2) Direito: Aplica-se o art. 165 do CTN. O Fisco, apesar de estar em conformidade com a legislação tributária ao fixar a alíquota mínima e máxima para os serviços de vigilância e segurança, violou o princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, *b* e *c*, da CF/1988, vez que não poderia aumentar no mesmo exercício financeiro a alíquota do ISS.

a.3) Desfecho: O contribuinte poderá ingressar com pedido de

repetição do indébito tributário, com base na cobrança indevida acima apontada.

a.4) Pedido e valor da causa:

a) Citação do réu para, querendo, contestar a demanda, no prazo legal sob pena de revelia;

b) Seja o réu condenado a restituir o valor a maior de ISS no total de R\$ 100.000,00, pago pelo contribuinte, com juros e correção monetária na forma do art. 167 do CTN;

c) Seja o réu condenado em custas e honorários advocatícios (art. 85 do CPC/2015);

d) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.

e) Valor da Causa – R\$ 100.000,00.

EXERCÍCIO 06 – VII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: Mandado de Segurança com pedido de liminar

Mérito: O STF já apreciou a possibilidade de extensão da imunidade recíproca à Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, entendendo que, por prestar serviço público, postal (art. 21, X, da CF/1988), de natureza obrigatória e exclusiva do Estado, goza de imunidade por extensão do § 2.º art. 150 c/c art. 150, VI, letra *a*, da CF/1988.

À ECT não se aplicaria o art. 150, § 3.º, da CF/1988, mas sim o § 2.º do art. 150 da CF/1988. (Nesse sentido, RE 407.099/RS, rel. Min Carlos Velloso, *DJ* 06.08.2004).

Também, no caso do IPVA, o STF decidiu no mesmo sentido, entendendo que a imunidade prevista no art. 150, VI, *a*, da CF/1988 alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, julgando procedente a ação proposta pela ECT para afastar a cobrança do IPVA, bem como as sanções decorrentes da inadimplência do tributo. (ACO 765/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Mello/Informativo. STF 546).

a) Estrutura da Peça:

a.1) Fato: Apesar de a ECT cobrar tarifas ou preços por seus serviços, a empresa estaria abrangida pela regra imunizante, não se enquadrando, portanto, na condição de contribuinte do IPVA ora analisado.

a.2) Direito: A regra da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, *a*, da CF/1988 é aplicável à ECT, pois presta serviço público postal, de natureza obrigatória e exclusiva do Estado, não ingressando em regime concorrencial com outras empresas, o que também afastaria a aplicação do art. 173, § 2.º, da CF/1988, o que resulta na configuração de direito líquido e certo a ser viabilizado mediante impetração de mandado de segurança, visto que a ECT não é contribuinte do IPVA.

a.3) Medida liminar: Caso não seja deferida liminar pleiteada, o impetrante será compelido a pagar os valores exigidos ilegalmente ou sofrerá inscrição em dívida ativa e posterior execução. Com isso, deverá ser apreciado pedido liminar antes mesmo da manifestação da autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

a.4) Conclusão: A ECT tem direito líquido e certo, sendo inválida a cobrança do imposto em questão, com base nos fundamentos de fato e de direito acima expendidos.

a.5) Pedido e valor da causa:

a) Deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009;

b) Notificação da autoridade coatora, enviando-lhe todas as cópias dos documentos que instruem a inicial, para que preste todas as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7.º, I, da Lei 12.016/2009);

c) Dado ciência ao Estado ou ao órgão de representação judicial ou

ainda à Procuradoria Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (art. 7.º, II, da Lei 12.016/2009);

c) Ouvido o representante do Ministério Público, para que opine no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei 12.016/2009);

d) Ao final, conceder definitivamente a segurança pleiteada para a anulação do lançamento. Condenação em custas. Não há condenação em honorários advocatícios, conforme Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Valor da causa: R\$ valor do débito do IPVA.

EXERCÍCIO 07 – VIII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: A peça a ser elaborada pelo candidato é um Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (art. 1.015 do CPC/2015), admitindo-se, ainda, a tutela antecipada na forma do art. 1.019, I, do mesmo diploma legal. Sendo a decisão de rejeição liminar da exceção de pré-executividade de natureza interlocutória, incabível outro recurso, que não o agravo de instrumento. Incabível a utilização do princípio da fungibilidade, por se tratar de equívoco inadmissível na prática forense, a interposição de recurso de apelação, ao invés de agravo de instrumento, para combater a decisão interlocutória em comento. Na narrativa do enunciado da questão, a exceção de pré-executividade fora corretamente proposta, eis que houve o pagamento por consignação, reconhecido por sentença, transitada em julgado, desnecessária a dilação probatória, conforme referido na Súmula 393 do STJ. Tendo havido o pagamento, a execução fiscal não poderia prosseguir, devendo ser extinta.

EXERCÍCIO 08 – IX EXAME UNIFICADO

Peça adequada: As instituições de ensino sem fins lucrativos estão abrangidas pela imunidade tributária, de acordo com o art. 150, VI, c, e § 4.º do mesmo artigo da CF/1988. A Súmula 724, editada pelo STF, já pacificou entendimento no sentido de que desde que a receita

auferida por tais entidades se destine às suas finalidades essenciais, não haverá incidência de impostos, incluindo-se neste caso o ISS.

Assim sendo, assiste direito líquido e certo com relação à instituição em questão, ao efeito, mediante a impetração do Mandado de Segurança de afastar a cobrança indevida do ISS objeto do aludido auto de infração.

a) Estrutura da peça:

a.1) Fato: A receita obtida com a exploração dos serviços de estacionamento é revertida para as finalidades essenciais da instituição de ensino.

a.2) Direito: A instituição de ensino não é contribuinte do ISS relativo à prestação dos serviços de estacionamento, pois é imune à incidência de impostos, com base no art. 150, VI, c, e § 4.º do mesmo artigo da CF/1988.

a.3) Medida liminar: Caso não seja deferida a liminar pleiteada, a impetrante será compelida a pagar os valores exigidos ilegalmente ou sofrerá inscrição em dívida ativa e posterior execução, com a constrição dos seus bens.

Com isso, deverá ser apreciado o pedido de liminar antes mesmo da manifestação da autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

a.4) Conclusão: A instituição de ensino tem direito líquido e certo, sendo inválida a cobrança do imposto em questão, com base nos fundamentos de fato e de direito acima expendidos.

a.5) Pedido e valor da causa:

a) Deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, art. 7.º, III, da Lei 12.016/2009;

b) Notificação da autoridade coatora, enviando-lhe todas as cópias dos documentos que instruem a inicial, para que preste todas as

informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7.º, I, da Lei 12.016/2009);

c) Dar ciência ao Município, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (art. 7.º, II, da Lei 12.016/2009);

d) Ouvir o representante do Ministério Público, para que opine no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei 12.016/2009);

e) Ao final, confirmada a liminar deferida, conceder, definitivamente, a segurança pleiteada para a anulação do lançamento. Não há condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Valor da causa: R\$ valor do débito do ISS.

EXERCÍCIO 09 – X EXAME UNIFICADO

De acordo com a banca examinadora, a ausência de uma redação mais clara no enunciado motivou a abertura do gabarito para as sete peças introduzidas. Tal fato, pelo nosso entendimento, não tenderá a ocorrer novamente, tendo em vista o grande desgaste para os candidatos e, notadamente, para a banca examinadora.

Agravo de instrumento

a) Estrutura da peça:

a.1) Endereçamento da Ação Tribunal Estadual (Justiça) ou Federal (TRF).

a.2) Qualificação do Autor e do Réu.

a.3) Síntese dos fatos.

a.4) Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015), presentes os requisitos;

a.5) Provimento do recurso para reforma do ato judicial para que seja feito o levantamento do depósito sem a incidência de imposto de renda.

- a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.
- a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.
- a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”.
- a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de proventos.
- a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

Apelação

a) Estrutura da peça:

- a.1) Endereçamento ao Juiz da Causa.
- a.2) Qualificação do Autor e do Réu.
- a.3) Síntese dos fatos.
- a.4) Comprovação do preparo recursal.
- a.5) Provimento do recurso para reforma do ato judicial para que seja feito o levantamento do depósito sem a incidência de imposto de renda.
- a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.
- a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.
- a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”.
- a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de

proventos.

a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

Recurso inominado (Lei 9.099/1995)

a) Estrutura da peça:

a.1) Endereçamento ao Juiz da Causa.

a.2) Qualificação do Autor e do Réu.

a.3) Síntese dos fatos.

a.4) Comprovação do preparo recursal.

a.5) Provimento do recurso para reforma do ato judicial para que seja feito o levantamento do depósito sem a incidência de imposto de renda.

a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.

a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.

a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais”.

a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de proventos.

a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

Ação de Repetição de Indébito

a) Estrutura da peça:

a.1) Endereçamento ao Juiz da Vara Cível, Fazenda Pública ou Vara Federal.

a.2) Qualificação do Autor e do Réu.

- a.3) Síntese dos fatos.
- a.4) Comprovação do recolhimento indevido.
- a.5) Procedência do pedido para condenar o ente tributante à restituição do imposto de renda indevidamente recolhido.
- a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.
- a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.
- a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”.
- a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de proventos.
- a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

a) Estrutura da peça:

- a.1) Endereçamento ao Juiz da Vara Cível, Fazenda Pública ou Vara Federal.
- a.2) Qualificação do impetrante e da autoridade coatora, com a indicação da pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.
- a.3) Síntese dos fatos, com comprovação do direito líquido e certo mediante prova documental juntada com a inicial.
- a.4) Pedido de liminar para realizar levantamento sem a retenção na fonte.
- a.5) Procedência do pedido para determinar à autoridade coatora que se abstenha de realizar a retenção na fonte do imposto de renda,

quando do levantamento.

a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.

a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.

a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”.

a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de proventos.

a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

Ação Anulatória

a) Estrutura da peça:

a.1) Endereçamento ao Juiz da Vara Cível, Fazenda Pública ou Vara Federal.

a.2) Qualificação do Autor e do Réu.

a.3) Síntese dos fatos.

a.4) Pedido de antecipação dos efeitos da tutela para realizar levantamento sem a retenção na fonte, presentes os requisitos.

a.5) Procedência do pedido para condenar o ente tributado à restituição do imposto de renda indevidamente recolhido.

a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.

a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.

a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”.

a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da

disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de proventos.

a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

a) Estrutura da peça:

a.1) Endereçamento ao Juiz da Vara Cível, Fazenda Pública ou Vara Federal.

a.2) Qualificação do Autor e do Réu.

a.3) Síntese dos fatos.

a.4) Pedido de antecipação dos efeitos da tutela para realizar levantamento sem a retenção na fonte, presentes os requisitos.

a.5) Procedência do pedido para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor a sofrer a retenção na fonte do imposto de renda, quando do levantamento.

a.6) Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado.

a.7) Danos materiais e morais: natureza jurídica de mera recomposição patrimonial.

a.8) Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais”.

a.9) O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos ou de proventos.

a.10) Não incidência de imposto de renda sobre mera recomposição patrimonial (art. 43 do CTN ou art. 153, III, da CF/1988).

EXERCÍCIO 10 – X EXAME UNIFICADO

Peça adequada: A sociedade WYZ Ltda. deverá impetrar Mandado de Segurança com pedido de liminar para suspender de imediato a interdição do estabelecimento, ante o risco à continuidade do negócio.

Deverá, além de indicar o correto endereçamento da peça processual, promover a escoreita identificação das partes.

Mérito: Após indicar a razão de cabimento do Mandado de Segurança (prova pré-constituída e existência de ilegalidade por parte da Autoridade Coatora), deverá expor os fundamentos em que se escora seu alegado direito, quais sejam:

a) A impossibilidade de interdição do estabelecimento como meio coercitivo de cobrança de tributo, o que inclusive é objeto da Súmula 70 do STF;

b) A inconstitucionalidade da lei municipal por violação ao princípio da razoabilidade, consubstanciado no aspecto substantivo do devido processo legal, que inclui a proporcionalidade em sentido estrito. E, sendo irrazoável e desproporcional a interdição, daí resulta a violação do direito constitucional de exercício da atividade econômica. Ainda nessa parte, deverá também mencionar a afronta ao devido processo legal, no seu aspecto formal, pois a lei cria um mecanismo coercitivo para se realizar o pagamento de uma espécie tributária, de forma a enfraquecer o direito de se questionar o cabimento ou não, da referida verba em sede judicial. Ou seja, cria um mecanismo para conferir, via indireta, o pagamento em foco sem a necessidade do processo de execução fiscal.

A petição deverá, ainda, indicar a presença dos requisitos essenciais para a concessão da liminar pleiteada: o *fumus boni iuris* (plausibilidade do direito alegado) e o *periculum in mora* (risco na demora da prestação jurisdicional).

A peça, quanto ao pedido, deverá conter a postulação de liminar e a

pretensão final, consistente, esta última, na declaração, ou reconhecimento da nulidade do ato decisório que determinou o fechamento do estabelecimento, pois sob o fundamento de lei inconstitucional.

Nesta parte da peça, coloca-se importante observar a “ideia” de reversão da situação de fechamento do estabelecimento, principalmente no plano da pretensão liminar.

Deve, ainda, na parte final da petição, o candidato fazer menção à notificação da autoridade coatora, à manifestação do ente público a que pertença a autoridade coatora, bem como ao pronunciamento do MP, a denotar, quanto ao último, que este tem participação obrigatória no procedimento.

Deve, também, neste momento fazer alusão ao valor da causa, esclarecer que está apresentando a segunda via da inicial e documentos juntos, além de indicar o endereço da empresa impetrante.

EXERCÍCIO 11 – XII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: Agravo de Instrumento, haja vista se estar diante de decisão interlocutória. Para se evitar dúvidas o enunciado mostra que não há mais prazo para embargos de declaração, e evidencia que ainda resta prazo para o recurso próprio mencionado.

- 1) Direcionamento ao Tribunal de Justiça;
- 2) Qualificar Agravante: Felipe das Neves, portador de grave deficiência mental, representado por (...) Agravado: ente público a cujos quadros pertença a Autoridade coatora; a autoridade impetrada no MS; Juízo da Vara Cível ou Vara de Fazenda Pública;
- 3) Fatos: solicitação do benefício e recusa do Delegado da Delegacia Regional Tributária. Indeferimento da Medida Liminar no Mandado de Segurança;

4) A antecipação dos efeitos da tutela recursal: o cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, que teria por efeito prático o deferimento da liminar pleiteada no Mandado de Segurança, e que foi indeferida pela decisão agravada, tem amparo no art. 1019, I, do CPC/2015;

5) O fundamento jurídico deve ser o de que o veículo a ser adquirido por deficiente físico, ainda que seja para ser dirigido por terceiro, porque a sua deficiência o impede de dirigir, deve receber a benesse pretendida, qual seja, a de isenção do tributo estadual, sob pena de se dar tratamento manifestamente desigual a tais deficientes. A negativa de tal benefício e a aplicação da regra da forma sustentada pela Fazenda implica tratamento diferenciado (mais gravoso) a pessoa que apresenta deficiência incapacitante análoga à física. A isenção deve ser interpretada de acordo com o que preceitua o art. 111, II, do CTN, desde que tal interpretação não afronte o princípio da isonomia. O candidato deverá defender a prática da interpretação sistemática e teleológica da norma isentiva, de modo a conciliar a legislação tributária com o texto constitucional, que propugna a integração social do deficiente e a eliminação de todas as formas de discriminação (art. 227, § 1.º, II, da CF/1988), bem como a eliminação de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente (art. 150, II, da CF/1988);

EXERCÍCIO 12 – XIII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: A peça apropriada é uma Exceção de Pré-executividade, por não depender de garantia de juízo.

Mérito: Deve ser alegada a ilegitimidade passiva do sócio por não poder ser responsabilizado pelo tributo, uma vez que o mero não recolhimento não enseja, por si só, a responsabilidade do sócio gerente (Súmula 430 do STJ). Deve ser alegada a inconstitucionalidade do dispositivo da lei estadual. Ao vincular a

conduta processual do sócio administrador à obrigação de responder solidariamente pelos débitos da pessoa jurídica perante o Estado, a lei estadual dispôs sobre a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF/1988. A previsão da responsabilidade tributária para esse caso deveria ser veiculada por lei complementar. Por fim, deve ser alegado que o descumprimento do encargo legal de depositário tem como única consequência a entrega do bem no estado em que foi recebido ou seu equivalente em dinheiro.

EXERCÍCIO 13 – XIV EXAME UNIFICADO

Peça adequada: A peça apropriada é o Mandado de Segurança, uma vez que se trata de direito líquido e certo e a medida não comporta condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF, Súmula 105 do STJ, e art. 25 de Lei 12.016/2009).

Deve ser apresentado pedido de liminar para assegurar que o novo tributo não poderá impedir o impetrante de obter a certidão de regularidade fiscal da pessoa jurídica. Para tanto devem ser demonstradas a presença dos requisitos essenciais à liminar, quais sejam o *fumus boni iuris* (plausibilidade do direito alegado) e o *periculum in mora* (risco na demora da prestação jurisdicional, em decorrência da proximidade da licitação).

Mérito: Quanto ao mérito, deve ser alegada a inconstitucionalidade da taxa em razão da violação do princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/1988) e ao princípio da anterioridade (tanto a anterioridade do exercício financeiro quanto a anterioridade nonagesimal – art. 150, III, *b* e *c*, da CF/1988). Também deve ser apontada a inconstitucionalidade do fato gerador da taxa não corresponder a serviço público específico e divisível, uma vez que o serviço de segurança pública possui caráter geral e indivisível (art. 145, II, da

CF/1988). Vale destacar, ainda, que a taxa é um tributo contraprestacional/vinculado e a base de cálculo instituída pelo decreto não reflete o custo despendido pelo Estado para a prestação da atividade.

EXERCÍCIO 14 – XV EXAME UNIFICADO

Peça adequada: João deverá oferecer exceção de pré-executividade, peça que não exige a garantia do juízo e que é cabível nos casos em que: (i) não é preciso dilação probatória, ou seja, todos os seus argumentos podem ser demonstrados de plano; e (ii) alega-se matéria relativa às condições da ação e aos pressupostos processuais, conhecíveis de ofício, como na hipótese (prescrição e ilegitimidade passiva).

Mérito: a peça envolverá conhecimentos sobre responsabilidade tributária, especificamente no que se refere ao disposto no art. 135 do CTN, e de prescrição tributária. O art. 135 do CTN dispõe que “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei, contratos e estatutos”. Do *caput* do dispositivo, é possível concluir que o mero inadimplemento tributário não gera responsabilidade tributária. Nesse sentido é a Súmula 430 do STJ. Além disso, os incisos do artigo não elencam o sócio como responsável tributário. Sendo assim, para que o sócio seja responsabilizado, é necessário que ele pratique atos de direção ou gerência (inciso III do dispositivo), o que não é o caso, pois se trata de mero sócio cotista, sem poderes de administração/gestão da sociedade, o que afastaria a incidência do art. 135 do CTN.

No que tange à responsabilidade tributária, deve o candidato ressaltar ainda que, como o nome de João não consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), cabe à Fazenda demonstrar que o responsável agiu com excesso de poderes ou cometeu infração à lei, contratos e estatutos, o

que não aconteceu na hipótese narrada. Ademais, deve o candidato destacar que o crédito tributário está prescrito, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal e a citação ocorreram em 2012, ou seja, mais de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário que, por sua vez, ocorreu em 2004. Sendo assim, conforme previsto no art. 174 do CTN, ocorreu a prescrição.

EXERCÍCIO 15 – XVI EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de compensação dos créditos tributários. A apelação deverá ser endereçada ao Juízo da causa (4.^a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado X), com as razões recursais dirigidas ao Tribunal Regional Federal, que as apreciará. O Apelante é a pessoa jurídica A, que restou sucumbente, e a Apelada é a União.

Mérito: no mérito, o examinando deverá afastar o argumento utilizado pelo Juízo *a quo*, no sentido de que o pedido de compensação deveria ter sido inicialmente feito na via administrativa. Isso porque a Constituição não exige que o contribuinte requeira administrativamente a compensação como condição de acesso ao Poder Judiciário. Ao contrário, a Constituição consagra, no art. 5.º, XXXV, a inafastabilidade do controle jurisdicional. Ademais, o examinando deverá apontar que o art. 166, do Código Tributário Nacional, permite a restituição de tributos indiretos quando o terceiro que suportou o encargo expressamente autorizar o contribuinte de direito a requerer a repetição, como no caso anunciado. O examinando deverá, ainda no mérito, requerer a aplicação da Súmula 461, que dispõe que “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. Sendo assim, incorreta a decisão do juiz *a quo* que afirmou ser incabível o pedido de compensação. Por fim, o examinando deverá formular pedido de

reforma da sentença e inversão dos ônus sucumbenciais, reiterando o pedido de compensação do indébito.

EXERCÍCIO 16 – XVII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: deve ser elaborado Agravo de Instrumento, destinado ao Tribunal de Justiça, com a qualificação da agravante, XYZ Ltda., e do agravado: Município (deve-se admitir, também, a indicação como “Agravado”, do Juízo da Vara Cível ou Vara de Fazenda Pública, bem como a Fazenda Pública Municipal). O recurso deve destacar o cabimento do Agravo de Instrumento por se tratar de processo de execução e pela possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

Mérito: quanto ao mérito da pretensão do recorrente, deve este destacar que tem prevalência a regra do art. 32, § 2.º, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), que, por sua vez, condiciona o levantamento do depósito judicial ao trânsito em julgado da decisão. A peça processual ainda deve ainda pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, justificando a urgência com o risco de iminente conversão em renda do depósito judicial por parte do recorrido. Deve ainda o recurso fazer menção ao fato de que estão sendo anexadas as peças obrigatórias para a instrução do Agravo de Instrumento (ou, alternativamente, a cópia integral dos autos judiciais a partir dos quais foi formado o instrumento).

EXERCÍCIO 17 – XVIII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: O examinando deverá elaborar o Agravo a que se refere o art. 557, § 1.º, do Código de Processo Civil (CPC). Quanto aos aspectos procedimentais, o examinando deverá: (i) endereçar a petição ao Desembargador Relator da Apelação (que proferiu a decisão agora agravada); (ii) apontar o fundamento legal que dá amparo ao recurso (Agravo); (iii) indicar o prazo legal para a interposição do Agravo. Depois de promover a descrição dos fatos

que levaram à necessidade de interposição do Agravo, o examinando deverá expor as razões que revelam o descabimento da exigência fiscal (pois isso foi expressamente demandado no enunciado da questão e é mesmo necessário para revelar o equívoco da decisão monocrática agravada – já que esta, ao negar curso à apelação, considerou que a sentença apelada, ao manter o crédito tributário, estava correta).

Mérito: Deverá o examinando, então, alegar que: (a) a inconstitucionalidade da TIP está pacificada no STF (Súmula 676 e/ou Súmula Vinculante 41); (b) o serviço de iluminação pública não é específico e divisível, pois não se pode mensurar o proveito que cada contribuinte isolado extrai do serviço, violando, assim, o art. 145, II, da CRFB/88; (c) a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto (e, no caso concreto, a base de cálculo da TIP é o valor venal utilizado para lançamento do próprio IPTU), pois isso viola o art. 145, § 2.º, da CRFB/88; (d) a exigência da TIP, já em janeiro de 2013, viola o princípio da anterioridade nonagesimal (ou noventa, também chamada de anterioridade mitigada e espera nonagesimal), prevista no art. 150, III, c, da CRFB/88. Por fim, deverá o examinando pedir: (I) a retratação da decisão agravada e, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, o provimento (pelo próprio Relator) da apelação, uma vez que a sentença apelada está em confronto com súmula do STF; (II) para a eventualidade de não ser atendido o pedido anterior, o provimento do Agravo, para que tenha seguimento a Apelação, conforme previsto na parte final do art. 557, § 1.º, do CPC (sendo desnecessário que o examinando peça também o provimento da Apelação, pois isso é objeto do próprio apelo que se pretende que venha a ser reexaminado).

EXERCÍCIO 18 – XIX EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar a petição inicial de um Mandado de Segurança, diante da existência de prova pré-

constituída e ausência do decurso do prazo de 120 dias desde a primeira apreensão das mercadorias. Não seriam cabíveis ações como a declaratória ou a anulatória, diante da informação de que a pessoa jurídica não quer se expor ao risco de condenação em honorários de sucumbência.

Mérito: o examinando deverá alegar que, nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não incide o ICMS, conforme Súmula 166 do STJ. Deverá o examinando argumentar, ainda, que não é possível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, conforme Súmula 323 do STF. Deverá ser exposta a presença do *fumus boni iuris* (plausibilidade do direito alegado pela parte) e do *periculum in mora* (risco de demora na concessão do provimento jurisdicional pleiteado), de modo a justificar o pedido de concessão de medida liminar.

EXERCÍCIO 19 – XX EXAME UNIFICADO

Peça adequada: a peça a ser elaborada são os Embargos à Execução, que consubstanciam defesa a ser apresentada em face de execução fiscal, prevista na Lei 6.830/80 (LEF), que, em seu art. 16, parágrafo 1.º, determina que os embargos do executado não serão admissíveis antes de garantida a execução. Por tal razão, não se admite a exceção de pré-executividade como peça processual.

Mérito: como argumento de defesa, o examinando deve alegar que a cobrança é inconstitucional, uma vez que as contribuições de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, na forma do art. 149, § 2.º, inciso I, da CRFB/88. O examinando deve alegar, também, que o novo tributo viola a Constituição da República ao não observar a proibição contida em seu art. 151, inciso I, que veda à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção

ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro. Como último fundamento, o examinando deve alegar que a cobrança é inconstitucional porque, de acordo com o art. 149 da CRFB/88, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, o que não se verifica no presente caso. A destinação dos recursos arrecadados com a contribuição para a área de educação não atende à referibilidade inerente às contribuições de intervenção no domínio econômico, pois a atividade a ser custeada, qual seja o desenvolvimento do ensino fundamental, não guarda referência com a exportação do café.

EXERCÍCIO 20 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO EM POVO VELHO (RO)

Peça adequada: o examinando deverá elaborar uma apelação em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A apelação deverá ser endereçada ao Juízo da causa (2.^a Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Estado X), com as razões recursais dirigidas ao Tribunal Regional Federal, que as apreciará. O apelante é Carlos, que restou sucumbente, e, a apelada, a União ou a Fazenda Nacional.

Mérito: o examinando deverá demonstrar que o crédito tributário foi alcançado pela prescrição, uma vez que a matéria (prescrição) é reservada à lei complementar, conforme o art. 146, inciso III, alínea *b*, da CRFB/88, sendo a Lei 8.212/91 inconstitucional. Na hipótese, se aplica o art. 174 do CTN, norma que foi recepcionada como lei complementar pela CRFB/88. No mesmo sentido, é a Súmula Vinculante 08 e a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 559943, no qual foi reconhecida a repercussão geral.

Ademais, o examinando deverá apontar que, ao contrário do decidido

pelo Juízo *a quo*, o mero inadimplemento da obrigação tributária não gera responsabilidade tributária, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. Tal responsabilidade só surge com o inadimplemento resultante de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme teor da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. O examinando deve demonstrar que a CDA é nula, uma vez que o art. 2.º, § 5.º, inciso VI, da Lei 6.830/80, e o art. 202, inciso V, do CTN determinam que a CDA indique o número do auto de infração ou processo administrativo no qual foi originado o débito. Tal dispositivo assegura ao devedor e/ou responsável tributário o devido processo legal.

EXERCÍCIO 21 – XXI EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar a petição inicial de uma Ação de Repetição de Indébito, uma vez que se pretende a restituição do empréstimo compulsório pago indevidamente. A ação declaratória isoladamente não satisfaz o interesse do cliente, visto que o objetivo não é evitar o lançamento do crédito tributário. Na hipótese, não há mais lançamento a ser realizado, visto que o tributo só seria devido pelo período de maio a dezembro de 2014. Tampouco é cabível a ação anulatória isoladamente, visto que não há lançamento a ser anulado. A ação de repetição de indébito deverá ser endereçada à Vara Federal da Seção Judiciária do Estado X. O autor da ação é Caio, e a ré, a União.

Mérito: o examinando deverá demonstrar que o empréstimo compulsório é inconstitucional, uma vez que este tributo deve ser instituído por lei complementar, conforme o art. 148, *caput*, da CRFB/88, e não por lei ordinária como na hipótese do enunciado. Ademais, o examinando deverá indicar a violação ao princípio da anterioridade, uma vez que o empréstimo compulsório referente a investimento público de caráter urgente e de relevante interesse

nacional somente pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, no caso somente em 2015, conforme o art. 148, inciso II c/c o art. 150, inciso III, alínea b, ambos da CRFB/88. Por fim, deve o examinando requerer a procedência do pedido para que os valores pagos indevidamente lhe sejam restituídos.

EXERCÍCIO 22 – XXII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá opor embargos à execução, que consubstanciam defesa a ser apresentada em face de execução fiscal, prevista na Lei 6.830/80 (LEF). Em seu art. 16, § 1.º, a Lei determina que os embargos não serão admissíveis antes de garantida a execução. Considerando que o enunciado menciona que a peça a ser elaborada tem a garantia do juízo como requisito indispensável para sua admissibilidade, estão afastadas as hipóteses de exceção de pré-executividade, mandado de segurança e ações de rito ordinário (anulatória/declaratória). Os embargos devem ser endereçados ao Juízo da causa (3.ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária de M, do Estado E). O embargante é Caio e a embargada é a Fazenda Nacional/União.

Mérito: o examinando deverá demonstrar que não incide imposto sobre a renda sobre os valores recebidos a título de férias proporcionais não gozadas e respectivo terço constitucional, uma vez que têm caráter indenizatório, conforme Súmula 386 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, deve o examinando afirmar que sobre os danos morais não há incidência de IRPF, pois eles também têm natureza jurídica de indenização, que têm como objetivo reparar a vítima do sofrimento causado pela lesão, conforme a Súmula 498 do STJ. O examinando deve também indicar que há nulidade de inscrição do crédito tributário, conforme art. 203 do CTN, uma vez que na certidão de dívida ativa não consta a quantia devida, na forma do art. 202, inciso II, do CTN, e/ou art. 2.º, § 5.º, inciso II, da Lei 6.830/80. Por fim, deve o examinando indicar que o único imóvel de

Caio, utilizado para a sua residência e de sua família, é impenhorável, nos termos do art. 1.º da Lei 8.009/90.

EXERCÍCIO 23 – XXIII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar petição inicial de uma Ação de Repetição de Indébito que contemple pedido de restituição do valor pago indevidamente (Ação de Procedimento Comum), a ser endereçada ao Juízo da Vara com atribuição fazendária da Comarca da Capital do Estado “X”. A parte autora será o partido político XYZ, e a parte ré, o Município Alfa.

Mérito: o(a) examinando(a) deverá mencionar que a imunidade abarca todos os imóveis pertencentes ao partido XYZ. Como fundamentos, o examinando deverá indicar que, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea c e § 4.º, da CRFB/88, o partido XYZ é instituição imune, tendo pago indevidamente o IPTU referente à sua sede, à sua fundação e também aos dois imóveis cuja receita do aluguel é revertida para as atividades do partido, fazendo jus à restituição dos valores pagos indevidamente (art. 165 do CTN). Além disso, o(a) examinando(a) deverá apontar que se trata de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 724, que passou a ter efeito vinculante aos órgãos do judiciário e da Administração Pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, por meio da publicação da Súmula Vinculante 52 (“Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, inciso VI, alínea c, da CRFB/88, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”). Por fim, o(a) examinando(a) deverá formular pedido de acordo com as peculiaridades típicas da ação de repetição de indébito, respeitando as normas de fechamento de peças.

EXERCÍCIO 24 – XXIV EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o(a) examinando deverá elaborar a petição inicial de uma Repetição de Indébito, uma vez que se pretende a restituição do ICMS pago a maior.

A ação declaratória não satisfaz o interesse do cliente, visto que o objetivo não é evitar o lançamento do crédito tributário e sim restituir o que foi pago a mais. Não há discussão sobre inexistência ou existência de relação tributária do contribuinte com o fisco. Tampouco é cabível a ação anulatória, visto que não há lançamento a ser anulado. Também não é possível cogitar de Mandado de Segurança, que é inviável para obter restituição em espécie.

A ação de repetição de indébito deverá ser endereçada à Vara Cível (ou Vara de Fazenda Pública) da comarca da capital do estado ABC.

O autor da ação é o supermercado Beta e o réu é o estado ABC. A legitimidade de Beta, como contribuinte substituído, está prevista no art. 10 da Lei Complementar 87/1996.

Mérito: o examinando deve argumentar que a base de cálculo do ICMS é o valor estimado de comercialização da mercadoria ao consumidor final, conforme critérios definidos pelo art. 8.º da Lei Complementar 87/1996. Deve demonstrar conhecer o comando constitucional segundo o qual o contribuinte terá direito à restituição do valor já pago caso o fato gerador presumido não se concretize (art. 150, § 7.º, parte final, da CRFB/88). Deve, por fim, ponderar que a restituição é cabível se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, conforme entendimento pacificado pelo STF.

Por fim, deve requerer a procedência do pedido para que sejam restituídos os valores pagos a mais.

EXERCÍCIO 25 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICADA EM POA ALEGRE

Peça adequada: o examinando deverá elaborar Ação Anulatória, que deverá ser endereçada à Vara Federal da Seção Judiciária do Estado.

A possibilidade de Mandado de Segurança é afastada pela informação de que a PJ pretende ver a União condenada em honorários – o que não seria possível em caso de MS.

A autora é a pessoa jurídica PJ e a ré é a União.

Mérito: o examinando deverá sustentar que a base de cálculo do imposto considerada pela União está incorreta, pois, no caso do desembaraço aduaneiro, será o preço normal do produto, acrescido do Imposto de Importação (II), das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis, conforme o art. 47, inciso I, alíneas *a*, *b* e *c*, do CTN.

Tendo isso em vista, o examinando deve alegar que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme a Súmula 323 do STF, e que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo, segundo a Súmula 70 do STF.

O examinando deve formalizar pedido de concessão de tutela de urgência para (i) a imediata liberação das mercadorias apreendidas, (ii) cessar a interdição do estabelecimento e (iii) suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite desta ação.

Deve o examinando requerer a procedência do pedido para: (i) a desconstituição do crédito tributário, (ii) a liberação dos equipamentos apreendidos, e (iii) para cessar a interdição de seu estabelecimento.

Por fim, o fechamento da peça.

EXERCÍCIO 26 – XXV EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar a peça de apelação, com o objetivo de ver sua pretensão efetivamente julgada no mérito pelo Tribunal, afastando-se a ilegitimidade passiva do Estado X para

reconhecer que este último está obrigado a restituir ao servidor o valor indevidamente retido na fonte quanto ao imposto sobre a renda.

O recurso deve ser interposto perante o juízo de 1º grau (3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado X), podendo inclusive ser objeto de juízo de retratação, mas as razões recursais devem ser endereçadas ao Tribunal de Justiça local. É apelante o servidor José da Silva e apelado o Estado X.

Quanto ao cabimento, deve-se indicar que contra sentença que indefere a petição inicial cabe apelação, nos termos dos arts. 331, 485, § 7º, e 1.009, todos do CPC, sendo o prazo de apelação de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Os fatos devem ser descritos nos termos colocados pelo enunciado.

O examinando deve ser capaz de, preliminarmente, indicar que o Estado X é sim parte legítima para figurar no polo passivo. Embora o imposto sobre a renda seja tributo de competência da União, a parte legítima para figurar no polo passivo desse tipo de demanda de repetição de indébito tributário é o próprio ente federado beneficiário da receita auferida com a retenção na fonte do IR, a saber, o próprio Estado X, por força do art. 157, inciso I, da CRFB/88 e conforme fixado na Súmula 447 do STJ.

Mérito: o examinando deve indicar que o pagamento em pecúnia de licença-prêmio que não foi gozada por necessidade do serviço assume caráter indenizatório, não configurando acréscimo patrimonial, mas sim compensação ao gravame a direito adquirido, não estando sujeito à incidência do IR, nos termos da Súmula 136 do STJ. Portanto, a retenção é indevida, devendo ser o apelado condenado a restituir o valor do tributo indevidamente cobrado.

Nos pedidos, deve o examinando requerer que seja afastada a ilegitimidade passiva do Estado X, de modo a que o Tribunal possa julgar imediatamente a demanda logo após as contrarrazões do

apelado (pois a causa já está em condições de ser julgada sem maior dilação probatória). Pode-se requerer o julgamento por decisão monocrática do relator, por afronta ao enunciado de Súmula do STJ, dando-se provimento ao recurso para reconhecer a não incidência do IR sobre o pagamento em pecúnia de licença-prêmio que não foi gozada por necessidade do serviço e para condenar o apelado a restituir, devidamente atualizado, o valor de tributo indevidamente retido, bem como condená-lo ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Por fim, o examinando deve respeitar as normas de fechamento da peça.

EXERCÍCIO 27 – XXVI EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar a peça recursal de Agravo de Instrumento. Ao exigir “peça recursal”, o enunciado afasta qualquer dúvida quanto ao cabimento de qualquer outra medida que não seja recurso, como, por exemplo, uma exceção de pré-executividade, que, ademais, seria indevida, pois o enunciado não contesta a executividade do título que aparelha tal execução e seus elementos essenciais, nem se contesta que tal cobrança é devida contra o executado (o enunciado tão somente indica que uma tutela provisória cautelar foi concedida de modo equivocado, como se pretende que o candidato identifique na peça).

O recurso deve ser interposto diretamente perante o Tribunal Regional Federal, endereçado ao Desembargador Presidente (que irá distribuir o recurso a uma das Turmas do Tribunal, a quem as razões recursais se destinam). É agravante José da Silva e agravada a União/Fazenda Nacional.

Quanto ao cabimento, deve-se indicar que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias (a indisponibilidade dos bens e direitos do

executado do art. 185-A do CTN tem natureza de tutela provisória de urgência de caráter cautelar), bem como contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (art. 1.015, inciso I e parágrafo único, do CPC).

Deve-se indicar a tempestividade do agravo, pois o enunciado exige atuação imediata do advogado. O executado já está ciente da decisão lançada nos autos, ainda que não tenha sido publicada. Portanto, se o art. 1.003, § 5º, do CPC prevê o prazo de 15 dias para interposição do agravo, e a decisão sequer foi publicada, é inequívoca a tempestividade, de acordo com o art. 218, § 4º, do CPC (“Art. 218. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”)

Deve-se mencionar o cumprimento do art. 1.017 e a juntada dos documentos ali previstos.

Os fatos devem ser descritos nos termos colocados pelo enunciado.

No mérito, o examinando deve indicar que, embora não tenham sido encontrados ativos financeiros, segundo a Súmula 560 do STJ, para que o juiz possa se valer da medida prevista no art. 185-A do CTN, é necessário o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. No caso, houve apenas a tentativa (infrutífera) de constrição sobre ativos financeiros. Não houve expedição de ofícios aos registros públicos devidos, de modo que ainda não se podia lançar mão da indisponibilidade de bens e direitos do art. 185-A do CTN. Ademais, o art. 185-A, § 1º, do CTN determina que tal indisponibilidade limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. Portanto, não poderia o juiz determinar a indisponibilidade dos bens e direitos do executado, no valor de até

três vezes o montante da dívida.

Deve também o examinando abrir uma seção para apresentar o caráter iminente da constrição patrimonial, que poderá causar ao executado dano grave ou de difícil reparação, e que se trata de decisão judicial equivocada, contrária ao enunciado de Súmula do STJ e ao texto expresso do art. 185-A, § 1º, do CTN, cabendo efeito suspensivo a ser requerido ao relator (presença de *fumus boni iuris* e *periculum in mora*), nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC.

Nos pedidos, deve o examinando requerer a concessão de efeito suspensivo, a intimação da agravada e que seja dado provimento ao agravo pelo próprio relator (monocraticamente), uma vez que a decisão recorrida é contrária à Súmula do STJ, de modo a que seja reformada a decisão interlocutória de indisponibilidade de bens. Por fim, o examinando deve respeitar as normas de fechamento da peça.

EXERCÍCIO 28 – XXVII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o examinando deverá elaborar Embargos à Execução, uma vez que se pretende a extinção dos créditos tributários perseguidos por meio da execução fiscal e ainda há prazo para os embargos (não sendo o caso, portanto, de ação anulatória, que não teria, salvo depósito integral ou tutela de urgência, o condão de suspender o curso da execução fiscal).

Os embargos à execução deverão ser endereçados à 4ª Vara de Fazenda Pública do Estado X.

O Embargante é a sociedade empresária XYZ e o embargado é o Estado X.

O examinando deverá requerer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, justificando a probabilidade do direito pela inconstitucionalidade flagrante da exação, e o perigo de dano pela possibilidade de grave lesão ao seu patrimônio.

Mérito: o examinando deverá abordar os seguintes pontos:

a taxa em apreço possui base de cálculo própria de imposto, qual seja o preço de venda das mercadorias, já alcançado pelo ICMS, em ofensa ao art. 145, § 2º, da Constituição Federal, e ao art. 77, parágrafo único, do CTN. No caso, nem é possível invocar, em favor da taxa, a Súmula Vinculante 29, pois a hipótese aventada na questão é de “integral identidade” entre as duas bases de cálculo

2. a taxa de vendas interestaduais não constitui contrapartida ao exercício do poder de polícia ou a serviço público específico e divisível, prestando-se exclusivamente a aumentar a arrecadação fiscal, desrespeitando, assim, a norma contida no art. 145, inciso II, da CRFB/88 e no art. 77, *caput*, do CTN; e

3. a taxa compromete a livre circulação de mercadorias ao onerar as operações de venda interestadual e estabelecer tratamento diferenciado em razão do destino do bem (arts. 150, inciso V, e 152, ambos da CRFB/88);

O examinando deverá requerer:

i) que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC vigente;

ii) que seja feita a intimação do exequente para, querendo, apresentar impugnação;

iii) a procedência do pedido para o fim de desconstituir o crédito tributário e extinguir a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da exação; e

iv) a condenação da exequente em custas e honorários advocatícios.

Por fim, o fechamento da peça.

EXERCÍCIO 29 – XXVIII EXAME UNIFICADO

Peça adequada: o(a) examinando(a) deverá elaborar a peça de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, para buscar perante c

STJ a concessão da segurança que foi denegada pelo Tribunal de Justiça local.

O recurso deve ser interposto por petição dirigida ao Desembargador Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, mas as razões recursais devem ser endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça. É recorrente sociedade empresária Sigma S/A e recorrido o Estado X.

O(a) examinando(a) deve requerer a intimação do recorrido para oferecer resposta e que o recurso seja remetido ao STJ, independentemente de juízo de admissibilidade.

Quanto ao cabimento, deve-se indicar que cabe ao STJ julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais dos estados, quando denegatória a decisão, nos termos do art. 105, inciso II, alínea *b*, da CRFB/88, do art. 18 da Lei 12.016/2009 ou do art. 1.027, inciso II, alínea *a*, do CPC/2015, bem como indicar a tempestividade do recurso. Além disso, deve ser recolhido o preparo, nos termos do art. 1.007, *caput*, CPC/2015.

Mérito: o(a) examinando(a) deve indicar que também são fatos geradores do ICMS as prestações de serviços de comunicação, nos termos do art. 155, inciso II, da CRFB/88. Contudo, serviços de comunicação propriamente ditos somente se configuram quando um terceiro, mediante prestação onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato, o que não é o caso do mero serviço de habilitação de telefone celular, em que não ocorre nenhuma comunicação. Assim, o STJ assentou que, na verdade, a habilitação do celular é mera atividade preparatória ao serviço de comunicação por telefonia móvel, mas não serviço de comunicação, razão pela qual não deve sobre tal habilitação incidir o ICMS, nos termos da Súmula 350 do STJ.

Além disso, deve indicar que, ainda que houvesse incidência do ICMS na hipótese, a possibilidade de constituir os pretensos créditos

tributários já foi alcançada pela decadência. A autuação com lançamento de ofício ocorreu em 31/07/2017, mais de 5 anos após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, OU do art. 150, § 4º, ambos do CTN (os pretensos fatos geradores teriam ocorrido de janeiro a junho de 2010).

Deve também impugnar a condenação em honorários de sucumbência, pois o rito especial do Mandado de Segurança os exclui, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, da Súmula 512 do STF ou da Súmula 105 do STJ.

Nos pedidos, deve requerer que seja dado provimento ao recurso para conceder a ordem, pois: a) não incide ICMS sobre a habilitação de telefones celulares; b) ainda que houvesse incidência, a possibilidade de constituir o crédito tributário foi atingida pela decadência.

O provimento ao recurso deve ser dado pelo próprio relator no STJ (monocraticamente), uma vez que a decisão recorrida é contrária à Súmula do STJ, e que, em qualquer hipótese, seja reconhecido o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência.

Por fim, deve-se pedir a condenação do recorrido ao ressarcimento das custas processuais.

O(A) examinando(a) deve respeitar as normas de fechamento da peça

QUESTÕES DISCURSIVAS

As questões discursivas aqui inseridas foram extraídas de exames passados realizados pela OAB, assim como as respostas fornecidas.



QUESTÃO 1 – EXAME OAB 2010.2

Mário Roberto possui terreno limítrofe entre as zonas urbana e rural do município de Pedra Grande. No ano de 2009, ele recebeu o carnê do IPTU, emitido pela Secretaria de Fazenda de Pedra Grande, e também foi surpreendido com a cobrança do ITR sobre a mesma parcela do imóvel.

Como advogado de Mário Roberto, discorra sobre a ação judicial mais adequada para a defesa de seu interesse. Aponte quem deve figurar no polo passivo da ação e de quem é a competência para o julgamento.

QUESTÃO 2 – EXAME OAB 2010.2

A empresa Vídeo Locadora, estabelecida no Município Y, tem como atividade principal a locação de fitas de vídeo, DVDs e congêneres,

estando tal atividade prevista em item específico da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, desta Municipalidade. Todavia a empresa, por meio de seu representante legal, entende que a sua atividade estaria fora do campo de incidência do ISS, razão pela qual pretende suspender o seu pagamento. A empresa ainda não foi notificada pelo Fisco e também nunca pagou o tributo.

O entendimento da empresa está correto? Em caso afirmativo, qual(is) demanda(s) a ser(em) proposta(s)? Justifique.

QUESTÃO 3 – EXAME OAB 2010.2

Determinada Lei Estadual, publicada em 10.01.2010, estabeleceu a redução das alíquotas e das multas aplicáveis, respectivamente, aos fatos jurídicos tributáveis e ilícitos fiscais previstos na legislação do ICMS daquele Estado.

Considerando que certo contribuinte tenha sido autuado pela fiscalização local em 15.12.2009, em razão de falta de pagamento do ICMS relativo aos meses de fevereiro/2009 a novembro/2009, poderia ser aplicada a nova lei aos fatos geradores e infrações fiscais ocorridas em 2009, uma vez que este contribuinte ofereceu impugnação em tempo hábil, estando ainda pendente de julgamento na esfera administrativa? Responda, com base na legislação aplicável à espécie.

QUESTÃO 4 – EXAME OAB 2010.2

Lei Municipal XYZ, publicada em 20.09.2010, alterou a cobrança do ISS para os advogados. A lei definiu que, a partir de 2011, a base de cálculo dos serviços prestados por advogados será o preço do serviço, qual seja, o valor dos honorários profissionais recebidos.

Com base na situação hipotética, emita parecer acerca da legalidade do diploma legal em questão. Caso entenda pela ilegalidade da

cobrança, que medida(s) judicial(ais) um advogado pode propor para suspender a cobrança do tributo?

QUESTÃO 5 – EXAME OAB 2010.2

Empresa de auditoria externa foi contratada por DELTA S.A. e verificou que houve cálculo equivocado e pagamento a maior de COFINS relativo às competências: de abril/2006; julho/2006 abril/2007 e julho/2007.

À vista disso, emita parecer sobre:

I. o prazo para o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente na esfera federal.

II. quais as medidas judicial(is) e administrativa(s) para que o contribuinte possa reaver os valores pagos indevidamente? Justifique.

QUESTÃO 6 – EXAME OAB 2010.3

Em março de 2009, João, após ser citado em execução fiscal, vendeu automóvel a Pedro, acarretando a sua insolvência. Posteriormente, a Fazenda requereu a penhora do bem, a qual foi prontamente deferida pelo Juízo da Execução. Inconformado, Pedro ajuizou embargos de terceiro alegando que, quando adquiriu o veículo, não havia restrição judicial sobre o bem, por não constar registro de penhora relativo ao automóvel. O veículo fora adquirido de boa-fé, descaracterizando, portanto, a fraude à execução, conforme sustentou o embargante, com base em entendimento jurisprudencial pacífico.

Com base na aplicação da legislação tributária, os embargos devem ser acolhidos? Empregue os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 7 – EXAME OAB 2010.3

Município situado na região XYZ do Brasil realizou serviços e obras de rede de água potável e esgoto de certo bairro, durante o primeiro

semestre de 2010, o que resultou na valorização de 100 (cem) imóveis da região. O custo total da obra correspondeu a R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Com isso, o Município editou Decreto, em 02.09.2010, a fim de disciplinar a instituição e cobrança de contribuição de melhoria incidente sobre os imóveis alcançados pela valorização imobiliária em questão. A municipalidade, para efetuar a respectiva cobrança, considerou somente a diferença entre o valor venal dos referidos imóveis antes da realização das obras e seu valor venal ao término das obras públicas, com base no cadastro do IPTU local. Em 10.10.2010, os contribuintes foram notificados mediante recebimento de cobrança, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, efetuarem o pagamento da referida exação fiscal.

Com base nesse cenário, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Discuta a correção da cobrança da exação, como realizada pela municipalidade, justificando com base na legislação e sua interpretação.
- b) Analise o cálculo feito pela municipalidade para encontrar o valor devido pelos contribuintes, esclarecendo se é compatível com a legislação em vigor.

QUESTÃO 8 – EXAME OAB 2010.3

Determinada pessoa física adquiriu de outra uma papelaria, estipulando-se, no contrato de compra e venda do estabelecimento, que o vendedor assumia plena responsabilidade por eventuais débitos fiscais anteriores à operação, ainda que apurados posteriormente. Três anos depois da operação, a Fiscalização Tributária Estadual lavrou auto de infração contra o adquirente do estabelecimento, por débitos do ICMS relativos à venda de mercadorias efetuadas em anos anteriores à aquisição da papelaria. Defendeu-se o autuado, dizendo

não ser responsável pelo imposto reclamado, visto que o vendedor, antigo dono, assumira tal responsabilidade.

Sabendo-se que o antigo proprietário, à época, aposentou-se cessando sua atividade empresarial, analise se há responsabilidade tributária do adquirente da papelaria, bem como os efeitos do contrato firmado entre o vendedor e o comprador do negócio. Justifique de forma cabal, com base na legislação.

QUESTÃO 9 – EXAME OAB 2010.3

O Estado de São Paulo, em razão da necessidade emergencial de conseguir novos recursos para pagar o 13.º salário do funcionalismo público, decide extinguir benefícios fiscais outrora concedidos e que acarretam diminuição da arrecadação. Dessa forma, é aprovada a Lei 2.000, publicada em 30 de março de 2007, que determina a imediata revogação de isenção do ICMS concedida aos comerciantes de leite e seus derivados, passando a ser aplicada a alíquota de 18% sobre a venda dos produtos em geral, conforme já previsto no ordenamento jurídico estadual. A empresa Longa Vida Laticínios Ltda. não recolhe o tributo e é autuada pelo Fisco Estadual em janeiro de 2008, que exigiu o ICMS de abril até dezembro do ano anterior.

Com base nesse cenário, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, discorra sobre a legalidade da exigência do ICMS para a empresa Longa Vida Laticínios Ltda.

QUESTÃO 10 – EXAME OAB 2010.3

A transportadora aérea brasileira Voe Bem S.A. firmou contrato de *leasing* por 20 anos e sem opção de compra de três aeronaves 747-800 novíssimas com a empresa Bongo, com sede em Minneapolis, Estados Unidos da América, para o transporte doméstico de passageiros. As aeronaves foram entregues no prazo avençado.

Ocorre que, na chegada das aeronaves ao Brasil, a Voe Bem S/A recebeu notificação do Estado X, por meio da Secretaria de Fazenda Estadual, determinando o pagamento do ICMS relativo às três aeronaves. O departamento jurídico da Voe Bem S/A entra em contato com você, renomado(a) tributarista, para consultá-lo(a) sobre a questão.

Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) A cobrança é constitucional ou inconstitucional?
- b) Quais são os pressupostos de incidência do imposto?
- c) Qual é a principal característica desse contrato que determina a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da cobrança?

QUESTÃO 11 – OAB FGV IV EXAME

A empresa Nova Casa atua no ramo de venda de eletrodomésticos e como tal encontra-se sujeita ao recolhimento do ICMS e ao dever de entregar arquivos magnéticos com as informações das vendas efetuadas em cada período de recolhimento. Em fiscalização realizada em 01.02.2009, o Fisco Estadual constatou a insuficiência do recolhimento do ICMS no período entre 01.01.2008 a 01.02.2009 e lavrou auto de infração exigindo o tributo não recolhido acrescido de multa no montante correspondente a 80% do tributo devido, na forma da legislação estadual. Ainda como consequência da fiscalização, foi lavrado outro auto de infração para aplicar a penalidade de R\$ 1.000,00 por cada arquivo magnético não entregue no mesmo período. Ocorre que, no prazo para apresentação da impugnação administrativa, os sócios da empresa Nova Casa finalizaram as negociações anteriormente iniciadas com a sua concorrente Incasa e decidiram vender a empresa, a qual foi incorporada pela Incasa. Ao se deparar com as autuações em questão, a Incasa aciona o seu corpo

jurídico.

Com base nesse cenário, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Existe a possibilidade de cancelar, total ou parcialmente, o auto de infração lavrado para cobrança do tributo devido e da sua respectiva penalidade?

b) Existe a possibilidade de cancelar, total ou parcialmente, o auto de infração lavrado para exigir a penalidade por falta de entrega dos arquivos magnéticos?

QUESTÃO 12 – OAB FGV IV EXAME

O Laboratório de Análises Clínicas Almeida Silva Ltda., cuja sociedade é constituída por 3 (três) sócios, um médico, um farmacêutico e uma empresária, explora, no ramo da medicina, serviços de análises clínicas, em caráter empresarial, mantendo, para tanto, várias filiais em funcionamento em diversas municipalidades de determinada região do país. Ocorre que, a partir de março/2011, a referida empresa, na qualidade de contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, deixou de recolher o respectivo tributo, dando origem a diversas autuações fiscais, que geraram defesas administrativas no sentido de que o ISS deveria ser calculado e recolhido como tributo fixo, ou seja, com base em um valor fixo previsto na legislação municipal pertinente a ser calculado em relação a cada sócio, não devendo ser considerado, para fins de apuração do imposto, o valor do serviço praticado pela empresa com incidência da alíquota correspondente à sua atividade.

Esclareça se o laboratório tem ou não direito a realizar o recolhimento na forma pretendida. Justifique, com base na legislação tributária pertinente.

QUESTÃO 13 – OAB FGV IV EXAME

Caio e Tício pretendem celebrar contrato de compra e venda de bem imóvel. Contudo, para consumarem o negócio, constituem previamente a pessoa jurídica Provisória Ltda., formada por eles apenas tendo por fito única e exclusivamente não fazer incidir o ITBI sobre a operação, com amparo no art.156, § 2.º, I, da CF/1988, que prevê hipótese de imunidade da referida exação sobre o imóvel utilizado na integralização do capital social. Nesse sentido, Caio, originalmente proprietário alienante do bem, integraliza suas quotas na forma do imóvel, e Tício completa o capital social da empresa depositando o montante correspondente ao valor do bem objeto da alienação. Após pouco mais de duas semanas, Caio e Tício dissolvem a sociedade e, como consequência, Caio recebe sua parcela do capital em dinheiro, ao passo que Tício recebe o seu quinhão na forma do imóvel.

Análise a conduta adotada pelos particulares e responda se, e como, poderia a Fazenda Municipal satisfazer seu crédito com relação à situação apresentada, uma vez descoberta a real intenção dos dois agentes.

QUESTÃO 14 – OAB FGV IV EXAME

Um Estado da Federação promulga lei ordinária que prevê como modalidade de extinção, total ou parcial, dos créditos tributários de sua competência inscritos em dívida ativa a dação em pagamento de bens móveis (títulos públicos). Analise a regularidade dessa lei e sua compatibilidade com o sistema jurídico tributário nacional.

QUESTÃO 15 – OAB FGV V EXAME

A concessionária de veículos Carros Ltda. impetra mandado de segurança em face da Fazenda Pública do Estado de Goiás objetivando que fosse considerado na base de cálculo adotada para fins de substituição tributária o valor dos descontos promocionais

concedidos pela empresa Ford quando da venda dos veículos a Carros Ltda. O juiz concedeu a liminar pleiteada e determinou que a Ford promovesse o recolhimento do ICMS-ST com base no valor de venda diminuído dos descontos promocionais. Quando da prolação da sentença, a liminar foi revogada e restabelecida a base de cálculo anterior, tendo sido intimada a Ford para que voltasse a proceder ao recolhimento com base no valor integral de venda. O processo atualmente encontra-se em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido mantida a sentença monocrática.

Em fiscalização realizada junto à Ford, o Fisco Estadual decidiu por exigir desta o recolhimento do montante que deixou de ser recolhido durante o período de vigência da medida liminar, acrescido das penalidades previstas. Na condição de advogado da Ford, quando consultado, avalie:

- a) a legitimidade passiva da Ford para suportar a autuação realizada;
- b) a possibilidade de tal exigência sobre o período abrangido pela medida liminar.

QUESTÃO 16 – OAB FGV V EXAME

Determinado jogador integrante de importante time de futebol de estado da federação brasileira, na qualidade de pessoa física, ao promover, em dezembro de 2010, a importação, por conta própria, de um automóvel de luxo, da marca Jaguar, zero quilômetro, fabricado no exterior, foi surpreendido com a cobrança de tributos, inclusive o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Todavia, o jogador de futebol, inconformado com a cobrança do referido imposto estadual, ajuizou, por meio de seu advogado, competente mandado de segurança, com base na Súmula 660 editada pelo STF, a fim de viabilizar a defesa dos seus direitos perante a Justiça Estadual.

Com base no caso acima, responda aos itens a seguir, empregando os

argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) O jogador de futebol em questão estaria enquadrado na qualidade de contribuinte do ICMS?
- b) Considerando que existe pedido liminar, analise sua viabilidade, bem como a do direito em discussão.

QUESTÃO 17 – OAB FGV V EXAME

A Corta Pinheiro Ltda., empresa madeireira regularmente estabelecida e em dia com suas obrigações fiscais, recebeu, há pouco, boleto para pagamento de duas taxas: a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída por lei federal, que confere ao Ibama poderes para controlar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, que deve ser paga trimestralmente, e a Taxa de Conservação das Vias e Logradouros Públicos (TCVLP) do município onde a Corta Pinheiro Ltda. est sediada, esta com exação anual. Após uma breve pesquisa, o departamento jurídico da empresa atesta que, no último ano, o Ibama, apesar de manter o órgão de controle em funcionamento, não procedeu a qualquer fiscalização da empresa e que o município efetivamente mantém órgão específico responsável pela conservação das vias e logradouros públicos.

Com base no caso acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Qual é a principal diferenciação entre a natureza jurídica da TCFA e a TCVLP e como ela influencia o caso em tela?
- b) As taxas são devidas?

QUESTÃO 18 – OAB FGV V EXAME

Em janeiro de 2007, o agricultor Manoel Santos teve sua extensa

propriedade invadida por cinquenta famílias de camponeses. Inconformado, ele moveu, tempestivamente, ação de reintegração de posse com pedido de medida liminar no intuito de ser reintegrado na posse do imóvel, a qual foi prontamente deferida, embora siga pendente de cumprimento, por inércia do poder público. Com base na situação apresentada, responda, fundamentadamente, como repercute a incidência do Imposto Territorial Rural.

QUESTÃO 19 – OAB FGV VI EXAME

Instituição financeira Bling Bling S.A insurge-se por meio de ação anulatória de débito fiscal em face de auto de infração lavrado por agente do fisco municipal, que fora expedido em decorrência da ausência do recolhimento do Imposto Sobre Serviço sobre as tarifas cobradas pelo banco pela atividade de análise, cadastro, controle e processamento, prestada na elaboração de contrato de adiantamento de crédito para clientes que se encontram sem fundos em suas contas bancárias. A empresa alega, em síntese, que não procede a cobrança, tendo em vista que o aludido serviço não configura hipótese de incidência de nenhuma forma de tributo, em especial o ISS, por não constar expressamente previsto na lista de serviços anexa à LC 116/2003. Responda se o pleito da demandante deve ser acolhido, empregando os fundamentos legais cabíveis.

QUESTÃO 20 – OAB FGV VI EXAME

A empresa de construção civil Britadeira Ltda. é intimada por autoridade da Fazenda Estadual para que proceda ao recolhimento do ICMS complementar referente à diferença das alíquotas interestaduais e internas proveniente de aquisição de materiais adquiridos pela limitada em outro Estado para utilizar em obra realizada no território da unidade federativa que realizou a intimação.

Diante desse fato, o administrador da empresa consulta os seus conhecimentos tributários, com o intuito de saber se, de fato, deve

incidir a cobrança do ICMS – ou de qualquer outra espécie de imposto estadual ou municipal – sobre a operação realizada pela companhia. Responda fundamentadamente.

QUESTÃO 21 – OAB FGV VI EXAME

Determinado contribuinte do ICMS, com sede no Estado Beta detentor de saldos credores do respectivo imposto acumulados desde a edição da Lei Complementar 87/1996, em razão de operações de exportação, foi autuado pela Fiscalização Estadual sob o entendimento de ser inválida a operação de transferência dos saldos credores do ICMS acumulados a outro estabelecimento seu, situado no mesmo Estado, tendo em vista a ausência de lei estadual disciplinando a hipótese objeto do auto de infração em questão. Procedeu o Fisco corretamente? Justifique com base na legislação tributária pertinente.

QUESTÃO 22 – OAB FGV VI EXAME

A Fábrica de Refrigerantes Super Refri Ltda. recolheu a maior o IP incidente sobre a saída dos respectivos produtos vendidos à Distribuidora de Bebidas Delta Ltda. Verificado o equívoco, a Distribuidora de Bebidas postulou em juízo o creditamento relativo ao IPI indevidamente pago pela fabricante, mas embutido no preço do produto. Nesse caso, tem a distribuidora legitimidade para requerer a repetição do indébito? Justifique, com base na legislação tributária pertinente.

QUESTÃO 23 – OAB FGV VII EXAME

Em 20.05.1995, a Receita Federal, em decorrência de fiscalização realizada na sede da empresa ABC, constatou que a empresa não havia declarado, e conseqüentemente recolhido, a COFINS referente a todos os meses do exercício de 1990. Notificada a empresa, esta impugnou, sem sucesso, o auto de infração e, depois, recorreu

administrativamente ao Conselho de Contribuintes. Em 20.07.2004, adveio a decisão definitiva, confirmando o ato da autoridade tributária, sendo a empresa notificada da referida decisão na própria data. A União Federal ajuizou execução fiscal relativa ao crédito em 20.06.2009, sendo que o despacho de citação foi exarado em 20.08.2010, entretanto, não encontrada de pronto a executada, a exequente não mais movimentou o processo.

Examine as questões envolvidas e responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Analise a constituição do crédito tributário pelo Fisco, referindo se ocorreu de forma regular ou não, bem como se adveio dentro do prazo legal.
- b) Houve, na hipótese, interrupção ou suspensão do prazo de cobrança do crédito fiscal?
- c) A propositura da execução em 20.06.2009 e o despacho de citação em 20.08.2010 resguardarão o direito da Fazenda Pública?

QUESTÃO 24 – OAB FGV VII EXAME

Até o ano de 2007, o Sr. José da Silva exerceu a função de sócio com poderes de gestão da “Acampados Turismo S/A”, tendo, posteriormente, se desligado da sociedade. Em fevereiro de 2011, é surpreendido ao ser citado em execução fiscal para responder por débitos fiscais pendentes relativos ao IRPJ, e pela falta de recolhimento de contribuições previdenciárias dos funcionários as quais foram devidamente descontadas, ambos referentes a período de apuração em que José administrava a empresa.

Considerando a situação acima, responda aos itens a seguir:

- a) É possível a cobrança integral do ex-sócio dos montantes tributários e previdenciários devidos e não recolhidos pela companhia, quando ele já não exercia mais atos de administração da

S/A?

b) Houve infração legal imputável a José da Silva?

QUESTÃO 25 – OAB FGV VII EXAME

Determinado contribuinte adquiriu um lote de terreno, em zona de expansão urbana, situado em Condomínio ainda não dotado de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1.º, do CTN.

Considerando o caso acima, responda aos itens a seguir:

a) Sobre o bem imóvel acima especificado há incidência de imposto?

b) Havendo incidência, qual Ente o titulariza?

Justifique, com a indicação dos dispositivos legais pertinentes.

QUESTÃO 26 – OAB FGV VII EXAME

Um jovem de 14 (quatorze) anos, especializado em rastreamento de sistemas e informática em geral, auferir, mensalmente, a quantia total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por força de contrato verbal de prestação de serviços, mantido com certa empresa contratante.

Nesse caso, entende o jovem, em razão da sua absoluta incapacidade civil, não estar adstrito a quaisquer obrigações tributárias, razão pela qual não procede ao recolhimento do tributo decorrente das operações acima mencionadas.

À vista disso, o procedimento adotado pelo referido jovem está em consonância com o sistema legal tributário? Justifique, apontando os dispositivos legais pertinentes.

QUESTÃO 27 – OAB FGV VIII EXAME

A Empresa LM S/A, produtora de cosméticos, recolheu a maior o IP incidente sobre a saída dos respectivos produtos vendidos a terceiros, tendo sido incluído, no preço da venda, o montante do tributo.

Verificado o equívoco, a empresa ingressou com pedido, junto à

Receita Federal competente, ao efeito de ser declarado o pagamento indevido e restituído o seu montante. A Receita Federal reconheceu o pagamento indevido, tendo, contudo, negado o pedido de restituição.

Esclareça se é possível a repetição do indébito no caso vertente, quem deveria requerer e com qual fundamento. Justifique com base no ordenamento jurídico em vigor.

QUESTÃO 28 – OAB FGV VIII EXAME

Determinado Município da Federação ingressa com execução fiscal referente ao IPTU devido, anos 2010/2011, em relação a um imóvel de propriedade da Companhia de Saneamento do Estado em que está localizado o exequente. A Companhia é sociedade de economia mista, dedicada à área de saneamento, com ações negociadas em bolsa de valores.

Com base no caso apresentado, responda, com a indicação dos dispositivos legais pertinentes, aos seguintes itens.

- a) Quais os fundamentos possíveis para a cobrança efetivada pelo Município?
- b) O que poderia alegar a Companhia na defesa de seu interesse em não pagar o imposto?

QUESTÃO 29 – OAB FGV VIII EXAME

Lei Estadual publicada em 12.05.2011 estabeleceu, entre outras providências, novo critério para apuração da base de cálculo do ICMS, no sentido de que o valor correspondente aos descontos incondicionais nas operações mercantis deve ser integrado à respectiva base de cálculo do ICMS.

À vista disso, alguns jornais especializados em economia noticiaram que a aludida lei seria inconstitucional, visto que lei ordinária não poderia tratar de base de cálculo do ICMS, sendo matéria reservada à lei complementar.

Nesse caso, a notícia divulgada está correta? Justifique, com o apontamento de todos os dispositivos legais pertinentes.

QUESTÃO 30 – OAB FGV VIII EXAME

Determinado Município instituiu, mediante lei, uma Taxa de Instalação de Rede Elétrica, tendo como contribuintes moradores de certo bairro que se encontravam desprovidos do serviço de iluminação pública.

Nesse caso, tal exação fiscal se compatibiliza com o ordenamento jurídico tributário em vigor? Justifique sua resposta, apontando todos os dispositivos legais pertinentes, ciente de que o fato gerador da taxa é a instalação de rede elétrica.

QUESTÃO 31 – OAB FGV IX EXAME

Determinado Prefeito Municipal editou o Decreto X, publicado em 20.09.2011, a fim de modificar os critérios relativos à apuração da base de cálculo do IPTU, tornando-o mais oneroso para os contribuintes da respectiva municipalidade. Sabe-se que as mudanças inseridas no aludido Decreto só entrariam em vigor a partir do dia 01.01.2012.

Nesse caso, o referido ato normativo compatibiliza-se com o ordenamento jurídico tributário em vigor? Justifique, com o apontamento dos dispositivos legais pertinentes.

QUESTÃO 32 – OAB FGV IX EXAME

Suponha que a União Federal tenha editado Lei Ordinária “X” em 14.05.2012, a fim de disciplinar o imposto sobre grandes fortunas – IGF, dispondo, em seu art. 1.º, exclusivamente, as seguintes hipóteses de incidência:

I – a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação

de ambos com valor acima de 1 milhão de reais.

II – quaisquer outros acréscimos patrimoniais não entendidos no inciso anterior.

De acordo com o exposto, é possível a instituição e a cobrança do referido imposto sobre grandes fortunas (IGF)?

Justifique, apontando os dispositivos legais pertinentes.

QUESTÃO 33 – OAB FGV IX EXAME

Jogador de Futebol, colecionador de carros de luxo, importa o último modelo de veículo utilitário para integrar sua coleção pessoal e é surpreendido ao ser impedido de retirar o produto no desembarço aduaneiro, em razão de ter apenas apresentado a documentação pertinente à quitação do Imposto de Importação, único tributo que o atleta acreditava devido, restando pendente a comprovação do pagamento do IPI, exigido pela autoridade alfandegária.

Utilizando todos os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente, responda aos itens a seguir.

- a) Na importação de produtos, a cobrança simultânea do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados revela hipótese de bitributação?
- b) Sobre a importação do veículo incide o Imposto sobre Produtos Industrializados?

QUESTÃO 34 – OAB FGV IX EXAME

Uma associação de indústrias de informática, sediada no município Alfa e que não goza de imunidade tributária, decide realizar um congresso de especialistas no município Beta, para que seus associados possam se atualizar sobre as novas tendências do mercado. Para organizar e administrar o evento, a associação contrata a empresa Pérola S/A, sediada no município Gama e sem estabelecimentos em outros locais. O valor desse contrato será pago,

30 dias após o evento, pela associação. Por outro lado, os interessados em assistir ao congresso têm de comprar ingressos. A receita de ingressos pertence à associação, cabendo à Pérola S/A apenas arrecadá-la nos guichês no dia do evento e repassá-la imediatamente à associação, sem qualquer desconto ou comissão.

Em face desses dados, responda, com base no ordenamento jurídico vigente, aos itens a seguir.

- a) Para qual(is) município(s) deve haver recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) por conta dos negócios jurídicos mencionados?
- b) Que receita(s) específica(s) compõe(m) a base de cálculo do ISS a ser recolhido pela empresa Pérola S/A?

QUESTÃO 35 – OAB FGV X EXAME

O Município “Z” ingressa com execução fiscal por conta de débito do ISS em face da empresa Bom Negócio Arrendamento Mercantil, da qual o Banco Bom Negócio S/A é sócio, pertencendo ambas ao mesmo grupo econômico. Com base no caso apresentado, responda justificadamente, utilizando todos os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie.

- a) Poderia o Banco Bom Negócio S/A ser parte legítima na execução fiscal? Resposta fundamentada.
- b) Quais são os requisitos que devem estar presentes para o reconhecimento de eventual solidariedade entre as duas empresas?

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 36 – OAB FGV X EXAME

A empresa “X”, atuante na locação de veículos, questiona judicialmente a incidência da COFINS referente às operações de locação que realiza, que não constituiriam prestação de serviço.

Com base na hipótese apresentada, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente.

- a) A locação de automóveis caracteriza prestação de serviço?
- b) Há incidência de COFINS sobre as operações de locação de veículos?

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 37 – OAB FGV X EXAME

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de determinada cidade entrou com ação na Vara de Fazenda Pública, impugnando a cobrança de IPTU sobre lojas de sua propriedade, situadas na área urbana do mesmo município, alegando e comprovando que os valores recebidos a título de aluguéis estavam sendo utilizados nas suas atividades essenciais.

O Município, em sua defesa, alega que os Sindicatos devem sustentar suas atividades com a contribuição sindical recebida e também que a própria cobrança de aluguel já evidencia a hipótese de restrição da imunidade prevista no art. 150, § 4.º, da Constituição Federal, por não ser finalidade essencial da entidade.

Com base no caso apresentado, assiste razão ao Sindicato? Justifique sua resposta com base na Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 38 – OAB FGV X EXAME

A Empresa JLMS Ltda. possui crédito no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em face da unidade federativa XYZ, onde mantém a sede de seu estabelecimento comercial, sendo tal crédito oriundo de um precatório judicial resultante de ação por

desapropriação.

Todavia, a empresa aqui cuidada encontra-se em débito com o Estado XYZ, em razão do não pagamento de ICMS no montante de 450.000,00.

Até o presente momento, a legislação estadual aplicável ao contribuinte em pauta somente prevê como forma de extinção do crédito de ICMS o pagamento em dinheiro conforme prazo e condições nela estabelecidas.

À vista disso, responda, justificadamente, utilizando todos os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie.

a) Qual a forma de extinção do crédito tributário que se amolda a liquidação do aludido débito do ICMS com a utilização do crédito oriundo do referido precatório judicial?

b) Com base na resposta contida na letra A, a referida empresa poderia liquidar o seu débito do ICMS fundado no crédito contido no aludido precatório judicial.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 39 – OAB FGV XI EXAME

A Procuradoria de Estado membro da Federação insurge-se, por meio de ação judicial, contra disposição constante de tratado internacional assinado entre os governos do Brasil e de outro país aderente ao Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT), o qual prevê a isenção de ICMS em relação a determinadas mercadorias importadas, listadas no acordo, quando também são isentados do imposto os produtos nacionais do mesmo gênero.

A Unidade da Federação, acima referenciada, sentindo-se lesada e alegando ter ocorrido a transgressão pela União de preceito relativo à competência tributária, busca a anulação da cláusula do pacto

internacional.

Deve ser acolhido o pedido do ente federativo? Responda fundamentadamente, apresentando a posição predominante no Supremo Tribunal Federal.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 40 – OAB FGV XI EXAME

A União, com o objetivo de financiar projetos de eletrificação rural, edita lei instituindo Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico que tem como fato gerador a propriedade de imóvel rural ao longo do exercício financeiro. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, e a alíquota é de 0,1%.

Diante da hipótese, analise a competência tributária para instituição da contribuição e os aspectos de seu fato gerador, notadamente a base de cálculo e o aspecto material.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 41 – OAB FGV XI EXAME

Baseado em uma efetiva hipótese de calamidade pública, o Presidente da República edita, em março de determinado ano, Medida Provisória instituindo empréstimo compulsório que passará a incidir a partir do mês subsequente. Indaga-se:

- a) Pode o empréstimo compulsório ser instituído por Medida Provisória?
- b) Qualquer que seja a resposta à questão anterior, deve o empréstimo compulsório observar o princípio da anterioridade?

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 42 – OAB FGV XI EXAME

No ano de 2012, Caio doou um bem móvel no valor de R\$ 100.000,00 para Tício, sem que tenha sido recolhido qualquer tributo. No ano seguinte, Tício, aconselhado por um amigo, antes de qualquer fiscalização por parte da Fazenda do Estado “X”, declarou e recolheu o Imposto sobre Transmissão *causa mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD) devido, acompanhado de juros de mora e correção monetária.

Ao tomar ciência do fato gerador do ITCD e verificar que não houve recolhimento da multa moratória, a Fazenda autuou Caio, visando à cobrança da multa.

Considerando o caso descrito e que a lei estadual previa que o doador é o contribuinte do ITCD, responda aos itens a seguir, fundamentadamente.

- a) Está correta a exclusão da multa moratória?
- b) Pode a lei estadual definir o contribuinte do ITCD?

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 43 – OAB FGV XII EXAME

João, de apenas 3 anos de idade, recebeu por herança apartamento que foi devidamente registrado em seu nome. Ao receber a primeira notificação para o pagamento de imposto predial e territorial urbano (IPTU) do referido imóvel no início de 2013, os pais de João deixaram de efetuar o recolhimento do tributo por entender que a cobrança seria improcedente, em razão da incapacidade civil do proprietário do imóvel.

Diante deste caso, analise:

- a) O entendimento dos pais de João está correto?
- b) O Fisco poderia cobrar o tributo diretamente dos pais de João?

QUESTÃO 44 – OAB FGV XII EXAME

A empresa XYZ deixou de declarar e pagar imposto sobre a renda, devido no ano calendário 2006. No início de 2013, a empresa decidiu incluir todos os valores não declarados e não pagos em um parcelamento previsto em lei federal, assinando, para tanto, termo de confissão de dívida.

Após quitação integral do parcelamento, a empresa XYZ percebeu que, antes mesmo da inclusão dos valores no referido programa, os débitos já tinham sido atingidos pela decadência, tendo em vista que em nenhum momento houve a constituição do crédito através do lançamento.

Diante disso, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Considerando o instrumento de confissão de dívida assinado pelo contribuinte, bem como a quitação integral do tributo, é possível que o contribuinte pleiteie a restituição dos valores que foram atingidos pela decadência?
- b) Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação não pago e não declarado, que dispositivo do Código Tributário Nacional é aplicável para regular a contagem do prazo para o Fisco realizar o lançamento?

QUESTÃO 45 – OAB FGV XII EXAME

Determinada instituição de educação sem fins lucrativos foi autuada pelo Estado “X”, em razão do descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação estadual. No caso, a obrigação acessória consistia em manter o livro de registro do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). Em sua defesa administrativa, a entidade sustentou que, por gozar de imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, *c*, da Constituição da República, e por não ser contribuinte do ISSQN, não estava obrigada a manter o livro de registro do referido imposto.

A tese sustentada na defesa apresentada pela entidade imune é procedente? Responda de forma fundamentada.

QUESTÃO 46 – OAB FGV XII EXAME

O Presidente da República editou Medida Provisória estabelecendo normas gerais sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), relativamente ao seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes.

Partindo da premissa de que estão preenchidos os requisitos de relevância e urgência, responda aos itens a seguir, de forma fundamentada, indicando os dispositivos legais pertinentes.

- a) Pode uma Medida Provisória do Presidente da República estabelecer normas gerais sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), tal como a acima referida?
- b) Inexistindo normas gerais relativas ao imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), podem os legisladores estaduais definir, no âmbito de suas competências, e observados os limites impostos pela Constituição Federal, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes desse imposto?

QUESTÃO 47 – OAB FGV XIII EXAME

O setor contábil da pessoa jurídica LP Ltda. entrega ao Fisco a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) devidamente preenchida, com relação ao recolhimento da contribuição para o PIS e da COFINS.

A Fazenda Nacional atestou que os respectivos tributos declarados no documento foram recolhidos a menor e enviou simples aviso de cobrança, quanto à diferença não recolhida.

Para participar em procedimento licitatório de seu interesse, a LP Ltda. não pode apresentar pendências fiscais e, por isso, interessa saber, com base na situação descrita:

a) Houve a constituição do crédito tributário relativo à diferença do valor já declarado, mas não recolhido pela LP Ltda.? Qual a posição dominante no STJ sobre o momento da constituição do crédito tributário?

b) A pessoa jurídica tem direito subjetivo à expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa?

O examinando deve fundamentar corretamente sua resposta.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 48 – OAB FGV XIII EXAME

No município X, a lei determina que, no caso de aquisição de imóvel em hasta pública, o fato gerador do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI) ocorre quando do registro do título aquisitivo no Registro de Imóveis. Em março de 2012, um imóvel localizado no município X é arrematado em hasta pública, e o arrematante paga o ITBI antecipadamente. A emissão da carta de arrematação e o registro da mesma no competente cartório do Registro de Imóveis ocorrem em maio do mesmo ano.

Em novembro do referido exercício, o município X publica lei (vigente a partir da publicação) aumentando a alíquota de ITBI e, atc contínuo, emite lançamento para cobrar, do citado arrematante, a correspondente diferença de ITBI em relação ao já pago.

Responda fundamentadamente:

a) O ITBI incidente sobre a operação narrada deveria ter sido recolhido ao município X?

b) Procede a cobrança, pelo município X, da diferença referida no enunciado?

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não

pontua.

QUESTÃO 49 – OAB FGV XIII EXAME

Julgada procedente a ação de repetição de indébito de imposto recolhido em 2009, proposta em face da Fazenda Estadual, José da Silva recorreu da decisão que lhe foi favorável, pretendendo alterar o marco temporal de aplicação dos juros moratórios constante da decisão judicial. O julgado determinou como devida a incidência dos juros moratórios na ordem de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, contrariando a pretensão autoral, que pleiteava o início do cômputo a partir da realização do pagamento indevido. Considerando que a legislação do Estado em questão não possui nenhuma norma própria a regular os índices de juros do imposto a ser restituído, responda aos itens a seguir.

- a) O contribuinte tem razão? Resposta fundamentada.
- b) Acaso a ação repetitória tratasse de um tributo federal, a contagem acerca da incidência dos juros seria diferente? Resposta fundamentada.

Justifique utilizando todos os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 50 – OAB FGV XIII EXAME

Uma pessoa jurídica, contribuinte do ICMS do Estado X, foi autuada por não recolhimento do ICMS devidamente escriturado, mas não informado em GIA-ICMS, dos meses de janeiro a julho de 2011. Foi exigida multa de 80% do valor não recolhido. No mês de maio de 2012, foi ajuizada a execução fiscal para cobrança do crédito tributário.

Devidamente citada, a sociedade ofereceu um caminhão em garantia,

que foi aceito pelo exequente e penhorado. A pessoa jurídica apresentou embargos à execução, sendo os mesmos desprovidos. Recorreu para o Tribunal de Justiça, que, por sua vez, não proveu a apelação. Protocolou recurso especial, estando este sujeito ao exame de admissibilidade. A Fazenda Estadual requereu o leilão do veículo, o que foi deferido em agosto de 2013.

O leilão foi marcado para 16 de dezembro de 2013. No dia 6 de dezembro foi publicada lei estabelecendo o percentual da multa para a mesma infração em 50%.

Diante da hipótese, qual é o percentual de multa que deve prevalecer? O examinando deve fundamentar corretamente sua resposta.

Obs.: A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 51 – XIV EXAME UNIFICADO

Ocorre o fato gerador do Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD) em 15.01.2001. Como não houve o recolhimento do imposto devido nem declaração por parte do contribuinte, em 17.07.2006 a Fazenda Estadual realiza o lançamento de ofício do imposto, dando ciência ao contribuinte. Após a interposição tempestiva de impugnação administrativa pelo contribuinte contra o lançamento e trâmite regular do processo administrativo tributário, o crédito foi constituído definitivamente em 10.06.2007, sendo o sujeito passivo notificado, pessoalmente, na mesma data.

Em razão de o valor do crédito tributário estar abaixo do limite de ajuizamento previsto na legislação estadual para a sua cobrança judicial, a Fazenda Estadual não ajuizou a respectiva Execução Fiscal.

Em 24.07.2012, a fim de regularizar sua situação junto ao Fisco, o contribuinte realiza o pagamento da dívida.

Diante desse cenário, responda aos itens a seguir.

- a) Na data em que foi realizado o pagamento, o crédito tributário estava decaído?
- b) Na data em que foi realizado o pagamento, o crédito tributário estava prescrito?
- c) Caso efetue o pagamento de um crédito prescrito, pode o contribuinte pleitear a restituição da quantia que foi paga?

Obs.: Responda às questões de forma fundamentada, indicando os dispositivos legais pertinentes.

QUESTÃO 52 – XIV EXAME UNIFICADO

A pessoa jurídica “X” é fabricante de telefones celulares, e nas vendas realizadas para seus adquirentes, comerciantes de tais aparelhos, efetua remessas de telefones entre diferentes Estados da federação. Em março de 2014, o Estado “Y”, ao fiscalizar uma dessas remessas, verificou que a pessoa jurídica “X” não recolheu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre tal operação e, imediatamente, apreendeu todos os telefones celulares.

Tendo em vista o caso apresentado, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) O Estado “Y” agiu corretamente ao apreender as mercadorias?
- b) Será aplicável a alíquota interna ou a interestadual à operação, realizada pela pessoa jurídica “X”, de remessa de aparelhos celulares a consumidor final localizado em outro Estado, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS?

Obs.: A mera citação ou transcrição do artigo ou súmula não pontua.

QUESTÃO 53 – XIV EXAME UNIFICADO

A pessoa jurídica Bom Porto S/A, domiciliada no Município A prestou serviços portuários no Município B, onde se localiza o Porto

de Ferro. A pessoa jurídica não realizou o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e os dois Municípios lavraram auto de infração visando à cobrança do ISS.

- a) Qual o Município competente para a cobrança do ISS? Justifique.
- b) Qual a medida judicial mais adequada para dirimir, na hipótese, o conflito de competência tributária relativo ao ISS?

Obs.: A mera citação ou transcrição do artigo não pontua.

QUESTÃO 54 – XIV EXAME UNIFICADO

No início do ano de 2014, João da Silva realizou a importação de um carro de procedência alemã para uso próprio. Na entrada da mercadoria importada do exterior, João da Silva foi surpreendido pela notificação de lançamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, cobrado pelo Estado da Federação em que João reside, que, por sua vez, desde 2006 conta com lei estadual prevendo a incidência do imposto nesta hipótese. O desembaraço ocorrerá nesse mesmo Estado, que determinou a retenção do carro até que o ICMS viesse a ser pago. João da Silva apresenta, então, impugnação ao lançamento, alegando que não é contribuinte do imposto e que, portanto, a cobrança é inconstitucional.

Sobre o assunto, responda aos itens a seguir.

- a) A alegação de João da Silva está correta? Fundamente.
- b) O Estado pode reter a mercadoria? Fundamente.

QUESTÃO 55 – XV EXAME UNIFICADO

Determinado Estado da Federação brasileira publicou, em 19.12.2013, a Lei Estadual 5.678, a qual introduziu algumas alterações na Lei Estadual 1.234, que dispõe sobre a cobrança do Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação – ITCMD no âmbito daquele Estado. A nova Lei Estadual 5.678 passou a vigorar na data da sua

publicação, conforme expressamente previsto em um dos seus artigos. Dentre as alterações introduzidas pelo novo diploma legal, houve (i) o aumento da alíquota do imposto; e (ii) a redução da penalidade incidente para o caso de atraso no pagamento. João, dono de vários veículos, doou um veículo a Pedro em 02.12.2013, mas, na qualidade de contribuinte, deixou de efetuar o pagamento do imposto no prazo legal, que venceu em 17.12.2013, antes do advento da Lei Estadual 5.678. Posteriormente, em 03.01.2014, João doou outro veículo a Tiago.

Tendo em vista o exposto, responda aos itens a seguir.

- a) João faz jus à penalidade reduzida, introduzida pela Lei Estadual 5.678, para o pagamento do crédito tributário inadimplido incidente sobre a doação efetuada a Pedro?
- b) Na doação efetuada a Tiago, incide a alíquota do imposto majorada pela Lei Estadual 5.678?

QUESTÃO 56 – XV EXAME UNIFICADO

Em 2001, Caio Silva comprou um imóvel de Tício Santos. Em 2002, a Fazenda Nacional inscreveu em dívida ativa créditos decorrentes do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, que em 2000 haviam sido objeto de constituição definitiva contra Tício. Em 2007, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal visando à cobrança dos créditos de IRPF.

Após Tício ser citado sem garantir o Juízo, a Fazenda Nacional requereu a penhora do imóvel vendido a Caio, visto que a alienação foi realizada quando o fato gerador do IRPF já tinha ocorrido, o que a tornaria, segundo a Fazenda Nacional, fraudulenta.

- a) Está correto o entendimento da Fazenda Nacional de que a alienação foi fraudulenta?
- b) Qual o argumento que Tício, contribuinte do IRPF, poderia alegar em sua defesa, em eventual oposição de embargos à execução?

QUESTÃO 57 – XV EXAME UNIFICADO

O Município Z ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica X para cobrança de valores de Imposto sobre Prestação de Serviços (ISS), referentes ao ano-calendário 2013, recolhidos a menor. Verificando a improcedência de referida cobrança, o contribuinte apresenta embargos à execução, nos quais se insurge contra a pretensão da Fazenda e requer que lhe seja garantida a obtenção de certidão negativa de débitos. Em garantia da execução, o contribuinte realiza o depósito do montante integral do tributo cobrado. Os embargos à execução são julgados procedentes em primeira instância e, em face da sentença, a Fazenda interpõe apelação, que aguarda julgamento pelo Tribunal.

Diante do caso apresentado, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) O contribuinte tem direito à certidão negativa de débitos (ou à certidão positiva com efeitos de negativa) antes da sentença de primeira instância que lhe foi favorável?
- b) O contribuinte, durante o curso da apelação interposta pela Fazenda, tem direito à mesma certidão?

QUESTÃO 58 – XV EXAME UNIFICADO

Joana é proprietária de um apartamento localizado no Município X. Em 05 de janeiro de 2014, o Município X enviou a Joana o carnê de IPTU referente ao ano de 2014. A data limite para pagamento ocorreu em 31 de janeiro. Como Joana não realizou o pagamento e não apresentou impugnação, em 10 de março de 2014 o Município X inscreveu o crédito em dívida ativa. Em 30 de abril de 2014, o Município X ajuizou execução fiscal cobrando o IPTU. Joana ofereceu, para garantir o juízo, o próprio imóvel, sendo a garantia aceita pelo Município X.

Sobre a hipótese descrita, responda aos itens a seguir.

- a) Quando ocorreu a constituição do crédito tributário, considerando-se a jurisprudência do STJ? Justifique.
- b) Joana pode substituir a penhora feita por depósito em dinheiro? Justifique.

QUESTÃO 59 – XVI EXAME UNIFICADO

O Município XYZ resolveu instituir, por meio de lei específica, um tributo que tem como fato gerador a valorização imobiliária decorrente de obra realizada pelo Estado Alfa em seu território, sendo o contribuinte o proprietário do imóvel valorizado e a base de cálculo, independentemente da valorização experimentada por cada imóvel, o custo da obra estatal.

Sobre a hipótese descrita, responda aos itens a seguir.

- a) Qual seria a espécie tributária que o Município XYZ pretende instituir? Aponte o dispositivo constitucional aplicável.
- b) Na hipótese descrita, o Município XYZ é competente para instituir tal tributo?
- c) A base de cálculo do tributo está correta?

QUESTÃO 60 – XVI EXAME UNIFICADO

Em 2008, constou na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) da pessoa jurídica AB&C Participações Ltda. que era devido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No entanto, a AB&C Participações Ltda. não efetuou o recolhimento antes do vencimento do tributo. Em 2009, antes do início de qualquer fiscalização por parte da Fazenda Nacional, a AB&C Participações Ltda. efetuou o recolhimento daquele montante da COFINS informado no ano anterior na DCTF, sem, no entanto, o acréscimo da multa de mora, em razão da ocorrência da denúncia

espontânea.

Por não concordar com a AB&C Participações Ltda., a Fazenda Nacional lavrou auto de infração cobrando o valor integral do tributo (deduzido do montante já recolhido), sendo a AB&C Participações Ltda. intimada para pagar ou apresentar defesa.

Sobre o caso, responda aos itens a seguir.

- a) Está correto o entendimento da pessoa jurídica AB&C Participações Ltda. sobre a ocorrência da denúncia espontânea?
- b) Caso a pessoa jurídica proponha ação anulatória buscando desconstituir o auto de infração, poderá apresentar, simultaneamente, defesa no processo administrativo?

QUESTÃO 61 – XVI EXAME UNIFICADO

O deputado federal Y apresentou dois projetos de lei ordinária federal. O primeiro pretende alterar o Código Tributário Nacional no que se refere aos artigos que tratam de responsabilidade tributária (obrigação tributária), e o segundo pretende instituir uma taxa de licenciamento de importação, cuja base de cálculo é o valor aduaneiro do produto importado.

- a) Analise a constitucionalidade do primeiro projeto de lei apresentado pelo deputado.
- b) A taxa a ser instituída é constitucional?

QUESTÃO 62 – XVI EXAME UNIFICADO

O Município “M” notificou a pessoa jurídica “Z”, fabricante de peças automotivas, para que efetuasse o pagamento do Imposto sobre a Transmissão *Inter Vivos* de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a transmissão de bens decorrentes de processo de incorporação de outra pessoa jurídica. Inconformada com a cobrança, a pessoa jurídica “Z” decide apresentar impugnação.

Verificando a inexistência de outros débitos, após a regular apresentação da impugnação, a pessoa jurídica “Z” requer a emissão da certidão de regularidade fiscal (no caso, Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa), que lhe é negada, sob o argumento de que, para a sua emissão, seria necessário o depósito do montante integral do crédito cobrado.

Diante desta situação, responda aos itens a seguir.

- a) Está correto o lançamento do imposto pelo Município “M”?
- b) A pessoa jurídica “Z” tem direito à certidão de regularidade fiscal?

QUESTÃO 63 – XVII EXAME UNIFICADO

No dia 23 de dezembro de 2013, a União, atendendo aos limites da disciplina legal do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) publicou decreto aumentando a alíquota para automóveis, a partir da data de sua publicação. Em vista desse aumento, a pessoa jurídica X decide impugná-lo, tendo como base a violação do princípio da anterioridade nonagesimal/noventena.

Com fundamento no princípio da legalidade tributária, a pessoa jurídica entende, ainda, que o aumento da alíquota não poderia ter sido veiculado por meio de decreto, considerando o disposto no art. 150, I, da Constituição, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça.

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir.

- a) Prospera o argumento da pessoa jurídica relativo ao princípio da anterioridade nonagesimal/noventena?
- b) Prospera o argumento da pessoa jurídica relativo ao princípio da legalidade tributária?

QUESTÃO 64 – XVII EXAME UNIFICADO

A União ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica ABC

Águas Ltda. e de João, diretor da pessoa jurídica, cujo nome estava indicado na certidão de dívida ativa (CDA), para a cobrança de valores relativos ao Imposto sobre a Renda (IR), supostamente devidos. De acordo com a União, a atribuição de responsabilidade ao Diretor estaria correta, tendo em vista o inadimplemento do tributo pela pessoa jurídica.

Diante desse caso, responda aos itens a seguir.

- a) A inclusão de João na CDA como responsável tributário, em razão do mero inadimplemento do tributo pela pessoa jurídica ABC Águas Ltda., está correta?
- b) Caso a execução fiscal tivesse sido ajuizada somente em face da pessoa jurídica, a União teria que demonstrar algum requisito para a inclusão do Diretor no polo passivo da execução fiscal?

QUESTÃO 65 – XVII EXAME UNIFICADO

O Estado X instituiu, em 2010, por meio de lei, taxa pelo serviço de prevenção e extinção de incêndio prestado ou colocado à disposição do contribuinte. A referida lei definiu o contribuinte como o proprietário de unidade imobiliária, residencial ou não residencial, à qual o serviço estaria dirigido, bem como determinou que o valor da taxa seria calculado com base no tamanho da unidade imobiliária. Nada se dispôs na lei sobre eventuais responsáveis tributários pelo pagamento da taxa. João, na qualidade de proprietário, aluga, desde 2011, seu imóvel, situado no referido Estado X, para Pedro.

No contrato de locação celebrado entre as partes, o qual foi devidamente registrado no Registro de Imóveis, estabeleceu-se, em uma das cláusulas, que a responsabilidade pelo pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio seria exclusivamente de Pedro, isentando João de qualquer obrigação sobre ela.

Tendo em vista o exposto, responda aos itens a seguir.

- a) É constitucional o cálculo do valor da taxa de prevenção e extinção

de incêndio tendo como parâmetro um dos elementos que compõem a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU?

b) Considerando que nem João nem Pedro recolheram a taxa de prevenção e extinção de incêndio relativas aos exercícios de 2012 e 2013, bem como o que consta no contrato de locação celebrado entre eles e registrado no Registro de Imóveis, em face de quem o Estado X deve efetuar a cobrança dos exercícios não pagos?

QUESTÃO 66 – XVII EXAME UNIFICADO

O Município “X” notificou a instituição de educação “Y” para que realizasse o pagamento do valor correspondente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao imóvel de sua propriedade, alugado a terceiros, por meio do envio de carnê para pagamento do tributo pelos correios.

Apesar de constatar que o valor dos aluguéis é aplicado no desenvolvimento das atividades essenciais da instituição, o Município entendeu que a imunidade conferida pelo texto constitucional somente se aplica quando o imóvel é usado como sede da instituição.

Com base no caso descrito, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) A cobrança do IPTU, realizada pelo Município “X”, está correta?
- b) De acordo com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, é válida a notificação da instituição por meio dos Correios?

QUESTÃO 67 – XVIII EXAME UNIFICADO

O Estado Alfa instituiu duas contribuições mensais compulsórias devidas por todos os seus servidores. A primeira, com alíquota de 10% sobre a remuneração mensal de cada servidor, destina-se ao custeio do regime previdenciário próprio, mantido pelo Estado Alfa. A segunda, no valor equivalente a 1/60 (um sessenta avos) da

remuneração mensal de cada servidor, destina-se ao custeio da assistência à saúde do funcionalismo público daquele Estado.

Sobre a situação apresentada, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado Alfa para o custeio do regime previdenciário próprio de seus servidores?
- b) É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado Alfa para a assistência à saúde de seus servidores?

QUESTÃO 68 – XVIII EXAME UNIFICADO

Caio tem 10 anos e seu pai o presenteou com uma casa de praia no litoral do Município Y. No entanto, Caio não realizou o pagamento do carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel de sua propriedade.

Caio, representado por seu pai, apresentou uma impugnação ao lançamento do crédito, alegando que Caio não tem capacidade civil e que, portanto, não pode ser contribuinte do IPTU.

O Município Y negou provimento à impugnação e Caio apresentou recurso voluntário ao Conselho Municipal de Contribuintes, que foi inadmitido por inexistência de depósito recursal prévio, conforme exigência da legislação municipal.

A partir da questão proposta, responda aos itens a seguir.

- a) Caio pode ser considerado contribuinte do imposto? Fundamente.
- b) É constitucional a exigência do depósito como condição para o recurso administrativo, conforme decisão do Conselho Municipal? Justifique.

QUESTÃO 69 – XVIII EXAME UNIFICADO

A União ajuizou execução fiscal em face de pessoa jurídica ABC, prestadora de serviços de telecomunicações, para cobrança de taxa

devida em razão da fiscalização de instalação e manutenção de orelhões, tendo como base de cálculo o valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica.

Inconformado com a cobrança, a contribuinte, certa de que seu pleito será bem-sucedido, pretende apresentar embargos à execução, sem o oferecimento de garantia, com base no art. 739-A do CPC.

Tendo em vista o caso em questão, responda aos itens a seguir.

- a) É possível a instituição da base de cálculo no valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica para a taxa em questão?
- b) É possível, segundo a legislação específica, a apresentação de embargos à execução fiscal sem o oferecimento de garantia, conforme pretendido pelo contribuinte?

QUESTÃO 70 – XVIII EXAME UNIFICADO

Em dezembro de 2014, a pessoa jurídica W teve a falência decretada durante o seu processo de recuperação judicial, iniciado no mesmo ano, em virtude da não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo previsto em lei.

Considerando a ordem a ser observada na classificação dos créditos na falência, a União alegou que os créditos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devidos pela contribuinte, relativos aos exercícios de 2011 e 2012, deveriam ser pagos antes dos créditos extraconcursais.

Diante disso, responda aos itens a seguir.

- a) Está correto o argumento da União?
- b) Após a decretação da falência, a cobrança judicial do crédito tributário pode prosseguir por meio de execução fiscal?

QUESTÃO 71 – XIX EXAME UNIFICADO

A pessoa jurídica Theta S.A. declarou e não pagou o débito referente

à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Meses depois, como iria participar de uma licitação, precisava apresentar certidão de regularidade fiscal, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização por parte da União, a pessoa jurídica Theta S.A. realizou o pagamento do tributo, excluindo, no entanto, a multa moratória. Sobre a hipótese descrita, responda aos itens a seguir.

- a) Está correta a exclusão da multa moratória? Fundamente.
- b) O contribuinte tem direito à certidão negativa de débitos? Justifique.

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 72 – XIX EXAME UNIFICADO

Por vários anos, Alberto trabalhou na pessoa jurídica Alfa Ltda. Quando da rescisão de seu contrato de trabalho, a pessoa jurídica pagou a Alberto a remuneração proporcional aos dias trabalhados no curso do mês em que se deu a rescisão; e o valor equivalente a 3 (três) meses de salário, como gratificação voluntária (mera liberalidade) pelos anos de bons serviços prestados pelo empregado.

Com base no caso apresentado, responda aos itens a seguir.

- a) Incide o Imposto sobre a Renda (IR) sobre a remuneração proporcional aos dias trabalhados por Alberto?
- b) Incide o Imposto sobre a Renda (IR) sobre a gratificação voluntária paga a Alberto?

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 73 – XIX EXAME UNIFICADO

Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica Beta adquiriu o estabelecimento comercial da pessoa jurídica Delta e continuou a explorar a atividade sob outra razão social. Ao adquirir o estabelecimento, a pessoa jurídica Beta não elegeu domicílio tributário. Três meses após a alienação, a pessoa jurídica Delta iniciou nova atividade no mesmo ramo de comércio. Em janeiro de 2015, a pessoa jurídica Beta foi notificada pelo Estado de Minas Gerais para pagamento de créditos de ICMS relativos ao estabelecimento adquirido e referentes ao ano de 2013, uma vez que, de acordo com o Estado de Minas Gerais, a responsabilidade da pessoa jurídica Beta quanto a tais créditos seria integral.

Diante disso, responda aos itens a seguir.

- a) É correto o entendimento do Estado de Minas Gerais no sentido de que a responsabilidade da pessoa jurídica Beta é integral?
- b) Diante da falta de eleição de domicílio tributário pela pessoa jurídica Beta, qual(is) local(is) deve(m) ser indicado(s) pela administração tributária para a notificação?

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 74 – XIX EXAME UNIFICADO

Em dezembro de 2014, o Município de Macaé-RJ editou a Lei 1.234 estendendo o prazo para a cobrança judicial dos créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de cinco para seis anos. O mesmo Município ajuizou, em 2015, execução fiscal em face da pessoa jurídica Ômega, para a cobrança de créditos IPTU não pagos. Os valores desses créditos sofreram correção monetária por ato do Poder Executivo em percentual superior ao índice oficial.

Diante disso, responda aos itens a seguir.

- a) O Município de Macaé-RJ agiu corretamente ao editar a Lei 1.234?

b) É correta a atualização monetária do IPTU em percentual superior aos índices oficiais por ato do Poder Executivo?

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 75 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO PORTO VELHO (RO)

A pessoa física X ajuizou ação de indenização por danos morais em face da pessoa jurídica W Ltda., em razão da inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. A pessoa jurídica foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). A União, ao tomar ciência da condenação, lavrou auto de infração visando à cobrança de imposto sobre a renda da pessoa física, incidente sobre a indenização recebida. A pessoa física X apresenta impugnação ao auto de infração, que está pendente de julgamento.

Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir.

a) A indenização recebida pela pessoa física X está sujeita ao imposto sobre a renda? Fundamente.

b) Na hipótese, a União poderá negar certidão de regularidade fiscal ao contribuinte?

QUESTÃO 76 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO PORTO VELHO (RO)

O Estado X ajuizou em face da pessoa jurídica W execução fiscal visando à cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre (i) serviço de transmissão de televisão a cabo, realizada de forma onerosa pela pessoa jurídica; e (ii) serviço de provedor de acesso à Internet. Após penhora de bem imóvel, a pessoa jurídica opôs embargos à execução. Posteriormente, a pessoa jurídica requereu a substituição da penhora

do imóvel por fiança bancária. O Estado X se manifestou contrariamente à substituição e o juiz indeferiu o pedido.

a) O ICMS incide sobre os serviços acima? Fundamente.

b) Está correta a decisão do juiz? Fundamente.

QUESTÃO 77 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO PORTO VELHO (RO)

O Município M ajuizou execução fiscal para a cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do contribuinte Z. A cobrança foi embasada na Lei 1.234, que determinou alíquotas diferentes para o IPTU em razão da data de construção do imóvel. Citado, o contribuinte Z, certo de que a cobrança é manifestamente infundada, imediatamente apresenta embargos à execução, antes de qualquer garantia ao Juízo.

Diante disso, responda aos itens a seguir.

a) Está correta a cobrança feita pelo Município M?

b) Os embargos à execução podem ser admitidos?

QUESTÃO 78 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO PORTO VELHO (RO)

O Estado X estabeleceu alíquotas diferenciadas de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), entre veículos nacionais e importados. Segundo a legislação estadual, a alíquota dos veículos importados será superior à dos veículos nacionais. Caio, proprietário de um automóvel importado, ajuizou ação questionando a diferença entre as alíquotas. No entanto, o juiz de 1.^a instância determinou a realização do depósito integral do montante discutido, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, por entender que o depósito é requisito de admissibilidade de ação judicial.

Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) O contribuinte tem razão quanto ao questionamento da diferença de alíquotas?
- b) Ao determinar a realização do depósito, o juiz está correto?

QUESTÃO 79 – XX EXAME UNIFICADO

Em 2015, a pessoa jurídica “X” verificou a existência de débito de Imposto sobre a Renda (IRPJ) não declarado, referente ao ano calendário de 2012. Antes do início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização, realizou o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora. Ao constatar o pagamento, a União notificou a contribuinte para que pagasse multa sancionatória incidente sobre o tributo pago extemporaneamente. Adicionalmente, efetuou o lançamento do IRPJ referente ao ano calendário 2008, que também não havia sido declarado nem pago pela contribuinte.

Diante disso, responda aos itens a seguir.

- a) Está correta a cobrança da multa?
- b) É correta a cobrança do IRPJ referente ao ano calendário 2008?

QUESTÃO 80 – XX EXAME UNIFICADO

Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica XYZ Ltda., com sede no Município “A”, prestou serviço de decoração e jardinagem no Município “C” e não recolheu o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). No entanto, em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos dois entes tributantes – pelo município “A” e pelo município “C”.

Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) A qual município o ISS é devido?
- b) Caso o contribuinte ajuíze ação consignatória com o depósito do montante integral, visando solucionar o conflito de competência entre os municípios “A” e “C”, os municípios poderão ajuizar execução

fiscal visando à cobrança de ISS?

QUESTÃO 81 – XX EXAME UNIFICADO

Em dezembro de 2014, o Município “M” publicou lei ordinária por meio da qual instituiu contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A referida lei, que entrou em vigor na data de sua publicação, fixou os respectivos contribuintes e a base de cálculo aplicável. Ao receber a cobrança da nova contribuição, João decide impugná-la sob o argumento de que a cobrança é inconstitucional, já que (i) compete exclusivamente à União instituir contribuições e (ii) cabe à lei complementar estabelecer as bases de cálculo e os contribuintes dos tributos.

Diante disso, responda:

- a) Está correto o argumento de João quanto à competência para a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública?
- b) Está correto o argumento de João quanto à necessidade de lei complementar para o estabelecimento da base de cálculo e dos contribuintes desta espécie de contribuição?

QUESTÃO 82 – XX EXAME UNIFICADO

Certa empresa de produtos químicos recebeu notificação do Município “X” para que pagasse um imposto por ele instituído no ano de 2013. O fato gerador do imposto era o ato de poluir o meio ambiente e a sua base de cálculo era a quantidade de lixo produzida.

Com base em tais fatos, responda aos itens a seguir.

- a) Pode o fato gerador de um imposto ser o ato de poluir o meio ambiente?
- b) O Município “X” teria competência constitucional para criar um novo imposto?

QUESTÃO 83 – XXI EXAME UNIFICADO

Em 01 de novembro de 2016, a União, por meio de lei ordinária, instituiu empréstimo compulsório para custear despesas advindas de uma forte tempestade que assolou a Região Sul do Brasil. Naquele diploma legal, ficou previsto que o empréstimo compulsório passaria a ser exigido já no mês de dezembro de 2016.

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir.

- a) No caso em exame, o empréstimo compulsório poderia ter sido instituído por lei ordinária?
- b) Empréstimo compulsório, instituído para o custeio de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, pode ser exigido já no mês seguinte à sua instituição?

QUESTÃO 84 – XXI EXAME UNIFICADO

Em abril de 2016, o Estado X publicou lei disciplinando as custas judiciais, concedendo isenção a todos os servidores do Poder Judiciário.

Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) As custas judiciais estão sujeitas às limitações ao poder de tributar?
- b) É legítima a isenção de custas judiciais concedida aos servidores da justiça?

QUESTÃO 85 – XXI EXAME UNIFICADO

O Estado Alfa editou duas leis relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. A primeira, com o objetivo de fomentar a indústria de uma determinada área e atrair contribuintes de outros Estados da Federação, concedeu redução da base de cálculo do ICMS para pessoas jurídicas que instalassem indústrias dentro daquela região, sem a deliberação dos outros Estados.

A segunda, de abril de 2016, reduziu o prazo para recolhimento do

ICMS.

Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) É legítima a redução de base de cálculo concedida pela primeira lei?
- b) A segunda lei está sujeita ao princípio da anterioridade?

QUESTÃO 86 – XXI EXAME UNIFICADO

O governo federal, com o objetivo de proteger a indústria nacional fabricante de aço, publicou, no ano de 2015, um decreto que aumentava de 15 para 20% a alíquota do imposto sobre a importação de produtos siderúrgicos, atendidos as condições e os limites estabelecidos em lei formal. O decreto previu que o aumento já valeria para aquele mesmo exercício financeiro.

Considerando a hipótese acima, responda aos itens a seguir.

- a) A majoração da alíquota do imposto de importação poderia se dar por meio de um ato do Poder Executivo?
- b) O governo federal agiu legalmente ao exigir a alíquota majorada do imposto de importação no mesmo exercício financeiro?

QUESTÃO 87 – XXII EXAME UNIFICADO

Em março de 2016, a União ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica Alfa para a cobrança de créditos de Imposto sobre a Renda (IRPJ), referentes aos anos-calendários de 2013 e 2014. De acordo com o exequente, em que pese a declaração dos créditos relativos aos anos-calendários em questão, a contribuinte apenas efetuou o pagamento parcial dos tributos, sendo, dessa forma, devido o pagamento da diferença inadimplida.

Devidamente cientificada da demanda, a contribuinte, após o oferecimento de garantia, apresentou embargos à execução, objetivando sua extinção, uma vez que a União não instruiu a petição

inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, inviabilizando a ampla defesa. Alegou a contribuinte, ainda, que o crédito não poderia ser objeto de execução, eis que não foi realizado, por parte da Administração Fazendária, o prévio lançamento por meio de processo administrativo regularmente instaurado.

Em vista das alegações da pessoa jurídica Alfa, responda aos itens a seguir.

- a) A execução fiscal deve ser extinta em virtude da falta do demonstrativo de cálculo do débito?
- b) A ausência de prévio lançamento por meio de processo administrativo regularmente instaurado inviabiliza a execução do crédito?

QUESTÃO 88 – XXII EXAME UNIFICADO

Em 2015, devido a uma grande enchente que assolou o município X, foi aprovada uma lei que reabria, por um ano, o prazo de pagamento do IPTU já vencido dos contribuintes proprietários de imóveis localizados nas áreas atingidas pela enchente.

Com base nessa situação, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o nome do instituto tributário utilizado para ajudar os contribuintes das áreas mais atingidas pela enchente? Aponte o seu dispositivo legal.
- b) A lei poderia ter delimitado a aplicação desse instituto a apenas um conjunto de sujeitos passivos, como fez neste caso, aplicando-o somente aos contribuintes das áreas mais atingidas?

QUESTÃO 89 – XXII EXAME UNIFICADO

A pessoa jurídica A realizou a importação de peças para utilização no processo de fabricação de equipamentos eletrônicos. Diante da constatação de que a contribuinte não havia recolhido o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a liberação da:

mercadorias importadas foi condicionada ao pagamento do referido tributo, tendo, ainda, sido determinada a interdição do estabelecimento da pessoa jurídica A.

Diante desse panorama, responda aos itens a seguir.

- a) A cobrança do ICMS pelo Fisco está correta?
- b) A interdição do estabelecimento realizada pelo Fisco está correta?

QUESTÃO 90 – XXII EXAME UNIFICADO

A União publicou lei ordinária estabelecendo regime jurídico único de arrecadação dos tributos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para microempresas e empresas de pequeno porte, e determinando a adesão obrigatória dos contribuintes que se enquadrassem nos requisitos legalmente previstos. Ao tomar conhecimento dessa nova lei, a pessoa jurídica B, microempresa, decidiu questionar a obrigatoriedade de sua adesão ao novo regime de recolhimento de tributos, bem como a imposição de tal adesão por lei ordinária. Considerando os fatos narrados acima, responda aos itens a seguir.

- a) A obrigatoriedade de adesão da pessoa jurídica B ao novo regime jurídico instituído pela lei ordinária é constitucional?
- b) É possível o estabelecimento das novas regras por meio de lei ordinária?

QUESTÃO 91 – XXIII EXAME UNIFICADO

A União ajuizou, em 2016, execução fiscal em face da pessoa jurídica “X”. Estavam em cobrança dois débitos distintos: um deles era relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vencido no final do mês de março de 2009, regularmente declarado pelo contribuinte no mesmo mês, mas que não foi recolhido; o outro era relativo à multa pelo descumprimento, em 2014, de obrigação acessória do IPI.

Regularmente citada, a pessoa jurídica “X” alegou a ocorrência de prescrição do débito relativo ao ano de 2009. Para tanto, sustentou que foi ultrapassado o prazo de cinco anos para a exigência do imposto – pois tal prazo tivera início com o vencimento do tributo, já que o montante devido foi oportunamente declarado. No que se refere à multa, sustentou a inexigibilidade da obrigação, porquanto referente a uma operação específica que, no momento de sua realização, estava coberta por isenção concedida pela própria União (isenção esta que efetivamente existia em 2014).

Com base no caso relatado, responda aos itens a seguir.

- a) Conforme sustentado pela contribuinte, operou-se a prescrição no presente caso?
- b) Está correto o argumento da pessoa jurídica “X” quanto à improcedência da multa?

QUESTÃO 92 – XXIII EXAME UNIFICADO

O Município Beta instituiu, por meio de lei municipal, uma taxa de limpeza cujo fato gerador é, exclusivamente, o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar de imóveis no município. A lei também determinou a utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa.

Diante desse quadro fático, responda aos itens a seguir.

- a) O fato gerador da taxa determinado pela lei municipal violou a Constituição da República?
- b) A base de cálculo adotada pelo Município Beta violou a regra constitucional de que taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos?

QUESTÃO 93 – XXIII EXAME UNIFICADO

Em 12 de novembro de 2016, o Estado “X” publicou lei para modificar, para além da inflação, a tabela que estabelece os valores

venais de veículos – base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O fato gerador do tributo, naquela unidade da Federação, ocorre em 1.º de janeiro de cada ano. Em janeiro de 2017, a autoridade administrativa efetuou o lançamento do tributo, já com base nos valores modificados.

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir.

- a) O Estado “X” pode realizar o lançamento do IPVA, em janeiro de 2017, já com a nova base de cálculo instituída em novembro de 2016?
- b) Se a nova lei, publicada em 12 de novembro de 2016, aumentasse a alíquota incidente sobre a base de cálculo, a majoração passaria a ser exigível para os fatos geradores ocorridos a partir de qual exercício (inclusive)?

QUESTÃO 94 – XXIII EXAME UNIFICADO

A sociedade empresária “X” foi autuada pelo Estado “Z” em 35% do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços (ICMS) devido, em razão do preenchimento incorreto de determinado documento fiscal. Observadas diversas inconsistências no auto de infração, os advogados da sociedade impugnaram administrativamente a autuação.

No curso do processo, nova lei foi publicada, estabelecendo nova penalidade para os casos de preenchimento incorreto de documentos fiscais, agora no percentual de 15% do valor do imposto.

Ocorre que, embora pendente a decisão da impugnação, o fisco inscreveu a sociedade em dívida ativa, assinalando, no termo de inscrição, a penalidade anterior, de 35%.

Com base nessas informações e de acordo com o disposto no CTN, responda aos itens a seguir.

- a) O fisco poderia ter inscrito o contribuinte em dívida ativa naquele momento? Justifique.

b) O percentual da multa assinalado no ato de inscrição está correto? Fundamente.

QUESTÃO 95 – XXIV EXAME UNIFICADO

O Estado “X” instituiu um adicional de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que tem como fato gerador a propriedade de veículos em mau estado de conservação e/ou que possuam duas ou mais multas não pagas.

Caio, proprietário de veículo automotor em mau estado de conservação e com cinco multas não pagas, é notificado da cobrança do adicional do tributo por meio de auto de infração. Como não apresentou defesa e não pagou o tributo, o Estado “X” ajuíza execução fiscal. Caio, no entanto, não possui meios para garantir a execução fiscal e opor embargos à execução, mas possui todos os documentos que comprovam sua defesa.

Com base na hipótese formulada, responda aos itens a seguir.

- a) O adicional de IPVA instituído pelo Estado “X” é devido?
- b) Qual seria o meio adequado para a defesa de Caio, nos próprios autos da execução fiscal, conforme o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores?

QUESTÃO 96 – XXIV EXAME UNIFICADO

A União publicou, no Diário Oficial de 30 de junho de 2017, decreto que majorou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). No decreto, foi estipulado que a alíquota majorada já seria válida para fatos geradores ocorridos a partir do mês seguinte.

Tendo em vista a anterioridade nonagesimal e a anterioridade do exercício financeiro, responda aos itens a seguir.

- a) É válida a exigência da alíquota majorada no mês seguinte à publicação do decreto?

b) Se, em vez de majorar a alíquota, o decreto alterasse apenas o prazo de recolhimento da obrigação tributária, seria válida a sua exigência a partir do mês seguinte ao da publicação?

QUESTÃO 97 – XXIV EXAME UNIFICADO

Em 2017, Carlos, após viagem ao exterior, decidiu importar do Japão, para uso próprio, um veículo automotor de última geração, lançamento do mercado japonês.

Considerando que Carlos é o consumidor final do veículo, responda aos itens a seguir.

- a) Na importação do referido veículo por Carlos, é devido o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)?
- b) Considerando que, em 2003, o estado onde Carlos é domiciliado editou uma lei instituindo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação realizada por consumidor final, é devido o ICMS na importação do veículo?

QUESTÃO 98 – XXIV EXAME UNIFICADO

A Pessoa Jurídica XYZ, notificada pela União para que proceda ao recolhimento de crédito fiscal, tenta colocar seus bens em nome de terceiros.

Ciente do fato, a União requereu medida cautelar fiscal. Dias depois do deferimento da referida medida, veio a ser definitivamente constituído o crédito tributário da União contra a Pessoa Jurídica XYZ, e, noventa (90) dias após a constituição definitiva do crédito, a União propôs a execução fiscal.

Diante de tal quadro fático, responda aos itens a seguir.

- a) Foi correto o procedimento da União ao ajuizar a medida cautelar fiscal antes de definitivamente constituído o crédito tributário?
- b) Foi adequado o prazo dentro do qual a União ajuizou a execução

fiscal?

**QUESTÃO 99 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICADO EM POB
ALEGRE**

No Estado “X”, até o ano de 2016, o mês para pagamento de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) era março, e o valor poderia ser dividido em, no máximo, três parcelas. Em janeiro de 2017, foi editada a Lei nº 123 alterando tal sistemática. A nova lei estabeleceu o pagamento para o mês de fevereiro do mesmo exercício, sem a possibilidade de parcelamento.

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir.

- a) A alteração do prazo para pagamento poderia se dar por meio de decreto?
- b) A Lei nº 123 precisa respeitar o princípio da anterioridade do exercício financeiro e o da anterioridade nonagesimal?

**QUESTÃO 100 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICADO EM POB
ALEGRE**

A pessoa jurídica “Z” fez uma Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e não pagou o débito referente ao Imposto sobre a Renda (IRPJ). Meses depois, com o intuito de obter a regularidade fiscal necessária para celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica “Z” realizou o pagamento do tributo. Entendendo que seu pagamento se deu de forma espontânea, face a ausência de qualquer procedimento por parte do fisco, não efetuou o recolhimento da multa de mora.

Sobre a hipótese descrita, responda aos itens a seguir:

- a) A multa de mora é devida?
- b) Poderia o contribuinte recolher espontaneamente os valores devidos, acrescidos de multa e encargos legais, após o início de um procedimento de fiscalização relativo ao mesmo tributo e período de

apuração? Justifique.

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 101 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICADO EM POE ALEGRE

Mário, 16 anos, ao chegar de viagem do exterior, desacompanhado de seus responsáveis, teve sua bagagem verificada pela alfândega. Nesse momento, o representante do Fisco identificou vinte aparelhos de celular de último tipo e diversos presentes, todos excluídos do conceito de bagagem, e promoveu o lançamento do imposto de importação e de multa em nome de Mário, por irregularidade na importação das mercadorias que adentraram no país. Representado por seu pai, Mário apresentou impugnação ao lançamento do crédito, alegando que não tem capacidade civil e que, portanto, não pode ser contribuinte do imposto de importação, tendo o provimento negado pela autoridade administrativa. Certo de suas alegações, após transcorrida a primeira etapa da esfera administrativa, o representante de Mário pretende discutir em segunda instância, porém é surpreendido com a exigência, por parte da autoridade administrativa, de depósito prévio como garantia de admissibilidade do recurso.

A partir dos fatos apresentados, responda aos itens a seguir.

- a) Mário pode ser considerado contribuinte do imposto de importação? Justifique.
- b) Ressalvada a excepcionalidade da eventual ausência de bens, é possível a exigência por parte da autoridade administrativa de depósito prévio ou de outra forma de garantia como requisito de admissibilidade dos recursos na esfera administrativa?

QUESTÃO 102 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICADO EM POE ALEGRE

Eduardo arrematou em hasta pública um imóvel situado no Município Alfa, no ano de 2013. Eduardo não efetuou o pagamento referente ao IPTU do imóvel nos anos de 2014 e 2015. Em 2016, surpreende-se com a sua citação, em sede de execução fiscal, para o pagamento do imposto referente aos anos de 2012, 2014 e 2015. Em seus Embargos à Execução Fiscal alegou que não deveria pagar o imposto referente a 2012 porque arrematou o imóvel em hasta pública. Com relação aos anos de 2014 e 2015, argumentou ter alugado o imóvel a Fernando e com ele realizado contrato por meio do qual o locatário seria o responsável pelo recolhimento do IPTU.

Baseando-se na situação acima, responda aos itens a seguir.

- a) Eduardo está correto com relação ao argumento utilizado para se esquivar do pagamento do imposto referente a 2012? Justifique.
- b) Eduardo está correto com relação ao argumento de que Fernando seria o responsável pelo IPTU?

QUESTÃO 103 – XXV EXAME UNIFICADO

Antônio doou seu carro para José, que, diante disso, realizou o pagamento do Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Três anos após a quitação do imposto, José constatou equívoco no cálculo do tributo, cujo pagamento foi realizado em valor superior ao efetivamente devido. Sendo assim, ajuizou ação de repetição de indébito em face do Estado “X”, requerendo a restituição do valor principal acrescido de juros moratórios e atualização pela SELIC. Devidamente citado, o Estado “X” apresentou contestação alegando prescrição da pretensão autoral, visto que inobservado o prazo legal de dois anos para o ajuizamento da ação. Adicionalmente, defendeu que, na eventualidade de não ser acolhido seu primeiro argumento, seria incabível a cumulação de juros moratórios e taxa SELIC, tendo em vista que, no Estado “X” não há previsão, na legislação local, de incidência da taxa SELIC na

cobrança de tributos pagos em atraso.

Considerando o caso em questão, responda aos itens a seguir.

- a) O prazo prescricional de dois anos indicado pelo Estado “X” está correto?
- b) A restituição do valor principal deve ser acrescida de juros moratórios e SELIC, conforme pretende o contribuinte?

QUESTÃO 104 – XXV EXAME UNIFICADO

Antes de realizado qualquer procedimento para a constituição do crédito tributário, determinado partido político optou, em 2016, pelo parcelamento da contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), com vencimentos entre 2005 e 2009, não pagas no prazo determinado. Para tanto, nos termos da lei que instituiu o parcelamento, o partido político apresentou “confissão irrevogável e irretratável dos débitos”. No entanto, o advogado do partido político opina que este deve rescindir o parcelamento, uma vez que, independentemente da assinatura do termo de confissão de débitos, a renda dos partidos políticos é imune, e os débitos estão alcançados pela decadência.

Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir:

- a) no que se refere à imunidade dos partidos políticos, o advogado está correto?
- b) a alegação sobre a ineficácia da confissão de débitos, no que se refere aos débitos alcançados pela decadência, está correta?

QUESTÃO 105 – XXV EXAME UNIFICADO

A pessoa jurídica “X” é devedora de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa da União no valor de R\$ 1 milhão. Antes de iniciada a execução, decidiu alienar seu único imóvel, avaliado em R\$ 2 milhões, por valor muito inferior ao da avaliação. Tomando ciência do fato, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) moveu ação

anulatória do negócio jurídico, alegando fraude à execução.

Considerando os fatos narrados, responda aos itens a seguir.

- a) é correto afirmar que, não tendo sido iniciada a execução fiscal, descabe a arguição de fraude pretendida pela PFN? Justifique.
- b) mesmo que o devedor reserve bens suficientes para a garantia da dívida inscrita, a fraude à execução remanesce? Justifique.

QUESTÃO 106 – XXV EXAME UNIFICADO

A sociedade empresária Beta, no mês de março de 2017, adquiriu diversas mercadorias da distribuidora gama. Beta registrou como crédito, em sua escrita fiscal do ICMS, o valor do ICMS pago por gama na mencionada operação de compra e venda. Em abril de 2017, ao revender as mercadorias a terceiros, Beta deduziu, do ICMS a pagar nessa nova operação, o valor do crédito de ICMS relativo à operação anterior (ou seja, a venda que lhe foi feita por gama). Ocorre que, em agosto de 2017, foi declarada inidônea a nota fiscal emitida por gama, quando da venda das mercadorias a Beta. Como consequência, Beta foi autuada pelo Fisco estadual, visando à cobrança do valor por ela utilizado como crédito de ICMS decorrente da aquisição das mercadorias. Ressalta-se que foram cumpridos todos os requisitos legais para o aproveitamento desses créditos.

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir.

- a) com base em que princípio Beta realizou o aproveitamento dos créditos de ICMS?
- b) Beta poderia ter sido autuada pelo fisco estadual?

QUESTÃO 107 – XXVI EXAME UNIFICADO

João, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do Município X, informa que o Fisco Municipal cobrou Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de um imóvel que o sindicato aluga a terceiros e cujo valor é integralmente utilizado para a defesa

dos interesses dos trabalhadores sindicalizados. João o consulta, sobre a viabilidade da exigência fiscal. Na oportunidade, um dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do Município “X” (sindicato patronal) indaga se o IPTU deveria incidir sobre imóvel de propriedade deste Sindicato, nas mesmas condições.

Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir.

- a) O município está correto em cobrar o IPTU sobre o imóvel de propriedade do sindicato dos trabalhadores? Justifique.
- b) Haveria incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade do sindicato patronal? Justifique.

QUESTÃO 108 – XXVI EXAME UNIFICADO

A seguradora ABC S.A. realizou a venda de um lote dos chamados “automóveis salvados de sinistro”, isto é, automóveis que, por algum acidente (colisão, enchente etc.), perderam mais de 75% de seu valor, sendo sua propriedade transferida para a seguradora, a qual paga a correspondente indenização ao segurado. O Fisco do Estado X, alegando que a venda dos “automóveis salvados de sinistro” é uma operação de compra e venda de mercadorias, exige o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre esta operação.

Diante do caso exposto, responda aos itens a seguir.

- a) o Fisco estadual está correto em sua exigência?
- b) uma sociedade empresária que se dedicasse exclusivamente a recuperar “automóveis salvados de sinistro”, parcial ou totalmente, vendendo-os, ou suas peças avulsas, aos consumidores em geral, seria contribuinte de ICMS?

QUESTÃO 109 – XXVI EXAME UNIFICADO

Em abril de 2015, 30 dias após o falecimento de Maria, Joana, uma de suas três filhas, ajuizou ação de inventário e partilha e foi nomeada

inventariante do espólio de sua mãe, composto por dois imóveis. Em julho do mesmo ano, a alíquota do Imposto sobre a Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD) do estado “Y”, onde Maria residia e onde estavam localizados seus dois imóveis, foi alterada de 4% para 6%. O Fisco Estadual, dois anos após o ajuizamento da ação de inventário e partilha, discordando do valor dos bens declarado pela inventariante que atribuiu aos imóveis o valor venal vigente na data da abertura da sucessão, lançou o ITCMD, utilizando, como base de cálculo, os valores dos bens arbitrados na data da avaliação e a alíquota de 6%, então em vigor. A inventariante, após regularmente notificada do lançamento do tributo e sentindo-se prejudicada pela decisão desfavorável do Fisco Estadual, decidiu impugnar administrativamente o lançamento do tributo.

A partir dos fatos apresentados, responda aos itens a seguir.

- a) A atitude do Fisco em cobrar o ITCMD com base na nova alíquota de 6% está correta? Fundamente.
- b) Sobre a base de cálculo, assiste razão à inventariante?

QUESTÃO 110 – XXVII EXAME UNIFICADO

O Município “X” instituiu, por uma mesma lei ordinária municipal datada de junho de 2017, ISS sobre a locação de automóveis realizada em seu território, bem como ISS sobre serviços de execução de tatuagens, *piercings* e congêneres. Em razão dessa lei, em junho de 2018, uma locadora de veículos foi autuada pelo fisco municipal por não estar declarando nem efetuando o recolhimento do referido tributo. Por sua vez, também em junho de 2018, uma loja que faz tatuagens foi autuada pelo não recolhimento do tributo, mas judicializou a questão e alegou que somente por lei complementar municipal poderia o ISS incidir sobre esse serviço.

Diante desse quadro, responda aos itens a seguir.

- a) A autuação feita pelo Fisco municipal contra a locadora de

automóveis está correta?

b) O Município X poderia valer-se dessa lei ordinária municipal para instituir fato gerador de ISS sobre prestação de serviços de tatuagem?

QUESTÃO 111 – XXVII EXAME UNIFICADO

Uma sociedade empresária ABC Ltda. explora a atividade empresarial de montagem de estruturas de metal para shows e eventos, exercendo suas atividades principalmente no Município “X”, onde está sediada. Excepcionalmente, tal sociedade foi contratada para montar o palco de um único show no Município “Y”, executando ali o serviço. Quanto ao serviço prestado em caráter excepcional no Município “Y”, esse ente federado pretende cobrar o ISS.

Diante desse quadro, responda aos itens a seguir.

a) Está correta a exigência do Município “Y”? Justifique.

b) Caso ambos os Municípios resolvam cobrar ISS pelo serviço prestado, qual seria a medida judicial típica e mais adequada, nos termos da legislação, para evitar que o contribuinte pague o imposto em duplicidade?

QUESTÃO 112 – XXVII EXAME UNIFICADO

Uma fábrica montadora de automóveis recolheu, em lugar de uma concessionária de automóveis, o ICMS devido na venda dos veículos ao consumidor final, incluindo o valor total do ICMS recolhido na nota fiscal emitida para a concessionária, sendo tais valores repassados ao consumidor no preço final. Posteriormente, verificou-se que a base de cálculo sobre a qual incidiu o ICMS estava equivocada, tendo a montadora recolhido valor a maior ao Fisco.

Diante desse quadro, responda aos itens a seguir.

a) Que tipo de responsável tributário é essa montadora em relação à concessionária? Indique o fundamento legal.

b) A montadora, que recolheu sozinha o tributo, possui legitimidade para pleitear a repetição de indébito tributário? Justifique.

QUESTÃO 113 – XXVII EXAME UNIFICADO

O Estado “X”, novo Estado da Federação, resultante do desmembramento do Estado “Y”, tem dificuldade de instituir, cobrar e fiscalizar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em todos os seus 200 municípios. Assim, decidiu delegar competência legislativa a seus Municípios para que instituíssem o tributo, realizassem a cobrança e promovessem a fiscalização e a administração do referido tributo, impondo aos Municípios o dever de repassar 50% das quantias arrecadadas ao Estado. A empresa de transportes de passageiros Sigma, detentora de grande frota de veículos, entendeu por questionar a cobrança do IPVA.

Diante dos fatos acima expostos, na condição de advogado(a), responda aos itens a seguir.

- a) Você vislumbra êxito na pretensão da empresa de transportes Sigma? Justifique.
- b) Se a delegação repousasse apenas sobre as atividades de arrecadação e fiscalização do IPVA, seria devida a pretensão da empresa Sigma? Justifique.

QUESTÃO 114 – XXVIII EXAME UNIFICADO

O Fisco Federal ajuíza uma ação de execução fiscal contra a sociedade empresária ABC Ltda. por créditos tributários vencidos e não pagos. Contudo, ao se tentar promover a citação da executada pelos Correios, percebe-se que a sociedade já não funciona no local por ela declarado ao Fisco, sem que tenha comunicado a nenhum órgão competente o local onde pode receber citações ou onde continua realizando suas atividades. Também não são encontrados bens da executada que pudessem ser objeto de penhora.

Diante dessa situação, responda aos itens a seguir.

- a) Frustrada a citação via postal, por quais outros meios se fará a citação da sociedade nesta execução fiscal?
- b) Qual a consequência, para o sócio administrador que sempre integrou a sociedade, de a executada não ser encontrada no domicílio por ela declarado?

QUESTÃO 115 – XXVIII EXAME UNIFICADO

No intuito de aumentar a arrecadação, o prefeito do Município “X” sancionou lei que fixou uma nova base de cálculo do IPTU. A referida lei foi publicada em novembro de 2016, estabelecendo que sua vigência se dará após a data de sua publicação. Bruno e Thiago são irmãos que, por herança, tornaram-se proprietários de um imóvel, no qual, apenas Thiago reside. Em janeiro de 2017, Bruno foi notificado do lançamento do IPTU referente ao imóvel de residência de Thiago, tendo 30 dias para pagá-lo. Bruno alegou que, pelo fato de apenas Thiago residir no imóvel, mesmo ele sendo coproprietário do bem, não precisaria pagar o imposto. Além disso, afirmou que, ainda que tivesse que pagá-lo, a lei que fixou uma nova base de cálculo do IPTU não respeitou a anterioridade nonagesimal.

Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir.

- a) Bruno está correto ao alegar que não é obrigado ao pagamento do imposto?
- b) Bruno está correto ao alegar que a lei que fixou uma nova base de cálculo do IPTU violou a anterioridade nonagesimal?

QUESTÃO 116 – XXVIII EXAME UNIFICADO

Maria, servidora pública do Estado “X”, verificou no contracheque referente ao mês de março que foi retido de sua remuneração um adicional de 2%, referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF. Ao questionar seu órgão de vinculação, obteve a informação

de que a cobrança tinha por fundamento a Lei Estadual nº 12.345, editada no último dia do exercício imediatamente anterior. Indignada com a cobrança, Maria procura você, na condição de advogado(a), para que adote as providências cabíveis, a fim de questionar judicialmente o desconto e obter a devolução do valor recolhido, já que seu pedido administrativo foi negado.

Analizando o contexto fático descrito, responda aos itens a seguir.

- a) No caso de eventual ação de repetição de indébito, qual a parte legítima para figurar no polo passivo da ação?
- b) O Estado “X” poderia ter estipulado o adicional de IRPF para seus servidores?

QUESTÃO 117 – XXVIII EXAME UNIFICADO

Em 01 de novembro de 2017, o Estado “X” instituiu um sistema progressivo de alíquotas para o Imposto sobre a Transmissão *Causa Mortis* e Doação – ITCD. A redação do dispositivo legal era a seguinte:

“Art. 26 – O valor da totalidade dos bens e direitos transmitidos é a base de cálculo do imposto e sobre ela incidirão as seguintes alíquotas:

I – 4% (quatro por cento), para valores entre R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II – 6% (seis por cento), para valores entre R\$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo) e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

III – 8% (oito por cento), para valores acima de R\$ 250.000,01 (duzentos e cinquenta mil reais e um centavo).

Parágrafo único: há isenção do imposto quando a totalidade dos bens e direitos transmitidos não exceder R\$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Caio, residente no Estado “Y”, recebeu de herança um bem imóvel

localizado no Estado “X”, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e decidiu impugnar o lançamento, afirmando que a progressividade do ITCD é inconstitucional, por ser este um imposto de caráter real. Alegou, ainda, que o imposto é devido no Estado “Y”, local de sua residência.

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir.

- a) Caio está correto quanto à alegação de inconstitucionalidade da progressividade do imposto?
- b) Em qual Estado o ITCD é devido?

GABARITO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS

QUESTÃO 01 – EXAME OAB 2010.2

- a) Nos termos do art. 164, III, do CTN, a ação de consignação em pagamento é a via mais adequada para garantir que este seja efetuado ao ente competente.
- b) A União e o Município de Pedra Grande devem figurar no polo passivo da consignatória em litisconsórcio passivo obrigatório.
- c) A competência será da Justiça Federal, por força do disposto na CF/1988 art. 109, I. O candidato que informar a competência da Justiça Estadual somente deve receber a pontuação se justificar a prorrogação de competência ante a possível ausência de vara federal no município.

QUESTÃO 02 – EXAME OAB 2010.2

A empresa está correta. O item 79 da LC 56/1987, anexa ao Decreto-lei 406/1968, foi objeto de julgamento, pelo STF, no Recurso Extraordinário 116.121-3/SP.

Em sessão plenária foi reconhecida a inconstitucionalidade da expressão “locação de bens móveis”.

Em síntese, entendeu o STF que o legislador complementar confundiu o arrendamento de coisa com prestação de serviço, sendo tal diferença consagrada no direito privado, de modo que só poderiam ser tributadas as “obrigações de fazer”, e não as “obrigações de dar”. Entendimento diverso configura ofensa ao conceito de serviço, bem como à regra prevista no art. 110 do CTN.

Esse julgado foi utilizado no veto presidencial ao item 3.01 da atual lista de serviços anexa à LC 116/2003, cuja redação se identificava com a do item que fora declarado inconstitucional.

Ademais, o STF entendeu que a Lista de Serviços deverá ser interpretada taxativamente em relação aos seus itens, não podendo a Municipalidade estabelecer em sua Lista de Serviços outros que não estejam previstos na referida Lista de Serviços anexa à Lei Complementar do imposto em questão.

Na hipótese da locação de fitas, bens móveis, estaria afastada a incidência do ISS, pois esta atividade se constitui em obrigação de dar.

Quanto à propositura de demanda judicial, poderá ser manejada ação declaratória de inexistência da relação jurídica tributária ou mandado de segurança preventivo.

QUESTÃO 03 – EXAME OAB 2010.2

O art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN determina que o lançamento reporta-se à data do fato gerador do tributo, não se aplicando, desse modo, as alíquotas da lei nova aos fatos geradores ocorridos no ano de 2009, portanto, anteriores à sua entrada em vigor e à sua eficácia.

Todavia, quanto às multas, aplica-se o art. 106, II, c, do CTN, isto é, a lei nova poderá retroagir em benefício do contribuinte apenas quanto aos ilícitos ocorridos em 2009, em se tratando de ato ou fato não definitivamente julgado.

Desse modo, mediante aditamento à impugnação fiscal oposta contra o lançamento tributário, ainda pendente de julgamento, poderia o contribuinte apenas ser beneficiado com a redução da multa fiscal, conforme disciplinada pela nova legislação.

QUESTÃO 04 – EXAME OAB 2010.2

O Decreto-lei 406/1968, em seu art. 9.º, § 1.º, estabelece que o imposto sobre serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal não pode ser calculado sobre a importância recebida a título de remuneração do próprio trabalho.

Com a entrada em vigor da LC 116/2003, o seu art. 10 não revogou expressamente o art. 9.º do Decreto-lei 406/1968, o que resulta ainda na sua aplicação quanto a essa forma específica de tributação.

Desse modo, os advogados não se submeteriam a tributação imposta pela lei prevista no enunciado, em razão de ilegalidade, com base no art. 10 da LC 116/2003 e art. 9.º, §§ 1.º e 3.º, do Decreto-lei 406/1968, que não foram expressamente revogados e constituem normas gerais a serem observadas pelos municípios.

O advogado poderá propor ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ou mandado de segurança preventivo.

QUESTÃO 05 – EXAME OAB 2010.2

O contribuinte tem direito à compensação por meio administrativo, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/1996, permitindo-se que possa ser efetuada mediante créditos e débitos de tributos administrados pela Receita Federal, ainda que distintos os destinos da arrecadação, no entanto exige-se prévio requerimento ao Fisco.

A compensação subordina-se ao mesmo prazo da repetição previsto no art. 168 do CTN, pois não deixa de ser uma forma de restituição.

Assim, o contribuinte, no prazo de 5 (cinco) anos contados do pagamento indevido do tributo, poderá optar pela compensação a ser

realizada na via administrativa e/ou repetição do indébito quer na via administrativa ou judicial.

QUESTÃO 06 – EXAME OAB 2010.3

Conforme prevê o art. 185 do CTN, “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita”.

Não se aplica a Súmula 375 do STJ (“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”), uma vez que os precedentes que levaram à edição do verbete não foram produzidos em processos tributários a serem confrontados com a redação assumida pelo art. 185 do CTN após a edição da LC 118/2005. Para caracterizar a fraude à execução fiscal, não é necessário o registro da penhora do bem objeto do negócio jurídico entre particulares, bastando que a alienação leve o contribuinte devedor do tributo à insolvência.

Há diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal, já que, naquela, ocorre a violação de um interesse privado, ao passo que, na segunda, o interesse é público, tendo em vista que o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. Nesse sentido, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se *in re ipsa*, sendo dotada de caráter absoluto, objetivo, dispensando o *concilium fraudis*.

Assim, com a atual redação do art. 185 do CTN, a fraude à execução tem sua caracterização antecipada, passando a ser presumida desde quando da realização da inscrição em dívida ativa.

QUESTÃO 07 – EXAME OAB 2010.3

a) A questão envolve a aplicação do princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da CF/1988, bem como o princípio da anterioridade tributária, constante no art. 150, III, *b* e *c*, da CF/1988. Nessa linha, o candidato deverá identificar que a lei seria o veículo adequado para instituição e cobrança da contribuição de melhoria (art. 97, I, do CTN), o que restou não observado pelo Poder Executivo ao instituí-la mediante simples edição de decreto, violando, frontalmente, os princípios da legalidade e da anterioridade tributária.

Ademais, o candidato deverá mencionar os arts. 81 e 82 do CTN, visto que tais dispositivos legais impõem determinados requisitos prévios para a instituição e cobrança da referida exação fiscal que não foram observados pelo Poder Executivo local.

b) Não. O candidato deverá identificar que o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente da obra pública, o que ocorreu, no caso descrito, em relação aos 100 (cem) imóveis em questão; porém o art. 81 do CTN estabelece dois limites para a cobrança: um individual e outro local. O limite individual deverá se ater à valorização individual de cada imóvel, e o limite total refere-se ao custo total das obras, isto é, a somatória das contribuições cobradas de cada proprietário não poderá exceder o limite total do custo da obra correspondente a R\$ 3.500.000,00.

Desse modo, o candidato deverá identificar que o custo total da obra sequer foi levado em consideração pelo Poder Executivo local, infringindo, portanto, o disposto previsto no art. 81 do CTN.

QUESTÃO 08 – EXAME OAB 2010.3

O examinando deverá citar o art. 133, I, do CTN. O novo proprietário responderá integralmente pelos tributos devidos relativos ao comércio adquirido, por força da responsabilidade por sucessão prevista no CTN.

O examinando deverá mencionar que o art. 123 do CTN determina que quaisquer contratos ou convenções particulares não podem ser opostos perante a Fazenda Pública, para modificar a sujeição passiva tributária prevista no CTN.

Pelo exposto, está correto o entendimento da Receita Federal, não possuindo a Empresa LM S/A legitimidade ativa perante a autoridade administrativa competente para pleitear a repetição do indébito do aludido imposto.

QUESTÃO 09 – EXAME OAB 2010.3

Primeira possibilidade de resposta:

A revogação de uma isenção equivale à instituição de um novo tributo, de forma que se deve respeitar o princípio da anterioridade.

Segunda possibilidade de resposta:

Funda-se na posição do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, com base no art. 178, “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inc. III do art. 104 do CTN”.

QUESTÃO 10 – EXAME OAB 2010.3

A questão foi sedimentada na posição do Supremo Tribunal Federal, que sublinha a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em operações de arrendamento mercantil, uma vez que não há transferência de domínio do bem nos casos de *leasing* sem opção de compra, ou seja, não há um dos pressupostos fundamentais do ICMS, que é a circulação do bem ou mercadoria. Nos contratos de arrendamento mercantil, não há a circulação do bem, que é exigência constitucional (CF/1988, art. 155, II) para a exação do tributo, já que a titularidade do bem permanece com a arrendadora, sendo a transferência para a arrendatária meramente temporária. Aliás,

cumprir ressaltar que essa é a principal característica deste contrato que influi diretamente na impossibilidade de cobrança do tributo supracitado. O imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias. Além disso, a LC 87/1996, art. 3.º, VIII, impossibilita a cobrança explicitamente em relação ao arrendamento mercantil. Demais precedentes: RE 460.814 AgRg, RE 194.255 AgR, RE 553.666 AgRg.

QUESTÃO 11 – OAB FGV IV EXAME

O art. 132 do CTN prevê que a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”. Ao utilizar a expressão “tributos”, segundo a interpretação consolidada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo 923.012/MG, o legislador não quis restringir a sucessão dos créditos tributários somente aos débitos decorrentes de inadimplemento no pagamento do tributo, mas também as multas de caráter moratório ou punitivo, eis que no art. 129 do CTN, o legislador expressamente utilizou a expressão “créditos tributários”, sem qualquer restrição. Portanto, as multas constituídas ou em fase de constituição até a data do ato de incorporação permanecem como devidas pela empresa incorporadora.

Na mesma linha, as obrigações chamadas de acessórias também são consideradas como devidas pela empresa incorporadora, pois, conforme prevê o art. 113, § 3.º, do CTN, as obrigações acessórias, pelo simples fato de sua inobservância, convertem-se em obrigação principal. Portanto, não há fundamento jurídico para excluí-las da sucessão por incorporação.

QUESTÃO 12 – OAB FGV IV EXAME

Dispõe o art. 7.º da LC 116/2003 que a base de cálculo do imposto corresponde ao preço do serviço.

Caso excepcional, contudo, é a regra do art. 9.º do Decreto-lei 406/1968, de vigência mantida pela LC 116/2003, que trata dos serviços prestados autonomamente pelo contribuinte ou sob a forma de agrupamento profissional, consoante §§ 1.º e 3.º do dispositivo citado, sendo exemplo as sociedades uniprofissionais formadas por médicos, contadores, advogados, dentistas etc. Nesses casos excepcionais, o tributo é fixo, exigido e calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade.

Ademais, a plena vigência dos §§ 1.º e 3.º do art. 9.º do Decreto-lei 406/1968 foi declarada pelo STF na Súmula 663.

Todavia, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que o ISS seja calculado e recolhido como tributo fixo deverá a sociedade caracterizar-se como sociedade uniprofissional, sem caráter empresarial, o que por certo não se compatibiliza com a sociedade limitada. Ademais, se a sociedade dispõe de caráter empresarial, não haveria incidência do art. 9.º, §§ 1.º e 3.º, do Decreto-lei 406/1968.

Dessa forma, não há direito da empresa em recolher o ISS na forma pretendida. O imposto deverá ter como base de cálculo o preço do serviço cobrado, de acordo com o art. 7.º da LC 116/2003, com incidência da alíquota prevista na legislação municipal local relativa ao serviço em questão.

QUESTÃO 13 – OAB FGV IV EXAME

A conduta é abusiva e não terá eficácia em face do Fisco. Representa hipótese de elusão fiscal (ou elisão ineficaz), em que o comportamento do contribuinte não é, a rigor, ilícito, mas adota um

formato artificioso, atípico para o ato que está sendo praticado, para obter redução de carga tributária. Caio e Tício constituíram a sociedade com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do ITBI, com o escopo de escapar artificialmente da tributação.

Caso o Fisco venha a perceber a manobra artificiosa adotada, poderia lançar o tributo devido, com a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, que dispõe: “A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”. O Fisco poderá, nesta hipótese, requalificar juridicamente os fatos, para fazer incidir o tributo devido.

QUESTÃO 14 – OAB FGV IV EXAME

Não é possível a lei ordinária criar uma nova forma de extinção do crédito tributário, conforme art. 141 do CTN (“Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”). Logo, somente mediante Lei Complementar seria modificável a hipótese de extinção do crédito tributário. Além disso, o art. 156, XI, do CTN prevê que a prestação substitutiva de pagamento em dinheiro somente poderá ser a dação em pagamento de bem imóvel, sendo o referido dispositivo dotado de caráter taxativo.

QUESTÃO 15 – OAB FGV V EXAME

A substituição tributária encontra-se prevista no art. 150, § 7.º, da CF/1988. Nessa hipótese, o contribuinte substituído deixa de integrar diretamente a relação jurídico-tributária com o Fisco, passando a suportar apenas o ônus econômico do tributo, cabendo ao

contribuinte substituto o dever de realizar a apuração e o recolhimento do tributo em nome do contribuinte substituído.

Na situação em análise, foi o contribuinte substituído que recorreu ao Poder Judiciário, por meio da impetração do *writ*, tendo convencido o julgador a lhe conceder medida liminar que acabou por reduzir o montante do ICMS a ser retido por substituição tributária pela FORD. Assim, a FORD não era parte na ação judicial, tendo se limitado a cumprir a decisão judicial. Não pode, em consequência, suportar os ônus da medida judicial, pois apenas agiu em cumprimento a uma ordem do juiz.

Desta forma, a liminar concedida pelo juiz, por via reflexa, transmudou a natureza da substituição tributária originalmente existente, deslocando a responsabilidade pelo eventual e futuro recolhimento do imposto para a parte impetrante, isto é, para o contribuinte substituído. Portanto, não é a FORD parte legítima para suportar os ônus advindos da autuação.

Já no que concerne à possibilidade da exigência de tributo durante o período em que esteve vigente a medida liminar posteriormente revogada, o STF, por meio da edição da Súmula 405, estabeleceu que a revogação de medida liminar acarreta a recomposição do *status quo* anterior, cabendo à parte que a requereu e dela se beneficiou, arcar com os ônus de tal recomposição. Portanto, como a medida liminar não se encontra mais em vigor, pode o Fisco Estadual constituir e exigir o tributo em face do contribuinte substituído.

QUESTÃO 16 – OAB FGV V EXAME

a) Sim. Até a entrada em vigor da EC 33, de 11.12.2001, o art. 155, IX, *a*, da CF/1988 não disciplinava, em sua redação originária, a possibilidade de incidência do ICMS de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física, daí por que inúmeros contribuintes, à época, questionaram judicialmente a cobrança do

ICMS pelos Estados, o que resultou em julgamentos favoráveis aos contribuintes, culminando com a edição da Súmula 660 do STF.

Contudo, com o advento da EC 33, de 11.12.2001, que alterou a redação do art. 155, IX, *a*, da CF/1988, a pessoa física passou, expressamente, a constar como contribuinte de bem ou mercadoria importado do exterior.

Ademais, a LC 87/1996 teve a redação alterada pela LC 114/2002, a qual passou a determinar, em seu art. 4.º, parágrafo único, I, que a pessoa física, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, enquadra-se como contribuinte do ICMS quando “importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade”.

Dessa forma, o candidato deverá interpretar as mudanças trazidas pela EC 33/2001 em relação ao caso posto em debate, bem como mencionar a inaplicabilidade da Súmula 660 do STF frente à redação atual prevista no art. 155, IX, *a*, da CF/1988.

b) Não. O presente *writ* é inviável, pois não engloba direito líquido e certo, portanto, não há que se falar em deferimento ou não da liminar (art. 5.º, LXIX, da CF/1988 e Lei 12.016/2009). Dessa forma, o examinando deverá identificar a aplicação ou não da existência de direito líquido e certo à luz das informações previstas no problema.

QUESTÃO 17 – OAB FGV V EXAME

A questão versa sobre duas espécies de taxas – aquela relativa ao exercício do poder de polícia e a taxa de serviço público.

O STF tem entendimento pacificado da desnecessidade da vistoria ou fiscalização “porta a porta” para a cobrança da taxa relativa ao exercício do poder de polícia.

Para o Pretório Excelso basta a existência do órgão competente na estrutura do ente federativo que exercite o poder de polícia, que não se restringe a atos fiscalizadores, mas compreende qualquer ato necessário para atestar a conformidade da atuação do contribuinte às

normas ambientais, no caso em tela. Deste modo, a TCFA é devida.

Já em relação à TCVLP, o Código Tributário Nacional exige que a possibilidade da exação encontre fundamento somente quando o serviço público prestado for específico e divisível, o que não confere com a essência da TCVLP, que, portanto, é indevida.

QUESTÃO 18 – OAB FGV V EXAME

O Fato Gerador do tributo é a situação ou circunstância com previsão legal suscetível de originar obrigação de natureza tributária.

O Imposto Territorial Rural (ITR) tem como hipótese de incidência tributária, segundo o já citado art. 29 do CTN, “a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município”.

Desde 2007, o proprietário não detém o direito de usar, gozar e dispor do imóvel, em decorrência da invasão pelos integrantes das famílias camponesas e o direito de reavê-lo não é assegurado pelo Estado.

Houve, portanto, o completo esvaziamento do conteúdo do direito de propriedade, que se mantém apenas formalmente, não configurando o fato gerador do ITR.

O ITR é inexigível ante o desaparecimento da base material do fato gerador.

O mesmo Estado que se omite na salvaguarda de direitos fundamentais, mesmo após decisão judicial exigindo a sua intervenção, não pode utilizar a aparência do direito para cobrar o tributo que pressupõe a incolumidade da titularidade do domínio não apenas formalmente, mas também materialmente.

QUESTÃO 19 – OAB FGV VI EXAME

Não. Vide Súmula 424 do STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987”.

A lista da LC 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva, de acordo com o sentido do termo “congênere” contido na LC 116/2003, devendo prevalecer não a literalidade da denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele.

QUESTÃO 20 – OAB FGV VI EXAME

Súmula 432 do STJ: “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.

A construtora, ao adquirir material de construção em Estado de origem, que exigiu o ICMS, ao utilizar as mercadorias como insumo em suas obras, não estará compelida à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário.

Logo, a empresa de construção civil que comprar material a ser utilizado em sua atividade comercial em outro Estado, tendo em vista não ser contribuinte do ICMS, deve se sujeitar tão somente à alíquota interna.

“É assente na Corte que as empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS, salvo nas situações que produzam bens e com eles pratiquem atos de mercancia diferentes da sua real atividade, como a pura venda desses bens a terceiros; nunca quando adquirem mercadorias e as utilizam como insumos em suas obras. (...). Consequentemente, é inadmissível a retenção, pelos Estados, do diferencial de alíquotas relativo a operações interestaduais efetuadas por empresa de construção civil para aquisição de mercadorias sem objetivo de comercialização. 4. Agravo Regimental desprovido” (AgRg no Ag 687.218/MA, 1.^a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 04.05.2006 DJ 18.05.2006).

QUESTÃO 21 – OAB FGV VI EXAME

O art. 25, § 1.º, da LC 87/1996 é expresso ao conferir ao contribuinte detentor de saldos credores de ICMS acumulados desde a edição da lei, em razão de operações de exportação, a faculdade de aproveitá-los mediante a transferência a qualquer estabelecimento seu no mesmo Estado (inc. I) e, havendo saldo remanescente, mediante transferência a outro contribuinte do mesmo Estado (inc. II), utilizando-se, nessa segunda hipótese, de documento expedido pela Fazenda, reconhecendo a existência de crédito. Trata-se, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RMS 13.969/PA), de norma de eficácia plena que dispensa regulamentação por lei estadual. A lei estadual somente seria obrigatória para a hipótese prevista no § 2.º do art. 25 da LC 87/1996.

Assim, não é dado ao legislador estadual qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos do ICMS, sob pena de se violar a não cumulatividade, quando este aproveitamento se fizer em benefício do contribuinte, no mesmo Estado.

Ademais, o art. 155, § 2.º, X, *a*, da CF/1988 dispõe que nas operações de exportação será ao contribuinte: “(...) assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”, o que resulta em plena eficácia do direito ao aproveitamento do crédito por força da aplicação do princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2.º, I, da CF/1988.

QUESTÃO 22 – OAB FGV VI EXAME

De acordo com o art. 166 do CTN, a restituição da quantia paga a título de tributo indireto deve ser feita ao potencial sujeito passivo da obrigação correspondente, quando este demonstre, de forma inequívoca, que não repassou o encargo respectivo, ou, tendo havido a transferência do ônus a terceiro, contribuinte de fato, deverá ser por este autorizado a receber a quantia a maior que tiver sido paga.

No caso do IPI, tributo indireto, legitimada a requerer a repetição de

indébito tributário será a pessoa que estaria no polo passivo da relação obrigacional correspondente, caso a tributação tivesse ocorrido de forma regular (contribuinte de direito), na hipótese da questão, a Fábrica de Refrigerantes Super Refri Ltda.

Em resumo, a fábrica que industrializa o refrigerante se enquadra como contribuinte do IPI, visto praticar o fato gerador deste imposto resultante do processo de industrialização com posterior venda, sendo certo que o IPI compõe o preço final do produto a ser vendido, ocorrendo, portanto, o repasse da carga econômica do imposto a terceiro (contribuinte de fato).

Pelo exposto, conclui-se que a Distribuidora de Bebidas não tem legitimidade para propor ação de repetição do indébito tributário, visto não se enquadrar como contribuinte de direito, na forma da legislação tributária (art. 46, parágrafo único c/c o art. 51, ambos do CTN); arts. 46, II, e 51, II, do CTN.

O contribuinte de fato é aquele que arca com o pagamento do tributo, que está embutido no preço do produto. A Distribuidora efetivamente não pode assim ser qualificada, visto que não está no fim do ciclo de produção, mas sim o consumidor final.

A distribuidora não tem com o Fisco qualquer relação jurídica, não participa da relação jurídica tributária.

QUESTÃO 23 – OAB FGV VII EXAME

a) A constituição do crédito tributário ocorreu de forma regular pelo Fisco, pois, como a empresa não havia declarado qualquer valor a recolher a título de COFINS, deve ser aplicada a regra prevista no art 173, I, do CTN, que estipula que o prazo decadencial somente se inicia no primeiro dia útil do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Assim, não se verificou a decadência do direito de lançar o tributo.

b) Houve, inicialmente, suspensão do prazo de cobrança com a

apresentação de impugnação administrativa que, conforme previsto no art. 151, III, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, o qual somente retoma a sua plena exigibilidade após a sua constituição definitiva, ocorrido após o término do processo administrativo. Portanto, conforme previsto no art. 174 do CTN, a execução fiscal deve ser ajuizada no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do encerramento do processo administrativo, sob pena de restar caracterizada a ocorrência de prescrição. No presente caso, o primeiro ato que interrompeu a fluência do prazo prescricional ocorreu com a determinação de citação do devedor. Como a executada não foi encontrada, o processo deve ser suspenso na forma do art. 40 da Lei 6.830/1980.

c) Como a execução fiscal foi ajuizada antes do prazo prescricional, o crédito tributário exigido por meio da presente execução não se encontra prescrito, já que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, na forma da Súmula 106 do STJ.

QUESTÃO 24 – OAB FGV VII EXAME

a) Sim, para a contribuição previdenciária, conforme o art. 135, III, do CTN, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

b) Não, em relação ao IRPJ, visto que neste caso se trata de inadimplemento da obrigação tributária, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula 430 do STJ.

Nas Sociedades Anônimas os diretores não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente “dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo e pelos atos

praticados com violação do estatuto ou lei” (art. 158, I e II, da Lei 6.404/1976).

Os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O referido dispositivo trata da responsabilidade por substituição. Aqueles que representam a sociedade e agem de má-fé merecem, por inteiro, o peso da responsabilidade tributária decorrente de atos praticados sob essas circunstâncias.

Sempre que a empresa deixa de recolher o tributo na data do respectivo vencimento, a impontualidade ou a inadimplência é da pessoa jurídica, não do sócio-gerente (ou diretor). Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Súmula 430 do STJ.

Contudo, a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas dos empregados se afigura em infração à lei, apropriação indébita.

QUESTÃO 25 – OAB FGV VII EXAME

Sim, incide o IPTU. Apesar de o art. 32, § 1.º, do CTN estabelecer a observância de pelo menos dois melhoramentos para que o imóvel venha a se enquadrar na zona urbana, certo é que há incidência do IPTU sobre sítio de recreio situado em zona de expansão urbana, conforme previsto no art. 32, § 2.º, do CTN, ainda que o imóvel ainda não disponha de tais benefícios.

Nessa linha, também é o entendimento do STJ, conforme REsp 181.105, Min. José Delgado.

QUESTÃO 26 – OAB FGV VII EXAME

A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, *ex vi* do art. 126, I, do CTN.

Nessa esteira, o jovem é contribuinte do ISS (art. 156, III, da CF/1988, e LC 116/2003) e do IRPF (art. 153, III, da CF/1988, e art. 43 do CTN), em razão das operações acima descritas, visto que pratica o fato gerador relativo a esses impostos.

QUESTÃO 27 – OAB FGV VIII EXAME

Inicialmente o candidato deveria citar o art. 165 do CTN ou esclarecer o cabimento da repetição do indébito, em função do pagamento a maior realizado pela empresa. Em segundo lugar, seria fundamental que o candidato identificasse que o IPI é tributo indireto, ou seja, o ônus financeiro é, via de regra, suportado por terceiro, chamado de contribuinte de fato. A norma do Código Tributário Nacional sobre a questão é o art. 166 do CTN, no qual fica consignado que cabe a restituição do tributo pago a maior, desde que provado pelo requerente que suportou o encargo financeiro, ou está autorizado a receber o valor pago de forma equivocada por quem ficou com este ônus. Nestes termos destacou-se no gabarito a Súmula 546 do STF. Por fim, o critério de correção adotado prestigiou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, emitido na forma de recurso repetitivo, de que, em se tratando de IPI, a legitimidade é do contribuinte de direito.

QUESTÃO 28 – OAB FGV VIII EXAME

A questão proposta está sendo apreciada pelo STF, na sistemática de repercussão geral. Desta forma, a banca considerou relevante que os candidatos conhecessem e pudessem expor as duas posições evidenciadas e pontuadas: a favorável à imunidade, no caso de sociedade de economia mista dedicada à prestação de serviço público, e aquela desfavorável, na hipótese desta mesma empresa ter ações negociadas em bolsa de valores. Assim sendo, pontua-se quem

responder pela impossibilidade do reconhecimento da imunidade recíproca (art. 150, VI, *a*, e art. 173, § 2.º, da CF/1988): natureza privada da companhia, que não goza de privilégio não extensível às empresas privadas, e também merece pontuação a resposta que, no segundo item avaliado, registra que a atividade é serviço público não sujeito à exploração privada: direito à imunidade, na forma do art. 175 da CF/1988, sendo inaplicável o art. 173, § 2.º, da CF/1988 para quem presta serviços públicos.

QUESTÃO 29 – OAB FGV VIII EXAME

Inicialmente o gabarito destaca o art. 146, III, *a*, da CF/1988, eis que neste dispositivo há expressa referência à lei complementar como a ferramenta legislativa própria para fixar base de cálculo dos impostos. Nesse caso, a Lei Complementar que disciplina matéria relativa ao ICMS é a LC 87/1996, dispondo em seu art. 13, § 1.º, II, *a*, que o valor correspondente à base de cálculo do ICMS inclui “seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”. Em outras palavras, os descontos incondicionais não deverão ser incluídos na base de cálculo do referido imposto, já dispondo o STJ da Súmula 457 que veda a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do referido imposto. Conclui-se, portanto, que a referida lei é inconstitucional.

QUESTÃO 30 – OAB FGV VIII EXAME

O gabarito proposto assinala como fundamental a referência ao art. 4.º, I, do CTN, o qual dispõe que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo seu fato gerador. Como segundo quesito de avaliação, requer-se que o candidato saiba observar que a exação não é taxa, por não se tratar de serviço público específico e divisível, nos termos dos art. 145, II, da CF/1988 ou art. 77 do CTN.

Obs.: Por fim, como sempre é ressaltado, registra-se que a mera

pontuação de artigo não pontua.

QUESTÃO 31 – OAB FGV IX EXAME

O Decreto X é inconstitucional, visto que contraria o art. 150, I, da CF/1988, e o art. 97, § 1.º, do CTN.

Nessa linha, o referido Decreto fere o princípio da legalidade tributária, pois somente a lei poderá criar novos critérios relativos à base de cálculo do IPTU, uma vez que a alteração da base de cálculo de modo a torná-lo mais oneroso, como ocorreu na hipótese aqui cuidada, equipara-se à majoração de tributo.

QUESTÃO 32 – OAB FGV IX EXAME

O IGF encontra-se previsto no art. 153, VII, da CF/1988 possibilitando à União Federal instituí-lo de acordo com as regras constitucionais previstas, sendo certo que deverá o IGF ser instituído mediante lei complementar, o que não foi observado.

Ademais, tem-se o mesmo fato gerador do imposto de renda, o que caracteriza dupla incidência sobre o mesmo fato gerador já previsto no art. 43, I e II, do CTN.

Desse modo, a lei em questão é inconstitucional.

QUESTÃO 33 – OAB FGV IX EXAME

a) Não há bitributação, pois os tributos apresentam fatos geradores distintos. Além disso, bitributação é figura que ocorre quando entes tributantes diversos exigem do mesmo sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador.

O fato gerador do Imposto de Importação é a entrada do produto no território nacional, *vide* art. 19 do CTN. Já a hipótese de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados na importação, na forma do art. 46, I, do CTN, é o desembaraço aduaneiro.

b) Não. Como a importação não se destina a comércio, o importador

não é considerado contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados. O fato gerador do IPI na importação envolve uma relação mercantil. Caso contrário haveria um descumprimento do Princípio da não cumulatividade, previsto no art. 153, § 3.º, II, da CF/1988.

QUESTÃO 34 – OAB FGV IX EXAME

- a) O ISS incidente sobre serviços de administração de congressos é devido no local do congresso, conforme art. 3.º, XXI, da LC 116/2003. Logo, é devido pelo contribuinte Pérola, prestadora desses serviços, ao município Beta. O ISS incidente sobre os ingressos vendidos para o congresso (isto é, sobre a receita de serviços de congresso, previstos no subitem 12.08 na lista da referida Lei Complementar) é devido no local onde se realiza o evento, conforme inc. XVIII do art. 3.º da citada Lei Complementar. Logo, também é devido no município Beta, embora por outro contribuinte (o prestador desses serviços é a associação).
- b) O único serviço prestado pela Pérola S/A é o de organização e administração do congresso. Logo, apenas o valor desse serviço compõe a base de cálculo do ISS a ser por ela recolhido, prevista no art. 7.º, da LC 116/2003. A receita de ingressos não remunera a atividade da Pérola e por isso não integra o preço de seu serviço.

QUESTÃO 35 – OAB FGV X EXAME

- a) Não há legitimidade do banco, já que sócio e sociedade não se confundem. Além disso, o fato de serem empresas do mesmo grupo econômico não torna o banco responsável. Não incide o art. 124, I, do CTN ou o art. 128 do CTN. Não há interesse comum.
- b) Os elementos que deveriam estar presentes, para ser reconhecida a solidariedade são: expressa previsão da legislação, relação pessoal com o fato gerador do tributo e interesse comum.

QUESTÃO 36 – OAB FGV X EXAME

- a) Não caracteriza. A locação de bens móveis não constitui uma prestação de serviços, mas disponibilização de um bem móvel para utilização do locatário. A locação de bens móveis não consta do rol de serviços da lista anexa à LC 116/2003. Súmula Vinculante 31 do STF.
- b) Sim. Súmula 423 do STJ: “A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS incide sobre as receitas proveniente das operações de locação de bens móveis”. A noção de receita ou faturamento, fato gerador da COFINS, *vide* art. 195, I, *b*, da CF/1988, engloba as receitas advindas das operações de locação de bens móveis, posto tratar-se de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial.

QUESTÃO 37 – OAB FGV X EXAME

- a) Aplica-se no caso concreto a imunidade prevista no art. 150, VI, *c*, da CF/1988, uma vez que este dispositivo não faz ressalva quanto à natureza do patrimônio (rural ou urbano) das entidades indicadas, dentre elas, os sindicatos. O fato de haver receitas oriundas de aluguéis em imóveis urbanos, não inviabiliza que tais valores possam ser usados nas atividades essenciais de tais entidades.
- b) Súmula 724 do STF: “Ainda quando alugado a terceiros permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, *c*, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”.

QUESTÃO 38 – OAB FGV X EXAME

- a) A modalidade de extinção do crédito tributário referida na questão é a compensação tributária prevista nos arts. 156, II, e 170, ambos do CTN; em outras palavras, os valores decorrentes do precatório

judicial a que faz jus o contribuinte poderiam ser compensados com o valor resultante do débito do ICMS que mantém perante o Estado, ao mesmo tempo devedor e credor da empresa com relação às respectivas obrigações.

b) Não poderia ser efetuada a compensação tributária nesse caso, pois não se amolda à previsão do art. 170 do CTN.

Somente seria possível se houvesse previsão expressa, o que não ocorre à luz do caso em tela.

QUESTÃO 39 – OAB FGV XI EXAME

O candidato deverá, na essência, observar quanto à pergunta, o seguinte:

Não. O Presidente da República age como Chefe de Estado ao firmar tratados internacionais em nome da soberana República Federativa do Brasil (Estado Brasileiro), ou seja, atua em nome do país, visto como unidade dos Entes que compõem a Federação, e não em nome exclusivo e único da União. Deverá observar, por fim, que o STF entende que a concessão de isenção na via do tratado não se sujeita à vedação, à concessão de isenção heterônoma, pois o âmbito de aplicação do art. 151, III, da CF/1988 é o das relações das entidades federadas entre si, não alcançando a União quando esta se apresenta na ordem externa.

QUESTÃO 40 – OAB FGV XI EXAME

O candidato deverá observar que a União Federal, de acordo com o estabelecido no art. 149 da CF/1988, tem competência para instituir Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. O fomento é uma forma de intervenção do Estado na economia, havendo referibilidade entre os contribuintes e o fato gerador da CIDE.

Não há como falar em violação ao art. 154, I, da CF/1988, por conta do fato gerador igual ao do ITR, uma vez que os requisitos apontados

no dispositivo alcançam somente os impostos.

No entanto, a lei é inconstitucional no tocante à base de cálculo (valor da propriedade) que não está inserida na alínea *a* do inc. III do § 2.º do art. 149 da CF/1988.

QUESTÃO 41 – OAB FGV XI EXAME

O candidato deverá, na essência, observar quanto às perguntas o seguinte:

- a) É negativa a resposta relativa à questão A. A Constituição da República veda, expressamente, a edição de Medida Provisória para dispor sobre matéria reservada à lei complementar (art. 62, § 1.º, III). E os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos por meio de lei complementar (CF/1988, art. 148).
- b) Também é negativa a resposta à questão B. A observância ao princípio da anterioridade é expressamente excepcionada com relação aos empréstimos compulsórios instituídos por força de calamidade pública (CF/1988, art. 150, § 1.º, conjugado com art. 148, I).

QUESTÃO 42 – OAB FGV XI EXAME

A questão aborda dois pontos: a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e o aspecto subjetivo do Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).

- a) Para se caracterizar o instituto da denúncia espontânea, o pagamento do tributo deve vir acompanhado da correção monetária e dos juros moratórios, conforme previsão legal. A denúncia espontânea, no entanto, exclui as multas de caráter punitivo, decorrentes do atraso no pagamento.

Sendo assim, o candidato deve responder que está correta a exclusão da multa moratória no caso descrito, tendo em vista a ocorrência da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.

- b) A resposta também é positiva. Segundo o art. 42 do CTN, a lei

poderá dispor sobre quem é o contribuinte: o donatário, no caso Tício, ou o doador, no caso Caio.

QUESTÃO 43 – OAB FGV XII EXAME

A questão aborda o tema contribuinte e responsabilidade tributária.

A) Inicialmente o candidato deverá indicar que o entendimento dos pais de João não está correto, tendo em vista que a condição de contribuinte independe da capacidade civil, na forma do art. 126, I, do CTN.

b) Além disso, cabe ao candidato afirmar que o Fisco poderia cobrar o tributo dos pais de João, tendo em vista a responsabilidade dos pais em relação aos tributos devidos por seus filhos menores, determinada pelo art. 134, I, do CTN.

QUESTÃO 44 – OAB FGV XII EXAME

A questão envolve conhecimentos do candidato sobre lançamento, decadência e direito de repetição do indébito.

a) O candidato deve afirmar que a decadência é forma de extinção do crédito tributário, incidindo, neste caso, o disposto no art. 173, I, do CTN. Nesse contexto, o instrumento de confissão de dívida assinado pelo contribuinte não tem o condão de restabelecer o crédito tributário, havendo inclusive entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Sendo assim, é possível que João pleiteie a restituição dos valores que foram atingidos pela decadência.

b) O prazo é regido pelo art. 173, I, do CTN. Conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. “O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o

pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.

QUESTÃO 45 – OAB FGV XII EXAME

A obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, § 2.º, do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Ou seja, o objetivo das obrigações tributárias acessórias é conferir meios para que a Administração Tributária possa fiscalizar o devido cumprimento de uma obrigação principal (de pagar o tributo).

Diferentemente do que ocorre no Direito Privado, a obrigação tributária acessória não depende da existência de uma obrigação tributária principal nem a ela se subordina. A referida “acessoriedade” decorre desse caráter instrumental dessa espécie de obrigação, para fins de controle do cumprimento da obrigação principal. São deveres instrumentais autônomos em relação à obrigação principal, estabelecidos com a finalidade de viabilizar a fiscalização do cumprimento das obrigações principais. Assim, obrigação tributária acessória é autônoma em relação à obrigação principal, como se pode verificar no art. 175, parágrafo único, e no art. 194, todos do CTN. Em razão dessa autonomia, os efeitos da imunidade podem restringir-se às obrigações tributárias principais, não dispensando a entidade imune de cumprir obrigações acessórias eventualmente previstas na legislação, conforme estabelece o art. 9.º, IV, c, c/c art. 14, III, todos do CTN. Assim, no caso em tela, em razão de previsão legal, a imunidade tributária da instituição de educação não dispensava a obrigação de manter livro de registro do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). Portanto, a tese apresentada na defesa da instituição imune é improcedente.

QUESTÃO 46 – OAB FGV XII EXAME

a) Não. De acordo com o art. 146, III,*a*, da CF/1988, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, definindo, inclusive em relação ao IPVA, os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Como o art. 62, § 1.º, III, da CF/1988 veda a edição de Medidas Provisórias em relação à matéria reservada à Lei Complementar, conclui-se que uma Medida Provisória não pode veicular normas gerais sobre o IPVA.

b) Sim. Inexistindo normas gerais relativas ao imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), o legislador estadual, no contexto da competência concorrente, exerce competência plena sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3.º, da CF/1988, e art. 34, § 3.º, do ADCT.

QUESTÃO 47 – OAB FGV XIII EXAME

a) Sim, houve. Ela ocorreu no momento da entrega da DCTF. A Súmula 436 do STJ estabelece que: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

b) Não, pois a pessoa jurídica mantém pendências fiscais. Neste sentido, dispõe a Súmula 446 do STJ: “Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa”.

QUESTÃO 48 – OAB FGV XIII EXAME

a) Sim, pois ocorreu fato gerador e o imóvel se situa em X, conferindo a competência para o respectivo ITBI, nos termos do art. 156, § 2.º, II, da CF/1988.

b) Não, pois a cobrança se volta para fato ocorrido anteriormente à vigência da lei que majorou o tributo, o que viola o princípio constitucional da irretroatividade tributária (art. 150, III,*a*, da CF/1988). Além disso, trata-se de fato ocorrido no mesmo exercício

daquele de publicação da lei majorante e antes de decorridos noventa dias da referida publicação, o que viola os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal (art. 150, III, *b* e *c*, da CF/1988) cuja aplicabilidade não é excepcionada pela Carta Política, no caso do ITBI.

QUESTÃO 49 – OAB FGV XIII EXAME

a) Não, o contribuinte não tem razão. Conforme esposado na Súmula 188 do STJ, “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”. Além disso, determina o art. 167, parágrafo único, do CTN: “A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”.

b) Sim. Na hipótese do tributo ser federal, será aplicado o disposto pela Lei 9.250/1995, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda, a qual, no seu art. 39, § 4.º, determina: “A partir de 1.º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada”.

QUESTÃO 50 – OAB FGV XIII EXAME

Deve ser considerado o percentual estabelecido na nova lei (50%), sendo aplicável a lei mais benéfica de forma retroativa por força do disposto no art. 106, II, *c*, do CTN. Isso por tratar-se de ato ainda não definitivamente julgado, assim entendida a execução fiscal não definitivamente encerrada, ou seja, aquela em que não foram ultimados os atos executivos destinados à satisfação da prestação.

QUESTÃO 51 – OAB FGV XIV EXAME

a) No caso em tela, não se pode falar em decadência. Com efeito, nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Como o lançamento poderia ser realizado no exercício de 2001, já que o fato gerador foi praticado em 15.01.2001, o prazo de 5 anos iniciou-se no primeiro dia útil do exercício seguinte, ou seja, 01.01.2002. Dessa forma, como o lançamento foi realizado em 17.07.2006, não transcorreram os 5 anos previstos no CTN para a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito.

b) No que concerne à prescrição, o art. 174 do CTN estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. O crédito em questão foi definitivamente constituído em 10.06.2007. Portanto, em 24.07.2012, quando foi efetuado o pagamento, a dívida já estava prescrita.

c) Nos termos do art. 156, V, do CTN, a prescrição extingue o crédito tributário. Assim, se na data do pagamento o crédito tributário já estava extinto, pode-se afirmar que o pagamento é indevido. Em sendo indevido, o contribuinte pode pleitear a restituição da quantia paga nos termos do art. 165 do CTN.

QUESTÃO 52 – OAB FGV XIV EXAME

a) Não, uma vez que o Estado dispõe de meios legalmente previstos para a cobrança de tributos e, conseqüentemente, para a satisfação dos seus créditos. Nesse sentido, dispõe a Súmula 323 do STF que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

b) Conforme dispõe o art. 155, § 2.º, VII, *b*, da CF/1988, com relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor

final localizado em outro Estado, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, adotar-se-á a alíquota interna.

QUESTÃO 53 – OAB FGV XIV EXAME

- a) Segundo o art. 3.º, XXII, da LC 116/2003, o serviço considera-se prestado no local do porto, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa (serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários). Sendo assim, o Município B, onde se localiza o Porto de Ferro, é o competente para cobrança do ISS na hipótese.
- b) A medida judicial mais adequada é a ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 164, III, do CTN.

QUESTÃO 54 – OAB FGV XIV EXAME

- a) Trata-se de questão envolvendo a incidência do ICMS sobre importações. Após a edição da EC 33, de 2001, que modificou a redação original do art. 155, § 2.º, IX, *a*, da CF/1988, o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física. Sendo assim, a alegação do João da Silva não está correta.
- b) Sim, a autoridade aduaneira, responsável pelo desembaraço da mercadoria, somente liberará o carro importado mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, conforme previsto no art. 12, § 2.º, da LC 87/1996.

QUESTÃO 55 – OAB FGV XV EXAME

- a) João faz jus à penalidade reduzida introduzida pela Lei Estadual 5.678, mesmo considerando que o prazo de pagamento do imposto devido pela doação a Pedro venceu antes da publicação da referida Lei. Isso porque, de acordo com o art. 106, inciso II, alínea *c*, do Código Tributário Nacional, que trata da retroatividade benigna, a lei

tributária aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

b) Na doação efetuada a Tiago, não incide a alíquota do imposto majorada pela Lei Estadual 5.678. De acordo com o art. 150, inciso III, da Constituição da República, é vedada a cobrança do tributo com a alíquota majorada: (i) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o aumentou (alínea *b*); (ii) antes de decorridos 90 (noventa) dias da data em que haja sido publicada a lei que o aumentou. No caso, embora a Lei 5.678 tenha sido publicada no exercício anterior àquele em que ocorreu o fato gerador (“doação”), em observância à anterioridade prevista no art. 150, inciso III, alínea *b*, da Constituição da República, entre a data da publicação e a realização do fato gerador não transcorreram os 90 (noventa) dias previstos no art. 150, inciso III, alínea *c*, da Constituição da República.

Dessa forma, em razão da necessidade de observância do referido dispositivo, a alíquota do imposto, majorada pela Lei Estadual 5.678, somente incidirá sobre fatos geradores ocorridos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

QUESTÃO 56 – OAB FGV XV EXAME

A questão aborda dois temas importantes do direito tributário: as garantias e os privilégios do crédito tributário e a prescrição deste.

a) Na hipótese analisada, a alienação do imóvel ocorreu antes da inscrição em dívida ativa. Sendo assim, tendo em vista o disposto no art. 185 do CTN (“Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”), não há que falar em presunção de fraude. Portanto, o entendimento da Fazenda Nacional não está correto: a

alienação não foi fraudulenta.

b) Tício poderá alegar que os créditos cobrados na execução fiscal foram alcançados pela prescrição. Isso porque, conforme destacado no enunciado, os créditos foram constituídos em 2000. Sendo assim, a Fazenda teria até o ano de 2005, conforme previsto no art. 174 do CTN, para cobrar os créditos tributários. No entanto, a execução fiscal somente foi ajuizada em 2007, quando os créditos já estavam prescritos.

QUESTÃO 57 – OAB FGV XV EXAME

a) A certidão positiva com efeitos de negativa é cabível por força do depósito integral do montante exigido pela Fazenda na Execução Fiscal. Já a certidão negativa não é cabível, uma vez que o crédito tributário já está constituído. Isso é fruto da conjugação dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional (CTN), combinados com o art. 151, inciso II, do mesmo Código.

b) Como o fundamento do direito do contribuinte à certidão positiva com efeitos de negativa é o depósito do montante integral do débito discutido (que não é alterado pela superveniente interposição da apelação por parte da Fazenda), o contribuinte continua tendo direito à certidão em questão. O item B somente será pontuado se a certidão correta for identificada no item A.

QUESTÃO 58 – OAB FGV XV EXAME

a) A constituição do crédito ocorreu com a remessa do carnê do IPTU, em 5 de janeiro de 2014. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 397.

b) Sim. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz a substituição, pelo executado, da penhora por depósito em dinheiro, conforme previsão do art. 15, inciso I, da Lei 6.830/1980.

QUESTÃO 59 – OAB FGV XVI EXAME

a) A espécie tributária que o Município XYZ pretendeu instituir foi a contribuição de melhoria, tributo que tem como fato gerador a valorização de imóvel decorrente de obra pública, conforme previsto no art. 145, III, da CF/1988.

b) Não. Apesar de a Constituição Federal outorgar a todos os entes federativos a competência para a instituição da contribuição de melhoria, tal tributo só pode ser instituído pelo ente que realizou a obra pública, no caso o Estado Alfa.

c) Não. A base de cálculo da contribuição de melhoria deve considerar a valorização do imóvel beneficiado pela obra pública e não os custos da obra, conforme previsto no art. 81 do CTN e/ou art. 3.º do Decreto-lei 195/1967. O valor da obra serve apenas como o limite a ser arrecadado pelo ente tributante com a contribuição de melhoria.

QUESTÃO 60 – OAB FGV XVI EXAME

a) Não. O benefício da denúncia espontânea, com a exclusão da multa de mora, não se aplica nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso da COFINS, quando, regularmente declarados, foram pagos a destempo, conforme enunciado da Súmula 360 do STJ.

b) Não. A Lei 6.830/1980 (a chamada Lei de Execuções Fiscais) prevê, em seu art. 38, parágrafo único, que “A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo (que é a ação anulatória) importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto”.

QUESTÃO 61 – OAB FGV XVI EXAME

a) O Código Tributário Nacional (Lei Ordinária 5.172/1966) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar, uma vez que estabelece normas gerais em matéria de

legislação tributária. Sendo assim, a alteração do CTN, especialmente no que se refere à responsabilidade tributária, deve ser feita por lei complementar, conforme o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.

b) A referida taxa possui a mesma base de cálculo do imposto de importação. O art. 145, § 2.º, da Constituição Federal veda a instituição de taxa com base de cálculo própria de imposto. Sendo assim, a taxa será inconstitucional, caso o projeto de lei seja aprovado.

QUESTÃO 62 – OAB FGV XVI EXAME

a) Não está correto o lançamento do imposto, uma vez que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, nos termos do art. 156, § 2.º, I, da Constituição.

b) A resposta é afirmativa, uma vez que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, do CTN, assegurando ao contribuinte a emissão da certidão de regularidade fiscal.

QUESTÃO 63 – OAB FGV XVII EXAME

A questão busca verificar o conhecimento do examinando sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar.

a) Quanto à alegada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal/noventena, o argumento está correto, por força do art. 150, III, c, da Constituição, não excepcionado, para o IPI, pelo art. 150, § 1.º, da CF/1988.

b) Não há violação ao princípio da legalidade tributária, pois o art. 153, § 1.º, da Constituição faculta ao Poder Executivo, atendidos as

condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IPI.

QUESTÃO 64 – OAB FGV XVII EXAME

A questão aborda o tema contribuinte e a responsabilidade tributária.

a) O examinando deverá indicar que o argumento apresentado pela União não está correto, tendo em vista que a falta de pagamento do tributo não gera, por si só, a responsabilidade do diretor, prevista no art. 135 do CTN. Nesse sentido, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.

b) O examinando deve destacar que, se a execução tivesse sido proposta somente em face da pessoa jurídica, havendo indicação do nome do Diretor na CDA, a União não teria de provar a presença dos requisitos do art. 135 do CTN, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza da CDA, conforme o art. 3.º da Lei 6.830/1980 e/ou o art. 204 do CTN. Admite-se como correta a resposta que indicar que caso o nome de João não constasse da CDA, a União teria de provar a presença de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do CTN ou da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 65 – OAB FGV XVII EXAME

a) Sim, é constitucional o cálculo do valor da taxa de prevenção e extinção de incêndio tendo como parâmetro um dos elementos que compõem a base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU. Embora o art. 145, § 2.º, da Constituição da República e o art. 77, parágrafo único, do CTN estabeleçam que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 29, já consolidou o entendimento de que não viola os referidos dispositivos a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da

base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

b) O Estado X deve efetuar a cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndio, relativa aos exercícios de 2012 e de 2013, diretamente de João, proprietário do imóvel, por ser ele o contribuinte do tributo, conforme disposto na lei estadual. No caso, é irrelevante para a Fazenda Estadual a cláusula constante no contrato de locação celebrado entre as partes, que atribui a responsabilidade pelo pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio exclusivamente a Pedro, locatário do imóvel, ainda que o referido contrato tenha sido registrado no Registro de Imóveis, tendo em vista que, nos termos do art. 123 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

QUESTÃO 66 – OAB FGV XVII EXAME

a) A cobrança feita pelo Município “X” não está correta, tendo em vista que, de acordo com a Súmula 724, do STF, *in verbis*, “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”.

b) A notificação é válida, tendo em vista que “a remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário”. Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)

QUESTÃO 67 – OAB FGV XVIII EXAME

a) Sim, é válida a contribuição. Os Estados podem instituir

contribuição para o custeio do regime previdenciário de seus servidores, conforme o art. 149, § 1.º, da CF/1988.

b) É inconstitucional qualquer outra contribuição compulsória instituída pelos Estados, além daquela exclusivamente voltada ao custeio do regime previdenciário de seus servidores. Portanto, não é válida a contribuição que, no caso proposto, foi instituída pelo Estado Alfa.

QUESTÃO 68 – OAB FGV XVIII EXAME

a) Sim. A capacidade tributária independe da capacidade civil das pessoas naturais. Sendo assim, Caio é contribuinte do IPTU independentemente de não ter capacidade civil. Nesse sentido, o art. 126, inciso I, do CTN.

b) Conforme a Súmula Vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, a exigência de um depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo é inconstitucional, pois fere o art. 5.º, incisos XXXIV (direito de petição independente do pagamento) e LV (assegurados o contraditório e a ampla defesa).

QUESTÃO 69 – OAB FGV XVIII EXAME

a) Não é possível a instituição da base de cálculo no valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica para a taxa em questão, uma vez que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, conforme determina o art. 145, § 2.º, da CF/1988 e o art. 77, parágrafo único, do CTN.

b) Não é possível a apresentação de embargos em execução fiscal sem o oferecimento de garantia, conforme pretendido pelo contribuinte, pois em sede de execução fiscal aplica-se o art. 16, § 1.º, da Lei 6.830/1980, de acordo com o qual não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

QUESTÃO 70 – OAB FGV XVIII EXAME

- a) Não está correto o argumento da União, tendo em vista que, na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado, conforme o art. 186, parágrafo único, I, do CTN.
- b) Sim, a cobrança judicial do crédito tributário pode prosseguir por meio de execução fiscal, já que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, nos termos do art. 187 do CTN. Ademais, de acordo com o art. 5.º da Lei 6.830/1980, a competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência.

QUESTÃO 71 – XIX EXAME UNIFICADO

- a) Trata-se de questão que versa sobre denúncia espontânea. O examinando deverá indicar que, na hipótese, não é cabível a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, pois a COFINS, tributo sujeito a lançamento por homologação, foi regularmente declarada, porém paga a destempo. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 360.
- b) O examinando deverá responder que o contribuinte não tem direito à certidão de regularidade fiscal, isso porque declarou o débito, porém não pagou integralmente, sendo legítima a recusa da emissão da certidão negativa, conforme Súmula 446 do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 72 – XIX EXAME UNIFICADO

- a) Sim, pois a remuneração está sujeita ao IR, uma vez que é produto do trabalho, tal como previsto no art. 43, inciso I, do Código

Tributário Nacional (CTN).

b) Sim, pois a denominação que venha a lhe dar o empregador (ou ex-empregador) não altera sua vinculação com os serviços prestados pelo empregado (ou ex-empregado), conforme previsto pelo art. 43, § 1.º, do CTN.

QUESTÃO 73 – XIX EXAME UNIFICADO

a) O entendimento do Estado de Minas Gerais não está correto, uma vez que, de acordo com o art. 133, II, do Código Tributário Nacional, a pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, estabelecimento comercial e continuar a respectiva exploração sob outra razão social responde pelos tributos relativos ao estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, subsidiariamente com o alienante, se este iniciar, dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ramo de comércio.

b) Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal, quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento, conforme o art. 127, II, do Código Tributário Nacional.

QUESTÃO 74 – XIX EXAME UNIFICADO

a) O Município de Maricá-RJ não agiu corretamente ao editar a Le 1.234, já que cabe à União, por meio de lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição, conforme art. 146, III, *b*, da Constituição Federal.

b) Não é correta a atualização monetária do IPTU em percentual superior aos índices oficiais por ato do Poder Executivo, uma vez que é defeso ao Município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, nos

termos da Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 75 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO EM POI VELHO (RO)

a) Segundo o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. Na indenização por dano moral, inexistente acréscimo patrimonial e, portanto, não é devido o imposto sobre a renda. Nesse sentido, é o teor da Súmula 498, do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”.

b) Na hipótese, como a pessoa física X apresentou impugnação ao auto de infração, hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, inciso III, do CTN, ele terá direito à certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

QUESTÃO 76 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO EM POI VELHO (RO)

a) Sobre a transmissão do sinal de televisão a cabo, quando realizada de forma onerosa, incide ICMS, nos termos do art. 2.º da Lei Complementar 87/1996, por ser considerado serviço de comunicação. No entanto, o ICMS não incide sobre a prestação de serviço de acesso à Internet, por se tratar de serviço de valor adicionado e não de comunicação, nos termos da Súmula 334 do STJ.

b) Não, a substituição de penhora por fiança bancária é direito subjetivo do executado, na forma do art. 15, inciso I, da Lei 6.830/1980 e do art. 835, § 2.º, do CPC/2015.

QUESTÃO 77 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO EM POI VELHO (RO)

a) Não. A cobrança feita pelo Município M não está correta, uma vez que, de acordo com o art. 156, § 1.º, da CRFB/1988, o IPTU somente pode ter alíquotas diferentes de acordo com o valor, a localização e o

uso do imóvel, o que não é o caso.

b) Os embargos não podem ser admitidos, já que, de acordo com o art. 16, § 1.º, da Lei 6.830/1980, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

QUESTÃO 78 – XX EXAME UNIFICADO – REAPLICAÇÃO EM POI VELHO (RO)

a) Sim. O art. 155, § 6.º, inciso II, da CRFB/1988 só admite a diferenciação da alíquota do IPVA em razão do tipo e da utilização do veículo, o que afasta a possibilidade de alíquota diferenciada em razão da origem do bem.

b) O juiz não está correto. A exigência de depósito prévio, como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, é inconstitucional, conforme redação da Súmula Vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 79 – XX EXAME UNIFICADO

a) Não está correta a cobrança da multa, uma vez que, de acordo com o art. 138 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Nesse sentido, o julgamento, pelo STJ, sob o rito dos Repetitivos, do REsp 1.149.022/SP.

b) Não está correta a cobrança do IRPJ referente ao ano calendário de 2008, uma vez que se trata de crédito tributário atingido pela decadência, na forma do art. 173, inciso I, do CTN.

QUESTÃO 80 – XX EXAME UNIFICADO

a) O art. 3.º da Lei Complementar 116/2003 prevê que, em regra, o “serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador”. No entanto, o referido artigo também prevê algumas exceções, quando o imposto será devido no local da execução do serviço. Esse é o caso da prestação dos serviços de decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores (subitem 7.11 da lista anexa – inciso VIII). Sendo assim, na hipótese descrita o imposto será devido no município “C”, local da execução do serviço.

b) A ação consignatória é a ação cabível para solucionar o conflito de competência e titularidade, uma vez que os municípios “C” e “A” estão exigindo ISS sobre o mesmo fato gerador, conforme art. 164, inciso III, do Código Tributário Nacional. Sendo assim, considerando que o contribuinte XYZ Ltda. realizou o depósito do montante integral, o crédito tributário está suspenso, na forma do art. 151, inciso II, do CTN. Dessa forma, considerando que o crédito está com a exigibilidade suspensa, os municípios não podem ajuizar a execução fiscal.

QUESTÃO 81 – XX EXAME UNIFICADO

a) Não está correto o argumento de João, já que a Constituição Federal prevê, em seu art. 149-A, que os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública.

b) Não está correto o argumento, pois a reserva de lei complementar para a definição da base de cálculo e dos contribuintes não se estende às contribuições. De acordo com o art. 146, inciso III, alínea a, da CRFB/1988, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição da República, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Tratando-se de contribuição, como é o caso, é possível que a base de cálculo e o

contribuinte sejam estabelecidos por lei ordinária.

QUESTÃO 82 – XX EXAME UNIFICADO

- a) A resposta é negativa. De acordo com o art. 3.º do CTN, é da essência de um tributo não ter natureza sancionatória.
- b) É negativa a resposta. Só a União tem competência para instituir impostos residuais (isto é, impostos não indicados na própria Constituição da República), conforme o art. 154, inciso I, da CRFB/1988.

QUESTÃO 83 – XXI EXAME UNIFICADO

- a) Não. O empréstimo compulsório só pode ser instituído por meio de lei complementar, conforme o art. 148, *caput*, da CRFB/1988.
- b) Sim. Ao empréstimo compulsório instituído por força de calamidade pública não se aplica a vedação inerente ao princípio da anterioridade do exercício financeiro ou nonagesimal, conforme art. 150, § 1.º, da CRFB/1988.

QUESTÃO 84 – XXI EXAME UNIFICADO

- a) Sim, as custas judiciais são taxas remuneratórias de serviço público específico e divisível e, como tais, estão sujeitas às limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 150 da CRFB/1988 legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade etc.)
- b) Não. O art. 150, inciso II, da CRFB/1988 reconhece a isonomia como uma limitação ao poder de tributar. O referido artigo é expresso ao proibir “qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles [contribuintes] exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. Portanto, a concessão de benefício fiscal para um determinado grupo, em razão da função por ele exercida, viola o princípio de isonomia.

QUESTÃO 85 – XXI EXAME UNIFICADO

a) Não. O art. 155, § 2.º, inciso XII, alínea g, da CRFB/1988 prevê que cabe à lei complementar regular como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos. Trata-se do artigo constitucional mais importante no combate à chamada “guerra fiscal”, que exige que os benefícios fiscais de ICMS sejam concedidos mediante deliberação dos Estados. Conforme o art. 1.º, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 24/1975, os benefícios fiscais relativos ao ICMS serão concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Portanto, a redução de base de cálculo concedida pela primeira lei não é legítima, uma vez que tal benefício somente poderia ter sido aprovado mediante prévia deliberação dos Estados e do Distrito Federal.

b) Não. A alteração do prazo de recolhimento, uma vez que não implica instituição ou majoração de tributos, não está sujeita ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, é o teor da Súmula Vinculante 50, do Supremo Tribunal Federal: “Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”.

QUESTÃO 86 – XXI EXAME UNIFICADO

a) Sim. O Imposto de Importação é exceção ao princípio da legalidade, ou seja, sua alíquota pode ser majorada por meio de ato do Poder Executivo, desde que atendidos as condições e os limites estabelecidos em lei, conforme dispõe o art. 153, §1.º, da CRFB/1988.

b) Sim. Por ser um imposto que tem como função regular o mercado, o Imposto de Importação é exceção ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado e cobrado ao tempo conveniente, conforme o art. 150, § 1.º, da CRFB/1988.

QUESTÃO 87 – XXII EXAME UNIFICADO

- a) O examinando deverá responder que a execução fiscal não deve ser extinta em virtude da falta do demonstrativo de cálculo do débito, eis que, a teor da Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça, em ações de execução fiscal é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6.º da Lei 6.830/1980.
- b) O examinando deverá responder que não, uma vez que a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, conforme Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 88 – XXII EXAME UNIFICADO

- a) O instituto é o da moratória, que é uma das modalidades de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Caracteriza-se por ser uma prorrogação do prazo de pagamento de tributo pelo ente competente para instituí-lo. Está previsto no art. 151, inciso I, e nos artigos 152 a 155, todos do CTN.
- b) Sim, a lei que institui a moratória pode delimitar os sujeitos passivos que dela se beneficiarão, na forma do art. 152, parágrafo único, do CTN.

QUESTÃO 89 – XXII EXAME UNIFICADO

- a) O examinando deverá responder que a cobrança está correta, pois é legítima a exigência do ICMS como condição para a liberação das mercadorias importadas, conforme a Súmula Vinculante 48 ou Súmula 661/STF ou Lei Complementar 87/1996, art. 12, IX, ou parágrafo 2.º.
- b) O examinando deverá responder que a interdição do estabelecimento comercial não está correta, eis que, na forma da Súmula 70 do STF, é inadmissível a interdição de estabelecimento

como meio coercitivo para cobrança de tributo.

QUESTÃO 90 – XXII EXAME UNIFICADO

- a) A obrigatoriedade de adesão ao novo regime é inconstitucional, pois, de acordo com o art. 146, parágrafo único, inciso I, da CRFB/1988, o regime jurídico único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios é opcional para o contribuinte.
- b) Não é possível o estabelecimento das novas regras por meio de lei ordinária, uma vez que cabe à lei complementar definir tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o art. 146, inciso III, alínea d, da CRFB/1988 ou art. 146, parágrafo único, da CRFB/1988.

QUESTÃO 91 – XXIII EXAME UNIFICADO

- a) Sim, já que, de acordo com a Súmula 436 do STJ, “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco,” razão pela qual o prazo prescricional teve início com o vencimento do tributo, em março de 2009, estando a prescrição consumada desde março de 2014.
- b) Não, pois de acordo com o art. 175, parágrafo único, do CTN, a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente.

QUESTÃO 92 – XXIII EXAME UNIFICADO

- a) Não. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo proveniente de imóveis não viola o art. 145, inciso II, da CRFB/1988 por possuírem tais serviços caráter específico e divisível, conforme a Súmula Vinculante 19 do STF.

b) Não. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, conforme a Súmula Vinculante 29 do STF.

QUESTÃO 93 – XXIII EXAME UNIFICADO

a) Sim. A fixação da base de cálculo do IPVA é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, inciso III, alínea c, e o art. 150, § 1.º, ambos da CRFB/1988. Desse modo, a autoridade administrativa pode realizar a cobrança do IPVA de 2017 já com base na nova tabela de valores. Ressalta-se, ainda, que a fixação da base de cálculo do IPVA não é exceção ao princípio da anterioridade do exercício. Desse modo, como a nova lei foi editada em 2016, não há problema em realizar a cobrança pelos novos valores no ano seguinte.

b) A majoração passaria a ser exigível para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2018 (ou do exercício de 2018 e seguintes), pois a alteração da alíquota do IPVA deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, inciso III, alínea c, da CRFB/1988. Desse modo, a majoração da alíquota promovida em novembro de 2016 somente passaria a ser aplicável a partir de fevereiro de 2017, após a ocorrência do fato gerador do IPVA de 2017.

QUESTÃO 94 – XXIII EXAME UNIFICADO

a) Não. A impugnação administrativa é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o fisco inscreva o crédito tributário em dívida ativa, na forma do art. 151, inciso III, c/c o art. 201, ambos do CTN.

b) Não. Deve ser aplicada ao contribuinte a penalidade da lei mais benéfica, no percentual de 15%, na forma do art. 106, inciso II, alínea

“c”, do CTN.

QUESTÃO 95 – XXIV EXAME UNIFICADO

a) O tributo não é devido por duas razões: primeiro porque sua previsão tem natureza sancionatória e, com isso, viola o conceito de tributo do art. 3.º do CTN (“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”); segundo, sob a roupagem de “adicional”, criou-se verdadeiro tributo novo, para o qual só a União tem competência, e, ainda assim, com observância dos requisitos do art. 154, inciso I, da CRFB/1988.

b) O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393, consolidou o cabimento da exceção de pré-executividade: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Na hipótese, a matéria a ser alegada por Caio em sua defesa (impossibilidade de cobrança do adicional do IPVA por se tratar de sanção por ato ilícito) é conhecível de ofício. Caio possui todos os documentos que comprovam sua defesa, o que não demandaria dilação probatória. Sendo assim, o meio de defesa possível para Caio é a Exceção de pré-executividade.

QUESTÃO 96 – XXIV EXAME UNIFICADO

a) Não, pois, embora o IPI não se submeta à anterioridade de exercício financeiro, está sujeito à anterioridade nonagesimal, na forma do disposto no art. 150, § 1.º, da CRFB/1988.

B) Não, pois a norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, conforme Súmula Vinculante 50 do STF.

QUESTÃO 97 – XXIV EXAME UNIFICADO

a) Sim. A incidência do IPI na importação de veículo para uso próprio, por pessoa física, é legítima, uma vez que a destinação final do bem não é relevante para a definição da incidência do tributo. Dessa forma, conforme o art. 51, inciso I, do CTN, o importador do produto industrializado é o contribuinte do IPI na importação. Nesse sentido há precedente do STF com Repercussão Geral (RE 723.651) decidindo pela incidência do IPI na importação de produtos destinados a um consumidor final.

b) Sim. Conforme o art. 155, § 2.º, inciso IX, alínea *a*, da CRFB/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 33/2001, incide ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Nesse sentido há precedente do STF com Repercussão Geral (RE 439.796), decidindo pela incidência do ICMS inclusive sobre as operações de importação realizadas por quem não seja comerciante, tema que também é objeto da Súmula Vinculante 48.

QUESTÃO 98 – XXIV EXAME UNIFICADO

a) Sim, pois a tentativa de colocar bens em nome de terceiros é uma das hipóteses que autoriza a medida cautelar fiscal antes da constituição definitiva do crédito tributário, conforme o art. 1.º, parágrafo único, e/ou o art. 2.º, inciso V, alínea *b*, ambos da Lei 8.397/1992.

b) Não, pois, quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a Fazenda Pública propor a execução judicial da dívida ativa no prazo de sessenta dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa, conforme art. 11 da Lei 8.397/1992.

QUESTÃO 99 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICAÇÃO EM POA ALEGRE

a) Sim. O prazo de pagamento não representa majoração do tributo, razão pela qual não se sujeita ao princípio da legalidade, conforme o art. 150, inciso I, da CRFB/88 E/OU o art. 97 do CTN.

b) Não. A alteração do prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade do exercício financeiro (anterioridade geral), nem ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Súmula Vinculante 50.

QUESTÃO 100 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICAÇÃO EM POE ALEGRE

a) Sim a multa de mora é devida. A questão trata do alcance da denúncia espontânea disciplinada pelo art. 138 do CTN. O examinando deverá indicar que não é cabível a denúncia espontânea para tributos sujeitos a homologação e regularmente declarados, ainda que pagos a destempo, consoante a Súmula 360 STJ.

b) No caso, como o procedimento foi iniciado pelo Fisco, o art. 138, parágrafo único, do CTN prevê que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de procedimento administrativo.

QUESTÃO 101 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICAÇÃO EM POE ALEGRE

a) Sim, de acordo com o art. 126, inciso I, do CTN, a capacidade tributária não depende da capacidade civil das pessoas naturais.

b) Na esfera administrativa, é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou outra forma de garantia, conforme preceitua a Súmula Vinculante 21 do STF.

QUESTÃO 102 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICAÇÃO EM POE ALEGRE

a) Sim, de acordo com o art. 126, inciso I, do CTN, a capacidade tributária não depende da capacidade civil das pessoas naturais.

b) Na esfera administrativa, é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou outra forma de garantia, conforme preceitua a Súmula Vinculante 21 do STF.

QUESTÃO 103 – XXV EXAME UNIFICADO – APLICAÇÃO EM POA ALEGRE

a) Sim, Eduardo está correto. Conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN, no caso de arrematação de bem em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Assim, todos os impostos incidentes sobre a propriedade do imóvel deverão ser descontados do preço pago pelo arrematante do bem.

b) Eduardo não está correto. Conforme o art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Ou seja, contratos privado não têm força para alterar o sujeito passivo definido pela lei. No caso, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel.

QUESTÃO 104 – XXV EXAME UNIFICADO

a) Não. O art. 168 do CTN determina que o direito de pleitear a restituição se extingue com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, que, no caso em questão, operou-se com o pagamento do imposto pelo contribuinte.

b) Não. A incidência da taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais só seria possível se estivesse prevista na legislação local como índice de atualização de tributos inadimplidos e, de todo modo, seria inviável sua cumulação com juros de mora, na forma da Súmula 523 do STJ.

QUESTÃO 105 – XXV EXAME UNIFICADO

a) Não. A imunidade da renda dos partidos políticos, prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da CRFB/1988 não alcança as contribuições

sociais, mas tão somente os impostos.

b) Sim. O parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo decadencial não restabelece o crédito tributário, uma vez que já estava extinto por força da decadência. Essa é a orientação pacificada pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, na qual foi consolidada a orientação de que “A decadência, consoante a letra do art. 156, inciso V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolancamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer”.

QUESTÃO 106 – XXV EXAME UNIFICADO

a) Não. A partir da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 185 do CTN, a caracterização da fraude à execução prescinde do ajuizamento da execução fiscal, com a ciência válida do executado. O momento da inscrição válida em Dívida Ativa da União passa a ser o momento a partir do qual se pode arguir a fraude à execução.

b) Não. Nos termos do art. 185, parágrafo único, do CTN, ocorrendo a reserva, pelo devedor, de bens ou rendas suficientes ao integral pagamento da dívida tributária inscrita, não se aplica o disposto no art. 185, *caput*, do CTN, que disciplina a hipótese de fraude à execução tributária

QUESTÃO 107 – XXV EXAME UNIFICADO

a) O aproveitamento do crédito do ICMS é autorizado pelo princípio da não cumulatividade, nos termos do art. 155, § 2º, inciso I, da CRFB/1988.

b) Não. O comerciante que adquire mercadoria cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) tenha sido posteriormente declarada inidônea é considerado terceiro de boa-fé, o que autoriza o

aproveitamento do crédito do ICMS, nos termos da Súmula 509 do STJ.

QUESTÃO 108 – XXVI EXAME UNIFICADO

- a) O município não está correto. O sindicato dos trabalhadores tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea *c*, da CRFB/1988, inclusive com relação a imóveis alugados, se o aluguel for revertido para suas atividades fins, conforme a Súmula Vinculante 52.
- b) Sim, pois o direito à imunidade tributária é limitado aos sindicatos de trabalhadores, não constando os sindicatos patronais no rol taxativo das entidades imunes, conforme o art. 150, inciso VI, alínea *c*, da CRFB/1988.

QUESTÃO 109 – XXVI EXAME UNIFICADO

- a) Sim. Nos termos do art. 132 do CTN, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado incorporadas, conforme interpretado pela Súmula 554 do STJ: “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão”.
- b) Não. Os sócios administradores da sociedade incorporadora não podem ser pessoalmente responsabilizados. Para que houvesse responsabilidade pessoal, seria necessário que, à época dos fatos que ensejaram a aplicação de multa punitiva, fossem administradores da sociedade incorporada. Somente são pessoalmente responsáveis aqueles que praticarem atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (art. 135, *caput*, do CTN). Ademais, o art. 137 do CTN, que trata de responsabilidade por infrações, não

cria responsabilidade pessoal do agente pelo mero fato de ser sócio administrador de sociedade incorporadora. Portanto, apenas a sociedade incorporadora, com seu patrimônio, responde por esses débitos em razão da sucessão de empresas.

QUESTÃO 110 – XXVI EXAME UNIFICADO

a) Sim. Nos termos do art. 132 do CTN, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado incorporadas, conforme interpretado pela Súmula 554 do STJ: “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão”.

b) Não. Os sócios administradores da sociedade incorporadora não podem ser pessoalmente responsabilizados. Para que houvesse responsabilidade pessoal, seria necessário que, à época dos fatos que ensejaram a aplicação de multa punitiva, fossem administradores da sociedade incorporada. Somente são pessoalmente responsáveis aqueles que praticarem atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (art. 135, *caput*, do CTN). Ademais, o art. 137 do CTN, que trata de responsabilidade por infrações, não cria responsabilidade pessoal do agente pelo mero fato de ser sócio administrador de sociedade incorporadora. Portanto, apenas a sociedade incorporadora, com seu patrimônio, responde por esses débitos em razão da sucessão de empresas.

QUESTÃO 111 – XXVI EXAME UNIFICADO

a) Não. Conforme a Súmula 112 do STF, o ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, que ocorre no exato momento da morte. Em outras palavras, o momento da abertura da sucessão definirá a legislação aplicável ao lançamento do ITCMD.

b) Não. Conforme a Súmula 113 do STF, o ITCMD é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação, portanto está correto o Fisco em atribuir aos imóveis o valor atual.

QUESTÃO 112 – XXVI EXAME UNIFICADO

a) Não. Conforme a Súmula 112 do STF, o ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, que ocorre no exato momento da morte. Em outras palavras, o momento da abertura da sucessão definirá a legislação aplicável ao lançamento do ITCMD.

b) Não. Conforme a Súmula 113 do STF, o ITCMD é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação, portanto está correto o Fisco em atribuir aos imóveis o valor atual.

QUESTÃO 113 – XXVII EXAME UNIFICADO

b) A autuação não é correta, pois é inconstitucional a incidência de ISS sobre a locação de bens móveis, já que a locação não configura prestação de serviço (Súmula Vinculante 31: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”).

B) Sim. O Município pode utilizar a espécie normativa de uma lei ordinária municipal para instituir fatos geradores de ISS em seu território, desde que tais fatos geradores estejam devidamente previstos na LC 116/2003 (Lei Complementar de caráter nacional exigida pelo art. 156, inciso III, da CRFB/1988). Os serviços de aplicação de tatuagens, *piercings* e congêneres foram inseridos na Lista de Serviços Anexa à LC 116/2003 (item 6.06) por força da LC 157, de 29/12/2016. Portanto, é legal a cobrança referida no enunciado.

Não se confunda a exigência de lei complementar de caráter nacional para veicular a previsão abstrata da lista de serviços anexa à LC 116/2003, com a efetiva instituição dos fatos geradores de ISS em

cada município, que se faz por lei ordinária municipal, que escolherá as hipóteses de incidência dentre aquelas previstas na lista de serviços anexa à LC 116/2003.

QUESTÃO 114 – XXVII EXAME UNIFICADO

a) Sim, a exigência está correta. Embora o ISS, como regra geral, seja devido no local do estabelecimento prestador, o imposto será devido no local da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, conforme exceção prevista no art. 3º, inciso II, da LC 116/2003.

b) Ação de consignação em pagamento, conforme o art. 164, inciso III, do CTN: “A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador”.

QUESTÃO 115 – XXVII EXAME UNIFICADO

a) A montadora é responsável tributária na modalidade de “substituta” (substituição tributária), nos termos do art. 128 do CTN: “Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

b) Em regra, a montadora não possui legitimidade para pleitear a repetição de indébito tributário, pois transferiu o encargo financeiro a terceiros, salvo se destes terceiros obtiver a autorização para pedir a restituição do tributo, como estabelece o art. 166 do CTN. No caso, o ICMS é um tributo indireto que comporta tal transferência por previsão legal. A montadora inseriu na Nota Fiscal o valor do ICMS recolhido, transferindo-o para terceiros. Somente se tivesse a

autorização dos terceiros ela teria legitimidade. Assim também a Súmula 546 do STF: “Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo”.

QUESTÃO 116 – XXVII EXAME UNIFICADO

a) Sim. Nos termos do art. 6º do CTN, a atribuição constitucional de competência tributária é plena, ressalvados os limites ali estabelecidos. Todavia, a competência legislativa é indelegável, a teor do art. 7º do CTN, sendo, portanto, ilegal o IPVA que vier a ser instituído por lei municipal. Dessa forma, a empresa Sigma encontra respaldo jurídico no referido art. 7º do CTN.

b) Não. Embora o art. 7º do CTN vede a delegação de competência legislativa, o mesmo dispositivo legal faz ressalva expressa à delegação das atividades de arrecadação e de fiscalização do tributo

QUESTÃO 117 – XXVIII EXAME UNIFICADO

a) Sendo frustrada a citação na execução fiscal feita primeiro pelo correio, os meios disponíveis são por Oficial de Justiça e por edital (art. 8º, inciso III, da Lei 6.830/1980).

b) A consequência será a responsabilidade tributária do sócio administrador pela prática de um ato com infração de lei (art. 135, inciso III, do CTN), a saber, o ato de dissolução irregular da sociedade, a qual é presumida quando a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, enseja o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador (Súmula 435 do STJ).

QUESTÃO 118 – XXVIII EXAME UNIFICADO

a) Não. Bruno e Thiago são solidariamente obrigados ao pagamento do IPTU por terem comum interesse no bem, diante da

copropriedade, na forma do art. 124, inciso I, do CTN OU do art. 34 do CTN.

b) Não. A fixação de nova base de cálculo do IPTU apenas deve respeitar a anterioridade do exercício financeiro, estando excepcionada da anterioridade nonagesimal, na forma do art. 150, § 1º, da CRFB/1988.

QUESTÃO 119 – XXVIII EXAME UNIFICADO

a) A ação deverá ser proposta em face do Estado “X”, que é o responsável pela retenção na fonte e destinatário do valor do IRPF no caso, já que se trata de servidora pública integrante de seus quadros, de acordo com o art. 157, I, da CRFB/1988 ou com a orientação da Súmula 447 do STJ.

b) Não. A competência tributária é da União, seja para instituir imposto sobre renda e proventos, seja sob a perspectiva da competência residual, na forma do art. 153, inciso III, ou do art. 154, I, ambos da CRFB/1988.

QUESTÃO 120 – XXVIII EXAME UNIFICADO

a) Não. A progressividade de alíquotas está de acordo com a CRFB/1988. Isso porque no Imposto sobre a Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCD) é possível aferir a capacidade contributiva do contribuinte do tributo, nos termos do art. 145, § 1º, da CRFB/1988. O ITCD é devido pelo contribuinte beneficiário de bem ou direito transmitido, implicando em um acréscimo patrimonial gratuito. Nesse sentido, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral no RE 562.045, julgou constitucional a progressividade de alíquotas do ITCD.

b) O imposto é devido, nos casos de bens imóveis, no Estado da situação do bem, ou seja, o Estado “X”, conforme o art. 41 do CTN ou o art. 155, § 1º, inciso I, da CRFB/1988.

SEXTA PARTE

DECISÕES JURISPRUDENCIAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA

EMENTÁRIO JURISPRUDENCIAL

Grande parte das teses em matéria tributária leva em consideração a jurisprudência, não apenas sumulada, mas pacificada nos Tribunais Superiores.

Com o fito de auxiliar no estudo dos candidatos da OAB e concursos públicos no geral, seguem as principais jurisprudências do STF e STJ.

A) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

- **Art. 155, § 3.º, da CF: imunidade e taxa**

Ante a vedação prevista no texto primitivo do art. 155, § 3.º, da CF, anterior à alteração decorrente da EC 33/2001, a 1.ª Turma desproveu recurso extraordinário interposto contra acórdão em que assentada a ilegalidade da cobrança pela Municipalidade de Taxa de Licença e Verificação Fiscal. Reputou-se descaber afastar da imunidade a mencionada taxa alusiva à fixação de postes ao solo para a sustentação de rede elétrica. Concluiu-se que, na redação primitiva da CF, a imunidade seria linear.

RE 391.623/MA, j. 02.12.2010, rel. Min. Marco Aurélio (RE 391623, Informativo 611, 1.ª Turma).

- **Imunidade tributária recíproca: sociedade de economia mista e serviços de saúde – 1**

Em conclusão, o Plenário, por maioria, proveu recurso extraordinário para assentar a incidência da imunidade recíproca (CF, art. 150, VI, *a*) de impostos estaduais à sociedade de economia mista recorrente, a qual atua na área de prestação de serviços de saúde – v. Informativo 597. Inicialmente, ao salientar o disposto no art. 197 da CF, consignou-se que o serviço público em questão estaria franqueado à

iniciativa privada sob a forma de assistência à saúde, não constituindo atividade econômica. Portanto, a iniciativa privada seria convocada para subsidiar o Poder Público, para se emparceirar com ele, na prestação de serviço público que, ao mesmo tempo, seria direito fundamental e, pela ótica do art. 196 da CF, direito de todos e dever do Estado. Realçou-se a heterodoxia do caso, porquanto, desde a década de 1970, o Estado, por desapropriação, seria detentor do controle dessa “empresa”, assenhoreando-se da atividade, prestando-a ininterruptamente, e controlando 99,99% das ações. Enfatizou-se que o hospital recorrente atenderia exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS e que suas receitas seriam provenientes de repasse públicos federais e municipais. Considerou-se, ademais, que o serviço de saúde por ele prestado teria caráter de serviço público, não configurando um negócio privado. Reiterou-se que a União teria expropriado praticamente a totalidade do capital social e, com isso, incorporado de fato o hospital ao seu patrimônio jurídico, conservando, por motivos desconhecidos, 0,01% do capital social em nome de conselheiros antigos. Dessa forma, teria mantido a aparência de uma sociedade anônima que se submeteria, de regra, ao regime jurídico de empresa privada. Afirmou-se que isso, entretanto, não seria suficiente, pois se trataria, na verdade, de uma entidade pública por ser pública praticamente a totalidade do capital social, pública sua finalidade e pública no sentido de potencialidade de exercício de poder a direção do hospital, haja vista que a União poderia decidir o que quisesse, porque 0,01% não significaria nada em termos de votação. Por fim, registrou-se que o pronunciamento da questão posta em sede de repercussão geral somente aproveitará hipóteses idênticas, em que o ente público seja controlador majoritário do capital da sociedade de economia mista e que a atividade desta corresponda à própria atuação do Estado na prestação de serviços à população. Vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, relator, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que desproviavam o recurso.

RE 580.264/RS, j. 16.12.2010, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, rel. p/ o acórdão Min. Ayres Britto (RE 580264) (Informativo 613, Plenário, Repercussão Geral) Princípios Constitucionais Tributários.

• **Imunidade tributária: Art. 150, VI, d, da CF e peças sobressalentes – 2**

A imunidade tributária conferida a livros, jornais e periódicos abrange todo e qualquer insumo ou ferramenta indispensável à edição de veículos de comunicação. Com base nessa orientação, a 1.^a Turma, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário no qual discutida a abrangência normativa da imunidade tributária do art. 150, VI, d, da CF (“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ac

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (...) VI – instituir impostos sobre: (...) d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão”). No caso, a União sustentava a exigibilidade do imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, do imposto sobre produto industrializado – IPI e do imposto de importação – II, no despacho aduaneiro de peças sobressalentes de equipamento de preparo e acabamento de chapas de impressão *off set* para jornais – v. Informativo 6. A Min. Cármen Lúcia, ao desempatar a votação, ressaltou que o entendimento firmado asseguraria e homenagearia o princípio da liberdade de imprensa. Vencidos os Ministros Menezes Direito, relator, e Ricardo Lewandowski.

RE 202.149/RS, j. 26.04.2011, rel. orig. Min. Menezes Direito, rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio (RE 202149) (Informativo 624, 1.ª Turma).

• **Art. 150, VI, b e c, da CF: maçonaria e imunidade tributária – 3**

As organizações maçônicas não estão dispensadas do pagamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU. Essa a conclusão da 1.ª Turma ao conhecer, em parte, de recurso extraordinário e, por maioria, negar-lhe provimento. Na espécie, discutia-se se templos maçônicos se incluíam no conceito de “templos de qualquer culto” ou de “instituições de assistência social” para fins de concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b e c, da CF [“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”] — v. Informativo 582. Entendeu-se que o enquadramento da recorrente na hipótese de imunidade constitucional seria inviável, consoante o Verbete 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) Aludiu-se, ainda, à observância do art. 14 do CTN para que pudesse existir a possibilidade do gozo do benefício, matéria que não possuiria índole constitucional. Pontuou-se que a maçonaria seria uma ideologia de vida e não uma religião.

RE 562.351/RS, j. 04.09.2012, rel. Min. Ricardo Lewandowski (RE 562351, Informativo 678, 1.ª Turma).

• **Art. 150, VI, b e c, da CF: maçonaria e imunidade tributária – 4**

Vencido o Min. Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso para reconhecer o direito à imunidade tributária dos templos em que realizados os cultos da recorrente. Sustentava que, diversamente das isenções tributárias, que configurariam favores fiscais do Estado, as imunidades decorreriam diretamente das liberdades, razão pela qual mereceriam interpretação, no mínimo, estrita. Frisava não caber potencializar o disposto no art. 111, II, do CTN – que determinaria a interpretação literal da legislação tributária que dispusesse sobre outorga de isenção –, estendendo-o às imunidades. Destacava que a Constituição não teria restringido a imunidade à prática de uma religião, mas apenas àquele ente que fosse reconhecido como templo de qualquer culto. Asseverava que, em perspectiva menos rígida do conceito de religião, certamente se conseguiria classificar a maçonaria como corrente religiosa, que contemplaria física e metafísica. Explicava haver inequívocos elementos de religiosidade na maçonaria. Presumia conceito mais largo de religião, até mesmo em deferência ao art. 1.º, V, da CF, que consagraria o pluralismo como valor basilar da República. Realçava que o pluralismo impediria que o Poder Judiciário adotasse definição ortodoxa de religião.

RE 562.351/RS, j. 04.09.2012, rel. Min. Ricardo Lewandowski (RE 562351).

• **Cooperativa: imunidade tributária e IPMF**

Inexistente legislação complementar regulamentadora de tratamento diferenciado às cooperativas, não se lhes reconhece imunidade tributária relativamente ao extinto Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira – IPMF. Essa a conclusão da 2.ª Turma ao desprover agravo regimental de decisão do Min. Gilmar Mendes, em que negado seguimento a agravo de instrumento, do qual relator. Os ora agravantes sustentavam que os artigos 146, III, c, e 174, § 2.º, da CF seriam autoaplicáveis e que o Supremo teria reconhecido a repercussão geral do tema no RE 599.362/RJ (*DJe* de 13.12.2010). Reputou-se não demonstrado o desacerto da decisão ora agravada. Por fim, verificou-se que a matéria em análise não guardaria similitude com o paradigma de repercussão geral apontado, que cuidaria da incidência da contribuição para o PIS sobre o ato cooperativo ou cooperado.

AI 740.269 AgR/SP, j. 18.9.2012, rel. Min. Gilmar Mendes (AI 740269).

• **Entidade de previdência privada e imunidade tributária**

A 1.ª Turma, por maioria, proveu agravo regimental em recurso extraordinário para restabelecer posicionamento de que a agravante, entidade de previdência privada, gozaria de imunidade tributária garantida pela Constituição. Na espécie,

consta do acórdão recorrido, objeto do extraordinário, que “De início, deve-se examinar se a remuneração dos serviços prestados descaracteriza a impetrante como instituição de assistência social. (...) Observe-se que a cobrança dos serviços prestados pelas entidades em tela não as descaracteriza como assistenciais, pois a gratuidade não constitui requisito previsto tanto pela Constituição Federal como por lei complementar”. Na monocrática ora adversada, afastara-se a imunidade, por entender afirmado no acórdão que a mencionada sociedade prestaria serviços a seus associados mediante pagamento de contribuição. Prevaleceu o voto do Min. Marco Aurélio. Inferiu inexistir assertiva na decisão do Tribunal *a quo* àquele respeito. Ato contínuo, consignou haver reiterados pronunciamentos do Supremo no sentido de que a entidade agravante seria detentora de imunidade tributária. Complementou que não se poderia ter descompasso em determinados processos, reconhecendo-se essa imunidade, porque não haveria contribuição dos beneficiários para a manutenção do próprio benefício, e, em outros, ter-se decisão diversa. Ante o contexto, entendeu que a ela conferir-se-ia imunidade tributária, consoante o Verbete 730 da Súmula do STF (“A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários”). Vencido o Min. Dias Toffoli, relator, que desprovia o agravo.

RE 163.164 AgR/SP, j. 12.06.2012, rel. orig. Min. Dias Toffoli, rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio (RE 163164).

• **Fundação educacional e certificado de entidade beneficente – 1**

Em conclusão, a 1.^a Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança no qual fundação educacional pretendia afastar decisão do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social que, ao manter decisão do Conselho Nacional de Assistência Social, teria cancelado seu certificado de entidade beneficente de assistência social relativo ao período de 1.º.01.1998 a 31.12.2000. O fundamento do ato coator seria a não aplicação de 20% da receita bruta da recorrente em gratuidade conforme exigência prevista no inciso IV do art. 2.º do Dec. 752/1993 [revogado pelo Dec. 2.536/1998] c/c o art. 2.º, III, da Res. 46/1994, daquele Ministério – *vide* Informativo 611. Preliminarmente, não se conheceu da impetração na parte em que se alegava quebra de isonomia tributária, ao se exigir que a recorrente aplicasse 20% de sua receita bruta em gratuidade, e ocorrência de tributação *in natura* ofensiva à imunidade do art. 195, § 7.º, da CF, por entender que seriam questões novas, não objeto do mandado de segurança e do acórdão recorrido.

RMS 28.456/DF, j. 22.05.2012, rel. Min. Cármen Lúcia (RMS 28456).

• **Fundação educacional e certificado de entidade beneficente – 2**

Destacou-se que o ato coator dataria de 11.03.2008 e que estariam em vigor, quando da renovação do certificado, as Leis 8.742/1993 e 8.909/1994 e o Dec. 2.536/1998, que revogara [revogado pelo Dec. 7.237/2010] o Dec. 752/1993. Não obstante, o cancelamento do certificado da ora recorrente teria sido mantido com fundamento no Dec. 752/1993 e na Res. 46/1994, do Ministério da Previdência e Assistência Social. Registrou-se vigorar sobre a matéria, hoje, a Lei 12.101/2009 – que alterara a Lei 8.742/1993 e revogara o art. 55 da Lei 8.212/1991 –, cujo art. 13 manteria a obrigatoriedade de aplicação de pelo menos 20% da receita bruta anual da entidade de educação em gratuidade. Rejeitou-se a assertiva de violação ao art. 150, I, da CF, porque o princípio da legalidade tributária diria respeito à exigência de lei para instituição ou aumento de tributos, o que não se teria. Na espécie, reputou-se que lei instituiria requisito a ser cumprido por entidade beneficente para obtenção do mencionado certificado. Realçou-se que, quanto à renovação periódica do certificado de entidade beneficente, esta Corte decidira não haver imunidade absoluta nem afronta ao art. 195, § 7.º, da CF, ao se estabelecer essa exigência.

RMS 28.456/DF, j. 22.05.2012, rel. Min. Cármen Lúcia (RMS 28456).

• **Imunidade tributária e obrigação acessória – 3**

Exigir de entidade imune a manutenção de livros fiscais é consentâneo com o gozo da imunidade tributária. Essa a conclusão da 1.ª Turma ao negar provimento a recurso extraordinário no qual o recorrente alegava que, por não ser contribuinte do tributo, não lhe caberia o cumprimento de obrigação acessória de manter livro de registro do ISS e autorização para a emissão de notas fiscais de prestação de serviços – v. Informativo 662. Na espécie, o Tribunal de origem entendera que a pessoa jurídica de direito privado teria direito à imunidade e estaria obrigada a utilizar e manter documentos, livros e escrita fiscal de suas atividades, assim como se sujeitaria à fiscalização do Poder Público. Aludiu-se ao Código Tributário Nacional (“Art. 14. C disposto na alínea c do inciso IV do art. 9.º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: (...) III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”). O Min. Luiz Fux explicitou que, no Direito Tributário, inexistiria a vinculação de o acessório seguir o principal, porquanto haveria obrigações acessórias autônomas e obrigação principal tributária. Reajustou o voto o Min. Marcc

Aurélio, relator.

RE 250.844/SP, j. 29.05.2012, rel. Min. Marco Aurélio (RE 250844).

• **Contribuições**

Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados.

Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados. Precedentes citados: *REsp 874.179-RJ, DJe 14.9.2010, e REsp 987.342-PR, DJe 12.5.2011.*

AgRg no AREsp 176.420-MG, j. 13.11.2012, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre valores recebidos em execução judicial.

É devida a retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público – PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo. Isso porque o desconto na fonte, realizado nos termos do art. 16-A da Lei 10.887/2004, constitui obrigação *ex lege*. Precedentes citados: *REsp 1.196.777-RS, DJe 4.11.2010 e REsp 1.196.778-RS, DJe 4.11.2010.*

EDcl no AgRg no REsp 1.266.616-RS, j. 20.11.2012, rel. Min. Humberto Martins.

Direito tributário. Contribuição previdenciária retida na fonte.

A determinação de retenção na fonte da contribuição previdenciária, na forma e pelo modo estabelecido no art. 16-A da Lei 10.887/2004, nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor. Com isso, o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito. Precedente citado: *EDcl no REsp 1.196.778-RS, DJe 7.6.2011.*

EDcl no AgRg no REsp 1.266.616-RS, j. 20.11.2012, rel. Min. Humberto Martins.

• **CSLL: EC 10/1996 e anterioridade nonagesimal – 1**

É indevida a cobrança da contribuição social sobre lucro líquido – CSLL, tal como exigida pela EC 10/1996, relativamente ao período de 1.º.01.1996 a 06.06.1996, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Essa a conclusão do Plenário ao desprover recurso extraordinário no qual a União sustentava a possibilidade dessa exação já a partir de janeiro de 1996. Rejeitou-se, de início, a tese da recorrente no sentido de que o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no § 6.º do art. 195 da CF (“As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b”), não se aplicaria ao poder constituinte derivado. Enfatizou-se que esse poder não seria ilimitado, submetendo-se ao que fixado no art. 60 da CF. Registrou-se, ademais, que o princípio da anterioridade nonagesimal configuraria uma garantia individual e, como consequência, cláusula pétrea, não passível de supressão por emenda constitucional.

RE 587.008/SP, j. 02.02.2011, rel. Min. Dias Toffoli. (RE 587008) (Informativo 614, Plenário, Repercussão Geral)

• **CSLL: EC 10/1996 e anterioridade nonagesimal – 2**

Em seguida, assinalou-se que a controvérsia teria origem na Emenda Constitucional de Revisão – ECR 1/1994, que, ao instituir o Fundo Social de Emergência para os exercícios de 1994 e 1995, estabeleceu como parcela integrante desse fundo o produto da arrecadação que resultara da elevação da alíquota da CSLL para 30%, exclusivamente para os contribuintes por ela mencionados (ADCT, art. 72, III), dentre os quais a recorrida, empresa de arrendamento mercantil. Ocorre que depois de expirado o prazo de vigência da aludida ECR, sobreviera, em 04.03.1996, a EC 10/1996, a qual, em seu art. 2.º, alterara a redação do art. 72, III, do ADCT para estender a cobrança da CSLL “bem assim no período de 1.º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997”. Reputou-se que, embora o objetivo da emenda questionada tivesse sido a não interrupção de vigência do referido inciso III, no caso, não houvera mera prorrogação, pois ocorrera solução de continuidade entre o término do prazo de vigência da ECR 1/1994 e a promulgação da EC 10/1996. Enfatizou-se que a expressão em apreço procedera da demora na tramitação da emenda. Assim, destacou-se que, vencido o prazo de vigência daquela, a contribuinte passara a recolher o tributo à alíquota de 18% (Lei 9.249/1995, art. 19, parágrafo único). Entendeu-se que a EC 10/1996 seria um novo texto, veiculador de norma nova e retroativa a janeiro de 1996, devendo, pois, respeitar o princípio da anterioridade

nonagesimal, haja vista que teria havido majoração da alíquota da CSLL.

RE 587.008/SP, j. 02.02.2011, rel. Min. Dias Toffoli. (RE 587008) (Informativo 614, Plenário, Repercussão Geral).

• **Dec.-lei 2.052/1983 e contribuintes do Pasep**

Em conclusão de julgamento, o Plenário, ao prover recurso extraordinário, declarou a inconstitucionalidade do art. 14, VI (inciso com execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da CF/1988, pela Res. 5, de 21.03.2013), do Dec.-lei 2.052/1983, que inclui, como contribuintes do Pasep, “quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público”. Na espécie, companhia de seguros questionava acórdão que decidira pelo seu enquadramento como contribuinte do Pasep, por ser ela controlada pelo Poder Público – v. Informativo 402. Preliminarmente, por maioria, conheceu-se do recurso, vencido, no ponto, o Min. Marco Aurélio, que entendia haver questão relativa ao próprio sistema, a exigir, em primeiro lugar, o pronunciamento do STJ para, após, ser julgado, se não prejudicado pela decisão daquele tribunal, o extraordinário simultaneamente interposto. No mérito, reputou-se que o PIS e, da mesma forma, o Pasep – por ter perdido a natureza tributária a partir da EC 8/1977 e não se inserir no âmbito das finanças públicas – não poderia ser alterado por decreto-lei.

RE 379.154/RS, j. 23.02.2011, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa (RE 379154) (Informativo 617, Plenário).

• **ED: vale-transporte e contribuição previdenciária**

O Plenário acolheu embargos declaratórios para esclarecer que a inconstitucionalidade do art. 4.º da Lei 7.418/1985 e do art. 5.º do Dec. 95.247/1987 seria tão somente para efeitos fiscais, portanto, exclusivamente com o intuito de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em pecúnia, a título de vale-transporte pelo recorrente aos seus empregados – v. Informativo 578. Asseverou-se, também, o recebimento dos embargos sem alteração do teor daquele outro julgamento.

RE 478.410 ED/SP, j. 15.12.2011, rel. Min. Luiz Fux (RE 478410) (Informativo 652, Plenário).

• **PIS e Cofins: vendas a prazo inadimplidas – 1**

A contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins são exigíveis no que se refere a vendas

a prazo inadimplidas, ou seja, cujos valores faturados não tenham sido recebidos. Essa a conclusão do Plenário ao, por maioria, negar provimento a recurso extraordinário em que se argumentava, em síntese, que para o recolhimento mensal das aludidas contribuições, como regra geral, as empresas seriam obrigadas a escriturar como receitas o total das vendas faturadas, independentemente de seu efetivo recebimento, o que as vincularia, em face do regime contábil adotado, ao pagamento do PIS e da Cofins também sobre valores não ingressados em suas contas como na hipótese de vendas inadimplidas. Nesses casos, portanto, não haveria demonstração de capacidade contributiva efetiva, vedada a tributação de parcelas que não exteriorizassem a riqueza do contribuinte, por inexistir substrato econômico.

RE 586.482/RS, j. 23.11.2011, rel. Min. Dias Toffoli (RE-586482) (Informativo 649, Plenário, Repercussão Geral).

• **PIS e Cofins: vendas a prazo inadimplidas – 2**

Inicialmente, constatou-se que a Corte teria firmado entendimento no sentido de que os fatos geradores do PIS e da Cofins seriam as operações econômicas exteriorizadas no faturamento (sua base de cálculo). Ademais, consideraria que “faturamento” envolveria não só “emitir faturas”, mas também o resultado das operações empresariais do agente econômico, assim compreendido como receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer natureza. Reputou-se que o Sistema Tributário Nacional fixara o regime de competência como regra geral para apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa. Pelo primeiro, haveria o reconhecimento simultâneo das receitas e das despesas realizadas, como consequência natural do princípio da competência do exercício, considerando-se realizadas as receitas e incorridas as despesas no momento da transferência dos bens e da fruição dos serviços prestados, independentemente do recebimento do valor correspondente. Afirmou-se que essa sistemática seria confirmada pelos arts. 177 e 187, § 1.º, *a*, da Lei 6.404/1976, bem como pelo art. 9.º da Res. 750/1993, do Conselho Federal de Contabilidade. Nesse contexto, aduziu-se que as mutações patrimoniais decorreriam de relações jurídicas integrantes do ativo ou do passivo da pessoa jurídica, representativas, respectivamente, de direitos ou de obrigações para com terceiros. Ocorreriam, pois, quando o vendedor fizesse a entrega para o comprador, passando, então, a ter jus ao recebimento do respectivo preço. Esse evento deveria ser vertido em linguagem competente, registrado o direito de crédito que o vendedor passaria a deter em face do comprador, equivalente ao preço estipulado quando da celebração do contrato. Frisou-se ser esse o momento em que

nasceria a relação jurídica, juntamente com a ocorrência do fato jurídico tributário.

RE 586.482/RS, j. 23.11.2011, rel. Min. Dias Toffoli (RE 586482) (Informativo 649, Plenário, Repercussão Geral).

• **PIS e Cofins: vendas a prazo inadimplidas – 3**

Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da Cofins e da contribuição para o PIS, ter-se-ia, desse modo, que o fato gerador da obrigação ocorreria com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, e não com o recebimento do preço acordado, isto é, com a disponibilidade jurídica da receita, que passaria a compor o aspecto material da hipótese de incidência das contribuições em questão. Salientou-se, nesse aspecto, que o STF teria firmado orientação do sentido de que a disponibilidade jurídica é presumida por força de lei, que definiria como fato gerador do imposto a aquisição virtual, e não efetiva, do poder de dispor. Além disso, a disponibilidade jurídica ou econômica da receita, para as pessoas jurídicas, não poderia ser limitada pelo efetivo recebimento de moeda ou dinheiro, diferenciando-se a disponibilidade econômica – patrimônio economicamente acrescido de um direito ou de um elemento material identificável como receita – da disponibilidade financeira – efetiva existência dos recursos financeiros. Assim, a primeira não pressuporia o repasse físico dos recursos para o patrimônio do contribuinte, bastando o acréscimo, mesmo que contábil, desses recursos no patrimônio da pessoa jurídica.

RE 586.482/RS, j. 23.11.2011, rel. Min. Dias Toffoli (RE 586482) (Informativo 649, Plenário, Repercussão Geral).

• **PIS e Cofins: vendas a prazo inadimplidas – 4**

Sublinhou-se inexistir disposição legislativa a permitir a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em discussão. Haveria, por outro lado, normas a definir que não integrariam renda e receita as vendas canceladas, devolvidas e os descontos incondicionais (Dec.-lei 1.940/1982, art. 1.º, § 4.º, e art. 12, § 1.º, da 1.598/1977; Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003). Sob esse prisma, as situações excludentes do crédito tributário contempladas na legislação do PIS e da Cofins ocorreriam apenas quando fato superveniente viesse a anular o fato gerador do tributo, nunca quando ele subsistisse perfeito e acabado, como ocorreria nas vendas inadimplidas. Asseverou-se que as vendas canceladas não poderiam equiparar-se às inadimplidas porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio jurídico seria desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor, as vendas inadimplidas – a despeito de poderem resultar no

cancelamento e na devolução da mercadoria –, enquanto não efetivamente canceladas, implicariam crédito para o vendedor oponível ao comprador. Permaneceria, portanto, o fato imponível. Destacou-se que o mesmo ocorreria com os descontos incondicionais, parcelas redutoras do preço de venda quando constantes da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Não caberia ao intérprete, assim, excluir as vendas inadimplidas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, sob a alegação de isonomia, por resultar hipótese de exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deveria ser restritiva, a teor do art. 111, I, do CTN. O Min. Ricardo Lewandowski destacou que, quando uma empresa vende a prazo, assumiria os riscos da inadimplência, e a legislação preveria a denominada provisão para devedores duvidosos, a permitir que determinada empresa, ao fim de cada exercício social, pudesse lançar como perda do período eventuais vendas atingidas por insolvências. Vencidos os Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, que proviam o recurso. Este asseverava que receita auferida seria somente a que ingressara na contabilidade da empresa, sujeito passivo dos tributos. Ademais, verificado o inadimplemento, o autor do negócio jurídico teria duplo prejuízo: não receberia e teria, ainda, de recolher o tributo. Assim, a capacidade contributiva não se faria presente. O Min. Celso de Mello consignava que o Fisco não poderia apropriar-se de parcelas a serem recolhidas com base em mera presunção de receita, visto que valores não recebidos seriam inábeis a compor a base de cálculo.

RE 586.482/RS, j. 23.11.2011, rel. Min. Dias Toffoli (RE 586482) (Informativo 649, Plenário, Repercussão Geral).

• **Contribuição previdenciária de prestadoras de serviço**

É constitucional a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte das empresas tomadoras de serviço, a título de contribuição previdenciária. Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, desproveu recurso extraordinário em que pretendida a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 8.212/1991. Asseverou que o instituto da substituição tributária seria necessário nas sociedades complexas atuais, as quais exigiriam a participação de terceiros para adimplemento de todas as obrigações e para maior facilidade tanto na arrecadação quanto na fiscalização, além de impedir o prejuízo aos trabalhadores nos contratos de terceirizados. Vencido o Min. Marco Aurélio, que provia o recurso ao fundamento de não se tratar de substituição tributária, mas de obrigação acessória, criada por medida provisória posteriormente

transformada em lei, contribuição essa estranha ao rol do art. 195, I, da CF, porque passara a incidir não sobre a folha de salários, porém sobre a nota fiscal, presente a prestação de serviços.

RE 603.191/MT, j. 1.º.08.2011, rel. Min. Ellen Gracie (RE 603191) (Informativo 634, Plenário, Repercussão Geral).

B) IMPOSTOS

• **Direito processual civil e tributário. Legitimidade ativa do consumidor. ICMS. Demanda contratada de energia elétrica.**

O consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica. Precedente citado: *REsp 1.299.303-SC (Repetitivo)*, DJe 14.8.2012.

AgRg nos EDcl no REsp 1.269.424-SC, j. 23.10.2012, rel. Min. Benedito Gonçalves.

• **Direito tributário. Competência para cobrança de ISS. Dec.-lei 406/1968. LC 116/2003. Arrendamento mercantil. Recurso repetitivo (art. 543-C do CPC e Res. 8/2008-STJ).**

O Município competente para a cobrança de ISS sobre operações de arrendamento mercantil, na vigência do Dec.-lei 406/1968, é o do local onde sediado o estabelecimento prestador (art. 12 – revogado pela LC 116/2003), e, a partir da LC 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado (art. 3.º). A LC 116/2003 adotou um sistema misto, considerando o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no local do domicílio do prestador e, para outras hipóteses definidas, o local da prestação do serviço, do estabelecimento do tomador ou do intermediário (art. 3.º, *caput* e I). Vê-se, assim, que nem mesmo a LC 116/2003, que sucedeu o Dec.-lei 406/1968, prestigiou em sua integralidade o entendimento externado pelo STJ, de modo que não se considera como competente para a arrecadação do tributo, em todos os casos, o Município em que efetivamente prestado o serviço. Ademais, ao definir estabelecimento prestador, emprestou-lhe alcance bastante amplo, quando assinalou, em seu art. 4.º, que “considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras

que venham a ser utilizadas”. Dessa forma, somente após a vigência da LC 116/2003 é que se poderá afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador do serviço no Município onde a prestação do serviço é perfectibilizada, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. É certo que a opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças das localidades periféricas do sistema bancário nacional, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de descapitalização dos Municípios de pequeno porte, onde se faz a captação da proposta de contrato bancário, para depois drenar para os grandes centros financeiros do País os recursos assim recolhidos, teria esse mecanismo um forte impacto sobre o ideal federalista descentralizador. No entanto, a interpretação do mandamento legal leva à conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que seria verdadeira quebra do princípio da legalidade.

REsp 1.060.210-SC, j. 28.11.2012, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

• **Direito tributário. IRPJ e CSSL. Base de cálculo. Ano-base de 1990. Correção monetária e demonstração financeira pela BTNF.**

Aplica-se o BTN Fiscal na correção monetária das demonstrações financeiras do período-base de 1990, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro – CSSL. Precedentes citados do STF: RE 201.465-MG/DJ 17.10.2003; do STJ: AgRg no EREsp 636.275-RJ, DJe 08.09.2008, e EREsp 210.261-ES, DJe 23.06.2008.

AgRg nos EAg 427.916-PR, j. 14.11.2012, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.

• **Direito tributário. ICMS. Serviços suplementares ao de comunicação.**

Não incide ICMS sobre a prestação de serviços acessórios ao de comunicação. A incidência do ICMS, no que se refere à prestação dos serviços de comunicação, deve ser extraída da CF e da LC 87/1996, incidindo o tributo sobre os serviços de comunicação prestados de forma onerosa, através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (art. 2.º, III, da LC 87/1996). A prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde

com a prestação da atividade-fim; processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta, sim, passível de incidência do ICMS. Exemplos de serviços acessórios são a troca de titularidade de aparelho celular, conta detalhada, troca de aparelho, troca de número, mudança de endereço de cobrança de conta telefônica, troca de área de registro, troca de plano de serviço, bloqueio de DDD e DDI, habilitação e religação. Desse modo, a despeito de alguns deles serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e admitirem a cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço público), por assumirem o caráter de atividade-meio, não constituem, efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS. Ressalte-se que nesse sentido, é a orientação consolidada na Súmula 350/STJ, que dispõe que “o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular”. Precedentes citados: REsp 1.022.257-RS, *DJe* 17.03.2008, e RMS 11.368-MT, *DJ* 09.02.2005.

Recurso Repetitivo – REsp 1.176.753-RJ, j. 28.11.2012, rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques.

• **Direito tributário. ISS. Serviço de marketing. Base de cálculo. Valor global cobrado pelo serviço.**

A base de cálculo do ISS, na prestação de serviços de *marketing*, é o valor global cobrado pelos serviços, não sendo legítima a dedução dos valores recebidos a título de reembolso por ausência de previsão legal. Precedentes citados: REsp 1.293.162-RS, *DJe* 03.08.2012; AgRg no AREsp 211.232-SC, *DJe* 17.09.2012; e AgRg no REsp 1.141.557-SP, *DJe* 24.08.2012.

AgRg no AREsp 227.724-SP, j. 20.11.2012, rel. Min. Benedito Gonçalves.

• **Direito tributário. Parcelamento especial (Lei 10.684/2003). Débitos posteriores a 28.02.2003.**

É possível a cumulação do parcelamento previsto na Lei 10.684/2003 (Paes) com outra modalidade de parcelamento, desde que os débitos tenham vencimento posterior a 28.02.2003. Segundo jurisprudência pacificada do STJ, a vedação de concessão de outros parcelamentos prevista no art. 1.º, § 10, da Lei 10.684/2003 somente é aplicável aos débitos com vencimento até o dia 28.02.2003, e não aos débitos posteriores à referida data. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.255.366-RS, *DJe* 10.8.2011, e AgRg no Ag 1.369.550-RJ, *DJe* 30.03.2011.

AgRg no REsp 1.313.079-RS, j. 13.11.2012, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

• **Direito tributário. Crédito presumido. ICMS. Impossibilidade de inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins.**

Não é possível a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins. O crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento. Assim, não se tratando de receita, não há que se falar em incidência do crédito presumido do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.229.134-SC, *DJe* 03.05.2011, e AgRg no REsp 1.165.316-SC, *DJe* 14.11.2011.

AgRg no REsp 1.329.781-RS, j. 27.11.2012, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.

• **Direito processual civil e tributário. Citação postal. IPTU. Prescrição. Interrupção.**

A citação encaminhada ao endereço do imóvel para cobrança de crédito relativo ao IPTU é considerada válida e atende à finalidade de interromper a prescrição do crédito tributário, na redação anterior à LC 118/2005. Precedentes citados: REsp 1.168.621-RS, *DJe* 26.04.2012, e AgRg no Ag 1.140.052-RJ, *DJe* 02.03.2010.

REsp 1.276.120-RJ, j. 13.11.2012, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3.ª Região).

• **IPTU: Progressividade e EC 29/2000 – 1**

Em conclusão, o Plenário proveu recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo e reconheceu a constitucionalidade da EC 29/2000 e da Lei Municipal 6.989/1966, na redação dada pela Lei Municipal 13.250/2001, que estabeleceu alíquotas progressivas para o IPTU tendo em conta o valor venal e a destinação do imóvel. O recurso impugnava acórdão o qual provera apelação em mandado de segurança e declarara a inconstitucionalidade da referida Lei municipal 13.250/2001 por vislumbrar ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, e ao art. 60, § 4.º, IV, da CF – v. Informativo 433. Após mencionar os diversos enfoques dados pela Corte em relação à progressividade do IPTU, em período anterior à EC 29/2000, concluiu-se, ante a interpretação sistemática da Constituição Federal, com o cotejo do § 1.º, I, do seu art. 156 com o § 1.º do seu art. 145, que essa emenda teria repellido as premissas que levaram a Corte a ter como imprópria a progressividade do IPTU. Enfatizou-se que a EC 29/2000 veio apenas aclarar o real significado do que disposto anteriormente sobre a graduação dos tributos, não tendo abolido nenhum direito ou garantia individual, visto que a redação

original da CF já versava a progressividade dos impostos e a consideração da capacidade econômica do contribuinte, não se tratando, assim, de inovação apta a afastar algo que pudesse ser tido como integrado a patrimônio.

RE 423.768/SP, j. 1.º.12.2010, rel. Min. Marco Aurélio (RE 423768, Informativo 611, Plenário).

• **IPTU: Progressividade e EC 29/2000 – 2**

Ressaltou-se que o § 1.º do art. 145 possuiria cunho social da maior valia, tendo como objetivo único, sem limitação do alcance do que nele estaria contido, o estabelecimento de uma gradação que promovesse justiça tributária, onerando os que tivessem maior capacidade para pagamento do imposto. Asseverou-se, no ponto, que o Texto Constitucional homenagearia a individualização, determinando que se atentasse à capacidade econômica do contribuinte, a qual haveria de ser aferida sob os mais diversos ângulos, inclusive o valor, em si, do imóvel. Observou-se ser necessário emprestar aos vocábulos da norma constitucional o sentido próprio, não se podendo confundir a referência à capacidade econômica com a capacidade financeira, cedendo a tradicional dicotomia entre tributo pessoal e real ao texto da Carta da República. Frisou-se que essa premissa nortearia a solução de conflitos de interesses ligados à disciplina da progressividade, buscando-se, com isso, alcançar o objetivo da República, a existência de uma sociedade livre, justa e solidária. Aduziu-se que a lei impugnada, por sua vez, teria sido editada em face da competência do Município e com base no § 1.º, I, do art. 156 da CF, na redação dada pela EC 29/2000, concretizando, portanto, a previsão constitucional. Salientou-se que o texto primitivo desse dispositivo não se referia ao valor do imóvel e à localização e ao uso respectivos, mas previa a progressividade como meio de se assegurar o cumprimento da função social da propriedade.

RE 423.768/SP, j. 1.º.12.2010, rel. Min. Marco Aurélio (RE 423768, Informativo 611, Plenário).

• **IPTU: Progressividade e EC 29/2000 – 3**

Nesta assentada, o Min. Celso de Mello registrou haver atualmente um modelo de progressividade que não mais se qualificaria como a simples progressividade-sanção em virtude exatamente da específica vinculação do instituto da progressividade tributária, em tema de IPI, ao cumprimento da função social da propriedade urbana, notadamente quando analisada em face das exigências públicas de adequada ordenação do solo urbano. Reputou que a pretensão de inconstitucionalidade, no

presente caso, seria afastada precisamente pelo conteúdo inequívoco do próprio discurso normativo que se encerraria no texto da EC 29/2000, portanto, não mais apenas a progressividade-sanção, mas, também, agora, o instituto da progressividade como medida de isonomia, como medida de justiça fiscal. Concluiu que, em face da EC 29/2000, o conteúdo de que se mostraria impregnada a Súmula 668 do STJ poderia ser então superada, tendo em vista o fato de que se mostraria plenamente legítimo e possível ao Município adequar o seu modelo pertinente ao IPTU à cláusula da progressividade, tal como prevista no § 1.º, I, do art. 156 da CF. Alguns precedentes citados: RE 153.771/MG (DJU de 05.09.1997); RE 234.105/SP (DJU de 31.03.2000).

RE 423.768/SP, j. 1.º.12.2010, rel. Min. Marco Aurélio (RE 423768, Informativo 611, Plenário).

• IPI e *leasing* internacional – 1

A 2.ª Turma desproveu recurso extraordinário em que discutida a incidência do Imposto de Importação – II e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre operação de importação amparada por arrendamento mercantil financeiro (*leasing*). A recorrente sustentava: (a) insubmissão do arrendamento mercantil, que seria um serviço, ao fato gerador do imposto de importação; (b) violação do princípio da isonomia, na medida em que seria proibida a adoção do regime de admissão temporária para as operações amparadas por arrendamento mercantil; (c) contrariedade à regra da legalidade, uma vez que a alíquota do imposto de importação teria sido definida por decreto e não por lei em sentido estrito; e (d) vilipêndio ao dever fundamental de prestação de serviços de saúde, pois o bem tributado seria equipamento médico.

RE 429.306/PR, j. 1.º.02.2011, rel. Min. Joaquim Barbosa (RE 429306, Informativo 614, 2.ª Turma).

• IPI e *leasing* internacional – 2

Aduziu-se, inicialmente, que a importação de produto mediante contrato de arrendamento mercantil implicaria tanto prestação de serviço (*leasing*) quanto a própria importação, de maneira que a incidência de tributos diferentes não significaria bitributação. Ademais, entendeu-se não ter sido violado o princípio da isonomia, uma vez que o objetivo da tributação do arrendamento mercantil seria não torná-lo mais atrativo que as operações de compra e venda financiada apenas por vantagens fiscais. Nesse sentido, operações idênticas ou bastante semelhantes

deveriam gerar cargas tributárias muito próximas, independentemente da formatação do negócio jurídico. Além disso, reputou-se ausente ofensa à regra da legalidade, pois a Constituição, no § 1.º do seu art. 153, permitiria expressamente que as alíquotas do imposto de importação fossem definidas pelo Poder Executivo, observados os limites estabelecidos em lei. Por fim, reconheceu-se não haver transgressão ao dever fundamental de prestação de serviços de saúde, pois, embora o princípio da seletividade impusesse que a carga tributária fosse graduada conforme a essencialidade da operação ou do produto, não haveria imunidade, considerados os princípios da capacidade contributiva, da concorrência, da livre-iniciativa e da solidariedade no custeio das atividades estatais.

RE 429.306/PR, j. 1.º.02.2011, rel. Min. Joaquim Barbosa (RE 429306, Informativo 614, 2.ª Turma).

• ICMS e alienação de salvados de sinistros – 1

O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Esse o teor da Súmula Vinculante 32, cuja edição foi aprovada pelo Plenário após dar provimento, por maioria, a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, com base na Súmula 152 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, reputara cabível essa incidência. Deliberou-se, ainda, que os Ministros decidam monocraticamente os casos idênticos. Na mesma linha do que firmado no julgamento da ADI 1.648/MG anteriormente relatada, reconheceu-se a inconstitucionalidade da expressão “e a seguradora”, constante do antigo item 4 do § 1.º do art. 7.º da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo. Prevaleceu o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, que salientou, de início, que o STF há muito possuiria jurisprudência contrária ao acórdão recorrido (ADI 1.332 MC/RJ, DJU de 11.04.1997), segundo a qual não competiria aos Estados, mas à União, tributar a alienação de salvados, que se integraria à operação de seguros (CF, art. 153, V).

RE 588.149/SP, j. 16.02.2011, rel. Min. Gilmar Mendes (RE 588149, Informativo 616, Plenário, Repercussão Geral).

• ICMS e alienação de salvados de sinistros – 2

Observou que, em razão de ser vedada às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 do Dec.-lei 73/1966, a exploração de qualquer outro ramo de comércio ou indústria, elas não seriam e nem poderiam ser comerciantes de sucata. Acrescentou que, por disposição contratual, as seguradoras receberiam por ato unilateral a propriedade do bem nas hipóteses em que, em decorrência de sinistro, tivesse este

perdido mais de 75% do valor do segurado. Asseverou que as companhias de seguro seriam obrigadas a pagar ao segurado 100% do valor do bem e que a posterior venda, por elas, dos salvados teria, no máximo, o condão de recuperar parte da indenização que houvesse superado o dano ocorrido. Enfatizou que, por isso, não haveria finalidade de obter lucro, nem, portanto, intenção comercial. Registrou ser esse o sentido da jurisprudência da Corte, conforme depreendido do Enunciado 541 da sua Súmula (“O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e equipamentos usados, que não se insere na atividade profissional do vendedor, e não é realizada com o fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade”).

RE 588.149/SP, j. 16.02.2011, rel. Min. Gilmar Mendes (RE 588149, Informativo 616, Plenário, Repercussão Geral).

• ICMS e alienação de salvados de sinistros – 3

Concluiu que o objeto das operações das seguradoras seria o seguro e que a eventual venda dos salvados não os tornaria mercadorias, porquanto as companhias seguradoras não possuiriam por objeto social a circulação de mercadorias, constituindo a referida alienação um elemento da própria operação de seguro. Mencionou, também, que o STJ teria cancelado o Enunciado 152 de sua Súmula, o que demonstraria adesão ao entendimento do STF. Além disso, afirmou que a Lei paulista 9.399/1996 teria dado nova redação à Lei Estadual 6.374/1989, para excluir a expressão “e a seguradora” de seu item 4 do § 1.º do art. 7.º, razão pela qual teria havido perda de objeto da ADI 1.390/SP (DJU de 06.02.2002). Tal fato permitiria ainda, deduzir que o Estado de São Paulo, de igual modo, aderira às razões expendidas pela jurisprudência do STF. Vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Ayres Britto, que negavam provimento ao recurso.

RE 588.149/SP, j. 16.02.2011, rel. Min. Gilmar Mendes (RE 588149, Informativo 616, Plenário, Repercussão Geral).

• ISS e cessão de direito sobre uso de marca

A 2.ª Turma negou provimento a agravo regimental em reclamação na qual se alegava não ser devido o Imposto sobre Prestação de Serviço – ISS sobre contrato de locação de bens móveis. Reputou-se que a decisão paradigma invocada na reclamação não abrangeria o auto de infração cuja manutenção e inscrição na dívida ativa seria o ato reclamado. Ademais, concluiu-se que se trataria de cessão de direito sobre uso de marca, que não poderia ser considerada locação de bens móveis, mas

serviço autônomo, como previsto na LC 116/2003. Assim, não haveria a incidência da Súmula Vinculante 31 (“É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”).

Rcl 8.623 AgR/RJ, j. 22.02.2011, rel. Min. Gilmar Mendes (RCL 8623 (Informativo 617, 2.ª Turma).

• **ICMS: diferença entre alíquotas interna e interestadual e cobrança**

As empresas de construção civil que adquirem material em Estado-membro que cobra alíquota mais favorável de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS não estão compelidas, uma vez empregadas as mercadorias em obra daquela pessoa jurídica, ao recolhimento da diferença em virtude de alíquota maior do Estado-membro destinatário. Com base nesse entendimento, a 1.ª Turma desproveu, com imposição de multa, agravo regimental interposto de decisão do Min. Marco Aurélio, proferida nos autos de embargos de declaração em recurso extraordinário, do qual relator, opostos pelo Estado do Ceará. Destacou-se que, nos termos do art. 155, § 2.º, VII, da CF, as construtoras seriam, de regra, contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS.

RE 248.830 AgR-ED/CE, j. 07.06.2011, rel. Min. Marco Aurélio (RE 248830 (Informativo 630, 1.ª Turma).

• **ICMS e operações de frete sob o regime de preço CIF**

A 2.ª Turma desproveu agravo regimental interposto de decisão da Min. Ellen Gracie, em que negado seguimento a recurso extraordinário, do qual relatora, com base nos Enunciados 279, 282 e 356 da Súmula do STF. No caso, a empresa recorrente pretendia creditar-se do ICMS advindo de operações de frete de mercadorias ou produtos do seu estabelecimento para o do comprador sob o regime de preço CIF (*cost, insurance and freight*). Salientou-se que, mesmo superada a ausência de prequestionamento, não seria incontroversa a inexistência de ressarcimento dos valores de ICMS incidentes sobre o frete. Destacou-se que, da leitura do acórdão recorrido, se depreenderia que o tribunal *a quo*, soberano na apreciação dos fatos e provas da causa, concluía que a ora agravante já se ressarcira da importância relativa ao ICMS incidente sobre a carga transportada de objetos sujeitos à mercancia, realizado sob a cláusula CIF.

RE 538.599 AgR/MT, j. 14.06.2011, rel. Min. Ellen Gracie, (RE 538599 (Informativo 631, 2.ª Turma).

• ICMS e “cálculo por dentro” – 1

A inclusão de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS em sua própria base de cálculo é constitucional. Essa a conclusão do Plenário ao, por maioria, desprover recurso extraordinário no qual sociedade empresária, contribuinte do tributo, sustentava, em síntese: (a) a ocorrência de dupla tributação e afronta ao princípio da não cumulatividade; (b) o não cabimento da taxa Selic na atualização do débito tributário, sob pena de majoração do imposto; e (c) a natureza confiscatória da multa moratória fixada em 20% sobre o valor do débito. Preliminarmente, também por votação majoritária, conheceu-se do recurso, vencidos os Ministros Cármen Lúcia e Dias Toffoli, no que se refere à utilização da taxa Selic, ao fundamento de que a matéria restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional. No mérito, quanto a esse respeito, ressaltou-se que – não obstante a existência de precedentes desta Corte no sentido manifestado pelos Ministros acima referidos – estar-se-ia diante de recurso com repercussão geral reconhecida. Assim, reputou-se legítima a incidência da Selic como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. O Min. Gilmar Mendes, relator, aduziu que a questão poderia ser suscitada à luz do princípio da isonomia, bem como da legalidade, consoante já declarado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. No tocante ao método de cálculo “por dentro” da exação, reafirmou-se orientação fixada no julgamento do RE 212.209/RS (DJU 14.02.2003) segundo a qual a quantia relativa ao ICMS faz parte do conjunto que representa a viabilização jurídica da operação e, por isso, integra a sua própria base de cálculo. Por outro lado, tendo em conta a razoabilidade do importe da multa moratória, rechaçou-se a alegação de eventual caráter confiscatório.

RE 582.461/SP, j. 18.05.2011, rel. Min. Gilmar Mendes (RE 582461) (Informativo 627, Plenário, Repercussão Geral).

• ICMS e “cálculo por dentro” – 2

Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que proviam o recurso. Este aduzia ser incompatível com o ordenamento constitucional a consideração de valores estranhos à materialidade da hipótese de incidência do ICMS, bem como extensível às obrigações acessórias o princípio da não confiscatoriedade. Aquele assentava que o cálculo “por dentro”, no que o vendedor não fatura o ICMS discreparia do modelo constitucional, em transgressão ao princípio da não cumulatividade. Consignava, ademais, que essa forma de cálculo, uma vez afirmada relativamente ao ICMS, poderia vir a ser transportada para qualquer outro tributo. Salientou também que se teria um confisco, ante a inexistência de móvel para essa

cobrança. Por fim, o Min. Cezar Peluso, Presidente, apresentou proposta de redação de súmula vinculante, a ser encaminhada à Comissão de Jurisprudência, com o seguinte teor: “É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na sua própria base de cálculo”.

RE 582.461/SP, j. 18.05.2011, rel. Min. Gilmar Mendes (RE 582461), (Informativo 627, Plenário, Repercussão Geral).

• **IRPJ: regime de estimativa e consolidação de resultados semestrais – 1**

Em conclusão, o Plenário, por maioria, desproveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do art. 86, § 2.º, da Lei 8.383/1991 – que impede que as pessoas jurídicas que apresentaram prejuízo fiscal no período-base de 1991 optem pelo pagamento do imposto de renda pelo regime de estimativa no exercício de 1992 – e da Portaria 441/1992, do Ministério da Fazenda, que faculta, aos contribuintes optantes pelo regime de estimativa, a substituição da consolidação de resultados mensais pela de resultados semestrais na declaração de ajuste anual do ano-base de 1992 – v. Informativos 426 e 592. Na espécie, tratava-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negara à recorrente, que apurara prejuízo no ano-base de 1991, o direito de substituir a consolidação de resultados mensais pela consolidação de resultados semestrais, na declaração de ajuste anual para a apuração do imposto de renda de pessoa jurídica, relativa ao ano-base de 1992.

RE 231.924/PR, j. 06.04.2011, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski (RE 231924) (Informativo 622, Plenário).

• **IRPJ: regime de estimativa e consolidação de resultados semestrais – 2**

Salientou-se, inicialmente, que a proibição contida no § 2.º do art. 86 da Lei 8.383/1991 teria explicação lógica, já que, se a pessoa jurídica que apurara prejuízo no ano de 1991 pudesse optar pelo cálculo do imposto por estimativa, a base de cálculo do imposto de renda, calculado também por estimativa, no ano seguinte seria igual a zero. Entendeu-se, em seguida, que o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento teria agido corretamente – e dentro da legalidade, ante a existência de expressa autorização legal para a prática do ato –, ao limitar, mediante a Portaria 441/1992, a possibilidade de apuração semestral dos resultados apenas às pessoas jurídicas que optaram pelo cálculo por estimativa, visto que somente elas poderiam respeitar o calendário de pagamento do imposto estabelecido na Lei 8.383/1991. Aduziu-se que, caso fosse permitido à recorrente a consolidação semestral, não teria ela como cumprir o cronograma legal de pagamento por manifesta impossibilidade de

calcular-se o imposto devido. Ressaltou o Min. Joaquim Barbosa, também, que o Poder Judiciário não poderia estender o calendário de recolhimento do imposto estabelecido para as pessoas jurídicas submetidas ao cálculo por estimativa às demais, visto que isso implicaria invasão da seara reservada ao Poder Legislativo. Reputou-se que o mesmo raciocínio aplicar-se-ia à impossibilidade de extensão da faculdade estabelecida na Portaria 441/1992 a outras pessoas jurídicas, para permitir-lhes substituir a consolidação dos resultados mensais pela de resultados semestrais, e que, de igual modo, nesse aspecto o Judiciário atuaria como legislador positivo. Observou-se, por fim, que, em razão de a recorrente não se encontrar na mesma situação dos contribuintes abrangidos pela Portaria 441/1992, porque impossibilitada de optar pelo cálculo do imposto por estimativa, não se poderia falar em ofensa ao princípio da isonomia em matéria tributária, tendo em vista, inclusive, a possibilidade de concessão de moratória de 6 meses a essa classe de contribuintes, se aplicado entendimento contrário. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que dava provimento ao recurso para, assentando a inconstitucionalidade da cláusula restritiva da Portaria 441/1992, assegurar à recorrente o direito de optar, independentemente do sistema por estimativa, pela feitura dos balanços semestrais.

RE 231.924/PR, j. 06.04.2011, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski (RE 231924) (Informativo 622, Plenário).

• **IPTU: alíquota progressiva e EC 29/2000**

Ao aplicar o Enunciado 668 da Súmula do Supremo (“É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”), o Plenário proveu recurso extraordinário, afetado pela 2.^a Turma, para que subsista, no período de vigência da lei municipal objeto do recurso, a tributação em alíquota única e mínima. Na situação em comento, norma municipal anterior à EC 29/2000 concedera isenções parciais de IPTU inversamente proporcionais ao valor venal de imóveis. Reputou-se configurado o estabelecimento, por vias transversas, de alíquotas progressivas do referido tributo. Salientou-se que a progressividade reservar-se-ia aos tributos de cunho pessoal, nos quais se pode aferir subjetivamente a atual e efetiva capacidade contributiva do cidadão, na forma do art. 145, § 1.º, da CF (“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) § 1.º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”). Por fim, aduziu-se que a aplicação da progressividade à espécie somente fora autorizada após a EC 29/2000.

RE 355.046/SP, j. 1.º.08.2011, rel. Min. Ellen Gracie (RE 355046) (Informativo 634, Plenário).

• **Alíquota de ICMS e resolução do Senado**

Em conclusão de julgamento, o Plenário não conheceu de embargos de divergência em que discutida a incidência, ou não, de ICMS na saída de produtos semielaborados remetidos ao exterior entre 1.º.03.1989 a 31.05.1989 – v. Informativo 603. Aduziu-se que, desde a instância ordinária, a questão fora decidida com base em fundamento diverso daquele utilizado no aresto paradigma. Ressaltou-se que a rejeição do pedido do contribuinte ocorrera com supedâneo no art. 34, § 5.º, da CF, ao passo que esse mesmo dispositivo constitucional não fora debatido na decisão apontada como divergente, porquanto não prequestionado. Reputou-se que não haveria, pois, dissenso entre o acórdão modelo e o ora hostilizado. O Ministro Luiz Fux acrescentou que a tese objeto do recurso também já fora pacificada no sentido do acórdão vergastado. Os Ministros relator e Dias Toffoli reformularam seus votos proferidos anteriormente.

RE 208.277 EDv/SP, j. 1.º.08.2011, rel. Min. Ricardo Lewandowski (RE 208277, Informativo 634, Plenário).

• **Direito processual civil e tributário. Legitimidade ativa *ad causam*. Consumidor final. Energia elétrica. Demanda contratada. Compensação de ICMS**

O usuário do serviço de energia elétrica (consumidor em operação interna), na condição de contribuinte de fato, é parte legítima para discutir pedido de compensação do ICMS supostamente pago a maior no regime de substituição tributária. Esse entendimento é aplicável, *mutatis mutandis*, em razão da decisão tomada no REsp 1.299.303/SC, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC, em que se pacificou o entendimento de que o consumidor tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

AgRg no RMS 28.044-ES, j. 13.11.2012, rel. Min. Mauro Campbell Marques.

• **Direito tributário. ISS. Construção civil. Base de cálculo. Abatimento dos materiais empregados e das subempreitadas. Possibilidade**

É possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores das subempreitadas e dos materiais utilizados em construção civil. O STF, ao julgar o RE 603.497-MG, no rito do art. 543-B do CPC, entendeu ser possível, mesmo na vigência da LC 116/2003, a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na construção civil. No mesmo sentido, no RE 599.497-RJ, concluiu-se que a orientação adotada no recurso acima é aplicável aos valores das subempreitadas, pois o art. 9.º do Dec.-Lei 406/1968 foi recepcionado pela CF. Precedentes citados: REsp 976.486-RS, *DJe* 10.08.2011; AgRg no AgRg no REsp 1.228.175-MG, *DJe* 1.º.09.2011, e AgRg no Ag 1.410.608-RS, *DJe* 21.10.2011.

REsp 1.327.755-RJ, j. 18.10.2012, rel. Min. Herman Benjamin.

• **Direito tributário. Débito fiscal. Compensação com precatório vencido e não pago. Legislação do ente federado**

A pretensão de compensar débitos fiscais com precatórios está sujeita à autorização do regime legislativo estadual regulador da matéria, conforme sistemática estabelecida pela EC 62/2009. Precedentes citados: RMS 28.783-PR, *DJe* 18.08.2011, e RMS 29.467-PR, *DJe* 23.09.2011.

RMS 36.173-PR, j. 18.10.2012, rel. Min. Herman Benjamin.

• **Direito tributário. ICMS. Direito de crédito. Limitação temporal da LC 87/1996**

São legítimas as restrições impostas pela LC 87/1996, inclusive a limitação temporal prevista no art. 33, I, para o aproveitamento dos créditos de ICMS em relação à aquisição de bens destinados ao uso e consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento contribuinte. O princípio constitucional da não cumulatividade, por si só, não permite o amplo e irrestrito creditamento relativo a material de uso e consumo ou a bens destinados ao ativo permanente das empresas. Precedentes citados do STF: RE-AgR 545.845-SP; do STJ: RMS 20.454-RJ, *DJ* 31.05.2007, e REsp 1.105.151-SP, *DJe* 13.05.2009.

AgRg no AREsp 186.016-PE, j. 18.10.2012, rel. Min. Herman Benjamin.

• **Direito tributário. ISS. Industrialização por encomenda**

A industrialização por encomenda está sujeita à incidência de ISS, e não de ICMS. A prestação de serviço personalizado feita em conformidade com o interesse exclusivo do cliente, distinto dos serviços destinados ao público em geral, caracteriza

espécie de prestação de serviço que está elencada na lista de serviços da LC 116/2003. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.280.329-MG, *DJe* 13.04.2012; AgRg no Ag 1.362.310-RS, *DJe* 06.09.2011; REsp 1.097.249-ES, *DJe* 26.11.2009.

AgRg no AREsp 207.589-RS, j. 06.11.2012, rel. Min. Humberto Martins.

C) INDÉBITO TRIBUTÁRIO

• Prazo para repetição ou compensação de indébito tributário e art. 4.º da LC 118/2005

É inconstitucional o art. 4.º, segunda parte, da LC 118/2005 [“Art. 3.º Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1.º do art. 150 da referida Lei. Art. 4.º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3.º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”]; CTN: “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados [...]”. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito – v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio da segurança jurídica – nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e expreso nos arts. 1.º e 5.º, XXXV, da CF – e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da *vacatio legis* de 120 dias, ou seja, a partir de 09.06.2005. Os Ministros Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez dissentiram apenas no tocante ao art. 3.º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de *vacatio legis*. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.

RE 566.621/RS, j. 04.08.2011, rel. Min. Ellen Gracie (RE 566621) (Informativo 634, Plenário, Repercussão Geral).

D) PRINCÍPIOS E GARANTIAS TRIBUTÁRIOS

• IRPF: atualização e princípios da capacidade contributiva e do não confisco

O Poder Judiciário não pode substituir o Legislativo na correção da tabela de

Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF. Esse o entendimento da maioria do Plenário ao concluir julgamento de recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Na espécie, o acórdão recorrido indeferira pedido de correção das tabelas do imposto de renda ao fundamento de que a sua não atualização, por si só, não violaria os princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco (arts. 146, III, *a*, e 150, II e IV) – v. Informativos 405, 434 e 592. Em preliminar, ante a falta de prequestionamento, não se conheceu do recurso quanto ao art. 146, III, *a*, da CF. No mérito, prevaleceu o voto proferido pela Min. Cármen Lúcia, que, em síntese, asseverara não caber ao Poder Judiciário substituir-se aos Poderes Executivo e Legislativo na análise do momento econômico e do índice de correção adequados para a retomada, ou mera aproximação, do quadro estabelecido entre os contribuintes e a lei, quando de sua edição, devendo essa omissão ficar sujeita apenas ao princípio da responsabilidade política, traduzido principalmente na aprovação ou rejeição dos atos de governo nos julgamentos ulteriores do eleitorado. A Min. Ellen Gracie salientou a necessidade de se ter critérios para a aplicação de correção monetária, sob pena de se perpetuar a cultura inflacionária. Afirmou cuidar-se de matéria que se situaria no plano das políticas econômica e monetária e que se vincularia às circunstâncias e à necessidade de recomposição do equilíbrio das relações. Por fim, o Colegiado aduziu caber ao legislador, pretendendo modificar ou revogar a imposição tributária anteriormente instituída, legislar novamente e que sua omissão implicaria manutenção das regras vigentes. Vencido o Min. Marco Aurélio, que, na parte conhecida, provia o extraordinário.

RE 388.312/MG, j. 1.º.08.2011, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia (RE 388312) (Informativo 634, Plenário).

• **Non olet e atividade ilícita**

É possível a incidência de tributação sobre valores arrecadados em virtude de atividade ilícita, consoante o art. 118 do CTN (“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”). Com base nessa orientação, a 1.^a Turma conheceu parcialmente de *habeas corpus* e, na parte conhecida, por maioria, denegou a ordem. Na espécie, o paciente fora condenado pelo crime previsto no art. 1.º, I, da Lei 8.137/1990 (“Art. 1.º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I – omitir informação, ou prestar

declaração falsa às autoridades fazendárias [...]”) e sustentava a atipicidade de sua conduta, porque inexistiria obrigação tributária derivada da contravenção penal do jogo do bicho (Dec.-lei 6.259/1944, art. 58). O Min. Dias Toffoli, relator, assinalou que a definição legal do fato gerador deveria ser interpretada com abstração da validade jurídica da atividade efetivamente praticada, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Ressaltou que a possibilidade de tributação da renda obtida em razão de conduta ilícita consubstanciar-se-ia no princípio do *non olet*. Assim, concluiu que o réu praticara sonegação fiscal, porquanto não declarara suas receitas, mesmo que resultantes de ato contravencional. O Min. Luiz Fux aludiu ao caráter *sui generis* da teoria geral do direito tributário. Acrescentou que seria contraditório o não pagamento do imposto proveniente de ato ilegal, pois haveria locupletamento da própria torpeza em detrimento do interesse público da satisfação das necessidades coletivas, a qual se daria por meio da exação tributária. Vencido o Min. Marco Aurélio, que concedia a ordem por entender que recolhimento de tributo pressuporia atividade legítima. Precedente citado: HC 77.530/RS (DJU 18.09.1998).

HC 94.240/SP, j. 23.8.2011, rel. Min. Dias Toffoli (HC 94240) (Informativo 637, 1.ª Turma).

E) TAXAS

• **Decisão do CNJ e destinação de taxa judiciária a entidades de classe**

O Plenário indeferiu mandado de segurança impetrado pela Associação Matogrossense dos Defensores Públicos – Amdep contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei matogrossense 8.943/2003 que – ao alterar a Lei 7.603/2001, que fixou o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial – instituiu contribuição para a associação impetrante. Na espécie, o CNJ julgara procedente pedido de providências para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a revisão de seus atos normativos sobre regime de custas, no sentido de expurgar qualquer cobrança de emolumento judicial com destinação a qualquer entidade de classe e/ou com finalidade privada. Alegava a impetrante que a cobrança de custas e emolumentos e o direito à participação da impetrante em parte delas encontraria previsão legal e que o CNJ teria usurpado competência jurisdicional do STF ao retirar a eficácia do art. 1.º da Lei 8.943/2008. Entendeu-se que o CNJ, ao declarar a inconstitucionalidade dos diplomas legislativos locais, zelara pela supremacia da Constituição Federal, tendo citado vasta jurisprudência do STF no

sentido da inconstitucionalidade da destinação da arrecadação de custas, taxas judiciárias e emolumentos a instituições privadas ou entidades de classe. Ressaltou-se, ainda, que o CNJ determinara o encaminhamento da sua decisão à Procuradoria-Geral da República para análise das leis mato-grossenses, a fim de que esta adotasse as medidas que reputasse cabíveis para sanar eventual frustração dos comandos constitucionais relativos à isonomia tributária.

MS 28.141/MT, j. 10.02.2011, rel. Min. Ricardo Lewandowski (MS 28141, Informativo 615, Plenário).

• **Suframa e natureza jurídica da remuneração por serviços prestados – 1**

O parágrafo único do art. 24 do Dec.-lei 288/1967 (“Art. 24. A Suframa poderá cobrar taxas por utilização de suas instalações e emolumentos por serviços prestados a particular. Parágrafo único. As taxas e emolumentos de que tratam este artigo serão fixadas pelo Superintendente depois de aprovadas pelo Conselho Técnico”) é incompatível com a CF. Essa a conclusão do Plenário ao desprover recurso extraordinário, afetado pela 1.^a Turma, em que a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa impugnava acórdão que lhe impusera obrigação de restituir indébito ao fundamento de que a cobrança por ela realizada teria natureza jurídica de taxa, e não de preço público. Alegava a recorrente ofensa aos arts. 145, II, § 2.º, e 150, I, da CF. Assinalou-se que a controvérsia diria respeito à natureza jurídica do valor recolhido pela empresa recorrida a título de remuneração pela anuência aos pedidos de guias de importação de insumos e de bens de capital, pela anuência aos pedidos de desembaraço aduaneiro e pelo controle dos internamentos na Zona Franca de Manaus.

RE 556.854/AM, j. 30.06.2011, rel. Min. Cármen Lúcia (RE 556854, Informativo 633, Plenário).

• **Suframa e natureza jurídica da remuneração por serviços prestados – 2**

De início, registrou-se que a Suframa seria uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo responsável pela administração das instalações e dos serviços da Zona Franca de Manaus (Dec.-lei 288/1967, art. 1.º). Na sequência, asseverou-se que, ao contrário do que sustentado, as cobranças efetuadas pela recorrente não seriam de pagamento facultativo a quem pretendesse fazer uso dos benefícios daquela zona franca. Enfatizou-se que a atividade por ela exercida seria afeta ao Estado (Dec.-lei 288/1967, art. 10), razão pela qual deveria ser cobrada por meio de taxa. Destacou-se, por conseguinte, que as

exações em comento estariam sujeitas à observância dos princípios constitucionais relativos aos tributos, dentre eles, o postulado da legalidade, o qual dispõe que as taxas devem ser instituídas por lei e não por portarias, atos infralegais. Concluiu-se que a Suframa não poderia, com base no referido parágrafo único do art. 24 do Dec.-lei 288/1967, ter estabelecido, por meio de portarias, a cobrança questionada, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade tributária. Por fim, consignou-se que, atualmente, esses tributos são cobrados pela Suframa por meio de taxas de serviços administrativos (Lei 9.960/2000, art. 1.º).

RE 556.854/AM, j. 30.06.2011, rel. Min. Cármen Lúcia (RE 556854).

F) BENEFÍCIOS FISCAIS

• **Lei 10.182/2001: extensão de incentivo fiscal e mercado de reposição**

Em conclusão, o Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF da 4.^a Região, que, com base no princípio da isonomia, estendera a empresa que trabalha com mercado de reposição de pneumáticos os efeitos do inc. X do § 1.º do art. 5.º da Lei 10.182/2001 (“Art. 5.º Fica reduzido em quarenta por cento o imposto de importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos [A redação atual do dispositivo é: ‘O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em (...)’]. § 1.º O disposto no *caput* aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de: (...) X – autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição”) – v. Informativos 371 e 484. Entendeu-se que o incentivo fiscal conferido pela citada lei não alcançaria a importação de pneumáticos para reposição, seja para montadoras, seja para fabricantes de veículos, mas, apenas, aquela destinada aos processos produtivos. O Min. Joaquim Barbosa, relator, considerou que a manutenção do acórdão impugnado, isto é, da decisão que concedera o benefício fiscal à recorrida, estaria em confronto com a jurisprudência do Supremo segundo a qual não seria possível acrescentar exemplos à lei, com base no princípio da isonomia, e que, portanto, referido aresto incorreria em ofensa ao princípio da separação de poderes. Os Ministros Cezar Peluso, Dias Toffoli e Cármen Lúcia deram provimento ao recurso, mas pelo fundamento de que o acórdão recorrido teria violado o art. 150, II, da CF, ao aplicar a

regra da isonomia a uma situação factual que não comportaria incidência. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ayres Britto, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento ao recurso.

RE 405.579/PR, j. 1.º.12.2010, rel. Min. Joaquim Barbosa (RE 405579).

G) GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO

- **Direito tributário. Indisponibilidade de bens do devedor tributário. Exaurimento das diligências.**

É necessária a comprovação do esgotamento de diligências destinadas à localização de bens do devedor para a determinação de indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN. A medida de decretação da indisponibilidade geral dos bens, com fundamento no mencionado dispositivo do CTN, a qual é mais gravosa do que a simples penhora *on line* dos valores executados, exige o prévio esgotamento de todas as diligências possíveis tendentes à localização de bens do devedor. No AgRg no Ag 1.429.330-BA, a Primeira Seção conceituou o esgotamento das diligências para localização de bens como o “uso dos meios ordinários que possibilitam o encontro de bens e direitos de titularidade da parte executada, como, por exemplo, o acionamento do sistema Bacen Jud e a expedição de ofícios aos registros públicos de bens para que informem se há patrimônio em nome do devedor”. Precedentes citados: REsp 1.184.765-PA, *DJe* 03.12.2010 (Repetitivo); AgRg no Ag 1.164.948-SP, *DJe* 02.02.2011, e AgRg no Ag 1.429.330-BA, *DJe* 03.09.2012.

AgRg no REsp 1.329.012-SC, j. 13.11.2012, rel. Min. Benedito Gonçalves.

H) PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA

- **Direito tributário. Mandado de segurança. Interrupção e suspensão do prazo prescricional.**

O ajuizamento de mandado de segurança interrompe e suspende o fluxo do prazo prescricional de ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, somente se reiniciando após o trânsito em julgado do *mandamus*. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.344.634-GO, *DJe* 17.03.2011, e AgRg no REsp 1.161.472-SC, *DJe* 29.11.2010.

AgRg no REsp 1.294.191-GO, j. 13.11.2012, rel. Min. Diva Malerba (Desembargadora convocada do TRF da 3.ª Região).

I) FRAUDE FISCAL

- **Direito tributário. Fraude à execução. Execução fiscal.**

Não se aplica a Súmula 375/STJ em execução fiscal de crédito de natureza

tributária. Dispõe a Súmula 375/STJ que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O art. 185 do CTN, seja em sua redação original seja na redação dada pela LC 118/2005, presume a ocorrência de fraude à execução quando, no primeiro caso, a alienação se dá após a citação do devedor na execução fiscal e, no segundo caso (após a LC 118/2005), quando a alienação é posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa. Precedente citado: REsp 1.141.990-PR (Repetitivo), DJe 19.11.2010.

AgRg no REsp 1.341.624-SC, j. 06.11.2012, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.

J) SIMPLES NACIONAL

• **Direito tributário. Regime tributário do simples. Impossibilidade de inclusão da TCFA.**

Não é possível a inclusão da TCFA no regime tributário do Simples. A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei 6.938/1981 e alterada pela Lei 10.165/2000, decorre da fiscalização de atividades poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, ou seja, remunera o exercício do poder de polícia exercido pelo Ibama. O Sistema Integrado de Recolhimento de Tributos (Simples) engloba o recolhimento exclusivo de tributos e contribuições expressamente elencados na Lei 9.317/1996 [Revogada pela LC 123/2006] e LC 123/2006, não sendo possível abranger, por ausência de previsão legal, a TCFA. Precedentes citados do STF: RE 416.601-DF, DJ 30.09.2005; do STJ: AgRg no Ag 1.419.767-MG, DJe 1.º.08.2012, e REsp 695.368-RJ, DJ 11.04.2005.

REsp 1.242.940-PR, j. 23.10.2012, rel. Min. Benedito Gonçalves.

BIBLIOGRAFIA

- ABRÃO, Carlos Henrique. *Lei de execução fiscal comentada e anotada*. 2. ed. São Paulo: RT, 1997.
- ALVIM, J. E. Carreira. *Nova execução de título extrajudicial*. Curitiba: Juruá, 2007.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *O novo processo civil brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015
- CHIMENTI, Ricardo Cunha. *Teoria e prática dos Juizados Especiais Cíveis estaduais e federais*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
- CUNHA, Leonardo José Carneiro da. *A Fazenda Pública em juízo*. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2007.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria geral do novo processo civil*. 4. ed. São Paulo: Malheiros.
- FERES, Carlos Roberto. *Antecipação da tutela jurisdicional*. São Paulo: Saraiva, 1999.
- MACHADO, Hugo de Brito. *Mandado de segurança em matéria tributária*. São Paulo: RT, 1994.
- MENDES, Gilmar Ferreira. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- NOLASCO, Rita Dias. *Exceção de pré-executividade*. São Paulo: Método, 2009.
- _____. *Execução fiscal à luz da jurisprudência: Lei 6.830/1980 comentada artigo por artigo: de acordo com o Novo CPC*. São Paulo: RT, 2015.
- PAULSEN, Leandro. *Direito processual tributário*. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.